



Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias



Instituto de
Estudios Fiscales

OCDE



JULIO 2010

Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias

22 DE JULIO DE 2010



ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS

La OCDE es un foro único en el que las Administraciones trabajan conjuntamente con el fin de afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la globalización. La OCDE también constituye la vanguardia de los esfuerzos realizados para comprender los avances y ayudar a las Administraciones a responder ante las nuevas áreas de interés como la regulación de las sociedades, la economía de la información y los retos de una población que envejece. La Organización proporciona un marco en el que las Administraciones pueden comparar sus experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar las prácticas correctas y trabajar en la coordinación de las políticas nacionales e internacionales.

Los Estados miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. La Comisión Europea participa en los trabajos de la OCDE.

Ediciones OCDE difunde los resultados de las recopilaciones estadísticas de la Organización y las investigaciones en materia económica, social y medioambiental, así como las convenciones, pautas y normalizaciones acordadas por sus miembros.

Obra publicada originalmente por la OCDE en inglés y francés con los títulos:

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

Principes de l'OCDE applicable en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

©2010, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Centre for Tax Policy and Administration (CTPA)

OECD PUBLISHING, 2, rue André-Pascal 75775 PARIS CEDEX 16. France
ISBN 978-92-64-09033-0

©2011, Instituto de Estudios Fiscales (IEF) para la edición española.

Obra publicada por acuerdo con la OCDE, París. El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) es responsable de la calidad de la edición española y de su coherencia con el texto original. En caso de discrepancias prevalecerá la edición en lengua inglesa.

ISBN 978-84-8008-336-2 NIPO: 602-11-030-6

D.L.:..... Printed by Publidisa

Traducción al español patrocinada por la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos en el marco del convenio de colaboración con la OCDE.

Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid. España.

Fe de erratas a las publicaciones de la OCDE accesibles en línea: www.oecd.org/publishign/corrigenda.

© OCDE 2010

Puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso, y puede incluir extractos de las publicaciones, bases de datos y productos multimedia de la OCDE en sus propios documentos, presentaciones, blogs, ciber sitios y materiales didácticos, siempre que incluya el debido reconocimiento a la OCDE como fuente y la cite como propietaria de los derechos de autor. Las solicitudes para su uso comercial o relativas a los derechos sobre su traducción deben remitirse a rights@oecd.org. Puede obtenerse permiso para fotocopiar parcialmente este material con el fin de darle un uso público o comercial a través del *Copyright Clearance Center (CCC)* en info@copyright.com o del *Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC)* en contact@cfcopies.com.

PREFACIO

Estas Directrices constituyen la revisión del Informe de la OCDE "Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales" (1979). El Comité de Asuntos Fiscales las aprobó el 27 de junio de 1995 y el Consejo de la OCDE decidió su publicación el 13 de julio de 1995.

Desde su primera versión, estas Directrices se han complementado:

- Con el Informe sobre derechos intangibles y servicios, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 23 de enero de 1996 [DAFFE/CFA(96)2], adoptado por el Consejo el 11 de abril 1996 [C(96)46], incorporado en los Capítulos VI y VII;
- Con el informe sobre los acuerdos de reparto de costes aprobado por el comité de Asuntos Fiscales el 25 de junio de 1997 [DAFFE/CFA(97)27], adoptado por el Consejo el 24 de julio de 1997 [C(97)144], incorporado en el Capítulo VIII;
- Con el informe sobre las líneas rectoras de los procedimientos de seguimiento de la aplicación de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y la implicación del mundo empresarial [DAFFE/CFA/WD(97)11/REV1], aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 24 de junio de 1997, adoptado por el Consejo el 28 de octubre de 1999 [C(99)138], incorporado en los anexos;
- Con el informe sobre los principios para la conclusión de acuerdos previos en materia de precios de transferencia en el marco de procedimientos amistosos, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 30 de junio de 1999 [DAFFE/CFA (99)31], adoptado por el Consejo el 28 de octubre de 1999 [C(99)138], incorporado en los anexos;
- Con el informe sobre cuestiones de precios de transferencia en la reestructuración de empresas, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 [CTPA/CFA(2010)46] y aprobado por el Consejo el 22 de julio de 2010 [Anexo I al documento C(2010)99], incorporado al Capítulo IX.

Asimismo, estas Directrices se han modificado:

- Mediante la actualización del Capítulo IV, aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 6 de junio de 2008 [CTPA/CFA(2008)30/REV1] y las actualizaciones del prefacio y el prólogo aprobadas por el Comité de

Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2009 [CTPA/CFA(2009)51/REV1] y por el Consejo el 16 de julio de 2009 [C(2009)88];

- Mediante la revisión de los Capítulos I a III aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 [CTPA/CFA(2010)55] y por el Consejo el 22 de julio de 2010 [Anexo I al documento C(2010)99]; y
- Mediante la actualización del prefacio, prólogo, glosario, de los Capítulos IV a VIII y de los anexos, aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 [CTPA/CFA(2010)47], y por el Consejo el 22 de julio de 2010 [Anexo I al documento C(2010)99].

Estas Directrices seguirán completándose con pautas adicionales referidas a otros aspectos de los precios de transferencia y se examinarán periódicamente en un proceso continuo de revisión.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Prólogo.....	22
Glosario.....	30

Capítulo I

El principio de plena competencia

A. Introducción.....	42
B. Declaración del principio de plena competencia	44
B.1 Artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE	44
B.2 Mantenimiento del consenso internacional en torno al principio de plena competencia	47
C. Un enfoque que no se apoya en el principio de plena competencia: el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida	48
C.1 Antecedentes y descripción del método	48
C.2 Comparación con el principio de plena competencia.....	49
C.3 Rechazo de los métodos no basados en el principio de plena competencia.....	53
D. Guía para la aplicación del principio de plena competencia.....	54
D.1 Análisis de comparabilidad	54
D.1.1 Importancia del análisis de comparabilidad y significado del término “comparable”	54
D.1.2 Los factores determinantes de la comparabilidad	56
D.1.2.1 Características de los bienes o de los servicios.....	56
D.1.2.2 Análisis funcional	58
D.1.2.3 Cláusulas contractuales.....	61
D.1.2.4 Circunstancias económicas	61
D.1.2.5 Estrategias empresariales.....	63

D.2 Aceptación de las operaciones realmente efectuadas.....	65
D.3 Pérdidas.....	67
D.4 Efectos de las decisiones de los poderes públicos.....	69
D.5 Utilización del valor de aduana.....	71

Capítulo II

Metodología para la determinación de los precios de transferencia

<i>Parte I: Selección del método de determinación de los precios de transferencia</i>	<i>74</i>
A. Selección del método de determinación de precios de transferencia más adecuado a las circunstancias del caso.....	74
B. Utilización de más de un método.....	77
<i>Parte II: Métodos tradicionales basados en las operaciones.....</i>	<i>78</i>
A. Introducción.....	78
B. Método del precio libre comparable	78
B.1 Términos generales	78
B.2 Ejemplos de aplicación del método del precio libre comparable.....	79
C. Método del precio de reventa.....	80
C.1 Términos generales	80
C.2 Ejemplos de aplicación del método del precio de reventa	86
D. Método del coste incrementado	87
D.1 Términos generales	87
D.2 Ejemplos de aplicación del método del coste incrementado.....	92
<i>Parte III: Métodos basados en el resultado de las operaciones.....</i>	<i>94</i>
A. Introducción.....	94
B. Método del margen neto operacional.....	94

B.1. Términos generales	94
B.2 Ventajas e inconvenientes	96
B.3 Orientaciones para la aplicación	98
B.3.1 Estándar de comparabilidad aplicable al método del margen neto operacional	98
B.3.2 Selección del indicador de beneficio neto	101
B.3.3 Determinación del beneficio neto.....	102
B.3.4 Ponderación del beneficio neto	104
B.3.4.1 Casos en los que el beneficio neto se pondera tomando las ventas como referencia	105
B.3.4.2 Casos en los que el beneficio neto se pondera tomando los costes como referencia	106
B.3.4.3 Casos en los que el beneficio neto se pondera tomando los activos como referencia	108
B.3.4.4 Otros indicadores posibles de beneficio neto	109
B.3.5 Ratio Berry	109
B.3.6 Otras pautas	110
B.4 Ejemplos de la aplicación del método del margen neto operacional	111
C. Método de la distribución del resultado	112
C.1. Términos generales	112
C.2 Ventajas e inconvenientes	113
C.3 Orientaciones para la aplicación	115
C.3.1 Términos generales.....	115
C.3.2 Criterios diversos para la distribución de resultados	116
C.3.2.1 Análisis de aportaciones	116
C.3.2.2 Análisis residual	117
C.3.3 Determinación de los resultados conjuntos objeto de distribución	118

C.3.3.1 Resultados reales o previstos	119
C.3.3.2 Diferentes medidas del resultado	120
C.3.4 Cómo distribuir los resultados conjuntos	121
C.3.4.1 Términos generales	121
C.3.4.2 Utilización de los datos extraídos de operaciones no vinculadas comparables	121
C.3.4.3 Claves de atribución	122
C.3.4.4 Utilización de datos procedentes de las operaciones del contribuyente (“datos internos”).....	124
D. Conclusiones sobre los métodos basados en el resultado de las operaciones	126

Capítulo III

Análisis de comparabilidad

A. Desarrollo de un análisis de comparabilidad.....	128
A.1 Proceso “tipo”	129
A.2 Análisis del conjunto de las circunstancias del contribuyente	130
A.3 Análisis de la operación vinculada y selección de la parte objeto de análisis.....	131
A.3.1 Evaluación de operaciones separadas y combinadas	131
A.3.2 Compensaciones intencionadas.....	133
A.3.3 Selección de la parte objeto de análisis	134
A.3.4 Información sobre la operación vinculada	135
A.4 Operaciones no vinculadas comparables.....	137
A.4.1 Términos generales	137
A.4.2 Comparables internos.....	137
A.4.3 Comparables externos y fuentes de información	138
A.4.3.1 Bases de datos.....	138
A.4.3.2 Comparables de fuente extranjera o no nacionales.....	140

A.4.3.3 Información no comunicada a los contribuyentes	140
A.4.4 Utilización de datos agregados de terceros	140
A.4.5 Limitaciones en la disponibilidad de los comparables	141
A.5 Selección o rechazo de comparables potenciales	142
A.6 Ajustes de comparabilidad	144
A.6.1 Distintos tipos de ajustes de comparabilidad	145
A.6.2 Objeto de los ajustes de comparabilidad	145
A.6.3 Fiabilidad del ajuste realizado	146
A.6.4 Documentación y prueba de los ajustes de comparabilidad	146
A.7 El rango de plena competencia	146
A.7.1 Aspectos generales	146
A.7.2 Selección del punto más apropiado del rango	148
A.7.3 Resultados extremos: problemas de comparabilidad	148
B. Marco temporal y comparabilidad	149
B.1 Fecha de origen	150
B.2 Fecha de recopilación	150
B.3 Valoración inicial incierta y acontecimientos imprevisibles	151
B.4 Datos relativos a ejercicios posteriores al de la operación	152
B.5 Datos de varios años	152
C. Cuestiones de cumplimiento	153

Capítulo IV

Procedimientos administrativos destinados a evitar y resolver las controversias en materia de precios de transferencia

A. Introducción	156
B. Prácticas para la aplicación del régimen de precios de transferencia	157
B.1 Prácticas en materia de inspección	159

B.2 Carga de la prueba.....	160
B.3 Sanciones	163
C. El ajuste correlativo y el procedimiento amistoso: artículos 9 y 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE	166
C.1 El procedimiento amistoso	166
C.2 El ajuste correlativo: párrafo 2 del artículo 9.....	168
C.3 Preocupaciones suscitadas por estos procedimientos.....	171
C.4 Recomendaciones para solucionar los problemas	172
C.4.1 Plazos de prescripción	172
C.4.2 Duración de los procedimientos amistosos	175
C.4.3 Participación del contribuyente	176
C.4.4 Publicación de los procedimientos aplicables	177
C.4.5 Problemas relativos a la recaudación derivada de la regularización de la cuota tributaria y del devengo de intereses	178
C.5 Ajustes secundarios	179
D. Inspecciones tributarias simultáneas	183
D.1 Definición y antecedentes	183
D.2 Fundamento jurídico de las inspecciones tributarias simultáneas.....	184
D.3 Inspecciones tributarias simultáneas y precios de transferencia	185
D.4 Recomendación relativa a la utilización de inspecciones tributarias simultáneas.....	188
E. Régimen de protección (safe harbours)	188
E.1 Introducción	188
E.2 Definición y concepto de los regímenes de protección.....	189
E.3 Factores a favor de la utilización de los regímenes de protección	190
E.3.1 Simplificación del cumplimiento con las obligaciones tributarias	190
E.3.2 Certidumbre	191

E.3.3 Simplificación administrativa.....	191
E.4 Problemas que plantea la utilización de regímenes de protección	191
E.4.1 Riesgo de doble imposición y dificultades en el procedimiento amistoso	193
E.4.2 Posibilidad de favorecer la planificación fiscal	196
E.4.3 Cuestiones de equidad y de uniformidad.....	197
E.5 Recomendaciones para la utilización del régimen de protección.....	197
F. Acuerdos previos sobre valoración de precios de transferencia	199
F.1 Definición y concepto de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia	199
F.2 Criterios posibles para la redacción de normas jurídicas y administrativas reguladoras de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia..	204
F.3 Ventajas de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia.....	205
F.4 Inconvenientes de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia	207
F.5 Recomendaciones.....	211
F.5.1 De índole general.....	211
F.5.2 Ámbito de aplicación de un acuerdo.....	211
F.5.3 Acuerdos unilaterales versus bilaterales (multilaterales).....	211
F.5.4 Ecuanimidad en el acceso de los contribuyentes a los APV	212
F.5.5 Adopción de acuerdos de trabajo entre autoridades competentes relativos a los APV y a la mejora de procedimientos	212
G. Arbitraje	213

Capítulo V

Documentación

A. Introducción	216
B. Criterios sobre normas y procedimientos de documentación.....	217

C. Información útil para determinar los precios de transferencia	221
D. Resumen de las recomendaciones sobre documentación	224

Capítulo VI

Consideraciones específicas aplicables a los activos intangibles

A. Introducción	226
B. Intangibles comerciales	227
B.1 Términos generales	227
B.2 Ejemplos: patentes y marcas comerciales	229
C. Aplicación del principio de plena competencia.....	231
C.1 Términos generales	231
C.2 Identificación de los acuerdos alcanzados para la transmisión de activos intangibles	232
C.3 Cálculo de una contraprestación de plena competencia.....	234
C.4 Determinación del precio de plena competencia cuando la valoración es muy incierta en el momento de la operación.....	237
D. Actividades de comercialización realizadas por empresas que no son propietarias de una marca comercial o de un nombre comercial	239

Capítulo VII

Cuestiones de aplicación específica a los servicios intragrupo

A. Introducción	242
B. Principales problemas	243
B.1 Concreción de los servicios intragrupo prestados	243
B.2 Determinación de la retribución de plena competencia	248
B.2.1 Términos generales.....	248
B.2.2 Identificación de los acuerdos efectivos para la remuneración de los servicios intragrupo.....	248

B.2.3 Cálculo de la contraprestación de plena competencia	251
C. Algunos ejemplos de servicios intragrupo	254

Capítulo VIII

Acuerdos de reparto de costes

A. Introducción	258
B. Concepto de ARC.....	259
B.1 Términos generales	259
B.2 Relación con otros capítulos	260
B.3 Tipos de ARC.....	260
C. Aplicación del principio de plena competencia	261
C.1 Términos generales	261
C.2 Determinación de los participantes	262
C.3 Importe de la aportación de cada participante.....	263
C.4 Determinación de la corrección del reparto	264
C.5 Tratamiento fiscal de las aportaciones y de los pagos compensatorios	266
D. Consecuencias fiscales de la no conformidad de un ARC con el principio de plena competencia.	267
D.1 Ajuste de las aportaciones.....	268
D.2 Decisión de ignorar todo o parte de un ARC	268
E. ARC: adhesión, retirada o rescisión	269
F. Recomendaciones para la estructuración y la documentación de los ARC	272

Capítulo IX

Reestructuración de empresas y precios de transferencia

<i>Introducción</i>	276
A. Ámbito	276

A.1 Reestructuraciones empresariales comprendidas en el ámbito de este capítulo .	276
A.2 Cuestiones comprendidas en el ámbito de este capítulo	278
B. Aplicación del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y de estas Directrices a las reestructuraciones de empresas: marco teórico	279
<i>Parte I: Consideraciones específicas en materia de riesgo</i>	<i>280</i>
A. Introducción	280
B. Términos contractuales	280
B.1 Determinación de si la forma en la que se conducen las empresas asociadas responde a la atribución de riesgos determinada mediante contrato	281
B.2 Determinación de si la atribución de los riesgos en una operación vinculada es conforme con el principio de plena competencia	283
B.2.1 El papel que desempeñan los comparables	283
B.2.2 Casos en los que no pueden encontrarse comparables	283
B.2.2.1 Atribución del riesgo y control	284
B.2.2.2 Capacidad financiera para asumir el riesgo	287
B.2.2.3 Ejemplo.....	288
B.2.3 Diferencia entre practicar un ajuste de comparabilidad y el rechazo de la atribución de los riesgos efectuada en el marco de una operación vinculada	289
B.3 ¿Cuáles son las consecuencias de la atribución de riesgos?.....	291
B.3.1 Consecuencias de una atribución de riesgos admitida a efectos fiscales...	291
B.3.2 ¿Puede generar un entorno de bajo riesgo la utilización de un método concreto de determinación de precios de4 transferencia?	292
C. Cuestiones de cumplimiento	293
<i>Parte II: Compensación de plena competencia por la propia reestructuración</i>	<i>294</i>
A. Introducción	294

B. Comprender la propia reestructuración	294
B.1 Identificación de las operaciones de reestructuración: funciones, activos y riesgos previos y posteriores a la reestructuración.....	295
B.2 Comprensión de las razones empresariales para a la reestructuración y de los beneficios que se espera obtener de ella, incluido el papel de las sinergias.....	296
B.3 Otras opciones disponibles de modo realista	297
C. Redistribución del beneficio potencial como consecuencia de la reestructuración empresarial.	299
C.1 Beneficio potencial	299
C.2 Redistribución de los riesgos y del beneficio potencial	300
D. Transferencia de un elemento de valor (por ejemplo un activo o una actividad en desarrollo)	303
D.1 Activos tangibles.....	303
D.2 Activos intangibles.....	306
D.2.1 Transferencia de activos intangibles efectuada por una entidad local a una entidad central (empresa asociada extranjera).....	307
D.2.2 Transferencia de activos intangibles en el momento en el que aun no se ha determinado su valor.....	309
D.2.3 Activos intangibles locales.....	310
D.2.4 Derechos contractuales.....	310
D.3 Transferencia de una actividad (negocio en funcionamiento).....	311
D.3.1 Valoración de una transferencia de actividad	311
D.3.2 Actividades deficitarias	312
D.4 Externalización.....	313
E. Indemnización de la entidad reestructurada por la terminación o renegociación sustancial de los acuerdos existentes.....	314

E.1. ¿Se ha formalizado por escrito el contrato finalizado, no renovado o sustancialmente renegociado? ¿Se ha previsto una cláusula de indemnización?	316
E.2. ¿Son de plena competencia los términos del acuerdo y la existencia o no de una cláusula de indemnización u otro tipo de garantía (así como los términos de dicha cláusula, cuando exista)?	316
E.3 ¿Amparan el derecho mercantil o la jurisprudencia el derecho a recibir la indemnización?	319
E.4 En condiciones de plena competencia ¿hubiera estado una de las partes dispuesta a indemnizar a la que sufre la finalización del contrato o su renegociación?.....	321
<i>Parte III: Remuneración de las operaciones vinculadas ulteriores a la reestructuración.....</i>	322
A. Reestructuraciones frente a “estructuración” empresarial	322
A.1 Regla general: aplicación uniforme del principio de plena competencia.....	322
A.2 Posibles diferencias factuales entre las situaciones que resultan de una reestructuración y las que se estructuran como tal desde el principio.....	323
B. Aplicación a situaciones de reestructuraciones de empresa: selección y aplicación de un método de determinación de precios de transferencia a las operaciones vinculadas posteriores a una reestructuración	325
C. Relación entre la indemnización por la reestructuración y la compensación de las operaciones que siguen a la reestructuración	328
D. Comparación de las situaciones que preceden y siguen a la reestructuración	329
E. Economías de localización.....	331
F. Ejemplo: implantación de una función centralizada de compras.....	333
<i>Parte IV: Aceptación de las operaciones realmente efectuadas.....</i>	337
A. Introducción	337

B. Operaciones realmente efectuadas. El papel que desempeñan los términos contractuales. Relación entre los párrafos 1.64 a 1.69 y otras partes de estas Directrices	338
C. Aplicación de los párrafos 1.64 a 1.69 de estas Directrices a las reestructuraciones de empresas	339
C.1 El rechazo de una operación se limita a casos excepcionales	339
C.2 Determinación de la sustancia económica de una operación o de un acuerdo	340
C.3 ¿Hubieran llegado al mismo acuerdo partes independientes?	341
C.4 Constatación de si para una operación o acuerdo hay una solución basada en los precios de transferencia	343
C.5 Importancia de la motivación fiscal	344
C.6 Consecuencias del rechazo por aplicación de los párrafos 1.64 a 1.69.....	344
D. Ejemplos	346
D.1 Ejemplo (A): conversión de un distribuidor “pleno” en un distribuidor “sin riesgo”	346
D.2 Ejemplo (B): transferencia de intangibles de valor a sociedades instrumentales	347
D.3 Ejemplo (C): aceptación de la transferencia de un intangible.....	348

<i>Listado de Anexos</i>	350
<i>Anexo a las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia:</i> Líneas rectoras de los procedimientos de seguimiento de la aplicación de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y la implicación del mundo empresarial	352
<i>Anexo I al Capítulo II:</i> Sensibilidad de los indicadores de beneficios brutos y netos	360
<i>Anexo II al Capítulo II:</i> Ejemplo ilustrativo de la aplicación del método de distribución del resultado residual	368
<i>Anexo III al Capítulo II:</i> Ejemplo de las distintas medidas del resultado cuando se aplica un método de la distribución del resultado	374
<i>Anexo al Capítulo III:</i> Ejemplo de ajuste del capital circulante	380
<i>Anexo al Capítulo IV:</i> Líneas rectoras de los Acuerdos Previos de Valoración de Precios de Transferencia en el marco de los procedimientos amistosos (APV PA) ...	386
<i>Anexo al Capítulo VI:</i> Ejemplos ilustrativos de la aplicación de las directrices sobre precios de transferencia a activos intangibles de valoración muy incierta	419
<i>Apéndice:</i> Recomendación del Consejo sobre la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas [C(95)126/FINAL]	423

Prólogo

1. El papel de las empresas multinacionales en el comercio mundial se ha incrementado espectacularmente durante los últimos veinte años. Esto refleja en parte la mayor integración de las economías nacionales y el progreso tecnológico, particularmente en el ámbito de las comunicaciones. El crecimiento de las empresas multinacionales plantea cuestiones fiscales cada vez más complejas tanto para las administraciones tributarias como para las propias empresas multinacionales, ya que no se puede considerar aisladamente la normativa fiscal aplicable a las empresas multinacionales en cada país, sino que debe abordarse en un contexto internacional amplio.
2. Estas cuestiones surgen, en primer lugar, de la dificultad práctica a la que se enfrentan tanto las empresas multinacionales como las administraciones tributarias al determinar la renta y los gastos que deben considerarse en una jurisdicción, correspondientes a una sociedad o un establecimiento permanente que forma parte de un grupo multinacional, y especialmente cuando las operaciones del grupo multinacional están muy integradas.
3. En el caso de las empresas multinacionales, la necesidad de cumplir con requisitos legales y administrativos que puedan diferir de un país a otro genera problemas adicionales. Esta diversidad de requisitos puede incrementar la carga de cumplimiento para las empresas multinacionales e implicar costes más elevados que aquellos en los que incurriría una empresa similar que operase únicamente en una única jurisdicción fiscal.
4. En el caso de las administraciones tributarias, los problemas se plantean tanto a nivel normativo como práctico. En el ámbito normativo, los países tienen que compatibilizar sus derechos legítimos de gravar los beneficios de un contribuyente en función de la renta y los gastos que puedan considerarse obtenidos en su territorio, con la necesidad de evitar la tributación de esa misma renta en más de una jurisdicción tributaria. Esta tributación doble o múltiple puede obstaculizar las operaciones con bienes y servicios y los movimientos transfronterizos de capitales. En la práctica, la atribución de tales rentas y gastos por parte de un país puede verse entorpecida por las dificultades para obtener los datos necesarios que estén fuera de su propia jurisdicción.

5. En principio, las potestades tributarias reivindicadas por cada país dependen de si utiliza un sistema de imposición basado en la residencia, en la fuente o en ambos. En un sistema fiscal basado en la residencia, el país incluirá en su base imponible toda o parte de la renta de cualquier persona (incluyendo personas jurídicas) a la que considere residente en su jurisdicción, comprendida la renta procedente de fuentes extranjeras. En un sistema fiscal basado en la fuente, el país incluirá en su base imponible las rentas obtenidas dentro de su jurisdicción, con independencia de la residencia del contribuyente. Al aplicar estos dos criterios a las empresas multinacionales, frecuentemente de forma conjunta, se suele considerar a cada empresa del grupo multinacional como una entidad independiente. Los países miembros de la OCDE han elegido este criterio de la entidad independiente como el medio más adecuado para llegar a unos resultados equitativos y minimizar el riesgo de no eliminar la doble imposición. De esta manera, cada miembro individual del grupo está sujeto a imposición por la renta que obtiene (según el criterio de residencia o de fuente).

6. Con el fin de aplicar el criterio de la entidad independiente a las operaciones intragrupo, el impuesto debe aplicarse a cada miembro del grupo individualmente, partiendo de la base de que, en sus operaciones con los restantes miembros, actúa de acuerdo con el principio de plena competencia. Sin embargo, las relaciones entre los miembros de un grupo multinacional pueden permitirles establecer condiciones especiales en sus relaciones intragrupo que difieran de aquellas que se hubieran acordado en caso de haber actuado como empresas independientes en el mercado libre. A fin de asegurar la aplicación correcta del criterio de la entidad independiente, los países miembros de la OCDE han optado por el principio de plena competencia, en virtud del que se debe eliminar el efecto provocado por condiciones especiales sobre el nivel de beneficios.

7. Los países miembros de la OCDE han optado por estos principios de fiscalidad internacional con el doble objetivo de asegurar el impuesto correcto en cada jurisdicción y de evitar la doble imposición, reduciendo así los conflictos entre administraciones tributarias y promoviendo el comercio y la inversión internacionales. En una economía global, la coordinación entre los países tiene más posibilidades de lograr estos objetivos que la competencia fiscal. La OCDE, en su misión de contribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, y de conseguir el crecimiento económico sostenible más elevado posible para sus miembros, trabaja constantemente con el fin de consensuar los principios de la fiscalidad internacional y evitar así respuestas unilaterales a problemas multilaterales.

8. Estos principios relativos a la tributación de las multinacionales están incluidos en el Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE (Modelo de Convenio Tributario de la OCDE), que constituye la base de la extensa red de convenios fiscales bilaterales entre países miembros de la OCDE y entre países miembros y no miembros. Estos principios también se han incorporado al Convenio Modelo de las Naciones Unidas sobre Doble Imposición entre Países desarrollados y Países en desarrollo.

9. Los principales mecanismos para resolver las cuestiones que surgen en la aplicación de los principios de la fiscalidad internacional a las multinacionales están contenidos en estos convenios bilaterales. Los artículos que afectan principalmente a la tributación de las empresas multinacionales son: el artículo 4, que define la residencia; los artículos 5 y 7, que determinan la tributación de los establecimientos permanentes; el artículo 9, que se refiere a la tributación de los beneficios de las empresas asociadas y aplica el principio de plena competencia; los artículos 10, 11 y 12, que determinan la tributación de dividendos, intereses y cánones, respectivamente; y los artículos 24, 25 y 26, que contienen disposiciones especiales relativas a la no discriminación, a la resolución de controversias y al intercambio de información.

10. El Comité de Asuntos Fiscales, que es el órgano principal de la OCDE en materia de política fiscal, ha elaborado numerosos informes relativos a la aplicación de estos artículos a las empresas multinacionales y a otras empresas. El Comité ha fomentado la aceptación de una interpretación común de estos artículos para reducir el riesgo de una tributación inapropiada, proporcionando así los medios adecuados para resolver los problemas que surgen por la interacción de las leyes y las prácticas de los diferentes países.

11. En la aplicación de estos principios a las multinacionales, una de las cuestiones más difíciles que se han planteado es la determinación de unos precios de transferencia que resulten apropiados a efectos fiscales. Los precios de transferencia son los precios a los que una empresa transmite bienes materiales y activos intangibles, o presta servicios, a empresas asociadas. A los efectos de estas Directrices, una "empresa asociada" es una empresa que cumple las condiciones determinadas en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b) del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Conforme a estas condiciones, dos empresas están asociadas si una de ellas participa directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de la otra; o si "las mismas personas participan directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital" de ambas empresas (es decir, si ambas empresas están sometidas a un control común). Las cuestiones abordadas en estas Directrices

se plantean igualmente en el contexto de los establecimientos permanentes, como se analiza en el *Informe sobre la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes*, aprobado por el Consejo de la OCDE en julio de 2008, que sustituye al Informe de la OECD *Modelo de Convenio Tributario: Atribución de rentas a establecimientos permanentes* (1994). También pueden encontrarse indicaciones útiles en el Informe de la OCDE *Elusión y Evasión Fiscal Internacional* (1987).

12. Los precios de transferencia son significativos tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias, porque determinan en gran medida la distribución de la renta y los gastos y, por tanto, de los beneficios gravables de las empresas asociadas situadas en diferentes jurisdicciones fiscales. Las cuestiones relativas a los precios de transferencia surgieron originalmente en las relaciones entre empresas asociadas que actuaban dentro de la misma jurisdicción fiscal. Estas Directrices no consideran cuestiones de naturaleza interna, sino que se centran en los aspectos internacionales de los precios de transferencia. Estos aspectos internacionales son más difíciles de tratar porque involucran a más de una jurisdicción tributaria y, en consecuencia, cualquier ajuste de los precios de transferencia en una jurisdicción implica la necesidad de practicar un ajuste correlativo en otra jurisdicción. Sin embargo, si la otra jurisdicción no está de acuerdo en realizar este ajuste correlativo, el grupo multinacional tributará dos veces por esa parte de sus beneficios. Con el objeto de reducir los riesgos de esta doble imposición, es necesario un consenso internacional acerca de cómo determinar, a efectos fiscales, los precios de transferencia de las operaciones transfronterizas.

13. Estas Directrices pretenden ser una revisión y una compilación de anteriores informes del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE referidos a precios de transferencia y otras cuestiones fiscales conexas en relación con las empresas multinacionales. El informe principal es *"Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales"* (1979) (el "Informe de 1979"), que el Consejo de la OCDE derogó en 1995. Otros informes se refieren a cuestiones sobre precios de transferencia en contextos específicos. Estos informes son *"Precios de Transferencia y Empresas Multinacionales. Tres Cuestiones Fiscales"* (1984) (el "Informe de 1984") y *"Subcapitalización"* (el "Informe de 1987").

14. Estas Directrices también reflejan la discusión iniciada en la OCDE respecto de la propuesta de regulación de precios de transferencia en los Estados Unidos [véase el Informe de la OCDE *"Aspectos Fiscales de Precios de Transferencia en Empresas Multinacionales: la Propuesta de Regulación de los EE.UU."* (1993)]. Sin embargo, el contexto en que dicho Informe fue escrito era muy diferente de aquel en el que se han acometido

estas Directrices; su ámbito era mucho más limitado y se dirigía específicamente a la propuesta de regulación de los EE.UU.

15. Los países miembros de la OCDE continúan adoptando el principio de plena competencia tal y como está recogido en el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE (y en los convenios bilaterales que vinculan legalmente a sus signatarios) y en el Informe de 1979. Estas Directrices se centran en la aplicación del principio de plena competencia para valorar los precios de transferencia de empresas asociadas. Las Directrices pretenden ayudar a las administraciones tributarias (tanto de los países miembros de la OCDE como de los países no miembros) y a las empresas multinacionales, mostrándoles vías para encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes en materia de precios de transferencia, reduciendo así los conflictos entre administraciones tributaria, y entre estas y las empresas multinacionales, y evitando costosos litigios. Estas Directrices analizan los métodos para valorar si las condiciones de las relaciones comerciales y financieras dentro de una multinacional satisfacen el principio de plena competencia, y estudian la aplicación práctica de estos métodos. También se incluye un estudio del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida.

16. Se insta a los países miembros de la OCDE a que sigan estas Directrices en sus prácticas internas sobre precios de transferencia, y a los contribuyentes a que las sigan al valorar, a efectos fiscales, si sus precios de transferencia satisfacen el principio de plena competencia. Se invita a las administraciones tributarias a que tengan en cuenta el criterio comercial del contribuyente al proceder a la comprobación de la aplicación del principio de plena competencia, y a desarrollar sus análisis de precios de transferencia desde esta perspectiva.

17. Estas Directrices también pretenden, en primer lugar, regir la resolución de los casos de precios de transferencia planteados en el marco de procedimientos amistosos entre países miembros de la OCDE y, cuando resulte apropiado, de los procedimientos seguidos en aplicación del convenio de arbitraje. También se ofrecen criterios para los casos en los que es necesario practicar un ajuste correlativo. El Comentario al apartado 2 del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE establece claramente que el Estado al que se requiere un ajuste correlativo debe cumplir con esta solicitud sólo si "considera que la cifra de beneficios rectificadas refleja correctamente la que se habría obtenido si las operaciones se hubiesen realizado en condiciones de total independencia". Esto significa que, en el procedimiento ante la autoridad competente, el Estado que ha propuesto el primer ajuste soporta la carga de demostrar al otro Estado que el ajuste "está justificado, tanto en sí mismo como en su importe". Se espera de

ambas autoridades competentes que resuelvan el procedimiento amistoso con espíritu cooperativo.

18. Con el objeto de lograr un equilibrio entre los intereses de los contribuyentes y de las administraciones tributarias que resulte equitativo para todas las partes, es necesario considerar todos los aspectos relevantes en cada supuesto de precios de transferencia. Uno de estos aspectos es la atribución de la carga de la prueba. En la mayoría de las jurisdicciones es la administración tributaria quien soporta la carga de la prueba, lo cual exige que esta demuestre, como primer paso, que el precio determinado por el contribuyente no es conforme con el principio de plena competencia. Se debe advertir, sin embargo, que incluso en tal caso sería razonable que la administración tributaria siguiera pudiendo obligar al contribuyente a presentar su contabilidad, de forma que la administración pudiera analizar las operaciones vinculadas. En otras jurisdicciones puede ocurrir que los sujetos pasivos tengan que soportar la carga de la prueba en relación con ciertos aspectos. Algunos países miembros de la OCDE consideran que el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE establece reglas de carga de la prueba en casos de precios de transferencia que prevalecen sobre cualquier disposición interna en contrario. Sin embargo, otros países consideran que el artículo 9 no procede a tal determinación (véase el párrafo 4 de los Comentarios al artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE). Independientemente de quién soporte la carga de la prueba, es preciso evaluar la equidad de su atribución a la luz de otros elementos del sistema fiscal de cada jurisdicción que incidan sobre la aplicación de las normas sobre precios de transferencia, comprendida la resolución de controversias. Estos elementos incluirían sanciones, prácticas de inspección, procedimientos de recursos administrativos, normas relativas al pago de intereses respecto de los impuestos debidos y de las devoluciones tributarias, la obligación eventual de efectuar el pago del tributo correspondiente antes de recurrir un ajuste, las normas de prescripción y el grado en que las disposiciones aplicables se conocen previamente. No sería apropiado confiar en cualquiera de estos elementos, incluida la carga de la prueba, para realizar afirmaciones infundadas sobre precios de transferencia. Algunas de estas cuestiones se examinan con detenimiento en el Capítulo IV.

19. Estas Directrices se centran en las cuestiones de principios más importantes que surgen en materia de precios de transferencia. En 2010 se aprobó una revisión de los Capítulos I a III y un nuevo Capítulo IX, que reflejan el trabajo que ha llevado a cabo el Comité sobre comparabilidad, los métodos para el cálculo de los beneficios de las operaciones y sobre ciertas cuestiones relacionadas con los precios de transferencia en el contexto de la reestructuración de empresas. En el trabajo futuro se abordarán cuestiones

tales como la aplicación del principio de plena competencia a operaciones relativas a activos intangibles, servicios, acuerdos de reparto de costes, establecimientos permanentes y subcapitalización. El Comité se propone analizar regularmente la experiencia que adquieran los países miembros y no miembros seleccionados en la aplicación de los métodos elegidos para hacer valer el principio de plena competencia, centrándose especialmente en las dificultades que planteen los métodos basados en el resultado de las operaciones (como se definen en el Capítulo II) y en las soluciones por las que ha optado para su resolución.

Glosario

Acuerdo previo de valoración de precios de transferencia (“APV”)

Accord de fixation préalable de prix de transfert

Advance pricing arrangement (“APA”)

Un acuerdo de esta clase permite determinar un conjunto de criterios (en particular, la metodología, los comparables, los ajustes pertinentes y las hipótesis críticas referidas a hechos futuros), con carácter previo a la realización de las operaciones vinculadas, con el fin de determinar los precios de transferencia aplicables a esas operaciones durante un período concreto. Los acuerdos previos de valoración pueden ser unilaterales, cuando sólo interviene una administración tributaria y un contribuyente, o multilaterales cuando intervienen dos o más administraciones tributarias.

Acuerdo de reparto de costes (“ARC”)

Accord de répartition des coûts (“ARC”)

Cost contribution arrangement (“CCA”)

Un ARC es un marco establecido de común acuerdo entre empresas para distribuir los costes y los riesgos de desarrollo, producción u obtención de activos, servicios o derechos, y para determinar la naturaleza e importancia de los intereses de cada participante en los resultados de esa actividad de desarrollo, producción o de obtención de tales activos, servicios o derechos.

Actividad del accionista

Activité d’actionnaire

Shareholder activity

Actividad desempeñada por un miembro de un grupo multinacional (en general, la sociedad matriz o una sociedad de cartera –*holding*- de ámbito regional) por su mera participación en uno o varios miembros del grupo, es decir, en su calidad de accionista.

Ajuste compensatorio

Ajustement compensatoire

Compensating adjustment

Ajuste en el cual el contribuyente declara un precio de transferencia a efectos tributarios que, en su opinión, constituye un precio de plena

competencia en el marco de una operación vinculada, aunque dicho precio difiera del importe realmente cargado entre las empresas asociadas. Este ajuste se realiza antes de la presentación de la declaración.

Ajuste correlativo

Ajustement corrélatif

Corresponding adjustment

Ajuste de la deuda tributaria de la empresa asociada establecida en una segunda jurisdicción fiscal, practicado por la administración tributaria de esa jurisdicción tras el ajuste primario realizado por la administración tributaria de la primera jurisdicción, con el fin de distribuir coherentemente los beneficios entre los dos países.

Ajuste primario

Ajustement primaire

Primary adjustment

Ajuste de los beneficios imponibles de una sociedad realizado por una administración tributaria de una primera jurisdicción, en virtud de la aplicación del principio de plena competencia, a operaciones en las que participa una empresa asociada de una segunda jurisdicción tributaria.

Ajuste secundario

Ajustement secondaire

Secondary adjustment

Ajuste que resulta de la aplicación de un impuesto a una operación secundaria.

Análisis de las aportaciones

Analyse des contributions

Contribution analysis

Análisis utilizado en el método de distribución del resultado en virtud del cual los resultados combinados de varias operaciones vinculadas se dividen entre las empresas asociadas, basándose en el valor relativo de las funciones realizadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) por cada una de las empresas que participan en las operaciones, completándose, en lo posible, con datos externos procedentes del mercado que indiquen cómo hubieran procedido a esa distribución empresas independientes en circunstancias similares.

Análisis de comparabilidad*Analyse de comparabilité**Comparability analysis*

Comparación de una operación vinculada con una o varias no vinculadas. Las operaciones vinculadas y no vinculadas son comparables si no existe diferencia alguna que afecte sustancialmente al factor elegido para aplicar la metodología (por ejemplo, el precio o el margen) o si es posible proceder a los ajustes necesarios para eliminar los efectos sustanciales que provoquen esas diferencias.

Análisis funcional*Analyse fonctionnelle**Functional analysis*

Análisis de las funciones desempeñadas por empresas asociadas en operaciones vinculadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) y por empresas independientes en operaciones no vinculadas.

Análisis residual*Analyse résiduelle**Residual analysis*

Análisis utilizado en el método de la distribución del resultado que divide en dos fases el beneficio total obtenido en las operaciones vinculadas objeto de examen. En la primera fase, a cada participante se le asigna un beneficio tal que constituya una remuneración suficiente por la operación que ha efectuado. Generalmente, este rendimiento básico se determina tomando como referencia los beneficios obtenidos en el mercado en una operación similar efectuada por empresas independientes. Por tanto, el rendimiento básico normalmente no tendrá en cuenta el rendimiento que generarían los activos únicos y valiosos que poseyeran los participantes en la operación. En la segunda fase, el beneficio (o pérdida) residual resultante tras la atribución efectuada en la primera fase, se atribuye a las partes sobre la base de un análisis de los hechos y circunstancias que muestre cómo se habría dividido ese beneficio (o pérdida) residual entre empresas independientes.

Beneficios brutos*Bénéfices bruts**Gross profits*

Los beneficios brutos de una operación empresarial son el importe obtenido al deducir de los ingresos brutos de la operación las compras o los

costes de producción atribuibles a las ventas, teniendo debidamente en cuenta los ajustes que deban practicarse por el incremento o la disminución de existencias o de bienes y equipos, pero no los demás gastos.

Compensación intencional
Compensation intentionnelle
Intentional set off

Beneficio que una primera empresa asociada aporta a otra segunda, perteneciente también al grupo, para compensarla deliberadamente, en cierta medida, por los beneficios que la primera recibe a cambio.

Costes directos
Coûts directs
Direct costs

Costes incurridos en la producción de un bien o en la prestación de un servicio como, por ejemplo, el coste de las materias primas.

Costes indirectos
Coûts indirects
Indirect costs

Costes de producción de un bien o de prestación de un servicio que, aunque estén estrechamente vinculados al proceso de producción, pueden ser comunes a varios bienes o servicios (por ejemplo, el coste de un servicio de reparaciones que se ocupa de los equipos utilizados para fabricar productos diferentes).

Empresas asociadas
Enterprises associées
Associated enterprises

Dos empresas están asociadas entre sí cuando una de ellas satisface los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 1, letras *a)* o *b)* del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en relación con la otra empresa.

Empresas independientes
Enterprises indépendantes
Independent enterprises

Dos empresas son independientes si no son empresas asociadas entre sí.

Empresa multinacional
Entreprise multinationale
Mutinational enterprise

Sociedad que forma parte de un grupo multinacional.

Grupo de empresas multinacionales
Groupe d'entreprises multinationales
Mutinational enterprise group (MNE group)

Grupo de empresas asociadas con establecimientos empresariales en dos o más países.

Indicador de beneficio neto
Indicateur de bénéfice net
Net profit indicator

La ratio del beneficio neto calculado sobre una base adecuada (por ejemplo, costes, ventas, activos). El método del margen neto operacional se apoya en la comparación de un indicador de beneficio neto apropiado para la operación vinculada con el mismo indicador de beneficio neto correspondiente a operaciones no vinculadas comparables.

Inspecciones fiscales simultáneas
Contrôles fiscaux simultanés
Simultaneous tax examination

Una inspección fiscal simultánea, tal como se define en la Parte A del Modelo de Acuerdo de la OCDE relativo a la realización de inspecciones tributarias simultáneas, designa “un acuerdo entre dos o más partes para inspeccionar, simultánea e independientemente, cada una en su territorio, la situación tributaria de uno (o varios) contribuyente(s) en los que tienen un interés común o conexo, con vistas a intercambiar cualquier información relevante que puedan obtener.”

Intangible comercial
Bien incorporel comercial
Commercial intangible

Intangible que se utiliza en actividades comerciales tales como la producción de un bien o la prestación de un servicio, así como un derecho intangible que, en sí mismo, constituye un activo empresarial transferido a los clientes o utilizado en el ejercicio de actividades económicas.

Intangible de comercialización
Bien incorporel de commercialisation
Marketing intangible

Intangible ligado a actividades de comercialización, que contribuye a la explotación comercial de un producto o de un servicio, o que tiene un valor de promoción importante para el producto en cuestión.

Intangible mercantil
Bien incorporel manufacturier
Trade intangible

Intangible comercial distinto del intangible de comercialización.

Margen sobre el precio de reventa
Marge sur le prix de revente
Resale price margin

Margen que representa la cuantía con la cual un revendedor intenta cubrir los gastos en los que incurre por razón de la venta y otros gastos de explotación y, dependiendo de las funciones realizadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos), obtener un beneficio apropiado.

Margen incrementado sobre el coste
Marge sur coûts (méthode du coût majoré)
Cost plus mark up

Margen de beneficio incrementado sobre los costes directos e indirectos en los que incurra un proveedor de bienes o de servicios en una operación.

Método de cargo directo
Méthode de facturation directe
Direct charge-method

Método que consiste en facturar directamente los servicios específicos intragrupo a partir de una base claramente definida.

Método de cargo indirecto
Méthode de facturation indirecte
Indirect charge method

Método que consiste en facturar los servicios intragrupo basándose en los métodos de atribución y reparto de los costes.

Método de distribución del resultado***Méthode du partage des bénéfices******Profit split method***

Método basado en el resultado de la operación que consiste en identificar el beneficio conjunto que se ha de distribuir entre las empresas asociadas como consecuencia de una operación vinculada (o de operaciones vinculadas que resulte adecuado agregar siguiendo los principios del Capítulo III) para dividirlo a continuación entre ellas, sobre la base de un criterio económicamente válido, que se aproxime a la distribución de beneficios prevista y materializada en un acuerdo suscrito en condiciones de plena competencia.

Método del precio libre comparable***Méthode (CUP) du prix comparable sur le marché libre******Comparable uncontrolled price (CUP) method***

Método para determinar precios de transferencia consistente en comparar el precio de los bienes o servicios transferidos en una operación vinculada con el precio facturado por bienes o servicios transferidos en el marco de una operación no vinculada efectuada en condiciones comparables.

Método del precio de reventa***Méthode du prix de revente******Resale price method***

Método para determinar precios de transferencia, basado en el precio al que se vende un producto a una empresa independiente, previamente adquirido a una empresa asociada. El margen del precio de reventa se detrae del precio de reventa. El resultado obtenido una vez deducido el margen del precio de reventa puede considerarse, tras el ajuste que corresponda por razón de otros costes asociados a la adquisición del producto (por ejemplo, los derechos de aduana) como un precio de plena competencia de la transmisión inicial del bien entre las empresas asociadas.

Método del coste incrementado***Méthode du coût majoré******Cost plus method***

Método para determinar precios de transferencia que utiliza los costes en los que incurre el proveedor de bienes (o de servicios) en el marco de una operación vinculada. Estos costes se incrementan en un margen que resulte apropiado para obtener un beneficio adecuado para las funciones realizadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) y las condiciones del mercado. El resultado obtenido una vez sumado dicho

margen a los costes citados puede considerarse como un precio de plena competencia de la operación vinculada inicial.

Método basado en el resultado de la operación

Méthode transactionnelle de bénéfices

Transactional profit method

Método para determinar precios de transferencia que examina los resultados obtenidos en determinadas operaciones vinculadas por una o varias empresas asociadas que participan en ellas.

Método del margen neto operacional

Méthode transactionnelle de la marge nette

Transactional net margin method

Método basado en el resultado de las operaciones que examina, con relación a una magnitud apropiada (por ejemplo, los costes, las ventas o los activos) el margen de beneficio neto que un contribuyente obtiene como consecuencia de una operación vinculada (o de operaciones vinculadas que resulte adecuado agregar siguiendo los principios del Capítulo III).

Métodos tradicionales basados en las operaciones

Méthode traditionnelle fondée sur les transactions

Traditional transaction methods

El método del precio libre comparable, el método del precio de reventa y el método del coste incrementado.

Operaciones no vinculadas

Transactions sur le marché libre

Uncontrolled transactions

Operaciones realizadas entre empresas que son independientes entre sí.

Operación no vinculada comparable

Transaction sur le marché libre comparable

Comparable uncontrolled transaction

Una operación no vinculada comparable es una operación realizada entre dos partes independientes que puede compararse a la operación vinculada objeto de examen. Puede tratarse bien de una operación comparable efectuada entre una parte interviniente en la operación vinculada y una parte independiente (“comparable interno”) o entre dos partes independientes, ninguna de las cuales interviene en la operación vinculada (“comparable externo”).

Operación secundaria*Transaction secondaire**Secondary transaction*

Construcción teórica a la que proceden determinados países en virtud de su legislación interna, después de haber propuesto un ajuste primario, a fin de realizar una atribución efectiva de los beneficios compatible con este ajuste primario. Las operaciones secundarias pueden tomar la forma de dividendos presuntos, de aportaciones presuntas de capital o de préstamos presuntos.

Operaciones vinculadas*Transactions contrôlées**Controlled transactions*

Operaciones entre dos empresas que están asociadas entre sí.

Pago compensatorio*Paielement compensatoire**Balancing payment*

Pago efectuado normalmente por uno o varios participantes a un tercero con el fin de ajustar los porcentajes de las aportaciones, cuyo efecto es el de incrementar el valor de las aportaciones del pagador y disminuir las del beneficiario en el importe de dicho pago.

Pago de entrada en un acuerdo de reparto de costes (ARC)*Paielement d'entrée**Buy-in payment*

Pago efectuado por un nuevo participante en un acuerdo de reparto de costes preexistente con el fin de obtener una participación en los resultados de la actividad anterior a su adhesión.

Pago recibido al retirarse de un acuerdo de reparto de costes (ARC)*Paielement de sortie**Buy-out payment*

Pago compensatorio que puede recibir un participante que se retira de un acuerdo de reparto de costes vigente, efectuado por los demás participantes, que remunera la transmisión efectiva de su participación en los resultados derivados de las actividades realizadas en el marco del ARC antes de su retirada.

Beneficio potencial***Potentiel de profits******Profit potential***

Beneficios futuros esperados. En algunos casos esta expresión puede incluir las pérdidas. La noción de “beneficio potencial” se utiliza frecuentemente en las valoraciones, en la determinación de la compensación de plena competencia correspondiente a la transmisión de activos intangibles o de una actividad empresarial, o para determinar la indemnización de plena competencia por la rescisión o renegociación sustancial de acuerdos vigentes, toda vez que se haya determinado que, en circunstancias comparables, partes independientes habrían procedido a dicha compensación o indemnización.

Principio de plena competencia***Principe de pleine concurrence******Arm's length principle***

Norma internacional que debe utilizarse para determinar los precios de transferencia con fines fiscales, tal como lo han acordado los países miembros de la OCDE. Dicha norma se enuncia en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE de la siguiente forma: “Cuando las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia”.

Procedimiento amistoso***Procédure amiable******Mutual agreement procedure***

Mecanismo a través del cual las administraciones tributarias se consultan entre sí para resolver sus diferencias en relación con la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. Este procedimiento, descrito y fundamentado en el artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, puede utilizarse para eliminar la doble imposición que pueda generarse como consecuencia de un ajuste de precios de transferencia.

Rango de plena competencia*Intervalle de pleine concurrence**Arm's length range*

Rango de cifras aceptables para definir si las condiciones de una operación vinculada son de plena competencia y que resulta, bien de la aplicación del mismo método de determinación de precios de transferencia a múltiples datos comparables, o bien de la aplicación de diferentes métodos de determinación de precios de transferencia.

Reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida*Répartition globale selon une formule**Global formulaary Apportionment*

Enfoque para la atribución de los beneficios globales de un grupo multinacional contabilizados sobre una base consolidada entre las empresas asociadas ubicadas en diferentes países, tomando como referencia una fórmula preestablecida.

Servicio intragrupo*Service intragroupe**Intra-group service*

Actividad (por ejemplo, administrativa, técnica, financiera, comercial, etc.) por la que una empresa independiente hubiera estado dispuesta a pagar, o que hubiera ejercido por cuenta propia.

Servicios prestados “a demanda”*Services rendus “sur demande”**“On call” services*

Servicios prestados por una sociedad matriz o un centro de servicios de un grupo, disponibles en todo momento para los miembros de un grupo multinacional.

Capítulo I

El principio de plena competencia

A. Introducción

1.1 Este capítulo constituye un análisis de fondo del principio de plena competencia, que es el estándar internacional sobre precios de transferencia acordada por los países miembros de la OCDE para su utilización, a efectos fiscales, por los grupos multinacionales y las administraciones tributarias. El capítulo analiza el principio de plena competencia, reafirma su condición de estándar internacional y establece criterios para su aplicación.

1.2 Cuando las empresas independientes negocian entre sí, las fuerzas del mercado determinan normalmente las condiciones de sus relaciones comerciales y financieras (por ejemplo, el precio de los bienes transmitidos o de los servicios prestados y las condiciones de la transmisión o de la prestación). Cuando las empresas asociadas operan entre sí, las fuerzas externas del mercado pueden no afectar de la misma forma a sus relaciones comerciales y financieras, aunque es frecuente que las empresas asociadas pretendan reproducir en sus operaciones la dinámica de las fuerzas del mercado, como se analiza más adelante en el párrafo 1.5. Las administraciones tributarias no deben considerar automáticamente que las empresas asociadas pretendan manipular sus beneficios. Pueden existir dificultades reales en la determinación exacta del valor normal de mercado ante la ausencia de fuerzas de mercado o por razón de la adopción de una estrategia empresarial concreta. Es importante tener presente que la necesidad de practicar ajustes para aproximarse a las condiciones de plena competencia surge con independencia de cualquier obligación contractual de satisfacer un precio en particular asumida por las partes, o de cualquier intento de minimizar la carga fiscal. Por tanto, los ajustes guiados por el principio de plena competencia no afectarían a las obligaciones contractuales sin finalidad fiscal asumidas por las empresas asociadas y podrían ser apropiados aun cuando no haya intención de minimizar o eludir impuestos. El análisis de los precios de transferencia debe desvincularse claramente de la consideración de los problemas de fraude o elusión fiscal, aun cuando las determinaciones que se adopten en materia de precios de transferencia puedan utilizarse para dichos fines.

1.3 Cuando los precios de transferencia no responden a las fuerzas del mercado y al principio de plena competencia, podría darse una distorsión en las deudas tributarias de las empresas asociadas y en la recaudación tributaria de los países receptores de la inversión. Por tanto, los países miembros de la OCDE han acordado que, a efectos fiscales, los beneficios de empresas asociadas puedan ajustarse en la medida necesaria para corregir tales distorsiones y asegurar de este modo que se cumple el principio de plena competencia. Los países miembros de la OCDE consideran que el ajuste apropiado se logra determinando las condiciones de las relaciones comerciales y financieras susceptibles de encontrarse entre empresas independientes, en operaciones y circunstancias comparables.

1.4 Aparte de las consideraciones fiscales, otros factores pueden distorsionar las condiciones de las relaciones comerciales y financieras establecidas entre empresas asociadas. Por ejemplo, dichas empresas pueden estar sometidas a obligaciones administrativas opuestas (en el propio país y en el extranjero) relativas a las valoraciones aduaneras, derechos anti-dumping y controles de cambio o de precios. Además, las distorsiones en los precios de transferencia pueden tener como origen las necesidades de tesorería de las empresas de un grupo multinacional. Un grupo multinacional que cotiza sus acciones en el mercado de valores puede verse presionado por los accionistas a mostrar una rentabilidad elevada en la sociedad matriz, en particular si la información dirigida a los accionistas no se presenta de forma consolidada. Todos estos factores pueden afectar a los precios de transferencia y a la cuantía de los beneficios atribuidos a las empresas asociadas de un grupo multinacional.

1.5 No se debería suponer que las condiciones establecidas en las relaciones comerciales y financieras entre empresas asociadas se desvían invariablemente respecto de las que demandaría el mercado libre. Las empresas asociadas de los grupos multinacionales en ocasiones tienen un grado de autonomía considerable y, a menudo, negocian entre sí como si fueran empresas independientes. En sus relaciones con terceros y con empresas asociadas, las empresas se ajustan a las situaciones económicas derivadas de las condiciones del mercado. Por ejemplo, los directivos locales pueden estar interesados en conseguir unos buenos resultados y, por tanto, no fijarían precios que redujeran los beneficios de sus propias empresas. Las administraciones tributarias deben tener presentes estas consideraciones con el objeto de facilitar una asignación eficiente de sus recursos a la hora de seleccionar y llevar a cabo comprobaciones de precios de transferencia. En ocasiones puede suceder que la relación entre las empresas asociadas influya en el resultado de la negociación. Por tanto, la evidencia de condiciones de

negociación duras no es suficiente, por sí sola, para determinar que las operaciones se realizan en condiciones de plena competencia.

B. Declaración del principio de plena competencia

B.1 Artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE

1.6 La declaración que otorga carácter oficial al principio de plena competencia se encuentra en el apartado 1 del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que constituye la base de la negociación de los convenios fiscales bilaterales entre países miembros de la OCDE, y entre un número cada vez mayor de países no miembros. El artículo 9 dispone que:

"(Cuando)... dos empresas (asociadas) estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia".

Con el objeto de ajustar beneficios, tomando como referencia las condiciones que hubieran concurrido entre empresas independientes en operaciones comparables efectuadas en condiciones igualmente comparables (es decir, en una “operación no vinculada comparable”) el objeto del principio de plena competencia es tratar a los miembros de un grupo multinacional como si operaran como empresas independientes en lugar de como partes inseparables de una sola empresa unificada. Dado que el criterio de entidad independiente considera a los integrantes de un grupo multinacional como si fueran empresas independientes, la atención se centra en la índole de las operaciones que realizan entre sí y en si las condiciones en las que las realizan difieren de las que concurrirían en operaciones no vinculadas comparables. Este análisis de las operaciones vinculadas y no vinculadas, al que nos referiremos como “análisis de comparabilidad”, es la esencia de la aplicación del principio de plena competencia. En el apartado D, más adelante, y en el Capítulo III pueden encontrarse pautas para la aplicación de este análisis de comparabilidad.

1.7 Es importante poner en perspectiva la cuestión de la comparabilidad a fin de subrayar la necesidad de buscar el equilibrio entre, por un lado, la fiabilidad del análisis de comparabilidad y, por el otro, la

carga que vaya a generar para los contribuyentes y las administraciones tributarias. El artículo 9, apartado 1 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE es la base de los análisis de comparabilidad, ya que prevé la necesidad:

- de una comparación entre las condiciones (incluidos, pero no exclusivamente los precios) acordadas o impuestas entre empresas asociadas y aquellas que se pactarían entre empresas independientes, a fin de determinar si es posible rectificar la contabilidad con la intención de calcular las obligaciones tributarias de las empresas asociadas en virtud del artículo 9 del Modelo de Convenio tributario de la OCDE (véase el párrafo 2 de los Comentarios al artículo 9); y
- de calcular los beneficios que se hubieran obtenido en condiciones de plena competencia, a fin de determinar la cuantía de la rectificación que pudiera tener que practicarse en la contabilidad.

1.8 Hay varias razones que explican por qué los países miembros y otros no miembros de la OCDE han adoptado el principio de plena competencia. Una de las primeras causas es que este principio ofrece un tratamiento fiscal equitativo para empresas multinacionales y empresas independientes. El trato igualitario a efectos fiscales entre empresas asociadas e independientes que propicia el principio de plena competencia evita que surjan ventajas o desventajas fiscales que, de otra forma, distorsionarían la posición competitiva relativa de cada tipo de entidad. El principio de plena competencia facilita el crecimiento del comercio y de las inversiones internacionales al excluir las consideraciones fiscales de la toma de decisiones económicas.

1.9 Se ha observado que el principio de plena competencia funciona muy eficazmente en la gran mayoría de los casos. Por ejemplo, hay muchas situaciones referidas a la compra y venta de bienes y préstamos de dinero en las que el precio de plena competencia se puede encontrar fácilmente recurriendo a operaciones comparables realizadas por empresas independientes comparables en circunstancias equiparables. Hay también muchos casos en los que es posible comparar operaciones en el plano de indicadores financieros tales como los márgenes incrementados sobre costes, el margen bruto o el beneficio neto. Sin embargo, existen casos muy significativos en los que la aplicación del principio de plena competencia resulta difícil y complicada, por ejemplo en el caso de grupos multinacionales involucrados en la producción integrada de bienes altamente especializados, en intangibles exclusivos, o en la prestación de servicios especializados. Existen soluciones que permiten abordar esos casos tan difíciles, incluyendo la utilización del método de la distribución del resultado

descrito en el apartado III del Capítulo II de estas Directrices, siempre que sea este método el más apropiado a las circunstancias del caso.

1.10 Hay quienes observan imperfecciones inherentes al principio de plena competencia ya que el criterio de entidad independiente puede que no tenga siempre en cuenta las economías de escala y la interrelación entre la pluralidad de actividades generada por la integración de empresas. Sin embargo, no existen criterios objetivos aceptados por la generalidad que permitan distribuir las economías de escala o los beneficios derivados de la integración entre empresas asociadas. La cuestión de las alternativas posibles al principio de plena competencia se aborda en la Sección C más adelante.

1.11 La aplicación del principio de plena competencia encuentra una dificultad práctica en el hecho de que las empresas asociadas pueden involucrarse en operaciones que las empresas independientes no llevarían a cabo. Estas operaciones no tienen que estar necesariamente motivadas por la elusión fiscal, sino que puedan darse porque, al operar entre sí, los miembros del grupo multinacional se enfrentan con circunstancias comerciales diferentes a las que se enfrentarían las empresas independientes. El mero hecho de que una operación no pueda encontrarse entre partes independientes no significa por sí mismo que no se realice en condiciones de plena competencia.

1.12 En determinados casos, el principio de plena competencia puede convertirse en una carga administrativa tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias al tener que valorar un número significativo y diverso de operaciones transfronterizas. Aunque las empresas asociadas fijan normalmente las condiciones de una operación a la hora de llevarla a cabo, en algún momento podrá requerirse a las empresas que demuestren su coherencia con el principio de plena competencia (véase el análisis del marco temporal y comparabilidad y del cumplimiento en las Secciones B y C del Capítulo III y en el Capítulo V sobre Documentación). También es posible que la administración tributaria tenga que embarcarse en el proceso de comprobación varios años después de que las operaciones se hayan realizado. La administración tributaria revisaría entonces la documentación reunida por el contribuyente con la intención de justificar la coherencia de las operaciones con el principio de plena competencia, a la vez que tendría que reunir información relativa a operaciones comparables, a las condiciones de mercado en el momento en el que las operaciones se realizaron, etc., y todo ello respecto de numerosas y diferentes operaciones. Esta tarea suele resultar más ardua con el paso del tiempo.

1.13 Con frecuencia, tanto las administraciones tributarias como los contribuyentes encuentran dificultades para obtener información precisa que

permita aplicar el principio de plena competencia. Este principio puede exigir una cantidad importante de datos ya que, normalmente, requiere que los contribuyentes y las administraciones tributarias evalúen operaciones no vinculadas y actividades comerciales de empresas independientes, y las comparen con las operaciones y actividades de empresas asociadas. La información accesible puede resultar incompleta y difícil de interpretar; en caso de existir otra información, podría ser complicado obtenerla a causa de la localización geográfica tanto de esta como de las partes que pueden procurarla. Además, puede suceder que, por razones de confidencialidad, resulte imposible conseguir información de empresas independientes. En otros casos, puede ser que simplemente no exista información relevante relativa a empresas independientes o pueden no existir empresas independientes comparables, por ejemplo, cuando el sector de actividad haya alcanzado un alto grado de integración vertical. Es importante no perder de vista el objetivo de llegar a una aproximación razonable de lo que sería un resultado de plena competencia basado en información fiable. En este punto, se debería recordar también que los precios de transferencia no son una ciencia exacta, sino que exigen juicios de valor tanto por parte de la administración tributaria como de los contribuyentes.

B.2 Mantenimiento del consenso internacional en torno al principio de plena competencia

1.14 Aun teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el criterio de los países miembros de la OCDE continúa siendo que el principio de plena competencia debe regir la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas. Este principio tiene un sólido fundamento teórico, ya que ofrece la posición más próxima al funcionamiento del mercado libre en los casos en que se transmiten propiedades (bienes u otros tipos de activos tangibles o intangibles) o se prestan servicios entre empresas asociadas. Aunque no siempre resulte sencillo aplicarlo en la práctica, suele determinar niveles apropiados de renta entre miembros de grupos multinacionales, aceptables para las administraciones tributarias. De este modo se refleja la realidad económica de los hechos y circunstancias particulares de contribuyentes asociados y se adopta como punto de referencia el funcionamiento normal del mercado.

1.15 Abandonar el principio de plena competencia supondría renunciar a la fundada base teórica descrita anteriormente y amenazar el consenso internacional, incrementando así sustancialmente el riesgo de que se produzca una doble imposición. La experiencia que se tiene de la aplicación de este principio es ya lo suficientemente amplia y diversa como para haber

generado una base sólida de entendimiento mutuo entre el mundo empresarial y las administraciones tributarias. Este entendimiento tiene un gran valor práctico a la hora de alcanzar los objetivos de fijar las bases impositivas adecuadas en cada jurisdicción y evitar la doble imposición. Esta experiencia debería utilizarse para desarrollar el principio de plena competencia, afinar su funcionamiento y mejorar su aplicación, ofreciendo más orientación a los contribuyentes y realizando comprobaciones más oportunas. En resumen, los países de la OCDE mantienen firmemente su apoyo al principio de plena competencia. En realidad, no ha surgido ninguna alternativa a este principio que sea admisible o realista. El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida, mencionado en ocasiones como alternativa posible, no resulta aceptable en su concepción teórica ni en su aplicación práctica (véase la Sección C, inmediatamente a continuación, donde se comenta el método del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida).

C. Un enfoque que no se apoya en el principio de plena competencia: el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida

C.1 *Antecedentes y descripción del enfoque*

1.16 El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida se ha propuesto en ocasiones como alternativa al principio de plena competencia para determinar la correcta atribución de los beneficios entre distintas jurisdicciones tributarias. Este enfoque no se ha aplicado en las relaciones internacionales, aunque sí se ha ensayado en algunas jurisdicciones fiscales locales.

1.17 El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida distribuiría los resultados globales consolidados de un grupo multinacional entre las empresas asociadas situadas en distintos países por medio de una fórmula predeterminada y automática. Este enfoque consta de tres elementos esenciales: determinar la unidad gravable, es decir, qué filiales y sucursales del grupo multinacional conformarían la entidad global sujeta a imposición; determinar con precisión los resultados globales, y establecer la fórmula aplicable para su distribución. La fórmula se fundamentaría posiblemente en una combinación de costes, activos, salarios y ventas.

1.18 El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida no debe confundirse con los métodos basados en el resultado de las operaciones analizados en la Parte III del Capítulo II. Este enfoque utilizaría una fórmula de reparto del beneficio predeterminada para todos los

contribuyentes, mientras que los métodos basados en el resultado comparan caso por caso los beneficios de una o varias empresas asociadas con aquellos que empresas independientes comparables hubieran tratado de conseguir en circunstancias comparables. El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida tampoco debe confundirse con la aplicación específica de una fórmula desarrollada por ambas administraciones tributarias en cooperación con un contribuyente concreto o un grupo multinacional tras un análisis minucioso de los hechos y circunstancias particulares, tal y como podría suceder en el ámbito de un procedimiento amistoso, de un acuerdo previo de valoración de precios de transferencia u otro mecanismo bilateral o multilateral. Esa fórmula se obtiene partiendo de los hechos y circunstancias específicas del contribuyente y, por tanto, se aleja del carácter globalmente predeterminado y automático del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida.

C.2 Comparación con el principio de plena competencia

1.19 Los partidarios del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida estiman que este enfoque ofrece, con relación al principio de plena competencia, mayor comodidad administrativa y mayor seguridad para el contribuyente. Asimismo afirman que el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida es más coherente con la realidad económica. Argumentan que para reflejar adecuadamente la realidad de las relaciones comerciales entre las empresas del grupo, los grupos multinacionales deben considerarse en su integridad o de forma consolidada. Sus partidarios consideran que el método basado en contabilidades distintas no resulta apropiado para grupos altamente integrados, puesto que es difícil determinar la aportación exacta que cada empresa asociada efectúa al resultado global del grupo multinacional.

1.20 Además de estos argumentos, sus partidarios sostienen que el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida reduce la carga de cumplimiento con las obligaciones tributarias para el contribuyente, puesto que, en principio, por lo que a la fiscalidad nacional se refiere, es necesaria una única contabilidad para todo el grupo.

1.21 Los países miembros de la OCDE no aceptan estas alegaciones y tampoco consideran, por las razones que siguen, que el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida sea una alternativa realista al principio de plena competencia.

1.22 La mayor preocupación que suscita el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida se refiere a la dificultad de aplicar el

sistema de forma que proteja contra la doble imposición y, a la vez, garantice una única imposición. Para alcanzar estos objetivos sería necesaria una elevada coordinación administrativa internacional y consenso sobre las fórmulas predeterminadas que fueran a utilizarse, así como sobre la composición del grupo en cuestión. Por ejemplo, para evitar la doble imposición se requeriría, en primer lugar, acordar la adopción del método; después, la forma de cuantificar la base imponible global del grupo multinacional, la utilización de un sistema contable común, los factores que intervienen para repartir la base imponible entre las distintas jurisdicciones fiscales (incluyendo países no miembros) y el modo de cuantificar y ponderar esos factores. Alcanzar este acuerdo sería muy lento y extremadamente difícil y dista de estar claro que los países quieran acordar una fórmula universal.

1.23 Aun cuando algunos países estuvieran dispuestos a aceptar el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida los desacuerdos serían inevitables, puesto que, sin duda, cada país querría resaltar o incluir factores distintos en la fórmula en función de las actividades o factores que predominen en su jurisdicción. Cada país estaría interesado en que la fórmula o las ponderaciones adoptadas maximizaran su propia recaudación. Por otra parte, las administraciones tributarias deberían examinar conjuntamente cómo resolver el problema de la transferencia artificial de los factores de producción empleados en la fórmula (por ejemplo, ventas o capital) hacia países de reducida tributación. Podría existir elusión fiscal en la medida en que se puedan manipular los componentes esenciales de la fórmula; por ejemplo, efectuando operaciones financieras innecesarias, localizando deliberadamente activos móviles, exigiendo a ciertas empresas del grupo multinacional mantener niveles de existencias excesivos con relación a los que hubiera tenido una sociedad independiente del mismo tipo, etc.

1.24 La transición a un sistema de reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida presentaría excepcionales complicaciones en el terreno político y administrativo, además de requerir un nivel de cooperación internacional que difícilmente cabe esperar en el ámbito de la fiscalidad. Esta coordinación multilateral exigiría la participación de todos los grandes países en los que operen empresas multinacionales. Si todos ellos no llegaran a acordar la adopción de este método, las empresas multinacionales se verían con la carga de cumplir con dos sistemas totalmente distintos. En otras palabras, estarían obligadas, para un mismo conjunto de operaciones, a calcular los beneficios realizados por cada miembro del grupo según dos estándares completamente diferentes. El resultado generaría posibilidades de doble imposición (o de sub-imposición) en todos los casos.

1.25 Además de los problemas de doble imposición que acaban de exponerse, este método plantea otras cuestiones cruciales. Una de ellas es que las fórmulas predeterminadas sean arbitrarias e ignoren las condiciones del mercado, las circunstancias particulares de las distintas empresas, y el reparto de recursos efectuado por los propios administradores, lo cual llevará a una distribución de los beneficios sin relación alguna con las circunstancias específicas en las que se lleva a cabo la operación. Más concretamente, una fórmula basada en una combinación de costes, activos, salarios y ventas está imputando implícitamente un porcentaje fijo de beneficio por unidad monetaria (por ejemplo, dólar, euro, yen...) de cada elemento a todos los miembros del grupo y en todas las jurisdicciones tributarias, independientemente de las diferencias entre funciones, activos, riesgos y eficiencias entre los miembros del grupo multinacional. Potencialmente, este método podría asignar beneficios a una entidad que, en caso de ser una empresa independiente, incurriría en pérdidas.

1.26 Otra dificultad del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida es el tratamiento de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Aunque las fluctuaciones de los tipos de cambio puedan complicar la aplicación del principio de plena competencia, el impacto no es el mismo que en la aplicación del método de reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida. El principio de plena competencia está mejor dotado para abordar las consecuencias económicas derivadas de las fluctuaciones de los tipos de cambio, dado que requiere el análisis de los hechos y circunstancias particulares del contribuyente. Si la fórmula se basara en los costes, la aplicación del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida provocaría que cuando una moneda se apreciara de forma regular frente a otra, empleada por una empresa asociada en su contabilidad, se atribuiría una porción mayor de los beneficios a la empresa situada en el primer país con el fin de reflejar el incremento nominal del coste de los salarios debido a la fluctuación de la moneda. En consecuencia, con el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida, la evolución del tipo de cambio de este ejemplo conllevaría un aumento de los beneficios de la empresa asociada que opera con la moneda más fuerte, mientras que, a largo plazo, la apreciación de la moneda reduciría la competitividad en la exportación y presionaría los beneficios a la baja.

1.27 De hecho, y contrariamente a lo que afirman sus partidarios, el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida puede ocasionar unos costes de cumplimiento y de exigencia de datos intolerable, ya que la información debe obtenerse sobre la totalidad del grupo multinacional y presentarse en cada jurisdicción en su moneda nacional y de acuerdo con sus normas fiscales y contables. Por lo tanto, la documentación

y los requisitos de cumplimiento para la aplicación del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida serían normalmente más gravosos que en aplicación del criterio de empresa independiente del principio de plena competencia. En el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida los costes se incrementarían aun más si los elementos de la fórmula o el modo de evaluar esos elementos no pudieran acordarse entre todos los países.

1.28 También surgirían dificultades en la determinación de las ventas de cada miembro y en la valoración de los activos (por ejemplo, coste histórico o valor normal de mercado), especialmente en la valoración de los activos intangibles. Estas dificultades radicarían en la existencia de diversos criterios contables y múltiples unidades monetarias entre las diferentes jurisdicciones fiscales. Para poder evaluar adecuadamente el beneficio del grupo multinacional en su conjunto habría que unificar estos criterios entre todos los países. Por supuesto, alguna de estas dificultades (por ejemplo, la valoración de activos y de intangibles) también se plantea con la aplicación del principio de plena competencia, pero se han efectuado notables progresos en este ámbito, mientras que en el caso del reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida no se ha propuesto ninguna solución creíble.

1.29 El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida trataría de gravar al grupo multinacional sobre una base consolidada, por lo que abandona el criterio de entidad independiente. En consecuencia, este enfoque no puede, desde un punto de vista práctico, subsanar las importantes diferencias geográficas, las distintas eficiencias empresariales, ni otros factores específicos de una empresa o de un subgrupo dentro del grupo multinacional; factores que desempeñan legítimamente una función en la determinación del reparto del beneficio entre empresas situadas en distintas jurisdicciones fiscales. En cambio, el principio de plena competencia reconoce que una empresa asociada puede constituir un centro de beneficios o de pérdidas distinto, con características específicas, con la posibilidad de obtener beneficios aun cuando el resto del grupo multinacional esté incurriendo en pérdidas. El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida carece de la flexibilidad necesaria para contemplar esta posibilidad adecuadamente.

1.30 Al ignorar las operaciones intragrupo a efectos de cálculo de los beneficios consolidados, el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida suscitaría interrogantes acerca de la oportunidad de aplicar una retención en la fuente respecto de los pagos transfronterizos entre miembros de un mismo grupo, y exigiría el abandono de cierto número de reglas incorporadas en los convenios bilaterales para evitar la doble imposición.

1.31 A menos que incluya a todos los miembros del grupo multinacional, el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida deberá seguir aplicando una norma basada en el criterio de entidad independiente para la conexión entre la parte del grupo sujeta al reparto del beneficio global y el resto del grupo multinacional. El reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida no sirve para valorar operaciones entre el grupo sujeto al reparto del beneficio global y el resto del grupo multinacional. Así, se observa claramente que el inconveniente de este enfoque es que no ofrece una solución completa para la atribución de los beneficios de un grupo multinacional mientras no se aplique sobre el conjunto de la empresa. Esta aplicación a nivel del conjunto del grupo multinacional sería un reto enorme para una sola administración tributaria, dada la dimensión y la envergadura de las operaciones de los grandes grupos multinacionales y la cantidad de información que sería necesaria. En cualquier caso, el grupo multinacional también debería mantener una contabilidad separada para las sociedades que no son miembros del grupo a los efectos fiscales de este reparto del beneficio, pero que sí son empresas asociadas a uno o varios miembros del grupo multinacional. En definitiva, muchas normas nacionales comerciales y contables seguirían requiriendo la aplicación del principio de plena competencia (por ejemplo, las aduaneras) de forma que independientemente de las normas fiscales, el contribuyente debería contabilizar correctamente todas las operaciones al precio de plena competencia.

C.3 *Rechazo de los métodos no basados en el principio de plena competencia*

1.32 Por las razones expuestas, los países miembros de la OCDE reiteran su apoyo al consenso alcanzado entre países miembros y no miembros para la aplicación del principio de plena competencia, y acuerdan que debe rechazarse la alternativa teórica al principio de plena competencia representada por el reparto del beneficio global según una fórmula preestablecida.

D. Guía para la aplicación del principio de plena competencia

D.1 Análisis de comparabilidad

D.1.1 Importancia del análisis de comparabilidad y significado del término “comparable”

1.33 La aplicación del principio de plena competencia se basa generalmente en la comparación de las condiciones de una operación vinculada con las condiciones de las operaciones efectuadas entre empresas independientes. Para que estas comparaciones sean útiles, las características económicas relevantes de las situaciones que se comparan deben ser lo suficientemente comparables. Ser comparable significa que ninguna de las diferencias (si las hay) entre las situaciones objeto de comparación pueda afectar significativamente a las condiciones analizadas en la metodología (por ejemplo, el precio o el margen), o que se pueden realizar ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos de dichas diferencias. Para determinar el grado de comparabilidad y qué ajustes son precisos para lograrla, es necesario comprender cómo evalúan las sociedades independientes las operaciones potenciales. En el Capítulo III se exponen las líneas rectoras detalladas para la realización del análisis de comparabilidad.

1.34 Las empresas independientes, al evaluar las condiciones de una posible operación, las comparan con otras opciones disponibles de modo realista y sólo participarán en ella si no ven una alternativa claramente más atractiva. Por ejemplo, no parece probable que una empresa acepte un precio ofertado por una empresa independiente si sabe que otros clientes potenciales desearían pagar más por su producto en condiciones similares. Este punto es relevante en la cuestión de la comparabilidad ya que las empresas independientes, a la hora de valorarlas, tendrán normalmente en cuenta cualquier diferencia con trascendencia económica que se aprecie entre las opciones disponibles de modo realista (tales como diferencias en el grado de riesgo u otros factores de comparabilidad que se mencionan más adelante). Por tanto, cuando se proceda a las comparaciones que implica la aplicación del principio de plena competencia, las administraciones tributarias deberán tener en cuenta también estas diferencias para determinar si hay comparabilidad entre las situaciones comparadas y cuáles son los ajustes que pueden resultar necesarios para lograrla.

1.35 Todos los métodos que aplican el principio de plena competencia giran en torno a la idea de que las empresas independientes consideran las opciones que tienen disponibles y, al compararlas entre sí, evalúan las

diferencias que pudieran afectar a su valor de manera significativa. Por ejemplo, es normal suponer que las empresas independientes consideren si pueden comprar un mismo producto a un tercero en términos y condiciones comparables, pero a un precio inferior, antes de comprarlo a un cierto precio. Por tanto, como se menciona en el Capítulo II, Parte II, el método del precio libre comparable compara una operación vinculada con una operación no vinculada similar, con el objeto de ofrecer una estimación directa del precio que las partes hubieran acordado en caso de haber optado por una operación ofrecida en el mercado como alternativa a la operación vinculada. Sin embargo, si todas las características de las operaciones no vinculadas que influyen significativamente en el precio cargado entre empresas independientes no son comparables, el método pierde fiabilidad como sustitutivo de una operación de plena competencia. De manera similar, los métodos del precio de reventa y del coste incrementado comparan el margen de beneficio bruto obtenido en las operaciones vinculadas con los márgenes de beneficio bruto obtenidos en operaciones no vinculadas comparables. La comparación ofrece una estimación del margen de beneficio bruto que hubiera podido obtener una de las partes en caso de haber realizado las mismas funciones para una empresa independiente y, por tanto, proporciona un cálculo del precio que esta hubiera demandado y que la otra parte hubiera estado dispuesta a pagar por realizar esas funciones en condiciones de plena competencia. Como se comenta en el Capítulo II Parte III, otros métodos se basan en comparaciones de indicadores de beneficios netos (por ejemplo márgenes de beneficios) entre empresas independientes y asociadas como medio para estimar los beneficios que hubiera podido obtener una de las empresas asociadas, o ambas, en caso de que hubieran negociado sólo con empresas independientes y, en consecuencia, la retribución que esas mismas empresas hubieran pedido, en condiciones de plena competencia, por la utilización de sus recursos en las operaciones vinculadas. Cuando existen diferencias entre las situaciones objeto de comparación que puedan afectar significativamente a la comparación es necesario realizar ajustes, cuando sea posible, que mejoren su fiabilidad. De esta manera, las retribuciones medias no ajustadas del sector industrial no pueden, en ningún caso, determinar por sí mismas las condiciones de plena competencia.

1.36 Como se indicó anteriormente, al efectuar la comparación se deben tener en cuenta las diferencias significativas entre las operaciones o entre las empresas comparadas. Para poder determinar el grado real de comparabilidad es necesario valorar las características de las operaciones, o de las empresas, que hubieran podido influir en las condiciones de la negociación en el mercado libre, y realizar así los ajustes apropiados para establecer las condiciones de plena competencia (o un rango de las mismas). Las características o “factores de comparabilidad” que pueden ser

importantes para determinar la comparabilidad son las características de la propiedad o de los servicios transmitidos, las funciones desempeñadas por las partes (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos), las cláusulas contractuales, las circunstancias económicas de las partes y las estrategias empresariales que estas persiguen. Más adelante, en la Sección D.1.2, se analizan estos factores de comparabilidad con más detalle.

1.37 La importancia de estos factores en la determinación de la comparabilidad dependerá de la naturaleza de la operación vinculada y del método de determinación de precios adoptado. En lo que concierne al papel de estos factores en la aplicación de cada uno de los métodos de determinación de precios, véase su análisis en el Capítulo II.

D.1.2 Los factores determinantes de la comparabilidad

1.38 El párrafo 1.36 hace referencia a cinco factores que pueden ser importantes para determinar la comparabilidad. En el marco de un ejercicio comparativo, el examen de los cinco factores es, en esencia, doble, dado que implica el análisis de los factores que inciden en las operaciones vinculadas del contribuyente y el de los factores que afectan a las operaciones no vinculadas. Tanto la naturaleza de la operación vinculada como el método de determinación de precios de transferencia adoptado (véase en el Capítulo II el análisis de los métodos de determinación de precios de transferencia) deben tenerse en cuenta al evaluar la importancia relativa de la información de la que se carezca sobre posibles comparables, que será distinta en función del caso. La información sobre las características del producto puede revestir mayor importancia si el método aplicado es el del precio libre comparable que si se trata del método del margen neto operacional. Si cabe suponer razonablemente que la diferencia no ajustada no va a afectar significativamente a la comparabilidad, la operación en cuestión realizada en el mercado libre no debe rechazarse como comparable potencial, aunque no se disponga de alguna información.

D.1.2.1 Características de los bienes o de los servicios

1.39 Las diferencias en las características específicas de los bienes o de los servicios explican a menudo, al menos parcialmente, las diferencias en su valor en el mercado libre. En consecuencia, la comparación de estas características puede ser útil en la determinación de la comparabilidad entre operaciones vinculadas y no vinculadas. Entre las características cuya consideración puede resultar útil se encuentran: en el caso de transmisiones de bienes tangibles, sus características físicas, sus cualidades y su fiabilidad,

así como su disponibilidad y el volumen de la oferta; en el caso de la prestación de servicios, la naturaleza y el alcance de los servicios; y en el caso de activos intangibles, la forma de la operación (por ejemplo, la concesión de una licencia o su venta), el tipo de activo (por ejemplo, patente, marca o conocimientos prácticos –*know how*-), la duración y el grado de protección y los beneficios previstos derivados de la utilización del bien.

1.40 Dependiendo del método de determinación de precios de transferencia, debe concedérsele mayor o menor importancia a este factor. Entre los métodos descritos en el Capítulo II de estas Directrices, la exigencia de comparabilidad de los bienes o servicios es más estricta para el método del precio libre comparable. Conforme a este método, toda diferencia significativa en las características de los bienes o de los servicios puede afectar al precio, por lo que exige la consideración de un ajuste (véase en concreto el párrafo 2.15). En la aplicación de los métodos del precio de reventa y del coste incrementado, algunas diferencias en las características de los bienes o servicios tienen menos probabilidad de afectar al margen de beneficio bruto o al margen incrementado sobre los costes (véanse en concreto los párrafos 2.23 y 2.41). Las diferencias en las características de los bienes o los servicios tienen también menos incidencia en el caso de los métodos basados en el resultado que en el de los métodos tradicionales (véase en concreto el párrafo 2.69). Esto no significa, no obstante, que pueda ignorarse la cuestión de la comparabilidad de las características de los bienes o servicios al aplicar estos métodos, porque puede ocurrir que las diferencias en los productos conlleven o sean el resultado del desarrollo de funciones, el uso de activos o la asunción de riesgos distintos por la parte objeto de estudio. Véanse los párrafos 3.18 y 3.19 donde se trata la noción de parte analizada.”

1.41 Se ha observado en la práctica que el análisis de comparabilidad para los métodos basados en los indicadores de beneficios netos o brutos suele hacer más hincapié en las similitudes de las funciones que en las de los productos. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, puede aceptarse la ampliación del ámbito de comparabilidad para incluir operaciones no vinculadas relacionadas con productos diferentes, pero en las que se desarrollan funciones similares. No obstante, la aceptación de este criterio depende del efecto que provoquen las diferencias en la fiabilidad de la comparación y de si se dispone o no de más datos fiables. Antes de ampliar la búsqueda para incluir un mayor número de operaciones no vinculadas potencialmente comparables por razón del desarrollo de funciones similares, debe considerarse si es probable que tales operaciones constituyan comparables fiables para la operación vinculada.

D.1.2.2 Análisis funcional

1.42 En las operaciones comerciales entre dos empresas independientes, la remuneración refleja normalmente las funciones desempeñadas por cada empresa (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos). Por tanto, para determinar si son comparables entre sí operaciones vinculadas y no vinculadas, o entidades asociadas e independientes, es necesario realizar un análisis funcional. Este análisis funcional pretende identificar y comparar las actividades con trascendencia económica, las funciones ejercidas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes en la operación. A estos efectos, puede resultar útil comprender la estructura y organización del grupo y cómo estos influyen en el contexto en el que opera el contribuyente. También será relevante concretar los derechos y las obligaciones jurídicas del contribuyente en el ejercicio de sus funciones.

1.43 Las funciones que los contribuyentes y las administraciones tributarias pueden tener que identificar y comparar incluyen, por ejemplo, el diseño, la fabricación, el montaje, la investigación y el desarrollo, la prestación de servicios, las compras, la distribución, la comercialización, la publicidad, el transporte, la financiación y la gestión. Deben identificarse las principales funciones desarrolladas por la parte objeto de examen. Debe también procederse a un ajuste ante cualquier diferencia importante respecto de las actividades desarrolladas por cualquier empresa independiente con la que se compara esa parte. Aun cuando una de las partes asuma un número considerable de funciones en relación con las que lleva a cabo la otra parte que interviene en la operación, la importancia radica en su sustancia económica desde el punto de vista de su frecuencia, naturaleza y valor para los respectivos interesados.

1.44 El análisis funcional debe considerar el tipo de activos utilizados, tales como instalaciones y equipos, la utilización de intangibles valiosos, activos financieros, etc., y la naturaleza de los mismos, por ejemplo su antigüedad, el valor de mercado, la ubicación, la existencia de derechos sobre la propiedad industrial, etc.

1.45 Las operaciones y entidades vinculadas e independientes no son comparables entre sí cuando hay diferencias significativas en los riesgos asumidos, que no pueden ser objeto de un ajuste apropiado. El análisis funcional resultará incompleto, a menos que se consideren los principales riesgos asumidos por cada parte, ya que la asunción o la distribución de riesgos influye en las condiciones de las operaciones entre empresas asociadas. Normalmente, en el mercado libre, la aceptación de un riesgo mayor se compensará con un aumento en los beneficios que se espera

obtener, aun cuando el rendimiento real aumentará o no dependiendo del grado en que se materialice efectivamente el riesgo.

1.46 Los riesgos que deben considerarse comprenden los del mercado, tales como las fluctuaciones en los costes de los factores de producción y en los precios de los productos; los de ganancias o pérdidas asociadas a la inversión en propiedad, planta y equipo y a su uso; los derivados del éxito o fracaso de las inversiones en investigación y desarrollo; los riesgos financieros, como los motivados por la inestabilidad de los tipos de cambio de moneda y de los tipos de interés; los riesgos crediticios, etc.

1.47 Las funciones ejercidas (considerando los activos utilizados y los riesgos asumidos) determinan hasta cierto punto la distribución del riesgo entre las partes y, por tanto, las condiciones que cada una de ellas puede esperar en las operaciones efectuadas en condiciones de plena competencia. Por ejemplo, cuando un distribuidor se responsabiliza de la comercialización y de la publicidad, arriesgando sus propios medios en dichas actividades, la retribución correspondiente a esta actividad se incrementará proporcionalmente, y las condiciones de la operación no serán las mismas que si el distribuidor se limita a intervenir como un agente, al que se reembolsan los costes y recibe una retribución adecuada a dicha actividad. De forma similar, un fabricante o un investigador por contrato y que no asuma riesgos importantes recibirán, por lo general, una remuneración limitada.

1.48 Conforme al análisis que se propone más adelante en relación con las cláusulas contractuales, es posible considerar si una pretendida atribución de riesgos resulta o no coherente con la sustancia económica de la operación. A este respecto, la conducta de las partes debería entenderse, con carácter general, como la mejor evidencia de la verdadera atribución de los riesgos. Si, por ejemplo, un fabricante vende bienes a un distribuidor asociado en otro país y en el contrato se afirma que el distribuidor es quien asume todos los riesgos derivados del tipo de cambio en relación con esta operación vinculada, pero el precio de transferencia parece de hecho ajustado de forma que el distribuidor está protegido de las oscilaciones del tipo de cambio, entonces las administraciones tributarias podrían cuestionar la pretendida atribución del riesgo derivado del tipo de cambio en esta operación vinculada concreta.

1.49 Un factor adicional que hay que considerar a la hora de examinar la sustancia económica de la pretendida atribución de riesgos es la consecuencia que tendría dicha atribución en operaciones basadas en el principio de plena competencia. En general, en las operaciones realizadas en condiciones de plena competencia, tiene más sentido que cada parte asuma

mayores cuotas de riesgo en aquellos aspectos sobre los que se tiene mayor control. Por ejemplo, supongamos que la sociedad A contrata con la sociedad B la producción y el envío de bienes. A la sociedad B le corresponde decidir el nivel de producción y envío. En tal caso, no parece probable que la sociedad A esté dispuesta a asumir muchos riesgos respecto de las existencias al no controlar su nivel, siendo la sociedad B la que lo fija. No cabe duda de que existen riesgos, como los que se producen a lo largo del ciclo económico, respecto de los cuales ninguna de las partes en la operación posee un control significativo y que, en condiciones de plena competencia, pudieran haberse asignado a cualquiera de ellas. Es necesario realizar algún tipo de análisis para determinar en la práctica en qué medida soporta tales riesgos cada una de las partes.

1.50 Cuando se plantea el grado en que cada una de las partes en la operación soporta los riesgos derivados de los tipos de cambio o de los tipos de interés, normalmente será necesario considerar si el contribuyente o el grupo multinacional desarrolla algún tipo de estrategia empresarial para minimizar o hacer frente a los riesgos mencionados. En la actualidad son comunes las operaciones de cobertura, la negociación de futuros entre las partes sin intervención de cámara de compensación (contrato de *forward*), las opciones de compra y de venta, los contratos de permuta financiera (*swap*) etc., concertadas tanto en mercados no organizados como con fines específicos. Los miembros de un grupo multinacional pueden utilizar igualmente mecanismos de cobertura con otras empresas asociadas, especialmente en el sector financiero. Si una parte que soporta un riesgo de mercado importante declina cubrir su exposición, esto puede ser consecuencia de que asuma el riesgo, o de que haya decidido aceptar que sea otra empresa dentro del grupo multinacional la que cubra el riesgo. Estas u otras estrategias relacionadas con la cobertura o no cobertura de los riesgos pueden inducir a una determinación del resultado errónea en una jurisdicción determinada en caso de no tenerse en cuenta debidamente en el análisis de los precios de transferencia.

1.51 En algunos casos se ha argumentado que la imprecisión del análisis funcional de los posibles comparables externos (como se definen en el párrafo 3.24) puede contrarrestarse con el tamaño de la muestra de datos sobre terceras partes; sin embargo, la cantidad no puede compensar la pobre calidad de los datos cuando se pretende un análisis suficientemente fiable. Véanse los párrafos 3.2, 3.38 y 3.46.

D.1.2.3 Cláusulas contractuales

1.52 En las operaciones efectuadas en condiciones de plena competencia, las cláusulas contractuales definen generalmente, de forma expresa o implícita, cómo se reparten las responsabilidades, riesgos y resultados entre las partes. En este sentido, el examen de los términos contractuales debe formar parte del análisis funcional al que nos hemos referido anteriormente. Las cláusulas de una operación se pueden encontrar, además de en el contrato escrito, en la correspondencia y en las comunicaciones entre las partes. Cuando no consten por escrito las condiciones contractuales entre las partes, habrá que deducirlas de su conducta y de los principios económicos que normalmente rigen las relaciones entre empresas independientes.

1.53 En las relaciones comerciales entre empresas independientes, las diferencias de intereses entre las partes aseguran que normalmente sean ellas mismas quienes velen por el cumplimiento de los términos del contrato, que sólo se ignorarán o modificarán si resulta de interés para ambas. Esta divergencia de intereses puede no existir en el caso de empresas asociadas, por lo que es importante examinar si el proceder de las partes es conforme con las condiciones del contrato, o si este indica que no se han seguido, o que son simuladas. En estos casos es necesario realizar un análisis más minucioso que determine las verdaderas condiciones de la operación.

1.54 En la práctica, la información relativa a las condiciones contractuales de operaciones no vinculadas potencialmente comparables puede ser limitada, o inaccesible, especialmente cuando el análisis se apoya en comparables externos. La importancia de la falta de información en el análisis de la comparabilidad depende del tipo de operación analizada y del método de determinación del precio de transferencia utilizado, véase el párrafo 1.38. Por ejemplo, si la operación vinculada es un contrato de licencia para la explotación de derechos sobre la propiedad intelectual y el método utilizado es el del precio libre comparable, cabe suponer que la información relativa a las principales cláusulas contractuales de las licencias entre partes independientes, tales como la duración de la licencia, la zona geográfica, la exclusividad, etc., es crítica para valorar si dichas licencias entre partes independientes ofrecen comparables fiables para la operación vinculada.

D.1.2.4 Circunstancias económicas

1.55 Los precios de plena competencia pueden variar entre mercados diferentes incluso para operaciones referidas a unos mismos bienes o

servicios; por tanto, para lograr la comparabilidad se requiere que los mercados en que operan las empresas independientes y las asociadas no presenten diferencias que incidan significativamente en los precios, o que se puedan realizar los ajustes apropiados. Como primer paso, resulta esencial identificar el mercado o los mercados considerando los bienes y servicios alternativos disponibles. Las circunstancias económicas que pueden ser relevantes para determinar la comparabilidad de los mercados son: su localización geográfica; su dimensión; el grado de competencia y la posición competitiva relativa de compradores y vendedores; la disponibilidad (el riesgo) de bienes y servicios alternativos; los niveles de oferta y demanda en el mercado en su totalidad, así como en determinadas zonas, si son relevantes; el poder adquisitivo de los consumidores, la naturaleza y alcance de la reglamentación del mercado; los costes de producción, incluyendo los costes del suelo, del trabajo y del capital; los costes de transporte; el nivel de mercado (por ejemplo, venta al por menor o al por mayor); la fecha y el momento de la operación, etc. Los hechos y circunstancias del caso concreto determinarán si las diferencias en las circunstancias económicas inciden significativamente sobre el precio, y si pueden realizarse ajustes razonablemente precisos para eliminar los efectos de tales diferencias. Véase el párrafo 1.38.

1.56 La existencia de un ciclo (económico, comercial o del producto) es una de las circunstancias económicas que pueden afectar a la comparabilidad. Véase el párrafo 3.77 en relación con el uso de datos plurianuales en los que se observan ciclos.

1.57 El mercado geográfico es otra circunstancia económica que puede afectar a la comparabilidad. La identificación del mercado pertinente es una cuestión de hecho. Para un cierto número de sectores, los grandes mercados regionales que incluyen a más de un país pueden resultar razonablemente homogéneos, mientras que para otros, las diferencias entre los mercados nacionales (e incluso dentro de un único mercado nacional) son muy significativas.

1.58 En los casos en los que un grupo multinacional realice operaciones vinculadas similares en diversos países y las situaciones económicas de estos países sean efectivamente homogéneas, puede resultar apropiado que este grupo multinacional recurra a un análisis de comparabilidad multi-país a fin de justificar su política en materia de precios de transferencia en ese grupo de países. Sin embargo, existen también numerosas situaciones en las que un grupo multinacional ofrece gamas de productos o de servicios significativamente distintos en cada uno de esos países, o desarrolla funciones también significativamente distintas en cada uno de ellos (utilizando activos y asumiendo riesgos significativamente distintos), o

situaciones en las que las estrategias empresariales o las circunstancias económicas son significativamente distintas. En estos casos el criterio multi-país puede reducir la fiabilidad del análisis.

D.1.2.5 Estrategias empresariales

1.59 También es necesario examinar las estrategias empresariales al determinar la comparabilidad con el fin de fijar los precios de transferencia. Estas atienden un gran número de aspectos propios de la empresa, como pueden ser la innovación y el desarrollo de nuevos productos, el grado de diversificación, la aversión al riesgo, la valoración de los cambios políticos, la incidencia de las leyes laborales vigentes y en proyecto, la duración de los acuerdos, así como cualesquiera otros factores que influyen en la gestión cotidiana de la empresa. Puede ser necesario tener en cuenta estas estrategias empresariales al determinar la comparabilidad entre operaciones vinculadas y no vinculadas y entre empresas asociadas e independientes.

1.60 Entre las estrategias empresariales también pueden incluirse las modalidades de penetración en los mercados. Un contribuyente que intenta penetrar en un mercado, o incrementar su cuota en el mismo, podría facturar temporalmente sus productos con precios inferiores a los cobrados por cualquier otro producto comparable en el mismo mercado. Más aun, cualquier contribuyente que pretenda entrar en un mercado o aumentar (o proteger) su cuota en el mismo podría, temporalmente, incurrir en costes mayores (por ejemplo, debido a costes de inicio de la actividad o al aumento de su presupuesto para comercialización) obteniendo por tanto unos niveles de beneficios inferiores a los de otros contribuyentes que operan en el mismo mercado.

1.61 El marco temporal puede crear problemas concretos a las administraciones tributarias a la hora de valorar si el contribuyente sigue una estrategia empresarial que le diferencia respecto de otras empresas potencialmente comparables. Algunas de estas estrategias, como las que se refieren a la penetración en mercados, o al aumento de cuotas de participación en el mismo, implican la reducción de los beneficios actuales del contribuyente en previsión del aumento de beneficios en el futuro. Si en el futuro no se logra ese incremento en los beneficios porque el contribuyente no siguió la estrategia empresarial propuesta, puede suceder que ciertos imperativos legales impidan a las administraciones tributarias proceder a una nueva comprobación de los períodos impositivos anteriores. Al menos en parte por esta razón, las administraciones tributarias tal vez quieran someter la cuestión de las estrategias empresariales a un examen particular.

1.62 A la hora de valorar si un contribuyente sigue una estrategia empresarial por la que temporalmente obtiene beneficios menores en espera de mejores resultados a largo plazo, deben considerarse diversos factores. Las administraciones tributarias deben examinar el comportamiento de las partes para determinar si es consecuente con la estrategia empresarial declarada. Por ejemplo, si un fabricante factura a su distribuidor asociado un precio inferior al normal de mercado como parte de su estrategia de penetración en el mismo, el ahorro de costes del distribuidor debería reflejarse en el precio facturado a sus propios clientes o en la incursión en mayores costes destinados a la introducción en el mercado. La estrategia de penetración en el mercado de un grupo multinacional pueden llevarla a la práctica el fabricante o el distribuidor, que actúa con independencia del fabricante (pudiendo cualquiera de ellos soportar el coste). Además, una estrategia de penetración en el mercado o de aumento de la cuota de participación en el mismo va acompañada, con frecuencia, de intensos esfuerzos de comercialización y publicidad. Otro factor que debe considerarse es si la naturaleza de las relaciones entre las partes en la operación vinculada es coherente con la situación del contribuyente que soporta los costes de la estrategia empresarial. Por ejemplo, en condiciones de plena competencia, una sociedad que actúa únicamente como agente de ventas, con poca o ninguna responsabilidad sobre su evolución en el mercado a largo plazo, normalmente no soportaría los costes de las estrategias utilizadas para introducirse en él. Cuando una sociedad emprenda actividades de desarrollo de mercado asumiendo el riesgo, y aumente el valor de un producto a través de una marca o un nombre comercial, o incremente el fondo de comercio asociado a ese producto, esta circunstancia deberá reflejarse en el análisis de funciones realizado a los efectos de determinar la comparabilidad.

1.63 Otro aspecto que habría que considerar es si existe una expectativa razonable de obtener unos ingresos suficientes que justifiquen los costes incurridos con dicha estrategia empresarial en un plazo que sería aceptable en una operación en plena competencia. Se admite que una estrategia empresarial dirigida a la introducción en un mercado puede ser infructuosa sin que este fracaso deba conducir a que se ignore a los efectos de la determinación del precio de transferencia. Sin embargo, cabe dudar de la condición de plena competencia de la estrategia si dicho resultado esperado no es factible en el momento en que se realiza la operación, o si la estrategia empresarial alegada es un fracaso y, a pesar de ello, sigue utilizándose más allá de lo que una empresa independiente aceptaría. Las administraciones tributarias tal vez deseen considerar las estrategias empresariales practicadas en el país en que se desarrollan para determinar el plazo que sería aceptable para una empresa independiente. Sin embargo, la consideración más

importante, en definitiva, es si sería razonable esperar que la estrategia en cuestión resulte rentable en un futuro previsible (aun reconociendo que la estrategia pudiera fracasar) y si un tercero que operase en condiciones de plena competencia hubiera estado dispuesto a renunciar a una determinada rentabilidad durante un período similar en las mismas circunstancias económicas y condiciones de competencia.

D.2 *Aceptación de las operaciones realmente efectuadas*

1.64 La comprobación por parte de una administración tributaria de una operación vinculada debe basarse normalmente en las operaciones realmente efectuadas por las empresas asociadas, tal y como estas las hayan estructurado, utilizando los métodos que los contribuyentes han aplicado, siempre que sean coherentes con los descritos en el Capítulo II. Salvo en casos excepcionales, las administraciones tributarias no deben ignorar las operaciones reales ni sustituirlas por otras. La reestructuración de operaciones empresariales legítimas constituiría un ejercicio totalmente arbitrario, agravado por la doble imposición que se generaría cuando la otra administración tributaria no comparta el mismo punto de vista sobre cómo debería estructurarse la operación.

1.65 Sin embargo, hay dos circunstancias particulares en las que, excepcionalmente, puede resultar apropiado y legítimo que la administración tributaria ignore la estructura planteada por el contribuyente para la realización de la operación vinculada. La primera circunstancia surge cuando la sustancia económica de la operación difiere de su forma. En tal caso, las administraciones tributarias pueden ignorar la calificación que las partes hayan otorgado a la operación y recalificarla de acuerdo con su sustancia. Un ejemplo podría ser una inversión en una empresa asociada en forma de préstamo con devengo de intereses cuando, en plena competencia, en función de las circunstancias económicas de la sociedad prestataria, no cabría esperar que la inversión adoptara esa forma. En este caso sería oportuno que la administración tributaria calificase la inversión de acuerdo con su sustancia económica, con el resultado de considerar al préstamo como una suscripción de capital. La segunda circunstancia surge cuando, coincidiendo la forma y el fondo de la operación, los acuerdos relativos a la misma, valorados globalmente, difieren de los que habrían suscrito empresas independientes que actuaran de modo racional desde un punto de vista comercial, y su estructura real impide en la práctica que la administración tributaria determine el precio de transferencia apropiado. Un ejemplo de esta segunda circunstancia podría ser una venta mediante un contrato a largo plazo en el que se realiza un pago único a cambio de un derecho ilimitado

sobre la propiedad intelectual que resulte de investigaciones futuras durante la vigencia del contrato (como se indicó anteriormente en el párrafo 1.11). Mientras que en este caso parece oportuno respetar la calificación de la operación como una transmisión de activo comercial, sin embargo sería apropiado que la administración tributaria ajustara las condiciones del contrato en su totalidad (y no únicamente en lo que a la fijación del precio respecta) de acuerdo con las que hubiera sido razonable esperar si la transmisión del activo hubiera constituido el objeto de una operación entre empresas independientes. Así, en el caso descrito, sería apropiado que la administración tributaria ajustara, por ejemplo, las condiciones del acuerdo de manera racional desde un punto de vista comercial, como si se tratara de un acuerdo permanente de investigación.

1.66 En ambos conjuntos de circunstancias, el carácter de la operación puede provenir de las relaciones entre las partes, más que de las condiciones comerciales habituales, y puede haber sido estructurada por el contribuyente para eludir o minimizar impuestos. En tales casos, todas las cláusulas serían el resultado de una condición a la que no se habría llegado si las partes hubieran negociado en condiciones de plena competencia. De este modo, el artículo 9 permitiría un ajuste en las condiciones para reflejar aquéllas a las que las partes se hubieran atenido en caso de que la operación se hubiera estructurado de acuerdo con la realidad económica y comercial de quienes negocian en un contexto de plena competencia.

1.67 Las empresas asociadas pueden realizar una mayor variedad de contratos y acuerdos que las independientes, pues no suele existir el conflicto de intereses normalmente presente entre partes independientes. Las empresas asociadas pueden concluir, y frecuentemente lo hacen, contratos de una naturaleza muy concreta que rara vez, o nunca, se encuentran entre partes no vinculadas. Así puede ser por diversas razones, económicas, legales o fiscales, dependiendo de las circunstancias de cada caso en particular. Más aun, los contratos celebrados en el seno de un grupo multinacional podrían alterarse, suspenderse, ampliarse o resolverse con facilidad, según la estrategia global del grupo multinacional en su conjunto; alteraciones que incluso pueden tener carácter retroactivo. En estos casos, al aplicar el principio de plena competencia, las administraciones tributarias tendrían que determinar cuál es la realidad que subyace al acuerdo contractual.

1.68 Además, las administraciones tributarias pueden encontrar útil referirse a operaciones entre empresas independientes estructuradas de otro modo para determinar si la estructura de una operación vinculada satisface el principio de plena competencia. El hecho de que se puedan considerar o no los datos que arroje una alternativa concreta dependerá de los hechos y de las circunstancias de cada caso, incluyendo el número y la precisión de los

ajustes necesarios para salvar las diferencias entre la operación vinculada y su alternativa, así como de la fiabilidad de cualquier otro dato disponible.

1.69 En el siguiente ejemplo se muestra la diferencia existente entre la reestructuración de una operación vinculada objeto de revisión que, como se indicó anteriormente, es inapropiado con carácter general, y la utilización de operaciones estructuradas de otra forma como operaciones no vinculadas comparables. Supongamos que un fabricante vende bienes a un distribuidor asociado situado en otro país y que este acepta todos los riesgos del cambio de moneda derivados de estas operaciones. Supongamos también que las operaciones similares concertadas entre fabricantes y distribuidores independientes se estructuran de manera diferente, de tal forma que es el fabricante y no el distribuidor quien soporta todos los riesgos del tipo de cambio. En tal caso, la administración tributaria no debería ignorar la intención de asignar el riesgo al distribuidor asociado, salvo que haya buenas razones para dudar de la esencia económica de la asunción del riesgo de cambio por este. El hecho de que las empresas independientes no estructuren sus operaciones de una determinada manera puede ser una razón para examinar de cerca la lógica económica de una estructura determinada, pero no debería ser concluyente. Sin embargo, las operaciones no vinculadas con una estructura distinta de asignación de los riesgos de cambio pueden ser útiles en la determinación del precio de la operación vinculada, quizás acudiendo al método del precio libre comparable, siempre que se puedan realizar ajustes en los precios suficientemente precisos como para reflejar la diferente estructuración de las operaciones.

D.3 Pérdidas

1.70 Cuando una empresa asociada incurre en pérdidas constantemente mientras que el grupo multinacional en su conjunto es rentable, cabe plantearse realizar un examen especial en lo relativo a la determinación de los precios de transferencia. Naturalmente, las empresas asociadas, lo mismo que las empresas independientes, pueden sufrir pérdidas reales, ya sea debido a altos costes de inicio de actividad, a circunstancias económicas desfavorables, a ineficiencias o a otras razones comerciales legítimas. Sin embargo, una empresa independiente no estaría dispuesta a soportar pérdidas indefinidamente. Una empresa independiente que incurriera en pérdidas recurrentes cesaría en algún momento sus actividades; por el contrario, una empresa asociada que arroja pérdidas puede continuar su actividad si esta beneficia al grupo multinacional en su conjunto.

1.71 El hecho de que una empresa que incurra en pérdidas realice negocios con otros miembros rentables de su grupo multinacional podría

sugerir a los contribuyentes o a las administraciones tributarias la necesidad de examinar los precios de transferencia. Puede ser que la empresa con pérdidas no esté siendo retribuida adecuadamente por el grupo multinacional del que forma parte teniendo en cuenta los beneficios derivados de sus actividades. Por ejemplo, un grupo multinacional puede necesitar la producción de toda una línea de productos o servicios si quiere seguir siendo competitiva y obtener un beneficio global, pero puede ocurrir que alguna línea concreta de productos sea habitualmente deficitaria. Un miembro del grupo multinacional podría tener pérdidas continuas porque produce todos los productos deficitarios, mientras que otros miembros del mismo fabrican los productos generadores de beneficios. Una empresa independiente prestaría dicho servicio sólo si estuviera retribuida adecuadamente. En consecuencia, una forma de afrontar este problema de determinación de precios de transferencia consistiría en considerar que la empresa deficitaria recibe la misma remuneración que la que obtendría una empresa independiente conforme al principio de plena competencia.

1.72 Un factor que hay que considerar en el análisis de las pérdidas es la diferencia que puede existir entre las estrategias empresariales de los distintos grupos multinacionales por varias razones de orden histórico, económico y cultural. Puede ser que las pérdidas recurrentes durante un período razonable estén justificadas, en algunos casos, por el desarrollo de una estrategia empresarial consistente en fijar precios especialmente bajos para lograr la penetración en el mercado. Por ejemplo, un productor podrá bajar los precios de sus productos, incluso hasta el punto de incurrir en pérdidas temporalmente, para poder entrar en nuevos mercados, incrementar su cuota en mercados ya existentes, introducir nuevos productos o servicios, o desalentar a posibles competidores. Aun así, unos precios especialmente bajos sólo serían soportables durante un período limitado, con el objetivo concreto de mejorar los resultados a largo plazo. Si la estrategia de precios se prolonga más allá de un período razonable, resultaría procedente un ajuste de precios de transferencia, en particular cuando los datos comparables de varios años muestran que se ha incurrido en pérdidas durante un período más largo del que soportan las empresas independientes comparables. Más aun, las administraciones tributarias no deberían aceptar precios especialmente bajos (por ejemplo, determinaciones de precios iguales al coste marginal en una situación de capacidades de producción infrautilizadas) como precios de plena competencia, salvo que pudiera esperarse que las empresas independientes hubieran determinado sus precios de forma comparable.

D.4 Efectos de las decisiones de los poderes públicos

1.73 Hay algunas situaciones en las que los contribuyentes pretenderán que el precio de plena competencia debe ajustarse a fin de reflejar ciertas intervenciones estatales, como puedan ser los controles en los precios (incluidos los recortes en los precios), en los tipos de interés, en los pagos de servicios u honorarios de dirección, en los pagos en concepto de cánones, subsidios a determinados sectores, controles de cambios, derechos anti-dumping o políticas de los tipos de cambio. Como regla general, estas intervenciones de los poderes públicos deben tratarse como factores del mercado de un determinado país y, en condiciones normales, se tendrán en cuenta en la determinación de los precios de transferencia del contribuyente en ese mercado. Lo que hay que dilucidar, a la luz de esos factores, es si las operaciones emprendidas por las empresas asociadas son coherentes con las efectuadas entre empresas independientes.

1.74 Se plantea la cuestión de determinar el momento en el que un control en los precios afecta al precio de un producto o de un servicio. Con frecuencia, la incidencia directa se producirá en el precio final para el consumidor pero, aun así, puede producirse algún efecto en los precios pagados en fases anteriores durante el suministro de productos al mercado. En la práctica puede ocurrir que las multinacionales no realicen ajustes en sus precios de transferencia que reflejen la existencia de esos controles, dejando que sea el vendedor final quien padezca las consecuencias de las posibles reducciones de beneficios, o que carguen precios que de alguna manera permitan distribuir esa carga entre el vendedor final y el proveedor intermediario. Debe considerarse si un proveedor independiente hubiera participado o no en los costes derivados de un control de precios y si una empresa independiente hubiera buscado una línea de productos alternativa u otras oportunidades empresariales. En este sentido, no parece posible que una empresa independiente estuviera preparada para producir, distribuir o proveer de otra forma productos o servicios en condiciones tales que no le hubieran reportado beneficios. Sin embargo, es obvio que un país con controles en los precios debe tener en cuenta que esos controles afectarán a los beneficios que pueden obtener las empresas que venden bienes sujetos a ellos.

1.75 Se plantea un problema peculiar cuando un país impide o “bloquea” el pago de un importe debido por una empresa asociada a otra o que, en un acuerdo en condiciones de plena competencia, hubiera facturado una empresa asociada a otra. Por ejemplo, los controles de cambio pueden impedir efectivamente que una empresa asociada transmita pagos de intereses al exterior, derivados de un préstamo concedido por otra empresa

asociada situada en otro país. Esta circunstancia puede valorarse de manera diferente en los dos países involucrados: el del prestatario puede considerar o no que los intereses no transmitidos se han pagado, y el del prestamista puede considerar o no que este los haya recibido. Como regla general, cuando la intervención de los poderes públicos se aplica por igual a operaciones entre empresas asociadas y entre empresas independientes (tanto de hecho como de derecho), la cuestión, cuando surge entre empresas asociadas, debe abordarse de la misma manera a efectos fiscales que cuando se plantea respecto de operaciones entre empresas independientes. En el caso de que la intervención pública se aplique sólo a operaciones entre empresas asociadas, no hay una solución sencilla. Quizás una forma de afrontar el problema sea aplicar el principio de plena competencia considerando la intervención como un factor que afecta a las condiciones de la operación. Los convenios internacionales podrían abordar expresamente las soluciones a disposición de los co-signatarios del convenio cuando se den estas circunstancias.

1.76 Este análisis plantea como dificultad el que, con frecuencia, las empresas independientes no concertarían operaciones en las que los pagos estuvieran bloqueados. Ocasionalmente, una empresa independiente puede verse envuelta en una operación de tal naturaleza, posiblemente porque la intervención estatal se imponga tras la concertación del acuerdo. Pero parece poco probable que una empresa independiente desee someterse a tan alto riesgo de impago de productos suministrados, o de servicios prestados, suscribiendo un acuerdo cuando ya existan rígidas medidas de intervención, salvo que los beneficios previstos o la remuneración que espera recibir la empresa independiente de la estrategia empresarial propuesta sean suficientes para generar un rendimiento aceptable, a pesar de la existencia de la intervención estatal que pueda afectar a los pagos.

1.77 Dado que las empresas independientes no concertarían operaciones sujetas a intervenciones estatales, no resulta evidente cómo operaría el principio de plena competencia. Una posibilidad es tratar el pago como si hubiera sido efectuado entre las empresas asociadas, suponiendo que una empresa independiente en circunstancias similares hubiera insistido en que el pago se efectuase por otros medios. Desde esta perspectiva, se trataría a la parte a la que se le debe el pago que está bloqueado como si estuviera prestando un servicio al grupo multinacional. Otra opción, posible en algunos países, sería diferir tanto la renta como los gastos pertinentes del contribuyente. Dicho de otro modo, la parte a la que se debe el pago bloqueado no podrá deducir gastos, como los costes financieros adicionales, hasta que no se realice el pago bloqueado. La preocupación de las administraciones tributarias en estas situaciones radica básicamente en sus

respectivas bases imponibles. Si una empresa asociada reclama una deducción en el cálculo del impuesto por un ingreso bloqueado, entonces debe contabilizarse la renta correspondiente en la otra parte. En cualquier caso, no se debería permitir que un contribuyente tratara los pagos bloqueados debidos por una empresa asociada de forma diferente que los pagos bloqueados debidos por una empresa independiente.

D.5 Utilización del valor de aduana

1.78 Con carácter general, el principio de plena competencia se aplica por muchas administraciones de aduanas como principio para comparar el valor atribuible a bienes importados por empresas asociadas, que puede estar afectado por la relación especial existente entre ellas, y el valor de bienes similares importados por empresas independientes. Los métodos de valoración a los efectos de aduanas pueden no coincidir con los métodos de determinación de precios de transferencia de la OCDE. Una vez aclarado esto, los valores de aduana pueden resultar útiles a las administraciones tributarias en la evaluación de la condición de plena competencia del precio de transferencia de la operación vinculada, y viceversa. En particular, las autoridades aduaneras dispondrán de documentación contemporánea relativa a la operación, que puede ser relevante en el examen de los precios de transferencia, especialmente si la ha elaborado el contribuyente, a la vez que las autoridades fiscales pueden disponer de información detallada sobre las circunstancias de la operación.

1.79 Los contribuyentes pueden tener motivaciones contrarias al fijar los valores a efectos aduaneros y fiscales. En general, un contribuyente que importa bienes puede estar interesado en fijar un precio bajo para la operación a fin de que los derechos de aduana también lo sean (las mismas consideraciones podrían surgir respecto de los impuestos sobre el valor añadido, los impuestos sobre ventas y los impuestos especiales). Sin embargo, a efectos fiscales, el contribuyente puede querer declarar el pago de un precio más alto por los mismos bienes con el objeto de incrementar los gastos deducibles en el país de importación (si bien esto podría aumentar igualmente el volumen de ventas del vendedor en el país de exportación). La cooperación entre administraciones tributarias y aduaneras dentro de un país para evaluar los precios de transferencia es cada vez más frecuente, y debería ayudar a reducir el número de casos en los que la valoración en aduana no es aceptable a efectos fiscales o viceversa. Sería particularmente provechosa una mayor cooperación en el área del intercambio de información, y no debería ser difícil de conseguir en aquellos países en los que han integrado la administración de los impuestos sobre la renta y de los derechos de aduana.

Los países que tienen administraciones separadas podrían considerar la modificación de las normas relativas al intercambio de información, de tal manera que esta pueda fluir con mayor facilidad entre las distintas administraciones.

Capítulo II

Metodología para la determinación de los precios de transferencia

Parte I: Selección del método de determinación de los precios de transferencia

A. Selección del método de determinación de precios de transferencia más adecuado a las circunstancias del caso

2.1 En las Partes II y III de este capítulo se describen respectivamente “los métodos tradicionales basados en las operaciones” y los “métodos basados en el resultado de las operaciones” que pueden utilizarse para determinar si las condiciones impuestas en las relaciones comerciales o financieras entre empresas asociadas son coherentes con el principio de plena competencia. Los métodos tradicionales basados en las operaciones son el método del precio libre comparable, el método del precio de reventa y el método del coste incrementado. Los métodos basados en el resultado de las operaciones son el método del margen neto operacional y el método de la distribución del resultado.

2.2 La selección de un método de determinación de precios de transferencia aspira en todos los casos a la selección del método más apropiado para las circunstancias concretas analizadas. Para que así sea, el proceso de selección debe ponderar las ventajas e inconvenientes de los métodos aceptados por la OCDE, la corrección del método considerado en vista de la naturaleza de la operación vinculada (determinada mediante un análisis funcional), la disponibilidad de información fiable (en concreto sobre comparables no vinculados) necesaria para aplicar el método seleccionado u otros, y el grado de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas (incluyendo la fiabilidad de los ajustes de comparabilidad necesarios para eliminar las diferencias importantes que existan entre ellas). No existe un único método apropiado para todas las situaciones, y tampoco es necesario demostrar que un método concreto no es adecuado atendiendo a las circunstancias analizadas.

2.3 Se considera que los métodos tradicionales basados en las operaciones son el medio más directo para determinar si las condiciones de

las relaciones comerciales o financieras de las empresas asociadas se ajustan al principio de plena competencia. Esto es así porque cualquier diferencia entre el precio de una operación vinculada y el de una operación comparable no vinculada puede imputarse directamente a las relaciones comerciales o financieras aceptadas o impuestas entre las empresas, pudiendo determinar las condiciones de plena competencia sustituyendo directamente el precio de la operación vinculada por el de la no vinculada. Por tanto, cuando teniendo en cuenta los criterios citados en el párrafo 2.2, pueda aplicarse de forma igualmente fiable un método tradicional basado en las operaciones y un método basado en el resultado, es preferible recurrir a los métodos tradicionales basados en las operaciones. De forma similar cuando, teniendo en cuenta los criterios descritos en el párrafo 2.2, pueda aplicarse el método del precio libre comparable y otro método de forma igualmente fiable, debe optarse por el primero. Véanse los párrafos 2.13 a 2.20, donde se analiza el método del precio libre comparable.

2.4 Hay situaciones en las que los métodos basados en el resultado de las operaciones resultan más apropiados que los métodos tradicionales basados en las operaciones. Por ejemplo, aquellos en los que cada una de las partes realiza aportaciones valiosas y únicas a la operación vinculada, o cuando las partes llevan a cabo actividades muy integradas, lo que puede hacer que el método de la distribución del resultado resulte mucho más apropiado que un método unilateral. Puede citarse otro ejemplo: cuando no se dispone de información pública y fiable sobre terceros en relación con el margen bruto, o esta es muy escasa, la aplicación de los métodos tradicionales basados en las operaciones puede resultar difícil salvo cuando existan comparables internos, por lo que los métodos basados en el resultado de las operaciones pueden ser los más apropiados a la vista de la información disponible.

2.5 Sin embargo, no resulta apropiado recurrir a un método basado en el resultado de las operaciones únicamente porque los datos relativos a las operaciones no vinculadas sean difíciles de obtener o incompletos en uno o más aspectos. Al evaluar la fiabilidad de los métodos basados en el resultado de las operaciones, deben volver a examinarse los mismos criterios citados en el párrafo 2.2 conducentes a la conclusión inicial de que no es posible aplicar de forma fiable un método tradicional basado en las operaciones en unas circunstancias concretas.

2.6 Los métodos basados en los resultados son aceptables únicamente en la medida en que resulten compatibles con el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, especialmente por lo que respecta a la comparabilidad. Esto se logra aplicando los métodos de forma que se aproximen a la determinación de precios de plena competencia. La

aplicación del principio de plena competencia se basa, por lo general, en una comparación del precio, el margen o los beneficios de una cierta operación vinculada con el precio, margen o beneficio de una operación comparable realizada entre empresas independientes. En el caso de un método de distribución del resultado, el principio de plena competencia se basa en una aproximación a la distribución de beneficios que realizarían empresas independientes si llevaran a cabo esas operaciones (véase el párrafo 2.108).

2.7 Los métodos basados en los resultados no deben aplicarse nunca de forma que generen una sobre-imposición de las empresas básicamente porque sus beneficios sean inferiores a la media, ni de forma que generen una menor imposición a aquellas empresas que obtienen un nivel de beneficios superior a la media. En el marco del principio de plena competencia no es justificable aplicar un impuesto adicional sobre las empresas que obtienen resultados más pobres que la media o, al contrario, una imposición menor sobre las empresas cuyos resultados son mejores que la media, cuando la razón de sus resultados, positivos o negativos, es atribuible a factores comerciales.

2.8 La directriz contenida en el párrafo 2.2, respecto a que la selección de un método de determinación de precios de transferencia debe aspirar siempre a optar por el método más apropiado en cada caso, no significa que deban analizarse en profundidad o probarse todos los métodos de determinación de precios de transferencia hasta poder seleccionar el más apropiado para cada caso. Como práctica correcta, la selección del método más apropiado y de los comparables debe fundamentarse adecuadamente e inscribirse en un proceso de búsqueda normalizado como se propone en el párrafo 3.4.

2.9 Además, los grupos multinacionales conservan la libertad de aplicar métodos no descritos en estas Directrices (denominados en lo sucesivo “otros métodos”) para determinar sus precios, siempre que estos satisfagan el principio de plena competencia en los términos descritos en estas Directrices. Sin embargo, estos otros métodos no deben usarse como sustitutivos de los métodos reconocidos por la OCDE cuando estos últimos resulten más apropiados en función de los hechos y circunstancias del caso. Cuando se recurra a los otros métodos, su elección debe estar fundamentada en una explicación de por qué se considera que los métodos reconocidos por la OCDE se consideran menos apropiados o inviables en unas circunstancias concretas, y la razón de por qué se considera que el otro método seleccionado ofrece una solución más satisfactoria. Los contribuyentes deben conservar la información relativa a la determinación de sus precios de transferencia y estar dispuestos a presentarla. Véase el Capítulo V en lo que se refiere a la documentación.

2.10 No es posible ofrecer unas pautas aplicables a todos los casos. Las administraciones tributarias deben plantearse la oportunidad de practicar ajustes menores o marginales. En general, las partes deben intentar lograr una solución razonable teniendo en cuenta la imprecisión de los distintos métodos, la preferencia por los niveles más altos de comparabilidad y por el vínculo más directo y estrecho posible con la operación. No debe aplicarse un criterio de comparabilidad demasiado rígido que obligue a rechazar información útil, como la que se desprende de las operaciones no vinculadas que no son idénticas a las operaciones vinculadas objeto de estudio, sólo por ese motivo. Del mismo modo, la información procedente de empresas que llevan a cabo operaciones vinculadas con empresas asociadas puede resultar útil para entender la operación revisada o como pista para iniciar una investigación más detallada. En este sentido, debe permitirse la aplicación de cualquier método siempre que resulte correcto a juicio de todos los miembros del grupo multinacional que intervienen en la operación u operaciones a las que vaya a aplicarse esa metodología, así como a las administraciones tributarias correspondientes a esos miembros del grupo multinacional.

B. Utilización de más de un método

2.11 El principio de plena competencia no exige la aplicación de más de un método en una operación concreta (o conjunto de operaciones debidamente agregadas siguiendo los criterios expuestos en el párrafo 3.9), y, de hecho, creer indebidamente en la necesidad de recurrir a más de un método puede suponer una carga importante para los contribuyentes. Así, estas Directrices no exigen, ni a los inspectores ni al contribuyente, practicar los análisis exigidos por más de un método. Si bien en algunos casos la selección de un método puede no ser directa, siendo preciso considerar al principio más de uno, en general será posible seleccionar un método apto para llegar a la mejor estimación posible de los precios de plena competencia. En casos complicados, sin embargo, cuando los criterios aplicados no resulten concluyentes, un acercamiento flexible permitiría usar conjuntamente los datos extraídos de la aplicación de distintos métodos. En estos casos debe intentarse llegar a una conclusión coherente con el principio de plena competencia que sea satisfactoria desde un punto de vista práctico para todas las partes interesadas, teniendo en cuenta los hechos y circunstancias del caso, la diversidad de los datos disponibles y la fiabilidad relativa de los distintos métodos considerados. En los párrafos 3.58 y 3.59 se analizan los casos en los que se maneja un rango de datos resultantes de la aplicación de más de un método.

Parte II: Métodos tradicionales basados en las operaciones

A. Introducción

2.12 En este apartado se ofrece una descripción detallada de los métodos tradicionales basados en las operaciones que se utilizan en la aplicación del principio de plena competencia. Estos métodos son el método del precio libre comparable, el método del precio de reventa y el método del coste incrementado.

B. Método del precio libre comparable

B.1 Términos generales

2.13 El método del precio libre comparable consiste en comparar el precio facturado por bienes o servicios transmitidos o prestados en una operación vinculada con el precio facturado por bienes o servicios transmitidos o prestados en una operación no vinculada comparable en circunstancias también comparables. Si hay diferencias entre los dos precios, esto puede indicar que las condiciones de las relaciones comerciales y financieras de las empresas asociadas no se ajustan a las de plena competencia y que el precio de la operación vinculada tal vez tenga que sustituirse por el precio de la operación no vinculada.

2.14 Conforme a los principios expuestos en el Capítulo I, una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada (esto es, se trata de una operación no vinculada comparable) a los efectos del método del precio libre comparable, si se cumple una de las dos condiciones siguientes: a) ninguna de las diferencias (si las hubiera) entre las dos operaciones que se comparan, o entre las dos empresas que llevan a cabo esas operaciones, influye significativamente en el valor normal de mercado; o b) pueden realizarse ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos importantes que provoquen esas diferencias. Cuando sea posible encontrar operaciones no vinculadas comparables, el método del precio libre comparable es el camino más directo y fiable para aplicar el principio de plena competencia. Por tanto, en esos casos, este método es preferible a los demás.

2.15 Puede resultar difícil encontrar una operación entre empresas independientes lo suficientemente parecida a una operación vinculada como para que no existan diferencias que tengan un efecto importante sobre el precio. Por ejemplo, una diferencia menor entre los bienes transmitidos en las operaciones vinculadas y no vinculadas podría afectar sustancialmente al precio, aunque la naturaleza de las actividades económicas emprendidas pueda asemejarse lo suficiente como para generar el mismo margen global de beneficio. De ser así, debe procederse a practicar ajustes. Como se analiza a continuación en el párrafo 2.16, el alcance y la precisión de esos ajustes afectarán a la fiabilidad relativa del análisis realizado en aplicación del método del precio libre comparable.

2.16 Al considerar si son comparables unas operaciones vinculadas con otras no vinculadas, debe tenerse en cuenta el efecto que tienen sobre los precios otras funciones más amplias de la empresa y no sólo el grado de comparabilidad del producto (es decir, los factores que determinan la comparabilidad vistos en el Capítulo I). Cuando existen diferencias entre la operación vinculada y la no vinculada o entre las empresas que efectúan tales operaciones, puede ser difícil llegar a unos ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos de esas diferencias sobre el precio. Las dificultades que surgen al intentar realizar estos ajustes precisos no deberían llevar a descartar automáticamente la posibilidad de la aplicación del método del precio libre comparable. Razones prácticas nos conducen a un criterio más flexible que permita la utilización del método del precio libre comparable, complementado si fuese necesario por otros métodos apropiados que deben valorarse según su precisión relativa. Debe hacerse todo lo posible para ajustar los datos de forma que puedan utilizarse convenientemente en el método del precio libre comparable. Como sucede con cualquier otro método, la fiabilidad relativa del método del precio libre comparable está condicionada por el grado de precisión con que puedan realizarse los ajustes para lograr la comparabilidad.

B.2 Ejemplos de aplicación del método del precio libre comparable

2.17 Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación del método del precio libre comparable, incluyendo situaciones en las que puede resultar necesario realizar ajustes en las operaciones no vinculadas para convertirlas en operaciones no vinculadas comparables.

2.18 El método del precio libre comparable es especialmente fiable cuando una empresa independiente vende el mismo producto que el vendido entre dos empresas asociadas. Por ejemplo, una empresa independiente vende granos de café de Colombia sin marca, de clase, calidad y en cantidad

similares a los vendidos entre dos empresas asociadas, suponiendo que la operación vinculada y la no vinculada ocurren más o menos contemporáneamente, en la misma fase de la cadena de producción/distribución, y en condiciones similares. Si la única operación no vinculada a la que puede recurrirse para efectuar la comparación fuera la realizada con granos de café de Brasil sin marca, sería necesario averiguar si la diferencia en los granos de café afecta significativamente al precio. Por ejemplo, habría que preguntarse si la procedencia de los granos de café implica una prima o un descuento en el mercado libre. Esta información se puede obtener en el mercado de materias primas o se puede deducir de los precios entre comerciantes. Si esta diferencia tiene un importante efecto sobre el precio habría que practicar ciertos ajustes. En caso de no poder hacer un ajuste lo suficientemente preciso se reducirá la fiabilidad de este método, pudiendo plantearse la necesidad de optar por un método menos directo.

2.19 Un caso ilustrativo de necesidad de ajustes es aquel en el que las circunstancias que rodean las ventas vinculadas y no vinculadas son idénticas, salvo por el hecho de que el precio de venta en la operación vinculada es un precio de entrega y el de la operación no vinculada es un precio F.O.B. (fábrica). Las diferencias en las condiciones del transporte y del seguro suelen tener un efecto observable y razonablemente cuantificable sobre el precio. Por tanto, para determinar el precio de las ventas en el mercado libre se deben efectuar ajustes en el precio que subsanen las diferencias en las condiciones de la entrega.

2.20 Pongamos otro ejemplo. Supongamos que un contribuyente vende 1.000 toneladas de un producto a \$80 por tonelada a una empresa asociada de su grupo multinacional y, al mismo tiempo, 500 toneladas del mismo producto a \$100 por tonelada a una empresa independiente. Este caso exige valorar si la diferencia en el volumen de las ventas daría como resultado un ajuste en el precio de transferencia. Sería preciso estudiar el mercado del que se tratara analizando las operaciones efectuadas con productos similares a fin de conocer los descuentos habituales aplicados en función del volumen.

C. Método del precio de reventa

C.1. Términos generales

2.21 El método del precio de reventa se inicia con el precio al que se ha adquirido a una empresa asociada un producto que se vende después a una empresa independiente. Este precio (el precio de reventa) se reduce en un margen bruto apropiado (el "margen del precio de reventa") representativo

de la cuantía con la que el revendedor pretende cubrir sus costes de venta y gastos de explotación y, dependiendo de las funciones desarrolladas (considerando los activos utilizados y los riesgos asumidos), obtener un beneficio apropiado. Lo que queda tras sustraer el margen bruto puede entenderse que constituye, tras los ajustes que correspondan por razón de otros costes asociados a la adquisición del producto (por ejemplo, los derechos de aduana), un precio de plena competencia de la transmisión de bienes inicial entre las empresas asociadas. Este método alcanza su máxima utilidad cuando se aplica a actividades de comercialización.

2.22 El margen del precio de reventa del revendedor en la operación vinculada puede calcularse partiendo del margen del precio de reventa obtenido por ese mismo revendedor sobre artículos comprados y vendidos en operaciones no vinculadas comparables (“comparable interno”). También puede utilizarse como pauta el margen del precio de reventa obtenido por una empresa independiente en operaciones no vinculadas comparables (“comparable externo”). Cuando el revendedor desarrolla actividades de corretaje, el margen del precio de reventa puede estar referido a una comisión de corretaje que, normalmente, se calcula como un porcentaje del precio de venta del producto enajenado. En ese caso, el cálculo del margen del precio de reventa debe tener en cuenta si el intermediario actúa por cuenta ajena o en nombre propio.

2.23 Siguiendo los principios enunciados en el Capítulo I, una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada (esto es, constituye una operación no vinculada comparable) a los efectos de la aplicación del método del precio de reventa cuando se cumple una de las dos condiciones siguientes: a) ninguna de las diferencias (si las hubiera) entre las operaciones que se comparan, o entre las empresas que llevan a cabo esas operaciones, influye significativamente en el margen del precio de reventa en el mercado libre; o b) pueden realizarse ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos importantes que puedan provocar esas diferencias. A la hora de establecer comparaciones con el objeto de aplicar el método del precio de reventa, suelen ser necesarios menos ajustes que subsanen las diferencias entre los productos que al aplicar el método del precio libre comparable, ya que es menos probable que las diferencias menores entre productos tengan un efecto tan importante sobre los márgenes de beneficio como el que tienen sobre el precio.

2.24 En una economía de mercado, la contraprestación por el ejercicio de funciones similares tiende a igualarse entre las distintas actividades. En cambio, los precios entre los diferentes productos sólo tienden a equipararse en la medida en que unos productos sean sustitutivos de otros. Las diferencias entre los productos son menos significativas como consecuencia

de que el margen de beneficio bruto representa una remuneración bruta, tras descontar el coste de venta de las funciones concretas realizadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos). Por ejemplo, los datos pueden indicar que una compañía distribuidora desarrolla las mismas funciones (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) cuando vende tostadores que cuando vende batidoras y, por ello, en una economía de mercado, la remuneración de estas dos actividades debería ser similar. Sin embargo, los consumidores no considerarán que un tostador y una batidora sean bienes sustitutivos, por lo que no hay razón para esperar que sus precios sean iguales.

2.25 Aunque en el método del precio de reventa se puedan permitir mayores diferencias entre los productos, los bienes transmitidos en una operación vinculada deben seguir siendo comparables a los transmitidos en la operación no vinculada. Cuanto mayor sean las diferencias, más diferencias se observarán también entre las funciones desarrolladas por las partes de las operaciones vinculada y no vinculada. Aunque al utilizar el método del precio de reventa se necesite una menor comparabilidad entre los productos, no deja de ser cierto que los productos con mayor comparabilidad arrojan mejores resultados. Por ejemplo, cuando en la operación intervenga un intangible valioso o único, la similitud de los productos cobrará mayor importancia, y se le debe prestar especial atención para garantizar la validez de la comparación.

2.26 Puede ser oportuno conceder más peso a otros atributos de la comparabilidad mencionados en el Capítulo I (las funciones ejercidas, las circunstancias económicas, etc.) cuando el margen de beneficio está directamente relacionado con esos otros atributos y, sólo de forma secundaria, al producto concreto que se transfiere. Esta circunstancia suele darse en particular cuando se determina el margen de beneficio de una empresa asociada que no ha utilizado activos exclusivos (como puedan ser los intangibles valiosos y únicos) para añadir un valor significativo al producto objeto de transmisión. Así, cuando las operaciones no vinculadas y las vinculadas son comparables en todas sus características excepto en el producto en sí mismo, el método del precio de reventa puede generar una valoración más fiable de las condiciones de plena competencia que el método del precio libre comparable, salvo cuando se puedan realizar ajustes lo suficientemente precisos como para subsanar las diferencias en los productos transmitidos. Lo mismo cabe decir del método del coste incrementado, analizado más adelante.

2.27 Cuando el margen del precio de reventa utilizado es el de una empresa independiente en una operación comparable, la fiabilidad del método del precio de reventa puede verse comprometida si existen

diferencias importantes en la forma en que las empresas asociadas y las independientes realizan sus negocios. Entre estas diferencias pueden incluirse aquellas que afectan a los niveles de costes considerados (por ejemplo, las diferencias podrían incluir los efectos que produce una gestión eficiente en los niveles y variedad de las existencias), que bien pueden tener incidencia en la rentabilidad de una empresa, pero que no afectan necesariamente al precio al que se compran o se venden sus bienes o servicios en el mercado libre. Este tipo de características debe analizarse a la hora de determinar si una operación no vinculada es comparable a los efectos de la aplicación del método del precio de reventa.

2.28 El método del precio de reventa depende también de la comparabilidad de las funciones desempeñadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos). Puede resultar menos fiable cuando haya diferencias entre las operaciones vinculadas y las no vinculadas, y entre las partes que intervienen en las operaciones, y esas diferencias incidan perceptiblemente sobre el atributo utilizado como indicador para valorar las condiciones de plena competencia, en este caso, el margen del precio de reventa obtenido. Cuando se observen diferencias sustanciales que afecten a los márgenes brutos obtenidos en las operaciones vinculadas e independientes (por ejemplo, en la naturaleza de las funciones desarrolladas por las partes que intervienen en la operación), será necesario practicar ajustes que subsanen esas diferencias. El grado y precisión de los ajustes afectarán a la fiabilidad relativa del análisis efectuado en el marco del método del precio de reventa en determinados casos concretos.

2.29 Es más fácil determinar un margen del precio de reventa apropiado cuando el revendedor no añade un valor sustancial al producto. En cambio, puede ser más difícil utilizar el método del precio de reventa para llegar a un precio de plena competencia cuando, antes de la venta, los bienes son objeto de una nueva transformación o se incorporan a un producto más complejo de tal modo que pierden su identidad o se transforman (por ejemplo, cuando se unen componentes en un producto acabado o semi-acabado). Otro ejemplo en el que el margen del precio de reventa exige particular cuidado es cuando el revendedor contribuye sustancialmente a la creación o a la conservación de activos intangibles asociados al producto (por ejemplo, marcas o nombres comerciales), propiedad de una empresa asociada. En tales casos, la contribución de los bienes originalmente transferidos al valor del producto final no puede calcularse fácilmente.

2.30 El margen del precio de reventa es más exacto cuando se ha obtenido poco tiempo después de que el revendedor adquiriera los bienes. Cuanto más tiempo transcurre entre la compra inicial y la reventa, más posibilidades hay de que se deban tener en cuenta otros factores (variaciones

en el mercado, en los tipos de cambio, en los costes, etc.) en cualquier comparación.

2.31 Debería esperarse que la cuantía del margen del precio de reventa dependa de las funciones ejercidas por el revendedor. Estas funciones pueden variar mucho, desde el caso en el que el revendedor realiza servicios mínimos como agente de transporte, hasta aquel en el que asume la totalidad de los riesgos de la propiedad de los bienes junto con la plena responsabilidad y los riesgos derivados de su publicidad, comercialización, distribución y garantía, de la financiación de existencias y de otros servicios complementarios. Si el revendedor en la operación vinculada no lleva a cabo una actividad comercial importante, sino que sólo transfiere los bienes a un tercero, el margen del precio de reventa podría ser pequeño en vista de las funciones ejercidas. Este margen del precio de reventa podría incrementarse cuando se pueda demostrar que el revendedor tiene una pericia especial en la comercialización de los bienes, soporta realmente riesgos especiales o contribuye sustancialmente a la creación o a la conservación de activos intangibles asociados al producto. Sin embargo, el grado de actividad desplegada por el revendedor, ya sea mínimo o sustancial, debe sustentarse en pruebas concluyentes. Entre estas se encontrarían: la justificación de gastos de comercialización que pudieran considerarse desproporcionadamente altos; por ejemplo, cuando se haya incurrido en parte o en la mayoría de los gastos de promoción en concepto de servicio realizado en favor del propietario legal de la marca comercial. En tal caso, el método del coste incrementado puede complementar bien el método del precio de reventa.

2.32 Cuando el revendedor desempeña claramente una actividad comercial sustancial añadida a la actividad de reventa propiamente dicha, cabe esperar un margen del precio de reventa razonablemente importante. Si en sus actividades el revendedor emplea activos valiosos y posiblemente únicos (por ejemplo, activos intangibles del revendedor, como puede ser su organización de comercialización), podría resultar inadecuado evaluar las condiciones de plena competencia en la operación vinculada utilizando un margen del precio de reventa no ajustado, derivado de operaciones no vinculadas, en las que el revendedor independiente no utiliza activos similares. Si el revendedor posee intangibles de comercialización valiosos, el margen del precio de reventa en la operación no vinculada podría infravalorar el beneficio que corresponde al revendedor en la operación vinculada, salvo que la operación no vinculada comparable incluya al mismo revendedor o a un revendedor con intangibles de comercialización igualmente valiosos.

2.33 En el caso de que exista un canal de distribución de bienes a través de una sociedad intermediaria, puede ser relevante para las administraciones tributarias observar no sólo el precio de reventa de los bienes adquiridos a la sociedad intermediaria, sino también el precio que dicha sociedad paga a su proveedor y las funciones que desempeña. No es difícil encontrar obstáculos para obtener esta información y para determinar las funciones exactas de la sociedad intermediaria. Si no se puede demostrar que la sociedad intermediaria soporta riesgos reales o desempeña una función económica que ha incrementado el valor de los bienes en el canal de distribución, entonces cualquier elemento del precio que se reclame imputable a las actividades de la sociedad intermediaria sería con toda razón atribuible a otra integrante del grupo multinacional, ya que las empresas independientes normalmente no hubieran permitido la participación de tal sociedad en los beneficios de la operación.

2.34 Se podría esperar que el margen del precio de reventa varíe en función de que el revendedor tenga el derecho exclusivo de revender los bienes en cuestión. Este tipo de acuerdos se da en operaciones entre empresas independientes y puede influir en el margen. Por tanto, este tipo de derechos exclusivos debe tenerse en cuenta al efectuar cualquier comparación. El valor que debe atribuirse a los derechos exclusivos dependerá hasta cierto punto de su ámbito geográfico y de la existencia y competitividad relativa de posibles bienes sustitutivos. El acuerdo puede ser beneficioso tanto para el proveedor como para el revendedor en una operación en plena competencia. Por ejemplo, la venta de una línea concreta de productos del proveedor puede ser un aliciente para que el revendedor haga un esfuerzo mayor. Por el contrario, un acuerdo semejante puede ofrecer al revendedor una especie de monopolio que le permita obtener un volumen de negocio importante sin gran esfuerzo. Por tanto, es necesario examinar cuidadosamente y en cada caso, el efecto de este factor sobre el margen del precio de reventa correspondiente.

2.35 Cuando las prácticas contables difieren entre la operación vinculada y la no vinculada, deberán practicarse los ajustes que corresponda sobre los datos utilizados para calcular el margen del precio de reventa, a fin de asegurar que se manejan las mismas categorías de costes en cada caso para llegar al margen bruto. Por ejemplo, los costes de investigación y desarrollo pueden reflejarse en los gastos de explotación o en los de venta. Los márgenes brutos respectivos no serían comparables sin los ajustes oportunos.

C.2 Ejemplos de aplicación del método del precio de reventa

2.36 Supongamos que hay dos distribuidores vendiendo el mismo producto en el mismo mercado con el mismo nombre comercial. El distribuidor A garantiza el producto, el distribuidor B, no. El distribuidor A no incluye la garantía como parte de la estrategia de fijación de precios y, por tanto, vende a precios más elevados que determinan un mayor margen de beneficio bruto (si no se tienen en cuenta los costes de dar un servicio de garantía) que el obtenido por el distribuidor B, que vende a un precio inferior. Estos márgenes no son comparables si no se realiza un ajuste que subsane esa diferencia.

2.37 Supongamos que la garantía se ofrece para todos los productos, de forma que su repercusión posterior en el precio es uniforme. El distribuidor C asume la función de garantía pero, de hecho, su proveedor le remunera con precios inferiores. El distribuidor D no asume la función de garantía, sino que la ejerce el suministrador (los productos se devuelven a fábrica). En ese caso, el proveedor de D le factura con un precio más alto que al distribuidor C. Si el distribuidor C contabiliza el coste de asumir la función de garantía como un coste de los bienes vendidos, entonces el ajuste del margen de beneficio bruto por esta diferencia es automático. Sin embargo, si los costes de la garantía se contabilizan como gastos de explotación, se produce una distorsión en los márgenes que debe corregirse. El razonamiento en este caso sería que, si D asume la función de garantía por sí mismo, su proveedor reduciría sus precios de transferencia y, en consecuencia, el margen de beneficio bruto de D sería mayor.

2.38 Una sociedad vende un producto a través de distribuidores independientes en cinco países en los que no tiene filiales. Los distribuidores se limitan a comercializar el producto sin desempeñar ninguna tarea adicional. La sociedad ha establecido una filial en un país. Por la importancia estratégica de este mercado concreto, la sociedad exige a su filial que venda sólo su producto y que preste servicios técnicos a sus clientes. Incluso si todos los demás hechos y circunstancias son similares, cuando los márgenes comparados procedan de empresas independientes que no están sujetas a acuerdos de venta en exclusiva ni realizan servicios técnicos como los asumidos por la filial, es necesario plantearse si deben hacerse algunos ajustes para lograr la comparabilidad.

D. Método del coste incrementado

D.1 *Términos generales*

2.39 El método del coste incrementado parte de los costes en que ha incurrido el proveedor de los bienes (o servicios) en una operación vinculada por los bienes transmitidos o los servicios prestados a un comprador asociado. Este coste se incrementa en un margen que le permita obtener un beneficio apropiado teniendo en cuenta las funciones desempeñadas y las condiciones del mercado. El resultado, que se obtiene después de incrementar el coste mencionado con dicho margen, puede considerarse como un precio de plena competencia de la operación vinculada original. Este método probablemente alcanza su máxima utilidad cuando se aplica a la venta de productos semi-acabados entre partes asociadas, cuando las partes asociadas han concluido acuerdos de explotación común o de compra-venta a largo plazo, o cuando la operación vinculada consiste en la prestación de servicios.

2.40 La solución ideal sería determinar el margen incrementado sobre el coste del proveedor en la operación vinculada tomando como referencia el margen incrementado sobre el coste que el mismo proveedor obtiene en operaciones no vinculadas comparables (“comparable interno”). Además, también puede recurrirse al margen incrementado sobre el coste que hubiera aplicado una empresa independiente en operaciones comparables (“comparable externo”).

2.41 De conformidad con los principios formulados en el Capítulo I, una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada (es decir, es una operación no vinculada comparable) a los efectos de aplicar el método del coste incrementado si se da una de las dos condiciones siguientes: a) ninguna de las diferencias (si las hubiera) entre las operaciones que se comparan, o entre las empresas que llevan a cabo esas operaciones, influye significativamente en el margen incrementado sobre el coste en el mercado libre; o b) pueden realizarse ajustes lo suficientemente precisos como para eliminar los efectos importantes que puedan provocar esas diferencias. A la hora de determinar si una operación no vinculada es comparable a los efectos de la aplicación del método del coste incrementado, pueden aplicarse los mismos principios descritos en los párrafos 2.23 a 2.28 respecto del método del precio de reventa. Por tanto, con la aplicación del método del coste incrementado pueden necesitarse menos ajustes que subsanen las diferencias respecto del producto que en el caso del método del precio libre comparable, por lo que puede resultar oportuno conceder más importancia a otros factores de comparabilidad descritos en el Capítulo I,

alguno de los cuales puede tener un efecto más significativo sobre el margen incrementado sobre el coste que el que tiene sobre el precio. Como en el método del precio de reventa (véase el párrafo 2.28), cuando existen diferencias que afectan significativamente a los márgenes incrementados sobre el coste obtenidos en las operaciones vinculadas y en las no vinculadas (por ejemplo, en la naturaleza de las funciones desempeñadas por las partes en las operaciones), deben practicarse los ajustes que sean necesarios para corregirlas. El alcance y la fiabilidad de esos ajustes afectarán a la fiabilidad relativa del análisis realizado en aplicación del método del coste incrementado en determinados casos concretos.

2.42 Por ejemplo, supongamos que la sociedad A fabrica y vende tostadores a un distribuidor que es una empresa asociada, que la sociedad B fabrica y vende planchas a un distribuidor que es una empresa independiente, y que los márgenes de beneficio en la fabricación de estos productos son generalmente los mismos en el sector de los pequeños aparatos electrodomésticos (la utilización del método del coste incrementado se apoya en la hipótesis de que no existen fabricantes de tostadores similares e independientes). Si aplicamos el método del coste incrementado, los márgenes objeto de comparación en las operaciones vinculadas y no vinculadas son la diferencia entre el precio de venta del fabricante al distribuidor y los costes de fabricación del producto, dividido por los costes de fabricación del producto. Sin embargo, la sociedad A puede ser mucho más eficiente en su proceso de fabricación que la sociedad B, lo cual le permite soportar menores costes. Como resultado, incluso si la sociedad A estuviera fabricando planchas en lugar de tostadores y facturando el mismo precio que la sociedad B por las planchas (es decir, si no existen condiciones especiales), sería apropiado que el margen de beneficios de la sociedad A fuera mayor que el de la sociedad B. Por tanto, salvo que sea posible ajustar el efecto provocado por esta diferencia en el beneficio, la aplicación del método del coste incrementado no sería plenamente fiable en este contexto.

2.43 El método del coste incrementado presenta algunas dificultades para su aplicación correcta, en particular en la determinación de los costes. Aunque sin duda una empresa debe cubrir sus costes en un determinado período de tiempo para poder mantener su actividad, esos costes pueden no ser determinantes del beneficio que deba obtenerse en un caso concreto y en un año dado. En tanto que las empresas se ven frecuentemente compelidas por la competencia a bajar sus precios en relación con los costes de producción de los bienes o de prestación de los servicios que ofertan, existen otras circunstancias en las que no se aprecia relación alguna entre el nivel de costes en que se ha incurrido y el valor normal de mercado (por ejemplo,

cuando se ha realizado un descubrimiento muy valioso y su propietario ha incurrido en costes de investigación bajos para lograrlo).

2.44 Además, al aplicar el método del coste incrementado se debe prestar atención a la aplicación de un margen comparable a una base de costes comparable. Por ejemplo, si el proveedor en la operación independiente objeto de comparación para la aplicación del método del coste incrementado utiliza activos empresariales arrendados en el desarrollo de su actividad, la base de costes no puede ser comparable sin ajustes cuando el proveedor en la operación vinculada sea propietario de sus activos. El método del coste incrementado se fundamenta en la comparación del margen incrementado sobre los costes aplicado en una operación vinculada y el margen sobre costes obtenido en una o más operaciones no vinculadas comparables. Por tanto, las diferencias entre las operaciones vinculadas y no vinculadas que afectan a la cuantía del margen deben analizarse para determinar qué ajustes deben realizarse en los márgenes correspondientes a las operaciones no vinculadas.

2.45 A estos efectos, resulta particularmente importante considerar las diferencias en los niveles y tipos de gastos (de explotación y otros, incluyendo los gastos de financiación) vinculados a las funciones desarrolladas y los riesgos asumidos por las partes o a las operaciones objeto de comparación. El estudio de estas diferencias puede poner de manifiesto lo siguiente:

- a) Si los gastos reflejan una diferencia funcional (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) que no se ha considerado al aplicar el método, puede ser necesario ajustar el margen incrementado sobre el coste.
- b) Si los gastos reflejan funciones adicionales distintas de las actividades a las que el método somete a análisis, puede ser necesario determinar remuneraciones independientes para esas funciones. Estas últimas pueden consistir, por ejemplo, en prestaciones de servicios para las que se podrá establecer una remuneración apropiada. Análogamente, puede ser necesario ajustar independientemente los gastos derivados de una estructura de capital que no responda a acuerdos basados en el principio de plena competencia.
- c) Si las diferencias en los gastos de las partes que se comparan reflejan simplemente eficiencias o ineficiencias de las empresas (como sería el caso respecto de los gastos de supervisión, generales y de administración), no será necesario realizar ajustes en el margen bruto.

En cualquiera de las circunstancias anteriores podrá ser útil complementar los métodos del coste incrementado y del precio de reventa atendiendo a los resultados obtenidos con la aplicación de otros métodos (véase el párrafo 2.11).

2.46 Otro aspecto importante de la comparabilidad es la homogeneidad de la contabilidad. Cuando las prácticas contables empleadas en la operación vinculada y la operación no vinculada difieren, los datos utilizados deberán ajustarse adecuadamente al objeto de asegurar, en aras de la coherencia, que los costes utilizados son del mismo tipo. Los márgenes de beneficio bruto deben cuantificarse de forma que permitan la comparación entre la empresa asociada y la empresa independiente. Además, las empresas pueden tratar de forma distinta los costes que afectan a los márgenes de beneficio bruto que deberán tenerse en cuenta para conseguir una comparabilidad fiable. En algunos casos puede resultar necesario considerar determinados gastos de explotación con el objeto de lograr coherencia y comparabilidad; en estas circunstancias el método del coste incrementado comienza a aproximarse al análisis del beneficio neto más que del beneficio bruto. En la medida en que el análisis considera gastos de explotación, su fiabilidad puede verse afectada adversamente por las razones expuestas en los párrafos 2.64 a 2.67. Así, las garantías descritas en los párrafos 2.68 a 2.75 pueden ser relevantes para valorar la fiabilidad de estos análisis.

2.47 Aunque las normas y los plazos contables pueden variar, en general los costes y los gastos de una empresa se pueden entender divididos en tres grandes categorías. En primer lugar, los costes directos de producción de un bien o un servicio, como puede ser el coste de las materias primas. En segundo lugar, los costes indirectos de producción que, aunque estén estrechamente vinculados al proceso de producción, pueden ser comunes a varios bienes o servicios (por ejemplo, el coste de un departamento de reparaciones que abarca los equipos utilizados en la producción de los distintos productos). Por último, los gastos de explotación de la empresa en su conjunto, entre los que se incluirían los de supervisión, generales y de administración.

2.48 La distinción entre el análisis de los beneficios brutos y netos puede entenderse en los siguientes términos. En general, el método del coste incrementado utilizará márgenes calculados sobre los costes directos e indirectos de producción, mientras que un método sobre el beneficio neto utilizará los beneficios calculados sobre los costes que comprendan también los gastos de explotación de la empresa. Dadas las diferencias en las prácticas contables de los países, es difícil trazar una línea precisa entre las tres categorías de gastos mencionadas anteriormente. Así, por ejemplo, la aplicación del método del coste incrementado puede comportar en un caso

concreto la consideración de algunos gastos que podrían entenderse como gastos de explotación, como se vio en el párrafo 2.46. Sin embargo, los problemas para delinear con precisión matemática los límites entre las tres categorías de gastos mencionadas no alteran la distinción práctica fundamental entre los criterios de beneficio bruto y neto.

2.49 En principio, los costes históricos deben atribuirse a las diferentes unidades de producción, aunque se admite que el método del coste incrementado puede sobrevalorar los costes históricos. Ciertos costes (por ejemplo, los costes de materiales, salariales y de transporte) son variables en el tiempo, por lo que puede resultar conveniente promediarlos para un periodo dado. También puede resultar adecuado promediar entre diferentes grupos de productos o entre líneas de productos específicas. Más aun, puede ser oportuno promediar los costes de los activos fijos cuando se producen o procesan simultáneamente productos diferentes y cuando fluctúa el volumen de actividad. También puede ser necesario considerar costes como los de reposición y los marginales, siempre que puedan calcularse, y que su cómputo arroje una determinación más precisa del beneficio apropiado.

2.50 Los costes que pueden tenerse en cuenta al aplicar el método del coste incrementado se limitan a los del proveedor de bienes o servicios. Esta limitación puede crear el problema de cómo distribuir algunos costes entre el proveedor y el comprador. Existe la posibilidad de que algunos costes los soporte el comprador para minorar la base de costes del proveedor sobre la que se calcula el margen. En la práctica, este efecto se puede conseguir no atribuyendo al proveedor el porcentaje correcto de costes generales y otros soportados por el comprador (con frecuencia, una sociedad matriz) en beneficio del proveedor (con frecuencia, una filial). La atribución debe realizarse mediante un análisis de las funciones desempeñadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) por cada una de las partes, como se indicó en el Capítulo I. Otro problema que puede surgir al respecto es cómo deben distribuirse los costes generales: por referencia al volumen de actividad, al número o al coste de los empleados, o en función de otro criterio. La cuestión de la asignación de costes se trata también en el Capítulo VIII que versa sobre los acuerdos de reparto de costes.

2.51 En algunos casos, la utilización exclusiva de costes variables o marginales puede justificarse por el hecho de que las operaciones constituyan la transmisión de una producción marginal. Este razonamiento podría alegarse si los bienes no se pueden vender a un precio superior en el mercado extranjero que corresponda (véase también el análisis sobre penetración en los mercados del Capítulo I). Entre los factores que deben tenerse en cuenta al evaluar esta propuesta se incluye la información sobre si el contribuyente ha efectuado alguna otra venta de productos idénticos o similares en ese

mercado extranjero concreto, el porcentaje de producción del contribuyente (tanto en términos de volumen como de valor) que representa la “producción marginal” propuesta, el periodo de vigencia del acuerdo y los detalles del análisis de comercialización que realizó el contribuyente o el grupo multinacional y que condujo a la conclusión de que los bienes no podían venderse a un precio superior en ese mercado extranjero.

2.52 No es posible formular una regla general para todos los casos. Los diversos métodos de determinación de costes deben ser uniformes tanto para las operaciones vinculadas como para las no vinculadas, e igualmente uniformes en el transcurso del tiempo con referencia la misma empresa. Por ejemplo, para determinar el margen que deba incrementarse sobre el coste puede ser necesario considerar si los productos pueden suministrarse por fuentes diversas a costes que difieran notablemente. Las empresas asociadas pueden optar por calcular su base de incremento de coste según criterios estandarizados. Un tercero independiente probablemente no aceptaría pagar un precio más alto que resultara de las ineficiencias de la otra parte. Por otro lado, si la otra parte es más eficiente de lo que se cabe esperar en condiciones normales, esta debería beneficiarse de dicha ventaja. La empresa asociada puede acordar previamente qué costes son aceptables como base para la aplicación del método del coste incrementado.

D.2 Ejemplos de aplicación del método del coste incrementado

2.53 A es un fabricante nacional de mecanismos de relojería para relojes fabricados en serie. A vende este producto a su filial extranjera B. A obtiene un margen de beneficio bruto del 5 por ciento en su actividad de fabricación. X, Y y Z son fabricantes nacionales independientes de mecanismos de relojería para relojes de pulsera fabricados en serie. X, Y y Z venden a compradores extranjeros independientes. X, Y y Z obtienen un margen de beneficio bruto respecto de sus actividades de fabricación de entre el 3 y el 5 por ciento. A contabiliza los costes de supervisión, generales y de administración como gastos de explotación, por lo que no se reflejan como costes en los bienes vendidos. Los márgenes de beneficio bruto de X, Y y Z sí reflejan sin embargo los costes de supervisión, generales y de administración como parte de los costes de los bienes vendidos. Por tanto, los márgenes de beneficio bruto de X, Y y Z tienen que ajustarse de forma que se subsane esta diferencia contable.

2.54 La sociedad C del país D es una filial al 100 por cien de la sociedad E, situada en el país F. En comparación con el país F, en el país D los salarios son muy bajos. La sociedad C monta aparatos de televisión a expensas y riesgo de la sociedad E. Esta última suministra todos los

componentes necesarios, los conocimientos prácticos -know-how-, etc. La sociedad E se compromete a comprar los productos montados en el caso de que los aparatos de televisión no superen un determinado nivel de calidad. Después de pasar los controles de calidad, los aparatos de televisión se envían, por cuenta y riesgo de la sociedad E, a los centros de distribución que esta sociedad tiene en diversos países. Puede decirse que las funciones de la sociedad C se limitan meramente a las que desarrolla un fabricante que realiza su actividad bajo contrato. Los riesgos que soporta la sociedad C son las diferencias que pudieran darse en la calidad y cantidad acordadas. La base para aplicar el método del coste incrementado estará compuesta por todos los costes ligados a las actividades de montaje.

2.55 La sociedad A de un grupo multinacional acuerda mediante contrato con la sociedad B del mismo grupo realizar una investigación para esta última. La sociedad B soporta los riesgos del fracaso de la investigación. Esta sociedad es también propietaria de todos los intangibles desarrollados a través de la investigación y, por lo tanto, le corresponden también las posibilidades de beneficio que de ella se deriven. Este es un esquema típico de aplicación del método del coste incrementado. Se deben retribuir todos los costes de la investigación acordados por las partes asociadas. El coste incrementado adicional puede reflejar cuán innovadora y compleja es la investigación desarrollada.

Parte III: Métodos basados en el resultado de las operaciones

A. Introducción

2.56 En esta Parte se analizan los métodos basados en el resultado de las operaciones a los que puede recurrirse para aproximarse a las condiciones de plena competencia cuando resulten los métodos más apropiados teniendo en cuenta las circunstancias del caso; véanse los párrafos 2.1 a 2.11. Los métodos basados en el resultado de las operaciones analizan los resultados derivados de una operación concreta entre empresas asociadas. Los únicos métodos basados en el resultado que satisfacen el principio de plena competencia son los que cumplen con lo dispuesto en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y que se ajustan a la exigencia de practicar el análisis de comparabilidad descrito en estas Directrices. En concreto, los denominados "métodos de los beneficios comparables" o "métodos del coste incrementado/precio de reventa modificados" sólo pueden aceptarse en la medida en que sean compatibles con estas Directrices.

2.57 Los métodos basados en el resultado de las operaciones estudian los beneficios que se derivan de una operación vinculada concreta. A los efectos de estas Directrices, se consideran métodos basados en el resultado de las operaciones el método de la distribución del resultado y el método del margen neto operacional. Los beneficios procedentes de una operación vinculada pueden constituir un indicador importante de si la operación se ha realizado en condiciones que difieran de aquellas que hubieran acordado empresas independientes en circunstancias, por lo demás, comparables.

B. Método del margen neto operacional

B.1. Términos generales

2.58 El método del margen neto operacional estudia el beneficio neto calculado sobre una magnitud apropiada (por ejemplo los costes, las ventas o los activos) que un contribuyente obtiene por razón de una operación vinculada (o una serie de operaciones que resulte adecuado agregar en virtud de lo expuesto en los párrafos 3.9 a 3.12). Por tanto, el método del margen neto operacional se aplica de forma similar a los métodos del coste incrementado y del precio de reventa. Esta similitud significa que, para que

resulte fiable, el método del margen neto operacional debe aplicarse de forma similar a como se aplican los métodos del precio de reventa o del coste incrementado. En concreto, esto supone que el indicador del beneficio neto que el contribuyente obtiene de la operación vinculada (u operaciones que resulte adecuado agregar en virtud de lo expuesto en los párrafos 3.9 a 3.12) debe determinarse teóricamente tomando como referencia el indicador del beneficio neto que ese mismo contribuyente obtiene en operaciones comparables realizadas en el mercado libre, es decir, tomando como referencia “comparables internos” (véanse los párrafos 3.27 y 3.28). Cuando no sea posible proceder de este modo, puede utilizarse como pauta el margen neto que hubiera obtenido una empresa independiente en una operación comparable (“comparable externo”); véanse los párrafos 3.29 a 3.35. Es necesario practicar un análisis funcional de las operaciones vinculadas y no vinculadas a fin de determinar su comparabilidad, así como los ajustes necesarios para obtener resultados fiables. Asimismo deben aplicarse los restantes criterios de comparabilidad y, en concreto, los de los párrafos 2.68 a 2.75.

2.59 La aplicación del método del margen neto operacional difícilmente resultará fiable si cada parte realiza aportaciones valiosas y únicas (véase el párrafo 2.4). En ese caso, el método más apropiado, en términos generales, es el método de la distribución del resultado (véase el párrafo 2.109). Sin embargo, los métodos unilaterales (métodos tradicionales basados en las operaciones, o el del margen neto operacional) pueden aplicarse en aquellos casos en los que es una de las partes la que realiza todas las aportaciones únicas que conlleva la operación vinculada, mientras que la otra parte no aporta ninguna. En ese caso, la parte objeto de análisis deberá ser la menos compleja. Por lo que respecta a la noción de parte objeto de análisis, véanse los párrafos 3.18 y 3.19.

2.60 Hay también muchos casos en los que una parte que interviene en una operación realiza aportaciones que no son únicas, por ejemplo, utiliza intangibles no únicos como puedan ser los procesos mercantiles o los conocimientos del mercado no exclusivos. En estos casos es posible satisfacer los requisitos de comparabilidad necesarios para la aplicación de un método tradicional basado en las operaciones o del método del margen neto operacional, porque cabe esperar que los comparables recurran también a un conjunto similar de aportaciones no únicas.

2.61 Finalmente, la ausencia de contribuciones únicas y valiosas en una operación concreta no implica automáticamente que el método más apropiado sea el del margen neto operacional.

B.2 Ventajas e inconvenientes¹

2.62 Una de las ventajas del método del margen neto operacional es que los indicadores de beneficio neto (por ejemplo, el rendimiento de los activos, la relación entre beneficio de explotación y ventas y otras posibles medidas del beneficio neto) son menos sensibles a las diferencias que afectan a las operaciones de lo que lo es el precio, que es la magnitud utilizada en el método del precio libre comparable. Los indicadores de beneficio neto pueden tolerar también mejor algunas diferencias funcionales entre las operaciones vinculadas y las no vinculadas que los márgenes de beneficio bruto. Las diferencias en las funciones desempeñadas en las empresas suelen reflejarse en variaciones en los gastos de explotación, lo que puede llevar a que exista un amplio rango de márgenes de beneficio bruto aunque se sigan manteniendo niveles similares de indicadores de beneficios de explotación netos. Asimismo, en algunos países, la falta de claridad en los datos públicos referidos a la clasificación de los gastos comprendidos en el beneficio bruto o en el de explotación, complica la comparabilidad de los márgenes brutos, mientras que la utilización de indicadores de beneficio neto puede evitar el problema.

2.63 Otra ventaja práctica del método del margen neto operacional es que, como ocurre en los métodos unilaterales, sólo es necesario analizar el indicador financiero de una de las empresas asociadas (la parte “objeto de análisis”). Del mismo modo, tampoco es necesario habitualmente homogeneizar los documentos contables de los participantes en la actividad empresarial, ni imputar costes a todos los participantes como ocurre en el caso del método de la distribución del resultado de la operación. En la práctica esto puede ser muy ventajoso cuando una de las partes de la operación es compleja y realiza diversas actividades estrechamente relacionadas, o cuando es difícil obtener información fiable sobre una de las partes. Sin embargo, siempre debe realizarse un análisis de comparabilidad (incluido el análisis funcional) a fin de calificar adecuadamente la operación realizada entre las partes, y elegir el método más apropiado para la determinación de precios de transferencia. Este análisis precisa generalmente de información sobre los cinco factores de comparabilidad en relación con ambas partes, la que constituye objeto de análisis y la que no. Véanse los párrafos 3.20 a 3.23.

¹

En el Anexo I al Capítulo II se incluye un ejemplo ilustrativo de la sensibilidad de los indicadores de los márgenes de beneficio bruto y neto.

2.64 El método del margen neto operacional presenta también ciertos inconvenientes. El indicador de beneficio neto de un contribuyente puede verse afectado por diversos factores que, o bien no tendrían incidencia, o que de tenerla sería mucho menor e indirecta sobre el precio o los márgenes brutos determinados entre empresas independientes. Estos elementos dificultan la fijación exacta y fiable de los indicadores de beneficio neto de plena competencia, por lo que es importante suministrar unas indicaciones detalladas para establecer la comparabilidad en el caso del método del margen neto operacional, según se indica en los párrafos 2.68 a 2.75 más adelante.

2.65 La aplicación de cualquier método de plena competencia precisa de información sobre operaciones no vinculadas que puede no ser accesible en el momento en que se llevan a cabo las operaciones vinculadas. Esto puede complicar especialmente la aplicación del método del margen neto a los contribuyentes que desean recurrir a él en el momento de llevar a cabo las operaciones vinculadas (aunque la utilización de datos referidos a varios años, como se expone en los párrafos 3.75 a 3.79 permite atenuar estas dificultades). Del mismo modo, los contribuyentes pueden no tener información específica suficiente sobre los beneficios atribuibles a operaciones no vinculadas comparables para poder aplicar correctamente el método. También puede resultar difícil calcular los ingresos y los gastos de explotación relacionados con las operaciones vinculadas para determinar el indicador de beneficio neto utilizado como medida del beneficio de las operaciones. Las administraciones tributarias pueden disponer de más información extraída de las inspecciones realizadas a otros contribuyentes. Véase el párrafo 3.36, en el que se habla sobre la información de la que disponen las administraciones tributarias que puede no comunicarse a los contribuyentes, y los párrafos 3.67 a 3.79 en los que se aborda el marco temporal.

2.66 Al igual que los métodos del precio de reventa y del coste incrementado, el método del margen neto operacional se aplica únicamente a una de las empresas asociadas. El hecho de que los beneficios netos pueden verse afectados por muchos factores que no están relacionados con los precios de transferencia, añadido a la naturaleza unilateral del análisis que se realiza en aplicación de este método, puede comprometer la fiabilidad del método del margen neto operacional si no se aplica un criterio de comparabilidad suficiente. En el apartado B.3.1 más adelante se ofrecen unas pautas detalladas sobre cómo establecer la comparabilidad en caso de aplicación de este método.

2.67 Cuando se aplica el método del margen neto operacional pueden surgir también dificultades al determinar un ajuste correlativo apropiado, en

particular cuando no es posible recalcular un precio de transferencia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el contribuyente opera con empresas asociadas tanto en las adquisiciones como en las ventas que se llevan a cabo en la operación vinculada. En ese caso, si el método del margen neto operacional indica que el beneficio del contribuyente debe ajustarse al alza, pueden surgir dudas sobre cual de las empresas asociadas es la que debe reducir sus beneficios

B.3 Orientaciones para la aplicación

B.3.1 Estándar de comparabilidad aplicable al método del margen neto operacional

2.68 Siempre es necesario llevar a cabo un análisis de comparabilidad a fin de seleccionar y aplicar el método de determinación de precios de transferencia más apropiado, y el proceso de selección y aplicación del método del margen neto operacional no debe resultar menos fiables que el de los restantes métodos. En la aplicación del método del margen neto operacional, la buena práctica consiste, al igual que con cualquier otro método, en seguir el proceso típico de identificación de operaciones comparables y de utilizar los datos así obtenidos, como se describe en el párrafo 3.4, u otro proceso equivalente destinado a garantizar la solidez del análisis. Una vez dicho esto, no deja de reconocerse que, en la práctica, el nivel de información disponible sobre los factores que afectan a las operaciones que constituyen comparables externos, es limitado. Para determinar una estimación fiable de un resultado de plena competencia es necesario recurrir a la flexibilidad y al buen juicio. Véase el párrafo 1.13.

2.69 Los precios probablemente resulten afectados por las diferencias en los productos y los márgenes brutos probablemente lo sean por las diferencias en las funciones, pero los indicadores de beneficio neto se distorsionan menos por esas diferencias. Como ocurre con los métodos del precio de reventa y del coste incrementado, a los que se parece el método del margen neto operacional, esto no significa que una mera similitud de funciones entre dos empresas lleve necesariamente a comparaciones fiables. Admitiendo que, a fin de aplicar este método, se puedan aislar funciones similares entre el amplio abanico de las que las empresas pueden desempeñar, los indicadores de beneficio neto relacionados con esas funciones pueden seguir sin ser automáticamente comparables cuando, por ejemplo, las empresas en cuestión ejercen las funciones en distintos sectores económicos o en mercados con distintos niveles de rentabilidad. Cuando las operaciones comparables no vinculadas que se emplean son las de una

empresa independiente, es necesario que exista un elevado grado de similitud en distintos aspectos entre la empresa asociada y la empresa independiente en cuestión, a fin de poder comparar las operaciones vinculadas. Existen múltiples factores, distintos de los productos y las funciones, que pueden repercutir significativamente en los indicadores de beneficio neto.

2.70 El empleo de indicadores de beneficio neto puede introducir una mayor volatilidad en la determinación de los precios de transferencia por dos razones. En primer lugar, los indicadores de beneficio neto pueden verse afectados por factores que no inciden (o que tienen un efecto menor o más indirecto) sobre los márgenes brutos y sobre los precios, debido al potencial de variación de los gastos de explotación entre las distintas empresas. En segundo lugar, los indicadores de beneficio neto pueden verse afectados por algunos de los mismos factores, tales como la posición competitiva, que pueden repercutir en el precio y en los márgenes brutos, pero en este caso, será más difícil eliminar la incidencia de estos factores. En los métodos tradicionales basados en las operaciones, el efecto de estos factores puede quedar suprimido por el simple hecho de hacer más hincapié en la similitud de productos y funciones. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso y, en concreto, del efecto que provoquen las diferencias funcionales en la estructura de costes y en la renta de los comparables potenciales, los indicadores de beneficio neto pueden ser menos sensibles que los márgenes brutos a las diferencias en el grado y complejidad de las funciones y a aquellas que se observen en el nivel de riesgo (suponiendo que la atribución contractual del riesgo sea de plena competencia). Por otro lado, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso y, en concreto, de la proporción de costes fijos y variables, el método del margen neto operacional puede ser más sensible que los métodos del coste incrementado o del precio de reventa respecto de las diferencias en la utilización de la capacidad, debido a que las diferencias en los niveles de absorción de costes fijos indirectos (por ejemplo, los costes fijos de producción o los costes fijos de distribución) afectarían a los indicadores de beneficio neto, pero pueden no afectar al margen bruto o al margen bruto incrementado sobre los costes si no se traducen en diferencias en los precios. Véase el Anexo I al Capítulo II “Sensibilidad de los indicadores de beneficios brutos y netos”.

2.71 Los indicadores de beneficios netos pueden resultar directamente afectados por las fuerzas que operan en el sector: el riesgo de penetración de nuevas empresas; la posición competitiva; la eficiencia en la gestión y las estrategias individuales; el riesgo de productos sustitutivos; las variaciones en la estructura de costes (como se refleja, por ejemplo, en la antigüedad de la planta y de los equipos); las diferencias en el coste del capital (autofinanciación frente a endeudamiento, por ejemplo); y el grado de

experiencia en la actividad (por ejemplo, si la actividad está en fase de inicio o es una actividad ya asentada). A su vez, cada uno de dichos factores puede verse influido por otros muchos elementos. Por ejemplo, el nivel de amenaza de penetración de nuevas empresas en el mercado dependerá de elementos tales como la diferenciación de productos, las necesidades de capital, de las subvenciones estatales y de la legislación aplicable. Algunos de estos factores también pueden influir en la aplicación de los métodos tradicionales basados en las operaciones.

2.72 Supongamos, por ejemplo, que un contribuyente vende reproductores de audio de calidad superior a una empresa asociada y que la única información sobre beneficios de la que se dispone, referida a actividades económicas comparables, es la de la venta de reproductores de audio genéricos de calidad media. Supongamos que las ventas en el mercado de reproductores de audio de alta gama están aumentando, que este mercado se caracteriza por fuertes barreras de acceso a él, que está integrado por un reducido número de competidores y que ofrece amplias posibilidades de diferenciación de productos. Todos estos factores pueden influir significativamente en la rentabilidad de las actividades comprobadas y de las comparadas, en cuyo caso sería necesario proceder a un ajuste. Como ocurre con los restantes métodos, la fiabilidad de los ajustes necesarios condiciona la fiabilidad del análisis. Debe hacerse constar que, aun cuando dos empresas ejerzan su actividad exactamente en el mismo sector, la rentabilidad puede variar en función de sus cuotas de mercado, de sus posiciones competitivas, etc.

2.73 Cabe argumentar que las potenciales inexactitudes resultantes de los factores antes citados se reflejarán en la amplitud del rango de plena competencia. El uso de un rango puede mitigar, en cierta medida, el nivel de inexactitud pero no podrá subsanarla totalmente cuando los beneficios del contribuyente se incrementen o reduzcan dependiendo de un factor exclusivo de ese contribuyente. En este caso, el rango no podrá incluir los puntos que representen los beneficios de las empresas independientes que se hallan afectadas de modo similar por un factor único. En definitiva, el empleo de un rango no solucionará, en todos los casos, las dificultades expuestas anteriormente. Véase el análisis sobre los rangos de plena competencia de los párrafos 3.55 a 3.66.

2.74 El método del margen neto operacional puede ofrecer una solución práctica a problemas de precios de transferencia que en otras circunstancias serían insolubles, a condición de que se utilice de forma racional, practicando los ajustes necesarios que permitan salvar las diferencias mencionadas anteriormente. No debe recurrirse a este método a menos que los indicadores de beneficio neto se determinen partiendo de operaciones no vinculadas del

mismo contribuyente en circunstancias comparables o, cuando las operaciones comparables no vinculadas sean las de una empresa independiente, se consideren debidamente las diferencias entre las empresas asociadas y las empresas independientes que puedan influir sustancialmente sobre el indicador de beneficio neto utilizado. Muchos países temen que las salvaguardias establecidas para los métodos tradicionales basados en las operaciones se ignoren al aplicar el método del margen neto operacional. En consecuencia, cuando las diferencias entre las características de las empresas comparadas repercutan significativamente sobre los indicadores de beneficio neto utilizados, no sería apropiado aplicar el método del margen neto operacional sin practicar los ajustes necesarios para subsanar esas diferencias. El alcance y la precisión de estos ajustes afectarán a la fiabilidad relativa del análisis practicado en el marco de este método. Véase el análisis sobre ajustes de comparabilidad de los párrafos 3.47 a 3.54.

2.75 Otro aspecto importante de la comparabilidad es la coherencia de las cuantificaciones efectuadas. Los indicadores de beneficio neto de la empresa asociada y los de la empresa independiente deben medirse de forma coherente. Asimismo, entre las empresas pueden darse diferencias en el tratamiento de los gastos de explotación y de otros gastos que afecten a los márgenes netos, tales como las amortizaciones, las reservas o las provisiones, que deberán subsanarse a fin de alcanzar un nivel de comparabilidad fiable.

B.3.2 Selección del indicador de beneficio neto

2.76 Para la aplicación del método del margen neto operacional, la selección del indicador de beneficio neto más apropiado debe seguir las pautas contenidas en los párrafos 2.2 y 2.8 referidas a la selección del método más apropiado en función de las circunstancias del caso. Es necesario considerar las ventajas y los inconvenientes de los distintos posibles indicadores; la corrección del indicador elegido a la vista de la naturaleza de la operación vinculada, determinada específicamente mediante un análisis funcional; la disponibilidad de información fiable (en concreto sobre los comparables no vinculados) necesaria para aplicar el método del margen neto operacional sobre la base de ese indicador; y el grado de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas, incluida la fiabilidad de los ajustes de comparabilidad que puedan ser necesarios para eliminar las diferencias entre ellos cuando se aplique el método del margen neto operacional sobre la base de ese indicador. Estos factores se analizan más adelante en relación con la determinación del beneficio neto y su cálculo.

B.3.3 Determinación del beneficio neto

2.77 Como cuestión de principio, al determinar el indicador de beneficio neto para la aplicación del método del margen neto operacional únicamente deben tenerse en cuenta aquellos elementos que (a) están directa o indirectamente relacionados con la operación vinculada objeto de análisis y (b) están relacionados con la explotación de la actividad.

2.78 Los ingresos y gastos no relacionados con la operación vinculada objeto de revisión deben excluirse cuando afecten significativamente a la comparabilidad con las operaciones no vinculadas. Para poder determinar o comprobar el beneficio neto que obtiene el contribuyente por una operación vinculada (o el procedente de operaciones que deben agregarse siguiendo lo establecido en los párrafos 3.9 a 3.12) es necesario disponer de un cierto grado de segmentación de sus datos financieros. Por tanto, sería inadecuado aplicar el método del margen neto operacional al nivel de toda la empresa si esta lleva a cabo distintas operaciones vinculadas que no pueden compararse sobre una base agregada con las de una empresa independiente.

2.79 De forma similar, al analizar las operaciones entre empresas independientes con la profundidad necesaria, deben excluirse de la comparación aquellos beneficios atribuibles a operaciones que no resulten similares a las operaciones vinculadas objeto de examen. Finalmente, cuando se recurra a la utilización de indicadores de beneficio neto de una empresa independiente, los beneficios atribuibles a las operaciones de la empresa independiente no deben estar distorsionados por las operaciones vinculadas de esa empresa. Véanse los párrafos 3.9 a 3.12 sobre la valoración de las operaciones separadas y combinadas de un contribuyente y el párrafo 3.37 sobre la utilización de datos agregados de terceros.

2.80 Los elementos no relacionados con la explotación, tales como los ingresos y gastos en concepto de intereses y los impuestos sobre la renta, deben excluirse de la determinación del indicador de beneficio neto. En términos generales, también deben excluirse los elementos excepcionales y extraordinarios de naturaleza no recurrente. Sin embargo, esto no es siempre así dado que puede haber situaciones en las que lo apropiado es incluirlos, dependiendo de las circunstancias del caso, de las funciones asumidas y de los riesgos soportados por la parte objeto de análisis. Incluso cuando estos elementos excepcionales y extraordinarios no se tienen en cuenta en la determinación del indicador de beneficio neto, puede resultar útil su revisión porque pueden proporcionar información útil a los efectos del análisis de comparabilidad (por ejemplo, reflejando que la parte objeto de análisis soporta un riesgo determinado).

2.81 En aquellos casos en los que existe una correlación entre las condiciones de crédito y los precios de venta, puede ser apropiado reflejar en el cálculo del indicador de beneficio neto las rentas percibidas en concepto de intereses respecto del capital circulante a corto plazo, o proceder a un ajuste del capital circulante. Véanse los párrafos 3.47 a 3.54. Un ejemplo podría constituirlo una gran empresa de venta minorista que se beneficia de condiciones de pago a largo plazo con sus proveedores y a corto plazo con sus clientes, lo que le facilita la obtención de un excedente de caja que, a su vez, le permite fijar unos precios de venta más bajos que si no dispusiera de esas ventajosas condiciones de crédito.

2.82 La inclusión o exclusión de las pérdidas y ganancias de cambio de moneda en la determinación del indicador de beneficio neto plantea un cierto número de problemas de comparabilidad, difíciles de resolver. Primero, es necesario considerar si las ganancias o pérdidas de cambio pueden contabilizarse como ganancias o pérdidas de naturaleza comercial (por ejemplo, las ganancias o pérdidas de cambio de las cuentas de clientes o proveedores) y si la parte objeto de análisis es o no responsable de ellas. En segundo lugar, es necesario considerar toda cobertura del riesgo de cambio sobre las cuentas por cobrar o por pagar subyacentes, y tratarla del mismo modo en la determinación del beneficio neto. En efecto, si se aplica el método del margen neto operacional a una operación en la que el riesgo de cambio lo soporta la parte objeto de análisis, las ganancias o pérdidas de cambio deben contabilizarse de forma coherente (bien en el cálculo del indicador de beneficio neto o por separado).

2.83 En el caso de las actividades financieras, cuando la entrega y la recepción de pagos adelantados constituya la actividad comercial ordinaria del contribuyente, lo apropiado será considerar el efecto que provocan los intereses y los importes con naturaleza de intereses a la hora de determinar el indicador de beneficio neto.

2.84 Pueden plantearse problemas de comparabilidad difíciles de resolver cuando el tratamiento contable de algunos elementos por terceros potencialmente comparables es incierto o no permite un cálculo o ajuste fiable (véase el párrafo 2.75). Esto puede ocurrir especialmente en el caso de los costes de depreciación y amortización, las opciones de compra sobre acciones y los costes de pensiones. La decisión de si incluir o no estos elementos en la determinación del indicador del beneficio neto para aplicar el método del margen neto operacional dependerá de la importancia relativa de los efectos que se prevea que puede provocar sobre la adecuación del indicador de beneficio neto a las circunstancias de la operación y sobre la fiabilidad de la comparación (véase el párrafo 3.50).

2.85 La determinación de si deben incluirse los costes de inicio y de cese de actividad en el cálculo del indicador de beneficio neto depende de los hechos y circunstancias del caso y de si, en circunstancias comparables, partes independientes hubieran acordado o bien que la parte que ejerce las funciones soporte los posibles costes de inicio o de cese de actividad, o que estos costes se repercutan total o parcialmente sin añadir margen alguno, por ejemplo, al cliente o al empresario principal; o que se repercutan añadiendo un margen, por ejemplo, incluyéndolos en el cálculo del indicador del beneficio neto de la parte que ejerce las funciones. Véase el Capítulo IX, Parte II, Sección E, donde se analiza la cuestión de los costes de cese de actividad en el contexto de la reestructuración empresarial.

B.3.4 Ponderación del beneficio neto

2.86 La selección del denominador debe ser coherente con el análisis de comparabilidad (incluido el análisis funcional) de las operaciones vinculadas y, en concreto, debe reflejar la atribución de riesgos entre las partes (siempre que esta atribución responda a la que debería efectuarse en condiciones de plena competencia; véanse los párrafos 1.47 a 1.50). Por ejemplo, las actividades que requieran de mucho capital, tales como ciertas actividades de fabricación, pueden conllevar un alto riesgo de inversión, incluso en aquellos casos en los que los riesgos operativos (como los riesgos de mercado o de existencias) pueden estar limitados. Cuando se aplica el método del margen neto operacional a esos casos, los riesgos relacionados con la inversión se reflejan en el indicador de beneficio neto si este indicador es un rendimiento de la inversión (por ejemplo, el rendimiento de los activos o el rendimiento correspondiente al capital utilizado). Este indicador puede precisar un ajuste (o la selección de un indicador de beneficio neto distinto) dependiendo de qué parte de la operación vinculada soporta ese riesgo, así como de la importancia de las diferencias en riesgos que se observen entre la operación vinculada del contribuyente y sus comparables. Véanse los párrafos 3.47 a 3.54 en los que se analizan los ajustes de comparabilidad.

2.87 El denominador debe centrarse en el indicador o indicadores relevantes del valor de las funciones desarrolladas por la parte objeto de análisis en la operación que se está revisando, teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos. En general, y a reserva de una revisión de los hechos y circunstancias del caso, las ventas o los gastos de distribución, comprendidos en los de explotación, pueden constituir una buena base para las actividades de distribución, los costes totales o costes de explotación pueden serlo para la actividad de prestación de servicios o de fabricación, mientras que los activos de explotación pueden ser una base adecuada para

las actividades que requieren de mucho capital, como lo son ciertas actividades de fabricación o determinados servicios de infraestructura. Dependiendo de las circunstancias del caso, también resultarán adecuadas otras bases.

2.88 El denominador debe ser razonablemente independiente de la operación vinculada, dado que de no ser así, no sería un punto de partida objetivo. Por ejemplo, al analizar una operación consistente en la adquisición de bienes por un distribuidor a una empresa asociada, para proceder a su venta posterior a clientes independientes, no cabría ponderar el indicador de beneficio neto en relación con el coste de los bienes vendidos, dado que estos costes son los de la operación vinculada cuya adecuación al principio de plena competencia es objeto de análisis. Del mismo modo, en una operación vinculada consistente en la prestación de servicios a una empresa asociada, no cabe ponderar el indicador de beneficio neto con la renta obtenida en la prestación del servicio, dado que se trata de una prestación vinculada cuya adecuación al principio de plena competencia es objeto de análisis. Cuando los costes de la operación vinculada que no son objeto de análisis (como los costes de sede, los pagos de alquiler o arrendamiento, o los cánones pagados a una empresa vinculada) afectan significativamente al denominador, es preciso asegurarse de que esos costes de la operación vinculada no distorsionan sustancialmente el análisis y, en particular, que son conformes con el principio de plena competencia.

2.89 El denominador debe poder calcularse de forma fiable y coherente al nivel de las operaciones vinculadas del contribuyente. Además, la base correcta será aquella que pueda calcularse de forma fiable y coherente a nivel de las operaciones comparables en el mercado libre. En la práctica, estas circunstancias limitan la posibilidad de usar ciertos indicadores, como se analiza en el párrafo 2.99 más adelante. Del mismo modo, la atribución de los costes indirectos del contribuyente a la operación objeto de revisión debe ser adecuada y coherente a lo largo del tiempo.

B.3.4.1 Casos en los que el beneficio neto se pondera tomando las ventas como referencia

2.90 Frecuentemente se recurre al indicador de beneficio neto del beneficio neto dividido por las ventas, o margen de beneficio neto, para determinar el precio de plena competencia de las adquisiciones a una empresa asociada para su venta posterior a clientes independientes. En esos casos, la cifra de ventas que aparece en el denominador debe ser la reventa de los artículos adquiridos en la operación vinculada revisada. Los ingresos obtenidos de ventas realizadas en operaciones no vinculadas (adquisiciones a

partes independientes para la reventa a partes independientes) no deben incluirse en la determinación o en el análisis de la remuneración procedente de las operaciones vinculadas, a menos que las operaciones no vinculadas sean de naturaleza tal que no afecten significativamente a la comparación, o que las operaciones vinculadas y no vinculadas estén tan estrechamente relacionadas entre sí que no puedan evaluarse adecuadamente de forma independiente. Un ejemplo de esta última situación ocurriría en relación con los servicios post-venta independientes, o con las ventas de componentes efectuadas por un distribuidor a consumidores finales independientes cuando están estrechamente relacionadas con operaciones de compra vinculadas efectuadas por el distribuidor para su reventa a los mismos consumidores finales independientes, por ejemplo, porque la actividad se efectúe utilizando derechos u otros activos otorgados en virtud de un acuerdo de distribución. Véase también la discusión de los criterios de cartera de productos del párrafo 3.10.

2.91 Una cuestión que se plantea en los casos en los que el indicador de beneficio neto se pondera con relación a las ventas es cómo contabilizar las bonificaciones y los descuentos ofertados a los clientes por el contribuyente o sus comparables. Dependiendo de los criterios de contabilidad, las bonificaciones y los descuentos pueden considerarse como una reducción de los ingresos derivados de las ventas o como gastos. En relación con las ganancias o pérdidas resultantes del cambio de moneda pueden plantearse dificultades semejantes. Cuando estos elementos afecten sustancialmente a la comparación, la clave radica en comparar elementos similares entre sí y seguir los mismos principios contables para el contribuyente que para sus comparables.

B.3.4.2 Casos en los que el beneficio neto se pondera tomando los costes como referencia

2.92 Los indicadores basados en los costes deben utilizarse únicamente en aquellos casos en los que los costes constituyen un indicador importante del valor de las funciones desarrolladas, de los activos utilizados y de los riesgos asumidos por la parte objeto de análisis. Igualmente, para determinar qué costes deben incluirse en la base de costes debe procederse a un cuidadoso examen de los hechos y circunstancias del caso. Cuando el indicador de beneficio neto se pondere con relación a los costes, únicamente deben considerarse aquellos directa o indirectamente relacionados con la operación vinculada objeto de revisión (o las operaciones agregadas de acuerdo con los principios contenidos en los párrafos 3.9 a 3.12). Por tanto, es necesario un nivel apropiado de segmentación de las cuentas del

contribuyente, a fin de excluir del denominador los cotes relacionados con otras actividades u operaciones que tengan una incidencia notable sobre la comparabilidad con las operaciones no vinculadas. Del mismo modo, en la mayoría de los casos, únicamente los costes calificados como de explotación deben incluirse en el denominador. El análisis contenido en los párrafos anteriores 2.80 a 2.85 se aplica también a los costes como denominador.

2.93 Al aplicar el método del margen neto operacional sobre la base de los costes suele recurrirse a costes completos, que engloban los costes directos e indirectos imputables a la actividad o la operación, junto con la correspondiente atribución de los costes generales de administración de la empresa. El problema que puede plantearse es si resulta aceptable y hasta qué punto, desde la perspectiva de la plena competencia, permitir que una parte importante de los costes en los que incurre el contribuyente se repercutan sin atribuírseles un elemento de beneficio (es decir, se que se traten como costes potencialmente excluibles del denominador del indicador de beneficio neto). Esto dependería de hasta qué punto una parte independiente, en condiciones comparables, hubiera estado de acuerdo en no aplicar margen alguno sobre una parte de los costes en los que hubiera incurrido. La respuesta no debe basarse en la clasificación de los costes como “internos” o “externos”, sino en un análisis de comparabilidad (incluido el análisis funcional). Véase el párrafo 7.36.

2.94 Cuando se considere que es conforme con el principio de plena competencia repercutir ciertos costes sin margen, se plantea un segundo problema en relación con las consecuencias que esto pueda tener sobre la comparabilidad y sobre la determinación del rango de plena competencia. Dado que es necesario comparar los iguales entre sí, si los costes repercutidos sin margen se excluyen del denominador del indicador de beneficio neto del contribuyente, los costes comparables deberán excluirse también del denominador del indicador de beneficio neto comparable. Cuando se disponga de poca información sobre el desglose de los costes de los comparables se pueden plantear problemas con la comparabilidad.

2.95 Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, los costes reales, así como los costes estándar o los costes presupuestados, pueden constituir una base de costes adecuada. La utilización de los costes reales puede resultar problemática, dado que las partes objeto de análisis pueden no tener incentivo alguno para controlarlos. En los acuerdos entre partes independientes no es extraño que se fije un objetivo de ahorro de costes como componente de la remuneración. También puede ocurrir en los contratos de fabricación entre partes independientes que los precios se fijen sobre la base de los costes estándar y que cualquier diferencia al alza o a la baja observada en la comparación entre los costes reales y los costes estándar

se atribuya al fabricante. Cuando reflejen los acuerdos que hubieran suscrito partes independientes, podrá recurrirse a mecanismos similares en la aplicación del método del margen neto operacional basado en los costes. Véase el párrafo 2.52, en el que se analiza la misma cuestión, referida al método del coste incrementado.

2.96 La utilización de costes presupuestados puede plantear también problemas cuando se observen diferencias importantes entre estos y los costes reales. Es muy improbable que partes independientes determinen sus precios sobre la base de los costes presupuestados sin acordar qué factores se van a considerar al determinar el presupuesto, sin examinar cómo se han comparado los costes presupuestados con los costes reales en años anteriores, y sin reflexionar sobre el tratamiento de las circunstancias imprevistas.

B.3.4.3 Casos en los que el beneficio neto se pondera tomando los activos como referencia

2.97 El rendimiento de los activos (o del capital) puede constituir una base adecuada en aquellos casos en los que los activos (y no los costes o las ventas) constituyan un mejor indicador del valor añadido por la parte objeto de análisis, por ejemplo, en ciertas actividades de fabricación u otras con fuerte utilización de activos y en las actividades financieras con fuerte utilización de capital. Cuando el indicador es un beneficio neto ponderado tomando como referencia los activos, sólo debe acudirse a los activos de explotación. Estos incluyen los activos fijos tangibles de explotación, que comprenden los terrenos y edificios, las fábricas y equipamientos, los activos intangibles de explotación utilizados en la actividad, tales como las patentes y los conocimientos prácticos –*know how*–, y los activos de capital circulante, como las existencias y las cuentas por cobrar (descontando las cuentas por pagar). Las inversiones y el saldo de caja no suelen considerarse activos de explotación fuera del sector financiero.

2.98 En aquellos casos en los que el beneficio neto se pondere tomando como referencia los activos, se plantea la cuestión de como valorar esos activos, es decir, según valor contable o valor de mercado. Si se utiliza el valor contable puede distorsionarse la comparación, por ejemplo, cuando esta se realiza entre empresas que han amortizado sus activos y otras con activos más recientes en curso de amortización, y entre empresas que utilizan intangibles adquiridos con otras que utilicen intangibles de desarrollo interno. Estas dificultades pueden atenuarse recurriendo al valor normal de mercado, si bien este otro puede plantear otros problemas, especialmente de fiabilidad, cuando la valoración de los activos sea incierta, y puede resultar extremadamente costosa y gravosa, especialmente en el caso de los activos

intangibles. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, podrían efectuarse ajustes que mejoren la fiabilidad de la comparación. La elección entre el valor contable, el valor contable ajustado, el valor de mercado y otras opciones de las que pueda disponerse, debe realizarse con la intención de conseguir la medida más fiable, teniendo en cuenta el volumen y la complejidad de la operación y los costes y cargas de cumplimiento que entraña; véase el Capítulo III, Sección C.

B.3.4.4 Otros indicadores posibles de beneficio neto

2.99 En función de los hechos y circunstancias de la operación, puede ser posible recurrir a otros indicadores de beneficio neto. Por ejemplo, dependiendo del sector y de las operaciones vinculadas objeto de revisión, podría ser útil examinar otros denominadores en los que puedan existir datos independientes, por ejemplo, superficie de los puntos de venta, peso de los productos transportados, número de empleados, tiempo, distancia, etc. Si bien no hay motivo para excluir la utilización de estas magnitudes cuando provean una indicación razonable del valor añadido por la parte objeto de análisis a la operación vinculada, deben utilizarse únicamente cuando sea posible obtener información comparable que resulte fiable y que apoye la aplicación del método sobre la base de tal indicador de beneficio neto.

B.3.5 *Ratio Berry**

2.100 La “ratio Berry” se define como el cociente entre el beneficio bruto y los gastos operativos. Los intereses y las rentas extraordinarias se excluyen de la determinación del beneficio bruto; las amortizaciones y depreciaciones pueden incluirse o no en los gastos de explotación, en función de la incertidumbre que puedan generar en la evaluación y comparabilidad.

2.101 La selección de un indicador financiero correcto depende de los hechos y circunstancias del caso; véase el párrafo 2.76. En ocasiones se ha expresado una cierta preocupación por el hecho de que pueda recurrirse a la ratio Berry cuando no es apropiado, sin adoptar la prudencia necesaria que debe regir la selección y aplicación de cualquier método de determinación de precios de transferencia y de cualquier indicador financiero. Véase el párrafo 2.92 en relación con el uso de indicadores basados en los costes en general.

* (N. de la T.) Ratio utilizada por el Profesor Charles Berry, experto de la Administración Tributaria estadounidense, en un caso concreto seguido ante esa Administración, en la que se relacionaba el margen de beneficio bruto con los gastos operativos como medida de la rentabilidad de una empresa.

Una dificultad común que se plantea en la determinación de la ratio Berry es que es muy sensible a la clasificación o no de los costes como costes de explotación, por lo que puede plantear problemas de comparabilidad. Asimismo, los problemas planteados en los párrafos 2.93 y 2.94 anteriores en relación con los costes repercutidos sin margen se plantean también en la aplicación de la ratio Berry. Para que esta ratio resulte apropiada para calcular la contraprestación obtenida en una operación vinculada (por ejemplo, consistente en la distribución de productos), es necesario:

- Que el valor de las funciones desarrolladas en la operación vinculada (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) sea proporcional a los gastos de explotación;
- Que el valor de las funciones desarrolladas en la operación vinculada (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) no esté sensiblemente afectada por el valor de los productos distribuidos; es decir, que no sea proporcional a las ventas, y
- Que el contribuyente no lleve a cabo, en las operaciones vinculadas, ninguna otra actividad importante (por ejemplo, la de fabricación) que deba remunerarse mediante otro método o indicador financiero.

2.102 La ratio Berry demuestra su utilidad en las actividades de intermediación en las que un contribuyente adquiere bienes a una empresa asociada y los vende a otra empresa asociada. En estos casos no puede aplicarse el método del precio de reventa, debido a la ausencia de ventas no vinculadas. Tampoco sería aplicable un método de coste incrementado que fijara un margen sobre el coste de los bienes vendidos si el coste de esos bienes vendidos se corresponde con las adquisiciones vinculadas. Sin embargo, los gastos de explotación en el caso de un intermediario pueden ser razonablemente independientes de la determinación de precios de transferencia, salvo en el caso de que estén muy influidos por los costes de una operación vinculada, como pueden ser los gastos de la sede, los arrendamientos o cánones pagados a una empresa asociada; por tanto, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, la ratio Berry puede ser un indicador correcto, teniendo en cuenta los comentarios expuestos anteriormente.

B.3.6 Otras pautas

2.103 Si bien el problema que plantea la utilización de datos agregados de terceros no surge exclusivamente cuando se utiliza el método del margen neto operacional, en la práctica se plantea de forma más acusada al recurrir a él, debido a su dependencia de comparables externos. El problema surge

porque es frecuente la carencia de datos públicos que permitan determinar los indicadores de beneficio neto de terceros a nivel de sus operaciones, hecho que determina la necesidad de que exista comparabilidad suficiente entre las operaciones vinculadas y las operaciones comparables no vinculadas. Dado que es frecuente que los únicos datos disponibles de terceros sean los datos agregados referidos al conjunto de la sociedad, las funciones ejercidas por la parte no vinculada en sus operaciones globales deben alinearse estrechamente con las funciones desarrolladas por la parte objeto de análisis en sus operaciones vinculadas a fin de poder utilizar las funciones de la parte no vinculada en la determinación de un resultado de plena competencia de la parte objeto de análisis. El objetivo general es el de determinar un nivel de segmentación que permita obtener comparables fiables de la operación vinculada en función de las características del caso concreto. Cuando sea imposible en la práctica llegar al nivel de desagregación considerado como ideal en estas Directrices, seguirá siendo importante tratar de encontrar los comparables más fiables posibles, como se señala en el párrafo 3.2, procediendo a los ajustes necesarios fundamentados en la información de la que se disponga.

2.104 Véanse en concreto los párrafos 3.18 y 3.19 en lo que respecta a la parte objeto de análisis, los párrafos 3.55 a 3.66 sobre el rango de plena competencia, y los párrafos 3.75 a 3.79 sobre la utilización de datos referidos a varios años.

B.4 Ejemplos de la aplicación del método del margen neto operacional

2.105 A título ilustrativo, el ejemplo del coste incrementado del párrafo 2.53 demuestra la necesidad de ajustar el margen bruto derivado de las operaciones a fin de obtener una comparación coherente y fiable. Estos ajustes pueden efectuarse sin dificultad cuando los costes relevantes pueden analizarse fácilmente. No obstante, cuando es sabido que es necesario practicar un ajuste, pero no es posible identificar los costes particulares que requieren el ajuste, aun puede identificarse el beneficio neto de la operación y, de este modo, asegurar la consistencia en la medición. Por ejemplo, si no pueden identificarse los gastos de supervisión, generales y de administración que se tratan como parte de los costes de los bienes vendidos a las empresas independientes X, Y y Z a fin de ajustar el margen para aplicar de forma fiable el método del coste incrementado, será necesario examinar los indicadores de beneficio neto, en ausencia de comparaciones más aceptables.

2.106 Quizá se requiera un planteamiento similar cuando existen diferencias entre las funciones desarrolladas por las partes objeto de comparación. Supongamos que los hechos son los mismos que en el ejemplo

del párrafo 2.38 con la excepción de que son las empresas independientes comparables las que ejercen la función adicional de asistencia técnica, y no la empresa asociada, y que estos costes se incorporan en los costes de los bienes vendidos, pero no pueden identificarse aisladamente. Debido a las diferencias de productos y de mercados, puede resultar imposible hallar un precio libre comparable y el método del precio de reventa no sería fiable, dado que el margen bruto de las empresas independientes tendría que ser más alto que el de la empresa asociada con el fin de reflejar las funciones adicionales y cubrir costes adicionales desconocidos. En este ejemplo, puede ser más fiable examinar los márgenes netos para evaluar la diferencia en los precios de transferencia que correspondería a la diferencia de funciones. En ese caso, el empleo de márgenes netos debe tener en cuenta la comparabilidad y puede implicar el riesgo de no resultar fiable si las funciones adicionales o las diferencias del mercado tuvieran un efecto importante sobre el margen neto.

2.107 Los hechos son los mismos que en el párrafo 2.36. Sin embargo, el importe de los gastos de garantía en que incurre el distribuidor A resulta imposible de cuantificar, de forma que no puede procederse a ajustar de forma fiable el beneficio bruto de A para que su margen de beneficio bruto sea comparable al de B. Sin embargo, si no hay otras diferencias funcionales relevantes entre A y B, y si se conoce la relación entre el beneficio neto de A y sus ventas, podría aplicarse el método del margen neto operacional a B, comparando el margen de A calculado sobre la ratio ventas a beneficio neto, con el margen de B calculado sobre la misma base.

C. Método de la distribución del resultado

C.1. Términos generales

2.108 El método de la distribución del resultado aspira a eliminar el efecto que provocan sobre los resultados las condiciones especiales acordadas o impuestas en una operación vinculada (o en operaciones vinculadas que resulte adecuado agregar según los principios expuestos en los párrafos 3.9 a 3.12), determinando la distribución de los beneficios que hubieran acordado empresas independientes atendiendo a su participación en la operación u operaciones. El método de la distribución del resultado identifica, en primer lugar, el beneficio que ha de distribuirse entre las empresas asociadas por las operaciones vinculadas en las que participan (los “resultados conjuntos”). Las referencias a los términos “resultados” y “beneficios” deben entenderse como aplicables igualmente a las pérdidas. Véanse los párrafos 2.124 a 2.131 en los que se analiza cómo calcular los

resultados objeto de distribución. Posteriormente se procede a la distribución de ese resultado común entre las empresas asociadas en función de unos criterios económicamente válidos, de forma que se aproximen a la distribución de beneficios que se hubieran previsto y reflejado en un acuerdo pactado en condiciones de plena competencia. Véanse los párrafos 2.132 a 2.145, donde se analiza cómo proceder a la distribución de los resultados conjuntos.

C.2 *Ventajas e inconvenientes*

2.109 La principal ventaja del método de la distribución del resultado es que constituye un método para abordar las operaciones estrechamente integradas, respecto de las que no sería posible aplicar un método unilateral. Véase por ejemplo el análisis sobre la idoneidad y la aplicación de los métodos de distribución del resultado en el ámbito del comercio mundial con instrumentos financieros entre empresas asociadas de la Parte III, Sección C del Informe sobre la Atribución de beneficios a los establecimientos permanentes². Este método de distribución del resultado puede ser también el más apropiado cuando ambas partes de una operación realizan aportaciones únicas y valiosas (por ejemplo, aportan intangibles únicos) a la operación, dado que en ese caso, partes independientes podrían desear compartir los resultados de la operación en proporción a sus aportaciones respectivas, por lo que un método bilateral es más apropiado que un método unilateral en esas circunstancias. Además, en el caso de una aportación única y valiosa, la información sobre comparables fiables puede ser insuficiente para aplicar otro método. Por el contrario, el método de la distribución del resultado normalmente no se aplicaría en aquellos casos en los que una parte ejerce funciones simples y no realiza ninguna aportación única significativa (por ejemplo la fabricación por contrato o las actividades prestadas bajo contratos de servicios en las circunstancias adecuadas), dado que en esos casos, el método de la distribución del resultado no resultaría apropiado en vista del análisis funcional de esa parte. Véanse los párrafos 3.38 a 3.39 donde se analizan las limitaciones relativas a la disponibilidad de comparables.

² Véase el Informe sobre la Atribución de beneficios a establecimientos permanentes aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 24 de junio de 2008 y por el Consejo para su publicación el 17 de julio de 2008, así como la versión depurada de este informe “*2010 Sanitised Version of the Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments*” aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 y por el Consejo para su publicación el 22 de julio de 2010.

2.110 Cuando existen datos comparables, estos pueden resultar pertinentes en el análisis de la distribución del resultado para corroborar el reparto de beneficios al que hubieran procedido partes independientes en circunstancias comparables. Los datos comparables también pueden resultar útiles en el análisis de la distribución del resultado para determinar el valor de las aportaciones de cada empresa asociada a la operación. En efecto, se parte de la hipótesis de que partes independientes hubieran dividido los resultados conjuntos en proporción al valor de sus respectivas aportaciones a la generación de ese beneficio. Por otro lado, la vinculación de los datos extraídos del mercado con esas operaciones, considerados al valorar la contribución que realiza cada empresa asociada a las operaciones vinculadas, es menor que en el caso de otros métodos disponibles.

2.111 Sin embargo, en los casos en los que no haya otras pruebas directas sobre cómo hubieran dividido partes independientes el resultado obtenido en operaciones comparables efectuadas en condiciones comparables, su distribución se basará en el reparto de funciones (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) entre las propias empresas asociadas.

2.112 Otra ventaja del método de la distribución del resultado reside en su flexibilidad, que le permite tener en cuenta hechos y circunstancias específicos y posiblemente únicos de las empresas asociadas, y que no se observan en empresas independientes, sin dejar por ello de ser un criterio respetuoso con el principio de plena competencia en la medida en que refleja lo que hubieran hecho partes independientes que actuaran con lógica comercial frente a las mismas circunstancias.

2.113 Otra ventaja más es que, al amparo del método de la distribución del resultado, es menos probable que una de las partes de la operación vinculada obtenga un resultado excepcional e improbable, dado que el análisis se realiza sobre ambas partes de la operación. Este aspecto adquiere especial relevancia cuando se analiza la aportación de las partes con relación a los activos intangibles empleados en las operaciones vinculadas. Puede recurrirse también a este criterio bilateral para lograr el reparto de los beneficios obtenidos por las economías de escala u otras eficiencias nacidas de la actividad conjunta, que satisfaga tanto al contribuyente como a las administraciones tributarias.

2.114 Una de las debilidades que presenta el método de la distribución del resultado reside en las dificultades que plantea su aplicación. A primera vista, este método puede parecer fácilmente accesible tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias, ya que tiende a apoyarse menos en la información procedente de terceros independientes.

Sin embargo, las empresas asociadas y las administraciones tributarias pueden tener dificultades para acceder a la información relativa a filiales extranjeras. Por otra parte, será difícil determinar los ingresos y los gastos conjuntos de todas las empresas asociadas participantes en las operaciones vinculadas, pues ello requeriría que los documentos contables se basaran en los mismos criterios y que se efectuaran ajustes en función de las distintas prácticas contables y monedas utilizadas. Asimismo, al aplicar el método de la distribución del resultado al resultado de explotación puede ser difícil tanto identificar los gastos de explotación relacionados con las operaciones, como distribuir correctamente los costes entre esas operaciones y otras actividades de las empresas asociadas.

C.3 Orientaciones para la aplicación

C.3.1 Términos generales

2.115 Estas Directrices no pretenden constituir un catálogo exhaustivo de las formas en las que es posible aplicar el método de la distribución del resultado. La aplicación de este método dependerá de las circunstancias del caso y de la información disponible, pero el objetivo final debe ser el de acercarse lo máximo posible a la distribución de resultados que hubieran efectuado las partes en caso de tratarse de empresas independientes.

2.116 Al aplicar este método, los resultados conjuntos son susceptibles de reparto entre las empresas asociadas sobre la base de una distribución válida desde el punto de vista económico, que se aproxime a la que se hubiera previsto y reflejado en un acuerdo suscrito en condiciones de plena competencia. En general, la determinación de los resultados conjuntos objeto de la distribución y los factores de distribución deben:

- ser coherentes con el análisis funcional de la operación vinculada objeto de revisión y, en concreto, reflejar la atribución de los riesgos entre las partes;
- ser coherentes con la determinación de los resultados conjuntos que van a distribuirse y con los factores de distribución que se hubieran podido acordar entre partes independientes;
- ser coherentes con el tipo de criterio utilizado para la distribución del resultado (por ejemplo, el análisis de aportaciones, análisis residual, u otros; criterios a priori o a posteriori, como se analiza en los párrafos 2.118 a 2.145 más adelante), y
- ser susceptibles de medición fiable.

2.117 Además,

- si se recurre al método de la distribución del resultado a fin de determinar el precio de transferencia en una operación vinculada (criterio a priori), sería razonable esperar que el tiempo de vigencia del acuerdo y el criterio o las claves de atribución se determinaran antes de la operación;
- quien utilice el método de la distribución del resultado (el contribuyente o la administración tributaria) debe estar preparado para explicar por qué lo ha considerado el método más apropiado a las circunstancias del caso, así como el procedimiento seguido para su aplicación y, en particular, el criterio o las claves de atribución que se hayan utilizado para el reparto de los resultados conjuntos, y
- como norma general, la determinación de los resultados conjuntos que vayan a distribuirse, así como de los factores de distribución, deberán ser homogéneos durante la vigencia del acuerdo, incluidos los años en los que se incurra en pérdidas, excepto en el caso de que partes independientes en circunstancias comparables hubieran llegado a otros acuerdos, siempre que la razón que sustenta la utilización de criterios o claves de atribución distintos esté documentada, o cuando las circunstancias específicas justifiquen una renegociación entre partes independientes.

C.3.2 Criterios diversos para la distribución de resultados

2.118 Existen distintos criterios que permiten determinar la distribución de los resultados sobre la base de los resultados previstos o reales, según convenga al caso, que hubiesen pactado empresas independientes. Dos de ellos se analizan en los párrafos siguientes. Estos criterios: el análisis de aportaciones y el análisis, residual no son necesariamente exhaustivos ni mutuamente excluyentes.

C.3.2.1 Análisis de aportaciones

2.119 En un análisis de las aportaciones, los resultados conjuntos, que están constituidos por el importe total de los beneficios que correspondan a las operaciones vinculadas sometidas a examen, se dividirían entre las empresas asociadas sobre la base de una aproximación razonable a la distribución de resultados que hubieran llevado a cabo empresas independientes que participaran en operaciones comparables. Esta distribución puede apoyarse en datos comparables siempre que se disponga de ellos. En ausencia de estos datos comparables, la distribución suele

basarse en el valor relativo de las funciones desarrolladas por cada una de las empresas asociadas que participa en las operaciones vinculadas, teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos. Cuando el valor relativo de las aportaciones pueda medirse directamente no será necesario calcular el valor normal de mercado de las aportaciones de cada participante.

2.120 Puede ser difícil determinar el valor relativo de la aportación que realiza cada una de las empresas asociadas a las operaciones vinculadas y, normalmente, el criterio dependerá de los hechos y circunstancias que concurren en cada caso. Esta determinación podría efectuarse comparando la naturaleza e intensidad de la aportación realizada por cada parte de distintas formas (por ejemplo, prestación de servicios, gastos de desarrollo, capital invertido) y procediendo a la asignación de un porcentaje en función de esta comparación y de los datos externos extraídos del mercado. Véanse los párrafos 2.132 a 2.145 en los que se analiza la distribución de los resultados conjuntos.

C.3.2.2 Análisis residual³

2.121 El análisis residual divide el resultado común procedente de la operación vinculada examinada en dos fases. En la primera, a cada participante se le atribuye una remuneración de plena competencia por las aportaciones que haya realizado, distintas de las que tengan carácter único, a las operaciones vinculadas en las que participa. Normalmente, esta remuneración inicial se calcula aplicando uno de los métodos tradicionales basados en las operaciones o el método del margen neto operacional, tomando como referencia la contraprestación percibida por empresas independientes que realicen operaciones comparables. En consecuencia, el rendimiento inicial no tendrá en cuenta, por lo general, el beneficio que genere cualquier aportación única y valiosa que efectúen los participantes. En la segunda fase, todo beneficio (o pérdida) residual tras la distribución efectuada en la primera fase se distribuirá entre las partes atendiendo a un análisis de los hechos y circunstancias que concurren, siguiendo las pautas contenidas en los párrafos 2.132 a 2.145 sobre el reparto de los resultados conjuntos.

2.122 Un criterio alternativo para la aplicación del análisis residual consistiría en tratar de reproducir el resultado que se derivaría de las negociaciones entre empresas independientes en el mercado libre. En este

³ En el Anexo II al Capítulo II se recoge un ejemplo ilustrativo de la aplicación del método de la distribución del resultado residual.

contexto, la remuneración inicial calculada en la primera fase para cada participante corresponde al precio más bajo que estaría dispuesto a aceptar un vendedor independiente en circunstancias similares y al precio más alto que, razonablemente, estaría dispuesto a pagar un comprador. Cualquier divergencia entre estas dos cifras constituiría el resultado residual respecto del que negociarían las empresas independientes. En la segunda fase, el análisis residual dividiría este resultado conjunto sobre la base de un análisis de los factores pertinentes que mostraran cómo hubieran repartido entre sí unas empresas independientes la diferencia entre el precio mínimo del vendedor y el máximo del comprador.

2.123 En ciertos casos podría efectuarse un análisis, quizás como parte de la distribución del resultado residual o como un método de distribución de resultados en sí mismo, teniendo en cuenta el descuento de flujos de caja de las partes de las operaciones vinculadas durante la duración prevista de la actividad. Este método puede ser efectivo en los casos de inicio de actividad, cuando las previsiones de tesorería se efectúan en el marco de la viabilidad de un proyecto, y la inversión de capital y el volumen de ventas puedan estimarse con un nivel de certidumbre razonable. En cualquier caso, la fiabilidad de un criterio de este tipo dependerá del empleo de un tipo de descuento apropiado, basado en las referencias existentes en el mercado. Desde este punto de vista, debe señalarse que las primas de riesgo utilizadas por las empresas para calcular el tipo de descuento pertinente, no distinguen entre sociedades y aun menos entre segmentos de actividades, y la estimación de la fecha de obtención de los ingresos puede ser problemática. En consecuencia, la aplicación de este criterio requiere unas dosis altas de prudencia y debería complementarse, en lo posible, con información obtenida por otros métodos.

C.3.3 Determinación de los resultados conjuntos objeto de distribución

2.124 Los resultados conjuntos que son el objeto de la distribución aplicando este método de la distribución del resultado son los que obtienen las empresas asociadas de las operaciones vinculadas en las que intervienen. Los resultados conjuntos objeto de distribución sólo pueden ser los que se deriven de la actividad o actividades vinculadas objeto de revisión. Al determinar estos resultados es esencial, en primer lugar, identificar las operaciones a las que va a aplicarse el método. También resulta fundamental identificar el nivel de agregación. Véanse los párrafos 3.9 a 3.12. Cuando un contribuyente realiza operaciones vinculadas con más de una empresa

asociada, es igualmente necesario identificar las partes en relación con las operaciones y los resultados que se van a dividir entre ellas.

2.125 Para determinar los resultados conjuntos objeto de distribución, es necesario que la contabilidad de las partes en la operación a la que se aplica este método esté expresada utilizando la misma base en lo que se refiere a prácticas contables y moneda, para poder combinarlas posteriormente. Dado que las normas contables influyen directamente en la determinación de los beneficios objeto de distribución, estas deben seleccionarse antes de proceder a aplicar el método y mantenerse durante la vigencia del acuerdo. Véanse los párrafos 2.115 a 2.117 en los que se ofrecen unas pautas generales sobre la coherencia en la determinación de los resultados conjuntos objeto de distribución.

2.126 En ausencia de normas de contabilidad fiscal armonizadas, la contabilidad financiera puede constituir un punto de partida desde el que determinar el resultado objeto de distribución. La utilización de otros datos financieros (por ejemplo, la contabilidad de costes) es permisible cuando estos datos existan, sean fiables, comprobables y estén lo suficientemente desagregados. En este contexto, la cuentas de resultados por líneas de producto o la contabilidad por departamentos pueden ser las más útiles.

C.3.3.1 Resultados reales o previstos

2.127 Cuando unas empresas asociadas recurran al método de la distribución del resultado para determinar los precios de transferencia de las operaciones vinculadas (es decir, un criterio a priori), estas intentarán llegar a una distribución de beneficios aceptable para empresas independientes que llevaran a cabo operaciones comparables. Dependiendo de los hechos y circunstancias de cada caso, en la práctica se observan distribuciones basadas en los resultados reales o en los previstos.

2.128 Cuando una administración tributaria analiza la aplicación del procedimiento usado a priori, para evaluar si este ha conducido a resultados de plena competencia, es fundamental que tenga en cuenta que el contribuyente podía desconocer cuáles iban a ser los resultados reales de la actividad económica en el momento en que se establecieron las condiciones de la operación vinculada. Si no se tiene en cuenta este hecho, la aplicación del método de la distribución del resultado podría penalizar o recompensar a un contribuyente sobre la base de circunstancias imprevisibles para él. Esta aplicación sería contraria al principio de plena competencia, ya que unas empresas independientes, en condiciones similares, sólo hubieran podido

basarse en previsiones, sin tener conocimiento de cuáles serían los resultados reales. Véase también el párrafo 3.74.

2.129 Al utilizar el método de la distribución del resultado para determinar las condiciones de las operaciones vinculadas, las empresas asociadas intentarán llegar a una distribución de resultados aceptable para empresas independientes. El análisis de las condiciones de la operación vinculada que llevan a cabo empresas asociadas, utilizando el método de la distribución del resultado, será muy fácil para la administración tributaria cuando las empresas asociadas hayan determinado tales condiciones sobre la misma base. El análisis podrá comenzar en ese caso partiendo de la misma base, a fin de comprobar si la distribución de resultados reales es conforme con el principio de plena competencia.

2.130 Cuando las empresas asociadas han fijado las condiciones de sus operaciones vinculadas sobre una base distinta del método de la distribución del resultado, las administraciones tributarias las evaluarán sobre la base de los resultados realmente obtenidos por la empresa. Sin embargo, es necesario tener cuidado para garantizar que la aplicación del método de la distribución del resultado se lleva a cabo en un contexto similar al que las empresas asociadas habrían experimentado, es decir, apoyándose en la información que conocían las empresas asociadas en el momento de efectuar las operaciones, o que podían prever con buena lógica, a fin de evitar el uso de la retrosección. Véanse los párrafos 2.11 y 3.74.

C.3.3.2 Diferentes medidas del resultado⁴

2.131 Por lo general, los resultados conjuntos que se distribuyen mediante el método de la distribución del resultado son los resultados de explotación. Esta forma de aplicar el método de la distribución del resultado garantiza que tanto la renta como los gastos del grupo multinacional se atribuyen a la empresa asociada sobre una base coherente. Sin embargo, en algunas ocasiones, lo apropiado puede ser llevar a cabo una distribución de los beneficios brutos y proceder después a la deducción de los gastos en los que se haya incurrido o que sean atribuibles a cada empresa en cuestión (excluyendo los gastos considerados al calcular los beneficios brutos). En esos casos, cuando se aplican análisis distintos para la distribución de la renta bruta y de los gastos de la empresa multinacional entre las empresas asociadas, es necesario tener cuidado para garantizar que los gastos en los

⁴

En el Anexo III al Capítulo II se recoge un ejemplo ilustrativo de las distintas medidas del resultado cuando se aplica un método de la distribución del resultado.

que se haya incurrido o que sean atribuibles a cada empresa sean coherentes con las actividades y riesgos que les correspondan, y que la atribución de los beneficios brutos es igualmente coherente con la atribución de actividades y riesgos. Por ejemplo, en el caso de un grupo multinacional que lleva a cabo operaciones comerciales a escala mundial altamente integradas, y que implican diversos tipos de bienes, podrán determinarse las empresas que incurren en los gastos (o a las que se les atribuyen), pero difícilmente se podrá precisar la actividad concreta a la que se refieren esos gastos. En ese caso, lo apropiado sería distribuir el beneficio bruto correspondiente a cada actividad y deducir posteriormente del beneficio bruto total que resulta los gastos en los que incurra cada empresa o que se le puedan atribuir, teniendo en cuenta la observación mencionada anteriormente.

C.3.4 Cómo distribuir los resultados conjuntos

C.3.4.1 Términos generales

2.132 La importancia de las operaciones no vinculadas comparables o de los datos internos y del criterio utilizado para proceder a una distribución de plena competencia de los beneficios dependerá de los hechos y circunstancias del caso. Por tanto, no es deseable presentar una lista prescriptiva de criterios o de claves de atribución. Para saber más sobre la coherencia en la determinación de los factores de distribución, véanse los párrafos 2.115 a 2.117. Asimismo, los criterios o las claves de atribución utilizadas en la distribución del resultado deben:

- ser razonablemente independientes de la formulación de una política de precios de transferencia, es decir, que deben apoyarse en datos objetivos (por ejemplo, ventas a terceros independientes) y no sobre datos relacionados con la remuneración de las operaciones vinculadas (por ejemplo, ventas a empresas asociadas), y
- sustentarse sobre datos comparables, datos internos, o ambos.

C.3.4.2 Utilización de los datos extraídos de operaciones no vinculadas comparables

2.133 Un criterio posible consiste en dividir los resultados conjuntos sobre la base de la distribución efectiva de los resultados que se efectúa en operaciones comparables no vinculadas. Entre los ejemplos de posibles fuentes de información sobre operaciones no vinculadas que pueden resultar útiles para la elección del criterio de distribución del resultado, dependiendo

de los hechos y circunstancias de cada caso, encontramos los acuerdos de participación que celebran algunas empresas independientes (joint-venture) en virtud de los que comparten beneficios, como en los proyectos de desarrollo en las industrias petroleras y gasísticas, las colaboraciones farmacéuticas, los acuerdos de comercialización y promoción conjunta, los acuerdos entre discográficas independientes y artistas, los acuerdos entre partes independientes en el sector de los servicios financieros, etc.

C.3.4.3 Claves de atribución

2.134 En la práctica, el reparto de los resultados conjuntos en aplicación de un método de la distribución del resultado se realiza normalmente utilizando una o más claves de atribución. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, la clave de atribución puede ser una cifra (por ejemplo, un 30-70% basada en datos sobre repartos similares entre empresas independientes en operaciones comparables), o una variable (por ejemplo, el valor relativo de los gastos de comercialización del participante) u otras posibles claves que se analizan más adelante. Cuando se recurre a más de una clave de atribución, es necesario ponderar cada una de ellas por separado para determinar la aportación relativa que representan en la obtención del resultado común.

2.135 En la práctica, se suelen utilizar las claves de atribución basadas en los activos / el capital (activos de explotación, inmovilizado material, activos intangibles, capital empleado) o en los costes (gastos o inversiones relativas en áreas claves como investigación y desarrollo, ingeniería, comercialización). Dependiendo de los hechos y circunstancias de las operaciones, también pueden resultar adecuadas otras claves de distribución basadas, por ejemplo, en el incremento de las ventas, el recuento de personal (número de personas que llevan a cabo las funciones clave que aportan valor a la operación), el tiempo dedicado por un grupo de trabajadores si existe una fuerte correlación entre ese tiempo y la generación de resultados conjuntos, número de servidores informáticos, datos almacenados, superficie de puntos de venta, etc.

Claves de atribución basadas en los activos

2.136 Puede recurrirse a las claves de atribución basadas en los activos o en el capital cuando la relación entre los activos tangibles o intangibles o el capital empleado y la generación de valor en el contexto de la operación vinculada es muy estrecha. Véase el párrafo 2.145 en el que se analiza brevemente la distribución de los resultados conjuntos en función del capital empleado. Para que una clave de atribución tenga sentido debe aplicarse

coherentemente a todas las partes de la operación. Véase el párrafo 2.98 en el que se analizan cuestiones de comparabilidad relacionadas con la valoración de los activos en el contexto del método del margen neto operacional, cuya aplicación también es válida en el contexto del método de la distribución del resultado.

2.137 Otra circunstancia concreta en la que puede determinarse que el método de la distribución del resultado es el más apropiado es cuando cada parte de la operación aporta intangibles únicos y de gran valor. Los activos intangibles plantean problemas difíciles tanto por lo que respecta a su identificación, como a su valoración. La identificación de los intangibles puede resultar difícil debido a que no todos los activos intangibles valiosos aparecen registrados en la contabilidad. Una parte esencial del análisis de la distribución del resultado de la operación consiste en identificar los activos intangibles que aporta cada empresa asociada a la operación vinculada y su valor relativo. En el Capítulo VI de estas Directrices se ofrecen las líneas rectoras en materia de activos intangibles. Pueden consultarse también los ejemplos del anexo al Capítulo VI “Ejemplos ilustrativos de la aplicación de las Directrices sobre precios de transferencia a activos intangibles de valoración muy incierta”.

Claves de atribución basadas en los costes

2.138 Las claves de atribución basadas en los gastos pueden resultar idóneas cuando es posible observar una fuerte correlación entre los gastos relativos incurridos y el valor relativo añadido. Por ejemplo, los costes de comercialización pueden ser una clave adecuada para los distribuidores-comercializadores si la publicidad genera intangibles de comercialización significativos, por ejemplo, en el caso de bienes de consumo, cuando la publicidad incide sobre el valor de los intangibles de comercialización. Los gastos de investigación y desarrollo pueden ser adecuados para los fabricantes, cuando estén relacionados con el desarrollo de intangibles mercantiles de valor, como las patentes. Sin embargo, si, por ejemplo, cada parte aporta distintos intangibles valiosos, no es apropiado utilizar una clave de atribución basada en los costes, a menos que el coste constituya una medida fiable del valor relativo de esos intangibles. Suele recurrirse al importe de las remuneraciones cuando las funciones humanas son el factor principal para la generación de resultados conjuntos.

2.139 Las claves de atribución basadas en los costes tienen la ventaja de la simplicidad. Sin embargo, no siempre se observa una fuerte correlación entre los gastos relativos y el valor relativo, como se analiza en el párrafo 6.27. Un problema que puede surgir con las claves de atribución basadas en los costes es que pueden ser muy sensibles a la calificación financiera de

estos. Por tanto, es imprescindible identificar de antemano qué costes se considerarán en la determinación de la clave de atribución, y asegurarse de que todas las partes aplican uniformemente esa clave.

Plazos

2.140 Otra cuestión importante es la determinación del plazo en el que deben considerarse los elementos incluidos en la determinación de la clave de atribución (por ejemplo, los activos, costes u otros). Se plantea un problema cuando transcurre un plazo de tiempo entre el momento en el que se incurre en los gastos y el momento en que se genera el valor y, en ocasiones, es difícil decidir qué período de gastos usar. Por ejemplo, en el caso de una clave de atribución basada en los costes, el recurso al gasto de un año puede ser adecuado en algunos casos, mientras que en otros será más oportuno recurrir a los gastos acumulados (netos de amortización o depreciación cuando sea adecuado a las circunstancias) en los que se haya incurrido tanto en los ejercicios anteriores como en el corriente. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, esta determinación puede tener gran trascendencia sobre la atribución de los beneficios entre las partes. Como se señaló en los párrafos 2.116 y 2.117 anteriores, la elección de la clave de atribución debe ser adecuada a las circunstancias concretas del caso y constituir una aproximación fiable a la distribución de resultados que hubieran acordado partes independientes.

C.3.4.4 Utilización de datos procedentes de las operaciones del contribuyente (“datos internos”).

2.141 Cuando no se disponga de operaciones no vinculadas comparables lo suficientemente fiables que sustenten la distribución efectuada de los resultados conjuntos, deberá recurrirse a los datos internos, que pueden constituir un medio fiable para determinar o comprobar la adecuación al principio de plena competencia de la distribución de los beneficios. El tipo de datos internos necesarios dependerá de cada caso, y deben satisfacer las condiciones enunciadas en esta sección y, en concreto, las contenidas en los párrafos 2.116, 2.117 y 2.132. Normalmente estos datos se extraerán de la contabilidad de costes o de la contabilidad financiera del contribuyente.

2.142 Por ejemplo, cuando se recurre a una clave de atribución basada en los activos, esta puede basarse en los datos extraídos del balance de las partes de la operación. Es frecuente que no todos los activos de los contribuyentes estén relacionados con la operación revisada y que, por tanto, sea necesario que el contribuyente lleve a cabo un cierto trabajo analítico que le permita redactar un balance “desagregado”, que será el que se utilice para la

aplicación del método de la distribución del resultado. Del mismo modo, cuando se utilizan claves de atribución basadas en los costes, fundamentadas en datos extraídos de las cuentas de resultados de los contribuyentes, será necesario generar una contabilidad por operaciones que identifique los gastos relacionados con la operación vinculada examinada y los que deben excluirse de la determinación de la clave de atribución. El tipo de gasto considerado (por ejemplo, retribuciones salariales, amortizaciones, etc.) así como el criterio utilizado para determinar si un gasto dado está relacionado con la operación analizada o con otra u otras operaciones del contribuyente (por ejemplo, otras líneas de productos que no participan de esta distribución de resultados) deberán mantenerse constantes en su aplicación por todas las partes que intervienen en la operación. Véanse también en el párrafo 2.98 los comentarios sobre la valoración de los activos en el contexto del método del margen neto operacional, donde el beneficio neto se calcula por referencia a los activos, que son igualmente pertinentes para la valoración de los activos en el contexto de un método de la distribución del resultado, en el que se recurre a una clave de atribución basada en los activos.

2.143 Los datos internos también pueden resultar útiles cuando la clave de atribución se basa en la contabilidad de costes, por ejemplo, las personas que participan en ciertos aspectos de la operación, el tiempo dedicado por ciertas categorías de personal a tareas concretas, el número de servidores, los datos almacenados, la superficie de los puntos de venta, etc.

2.144 Los datos internos son esenciales para calcular el valor de las aportaciones de cada una de las partes a la operación vinculada. La determinación de este valor se apoya en un análisis funcional que considere todas las funciones con trascendencia económica, los activos y los riesgos que aporten las partes a la operación vinculada. En los casos en los que el beneficio se atribuya en función del resultado del análisis de la importancia relativa de las funciones, activos y riesgos respecto del valor añadido a la operación vinculada, esta valoración deberá apoyarse en datos fiables objetivos que permitan limitar la arbitrariedad. Debe prestarse una atención especial a la identificación de las aportaciones de intangibles valiosos y a la asunción de riesgos significativos, así como a la importancia, la pertinencia y la medida de los factores que generan esos intangibles valiosos y riesgos significativos.

2.145 Una posibilidad no mencionada anteriormente consiste en la distribución de los resultados conjuntos de forma que cada empresa asociada que participe en la operación vinculada obtenga el mismo porcentaje de rendimiento por el capital invertido en la operación. Este método presupone que la inversión de capital de todos los partícipes soporta un nivel de riesgo similar, por lo que cabría esperar que cada uno de ellos obtuviera un

rendimiento similar si operara en el mercado libre. Sin embargo, esta suposición puede no ser realista. Por ejemplo, ignora las condiciones de los mercados de capital y puede obviar otros aspectos importantes que revelaría un análisis funcional y que deberían tenerse en cuenta en una distribución de resultados.

D. Conclusiones sobre los métodos basados en el resultado de las operaciones

2.146 Los párrafos 2.1 a 2.11 contienen las líneas rectoras para la selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado a las circunstancias del caso.

2.147 Como ya se ha indicado en estas Directrices, el método del margen neto operacional suscita alguna preocupación, y en especial el hecho de que en ocasiones se aplique sin tener debidamente en cuenta las diferencias sustanciales entre las operaciones vinculadas y no vinculadas objeto de comparación. A muchos países les preocupa el hecho de que al aplicar el método del margen neto operacional se ignoran las salvaguardias creadas para la aplicación de los métodos tradicionales basados en las operaciones. Por tanto, cuando las diferencias en las características de las operaciones que se comparan influyan en los indicadores de beneficio neto utilizados, no es apropiado aplicar el método del margen neto operacional sin proceder a ajustar las diferencias. Véanse los párrafos 2.68 a 2.75 que tratan sobre el criterio de comparabilidad que debe regir la aplicación del método del margen neto operacional.

2.148 La aceptación de la posible necesidad de la adopción de los métodos basados en el resultado de las operaciones no pretende sugerir que las empresas independientes deban recurrir a ellos para determinar sus precios. Como con cualquier otro método, al utilizar los métodos del resultado de la operación es importante que sea posible realizar los ajustes correlativos pertinentes, admitiendo que, en ciertos casos, los ajustes correlativos pueden determinarse sobre una base agregada, conforme a los principios de agregación recogidos en los párrafos 3.9 a 3.12.

2.149 En cualquier caso, la prudencia debe regir la determinación de si un método basado en el resultado de la operación, aplicado a un aspecto concreto de un caso, puede arrojar un resultado de plena competencia, bien por sí mismo o en conjunción con un método tradicional basado en las operaciones. Esta cuestión, en último término, sólo podrá resolverse caso por caso, sopesando las ventajas e inconvenientes señalados anteriormente

respecto del uso de un método basado en el resultado de la operación, teniendo en cuenta el análisis de comparabilidad (comprendido el análisis funcional) de las partes que intervienen en la operación, y la disponibilidad y fiabilidad de datos comparables. Además, al elaborar estas conclusiones se presupone que los sistemas fiscales de los países están lo suficientemente elaborados como para aplicar estos métodos.

Capítulo III

Análisis de comparabilidad

A. Desarrollo de un análisis de comparabilidad

3.1 La Sección D del Capítulo I contiene las indicaciones generales sobre la comparabilidad. Por definición, una comparación implica la consideración de dos elementos: la operación vinculada objeto de revisión y las operaciones no vinculadas que se consideran potencialmente comparables. La búsqueda de comparables constituye solamente una parte del análisis de comparabilidad que no debe confundirse con el análisis en sí, ni desvincularse de él. La búsqueda de información sobre operaciones no vinculadas potencialmente comparables y el proceso de identificación de comparables depende del análisis previo de las operaciones vinculadas que realiza el contribuyente y de los factores de comparabilidad pertinentes (véanse los párrafos 1.38 a 1.63). Un criterio metodológico coherente debe garantizar una cierta continuidad o establecer los vínculos dentro de todo un proceso analítico, permitiendo así mantener una relación constante entre las distintas etapas: desde el análisis preliminar de las condiciones de la operación vinculada, hasta la selección del método de determinación de los precios de transferencia, pasando por la identificación de comparables potenciales para llegar finalmente a una conclusión sobre si las operaciones vinculadas objeto de estudio son compatibles con el principio de plena competencia descrito en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE.

3.2 En el marco del proceso de selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado (véase el párrafo 2.2) y de su aplicación, el objeto del análisis de comparabilidad es siempre el de encontrar los comparables más fiables. En consecuencia, cuando es posible determinar que una operación no vinculada tiene un grado menor de comparabilidad que otras, esta debe eliminarse (véase también el párrafo 3.56). Esto no significa que sea preciso realizar una búsqueda exhaustiva en todas las fuentes posibles de comparables, ya que se admite que hay limitaciones en la disponibilidad de la información, y el hecho de que la búsqueda de datos comparables puede ser muy gravosa. Véanse también los

párrafos 3.80 a 3.83 en los que se trata el cumplimiento con las obligaciones tributarias.

3.3 Para que el proceso resulte transparente, se considera una buena práctica que el contribuyente que recurra a comparables para justificar sus precios de transferencia, o las administraciones tributarias que recurran a ellos para justificar un ajuste en los precios de transferencia, aporten a la otra parte interesada (a saber: inspección tributaria, contribuyente o autoridad competente extranjera) la información justificativa que permita valorar la fiabilidad de los comparables utilizados. Véase el párrafo 3.36 en lo que concierne a la información de la que disponen las administraciones tributarias que no se comunica a los contribuyentes. En el Capítulo V de estas Directrices se recogen las reglas generales sobre obligaciones de documentación. Véase también el anexo al Capítulo IV “Líneas rectoras de los acuerdos previos de valoración en el marco de los procedimientos amistosos” (APV PA). ”.

A.1 Proceso “tipo”

3.4 A continuación se describe el proceso “tipo” que puede seguirse al realizar un análisis de comparabilidad. Este proceso se considera como una buena práctica aceptada, sin embargo su aplicación no es obligatoria, por lo que cualquier otro proceso de búsqueda que conduzca a la identificación de comparables fiables será igualmente aceptable, ya que es la fiabilidad del resultado la que prima sobre el proceso (es decir, el seguimiento del proceso no garantiza la consecución de un resultado de plena competencia, y la divergencia tampoco implica que el resultado final no sea de plena competencia).

Paso 1: Determinación de los años incluidos en el análisis.

Paso 2: Análisis del conjunto de las circunstancias del contribuyente.

Paso 3: Comprensión de la operación u operaciones vinculadas objeto de comprobación, sobre la base, en particular, de un análisis funcional a fin de seleccionar la parte objeto de análisis (cuando sea necesario), el método de determinación de precios de transferencia más apropiado a las circunstancias del caso, el indicador financiero que será analizado (en el caso de un método basado en el resultado de la operación), e identificar factores de comparabilidad importantes que deban tenerse en cuenta.

Paso 4: Revisión de los comparables internos existentes, si los hubiera.

- Paso 5: Determinación de las fuentes de información disponibles sobre comparables externos cuando sean necesarios, teniendo en cuenta su fiabilidad relativa.
- Paso 6: Selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado y, dependiendo del método, determinación del indicador financiero pertinente (por ejemplo, determinación del indicador de beneficio neto pertinente en caso de que se trate del método del margen neto operacional).
- Paso 7: Identificación de comparables potenciales: determinación de las características clave que debe cumplir una operación no vinculada para poder considerarla potencialmente comparable, sobre la base de los factores pertinentes identificados en el Paso 3 y de acuerdo con los factores de comparabilidad determinados en los párrafos 1.38 a 1.63.
- Paso 8: Determinación y aplicación de los ajustes de comparabilidad que sean pertinentes.
- Paso 9: Interpretación y uso de los datos recabados y determinación de la remuneración de plena competencia.

3.5 En la práctica, este proceso no es lineal. En concreto, los pasos 5 a 7 pueden tener que repetirse hasta llegar a una solución satisfactoria, es decir, hasta la selección del método más apropiado, especialmente debido al hecho de que el examen de las fuentes de información disponibles puede influir en algunos casos sobre la selección del método de determinación de precios de transferencia. Por ejemplo, cuando no es posible encontrar información sobre operaciones comparables (paso 7) o realizar los ajustes necesarios (paso 8), los contribuyentes pueden tener que recurrir a otro método de determinación de precios de transferencia y repetir el proceso empezando por el paso 4.

3.6 Véase el párrafo 3.82 referido al análisis del proceso de determinación, control y revisión de los precios de transferencia.

A.2 *Análisis del conjunto de las circunstancias del contribuyente*

3.7 El “análisis del conjunto de las circunstancias” es un paso esencial del análisis de comparabilidad. Puede definirse como un análisis del sector y de los factores económicos y referidos a la competencia y la regulación, así como de otros elementos que afecten al contribuyente y su entorno, sin llegar a situarse en el contexto limitado de las operaciones concretas de las que se trata. Este paso ayuda a entender las condiciones de la operación vinculada del contribuyente, así como las de las operaciones no vinculadas con las que

se compara, en concreto, las circunstancias económicas de la operación (véanse los párrafos 1.55 a 1.58).

A.3 *Análisis de la operación vinculada y selección de la parte objeto de análisis*

3.8 Con la revisión de la operación u operaciones vinculadas examinadas se aspira a identificar los factores pertinentes que condicionan la selección de la parte estudiada (cuando sea necesario), la selección y aplicación del método de determinación de precios de transferencia más apropiado a las circunstancias del caso, el indicador financiero que será analizado (en el caso de un método basado en el resultado de la operación) la selección de comparables y, cuando corresponda, la determinación de los ajustes de comparabilidad.

A.3.1 *Evaluación de operaciones separadas y combinadas*

3.9 En teoría, para llegar a la aproximación más precisa posible a las condiciones de plena competencia, el principio de plena competencia debe aplicarse operación por operación. Ahora bien, a menudo se dan situaciones en las que operaciones separadas se encuentran tan estrechamente ligadas entre sí, o su continuidad está tan marcada, que no pueden valorarse adecuadamente por separado. Es el caso, por ejemplo de: 1. algunos contratos a largo plazo para el suministro de bienes o servicios; 2. derechos de uso de activos intangibles, y 3. la determinación del precio de un conjunto de productos muy similares (por ejemplo, una línea de productos) cuando es impracticable la determinación del precio de cada producto o de cada operación en particular. Otro ejemplo podría ser la cesión vía licencia de conocimientos prácticos -know-how- de fabricación y el suministro de componentes esenciales a un fabricante asociado, situaciones en las que sería más razonable determinar las condiciones de plena competencia de forma conjunta para las dos operaciones que aisladamente para cada una de ellas. Ambas operaciones deben valorarse conjuntamente utilizando el método o métodos de plena competencia más apropiados. Otro ejemplo más podría ser la canalización de una operación a través de otra empresa asociada. En este caso, puede ser más oportuno considerar la operación, en la que la canalización es sólo una parte de su totalidad, antes que considerar cada una de las operaciones de forma separada.

3.10 Hay otros ejemplos en los que las operaciones de un contribuyente pueden estar combinadas, son los relacionados con los criterios de cartera de productos. El criterio de cartera de productos es una estrategia empresarial

consistente en que un contribuyente reagrupa ciertas operaciones a fin de obtener un beneficio apropiado en el conjunto de ellas más que sobre un único producto de la cartera. Por ejemplo, algunos productos pueden comercializarse con beneficio bajo, o incluso con pérdida, dado que generan demanda de otros productos o de servicios con ellos relacionados, prestados por el mismo contribuyente, que procede entonces a su venta o prestación con un beneficio elevado (por ejemplo, equipos y consumibles post-venta, como las cafeteras y las cápsulas de café, o las impresoras y los cartuchos de tóner). Este mismo criterio puede observarse en diversos sectores. El criterio de cartera de productos es un ejemplo de una estrategia empresarial que puede ser necesario tener en cuenta en el análisis de comparabilidad y en el examen de la fiabilidad de los comparables. Véanse los párrafos 1.59 a 1.63 sobre estrategias empresariales. No obstante, como se analiza en los párrafos 1.70 a 1.72, estas consideraciones no pueden explicar pérdidas generales sostenidas o rendimientos bajos dilatados en el tiempo. Es más, para poder considerarlo aceptable, el criterio de cartera de productos debe estar razonablemente orientado, ya que no debe servir para aplicar un método de determinación de precios de transferencia a nivel del conjunto de la empresa de un contribuyente en los casos en los que las operaciones tengan una lógica comercial distinta y deban fragmentarse. Véanse los párrafos 2.78 y 2.79. Finalmente, los comentarios anteriores no deben malinterpretarse como legitimadores de una contraprestación inferior a la de plena competencia por una entidad integrada en un grupo a fin de generar beneficios a otra entidad del grupo multinacional (véase en particular el párrafo 1.71).

3.11 Si bien hay operaciones contratadas separadamente entre empresas asociadas que requieren evaluarse de forma conjunta para determinar si reúnen las condiciones propias de la plena competencia, existen otras operaciones contratadas globalmente entre esas mismas empresas que necesitan evaluarse separadamente. Un grupo multinacional puede reagrupar en una única operación y a un único precio un conjunto de beneficios tales como la cesión de patentes, de conocimientos prácticos *-know-how-*, de marcas, la prestación de servicios técnicos y administrativos y el arrendamiento de instalaciones de producción. Este tipo de acuerdos se suele conocer como acuerdos globales. Estas fórmulas de conjunto difícilmente incluyen la venta de bienes, aunque el precio exigido por la venta de bienes puede cubrir la prestación de algunos servicios auxiliares. En algunos casos, puede que no sea posible valorar el acuerdo en su conjunto, de forma que resulte necesario segregar algunos de sus elementos. En estos casos, una vez que se determine el precio de transferencia separado que corresponda a los elementos separados, la administración tributaria deberá considerar no obstante si el precio de transferencia para los diferentes elementos responde en su totalidad al principio de plena competencia.

3.12 Incluso en una operación no vinculada, los acuerdos globales pueden combinar elementos sujetos a regímenes fiscales distintos de acuerdo con las leyes internas o con algún convenio para evitar la doble imposición. Por ejemplo, puede ocurrir que pagos en concepto de cánones estén sujetos a una retención mientras que los pagos de arrendamiento tributen por su valor neto. En estas circunstancias, puede ser apropiado determinar el precio de transferencia respecto del acuerdo considerado en su conjunto; la administración tributaria determinará entonces si, por otras razones fiscales, es necesario distribuir el precio entre los elementos del conjunto. Para llegar a esta conclusión, las administraciones tributarias deberían examinar el acuerdo global entre las empresas asociadas de la misma forma que analizarían acuerdos similares celebrados entre empresas independientes. Los contribuyentes deben poder demostrar que el acuerdo global contempla un precio de transferencia correcto.

A.3.2 Compensaciones intencionadas

3.13 Existe una compensación intencionada cuando una empresa asociada incluye una cláusula ex profeso en las condiciones de las operaciones vinculadas. Se da cuando una empresa asociada genera un beneficio para otra empresa asociada dentro del grupo que de alguna forma se compensa con la percepción de diferentes beneficios a cambio. Estas empresas pueden indicar que los beneficios que cada una ha recibido deben compensarse con los que cada una ha aportado como pago total o parcial por los mismos, de tal forma que en la liquidación de la deuda tributaria únicamente debe considerarse la ganancia o la pérdida neta (si la hubiera) derivada de la operación. Por ejemplo, una empresa puede autorizar el uso de una patente a otra empresa en contraprestación por la provisión de conocimientos prácticos *-know-how-* en otra actividad y afirmar que la operación no produce ganancias ni pérdidas a ninguna de las partes. En ocasiones se puede encontrar este tipo de acuerdos entre empresas independientes, que deben valorarse de acuerdo con el principio de plena competencia con el objeto de cuantificar el valor de los respectivos beneficios presentados como compensación.

3.14 Las compensaciones intencionadas pueden variar en importancia y complejidad. Pueden oscilar desde la simple compensación de dos operaciones (por ejemplo, fijar un precio de venta favorable para bienes manufacturados a cambio de un precio de compra favorable para las materias primas utilizadas en la producción del bien) hasta un acuerdo general para equilibrar todos los beneficios obtenidos por ambas partes durante un período. Difícilmente las empresas independientes considerarían este último

tipo de acuerdo, a menos que los beneficios se puedan cuantificar con precisión y el contrato se concluya previamente. Normalmente, las empresas independientes preferirán que sus ingresos y sus gastos fluyan independientemente unos de otros, asumiendo cualquier pérdida o beneficio derivados de su actividad normal.

3.15 La existencia de compensaciones intencionadas no altera la condición esencial que es la conformidad con el principio de plena competencia, a efectos fiscales, de los precios de transferencia de las operaciones vinculadas. Sería conveniente que los contribuyentes pusieran de manifiesto la existencia de compensaciones intencionadas en dos o más operaciones entre empresas asociadas y probaran (o reconocieran que tienen la documentación necesaria y que han efectuado análisis suficientes como para demostrarlo) que, después de tener en cuenta las compensaciones, las condiciones que rigen las operaciones son compatibles con el principio de plena competencia.

3.16 Puede ser necesario evaluar las operaciones separadamente para determinar si satisfacen o no el principio de plena competencia. En el caso de que se vayan a analizar de forma conjunta, la selección de las operaciones comparables debe ser muy cuidadosa, además de observar las consideraciones realizadas en los párrafos 3.9 a 3.12. Las disposiciones relativas a la compensación de operaciones internacionales vinculadas pueden no ser totalmente compatibles con las relativas a las operaciones nacionales no vinculadas, debido a las diferencias en los distintos regímenes fiscales nacionales aplicables a las compensaciones o a las diferencias en el régimen fiscal de los pagos previsto en los distintos convenios para evitar la doble imposición. Por ejemplo, una retención en la fuente complicaría la compensación de los cánones con ingresos por ventas.

3.17 Durante la comprobación tributaria, un contribuyente puede intentar obtener una reducción en un ajuste por precios de transferencia basándose en una sobrevaloración no intencionada de la renta imponible. Dependerá de la discrecionalidad de las administraciones tributarias concederla o no. Las administraciones tributarias también pueden considerar esta solicitud en el contexto de los procedimientos amistosos y los ajustes correlativos (véase el Capítulo IV).

A.3.3 Selección de la parte objeto de análisis

3.18 Al aplicar los métodos del coste incrementado, del precio de reventa o del margen neto operacional descritos en el Capítulo II, es necesario elegir la parte de la transacción respecto de la que se analiza un

indicador financiero (margen sobre costes, margen bruto o indicador de beneficio neto). La selección de la parte objeto de análisis debe ser coherente con el análisis funcional de la operación. Como norma general, la parte objeto de análisis es aquella a la que puede aplicarse el método de determinación de precios de transferencia con más fiabilidad, y para la que existen comparables más sólidos, es decir, normalmente será aquella cuyo análisis funcional resulte menos complejo.

3.19 Veamos un ejemplo. Supongamos que una sociedad A fabrique dos productos, P1 y P2, que vende a la sociedad B, que es una empresa asociada en otro país. Supongamos que A fabrica el producto P1 utilizando activos intangibles únicos que pertenecen a B y siguiendo las especificaciones técnicas de B. Supongamos que, en las operaciones relacionadas con el P1, A únicamente desarrolla funciones simples y no hace ninguna aportación valiosa y única. Lo habitual es que la parte objeto de análisis respecto de las operaciones con el P1 sea A. Supongamos ahora que A fabrica también el producto P2 para lo que posee y utiliza intangibles valiosos únicos tales como patentes y marcas comerciales, y respecto del que B interviene como distribuidor. Supongamos que en esta operación con el P2, B únicamente desarrolla funciones simples y no hace ninguna aportación valiosa y única a la operación. Lo habitual será que la parte objeto de análisis respecto de las operaciones con el P2 sea B.

A.3.4 Información sobre la operación vinculada

3.20 Para poder seleccionar y aplicar el método de determinación de precios de transferencia más apropiado a las circunstancias del caso, es necesario contar con información sobre los factores de comparabilidad en relación con la operación vinculada revisada, y en concreto sobre las funciones, activos y riesgos de todas las partes que intervienen en la operación, incluidas la empresas asociadas localizadas en el extranjero. Si bien los métodos unilaterales (por ejemplo, el del coste incrementado, el precio de reventa o el del margen neto operacional que se analizan con detalle en el Capítulo II) sólo requieren del examen de un indicador financiero o de un indicador del nivel de beneficios de una de las partes intervinientes en la operación (la “parte objeto de análisis” como se expuso en los párrafos 3.18 y 3.19), también es preciso contar con cierta información sobre los factores de comparabilidad de la operación vinculada y, en concreto, sobre el análisis funcional de la parte que no constituye objeto de análisis, a fin de calificar adecuadamente la operación vinculada y de elegir el método de determinación de precios de transferencia más apropiado.

3.21 Cuando el método de determinación de precios de transferencia más apropiado atendiendo a las circunstancias del caso, elegido siguiendo las pautas contenidas en los párrafos 2.1 a 2.11, sea el método de la distribución del resultado, es necesario contar con información financiera referida a todas las partes de la operación, nacionales o extranjeras. Debido a la naturaleza bilateral de este método, la distribución del resultado de la operación precisa de información particularmente detallada sobre la parte asociada extranjera que interviene en la operación. Esta información incluiría la relativa a los cinco factores de comparabilidad conducentes a la correcta calificación de la relación existente entre las partes, la información que permitiera demostrar la idoneidad del método de la distribución del resultado, así como información financiera (la determinación de los resultados conjuntos objeto de la distribución y el propio reparto de estos resultados se apoyan en información financiera relativa a todas las partes intervinientes en la operación, incluida la empresa asociada extranjera). Por consiguiente, cuando el método más apropiado a las circunstancias del caso sea el de la distribución del resultado, sería razonable esperar que los contribuyentes estén dispuestos a facilitar a las administraciones tributarias la información necesaria sobre la empresa asociada extranjera que es parte en la operación, incluyendo los datos financieros necesarios para calcular la distribución del resultado.

3.22 Cuando el método de determinación de precios de transferencia más apropiado atendiendo a las circunstancias del caso, elegido siguiendo las pautas contenidas en los párrafos 2.1 a 2.11, sea un método unilateral, es necesario contar con la información financiera relativa a la parte objeto de análisis, además de la mencionada en el párrafo 3.20, con independencia de si la parte objeto de análisis es nacional o extranjera. Por tanto, si el método más apropiado es el del coste incrementado, el del precio de reventa o el del margen neto operacional, y la parte objeto de análisis es la entidad extranjera, es necesario contar con información suficiente para aplicar con fiabilidad el método elegido a la parte objeto de análisis extranjera, y para que el país de la parte que no constituye objeto de análisis pueda examinar la aplicación del método a la parte objeto de análisis extranjera. Por otro lado, una vez que se elige un método unilateral como método más apropiado y que la parte objeto de análisis es el contribuyente nacional, la administración tributaria no tendrá, en general, razones para seguir solicitando datos financieros a la entidad asociada extranjera.

3.23 Como se explicó anteriormente, el análisis de los precios de transferencia precisa de cierta información sobre las empresas asociadas extranjeras, cuyo alcance y naturaleza depende, particularmente, del método de precios de transferencia que se utilice. Sin embargo, como se señala en el párrafo 5.11, recabar esa información puede entrañar dificultades para el

contribuyente a las que no se enfrenta cuando elabora su propia documentación. Estas dificultades deben tenerse en cuenta al definir las normas o los procedimientos de documentación.

A.4 Operaciones no vinculadas comparables

A.4.1 Términos generales

3.24 Una operación no vinculada comparable es aquella que ocurre entre dos partes independientes y que es comparable a la operación vinculada objeto de examen. Puede tratarse bien de una operación comparable entre una parte de la operación vinculada y una parte independiente (“comparable interno”) o entre dos empresas independientes, ninguna de las cuales es parte de la operación vinculada (“comparable externo”).

3.25 Las comparaciones entre una operación vinculada del contribuyente con otra operación vinculada llevada a cabo por el mismo grupo multinacional u otro son irrelevantes para la aplicación del principio de plena competencia, por lo que las administraciones tributarias no deben recurrir a ellas como base para el ajuste de los precios de transferencia, ni el contribuyente para fundamentar su política de determinación de precios de transferencia.

3.26 La presencia de accionistas minoritarios puede provocar que las operaciones vinculadas de un contribuyente se aproximen a las condiciones de plena competencia, pero esta circunstancia no es determinante en sí misma. La influencia de los accionistas minoritarios depende de una serie de factores, incluido el hecho de si estos tienen participación en el capital de la matriz o en el de una filial, y de si realmente influyen en la determinación de los precios de transferencia de las operaciones intragrupo.

A.4.2 Comparables internos

3.27 El paso 4 del proceso “tipo” descrito en el párrafo 3.4 es la revisión de los comparables internos que pudieran existir. Los comparables internos pueden estar más directa y estrechamente relacionados con la operación vinculada revisada que los comparables externos. El análisis financiero se simplifica y resulta más fiable al apoyarse en prácticas y criterios contables supuestamente idénticos para los comparables internos y la operación vinculada. Asimismo, la información sobre los comparables internos puede resultar más completa y menos onerosa.

3.28 Por otro lado, los comparables internos no siempre son más fiables, por lo que tampoco puede considerarse que cualquier operación entre un contribuyente y una parte independiente sea un comparable fiable para las operaciones vinculadas realizadas por ese mismo contribuyente. Los comparables internos, cuando existen, deben satisfacer los cinco factores de comparabilidad del mismo modo que los comparables externos; véanse los párrafos 1.38 a 1.63. Las pautas sobre los ajustes en la comparabilidad también son aplicables a los comparables internos; véanse los párrafos 3.47 a 3.54. Supongamos, por ejemplo, que un contribuyente fabrica un producto concreto, del que vende un volumen importante a su distribuidor minorista asociado, que radica en el extranjero, y una parte marginal de ese mismo producto a una parte independiente. En tal caso, la diferencia en el volumen de producto vendido afectará sustancialmente y con toda probabilidad a la comparabilidad de ambas operaciones. Si no es posible realizar un ajuste preciso que elimine los efectos de tal diferencia, la operación entre el contribuyente y su cliente independiente difícilmente constituirá un comparable fiable.

A.4.3 Comparables externos y fuentes de información

3.29 Existen diversas fuentes de información a las que puede recurrirse para identificar posibles comparables externos. Bajo este epígrafe se estudian algunas cuestiones concretas que pueden plantearse respecto de las bases de datos comerciales, los comparables extranjeros y la información no comunicada a los contribuyentes. Asimismo, siempre que existan comparables internos fiables, la búsqueda de comparables externos puede ser innecesaria; véanse los párrafos 3.27 y 3.28.

A.4.3.1 Bases de datos

3.30 Las bases de datos comerciales son una fuente de información habitual. Estas bases han sido creadas por editores que recopilan la contabilidad presentada por las sociedades ante los órganos administrativos competentes y las presentan en formato electrónico, lo que permite realizar búsquedas y análisis estadísticos. Estas bases de datos pueden resultar un método práctico y rentable para identificar comparables externos, pudiendo constituir la fuente de información más fiable, dependiendo de las circunstancias del caso.

3.31 Es frecuente identificar una serie de limitaciones en las bases de datos. Dado que se basan en la información disponible al público en general, no existen en todos los países, puesto que no todos ellos publican la misma

información sobre sus empresas. Asimismo, cuando puede accederse a ellas, no siempre contienen la misma información para todas las sociedades que operan en un determinado país, dado que las obligaciones en materia de comunicación y depósito de información pueden variar dependiendo de la forma jurídica que adopte la sociedad y de si cotiza o no en bolsa. La decisión sobre si utilizar las bases de datos, y cómo, debe ir precedida de la debida cautela, puesto que estas se elaboran y presentan con fines distintos a los de precios de transferencia. No siempre las bases de datos comerciales contienen información lo suficientemente detallada para justificar el método elegido. No todas ellas comprenden el mismo nivel de detalle, ni pueden usarse con el mismo grado de fiabilidad. Es relevante señalar que se ha constatado que en muchos países las bases de datos se utilizan para comparar los resultados de las sociedades, más que de las operaciones, porque la información sobre operaciones con terceros está raramente disponible. Véase el párrafo 3.37 sobre la utilización de los datos agregados sobre terceros.

3.32 La utilización de una base de datos comercial puede no ser necesaria cuando existan otras fuentes fiables de información, por ejemplo comparables internos. Cuando se recurre a ellas, estas bases deben utilizarse de forma objetiva, que se traduzca en la voluntad real de identificar información comparable que resulte fiable.

3.33 En la utilización de bases de datos comerciales no debe primar la cantidad sobre la calidad. En la práctica, basar el análisis de comparabilidad únicamente en una base de datos comercial puede generar dudas sobre la fiabilidad del análisis, debido a la calidad de la información precisa para evaluar la comparabilidad que puede obtenerse, en términos generales, de una base de datos. Para paliar este déficit es posible que sea necesario afinar las búsquedas en las bases de datos acudiendo a otra información disponible públicamente, dependiendo de los hechos y circunstancias. Este perfeccionamiento en la búsqueda de información en las bases de datos con otras fuentes de información pretende primar la calidad sobre los criterios estandarizados y es válida tanto para las búsquedas en bases de datos realizadas por los contribuyentes o profesionales de la fiscalidad como para las efectuadas por las administraciones tributarias. Su aplicación debe entenderse en el marco del análisis realizado en los párrafos 3.80 a 3.83 sobre costes y cargas de cumplimiento que deben soportar los contribuyentes.

3.34 Existen igualmente bases de datos privadas desarrolladas y gestionadas por ciertos despachos de asesoría. Además de los problemas que plantean las bases de datos comerciales antes mencionados, las bases de datos privadas plantean además el interrogante de la cobertura de sus datos, dado que pueden basarse en una parte más limitada del mercado que una base de datos comercial. Cuando un contribuyente ha recurrido a una base de

datos privada para justificar la determinación de sus precios de transferencia, la administración tributaria, por razones obvias de transparencia, puede requerir el acceso a dicha base de datos a fin de revisar los resultados obtenidos por el contribuyente.

A.4.3.2 Comparables de fuente extranjera o no nacionales

3.35 Los contribuyentes no siempre buscan comparables en cada país, por ejemplo cuando los comparables a escala nacional sean insuficientes, o con la intención de reducir la carga de cumplimiento cuando distintas entidades de un grupo multinacional tengan análisis funcionales comparables. Los comparables extranjeros no deben rechazarse automáticamente sólo por su condición de tales. Para determinar la fiabilidad de los comparables extranjeros debe procederse caso por caso y examinando la medida en que satisfacen los cinco factores de comparabilidad. El hecho de que una búsqueda regional de comparables pueda utilizarse de forma fiable o no para distintas filiales de un grupo multinacional que desarrolla su actividad en un área concreta del mundo depende de las circunstancias en las que opera cada una de estas filiales. Véanse los párrafos 1.57 y 1.58 sobre las diferencias entre mercados y análisis que abarcan varios países. La diversidad de criterios contables puede ser origen también de dificultades.

A.4.3.3 Información no comunicada a los contribuyentes

3.36 La administración tributaria puede disponer de información obtenida en actuaciones con otros contribuyentes o de otras fuentes de información que no se comuniquen al contribuyente. Sin embargo, sería injusto aplicar un método de determinación de precios de transferencia sobre la base de esos datos, a menos que la administración tributaria pueda revelárselos al contribuyente (respetando los límites exigidos por las normas fiscales sobre confidencialidad), de forma que permitan al contribuyente defender su posición, y garantizar un efectivo control judicial por parte de los tribunales.

A.4.4 Utilización de datos agregados de terceros

3.37 En los párrafos 3.9 a 3.12 se estudia cómo los métodos de determinación de precios de transferencia se centran en las operaciones, así como la cuestión de la posible agregación de las operaciones vinculadas. Puede plantearse una cuestión diferente, a saber, si los datos agregados de terceros pueden constituir comparables fiables para las operaciones vinculadas de un contribuyente (o un conjunto de operaciones agregadas

coherentemente conforme a los párrafos 3.9 a 3.12). En la práctica, los datos de terceros de los que suele disponerse son datos agregados, referidos a la empresa o a un segmento, en función de los criterios contables aplicables. Si tales datos agregados de terceros pueden constituir o no comparables fiables para las operaciones vinculadas de un contribuyente o respecto de una serie de operaciones agregadas coherentemente siguiendo las pautas de los párrafos 3.9 a 3.12 depende, en concreto, de si esa tercera parte efectúa una gama de operaciones sensiblemente diferentes. Cuando se dispone de ellos, los datos segmentados suelen constituir unos mejores comparables que los referidos al conjunto de la sociedad, porque están más centrados en las operaciones, aunque no deja de ser cierto que los datos segmentados pueden plantear problemas en cuanto a la atribución de gastos a los distintos segmentos. Del mismo modo, en ciertas ocasiones, los datos de terceros referidos al conjunto de la sociedad pueden ofrecer mejores comparables que los datos segmentados de terceros, por ejemplo, cuando las actividades que recogen los comparables corresponden a la gama de operaciones vinculadas del contribuyente.

A.4.5 Limitaciones en la disponibilidad de los comparables

3.38 La identificación de comparables potenciales debe tener como objetivo la consecución de los datos más fiables, sin dejar de admitir que no siempre serán perfectos. Por ejemplo, en ciertos sectores y mercados, las operaciones independientes pueden ser muy poco frecuentes. Habrá que buscar entonces una solución pragmática, procediendo caso por caso, por ejemplo, ampliando la búsqueda y utilizando información sobre operaciones no vinculadas que se den en el mismo sector y en un mercado geográfico comparable, pero que efectúen terceras partes con estrategias o modelos empresariales distintos u otras circunstancias económicas ligeramente distintas; o información sobre operaciones no vinculadas que se efectúen dentro del mismo sector pero en otras áreas geográficas; o información sobre operaciones no vinculadas que se lleven a cabo en el mismo mercado geográfico, pero en sectores distintos. La elección entre estas posibles opciones dependerá de los hechos y circunstancias del caso y, en concreto, de la importancia de los efectos que puedan provocar los defectos de comparabilidad en la fiabilidad del análisis.

3.39 Sin datos comparables cabría la posibilidad de elegir, en las circunstancias apropiadas, el método de la distribución del resultado, por ejemplo, cuando la ausencia de datos comparables se deba a la presencia de intangibles de valor, únicos, aportados por cada parte de la operación (véase el párrafo 2.109). Sin embargo, incluso en los casos en los que los datos

comparables son pocos e imperfectos, la selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado debe ser coherente con el análisis funcional de las partes. Véase el párrafo 2.2.

A.5 Selección o rechazo de comparables potenciales

3.40 Básicamente, existen dos enfoques para identificar operaciones efectuadas por terceros que resulten potencialmente comparables.

3.41 El primero, que puede calificarse como “aditivo”, consiste en que la persona que realice la búsqueda elabore una lista de terceras partes respecto de las que se crea que realizan operaciones potencialmente comparables. Después se procede a recopilar información sobre las operaciones que llevan a cabo dichas terceras partes a fin de confirmar que se trata, efectivamente, de comparables aceptables, basándose en los criterios de comparabilidad predeterminados. Se podría sostener que este enfoque arroja resultados bien estructurados: todas las operaciones consideradas en el análisis las han llevado a cabo entidades bien conocidas en el mercado del contribuyente. Como se señaló anteriormente, a fin de garantizar un grado de objetividad suficiente, es importante que el proceso seguido sea transparente, sistemático y verificable. El enfoque “aditivo” puede utilizarse como enfoque único cuando la persona que realiza la búsqueda tenga conocimiento de algunas terceras partes que lleven a cabo operaciones comparables a la operación vinculada examinada. Merece la pena reseñar que el enfoque “aditivo” muestra similitudes con el criterio seguido al identificar comparables internos. En la práctica, un enfoque “aditivo” puede abarcar comparables tanto internos como externos.

3.42 La segunda posibilidad, el enfoque “deductivo” se inicia con una amplia serie de sociedades que operan en el mismo sector de actividad, llevan a cabo funciones generales similares y no presentan características económicas que resulten sensiblemente diferentes. El listado se depura a continuación aplicando unos criterios de selección y la información a disposición pública (por ejemplo, bases de datos, cibernets, información sobre los competidores del contribuyente que se conozcan). En la práctica, el enfoque “deductivo” se inicia normalmente con una búsqueda efectuada en una base de datos. Por consiguiente, es importante seguir las pautas sobre comparables internos y sobre fuentes de información de comparables externos; véanse los párrafos 3.24 a 3.39. Asimismo, el enfoque “deductivo” no es apropiado para todos los casos y métodos, por lo que no debe interpretarse que el análisis que aquí se realiza afecta a la selección del método de determinación de precios de transferencia que se expone en los párrafos 2.1 a 2.11.

3.43 En la práctica se utilizan tanto criterios cuantitativos como cualitativos para aceptar o rechazar comparables potenciales. Pueden encontrarse ejemplos de criterios cualitativos en las carteras de productos y en las estrategias de las empresas. Los criterios cuantitativos más comúnmente observados son:

- Criterios referidos al tamaño de la empresa atendiendo a ventas, activos o número de empleados. El volumen de la operación como valor absoluto o en proporción a las actividades de las partes puede afectar a las posiciones competitivas relativas del comprador y el vendedor y, por tanto, a la comparabilidad.
- Criterios vinculados a los intangibles, tales como la ratio “valor neto de los intangibles/valor neto total de los activos” o la ratio de “investigación y desarrollo (I+D)/ventas”. Cuando se disponga de ellos, estos datos pueden utilizarse, por ejemplo, para excluir a las sociedades con activos intangibles o actividades de I+D en aquellos casos en los que la parte objeto de análisis no utilice activos intangibles valiosos ni participe en actividades significativas de I+D.
- Criterios relacionados con la importancia de las exportaciones (volumen de exportación a venta total), cuando corresponda.
- Criterios relacionados con las existencias, en su valor absoluto o relativo, cuando corresponda.
- Otros criterios que permitan excluir a terceras partes que se encuentren en situaciones especiales, tales como sociedades que estén iniciando su actividad, siguiendo un proceso concursal, etc., cuando dichas situaciones especiales obviamente no constituyan una comparación adecuada.

La selección y aplicación de un criterio depende de los hechos y circunstancias de cada caso concreto, y la lista expuesta anteriormente no es limitativa ni prescriptiva.

3.44 Una ventaja del enfoque “deductivo” es que es más transparente y reproducible que el “aditivo”. También es más fácil de verificar, puesto que el examen se concentra en el proceso y en la pertinencia de los criterios de selección por los que se opta. Por otro lado, es evidente que la calidad de los resultados derivados del enfoque “deductivo” depende de la calidad de las herramientas de búsqueda en las que se confíe (por ejemplo, la calidad de la base de datos, cuando se utilice, y la posibilidad de obtener información detallada en la cuantía suficiente). Esto puede constituir una limitación práctica en algunos países en los que la fiabilidad y utilidad de las bases de datos es cuestionable en lo que se refiere a su uso para análisis de comparabilidad.

3.45 No resulta apropiado conceder una preferencia sistemática a uno de los enfoques respecto del otro, debido a que, en función de las circunstancias del caso, pueden encontrarse aspectos positivos tanto en el “aditivo” como en el “deductivo”, o en una combinación de ambos. La utilización de estos enfoques “aditivo” y “deductivo” no suele ser exclusiva. En un enfoque “deductivo” típico, además de recurrir a bases de datos públicas, es común incluir a terceras partes, por ejemplo competidores de los que se tenga conocimiento (o terceras partes de las que se sepa que llevan a cabo operaciones potencialmente comparables a las del contribuyente), a las que no podría llegarse siguiendo un enfoque puramente deductivo, por ejemplo, porque estén clasificadas bajo códigos de sector distintos. En tal caso, el enfoque “aditivo” constituye una herramienta de perfeccionamiento de una búsqueda basada en un enfoque “deductivo”.

3.46 El proceso seguido para identificar comparables potenciales es uno de los aspectos más críticos del análisis de comparabilidad y debe ser transparente, sistemático y verificable. En concreto, la elección de los criterios de selección influye notablemente en el resultado del análisis, por lo que debe reflejar las características económicas más significativas de las operaciones que se comparan. Quizá no es posible eliminar totalmente los juicios subjetivos en la selección de comparables, pero es mucho lo que puede hacerse para incrementar la objetividad y garantizar la transparencia en la aplicación de esos juicios subjetivos. El grado óptimo de transparencia del proceso dependerá de la medida en que pueda revelarse el criterio utilizado para seleccionar comparables potenciales, así como de la posibilidad de explicar las razones para eliminar ciertos comparables potenciales. El aumento de la objetividad y la garantía de transparencia del proceso pueden depender igualmente de la medida en que la persona que revisa el proceso (el contribuyente o la administración tributaria) tenga acceso a información sobre el proceso seguido y a las mismas fuentes de datos. En el Capítulo V se tratan las cuestiones relativas a la documentación del proceso de identificación de comparables.

A.6 *Ajustes de comparabilidad*

3.47 La necesidad de ajustar los comparables y la exigencia de precisión y fiabilidad se subrayan en estas Directrices en distintas ocasiones, tanto en la aplicación general del principio de plena competencia como, más específicamente, en el contexto de cada método. Como se señaló en el párrafo 1.33, ser comparable significa que ninguna de las posibles diferencias existentes entre las situaciones objeto de comparación puede influir significativamente en la condición examinada metodológicamente, o que

pueden realizarse ajustes lo suficientemente precisos para eliminar el efecto de tales diferencias. La cuestión de si deben realizarse ajustes de comparabilidad (y en tal caso, cuáles) en un caso concreto, es materia de opinión que debe valorarse a la luz de los comentarios sobre los costes y la carga administrativa recogidos en la Sección C.

A.6.1 Distintos tipos de ajustes de comparabilidad

3.48 Entre los ejemplos de ajustes de comparabilidad se incluyen aquellos tendentes a la búsqueda de consistencia contable, destinados a eliminar las diferencias provocadas por la diversidad de criterios contables entre las operaciones vinculadas y las efectuadas en condiciones de plena competencia; la segmentación de los datos financieros que permiten eliminar las operaciones no comparables y los ajustes efectuados por razón de diferencias en el capital, funciones, activos y riesgos.

3.49 En el Anexo al Capítulo III se recoge un ejemplo de ajuste del capital circulante diseñado para reflejar distintos niveles de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. El hecho de que estos ajustes se encuentren en la práctica no significa que deban realizarse obligatoria o rutinariamente. Por el contrario, conviene probar que el ajuste propuesto mejora la comparabilidad (como cualquier ajuste). Asimismo, un nivel de capital circulante relativo marcadamente distinto entre partes vinculadas y no vinculadas puede llevar a un examen más detenido de las características de comparabilidad del comparable potencial.

A.6.2 Objeto de los ajustes de comparabilidad

3.50 Los ajustes de comparabilidad deben considerarse si (y solo si) se espera que mejoren la fiabilidad de los resultados. Las consideraciones que hay que plantearse a este respecto abarcan la importancia de la diferencia por la que se considera el ajuste, la calidad de los datos sometidos al ajuste, el objeto de este y la fiabilidad del criterio utilizado para practicarlo.

3.51 Es preciso subrayar que los ajustes de comparabilidad únicamente son apropiados en el caso de que las diferencias afecten realmente a la comparación. Es inevitable la existencia de diferencias entre las operaciones vinculadas del contribuyente y las de terceros comparables. La comparación puede ser correcta incluso a pesar de la existencia de una diferencia no ajustada, siempre que esta no afecte a la fiabilidad de la comparación. Por el contrario, la necesidad de realizar numerosos ajustes o ajustes muy importantes en los factores clave de comparabilidad puede indicar que las operaciones efectuadas por el tercero no son lo suficientemente comparables.

3.52 No siempre están justificados los ajustes. Por ejemplo, un ajuste practicado en las cuentas pendientes de cobro no resultará especialmente útil cuando existan diferencias sustanciales en los criterios contables que no puedan solventarse. Del mismo modo, en ocasiones se realizan ajustes sofisticados para generar la falsa impresión de que el resultado de la búsqueda de comparables es “científico”, fiable y preciso.

A.6.3 Fiabilidad del ajuste realizado

3.53 No es apropiado considerar “rutinarios” e indiscutibles ciertos ajustes de comparabilidad, por ejemplo los referidos a las diferencias en el nivel del capital circulante, y considerar otros, como los relativos al riesgo-país, como más subjetivos y, por tanto, condicionados a requisitos de prueba y fiabilidad adicionales. Los únicos ajustes que deben realizarse son aquellos de los que se espera que mejoren la comparabilidad.

A.6.4 Documentación y prueba de los ajustes de comparabilidad

3.54 Asegurar el nivel de transparencia preciso en los ajustes de comparabilidad puede depender de la posibilidad de ofrecer una explicación para cada uno de los ajustes efectuados, las razones que han llevado a considerarlos apropiados, el procedimiento de cálculo seguido, la forma en la que el ajuste modifica los resultados para cada comparable y mejora la comparabilidad. En el Capítulo V se analizan las cuestiones relativas a la documentación de los ajustes de comparabilidad.

A.7 El rango de plena competencia

A.7.1 Aspectos generales

3.55 En algunos casos es posible aplicar el principio de plena competencia hasta determinar una cifra única (por ejemplo, un precio o un margen) que constituirá la referencia más fiable para establecer si una operación responde a las condiciones de plena competencia. Sin embargo, en la medida en que la determinación de precios de transferencia no constituye una ciencia exacta, habrá muchas ocasiones donde la aplicación del método o métodos más apropiados conduzcan a un rango de cifras en el que todas ellas sean relativamente igual de fiables. En estos casos, las diferencias entre las cifras incluidas en el rango pueden deberse a que, en general, la aplicación del principio de plena competencia permite sólo una aproximación a las condiciones en las que hubieran operado empresas independientes. Es

posible también que los diferentes puntos del rango reflejen el hecho de que empresas independientes que realicen operaciones comparables en circunstancias igualmente comparables pueden no establecer exactamente el mismo precio para la operación.

3.56 Habrá casos en los que no todas las operaciones comparables examinadas tengan un grado de comparabilidad relativamente igual. Cuando es posible determinar que una operación no vinculada tiene un menor grado de comparabilidad que otras, esta debe eliminarse.

3.57 Puede ocurrir también que, a pesar de haber hecho todo lo posible para excluir los puntos con menor grado de comparabilidad, se llegue a un rango de cifras respecto de las que se considere que, teniendo en cuenta el proceso utilizado para seleccionar los comparables y las limitaciones de la información que se tiene sobre ellos, siguen conteniendo algunos defectos en la comparabilidad que no puede identificarse o cuantificarse, y que por tanto, no son susceptibles de ajuste. En estos casos, si en el rango se ha obtenido a través de un número importante de observaciones, las herramientas estadísticas que permiten estrecharlo tomando como referencia la tendencia central (por ejemplo, el rango intercuartil u otros percentiles) pueden ayudar a mejorar la fiabilidad del análisis.

3.58 El rango de cifras también puede producirse cuando se aplica más de un método para evaluar una operación vinculada. Por ejemplo, dos métodos que muestran grados similares de comparabilidad pueden utilizarse para valorar la conformidad de una operación con las condiciones de plena competencia. Cada método puede determinar un resultado o un rango de resultados que difiera de los obtenidos con el otro método como consecuencia de las diferencias en su propia naturaleza y en la de los datos utilizados necesarios para la aplicación de cada método. Sin embargo, cada uno de los rangos puede utilizarse para determinar un rango aceptable de precios de plena competencia. Los datos resultantes de estos rangos podrían permitir una determinación más precisa del rango de plena competencia, por ejemplo, cuando los rangos se superponen, o pueden llevar a reconsiderar la precisión de los métodos usados, cuando no lo hacen. No es posible establecer una regla general en lo concerniente a la utilización de los rangos obtenidos de la aplicación de métodos diversos, ya que las conclusiones que se extraigan de su uso dependerán de la fiabilidad relativa de los métodos empleados para determinar los rangos y de la calidad de la información utilizada para aplicar los diferentes métodos.

3.59 Cuando la aplicación del método más apropiado (o, en las circunstancias precisas, la aplicación de más de un método, véase el párrafo 2.11) determina un rango de cifras, una desviación importante entre puntos

del mismo puede indicar que los datos utilizados para concretar algunos puntos tal vez no sean tan fiables como los utilizados para determinar los restantes puntos en el rango, o que dicha desviación resulte de características de los datos comparables que requieran ajustes. En tales casos, puede ser necesario un análisis más detenido de esos puntos con el objeto de evaluar la idoneidad de su inclusión en un rango de plena competencia.

A.7.2 Selección del punto más apropiado del rango

3.60 Si las condiciones relevantes de la operación vinculada (por ejemplo, el precio o el margen) se encuentran dentro del rango de plena competencia, no será necesario realizar ajustes.

3.61 Si las condiciones relevantes de la operación vinculada (por ejemplo, el precio o el margen) se encuentran fuera del rango de plena competencia determinado por la administración tributaria, debe darse al contribuyente la oportunidad de argumentar cómo satisfacen el principio de plena competencia las condiciones de la operación vinculada, y si el resultado está comprendido en el rango de plena competencia (es decir, que el rango de plena competencia es distinto al determinado por la administración tributaria). Si el contribuyente no es capaz de demostrar estos hechos, la administración tributaria debe determinar el punto comprendido en el rango de plena competencia al que ajustar la condición de la operación vinculada.

3.62 Para determinar este punto, cuando el rango comprende resultados muy fiables y relativamente iguales, puede argumentarse que cualquiera de ellos satisface el principio de plena competencia. Cuando persistan algunos defectos en la comparabilidad, como se vio en el párrafo 3.57, podría ser conveniente utilizar medidas de tendencia central que permitan determinar este punto (por ejemplo, la mediana, la media o la media ponderada, dependiendo de las características específicas de los datos) a fin de minimizar el riesgo de error provocado por defectos en la comparabilidad que persistan pero que no se conocen o no pueden cuantificarse.

A.7.3 Resultados extremos: problemas de comparabilidad

3.63 Los resultados extremos pueden consistir en pérdidas o en beneficios inusualmente elevados. Estos resultados extremos pueden afectar a los indicadores financieros analizados en el método seleccionado (por ejemplo, el margen bruto cuando se aplica el precio de reventa, o un indicador de beneficio neto cuando se aplica el método del margen neto operacional). Pueden afectar también a otros elementos, por ejemplo,

conceptos excepcionales que se computen por debajo del beneficio neto, pero que sin embargo pueden reflejar circunstancias excepcionales. Cuando uno o más de los posibles comparables presenten resultados extremos, será necesario persistir en el análisis a fin de entender las razones que los subyacen. La razón puede ser un defecto en la comparabilidad, o condiciones excepcionales que concurren en una tercera parte, por todo lo demás comparable. Los resultados extremos pueden excluirse sobre la base de la existencia de un defecto significativo en la comparabilidad que anteriormente no se había observado, y no meramente porque los resultados derivados del “comparable” propuesto sean muy distintos de los resultados observados en otros “comparables” propuestos.

3.64 Una empresa independiente no persistiría en el ejercicio de actividades generadoras de pérdidas a menos que tuviera unas expectativas razonables de beneficios futuros. Véanse los párrafos 1.70 a 1.72. En concreto, no suele esperarse de las funciones simples o que conllevan un riesgo bajo que generen pérdidas en un largo período de tiempo. Sin embargo, esto no significa que las operaciones que generan pérdidas nunca puedan ser comparables. En términos generales, debe utilizarse toda la información pertinente y no debe existir una regla prevalente sobre la inclusión o exclusión de los comparables que reflejan pérdidas. Naturalmente, serán los hechos y circunstancias de la sociedad los que determinen su condición de comparable, y no su resultado financiero.

3.65 En términos generales, una operación no vinculada deficitaria debe inducir a un análisis más exhaustivo a fin de determinar si puede utilizarse o no como comparable. Las circunstancias en las que deben excluirse las operaciones o las empresas deficitarias de la lista de comparables comprenden casos en los que las pérdidas no reflejan las condiciones de actividad normales, y en las que las pérdidas incurridas por terceros reflejan un nivel de riesgo no comparable al asumido por el contribuyente en sus operaciones vinculadas. Sin embargo, los comparables que reflejan pérdidas y que satisfacen el análisis de comparabilidad no deben rechazarse por el único motivo de sufrir pérdidas.

3.66 Debe llevarse a cabo un examen similar respecto de los comparables potenciales que muestran beneficios anormalmente elevados en relación con otros comparables potenciales.

B. Marco temporal y comparabilidad

3.67 La comparabilidad plantea cuestiones referidas al marco temporal en relación con la fecha de origen, de recopilación y de elaboración de la

información relativa a los factores de comparabilidad y a las operaciones no vinculadas comparables que se utilizan en el análisis de comparabilidad. En lo que concierne al marco temporal en el contexto de las obligaciones de documentación en materia de precios de transferencia, véanse los párrafos 5.3, 5.4, 5.5, 5.9 y 5.14 del Capítulo V.

B.1 *Fecha de origen*

3.68 En principio, cabe esperar que la información más precisa que puede usarse en un análisis de comparabilidad es aquella relativa a las condiciones de las operaciones no vinculadas comparables efectuadas de forma contemporánea a la operación vinculada (“operaciones no vinculadas contemporáneas”), dado que refleja el comportamiento de partes independientes en un entorno económico idéntico a aquel en el que se desarrolló la operación vinculada del contribuyente. Sin embargo, la práctica muestra una cierta limitación en la disponibilidad de información sobre operaciones no vinculadas contemporáneas, dependiendo de la fecha en la que esta se recopile.

B.2 *Fecha de recopilación*

3.69 En algunos casos, los contribuyentes preparan una documentación de precios de transferencia a fin de demostrar que han hecho esfuerzos razonables por respetar el principio de plena competencia en el momento en que se realizaron las operaciones intragrupo, es decir, con un criterio temporal apriorístico (denominado en lo sucesivo “criterio de determinación del precio de plena competencia”), basado en la información de la que pudieron disponer razonablemente en ese momento. Esta información comprende no sólo información sobre operaciones comparables de años anteriores, sino también la referida a los cambios económicos y del mercado que pueda haber habido entre esos años anteriores y aquel en el que se realizó la operación vinculada. Del mismo modo, partes independientes en circunstancias similares no basarían su determinación de precios únicamente en datos históricos.

3.70 En otros casos, los contribuyentes pueden tener que verificar el resultado real de sus operaciones vinculadas para demostrar que las condiciones de estas operaciones son coherentes con el principio de plena competencia, es decir, con un criterio temporal a posteriori (denominado en lo sucesivo “criterio de verificación del resultado de plena competencia”). Esta verificación se lleva a cabo normalmente como parte del proceso de elaboración de la declaración tributaria a fin del ejercicio.

3.71 Ambos criterios, el de determinación y el de verificación del resultado de plena competencia, así como combinaciones de ambos, pueden encontrarse entre los países miembros de la OCDE. El problema de la doble imposición puede surgir cuando en la operación vinculada intervienen dos empresas asociadas que aplican criterios distintos, conducentes a resultados igualmente distintos, por ejemplo debido a la discrepancia de los datos referidos a las expectativas de mercado según el criterio de determinación de precios de plena competencia y los resultados reales observados al aplicar el criterio de verificación. Véanse los párrafos 4.38 y 4.39. Se invita a las autoridades competentes a hacer lo posible para resolver cualquier problema de doble imposición que pueda surgir como consecuencia de la diferencia de criterios entre los países en lo que concierne a los ajustes de fin de ejercicio y que puedan presentárseles en el marco de un procedimiento amistoso (artículo 25 del Modelo de Convenio tributario de la OCDE).

B.3 Valoración inicial muy incierta y acontecimientos imprevisibles

3.72 Se plantea el problema de saber si deben tenerse en cuenta, en el marco del análisis de precios de transferencia, los acontecimientos futuros que sean imprevisibles en el momento de comprobar una operación vinculada, en concreto, cuando la valoración en ese momento fuera muy incierta y, en caso afirmativo, cómo proceder a ello. Esta cuestión deben resolverla tanto los contribuyentes como las administraciones tributarias por referencia a lo que hubieran hecho empresas independientes en circunstancias comparables para tener en cuenta la incertidumbre de la valoración en la determinación del precio de la operación.

3.73 El razonamiento que subyace a los párrafos 6.28 a 6.32 y al Anexo al Capítulo VI: “Ejemplos ilustrativos de la aplicación de las Directrices sobre precios de transferencia a activos intangibles de valoración muy incierta” para las operaciones en las que intervienen intangibles de valoración muy incierta se aplica, por analogía, a otros tipos de operaciones cuya valoración es también incierta. Lo más importante es determinar si la valoración fue lo suficientemente incierta al principio como para justificar que las partes que operan en condiciones de plena competencia hubieran tenido que aplicar un mecanismo de ajuste de precios, o si el cambio de valor constituiría un hecho tan importante como para conducir a la renegociación de la operación. Si este fuera el caso, la administración tributaria estaría justificada para determinar el precio de plena competencia de la operación sobre la base de la cláusula de ajuste o de la renegociación a las que se

hubiera recurrido en condiciones de plena competencia en una operación no vinculada comparable. En otras circunstancias, cuando no haya razón para considerar que la valoración fue lo suficientemente incierta al principio como para que las partes hubieran necesitado una cláusula de ajuste de precios o la renegociación de los términos del acuerdo, no hay razón para que las administraciones tributarias procedan a dicho ajuste, ya que constituiría un uso injustificado de la retrospección. La mera existencia de incertidumbre no conduce a un ajuste a posteriori sin antes considerar qué hubieran hecho o acordado partes independientes.

B.4 Datos relativos a ejercicios posteriores al de la operación

3.74 Los datos referidos a años posteriores al de la operación también pueden ser relevantes en el análisis de los precios de transferencia, pero hay que tener cuidado en el uso de la retrospección. Por ejemplo, los datos de años subsiguientes pueden ser prácticos para comparar ciclos de vida de productos en operaciones vinculadas y no vinculadas con el objeto de determinar si una operación no vinculada constituye un elemento comparable apropiado en la aplicación de un método concreto. El comportamiento posterior de las partes también puede ser relevante para averiguar los términos y circunstancias reales existentes entre ellas.

B.5 Datos de varios años

3.75 En la práctica, el examen de los datos relativos a varios años suele resultar útil para el análisis de comparabilidad, si bien no es una exigencia sistemática. Estos datos referidos a varios años deben utilizarse cuando aportan valor al análisis de precios de transferencia. No sería apropiado fijar normas respecto al número de años que deben abarcar los análisis de más de un ejercicio.

3.76 Para poder llegar a comprender plenamente los hechos y circunstancias que rodean una operación vinculada, puede resultar útil examinar los datos referidos tanto al año que se examina como a los anteriores. El análisis de esta información podría poner de manifiesto hechos que pueden haber influido (o que deberían haber influido) en la determinación del precio de transferencia. Por ejemplo, el uso de datos procedentes de años anteriores mostrará si la pérdida en una operación declarada por un contribuyente es parte de una serie de pérdidas producidas en operaciones similares, si es el resultado de circunstancias económicas particulares de un año anterior que implicaron incrementos en los costes en el año siguiente o si constituye el reflejo del hecho de que un producto

determinado se encuentra al final de su ciclo vital. Este tipo de análisis puede ser particularmente útil cuando se acude a un método basado en el resultado de la operación. Véase el párrafo 1.72 sobre la utilidad de los datos plurianuales para el análisis de las situaciones de pérdida. Estos datos referidos a varios años pueden ayudar también a mejorar la comprensión de los contratos a largo plazo.

3.77 Los datos plurianuales también son útiles para disponer de información acerca de los ciclos económicos relevantes y de los ciclos de vida de los productos de los comparables. Las diferencias en el ciclo económico o en el ciclo de los productos pueden tener un efecto sustancial en las condiciones de los precios de transferencia que debe evaluarse para determinar su comparabilidad. Los datos de años anteriores pueden mostrar si una empresa independiente que interviene en una operación comparable se vio afectada de manera comparable por circunstancias económicas comparables, o si las diferentes condiciones de algún año anterior afectaron a sus precios o a sus beneficios de tal forma que no deba utilizarse como elemento comparable.

3.78 Los datos de varios años pueden mejorar también el proceso de selección de terceros comparables, por ejemplo, identificando los resultados que pueden indicar una variación significativa respecto de las características de comparabilidad subyacentes de la operación vinculada objeto de revisión, lo que en ocasiones conduce al rechazo del comparable, o a detectar anomalías en la información sobre terceros.

3.79 El uso de datos referidos a varios años no implica necesariamente la utilización de medias plurianuales. No obstante, los datos plurianuales y las medias, pueden utilizarse en algunas circunstancias para mejorar la fiabilidad del rango. Véanse los párrafos 3.57 a 3.62 en los que se tratan las herramientas estadísticas.

C. Cuestiones de cumplimiento

3.80 Una cuestión que se plantea al situar en perspectiva la necesidad del análisis de comparabilidad es el alcance de la carga y los costes que puede suponer para el contribuyente la identificación de posibles comparables y la obtención de información detallada referida a ellos. Se admite que el coste de la información puede constituir realmente un problema, especialmente para las operaciones de pequeña y mediana envergadura, pero también para aquellas multinacionales que manejan un número muy elevado de operaciones vinculadas en muchos países. Los

párrafos 4.28, 5.6, 5.7 y 5.28 reconocen expresamente la necesidad de una aplicación razonable de la obligación de documentar la comparabilidad.

3.81 Cuando se emprende un análisis de comparabilidad, no es necesario efectuar una búsqueda exhaustiva en todas las fuentes de información posibles. Los contribuyentes y las administraciones tributarias deben aplicar su juicio para determinar si determinados comparables son fiables.

3.82 Resulta una práctica correcta el que los contribuyentes instauren un proceso para determinar, controlar y revisar sus precios de transferencia en función del volumen de las operaciones, su complejidad, el nivel de riesgo que entrañan y de si se desarrollan en un entorno estable o variable. Un criterio práctico de esta naturaleza sería conforme con la estrategia de evaluación pragmática de los riesgos o con el concepto de gestión empresarial prudente. En la práctica, esto se traduciría en la razonabilidad de que el contribuyente reduzca la búsqueda de información sobre comparables en relación con las operaciones vinculadas menos importantes o menos significativas. En el caso de operaciones simples que se desarrollen en un entorno estable y cuyas características permanezcan constantes o resulten similares puede no ser necesario practicar anualmente un análisis de comparabilidad detallado (incluyendo el funcional).

3.83 Los problemas con los precios de transferencia afectan cada vez más a las pequeñas y medianas empresas, y el número de operaciones internacionales está en permanente crecimiento. Aun cuando el principio de plena competencia se aplica igualmente a las pequeñas y medianas empresas y operaciones, lo idóneo es buscar soluciones pragmáticas que ofrezcan respuesta a cada problema de precios de transferencia individualmente.

Capítulo IV

Procedimientos administrativos destinados a evitar y resolver las controversias en materia de precios de transferencia

A. Introducción

4.1 Este capítulo examina los diferentes procedimientos administrativos a los que puede recurrirse para reducir al máximo las controversias en materia de precios de transferencia y contribuir a resolverlas cuando surjan entre los contribuyentes y sus administraciones tributarias, así como entre diferentes administraciones tributarias. Estas controversias pueden aparecer aun cuando se sigan escrupulosamente las pautas contenidas en estas Directrices para la aplicación del principio de plena competencia. Es posible que los contribuyentes y las administraciones tributarias lleguen a conclusiones diferentes en lo que respecta a las condiciones de plena competencia en operaciones vinculadas objeto de examen, debido a la complejidad de algunas cuestiones relativas a los precios de transferencia y a las dificultades en la interpretación y evaluación de las circunstancias de cada caso concreto.

4.2 Cuando dos o más administraciones tributarias adoptan posiciones distintas al determinar las condiciones de plena competencia puede aparecer una doble imposición. La doble imposición significa la inclusión de la misma renta en la base imponible por más de una administración tributaria, bien cuando la renta se encuentra en manos de diferentes contribuyentes (doble imposición económica en el caso de empresas asociadas) o cuando la renta se encuentra en manos de la misma entidad jurídica (doble imposición jurídica para establecimientos permanentes). La doble imposición no es deseable y debe eliminarse en la medida de lo posible, porque constituye una barrera potencial a la expansión de los flujos internacionales del comercio y la inversión. La doble inclusión de la misma renta en la base imponible de más de una administración tributaria no significa siempre que efectivamente se grave dos veces.

4.3 Este capítulo explica varios procedimientos administrativos para resolver las controversias debidas a los ajustes de precios de transferencia y para evitar la doble imposición. En la Sección B se estudian las prácticas que

siguen las administraciones tributarias para verificar el cumplimiento de las normas sobre precios de transferencia, en particular las prácticas de inspección, la carga de la prueba y las sanciones. La Sección C versa sobre los ajustes correlativos (párrafo 2 del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE) y el procedimiento amistoso (artículo 25). La Sección D describe la utilización de las inspecciones tributarias simultáneas por dos (o más) administraciones tributarias para acelerar la identificación, el procedimiento y la resolución de los problemas surgidos en materia de precios de transferencia y de otros problemas fiscales internacionales. Las Secciones E y F describen algunas posibilidades tendentes a minimizar las controversias en materia de precios de transferencia entre los contribuyentes y sus administraciones tributarias. La Sección E aborda la posibilidad de aplicar regímenes de protección para ciertos contribuyentes y la Sección F trata de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia, que plantean la posibilidad de determinar por anticipado una metodología de precios de transferencia o las condiciones que el contribuyente debe seguir en determinadas operaciones vinculadas. La Sección G considera brevemente el uso de los procedimientos de arbitraje para resolver las controversias entre países en materia de precios de transferencia.

B. Prácticas para la aplicación del régimen de precios de transferencia

4.4 Las prácticas tendentes al cumplimiento de las normas tributarias se definen y aplican en cada país miembro de acuerdo con su legislación interna y con sus procedimientos administrativos. Un gran número de prácticas nacionales tendentes al cumplimiento de las normas tributarias se basan básicamente en tres elementos: a) reducir las oportunidades para el incumplimiento (por ejemplo, a través de las retenciones en la fuente y exigiendo la comunicación de información); b) suministrar de manera positiva asistencia para facilitar el cumplimiento (por ejemplo, a través de actuaciones de formación y con la publicación de guías); y c) desincentivar la falta de cumplimiento. Por razones de soberanía nacional, y a fin de acomodarse a las peculiaridades de una amplia gama de sistemas tributarios, estas prácticas de cumplimiento deben permanecer en el marco competencial de cada país. Sin embargo, la aplicación equitativa del principio de plena competencia requiere normas procedimentales claras para garantizar la adecuada protección del contribuyente y asegurar que la recaudación tributaria no se transfiere a países que aplican normas excesivamente severas. Cuando un contribuyente sujeto a inspección en un país es miembro de un grupo multinacional, es posible que las prácticas de cumplimiento con las

obligaciones tributarias del país que inspecciona al contribuyente tengan consecuencia en otras jurisdicciones fiscales. Esto ocurre especialmente cuando se trata de cuestiones de precios de transferencia relativas a operaciones transfronterizas, porque los precios de transferencia tienen implicaciones en los impuestos recaudados en las jurisdicciones fiscales de las empresas asociadas participantes en la operación vinculada. Si otras jurisdicciones fiscales no aceptan el mismo precio de transferencia, el grupo multinacional puede estar sometido a una doble imposición, tal como se explica en el párrafo 4.2. En consecuencia, las administraciones tributarias deberían tener en cuenta el principio de plena competencia cuando apliquen sus prácticas internas de cumplimiento, así como las implicaciones que puedan derivarse de las reglas de cumplimiento de los precios de transferencia para otras jurisdicciones fiscales, y tratar de facilitar una asignación equitativa de los impuestos entre las jurisdicciones, así como evitar la doble imposición de los contribuyentes.

4.5 En esta Sección se describen tres aspectos del cumplimiento con los precios de transferencia a los que debe atenderse especialmente para contribuir a que las administraciones tributarias apliquen sus reglas sobre precios de transferencia de forma equitativa tanto para los contribuyentes como para otras jurisdicciones. Mientras que otras prácticas para el cumplimiento de las normas tributarias son de aplicación habitual en los países miembros de la OCDE (por ejemplo, la utilización de procedimientos contenciosos y de sanciones en materia de carga de la prueba cuando una administración tributaria está facultada para requerir información y no se le suministra) estos tres aspectos suelen incidir sobre la manera en que las administraciones tributarias de otras jurisdicciones encauzan los procedimientos amistosos y definen su respuesta administrativa para asegurar el cumplimiento de su propia reglamentación en materia de precios de transferencia. Estos tres aspectos son los siguientes: las prácticas en materia de inspección, la carga de la prueba y los regímenes sancionadores. Su evaluación diferirá necesariamente en función de las características del sistema fiscal en el que se enmarque, por lo que no es posible definir un conjunto uniforme de principios o un índice de problemas que sea válido en todos los casos. Esta Sección intenta ofrecer unas indicaciones generales en cuanto al tipo de problemas que pueden plantearse y unos criterios razonables para conseguir el equilibrio entre los intereses de los contribuyentes y los de las administraciones tributarias que participen en las inspecciones en materia de precios de transferencia.

B.1 Prácticas en materia de inspección

4.6 Las prácticas en materia de inspección varían considerablemente entre los países miembros de la OCDE. Las diferencias en los procedimientos pueden deberse a toda una serie de factores, particularmente: el sistema y estructura de la administración tributaria, la superficie y la población del país, el volumen del comercio interior y del comercio exterior, así como las influencias culturales e históricas.

4.7 Los casos de precios de transferencia pueden plantear dificultades específicas en relación con las prácticas normales de inspección o comprobación, tanto para la administración tributaria como para el contribuyente ya que ponen en juego un gran número de elementos fácticos y pueden exigir evaluaciones complejas por lo que respecta a la comparabilidad, los mercados y la información de naturaleza financiera u otra referente al sector. En consecuencia, algunas administraciones tributarias cuentan con inspectores especialistas en precios de transferencia y el proceso de inspección puede exigir más tiempo que otros y seguir procedimientos específicos.

4.8 Dado que la determinación de precios de transferencia no constituye una ciencia exacta, no siempre será posible determinar un único precio correcto de plena competencia; por el contrario (como reconoce el Capítulo III) a veces será necesario estimar el precio correcto tomando como referencia un rango de cifras aceptables. Por otra parte, es frecuente que la elección de la metodología de determinación de los precios de plena competencia no sea un proceso exento de ambigüedades. El contribuyente puede tener dificultades especialmente cuando la administración tributaria propone aplicar una metodología, por ejemplo, un método basado en el resultado de la operación, distinta a la utilizada por el contribuyente.

4.9 Cuando un caso de precios de transferencia plantea problemas difíciles debido a la complejidad de los hechos que han de evaluarse, incluso el contribuyente mejor intencionado puede cometer un error de buena fe. Del mismo modo, incluso el inspector mejor intencionado puede llegar a conclusiones erróneas sobre los hechos. Las administraciones tributarias deben tener en cuenta esta observación cuando lleven a cabo sus inspecciones en materia de precios de transferencia. Esto tiene dos consecuencias: en primer lugar, es deseable que la inspección muestre flexibilidad en su criterio y no exija de los contribuyentes una precisión poco adecuada a los hechos y circunstancias del caso por lo que respecta a la determinación de sus precios de transferencia. En segundo lugar, es recomendable que los inspectores tengan en consideración el punto de vista comercial del contribuyente sobre la aplicación del principio de plena

competencia, a fin de que el análisis de los precios de transferencia responda a las realidades empresariales. Por consiguiente, es recomendable que los inspectores comiencen por examinar los precios de transferencia desde la perspectiva del método elegido por el contribuyente. Las directrices del Capítulo II, Parte I, sobre la selección del método más apropiado para la determinación de los precios de transferencia pueden ser útiles a este respecto.

4.10 La administración tributaria debe tener en cuenta el proceso de determinación de precios utilizado por el contribuyente a la hora de asignar los recursos de inspección de que dispone, por ejemplo cuando el grupo multinacional opere sobre la base de un centro de beneficios. Véase el párrafo 1.5.

B.2 Carga de la prueba

4.11 Al igual que las prácticas en materia de inspección, las reglas que rigen la carga de la prueba en materia tributaria también difieren entre los países miembros de la OCDE. En la mayor parte de las jurisdicciones, la administración tributaria soporta la carga de la prueba, tanto en el área de sus relaciones internas con el contribuyente (por ejemplo, valoraciones y recursos) como en el área contenciosa. En algunos de estos países, la carga de la prueba puede invertirse, permitiendo que la administración tributaria pueda calcular la renta imponible si se constata que el contribuyente no ha actuado de buena fe (por ejemplo, no prestando su cooperación o no cumpliendo con requerimientos razonables de documentación, o presentando declaraciones falsas o engañosas). En otros países la carga de la prueba incumbe al contribuyente. A este respecto, es necesario tener en cuenta las conclusiones de los párrafos 4.16 y 4.17.

4.12 Debe valorarse la incidencia de las disposiciones que regulan la carga de la prueba en el comportamiento de la administración tributaria y del contribuyente. Por ejemplo, cuando la carga de la prueba recae en la administración tributaria en aplicación de la normativa interna, el contribuyente puede no tener ninguna obligación legal de probar la corrección del cálculo de su precio de transferencia, a menos que la administración tributaria haya aportado una prueba, en principio válida, demostrando que la determinación de los precios no es conforme con el principio de plena competencia. Incluso en ese supuesto, la administración tributaria seguiría pudiendo obligar legítimamente al contribuyente a presentar los documentos contables que permitan a la administración tributaria su inspección. En algunos países los contribuyentes tienen la obligación por ley de cooperar con la administración tributaria. Si el

contribuyente no cumple esta obligación, puede facultarse a la administración tributaria para calcular de oficio sus rentas y a estimar su situación sobre la base de los datos de que disponga. Siendo obligatoria la cooperación, las administraciones tributarias no deben imponer reglas demasiado estrictas que resulten de difícil cumplimiento para los contribuyentes honestos.

4.13 En las jurisdicciones donde la carga de la prueba incumbe al contribuyente, las administraciones tributarias no suelen poder practicar liquidaciones que no se apoyen en bases jurídicas sólidas. Por ejemplo, una administración tributaria de un país miembro de la OCDE no podría practicar una liquidación sobre la base de una renta sujeta a imposición calculada a partir de un porcentaje fijo sobre el volumen de negocios, sin tener en cuenta el principio de plena competencia. En caso de procedimiento contencioso, en aquellos países en los que la carga de la prueba recae sobre el contribuyente esta suele considerarse susceptible de inversión. Cuando el contribuyente presenta ante un tribunal argumentos y pruebas suficientes para demostrar que la determinación de sus precios de transferencia está de acuerdo con el principio de plena competencia, la carga de la prueba puede, legalmente o "de facto", desplazarse a la administración tributaria, para contrarrestar la posición del contribuyente y presentar argumentos y datos que demuestren por qué el precio de transferencia fijado por el contribuyente no se ajusta al principio de plena competencia y por qué la valoración de la Administración es correcta. Por otra parte, si un contribuyente no ha demostrado satisfactoriamente que su determinación de precios de transferencia se ajusta al principio de plena competencia, la obligación en materia probatoria del contribuyente no quedará satisfecha cuando la administración tributaria proceda a practicar una liquidación basada en fundamentos jurídicos sólidos.

4.14 En las cuestiones de precios de transferencia, las diferentes reglamentaciones sobre la carga de la prueba aplicadas en los países miembros de la OCDE constituirán un problema serio si los estrictos derechos jurídicos derivados de tales reglas se utilizan como pauta de conducta idónea. Tomemos como ejemplo la inspección de una operación vinculada en la que intervenga una jurisdicción donde la carga de la prueba recae sobre el contribuyente y una segunda jurisdicción donde la carga recae sobre la administración tributaria. Si la carga de la prueba es determinante para la conducta adoptada, la administración tributaria de la primera jurisdicción podría sostener una posición sin fundamento sobre la determinación de precios de transferencia, que el contribuyente podría aceptar, siendo la administración tributaria de la segunda jurisdicción la obligada a demostrar la incorrección de los precios fijados. Podría suceder que ni el contribuyente de la segunda jurisdicción, ni la administración

tributaria de la primera, hagan esfuerzo alguno para llegar a un precio aceptable de plena competencia. Este tipo de comportamiento podría generar un notable conflicto, así como conducir a la doble imposición.

4.15 Consideremos una situación idéntica a la del ejemplo del párrafo precedente. Si la carga de la prueba es de nuevo determinante de la conducta idónea, un contribuyente de la primera jurisdicción, que es filial de otro contribuyente de la segunda, puede no ser capaz o no desear demostrar (no obstante las reglas en materia de carga de la prueba y estas Directrices) que sus precios de transferencia son de plena competencia. La administración tributaria de la primera jurisdicción, después de realizar la inspección, efectúa un ajuste de buena fe basándose en la información de que dispone. La matriz, en la segunda jurisdicción, no está obligada a facilitar a su administración tributaria ninguna información que demuestre que el precio de transferencia era de plena competencia, dado que la carga de la prueba recae en la administración tributaria. Este escenario dificultaría la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de las actuaciones que las autoridades competentes iniciaran.

4.16 En la práctica, ni los países ni los contribuyentes deberían hacer un mal uso de las reglas sobre la carga de la prueba, tal como se ha descrito. Debido a las dificultades de los análisis en materia de precios de transferencia, sería conveniente que tanto los contribuyentes como las administraciones apliquen con particular prudencia y moderación las reglas relativas a la carga de la prueba en el curso de las inspecciones sobre precios de transferencia. Concretamente, y como cuestión de buena práctica, ni las administraciones tributarias ni los contribuyentes deberían hacer un mal uso de las reglas de la prueba como justificación para realizar afirmaciones sin fundamento y no verificables en el contexto de los precios de transferencia. Las administraciones tributarias deben estar dispuestas a demostrar de buena fe que su determinación de los precios de transferencia se basa en el principio de plena competencia, aun cuando la carga de la prueba recaiga en el contribuyente; y, de manera similar, los contribuyentes deben estar dispuestos a demostrar de buena fe que han fijado sus precios de transferencia conforme al principio de plena competencia, con independencia de en quién recaiga la carga de la prueba.

4.17 Los comentarios al párrafo 2 del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE precisan que el Estado al que se exige un ajuste correlativo no debería dar trámite a esta solicitud más que si "considera que la cifra de beneficios rectificadas refleja correctamente la que se habría obtenido si las operaciones se hubiesen realizado en condiciones de total independencia". Esto significa que, en el ámbito de las actuaciones entre autoridades competentes, al Estado que ha propuesto el ajuste primario le

incumbe la carga de demostrar al otro Estado que el ajuste "está justificado, tanto en principio como en lo que se refiere a su importe". Es necesario que las autoridades competentes de los dos países cooperen en la resolución de los procedimientos amistosos.

B.3 Sanciones

4.18 El propósito de las sanciones consiste generalmente en disuadir al contribuyente del incumplimiento de la legislación tributaria cuando las obligaciones en cuestión se refieren a requerimientos de naturaleza procedimental, como el suministro de la información necesaria, la presentación de declaraciones o a la determinación precisa de la deuda tributaria. Las sanciones suelen fijarse de modo que el coste por pagos insuficientes u otras inobservancias de la legislación tributaria sea más elevado que el que correspondería si se cumplieran las obligaciones tributarias. El Comité de Asuntos Fiscales ha reconocido que el objetivo primario de las sanciones fiscales de naturaleza civil debería ser alentar al cumplimiento de la legislación tributaria (véase el Informe de la OCDE *Taxpayer's Rights and Obligations*, "Derechos y obligaciones de los contribuyentes" [1990]). Si un procedimiento amistoso entre dos países lleva a la renuncia o a la reducción del ajuste, es importante que existan posibilidades de eliminar o atenuar una sanción impuesta por las administraciones tributarias.

4.19 La comparación de las prácticas y políticas en materia de sanciones entre diferentes países debe hacerse con mucha prudencia. En primer lugar, cualquier comparación debe tener en cuenta que es posible que existan sanciones con denominaciones distintas, en función del país, que cumplan los mismos objetivos. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta el conjunto de disposiciones que garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias del país miembro de la OCDE. Las prácticas nacionales en materia de cumplimiento, como se ha indicado anteriormente, están en función del conjunto del sistema tributario del país, se definen atendiendo a las necesidades y al equilibrio interno, y comprenden la elección entre las medidas fiscales que eliminan o limitan las posibilidades de incumplimiento tributario (por ejemplo imponiendo a los contribuyentes la obligación de cooperar con la administración tributaria o invirtiendo la carga de la prueba cuando el contribuyente parece no haber actuado de buena fe) y la utilización de sanciones pecuniarias (por ejemplo, la aplicación de un recargo en caso de minoración del impuesto, además del pago del impuesto no ingresado). La naturaleza de las sanciones tributarias puede verse afectada por el sistema judicial del país. La mayor parte de los países no aplica

sanciones si no existe culpabilidad; en determinados países, por ejemplo, la imposición de una sanción sin la existencia de culpabilidad sería contraria a los principios fundamentales de su sistema jurídico.

4.20 Existen diversos tipos de sanciones adoptadas por las jurisdicciones tributarias. Estas pueden consistir tanto en sanciones civiles como penales. Las sanciones penales, en la práctica, están siempre reservadas a los casos muy serios de fraude y suelen conllevar una elevada carga de prueba para la parte que invoca la aplicación de la sanción (es decir, la administración tributaria). En ningún país miembro de la OCDE las sanciones penales constituyen el principal medio para promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las sanciones civiles (o administrativas) son más comunes, tratándose generalmente de sanciones pecuniarias (aunque, como se vio anteriormente, la sanción puede tener un carácter distinto del pecuniario, particularmente bajo la forma de una inversión de la carga de la prueba, cuando, por ejemplo, el contribuyente no ha cumplido determinadas reglas de procedimiento o no ha cooperado, y el ajuste discrecional determina una sanción efectiva).

4.21 Algunas sanciones civiles están dirigidas al cumplimiento de obligaciones de orden formal, como la presentación de declaraciones en plazo y la comunicación de información. A menudo, las sanciones de este tipo son de escasa cuantía, calculándose sobre la base de una cantidad fija por cada día de retraso, por ejemplo, en la presentación de la declaración. Las sanciones civiles más fuertes son las que atañen a la minoración de la obligación tributaria.

4.22 Aunque algunos países pueden emplear el término "sanción", en otros países, las mismas o similares exacciones pueden clasificarse dentro de la categoría de "intereses". Los regímenes sancionadores de determinados países pueden, en consecuencia, incluir "un impuesto adicional" o "intereses" en caso de declaraciones insuficientes con el resultado de pago de los impuestos con posterioridad a la fecha de su exigibilidad. Estas disposiciones suelen estar destinadas a asegurar, al menos, la recuperación del valor en tiempo real del dinero (impuesto) no recaudado.

4.23 Las sanciones pecuniarias civiles por declaraciones insuficientes suelen aplicarse en los siguientes casos: declaración insuficiente del impuesto debido por encima de una cierta cuantía mínima; negligencia del contribuyente o intención deliberada de evadir el impuesto (y también de fraude, aun cuando el fraude puede generar sanciones penales más severas). Muchos países miembros de la OCDE imponen sanciones pecuniarias por negligencia o intencionalidad, mientras que sólo unos pocos penalizan las

declaraciones en las que se infravalora la obligación tributaria sin que exista culpabilidad.

4.24 Es difícil evaluar en abstracto si una sanción pecuniaria civil es, o no, excesiva. En los países miembros de la OCDE, las sanciones pecuniarias civiles debidas a una declaración de impuestos por defecto se suelen calcular en forma de porcentaje sobre dicho defecto, que varía entre el 10 y el 200%. En la mayor parte de los países miembros la cuantía de la sanción aumenta en la medida en que se incrementan las condiciones que determinan su imposición. Por ejemplo, las sanciones más severas a menudo se reservan para el caso de un alto grado de culpabilidad del contribuyente, como la intención deliberada de evadir el impuesto. Las sanciones sin existencia de culpabilidad, en los casos en los que se aplican, suelen ser menos severas que las que implican culpabilidad por parte del contribuyente (véase el párrafo 4.28).

4.25 El uso apropiado de sanciones puede jugar un papel útil, dando respuesta a la preocupación de los países miembros por conseguir un mayor respeto de las obligaciones tributarias en el área de los precios de transferencia. Sin embargo, debido a la naturaleza de los problemas que plantean los precios de transferencia, hay que procurar que la aplicación del sistema sancionador, en tales supuestos, sea justa y no constituya una carga excesivamente onerosa para el contribuyente.

4.26 Debido a que las cuestiones transfronterizas en materia de precios de transferencia afectan a la base imponible de dos países, un sistema sancionador demasiado severo en un país puede incitar al contribuyente a declarar por exceso sus rentas en dicho país, contraviniendo el artículo 9. Si se llega a este resultado, el dispositivo sancionador no ha conseguido su objetivo primario, es decir, promover el respeto de las obligaciones tributarias y, por el contrario, lleva a una inobservancia de diferente género: el incumplimiento del principio de plena competencia y la declaración por defecto de las rentas en otra jurisdicción. Todos los países miembros de la OCDE deberían cerciorarse de que sus prácticas en materia de precios de transferencia no se aplican de forma incompatible con los objetivos del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, evitando las distorsiones antes mencionadas.

4.27 Los países miembros de la OCDE estiman, en general que, para apreciar la equidad de un sistema sancionador, es necesario considerar si la sanción es proporcional a la infracción. Esto significaría, por ejemplo, que la gravedad de la sanción estaría en función de las condiciones bajo las cuales podría imponerse y que, en la medida en que aumente la severidad de la sanción, las condiciones para su aplicación serían más estrictas.

4.28 Puesto que las sanciones no constituyen más que uno de los numerosos aspectos administrativos y procedimentales de un sistema tributario, es difícil pronunciarse sobre la equidad de una sanción sin examinar los restantes aspectos del sistema tributario. Sin embargo, los países miembros de la OCDE están de acuerdo en que es posible extraer las siguientes conclusiones, con independencia de los otros aspectos del sistema tributario en vigor en un país determinado. En primer lugar, la aplicación de una sanción importante en ausencia de culpa, basada en el mero hecho de una menor declaración en una cierta cuantía, sería considerada como excesivamente severa cuando se trata de un error de buena fe y no de una negligencia o de una auténtica intención de evadir el impuesto. En segundo lugar, sería injusto imponer sanciones severas a los contribuyentes que han hecho un esfuerzo razonable de buena fe para fijar las condiciones de sus operaciones con empresas asociadas de conformidad con el principio de plena competencia. En concreto, no se debe imponer una sanción a un contribuyente por no haber contemplado datos a los que no tenía acceso a la hora de determinar sus precios de transferencia, ni por no haber aplicado un método de determinación de precios que exigía contar con datos fuera de su alcance. Se invita a las administraciones tributarias a que tengan en cuenta estas observaciones en la aplicación de sus regímenes sancionadores.

C. El ajuste correlativo y el procedimiento amistoso: artículos 9 y 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE

C.1 *El procedimiento amistoso*

4.29 El procedimiento amistoso constituye un medio tradicional a través del que las administraciones tributarias se consultan para la resolución de las controversias relativas a la aplicación de los convenios de doble imposición. Este procedimiento, descrito y autorizado por el artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, puede utilizarse para eliminar la doble imposición que pudiera derivarse de un ajuste de precios de transferencia.

4.30 El artículo 25 indica tres áreas en las cuales el procedimiento amistoso suele utilizarse. La primera incluye ejemplos de "imposición que no es conforme con las disposiciones del Convenio" y está contemplada en los párrafos 1 y 2 del artículo. En esta área, generalmente es el contribuyente quien inicia los procedimientos. Las otras dos áreas, que no involucran necesariamente al contribuyente, se tratan en el párrafo 3 y se refieren a cuestiones de "interpretación o aplicación del Convenio" y a la eliminación de la doble imposición en los casos no previstos en el Convenio. El párrafo 9 de los Comentarios al artículo 25 precisa que el artículo 25 constituye

igualmente un mecanismo que permite a las autoridades competentes resolver los casos no sólo de doble imposición jurídica sino también de doble imposición económica derivados de los ajustes de los precios de transferencia efectuados conforme al párrafo 1 del artículo 9.

4.31 El apartado 5 del artículo 25, que se incorporó al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE en 2008, establece que, en los casos en los que las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo en el plazo de dos años desde la presentación del caso conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25, a instancia de la persona que lo haya solicitado se someterá a arbitraje toda cuestión irresoluta. Esta ampliación del procedimiento amistoso garantiza que cuando las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo respecto de una o más cuestiones, y esto impida avanzar hacia la resolución del procedimiento, será aun posible resolverlo remitiendo dichas cuestiones a arbitraje. Cuando conforme a esa disposición se remitan una o más cuestiones a arbitraje, a menos que una persona a la que concierna directamente el caso rechace el acuerdo amistoso que aplique el dictamen emitido, dicho dictamen será vinculante para ambos Estados, la imposición a la que se someta a cualquier persona directamente relacionada con el caso tendrá que ajustarse al mismo, y este quedará reflejado en el procedimiento amistoso que se les presente. Cuando un convenio bilateral concreto no contenga una cláusula referida al arbitraje similar a la del apartado 5 del artículo 25, el procedimiento amistoso no obliga a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo y a resolver sus controversias en materia fiscal, y las autoridades competentes únicamente están obligadas a esforzarse en alcanzar un acuerdo. Es posible que las autoridades competentes no lleguen a un acuerdo debido a divergencias entre sus legislaciones internas o a restricciones en los poderes de negociación de la administración tributaria, derivadas de la legislación nacional. Obsérvese, sin embargo, que incluso en ausencia de una cláusula sobre arbitraje similar a la del apartado 5 del artículo 25 en un convenio bilateral concreto, las autoridades competentes de los Estados contratantes pueden establecer de mutuo acuerdo un arbitraje igualmente vinculante (véase el párrafo 69 de los Comentarios al artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Obsérvese asimismo que los Estados miembros de las Comunidades Europeas firmaron el 23 de julio de 1990 un Convenio multilateral de arbitraje, que entró en vigor el 1 de enero de 1995, para resolver entre ellos las controversias referidas a la determinación de precios de transferencia.

C.2 El ajuste correlativo: párrafo 2 del artículo 9

4.32 Para eliminar la doble imposición en los casos de precios de transferencia, las administraciones tributarias pueden considerar las solicitudes de ajustes correlativos tal y como están descritas en el párrafo 2 del artículo 9. Un ajuste correlativo que en la práctica puede desarrollarse como parte del procedimiento amistoso puede atenuar o eliminar la doble imposición en los casos en que una primera administración tributaria incrementa los beneficios sujetos a imposición de una sociedad (es decir, efectúa un "ajuste primario") como resultado de aplicar el principio de plena competencia a operaciones donde interviene una empresa asociada de una segunda jurisdicción tributaria. En este supuesto, el ajuste correlativo consiste en un ajuste a la baja de la deuda tributaria de esta empresa asociada, efectuado por la administración tributaria de la segunda jurisdicción, de manera que la atribución de beneficios entre las dos jurisdicciones sea conforme con el ajuste primario y no se produzca doble imposición. Es también posible que la primera administración tributaria acepte reducir (o eliminar) el ajuste primario como consecuencia de las consultas llevadas a cabo con la otra administración tributaria, en cuyo caso el ajuste correlativo sería inferior (o quizás innecesario). Debe señalarse que el ajuste correlativo no tiene por finalidad procurar a un grupo multinacional un beneficio superior al que hubiera resultado de operaciones vinculadas realizadas desde el principio en condiciones de plena competencia.

4.33 El párrafo 2 del artículo 9 recomienda expresamente que las autoridades competentes intercambien las consultas necesarias para determinar el ajuste correlativo. Esto demuestra que el procedimiento amistoso del artículo 25 puede utilizarse para considerar las solicitudes de ajuste correlativo. Sin embargo, la coincidencia entre los dos artículos ha determinado que los países miembros de la OCDE se planteen si el procedimiento amistoso es aplicable para proceder al ajuste correlativo cuando el convenio bilateral entre dos Estados contratantes no incluya una disposición comparable a la del párrafo 2 del artículo 9. Los párrafos 11 y 12 de los Comentarios al artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE explicita actualmente la opinión de la mayoría de los países miembros de la OCDE, en el sentido de que el procedimiento amistoso es aplicable a los ajustes de precios de transferencia aun en ausencia de una disposición comparable a la del párrafo 2 del artículo 9. Asimismo, el párrafo 12 de los Comentarios señala que los países miembros de la OCDE que no compartan esta opinión aplicarán su normativa interna de forma que pueda eliminarse la doble imposición de las empresas que actúen de buena fe la mayoría de los casos.

4.34 Según el párrafo 2 del artículo 9, un Estado contratante puede efectuar un ajuste correlativo calculando de nuevo, sobre la base del precio revisado, los beneficios imponible de la empresa asociada en ese Estado o, sin modificar los cálculos, concediendo a la empresa asociada una reducción en el impuesto debido en ese Estado, equivalente al impuesto adicional cargado a la empresa asociada por el Estado que efectúa el ajuste como consecuencia del ajuste del precio de transferencia. El primer método es, con mucho, el más común entre los países miembros de la OCDE.

4.35 En ausencia de un dictamen al que se llegue mediante el recurso a un procedimiento arbitral similar al previsto en el apartado 5 del artículo 25, que determine un ajuste correlativo, los ajustes correlativos no son obligatorios, habida cuenta de la regla según la cual las administraciones tributarias no están obligadas a alcanzar un acuerdo dentro del procedimiento amistoso. En virtud del párrafo 2 del artículo 9, una administración tributaria solamente debería efectuar un ajuste correlativo en la medida en que considere justificado el ajuste primario, tanto en principio como en lo que se refiere a su cuantía. La naturaleza no obligatoria de los ajustes correlativos es necesaria a fin de que una administración tributaria no se vea forzada a aceptar las consecuencias de un ajuste arbitrario o caprichoso realizado por otro Estado. También es importante para respetar la soberanía fiscal de cada país miembro de la OCDE.

4.36 Una vez que una administración tributaria ha aceptado realizar un ajuste correlativo, es necesario establecer si ese ajuste ha de atribuirse al año en el que se han realizado las operaciones vinculadas determinantes del ajuste, o a otro año, como por ejemplo al año en el cual se efectuó el ajuste primario. A este respecto, a menudo se plantea la cuestión de determinar si un contribuyente tiene derecho a intereses por los impuestos que ha ingresado en exceso en la jurisdicción que ha aceptado proceder al ajuste correlativo (véanse los párrafos 4.63 a 4.65). El primer criterio es más apropiado porque permite una correlación entre rentas y gastos y refleja mejor la situación económica que habría prevalecido si las operaciones vinculadas se hubieran efectuado en condiciones de plena competencia. Sin embargo, cuando exista un lapso de tiempo importante entre el año al que se refiere el ajuste y el año en que el contribuyente lo acepta o en el que se ha dictado sentencia definitiva por los tribunales, la Administración debería tener la flexibilidad suficiente para aceptar realizar el ajuste correlativo en el año de aceptación del ajuste primario o en el que se adopta la decisión judicial. Este método supone necesariamente disposiciones de derecho interno que permitan su aplicación. Aunque no sea el criterio preferido, podría resultar apropiado como medida equitativa en casos excepcionales para facilitar la aplicación del ajuste y evitar una eventual prescripción.

4.37 Los ajustes correlativos pueden constituir un medio muy eficaz para mitigar la doble imposición resultante de los ajustes de precios de transferencia. En general, los países miembros de la OCDE se esfuerzan de buena fe en llegar a un acuerdo cada vez que se invoca el procedimiento amistoso. Gracias a dicho procedimiento, las administraciones tributarias pueden tratar los problemas en un ámbito no contencioso y llegar frecuentemente a una solución negociada en beneficio de todas las partes. El procedimiento amistoso permite igualmente a las administraciones tributarias tener en cuenta otros aspectos de la imposición, particularmente las retenciones en la fuente.

4.38 Al menos un país miembro de la OCDE ha establecido un procedimiento que puede reducir la necesidad de los ajustes primarios; este mecanismo consiste en autorizar al contribuyente a declarar, con fines tributarios, un precio de transferencia que estime conforme con el precio de plena competencia para una operación vinculada, aun si este precio es diferente del efectivamente cargado entre las dos empresas asociadas. Este ajuste, denominado en ocasiones "ajuste compensatorio", se realiza antes de presentar la declaración tributaria. Los ajustes compensatorios pueden facilitar la declaración de la renta imponible por los contribuyentes de acuerdo con el principio de plena competencia, admitiendo que la información sobre operaciones comparables no vinculadas puede no estar disponible en el momento en que las empresas asociadas establecen los precios de sus operaciones vinculadas. En consecuencia, con la finalidad de declarar correctamente el impuesto, el contribuyente estaría autorizado a realizar un ajuste compensatorio que contabilizara la diferencia entre el precio de plena competencia y el precio efectivamente registrado en sus documentos contables.

4.39 Sin embargo, la mayor parte de los países miembros de la OCDE no admite los ajustes compensatorios, basándose en que la declaración tributaria debe reflejar las operaciones reales. Si los ajustes compensatorios están autorizados (o son obligatorios) en el país de una empresa asociada, pero no lo están en el país de la otra empresa asociada, puede producirse doble imposición porque no será posible un ajuste correlativo a falta de un ajuste primario. Puede recurrirse al procedimiento amistoso para resolver las dificultades planteadas por los ajustes compensatorios, y se insta a las autoridades competentes a que hagan lo posible para resolver toda doble imposición que pudiera derivarse de las diferencias de criterios de los países respecto de los ajustes practicados al final del ejercicio.

C.3 Preocupaciones suscitadas por estos procedimientos

4.40 Si bien es cierto que el ajuste correlativo y los procedimientos amistosos han demostrado su capacidad para resolver la mayoría de los conflictos de precios de transferencia, los contribuyentes han expresado serias preocupaciones. Por ejemplo, temen que, por razón de la complejidad de los problemas de precios de transferencia, los procedimientos destinados a evitar la doble imposición no constituyan salvaguardias suficientes. La inclusión en la actualización de 2008 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE de un nuevo aparato 5 en el artículo 25 es la respuesta a estas preocupaciones. Este apartado introduce un mecanismo que permite a los contribuyentes referir a arbitraje las cuestiones irresolutas que impidan a las autoridades competentes llegar a un acuerdo en el plazo de dos años. En los Comentarios al artículo 25 se prevé igualmente el recurso a mecanismos alternativos de resolución de controversias, además del arbitraje, que comprenderían la mediación de terceros expertos y la remisión a estos de las controversias de hecho.

4.41 Los contribuyentes recelan igualmente de que sus casos no se resuelvan únicamente en función de las características individuales de su expediente, sino con referencia a un balance global de los resultados obtenidos en otros casos. La buena práctica admitida consiste en que, en la resolución de los procedimientos amistosos, las autoridades competentes deben llevar a cabo su discusión con la otra autoridad competente sobre la base de una argumentación bien fundada, justa y objetiva, llegando a la conclusión de cada caso en función de sus propias circunstancias y no buscando el equilibrio con otros. En la medida en que resulten aplicables, estas Directrices constituyen una base adecuada sobre la que desarrollar un criterio bien fundamentado. Asimismo, se pueden temer medidas de represalia o ajustes compensatorios por parte del país al que se ha solicitado el ajuste correlativo. No es la intención de las administraciones tributarias tomar medidas de represalia; el temor de los contribuyentes quizá se deba a una información inadecuada. Las administraciones tributarias deben llevar a cabo acciones para garantizar a los contribuyentes que no deben temer la aplicación de medidas de retorsión y que, conforme al principio de plena competencia, cada caso se resuelve en función de sus propias particularidades. No debe disuadirse a los contribuyentes de iniciar procedimientos amistosos en los casos en que puedan acogerse al artículo 25.

4.42 Las preocupaciones quizá más importantes expresadas en relación con el procedimiento amistoso, en la medida en que afecta a los ajustes correlativos, se discuten separadamente en las secciones siguientes:

1. Los plazos de prescripción previstos en el derecho interno pueden imposibilitar los ajustes correlativos si dichos plazos no se derogan en el correspondiente convenio.
2. El procedimiento amistoso puede durar excesivamente.
3. La participación del contribuyente puede ser limitada.
4. Los contribuyentes pueden no acceder fácilmente a información escrita que les instruya sobre la utilización del procedimiento.
5. Puede darse el caso de que no existan procedimientos para suspender la recaudación de las deficiencias en la liquidación de los impuestos, o el devengo de los intereses, mientras el procedimiento amistoso está pendiente de resolución.

C.4 Recomendaciones para solucionar los problemas

C.4.1 Plazos de prescripción

4.43 El ajuste en la cuantía del impuesto previsto en el párrafo 2 del artículo 9 puede resultar inviable cuando ha expirado el plazo fijado por el convenio o por la Ley interna para proceder al ajuste correlativo. El párrafo 2 del artículo 9 no establece ningún límite a partir del cual el ajuste correlativo no podrá efectuarse. Algunos países prefieren una solución flexible para atenuar la doble imposición. Otros no consideran razonable este enfoque abierto por razones administrativas. En consecuencia, la desgravación puede depender de si el convenio aplicable deroga los plazos de prescripción nacionales, establece otros plazos o no tiene ningún efecto sobre los plazos previstos en la Ley interna.

4.44 Los plazos de prescripción que determinan la extinción de la deuda tributaria de un contribuyente son necesarios para dotar de certidumbre a los contribuyentes y a las administraciones tributarias. En un caso de precios de transferencia, un país puede encontrarse en la incapacidad jurídica de proceder a un ajuste correlativo si ha expirado el plazo previsto para liquidar definitivamente el impuesto debido por la empresa asociada en cuestión. En consecuencia, con el fin de minimizar la doble imposición, debe tenerse en cuenta la existencia de tales plazos de prescripción y el hecho de que varíen de un país a otro.

4.45 El párrafo 2 del artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE trata la cuestión del plazo de prescripción requiriendo la aplicación del acuerdo alcanzado siguiendo el procedimiento amistoso

independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los Estados contratantes. En consecuencia, dichos plazos de prescripción no impiden realizar los ajustes correlativos cuando un convenio bilateral incluye esta disposición. Algunos países sin embargo, que no desean o no pueden derogar los plazos de prescripción previstos en su Derecho interno de esta manera, han formulado reservas explícitas sobre este punto. Los países miembros de la OCDE están pues invitados, en la medida de lo posible, a ampliar los plazos de prescripción nacionales a efectos de realizar los ajustes correlativos cuando se haya invocado un procedimiento amistoso.

4.46 Cuando un convenio bilateral no deroga los plazos de prescripción previstos en el derecho interno a efectos del procedimiento amistoso, las administraciones tributarias deben estar preparadas para iniciar rápidamente las discusiones cuando el contribuyente lo solicite, con anterioridad suficiente a la expiración de cualquier plazo que impida la realización del ajuste. Además, es deseable que los países miembros de la OCDE adopten, en su derecho interno, disposiciones que autoricen la suspensión de los plazos aplicables para la determinación del impuesto debido hasta que las discusiones hayan concluido.

4.47 La cuestión de los plazos de prescripción puede resolverse también a través de reglas que regulan los ajustes primarios más que los ajustes correlativos. El problema de los plazos en los ajustes correlativos obedece a veces al hecho de que los cálculos iniciales de los ajustes primarios no se realizan hasta transcurridos muchos años después de la conclusión del período impositivo. Por ello, algunos países estiman que debería preverse en los convenios bilaterales una disposición que imposibilitase la liquidación inicial a partir de un momento dado. Sin embargo, un gran número de países se opone a esta solución. En efecto, las administraciones pueden requerir un tiempo dilatado para realizar las investigaciones necesarias para proceder al ajuste. Para muchas administraciones tributarias sería difícil ignorar la necesidad de un ajuste, con independencia del momento en que se evidenciara, siempre que los plazos de prescripción fijados por su derecho interno no impidan realizarlo. Aunque no es posible en la fase actual formular una recomendación general sobre el plazo de prescripción de la liquidación inicial, es deseable que las administraciones tributarias procedan a estas liquidaciones en los plazos previstos en su legislación interna sin ampliarlos. Si la complejidad del caso o la falta de cooperación por parte del contribuyente exigiesen una prórroga, esta debería ser por un período mínimo y específico. Además, cuando los plazos aplicables internamente pueden ampliarse con la conformidad del contribuyente, dicha prórroga debería realizarse solamente cuando el consentimiento del contribuyente sea plenamente voluntario. Es aconsejable que los inspectores indiquen a los

contribuyentes, desde el inicio, su intención de proceder a una liquidación basada en los precios de transferencia de las operaciones transfronterizas, de manera que el contribuyente pueda, si es su deseo, informar a la administración tributaria del otro Estado interesado, lo que permite a esta última considerar la cuestión en el contexto de un eventual procedimiento amistoso.

4.48 Otro plazo que debe tenerse en cuenta es el de los tres años durante los que el contribuyente debe instar el procedimiento amistoso en virtud del artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Este plazo de tres años comienza a contar a partir de la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio, que puede ser el momento en el que la administración tributaria notifique por primera vez el ajuste propuesto, la "medida de ajuste" o "actuación tributaria", o una fecha anterior, como se analiza en los párrafos 21 a 24 de los Comentarios al artículo 25. Si bien algunos países consideran que este plazo de tres años es demasiado corto para instar el procedimiento, otros lo consideran demasiado largo y han formulado reservas al respecto. Los Comentarios al artículo 25 indican que el plazo "debe considerarse como mínimo, de tal suerte que los Estados contratantes son libres de concertar bilateralmente un plazo más largo en favor de los contribuyentes".

4.49 El plazo de tres años plantea un problema por lo que se refiere a la fecha de inicio, que se aborda en los párrafos 21 a 24 de los Comentarios al artículo 25. En concreto, el párrafo 21 indica que dicho plazo "debería interpretarse de la manera más favorable posible para el contribuyente". El párrafo 22 contiene unas pautas sobre la determinación de la fecha de la actuación tributaria. El párrafo 23 aborda los casos de autoliquidación. El párrafo 24 precisa que, "cuando la imposición no conforme al convenio resulte del efecto combinado de decisiones o medidas tomadas en los dos Estados contratantes, el plazo se computará desde la primera notificación de la decisión o de la actuación más reciente".

4.50 Con el fin de minimizar la posibilidad de que los plazos establecidos impidan el funcionamiento eficaz del procedimiento amistoso para la reducción o eliminación de la doble imposición, debe permitirse que el contribuyente pueda iniciar este procedimiento lo antes posible; es decir, desde el momento en que parezca probable el ajuste. De esta manera, las consultas podrían empezar antes de que una u otra de las administraciones tributarias tome medidas irrevocables con objeto de que los obstáculos procedimentales para llegar a una conclusión mutuamente aceptable sean los menos posibles. Sin embargo, algunas autoridades competentes pueden no desear intervenir en una fase tan inicial dado que el ajuste propuesto puede no llegar a una actuación final, o no desencadenar necesariamente una

solicitud de ajuste correlativo. Por lo tanto, permitir a los contribuyentes invocar prematuramente el procedimiento amistoso puede ser una fuente de trabajo innecesario.

4.51 No obstante, las autoridades competentes deben estar preparadas para iniciar discusiones sobre precios de transferencia en el marco de los procedimientos amistosos tan pronto como les sea posible, teniendo en cuenta la utilización racional de sus recursos.

C.4.2 Duración de los procedimientos amistosos

4.52 Una vez que se han iniciado las deliberaciones en el marco del procedimiento amistoso, estas pueden dilatarse en el tiempo. La complejidad de los casos sobre precios de transferencia puede hacer difícil que las administraciones tributarias alcancen una solución rápida. La distancia impide a veces que las administraciones tributarias se reúnan frecuentemente y el intercambio de correspondencia no suple satisfactoriamente las discusiones en persona. Hay que tener en cuenta también las dificultades por las diferencias de lengua, de procedimientos y de sistemas jurídicos y contables, que pueden alargar el procedimiento. Este procedimiento puede dilatarse también si el contribuyente se retrasa en suministrar toda la información que las administraciones tributarias requieren para un completo entendimiento del caso de precios de transferencia planteado. Sin embargo, los retrasos no se producen siempre y, en la práctica, las consultas suelen dar como resultado una solución relativamente rápida al problema.

4.53 Es posible reducir el tiempo necesario para concluir un procedimiento amistoso. Simplificar las formalidades requeridas para aplicar el procedimiento puede acelerar el proceso. A este respecto, los contactos personales o las conferencias telefónicas pueden ser útiles para establecer más rápidamente si un ajuste practicado por un país puede provocar o no dificultades en el otro. Estos contactos son caros, pero a largo plazo pueden tener una mejor relación coste-eficacia que las comunicaciones formales por escrito, que requieren más tiempo. La OCDE ha desarrollado un Manual en línea para la aplicación efectiva del procedimiento amistoso, que señala una serie de prácticas idóneas que los países deben utilizar para mejorar la eficacia de sus procedimientos amistosos.

4.54 Lo esencial es que la introducción de una cláusula sobre arbitraje similar a la prevista en el apartado 5 del artículo 25 para la resolución de las cuestiones pendientes tras la conclusión de un plazo de dos años reduciría sustancialmente el riesgo de procedimientos amistosos excesivamente dilatados en el tiempo.

C.4.3 Participación del contribuyente

4.55 El párrafo 1 del artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE otorga al contribuyente el derecho a presentar una solicitud para iniciar un procedimiento amistoso. El párrafo 34 de los Comentarios al artículo 25 precisa que tales solicitudes no deben rechazarse sin un motivo válido. Las circunstancias en las que un Estado puede denegar el acceso del contribuyente al procedimiento amistoso y las vías correctas para gestionar estos casos se analizan en los párrafos 26 a 29 de los Comentarios al artículo 25.

4.56 Sin embargo, aunque el contribuyente tiene el derecho de iniciar el procedimiento, carece del derecho específico de participar en él. Se ha argumentado que el contribuyente debería tener también el derecho a participar en el procedimiento amistoso, y, como mínimo, a presentar su caso ante ambas autoridades competentes y a ser informado sobre el estado de las deliberaciones. Debería señalarse a este respecto que la aplicación efectiva del procedimiento amistoso requiere el acuerdo del contribuyente. Algunos representantes de los contribuyentes han sugerido que el contribuyente debería también tener el derecho a presenciar las entrevistas personales entre las autoridades competentes. El propósito sería evitar cualquier malentendido, por parte de las autoridades competentes, en cuanto a los hechos y a la argumentación del contribuyente.

4.57 El procedimiento amistoso contemplado en el artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y adoptado en un gran número de convenios bilaterales, no constituye un procedimiento contencioso. Si bien es cierto que en determinados casos la intervención del contribuyente puede facilitar el desarrollo del procedimiento, esta participación debería dejarse a la discreción de las autoridades competentes.

4.58 Al margen de las discusiones concretas entre las autoridades competentes, es esencial que el contribuyente facilite oportunamente a las autoridades competentes toda la información que resulte pertinente. Las administraciones tributarias disponen de medios limitados y los contribuyentes deberían hacer todo lo posible para simplificar el proceso. Además, puesto que el procedimiento amistoso tiene por finalidad prioritaria ayudar al contribuyente, las administraciones tributarias deben permitir que estos presenten, en todas las ocasiones propicias, los hechos y argumentos que permitan evitar, en la medida de lo posible, los malentendidos.

4.59 En la práctica, las administraciones tributarias de un gran número de países de la OCDE ofrecen esta posibilidad al contribuyente, lo mantienen informado del estado de desarrollo de las discusiones, y a menudo le

consultan durante las deliberaciones sobre si aceptaría las soluciones contempladas por las autoridades competentes. Estas prácticas, que ya constituyen un procedimiento habitual en la mayor parte de los países, y que deberían adoptarse de la manera más amplia posible, están recogidas en el Manual para la aplicación efectiva del procedimiento amistoso de la OCDE.

C.4.4 Publicación de los procedimientos aplicables

4.60 Para una mejor información del contribuyente, sería útil que las autoridades competentes establecieran e hicieran públicas sus propias reglas o procedimientos internos sobre la utilización del procedimiento amistoso, de manera que los contribuyentes entendieran más fácilmente el proceso. Los países miembros de la OCDE y algunas economías no integradas en la Organización, han acordado incluir en el ciber sitio de la OCDE, en el apartado “*Dispute Resolution Country Profiles*” (Reseñas nacionales sobre la resolución de controversias), que se actualiza regularmente, una referencia a sus normas o procedimientos internos al respecto. La confección y publicación de estas reglas beneficiaría también a las administraciones tributarias, particularmente si se enfrentan a la posibilidad de que aumenten significativamente los casos en los que puede ser deseable el procedimiento amistoso con otras administraciones, ahorrándoles la necesidad de contestar a numerosas peticiones o de elaborar nuevos procedimientos para cada caso.

4.61 En la publicación de tales reglas y procedimientos podría clarificarse, por ejemplo, el proceso que debe seguir el contribuyente para someter un problema al análisis de la autoridad competente, de suerte que esta pueda iniciar la discusión con la autoridad competente del otro país. La información puesta a disposición pública podría incluir la dirección del centro al que dirigirse para contactar con las autoridades competentes; el momento en el que la autoridad competente podría aceptar a trámite el asunto; la naturaleza de la información necesaria o útil para la autoridad competente a efectos de instruir el expediente, etc. Podría ser igualmente interesante exponer la política de las autoridades competentes en lo que respecta a las cuestiones derivadas de los precios de transferencia y de los ajustes correlativos. La autoridad competente puede estudiar esta posibilidad unilateralmente, para después, y cuando proceda, dar la publicidad oportuna a sus normas y procedimientos a nivel nacional (respetando, naturalmente, la confidencialidad de los datos relativos al contribuyente).

4.62 No es necesario que las autoridades competentes consensúen las reglas o directrices que regulan el procedimiento amistoso, puesto que estas se limitan a regir las relaciones entre la autoridad competente de un país y sus contribuyentes. Convendría, sin embargo, que cada autoridad competente

comunicara regularmente sus reglas o directrices unilaterales a las autoridades competentes de los países con los que ha suscrito procedimientos amistosos.

C.4.5 Problemas relativos a la recaudación derivada de la regularización de la cuota tributaria y del devengo de intereses

4.63 El proceso de obtención de la desgravación por doble imposición, mediante un ajuste correlativo puede complicarse por los problemas de recaudación de las deficiencias en la liquidación de los impuestos, y por el cálculo de los intereses tras la regularización (por exceso o defecto). Un primer problema se deriva del hecho de que la recaudación de la cuota resultante de la liquidación puede ser previa a la conclusión del ajuste correlativo, debido a la falta de mecanismos internos que permitan suspender la recaudación. Esto puede provocar que el grupo multinacional pague dos veces el mismo impuesto hasta la resolución del caso. Este problema surge no sólo en el contexto del procedimiento amistoso, sino también en la interposición de recursos internos. Es deseable que los países que carezcan de un procedimiento que les permita suspender la recaudación durante un procedimiento amistoso lo adopten, siempre que se lo permita su normativa interna, aunque manteniendo el derecho a protegerse contra el riesgo de incumplimiento por parte del contribuyente. Véanse los párrafos 47 y 48 de los Comentarios al artículo 25.

4.64 Tanto si la recaudación de la liquidación se suspende o no, total o parcialmente, pueden surgir otras complicaciones. Debido al largo período de tiempo que requiere la tramitación de muchos casos de precios de transferencia, los intereses correspondientes a una insuficiencia en el pago del impuesto o, si se permite el ajuste correlativo, los intereses correspondientes al exceso de impuesto pagado en el otro país, pueden ser iguales o superiores a la cuantía misma del impuesto. Las administraciones tributarias deberían ser conscientes del hecho de que la incompatibilidad entre las reglas de cálculo de los intereses aplicadas en los dos países puede originar un coste adicional para el grupo multinacional o, en otros supuestos, constituir un beneficio para el grupo (por ejemplo, cuando el interés pagado en el país que efectúa el ajuste correlativo excede del interés aplicado en el país que efectúa el ajuste primario) que no habría existido si las operaciones vinculadas se hubieran desarrollado desde el principio en condiciones de plena competencia. Es preciso tener en cuenta este hecho en los procedimientos amistosos.

4.65 La cuantía de los intereses (que debe distinguirse del tipo de cálculo) puede depender también del año al que atribuye el ajuste correlativo

la jurisdicción que lo practica. La jurisdicción que efectúa el ajuste correlativo puede decidir imputarlo al año en el que se practica el ajuste primario, en cuyo caso los intereses devengados serán relativamente pocos (con independencia del tipo de interés al que se paguen), mientras que la jurisdicción que efectúa el ajuste primario puede intentar aplicar intereses sobre la deficiencia en la cuota tributaria desde el ejercicio en el que se realizaron las operaciones vinculadas (con independencia de que se aplique un tipo de interés relativamente bajo). En el párrafo 4.36 se plantea la cuestión de la determinación del año al que debe imputarse un ajuste correlativo. En consecuencia, será conveniente en determinados casos que ambas autoridades competentes acuerden que el ajuste en cuestión no genere intereses que el contribuyente deba pagar o percibir, lo que puede resultar inviable si el convenio bilateral aplicable no contiene una cláusula al efecto. Este procedimiento reduciría también las complicaciones administrativas. Sin embargo, en la medida en que los intereses sobre los pagos insuficientes o en exceso son imputables a contribuyentes diferentes de países diferentes, este método no garantiza un resultado económico correcto.

C.5 Ajustes secundarios

4.66 Los ajustes correlativos no son los únicos ajustes que pueden producirse como consecuencia de un ajuste primario de precios de transferencia. Los ajustes primarios de un precio de transferencia y sus ajustes correlativos modifican la atribución de beneficios imponibles dentro de un grupo multinacional a efectos fiscales, pero no alteran el hecho de que el excedente de beneficio correspondiente al ajuste no es compatible con el resultado que se hubiera obtenido si las operaciones vinculadas se hubieran realizado en condiciones de plena competencia. Para que la atribución efectiva de los beneficios sea conforme con el ajuste primario de los precios de transferencia, algunos países, habiendo propuesto un ajuste, asumen la existencia de una operación presunta (operación secundaria), en la cual el exceso de beneficio resultante del ajuste primario se trata como si se hubiese transferido de alguna otra forma y se grava en consecuencia. En general, la operación secundaria adoptará la forma de dividendos presuntos, de aportaciones presuntas de fondos propios o de préstamos presuntos. Por ejemplo, un país que efectúe un ajuste primario sobre la renta de una filial de una matriz extranjera podrá tratar el excedente de beneficio de la matriz extranjera como un dividendo percibido, sujeto en su caso a una retención en la fuente. Es posible que la filial haya pagado a su matriz extranjera un precio de transferencia excesivo para evitar esa retención en la fuente. En consecuencia, los ajustes secundarios intentan subsanar la diferencia entre los beneficios imponibles ajustados y los inicialmente contabilizados. La

sujeción al impuesto de una operación secundaria genera un ajuste secundario del precio de transferencia. Así, los ajustes secundarios pueden servir para prevenir la evasión fiscal. Las modalidades exactas de la operación secundaria y el ajuste secundario consiguiente estarán en función de las particularidades del caso concreto y de la legislación tributaria del país que practica el ajuste secundario.

4.67 Otro ejemplo en el que una administración tributaria asumiría la existencia de una operación secundaria puede ser aquél en el que la administración tributaria que efectúa el ajuste primario trata el exceso de beneficio como un préstamo presunto de una empresa asociada a otra empresa asociada. En este caso se entendería que surge la obligación de reembolsar el préstamo. La administración tributaria que efectúa el ajuste primario puede entonces intentar aplicar el principio de plena competencia a esta operación secundaria, a los efectos de imputar un tipo de interés de plena competencia. En términos generales, es necesario estudiar el tipo de interés que va aplicarse, la fecha a la que deben vincularse los pagos de intereses, en su caso, y si los intereses deben capitalizarse. El criterio del préstamo presunto puede incidir no solamente sobre el año al que se refiere el ajuste primario, sino también sobre los años posteriores hasta la fecha en la que la administración tributaria que defienda el ajuste secundario considere reembolsado el préstamo presunto.

4.68 El ajuste secundario puede generar doble imposición a menos que el otro país conceda un crédito, o cualquier otra forma de desgravación, por el impuesto adicional que resulte del ajuste secundario. Cuando el ajuste secundario adopte la forma de dividendo presunto, cualquier retención en la fuente que se aplicara en ese caso podría no ser susceptible de desgravación en la medida en que el derecho interno del otro país no considere una recepción presunta de los dividendos.

4.69 Los Comentarios al párrafo 2 del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE precisan que el artículo no trata de los ajustes secundarios y que, en consecuencia, ni prohíbe ni obliga a las administraciones tributarias a efectuarlos. En un sentido amplio, la finalidad de los convenios fiscales es evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Muchos países no practican ajustes secundarios, ya sea por una cuestión práctica o porque su derecho interno no les autoriza. Algunos países podrían rehusar la concesión de una desgravación con respecto a los ajustes secundarios efectuados por otros países y, de hecho, el artículo 9 no les obliga a hacerlo.

4.70 Algunos países rechazan los ajustes secundarios por las dificultades prácticas que presentan. A título de ejemplo, si se efectúa un

ajuste primario entre dos sociedades con una relación paralela dentro del organigrama del grupo, el ajuste secundario puede producir la distribución en cadena de un dividendo teórico por una de estas sociedades hasta la sociedad matriz común, seguida de aportaciones presuntas de fondos propios en sentido inverso por la cadena de propiedad hasta la otra sociedad que interviene en la operación. Se podrían construir teóricamente un gran número de operaciones, planteando interrogantes sobre si en otros países deberían desencadenarse consecuencias tributarias más allá de las que se relacionan con la operación para la que se efectuó el ajuste primario. Esto podría evitarse asimilando la operación secundaria a un préstamo, pero la mayoría de los países no utiliza los préstamos presuntos con esta finalidad, que además plantean en sí mismos problemas por lo que respecta a los intereses imputados. No resulta apropiado considerar a los accionistas minoritarios, que no son parte de las operaciones vinculadas y que, en consecuencia, no han recibido un exceso de pagos, como beneficiarios de un dividendo presunto, aun cuando un dividendo no proporcional pueda considerarse incompatible con las disposiciones aplicables del derecho de sociedades. Además, como resultado de la interacción con el sistema de crédito por impuesto extranjero, un ajuste secundario puede reducir excesivamente la carga fiscal global del grupo multinacional.

4.71 Dadas las dificultades que acaban de señalarse, es conveniente que las administraciones tributarias procedan a realizar los ajustes secundarios que consideren necesarios de forma tal que se reduzca al mínimo el riesgo de doble imposición que pudiera derivarse de ellos, salvo cuando el comportamiento del contribuyente denote una intención de disfrazar un dividendo con la finalidad de evitar la retención en la fuente. Además, los países que se encuentran en proceso de definir o revisar su política en este terreno deben tener en cuenta las dificultades mencionadas anteriormente.

4.72 Algunos países que practican los ajustes secundarios ofrecen al contribuyente que ha recibido el ajuste primario otra opción que le permite evitar el ajuste secundario, haciendo que el grupo multinacional del que forma parte repatrie el exceso de beneficios, a fin de adecuar sus cuentas al ajuste primario. La repatriación podría efectuarse bien constituyendo una cuenta por cobrar, o reclasificando otras transferencias, por ejemplo los pagos de dividendos cuando el ajuste se efectúa entre una sociedad matriz y su filial, como el pago de un precio de transferencia adicional (cuando el precio inicial fuese demasiado bajo) o como el reembolso de una parte del precio de transferencia (cuando el precio inicial fuese demasiado elevado).

4.73 Cuando la repatriación implica la reclasificación de un pago de dividendos, el importe del dividendo (hasta el importe del ajuste primario) no se incluye en la renta bruta del beneficiario (porque ya se habrá tomado en

cuenta en el ajuste primario). En consecuencia, el beneficiario pierde cualquier crédito fiscal indirecto (o el beneficio de una exención del dividendo en un régimen de exención) y el crédito por la retención en la fuente que se hubiese acordado para el dividendo.

4.74 Cuando la repatriación se traduce en la constitución de una cuenta por cobrar, las rectificaciones de los flujos efectivos de tesorería se escalonarán en el tiempo, pudiendo el derecho interno, sin embargo, limitar el plazo de liquidación de esta cuenta. Este planteamiento es idéntico a la utilización de un préstamo presunto como operación secundaria para explicar el exceso de beneficio que se encuentra en manos de una de las partes que intervienen en la operación vinculada. Los intereses devengados por la cuenta podrían generar sus propias consecuencias tributarias, lo que puede complicar el proceso según la fecha en que comiencen a devengarse de acuerdo con el derecho interno (como se analiza en el párrafo 4.67). Algunos países pueden renunciar a gravar los intereses devengados por estas cuentas como parte de un acuerdo entre autoridades competentes.

4.75 Cuando se intenta una repatriación, se plantea la cuestión de saber cómo se deben registrar tales pagos o acuerdos en la contabilidad del contribuyente que repatría los pagos a su empresa asociada, de forma que esta y la administración tributaria del país en cuestión estén informadas de que se ha procedido o previsto la repatriación. La contabilización efectiva de la repatriación en las cuentas de la empresa a la que se le solicita dependerá, en definitiva, de la forma que tal repatriación adopte. Por ejemplo, cuando la administración tributaria que efectúa el ajuste primario y el contribuyente que percibe el dividendo consideren un dividendo percibido como una repatriación, no es obligatorio que este tipo de acuerdo quede expresamente registrado en las cuentas de la empresa asociada que paga el dividendo, ya que tal acuerdo puede no afectar a la cuantía o a la calificación del dividendo que tiene en sus manos. Por otra parte, cuando se constituye una cuenta por pagar, tanto el contribuyente que registra la cuenta como la administración tributaria de ese país, deberán ser conscientes de que la cuenta se refiere a una repatriación, de manera que puedan identificarse claramente todos los reembolsos efectuados con cargo a la cuenta o los intereses procedentes de su saldo, y tratarlos de acuerdo con la legislación interna de ese país. Además, pueden plantearse problemas en lo referente a las ganancias y pérdidas por el cambio de moneda.

4.76 Como en el momento actual la mayor parte de los países miembros de la OCDE no tiene mucha experiencia en esta materia, se recomienda que los acuerdos entre contribuyentes y administraciones tributarias relativas a las repatriaciones que vayan a efectuarse se traten en el contexto del

procedimiento amistoso que se haya iniciado con referencia al ajuste primario correspondiente.

D. Inspecciones tributarias simultáneas

D.1 Definición y antecedentes

4.77 La inspección tributaria simultánea constituye una forma de asistencia mutua utilizada en una amplia variedad de cuestiones relacionadas con operaciones internacionales, que permite a dos o más países cooperar en las investigaciones tributarias. Las inspecciones tributarias simultáneas pueden ser particularmente útiles cuando la información que se encuentra en un tercer país es determinante para una inspección, ya que en general propician y facilitan los intercambios de información. Tradicionalmente las inspecciones tributarias simultáneas en materia de precios de transferencia se centran en aquellos casos en los que la interposición de paraísos fiscales enmascara la verdadera naturaleza de las operaciones. Sin embargo, en casos complejos de precios de transferencia parece que las inspecciones simultáneas podrían jugar un papel más amplio, ya que pueden mejorar la calidad de los datos de que disponen las administraciones tributarias participantes para los análisis de precios de transferencia. Se ha sugerido igualmente que las inspecciones simultáneas podrían ayudar a reducir las posibilidades de doble imposición económica y la carga de cumplimiento para el contribuyente, así como a acelerar la resolución de los problemas. Cuando una inspección simultánea determina una nueva liquidación, los dos países afectados deberían esforzarse en conseguir un resultado que permita evitar la doble imposición del conjunto del grupo multinacional.

4.78 Las inspecciones tributarias simultáneas se definen en el apartado A del Modelo de Acuerdo de la OCDE relativo a la realización de inspecciones tributarias simultáneas ("Modelo de Acuerdo de la OCDE"). Según este acuerdo, una inspección tributaria simultánea es un "acuerdo entre dos o más partes para inspeccionar simultánea e independientemente, cada una en su territorio, la situación tributaria de uno o de varios contribuyentes en los que tienen un interés común o conexo con vistas a intercambiar cualquier información relevante que puedan obtener". Esta forma de asistencia mutua no intenta reemplazar el procedimiento amistoso. Cualquier intercambio de información que se derive de una inspección simultánea continúa efectuándose a través de las autoridades competentes, con todas las salvaguardias previstas en este tipo de intercambios. La información práctica sobre inspecciones simultáneas puede encontrarse en el apartado correspondiente del Manual sobre Intercambio de Información

aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 23 de enero de 2006 (véase <http://www.oecd.org/ctp/eoi/manual>).

4.79 Aunque las disposiciones que siguen el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE pueden constituir la base jurídica necesaria para la realización de las inspecciones simultáneas, las autoridades competentes concluyen a menudo acuerdos específicos que definen los objetivos de sus programas de inspecciones simultáneas y los procedimientos prácticos relacionados con ellas y con el intercambio de información. Una vez que se han acordado las líneas generales del procedimiento y que se han seleccionado los casos concretos, los inspectores fiscales de cada Estado procederán separadamente a sus inspecciones, dentro de su propia jurisdicción y conforme a su derecho interno y prácticas administrativas.

D.2 Fundamento jurídico de las inspecciones tributarias simultáneas

4.80 Las inspecciones tributarias simultáneas entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones previstas en materia de intercambio de información en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Este artículo rige la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados contratantes en forma de intercambios de información para la aplicación de las disposiciones del Convenio, o de su derecho interno, relativas a los impuestos objeto del Convenio. El artículo 26 y los Comentarios no limitan las posibilidades de asistencia a los tres métodos de intercambio de información mencionados en los Comentarios (previa solicitud, automático y espontáneo).

4.81 Las inspecciones tributarias simultáneas pueden autorizarse fuera del contexto de los convenios de doble imposición. Por ejemplo, el artículo 12 del Convenio Nórdico de Asistencia Mutua en materia tributaria rige el intercambio de información y la asistencia en materia de recaudación en los países nórdicos y abre la posibilidad de proceder a inspecciones tributarias simultáneas. Este Convenio contiene directrices comunes para la selección de los casos y la ejecución de dichas inspecciones. El Convenio conjunto del Consejo de Europa y de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria prevé también expresamente, en su artículo 8, la posibilidad de inspecciones tributarias simultáneas.

4.82 En todos los casos, la información obtenida por la administración tributaria de un Estado debe tratarse de manera confidencial en el marco de su derecho interno, pudiendo utilizarse únicamente para determinados fines de naturaleza tributaria y divulgarse únicamente a ciertas personas y autoridades cuya intervención se define con precisión y queda amparada en

el convenio tributario o en el acuerdo de asistencia mutua. Normalmente se notifica a los contribuyentes que han sido seleccionados para una inspección tributaria simultánea, y en ciertos países tienen el derecho a ser informados cuando las administraciones tributarias estén considerando una inspección tributaria simultánea o cuando vaya a transmitirse información conforme al artículo 26. En estos casos la autoridad competente debe informar a su homóloga extranjera de que se va a proceder a la notificación al contribuyente.

D.3 Inspecciones tributarias simultáneas y precios de transferencia

4.83 Las diferencias que existen de un país a otro en cuanto a los plazos para la realización de inspecciones o liquidaciones, así como respecto de los ejercicios susceptibles de inspección, pueden obstaculizar considerablemente la selección de los casos de precios de transferencia que se someterán a inspección simultánea. Sin embargo, estos problemas pueden atenuarse si las autoridades competentes se comunican con suficiente antelación sus planes de inspección, con el fin de poder determinar en qué casos coinciden los plazos y de sincronizar los plazos futuros. Aunque a primera vista parecería positivo el intercambio de los planes de inspección desde su confección, algunos países han constatado que las oportunidades de que sus co-signatarios de convenios acepten una propuesta mejoran considerablemente cuando se pueden presentar los hechos que justifiquen la inspección simultánea de forma más completa.

4.84 Una vez seleccionado un caso para inspección simultánea, es habitual que los inspectores fiscales se reúnan para planificar, coordinar y seguir de cerca los resultados de la inspección simultánea. Especialmente en casos complejos, las reuniones entre inspectores pueden celebrarse con la presencia del contribuyente a fin de clarificar los elementos de hecho. En los países donde el contribuyente tiene el derecho de ser consultado antes de suministrar información a otra administración tributaria, este proceso deberá seguirse igualmente en el contexto de las inspecciones simultáneas. En este caso, antes de empezar la inspección simultánea, la administración tributaria debe informar a sus socios de convenio sobre la existencia de este requisito.

4.85 Las inspecciones tributarias simultáneas pueden constituir un medio útil para determinar correctamente la deuda tributaria de las empresas asociadas cuando, por ejemplo, hay reparto o imputación de costes y cuando se distribuyen beneficios entre contribuyentes de diferentes jurisdicciones tributarias o, más comúnmente, cuando se plantean problemas de determinación de precios de transferencia. Las inspecciones tributarias simultáneas pueden facilitar los intercambios de información relativos a las

prácticas empresariales multinacionales, a las operaciones complejas, a los acuerdos sobre reparto de costes y a los métodos de atribución de beneficios en áreas particulares, tales como el comercio mundial de productos financieros o las operaciones innovadoras. Como resultado de las inspecciones simultáneas, las administraciones tributarias pueden adquirir una mejor comprensión de las actividades de conjunto de una empresa multinacional y ampliar sus posibilidades de comparación y comprobación de las operaciones internacionales. Las inspecciones tributarias simultáneas pueden contribuir igualmente al intercambio de información de un sector de actividad, con la finalidad de conocer mejor el comportamiento de los contribuyentes, las prácticas y tendencias del sector, y obtener otras informaciones que pueden resultar útiles al margen de los asuntos específicos objeto de la inspección.

4.86 Uno de los objetivos de las inspecciones tributarias simultáneas es promover el cumplimiento de las reglamentaciones sobre precios de transferencia. En efecto, puede ser difícil para una administración tributaria obtener las informaciones necesarias y determinar los hechos y circunstancias relativos, por ejemplo, a las condiciones bajo las cuales las empresas asociadas de dos o más países fijan sus precios de transferencia, sobre todo si los contribuyentes de su jurisdicción no cooperan o no suministran a su debido tiempo la información necesaria. Las inspecciones tributarias simultáneas permiten a las administraciones tributarias establecer estos elementos de hecho más rápida y eficazmente, y con menores costes.

4.87 Este procedimiento puede permitir igualmente identificar desde las primeras fases las posibles controversias en materia de precios de transferencia, minimizando así los litigios con los contribuyentes. Sobre la base de la información obtenida en el curso de una inspección tributaria simultánea, los inspectores fiscales tienen la oportunidad de discutir sus diferencias de opinión respecto de las condiciones de determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas y conciliar sus opiniones. Cuando se inicia una inspección tributaria simultánea, los funcionarios participantes deberían, en la medida de lo posible, llegar a declaraciones convergentes en cuanto a la determinación y evaluación de los hechos y circunstancias referentes a las empresas asociadas, señalando, en su caso, los posibles desacuerdos en la evaluación de los hechos, así como las divergencias en el tratamiento jurídico de las condiciones de determinación de precios de transferencia entre las empresas asociadas. Estas declaraciones pueden servir de base a procedimientos amistosos ulteriores, y quizás evitar los problemas que se plantean cuando un país inspeccione la actividad económica de un contribuyente mucho tiempo después de que el co-signatario del convenio haya liquidado definitivamente el impuesto de la

empresa asociada afectada. De esta manera se podría, por ejemplo, minimizar las dificultades del procedimiento amistoso generadas por la falta de información relevante.

4.88 En ciertos casos, el procedimiento de la inspección tributaria simultánea puede permitir a las administraciones tributarias participantes alcanzar un acuerdo sobre las condiciones de determinación de los precios de transferencia de operaciones vinculadas entre empresas asociadas. Cuando se alcanza el acuerdo, los ajustes correlativos pueden efectuarse en las primeras fases del proceso, gracias a lo cual se evitan al máximo la prescripción y la doble imposición económica. Además, si el acuerdo sobre la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas goza del consentimiento del contribuyente, pueden evitarse largos y costosos litigios.

4.89 Aun si las administraciones tributarias no llegan a un acuerdo durante una inspección tributaria simultánea sobre la determinación del precio de transferencia entre empresas asociadas, el Modelo de Acuerdo de la OCDE prevé la posibilidad de que cualquiera de las dos empresas asociadas presente una solicitud de inicio de un procedimiento amistoso, con la finalidad de evitar la doble imposición económica, en un momento anterior al que hubiera correspondido de no realizarse esa inspección tributaria simultánea. Esto permite reducir sensiblemente el plazo entre los ajustes de la deuda tributaria de un contribuyente efectuados por una administración tributaria y la ejecución del procedimiento amistoso. Además, el Modelo de Acuerdo de la OCDE prevé la posibilidad de que las inspecciones tributarias simultáneas faciliten el procedimiento amistoso, dado que las administraciones tributarias podrán reunir pruebas fácticas más completas sobre aquellos ajustes que incitarán al contribuyente a solicitar el inicio del procedimiento amistoso. Tomando como punto de referencia la determinación y evaluación de los hechos, así como el tratamiento tributario propuesto en relación con los precios de transferencia en cuestión, expuestos en las declaraciones antes mencionadas de las administraciones tributarias, la ejecución del procedimiento amistoso se verá sensiblemente mejorada, permitiendo a las autoridades competentes alcanzar un acuerdo de una forma más sencilla.

4.90 Las empresas asociadas pueden beneficiarse asimismo del ahorro de tiempo y de recursos que suponen las inspecciones tributarias simultáneas, gracias a la coordinación de las investigaciones de las administraciones tributarias a las que concierna y a la eliminación de duplicaciones. Además, la intervención simultánea de dos o más administraciones tributarias en la inspección de los precios de transferencia entre empresas asociadas, ofrece a la empresa multinacional la posibilidad de jugar un papel más activo en la resolución de sus problemas en materia de precios de transferencia.

Presentando los hechos y argumentos pertinentes a cada una de las Administraciones participantes durante la inspección tributaria simultánea, las empresas asociadas podrán evitar malentendidos y facilitar el trabajo paralelo de las administraciones tributarias involucradas en la evaluación y determinación de sus precios de transferencia. Las empresas asociadas pueden tener pues certidumbre, en lo que respecta a sus precios de transferencia, en una fase temprana. Véase el párrafo 4.77.

D.4 *Recomendación relativa a la utilización de inspecciones tributarias simultáneas*

4.91 Como resultado de la creciente utilización de las inspecciones tributarias simultáneas entre países miembros de la OCDE, el Comité de Asuntos Fiscales ha juzgado útil redactar un Modelo de Acuerdo para la realización de inspecciones tributarias simultáneas, destinado a aquellos países que pueden y desean vincularse a este tipo de cooperación. El 23 de julio de 1992, el Consejo de la OCDE recomendó a los países miembros utilizar este Modelo de Acuerdo, que establece las directrices sobre los aspectos legales y prácticos de esta forma de cooperación.

4.92 Con la creciente internacionalización del comercio y de las actividades económicas, y debido a la complejidad de las operaciones de las empresas multinacionales, los problemas relacionados con los precios de transferencia juegan un papel cada vez más importante. Las inspecciones tributarias simultáneas pueden atenuar las dificultades que experimentan tanto los contribuyentes como las administraciones en relación con la determinación de los precios de transferencia de las empresas multinacionales. Se recomienda, en consecuencia, una mayor utilización de las inspecciones tributarias simultáneas en materia de precios de transferencia, facilitar el intercambio de información y la aplicación de los procedimientos amistosos. En una inspección tributaria simultánea, si se efectúa un ajuste, los dos países implicados deben esforzarse en alcanzar un acuerdo que evite la doble imposición del grupo multinacional.

E. Régimen de protección (*safe harbours*)

E.1 Introducción

4.93 La aplicación del principio de plena competencia exige la búsqueda de numerosos elementos de hecho y conlleva, a menudo, un amplio margen de subjetividad. Puede generar incertidumbre e imponer a los contribuyentes y a las administraciones tributarias una pesada carga

administrativa que puede agravarse por la complejidad de las reglamentaciones y de las formalidades que los contribuyentes deben respetar. Estos hechos han llevado a los países miembros de la OCDE a considerar la oportunidad de establecer regímenes de protección en el área de los precios de transferencia.

E.2 Definición y concepto de los regímenes de protección

4.94 Las dificultades que suscita la aplicación del principio de plena competencia pueden atenuarse determinando las circunstancias en las que los contribuyentes pueden recurrir a un conjunto de reglas simples cuyo seguimiento determine la aceptación automática de los precios de transferencia por la administración tributaria nacional. Tales disposiciones se conocen como "régimen de protección" ("*safe harbour*" o "*safe haven*"). En el ámbito tributario, un régimen de protección es una reglamentación que se aplica a una categoría determinada de contribuyentes, exonerándolos de ciertas obligaciones impuestas por la norma tributaria, haciéndolos beneficiarios de un régimen excepcional, normalmente más simple. En el caso concreto de los precios de transferencia, el conjunto de reglas administrativas aplicables a un régimen de protección puede ir desde la exoneración total para los contribuyentes seleccionados de la obligación de someterse a la legislación nacional en materia de precios de transferencia y su reglamentación, hasta la obligación de atenerse a diversas reglas de procedimiento para poder beneficiarse del régimen de protección. Estas reglas podrían, por ejemplo, imponer a los contribuyentes la determinación de sus precios de transferencia o de sus resultados siguiendo un proceso concreto; por ejemplo, aplicando un método simplificado de determinación de precios de transferencia establecido por la administración tributaria, o cumpliendo determinadas disposiciones relativas a la comunicación de información o a la conservación de documentación sobre las operaciones con empresas asociadas. Este procedimiento requiere una mayor participación de la administración tributaria, ya que puede ser necesario controlar el cumplimiento del contribuyente con las reglas de procedimiento.

4.95 Un régimen de protección puede tener dos variantes desde el punto de vista de las condiciones del contribuyente en las operaciones vinculadas: o se excluyen ciertas operaciones del ámbito de aplicación de las reglas en materia de precios de transferencia (en particular, a través de la fijación de umbrales), o se simplifican las reglas que se aplican (por ejemplo, fijando rangos dentro de los cuales deberán inscribirse los precios o los beneficios). Estas dos formas de delimitación de los regímenes de protección pueden tener que revisarse y publicarse periódicamente por parte de las autoridades

fiscales. Los regímenes de protección no incluyen los procedimientos por los cuales una administración tributaria y un contribuyente acuerdan por anticipado el precio de transferencia en operaciones vinculadas (acuerdos previos de valoración), que se analizan en la sección F del presente capítulo. Tampoco se trata en esta sección de las disposiciones tributarias destinadas a prevenir el endeudamiento "excesivo" de una filial extranjera (reglas relativas a la "subcapitalización"), que serán objeto de trabajos posteriores.

4.96 Los regímenes de protección plantean problemas importantes desde el punto de vista del riesgo de arbitrariedad que generaría la determinación de los precios de transferencia por los contribuyentes que pueden beneficiarse de estos regímenes, de las posibilidades de planificación fiscal, y del riesgo de doble imposición resultante de una eventual incompatibilidad de los regímenes de protección con el principio de plena competencia.

E.3 Factores a favor de la utilización de los regímenes de protección

4.97 Los objetivos principales de los regímenes de protección son los siguientes: simplificar la determinación de las condiciones de plena competencia de las operaciones vinculadas de los contribuyentes que pueden beneficiarse de ellos; otorgar a una categoría de contribuyentes la seguridad de que el precio pactado o percibido en operaciones vinculadas será aceptado por la administración tributaria sin comprobación ulterior; y, por último, exonerar a la administración tributaria de la tarea de llevar a cabo ulteriores inspecciones o comprobaciones de los precios de transferencia de esos contribuyentes.

E.3.1 Simplificación del cumplimiento con las obligaciones tributarias

4.98 La aplicación del principio de plena competencia puede exigir la captación y el análisis de datos difíciles de obtener o evaluar. En ciertos casos, tal complejidad puede resultar desproporcionada con relación al tamaño de la sociedad o al volumen de sus operaciones vinculadas.

4.99 Los regímenes de protección podrían facilitar sensiblemente el cumplimiento de las obligaciones eximiendo a los contribuyentes de ciertas disposiciones. Concebidos como un mecanismo de facilitación, los regímenes de protección permiten una mayor flexibilidad sobre todo cuando no existen precios de plena competencia equivalentes o comparables. Dentro de un régimen de protección los contribuyentes conocerían por anticipado el rango de precios o de beneficios en el que deben enmarcarse los de la empresa para beneficiarse de este régimen. El cumplimiento de tales

condiciones requeriría meramente la aplicación de un método simplificado, preferiblemente una medida de rentabilidad, que evitara al contribuyente la búsqueda de elementos comparables, ahorrando de esta manera el tiempo y los recursos que de otra forma hubiera dedicado a la determinación de los precios de transferencia.

E.3.2 Certidumbre

4.100 Otra ventaja de los regímenes de protección reside en la certidumbre de que la administración tributaria aceptará los precios de transferencia del contribuyente. Los contribuyentes a los que se permite el beneficio del régimen de protección tendrían la seguridad de no estar sujetos a una inspección o a una nueva reevaluación de sus precios de transferencia. La administración tributaria aceptaría automáticamente, sin más comprobaciones, todo precio o resultado que sobrepasase un umbral mínimo o que cayese dentro de un rango preestablecido. A estos efectos, los contribuyentes podrían obtener los parámetros pertinentes que permitiesen determinar un precio de transferencia o un resultado aceptable para la administración tributaria. Podría tratarse, por ejemplo, de una serie de márgenes comerciales o de indicadores de beneficios correspondientes a un sector específico.

E.3.3 Simplificación administrativa

4.101 Los regímenes de protección simplifican la tarea de la administración tributaria. Una vez determinado el grupo de contribuyentes beneficiarios del régimen de protección, estos no requerirían más que de una inspección mínima de sus precios de transferencia o de los resultados de sus operaciones vinculadas. La administración tributaria podría entonces asignar mayores recursos a la inspección de otras operaciones y de otros contribuyentes.

E.4 Problemas que plantea la utilización de regímenes de protección

4.102 La existencia de un régimen de protección para una categoría determinada de contribuyentes puede presentar ciertas consecuencias adversas, que las administraciones tributarias deben valorar cuidadosamente con relación a los beneficios que esperan. Estas preocupaciones resultan del hecho de que:

1. la aplicación del régimen de protección en un país determinado no afectará únicamente al cálculo del impuesto en esa jurisdicción, sino que

también puede repercutir sobre el cálculo del impuesto para las empresas asociadas en otras jurisdicciones;

2. es difícil establecer criterios satisfactorios para definir los regímenes de protección, y en consecuencia podrían arrojar precios o resultados no conformes con el principio de plena competencia.

Esta cuestión puede examinarse desde diversas perspectivas.

4.103 En el contexto de un régimen de protección, los contribuyentes pueden estar exonerados de la obligación de aplicar un método concreto de determinación de precios, o incluso de utilizar un método de determinación de precios con fines tributarios. Cuando el régimen de protección obliga a la utilización de un método simplificado para la determinación de precios de transferencia, es poco probable que, según las reglas generales en materia de precios de transferencia, este único método resulte el más apropiado en todos los casos y circunstancias del contribuyente. Por ejemplo, un régimen de protección puede establecer un porcentaje de beneficio mínimo en el ámbito de un método basado en el beneficio, cuando el contribuyente hubiera podido utilizar el método del precio libre comparable u otros métodos basados en las operaciones.

4.104 En este caso, podría considerarse que existe una incompatibilidad con el principio de plena competencia, que exige la utilización de un método de determinación de precios coherente con las condiciones que hubieran convenido en el mercado libre partes independientes que llevaran a cabo operaciones comparables en condiciones igualmente comparables. Algunos sectores en los que los bienes, las materias primas o los servicios están normalizados y los precios de mercado son bien conocidos, por ejemplo, el sector del petróleo o de la minería o el sector de los servicios financieros, la aplicación de un régimen de protección tendría un alto grado de precisión y, por tanto, una menor desviación del principio de plena competencia. Pero incluso en estos sectores de actividad se produce una amplia variedad de resultados que, muy probablemente, un régimen de protección no puede adaptar para satisfacción de las administraciones tributarias. Además, la existencia de precios de mercado accesibles al público facilitaría presumiblemente la utilización de métodos basados en las operaciones, en cuyo caso no habrá necesidad de un régimen de protección.

4.105 Aun asumiendo que el método de determinación de precios establecido en un régimen de protección se adapte a la situación concreta de determinados casos, la aplicación de un régimen semejante sacrifica la precisión en la declaración del precio de transferencia. Esto es inherente a la propia naturaleza de los regímenes de protección, ya que en ellos, los precios de transferencia se establecen tomando como referencia un objetivo

estandarizado, y no las características individuales de la operación como ocurre en la aplicación del principio de plena competencia. De lo anterior se sigue que los precios o resultados a los que se llega en cumplimiento del objetivo estandarizado pueden no ser precios o resultados de plena competencia.

4.106 Los regímenes de protección corren el riesgo de ser arbitrarios por el hecho de que raramente se ajustan de manera exacta a las múltiples situaciones de las empresas, aun cuando estas pertenezcan al mismo sector o rama de actividad. Esta arbitrariedad no se minimizaría sino con gran dificultad, dedicando a numerosos agentes especializados a la recopilación, comparación y actualización permanente de todo un conjunto de informaciones relativas a la evolución de los precios y a sus métodos de determinación. Obtener la información relevante para el establecimiento y seguimiento de los parámetros del régimen de protección puede, en consecuencia, imponer pesadas cargas administrativas a las administraciones tributarias, porque tal información puede no estar fácilmente disponible, o ser accesible únicamente a través de investigaciones en profundidad sobre los precios de transferencia. Por tanto, la amplitud de las investigaciones necesarias para establecer los parámetros de un régimen de protección de forma lo suficientemente precisa como para cumplir el principio de plena competencia, lesionaría una de las finalidades del régimen de protección, a saber, la simplicidad administrativa.

E.4.1 Riesgo de doble imposición y dificultades en el procedimiento amistoso

4.107 Desde un punto de vista práctico, el problema más importante que plantean los regímenes de protección reside en su impacto internacional. Los regímenes de protección pueden afectar a la estrategia de determinación de precios de las sociedades. La existencia de "objetivos" fijados por un régimen de protección puede inducir a los contribuyentes a modificar los precios que habrían cargado en otras circunstancias a las empresas asociadas, con la finalidad de incrementar sus beneficios para cumplir los objetivos y evitar de esta manera la comprobación de sus precios de transferencia en el curso de una inspección. El riesgo de una declaración en exceso de la renta imponible en el país que concede el régimen de protección aumenta cuando este país sanciona fuertemente la declaración del impuesto por debajo de la obligación real o el incumplimiento de las obligaciones de documentación, lo cual constituye un estímulo adicional para que el contribuyente se asegure de que sus precios de transferencia vayan a aceptarse sin ulteriores comprobaciones.

4.108 Los contribuyentes pueden valorar la certidumbre que les procura el régimen de protección hasta el punto de elevar los precios facturados a las empresas asociadas, con la finalidad de disfrutar del beneficio de este régimen, aun cuando estos precios de transferencia sean superiores a los precios de plena competencia que hubieran utilizado habida cuenta de sus circunstancias específicas. En este caso, el régimen de protección puede resultar ventajoso para la administración tributaria que lo concede, porque los contribuyentes residentes declararían más rentas imponibles. Por otro lado, el régimen de protección penalizaría a la vez a las empresas asociadas extranjeras y a las administraciones tributarias de las jurisdicciones a las que pertenecen, ya que estas empresas declararían menos beneficios y rentas imponibles en sus respectivas jurisdicciones. Se crearía, en consecuencia, un problema en relación con la distribución de la recaudación tributaria entre las dos jurisdicciones.

4.109 En efecto, en tales casos, la administración tributaria del país afectado negativamente por este régimen puede no estar dispuesta a aceptar los precios facturados a su contribuyente con ocasión de operaciones con empresas asociadas del país que acuerda el régimen de protección. Estos precios pueden diferir de los obtenidos en estas jurisdicciones en aplicación de los métodos de determinación de precios de transferencia conformes con el principio de plena competencia, por lo que cabe esperar que las administraciones tributarias extranjeras rechacen los precios resultantes de la aplicación del régimen de protección, con el riesgo para el contribuyente de sufrir una doble imposición.

4.110 A primera vista, cabe argumentar que la posibilidad de doble imposición anula los objetivos de certidumbre y simplicidad perseguidos originalmente por el contribuyente al elegir el régimen de protección. Sin embargo, los contribuyentes pueden considerar que una doble imposición limitada constituye un precio aceptable por no tener que cumplir las complejas reglas de determinación de precios de transferencia.

4.111 De ello se sigue que la doble imposición puede no ser, en sí misma, un factor de descalificación de los regímenes de protección. Se puede argumentar que el contribuyente debe decidir por sí mismo, al optar o no por el régimen de protección, si el riesgo de doble imposición es aceptable. Sin embargo, para asegurar que los contribuyentes tomen tal decisión en función de esta compensación perjuicio-beneficio, sería necesario que el país que ofrece el régimen de protección hiciese saber claramente si intentaría o no atenuar la doble imposición que pueda resultar del régimen de protección. Dado que el régimen de protección otorga al contribuyente el privilegio de eludir toda comprobación o inspección ulterior de los precios de transferencia obtenidos con su aplicación, y que los precios o resultados

obtenidos, por la naturaleza de los regímenes de protección, no son por definición más que una aproximación a los que se obtendrían aplicando el principio de plena competencia, el contribuyente debería estar igualmente dispuesto, cuando opte por un régimen de protección, a soportar la doble imposición internacional que puede resultar de la no aceptación, por una administración tributaria extranjera, de los precios de transferencia declarados en el marco de dicho régimen. Esto implicaría lógicamente que los contribuyentes que opten por un régimen de protección deberían, en general, perder el derecho de llevar ante las autoridades competentes los casos de doble imposición cuando la utilización del régimen de protección generara una doble imposición internacional. La atenuación de la doble imposición atribuible a la elección de un régimen de protección por un contribuyente sólo debería concederse en el país extranjero si el contribuyente puede demostrar que los resultados obtenidos en aplicación del régimen de protección son conformes con el principio de plena competencia.

4.112 Sin embargo, los ajustes de los precios de transferencia realizados por administraciones tributarias extranjeras serán más complejos cuando la multinacional haya optado por un régimen de protección en otro país, porque el contribuyente probablemente objetará el ajuste para evitar la doble imposición. El hecho de que los procedimientos amistosos no suelen permitir un ajuste a la baja de los precios o resultados obtenidos en aplicación de un régimen de protección, puede generar un efecto negativo para la administración tributaria de los países extranjeros.

4.113 La adopción de regímenes de protección en un país puede obligar a las administraciones tributarias de otros países a examinar la política de precios de transferencia de todas las empresas asociadas con las empresas que han optado por el régimen de protección, a fin de identificar los posibles casos de inconsistencia con el principio de plena competencia. De no hacerlo así, puede producirse una transferencia de recaudación desde estos países en beneficio del país que otorga el régimen de protección. En consecuencia, la simplificación administrativa obtenida por la administración tributaria del país que acuerda el régimen de protección se obtendría a expensas de otros países, quienes, para proteger su propia base de imposición, deberían determinar sistemáticamente si los precios o resultados autorizados dentro del régimen de protección son compatibles con los que se conseguirían en aplicación de sus propias reglas de precios de transferencia. El trabajo administrativo que se ha evitado en el país que concede el régimen de protección se desplaza de esta manera hacia las jurisdicciones extranjeras.

4.114 Los riesgos de doble imposición no existen sólo cuando un único país adopta un régimen de protección. La adopción de un régimen de protección por diversos países no evitará la doble imposición si cada

jurisdicción tributaria adopta procedimientos y métodos contradictorios. Los parámetros tenidos en cuenta en los regímenes de protección de dos países para ramas específicas de actividad serán sin duda diferentes, ya que ambos países querrán preservar sus ingresos tributarios. En teoría, la coordinación internacional podría conseguir el grado de armonización de los sistemas nacionales necesario para evitar la doble imposición. Pero, en la práctica, es bastante improbable que dos jurisdicciones puedan armonizar regímenes de protección contradictorios de manera que se elimine la doble imposición.

E.4.2 Posibilidad de favorecer la planificación fiscal

4.115 Asimismo, los regímenes de protección abrirían igualmente a los contribuyentes posibilidades de planificación fiscal. Las empresas pueden tener un incentivo para modificar sus precios de transferencia a fin de transferir rentas imponibles a otras jurisdicciones. Esto puede favorecer la evasión fiscal, en la medida en que los contribuyentes utilicen mecanismos artificiales para sacar partido de los regímenes de protección.

4.116 Si un régimen de protección estuviera basado en la media de un sector, podrían existir oportunidades de planificación fiscal para los contribuyentes con una rentabilidad superior a la media. Por ejemplo, una empresa con una estructura eficiente de costes que venda a precios de plena competencia puede estar obteniendo un margen del 15 por ciento sobre las ventas a empresas asociadas. Esta empresa tendría interés en optar por un régimen de protección que prevea un margen del 10 por ciento. En aplicación del régimen de protección, la empresa estaría sometida a imposición sobre un beneficio infravalorado, a pesar del hecho de que los precios de transferencia subyacentes de las operaciones vinculadas sean sensiblemente inferiores a los precios de plena competencia. En consecuencia habría una salida del país de renta imponible. A gran escala, esto podría traducirse en una considerable pérdida de recaudación para el país que ofrece el régimen de protección. Por la concepción misma del mecanismo, la administración tributaria no tendría ningún recurso para contrarrestar tales transferencias de beneficios.

4.117 Los regímenes de protección pueden producir una subimposición de las rentas a escala internacional en la medida en que generen precios o beneficios que no se aproximen a los de plena competencia y que permitan transferir rentas sujetas a imposición hacia países de baja fiscalidad o paraísos fiscales.

4.118 Corresponde a cada país decidir si está dispuesto a sufrir una cierta erosión de su base imponible por poner en práctica un régimen de protección.

Los resultados que deben valorarse para tomar tal decisión de política fiscal son, por un lado, el alcance y el atractivo del régimen de protección para los contribuyentes y, por otro, la erosión de la recaudación tributaria. Cuanto más atractivo resulte un régimen de protección para los contribuyentes, mayor será el número de los que opten por él, reduciendo de esta manera la carga administrativa de la administración tributaria. Pero, por otra parte, cuanto más atractivo sea el régimen de protección, más se agrava el riesgo de pérdida de recaudación debido a una declaración de rentas por debajo de la cifra real. Sin embargo, la magnitud de los costes y beneficios correspondientes a cada elemento de la disyuntiva es irrelevante si la administración tributaria no está dispuesta, como cuestión de principio, a renunciar a sus prerrogativas en materia de determinación de las obligaciones tributarias del contribuyente.

E.4.3 Cuestiones de equidad y de uniformidad

4.119 Finalmente, los regímenes de protección causan problemas que conciernen a la equidad y la uniformidad. Al establecer un régimen de protección, se crean dos conjuntos distintos de reglas en la determinación de los precios de transferencia: uno que requiere la conformidad de los precios con el principio de plena competencia y otro que requiere la conformidad con condiciones diferentes y más sencillas. Puesto que sería imprescindible determinar los criterios que permitan diferenciar a los contribuyentes con derecho al régimen de protección de los demás contribuyentes, puede suceder que, en ciertas circunstancias, dos contribuyentes similares y posiblemente competidores se sitúen en las márgenes opuestas del umbral del régimen de protección y estén, en consecuencia, sometidos a un tratamiento tributario diferente: uno, regido por las reglas del régimen de protección y, por tanto, exento del cumplimiento de las obligaciones generales; y el otro, obligado a respetar en todos los casos el principio de plena competencia (ya porque la empresa opere de hecho en condiciones de plena competencia o porque esté sujeta a una legislación sobre precios de transferencia basada sobre el principio de plena competencia). El tratamiento tributario preferencial bajo un régimen de protección otorgado a una categoría específica de contribuyentes puede implicar discriminación y distorsión de la competencia.

E.5 Recomendaciones para la utilización del régimen de protección

4.120 El análisis anterior sugiere que, aun cuando los regímenes de protección pueden alcanzar un cierto número de objetivos relativos al cumplimiento y a la gestión de las reglas para la determinación de los precios de transferencia, también

presentan problemas cardinales. Podrían convertirse en fuente potencial de efectos negativos sobre la toma de decisiones en materia de precios por parte de las empresas que efectúen operaciones vinculadas. Pueden tener también repercusiones negativas sobre la recaudación tributaria del país que aplica el régimen de protección, así como de los países en los que las empresas asociadas realizan operaciones vinculadas con contribuyentes que han optado por un régimen de protección. Pero, sobre todo, los regímenes de protección no suelen ser compatibles con la aplicación de precios de transferencia conformes con el principio de plena competencia. Es necesario sopesar estos inconvenientes con los beneficios que se espera obtener de un régimen de protección, a saber: certidumbre y simplicidad de cumplimiento para el contribuyente y disminución de la carga de trabajo para la administración tributaria.

4.121 En la aplicación general de las leyes tributarias no puede garantizarse certidumbre al contribuyente, puesto que la administración tributaria debe conservar la capacidad de verificar todos los elementos que intervienen en el cálculo del impuesto del obligado tributario, comprendidos los precios de transferencia. Fundamentalmente, la aplicación de un régimen de protección significa que la administración tributaria renuncia en parte a sus prerrogativas en beneficio de la aplicación de reglas automáticas. Habrá administraciones tributarias que no estén dispuestas a llegar tan lejos y que consideren esencial conservar la posibilidad de verificar la exactitud de la auto-liquidación practicada por el contribuyente y de la determinación de los elementos que conforman su deuda tributaria. Además, la sencillez del cumplimiento puede aparecer frecuentemente subordinada a otros objetivos de política fiscal tales como la racionalidad y adecuación de la documentación y de la información, y la prevención de la elusión fiscal.

4.122 Por otra parte, las administraciones tributarias disponen de una gran flexibilidad para la gestión de la legislación tributaria. Pueden optar por concentrar más recursos en los casos que afecten a grandes contribuyentes, o que estén relacionados con un número importante de operaciones vinculadas, y mostrarse más tolerantes respecto de los pequeños contribuyentes. Si bien unas prácticas administrativas más flexibles en relación con los pequeños contribuyentes no constituyen un sustituto de un régimen de protección formal, pueden conseguir, hasta cierto punto, los mismos objetivos perseguidos por estos. En términos generales y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, no se consideran aconsejables los regímenes de excepción a favor de ciertas categorías de contribuyentes al determinar los precios de transferencia, por lo que no se recomienda la utilización de regímenes de protección.

F. Acuerdos previos sobre valoración de precios de transferencia¹

F.1 *Definición y concepto de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia*

4.123 Un acuerdo previo de valoración de precios de transferencia (APV) es un acuerdo que determina, con carácter previo a la ejecución de la operación vinculada, una serie de criterios oportunos (relativos, por ejemplo, al método, los comparables, los ajustes pertinentes y las hipótesis críticas relacionadas con eventos futuros) para la determinación de los precios de transferencia aplicados a estas operaciones, a lo largo de un cierto período. Los APV se inician formalmente a instancias del contribuyente e implican la negociación entre el contribuyente, una o más empresas asociadas y una o más administraciones tributarias. Los APV tienen por objeto completar los mecanismos tradicionales administrativos, judiciales y basados en los convenios para resolver los problemas derivados de los precios de transferencia. Pueden ser de la máxima utilidad cuando los mecanismos tradicionales fallan o son difíciles de aplicar. La adopción de las directrices detalladas para el desarrollo de los acuerdos previos de valoración en el marco de los procedimientos amistosos (APV PA) data de octubre de 1999 y se reproducen en un anexo a este capítulo.

4.124 Una de las cuestiones claves en el concepto de APV es su grado de especificidad en la determinación de los precios de transferencia de un contribuyente para un cierto número de años; por ejemplo, si únicamente es necesario determinar la metodología de precios de transferencia o si es preciso llegar a resultados más concretos. En general, es necesario ser muy prudente si el APV va más allá de la mera determinación de la metodología, de sus modalidades de aplicación y de las hipótesis críticas, dado que las conclusiones más específicas se fundan en predicciones sobre hechos futuros.

4.125 La fiabilidad de una predicción utilizada en un APV depende tanto de la naturaleza de esta como de las hipótesis críticas que en ella se manejen. Por ejemplo, no sería razonable considerar que, en condiciones de plena competencia, el tipo de interés para préstamos a corto plazo de una empresa determinada en el contexto de un grupo va a mantenerse estable en el 6 por ciento durante los tres años siguientes. Una predicción más plausible

¹

En el Anexo al Capítulo IV pueden consultarse indicaciones adicionales para la conclusión de Acuerdos Previos de Valoración de precios de transferencia en el marco de procedimientos amistosos.

sugeriría que ese tipo de interés fuera igual al LIBOR incrementado en un porcentaje fijo. Esta predicción sería incluso más fiable si se añadiese una hipótesis crítica relativa a la calificación crediticia (por ejemplo, que el porcentaje añadido al LIBOR se modificará si cambia la calificación crediticia).

4.126 Otro ejemplo: no sería apropiado especificar una fórmula de distribución del resultado entre empresas asociadas si se espera que la asignación de funciones entre estas sea inestable. Por el contrario, sí sería posible utilizar dicha fórmula de distribución cuando determinadas hipótesis críticas permitan articular adecuadamente el papel de cada empresa. En ciertos casos resultaría factible incluso formular una predicción razonable sobre el porcentaje real de participación en los resultados, siempre que sea posible fundamentarla en hipótesis suficientes.

4.127 Para decidir el grado de especificidad de un APV en un caso particular, las administraciones tributarias deben ser conscientes de que las predicciones sobre beneficios futuros absolutos son las menos plausibles. Es posible utilizar los porcentajes de beneficios de empresas independientes como comparables, pero incluso estos son frecuentemente volátiles y difíciles de prever. El uso de hipótesis críticas pertinentes y de rangos aumentará la fiabilidad de las predicciones. Los datos históricos del sector también pueden constituir una referencia útil.

4.128 En resumen, la fiabilidad de una predicción depende de los hechos y circunstancias de cada caso particular. Los contribuyentes y las administraciones tributarias deben prestar una gran atención a la fiabilidad de las predicciones al plantearse el ámbito de un APV, y excluir las no fiables. En general, podrá formularse una predicción más fiable sobre la adecuación de un método y de su aplicación, así como sobre las hipótesis críticas, que sobre los resultados futuros (nivel de precios o de beneficios).

4.129 En algunos países existen acuerdos unilaterales en los que la administración tributaria y el contribuyente de su jurisdicción establecen un convenio sin la intervención de otras administraciones tributarias interesadas. Sin embargo, un APV unilateral puede afectar a las obligaciones tributarias de empresas asociadas situadas en otra jurisdicción tributaria. Cuando se permiten los APV unilaterales debe informarse de ello a las autoridades competentes de los otros países afectados en las primeras etapas del procedimiento, a fin de establecer si pueden y quieren considerar un acuerdo bilateral en el ámbito del procedimiento amistoso. En cualquier caso, los países no deben incluir en ninguno de los APV unilaterales que puedan concluir con un contribuyente la condición de que este renuncie a la posibilidad de iniciar un procedimiento amistoso en caso de que surjan

controversias referidas a los precios de transferencia. En caso de que otro país planteara un ajuste de precios de transferencia respecto de una operación o cuestión comprendida en el APV unilateral, se insta al primer país a que considere la oportunidad de realizar un ajuste correlativo y a que no considere el APV unilateral como un acuerdo irreversible.

4.130 Debido a los problemas de doble imposición, la mayor parte de los países prefiere los APV bilaterales o multilaterales (es decir, un acuerdo entre dos o más países) y, en efecto, ciertos países no conceden APV unilaterales (es decir, el APV entre el contribuyente y una sola administración tributaria) a los contribuyentes de su jurisdicción. El procedimiento bilateral (o multilateral) ofrece muchas más posibilidades de reducir el riesgo de doble imposición y de resultar equitativo para el conjunto de administraciones tributarias y de contribuyentes afectados a la vez que genera más certidumbre a los contribuyentes. Ocurre también que, en ciertos países, la legislación interna no permite a las administraciones tributarias concluir acuerdos vinculantes directamente con el contribuyente, de manera que los APV sólo pueden firmarse, en el marco del procedimiento amistoso, con la autoridad competente de un Estado con el que se ha suscrito un convenio. A los efectos de las discusiones que siguen, los acuerdos unilaterales no se considerarán incluidos en los APV, salvo referencia expresa a un APV unilateral.

4.131 Las administraciones tributarias pueden considerar que los APV son especialmente útiles en la atribución de beneficios o en la imputación de rentas en el contexto de las operaciones mundiales con valores y mercancías, así como en la aplicación de acuerdos multilaterales de reparto de costes. El concepto de APV puede resultar también útil en la resolución de las cuestiones que plantea el artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE sobre problemas de atribución, establecimientos permanentes y sucursales.

4.132 Los APV, incluso cuando son unilaterales, difieren en ciertos puntos de las tradicionales resoluciones* que algunas administraciones

* (N. de la T.) Se entenderá que esta expresión engloba todos los actos susceptibles de negociación entre el administrado y la administración que constituyen una práctica habitual en el mundo anglosajón, así como la interpretación judicial o administrativa de ciertas disposiciones del Derecho, comprendidas la evacuación de consultas y la emisión de cualquier otra resolución que constituya doctrina (ruling system).

tributarias pueden emitir a solicitud de los contribuyentes. Un APV valora generalmente elementos de hecho, mientras que las resoluciones tradicionales suelen limitarse a la interpretación de cuestiones de índole jurídica, sobre la base de los datos presentados por el contribuyente. En el caso de una resolución tradicional a instancia de parte, la administración tributaria puede no cuestionar los hechos subyacentes, mientras que es probable que en un APV los hechos se analicen e investiguen en profundidad. Además, un APV generalmente abarca varias operaciones, varias categorías de operaciones recurrentes o la totalidad de las operaciones internacionales del contribuyente para un determinado período de tiempo. Por el contrario, la resolución tradicional a instancia de parte generalmente sólo es vinculante para una determinada operación.

4.133 La cooperación de las empresas asociadas es vital para que la negociación del APV tenga éxito. Por ejemplo, se esperará de las empresas asociadas que indiquen a las administraciones tributarias el método que juzgan más apropiado en su situación y circunstancias. También se espera de ellas que presenten la documentación que fundamente su propuesta y que incluya, por ejemplo, los datos referentes al sector, los mercados y los países a los que se extenderá el acuerdo. Además, las empresas asociadas podrán identificar las operaciones no vinculadas que sean comparables o similares a sus operaciones, desde el punto de vista de la actividad económica ejercida y de las condiciones de precios de transferencia (por ejemplo, los costes económicos y los riesgos incurridos) y efectuar un análisis funcional, tal como se describe en el Capítulo I de estas Directrices.

4.134 En general, las empresas asociadas están autorizadas para participar en el procedimiento de obtención de un APV, presentando el caso y negociando con las autoridades fiscales a las que concierna, suministrando la información necesaria y buscando el acuerdo en materia de precios de transferencia. Desde el punto de vista de las empresas asociadas, esta posibilidad de intervenir puede resultar ventajosa frente al procedimiento amistoso convencional.

4.135 Una vez concluido el APV, las administraciones tributarias deben garantizar a las empresas asociadas de su jurisdicción que no se efectuará ningún ajuste de precios de transferencia en tanto que los contribuyentes cumplan los términos de los acuerdos. El APV debería contener igualmente una cláusula que prevea la posibilidad de revisión o anulación del acuerdo en años futuros (quizá tomando como referencia un rango) en caso de modificación importante de las operaciones de la empresa, o de circunstancias económicas imprevisibles (por ejemplo, modificaciones importantes de los tipos de cambio) que afecten severamente a la fiabilidad del método utilizado, en modo tal que las empresas independientes hubieran

considerado estos cambios como significativos para la determinación de sus precios de transferencia.

4.136 Un APV puede abarcar todas las cuestiones referidas a los precios de transferencia de un contribuyente (es la solución preferida por ciertos países) o dejar al contribuyente la posibilidad de limitar su petición de APV a filiales concretas o a operaciones entre empresas determinadas. En general, el APV se aplicará a ejercicios y operaciones futuros, y su duración dependerá del sector de actividad, de los productos o de las operaciones en cuestión. Las empresas asociadas podrán limitar su petición a ejercicios futuros concretos. El APV puede ofrecer la posibilidad de aplicar el método convenido de determinación de precios de transferencia para resolver problemas similares que se hayan planteado en ejercicios anteriores no prescritos. Sin embargo, aplicarlo de esa manera requeriría el acuerdo de la administración tributaria, del contribuyente y, en su caso, de la Administración del Estado co-signatario del convenio.

4.137 Naturalmente, cada administración tributaria que intervenga en el APV querrá efectuar un seguimiento del cumplimiento del acuerdo por parte de los contribuyentes de su jurisdicción, lo que podrá realizar de dos maneras. En primer lugar, podrá exigir al contribuyente un informe anual demostrando la conformidad de sus precios de transferencia con las condiciones previstas en el APV y mostrando la vigencia de las hipótesis críticas. En segundo lugar, podrá continuar el examen de la situación del contribuyente en el marco de sus inspecciones regulares, sin evaluar de nuevo la validez del método. En su lugar, la administración tributaria puede limitar la inspección de los precios de transferencia a la verificación de los datos iniciales sobre los que se ha fundado la propuesta del APV y a la determinación de si el contribuyente ha cumplido o no con los términos y condiciones de este. Podrá, igualmente, revisar la fiabilidad y precisión de las informaciones consignadas en el APV y en los informes anuales, así como de la aplicación precisa y coherente del método acordado. Cualquier otra cuestión no vinculada con el APV cae dentro del procedimiento ordinario de inspección.

4.138 El APV debe poder cancelarse, incluso retroactivamente, en caso de fraude o de tergiversación de la información en el curso de las negociaciones del APV, o en caso de inobservancia por el contribuyente de las condiciones previstas en el mismo. En el caso de propuesta de cancelación o de revocación de un APV, la administración tributaria que lo propone debe informar a las otras administraciones de su intención y de sus motivos.

F.2 Criterios posibles para la redacción de normas jurídicas y administrativas reguladoras de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia

4.139 Los APV que involucran a la autoridad competente de un país con el cual existe convenio fiscal deben considerarse dentro del ámbito del procedimiento amistoso previsto en el artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, aunque tales acuerdos no se mencionen expresamente en el mismo. El párrafo 3 de dicho artículo dispone que las autoridades competentes harán lo posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del convenio a través del procedimiento amistoso. Aunque el párrafo 50 de los Comentarios indica que el párrafo se refiere a dificultades de naturaleza general que conciernen a una categoría de contribuyentes, reconoce expresamente que pueden surgir problemas relacionados con casos concretos. En un cierto número de casos, los APV se inician por razón de las dudas o dificultades surgidas en la aplicación de reglas en materia de precios de transferencia a una categoría particular de contribuyentes. El párrafo 3 del artículo 25 indica igualmente que las autoridades competentes pueden consultarse con la finalidad de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el convenio. Los APV bilaterales deberían entenderse incluidos en esta disposición porque uno de sus objetivos es evitar la doble imposición. A pesar de que el Convenio prevé ajustes por precios de transferencia, no indica métodos ni procedimientos particulares distintos del principio de plena competencia establecido en el artículo 9. Se podría pues considerar que los APV están autorizados por el párrafo 3 del artículo 25, ya que los supuestos específicos de precios de transferencia sometidos a un APV no están contemplados de otra manera en el Convenio. El artículo 26, relativo al intercambio de información, podría posibilitar igualmente los APV, ya que reglamenta la cooperación entre autoridades competentes en forma de intercambio de información.

4.140 Para instituir los APV, las administraciones tributarias pueden apoyarse asimismo en las prerrogativas generales que les confiere su ley interna para la administración de los impuestos. En ciertos países las administraciones tributarias están facultadas para formular directrices administrativas o procedimentales específicas para los contribuyentes, que describen el régimen fiscal de las operaciones y el método apropiado de determinación de precios. Como se ha mencionado anteriormente, las leyes generales tributarias de ciertos países miembros de la OCDE incluyen disposiciones que permiten a los contribuyentes obtener resoluciones específicas a sus consultas con diferentes finalidades. Aun cuando tales resoluciones no se diseñaron específicamente para abarcar los APV, su

campo de aplicación es a menudo lo suficientemente amplio como para incluirlos.

4.141 Algunos países carecen de base, en virtud de su derecho interno, para instituir los APV. Sin embargo, cuando un convenio fiscal contiene una cláusula relativa al procedimiento amistoso similar al artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, las autoridades competentes, en términos generales, estarían autorizadas para concertar un APV si los problemas que plantean los precios de transferencia pueden conllevar una doble imposición o dificultades o dudas en cuanto a la interpretación o aplicación del convenio. Tal acuerdo sería jurídicamente vinculante para los dos Estados y generaría derechos para los contribuyentes a los que afecte. En la medida en que los convenios de doble imposición prevalecen sobre el derecho interno, la ausencia de base jurídica para autorizar un APV no impide su aplicación en el marco de un procedimiento amistoso.

F.3 Ventajas de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia

4.14 Los APV pueden resultar muy útiles para los contribuyentes porque eliminan la incertidumbre y hacen más previsible el régimen tributario de las operaciones internacionales. Suponiendo que se han cumplido las hipótesis críticas, el APV permitirá a los contribuyentes tener certidumbre sobre el régimen tributario de las operaciones sujetas a precios de transferencia a las que se refiere, para un período de tiempo determinado. En ciertos casos puede ampliarse el plazo de aplicación del APV. Cuando el plazo de vigencia de un APV expira, las administraciones tributarias y los contribuyentes a los que concierne pueden tener la posibilidad de renegociarlo. Gracias a la certidumbre que proporciona un APV, el contribuyente se sitúa en una mejor posición para prever sus obligaciones tributarias creando, en consecuencia, un entorno fiscal favorable a la inversión.

4.143 Los APV constituyen la ocasión para que las administraciones tributarias y los contribuyentes se consulten y cooperen en un espíritu de concertación. La posibilidad que se ofrece de examinar problemas fiscales complejos en un ambiente más sereno que el de una inspección de precios de transferencia puede favorecer la libre circulación de información entre todas las partes que intervienen, permitiendo alcanzar un resultado jurídicamente correcto y trasladable a la práctica. La ausencia de confrontación puede conducir igualmente a una mayor objetividad en la revisión de los datos e información suministrados que en un contexto más antagónico (por ejemplo, ante los tribunales). Las consultas y la estrecha cooperación necesarias entre

administraciones tributarias para la puesta en práctica de un procedimiento de negociación de APV se traducen igualmente en relaciones más estrechas con los co-signatarios de convenios en lo que se refiere a la determinación de precios de transferencia.

4.144 Un APV puede evitar a los contribuyentes y a las administraciones tributarias largas y costosas inspecciones y los litigios que pueden generar los precios de transferencia. Tras la conclusión de un APV, las administraciones tributarias necesitarán menos recursos para subsiguientes inspecciones de las declaraciones del contribuyente, ya que tendrán más información sobre él. Sin embargo, el seguimiento de la aplicación del Acuerdo podrá seguir planteando dificultades. El procedimiento del APV puede en sí mismo ahorrar tiempo tanto a los contribuyentes como a las administraciones tributarias respecto de las inspecciones tradicionales, aunque en conjunto puede no haber un ahorro neto de tiempo; por ejemplo, en los países que no tienen un procedimiento de inspección y donde la existencia de un APV puede no afectar directamente al importe de los recursos destinados al cumplimiento de la legislación tributaria.

4.145 Los APV bilaterales y multilaterales reducen sustancialmente o eliminan la posibilidad de doble imposición o de no imposición, jurídica o económica, desde el momento en que participan todos los países implicados. Por el contrario, los APV unilaterales no aportan certidumbre en la reducción de la doble imposición, porque las administraciones tributarias afectadas por las operaciones cubiertas por el APV pueden considerar que la metodología adoptada no genera un resultado conforme con el principio de plena competencia. Además, los APV bilaterales o multilaterales pueden mejorar el procedimiento amistoso reduciendo significativamente el tiempo necesario para alcanzar un acuerdo, en la medida en que las autoridades competentes manejan datos actuales y no referidos a ejercicios anteriores, cuya obtención puede ser difícil y exigir un tiempo.

4.146 Las obligaciones de comunicación de información en el contexto de los APV, así como el espíritu de cooperación que preside su negociación, pueden permitir a las administraciones tributarias comprender mejor ciertas operaciones internacionales complejas que llevan a cabo las multinacionales. Gracias a los procedimientos para la negociación de APV es posible conocer y comprender mejor los aspectos extremadamente técnicos y los elementos de hecho de ciertas áreas de actividad, como las operaciones con productos financieros a escala mundial y los problemas fiscales que plantean. El desarrollo de competencias muy especializadas sobre ciertos sectores o ciertos tipos de operaciones posibilitará que las administraciones tributarias den un mejor servicio a los contribuyentes que se encuentren en situaciones similares. A través de un los procedimientos de negociación de APV las

administraciones tributarias acceden a datos sectoriales y al análisis de métodos de determinación de precios muy útiles en un ambiente cooperativo.

F.4 Inconvenientes de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia

4.147 Los APV unilaterales pueden plantear serios problemas tanto para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. Desde el punto de vista de otras administraciones tributarias, los problemas surgen por un posible desacuerdo con las conclusiones del APV. Desde el punto de vista de las empresas asociadas que intervienen en él, uno de estos problemas se refiere a la incidencia que puede tener sobre su comportamiento. Contrariamente a los APV bilaterales o multilaterales, los APV unilaterales pueden no reducir la incertidumbre para el contribuyente al que concierne, ni la doble imposición económica o jurídica para el grupo multinacional. Si el contribuyente, a fin de evitar largas y costosas inspecciones sobre los precios de transferencia o sanciones excesivas, acepta un acuerdo que se traduce en una sobre imputación de rentas en el país con el que ha concluido el APV, la carga administrativa se desplazará desde el país que acuerda el APV a otras jurisdicciones tributarias. Estos motivos no deberían llevar a los contribuyentes a concluir un APV.

4.148 Los APV unilaterales plantean otro problema: el del ajuste correlativo. La flexibilidad que ofrece un APV puede conducir a que el contribuyente y la empresa asociada acomoden sus precios dentro del rango autorizado en él. En un APV unilateral es absolutamente necesario que esta flexibilidad se atenga al principio de plena competencia, ya que una autoridad competente extranjera probablemente rehusará efectuar un ajuste correlativo que se derive de un APV no conforme, desde su punto de vista, con el principio de plena competencia.

4.149 Los APV pueden presentar otro posible inconveniente si se basan en predicciones no muy fiables sobre la evolución del mercado, sin haber determinado convenientemente las hipótesis críticas, tal como se vio anteriormente. Para evitar el riesgo de doble imposición, es necesario que el programa de APV sea flexible, ya que un APV rígido puede no reflejar satisfactoriamente las condiciones de plena competencia.

4.150 Los procedimientos para la negociación de APV pueden suponer inicialmente una carga considerable para los servicios encargados de la comprobación de los precios de transferencia, porque será frecuente que las administraciones tributarias deban desviar recursos afectados a otras finalidades (por ejemplo, inspecciones, consultas, litigios, etc.). Los

contribuyentes, preocupados por cumplir con sus objetivos empresariales y por respetar sus calendarios, demandarán la conclusión de los APV en el plazo más breve posible. El procedimiento establecido para los APV dependerá a menudo de las exigencias de los medios empresariales. Estas exigencias pueden no coincidir con el plan de gestión de recursos de las administraciones tributarias, lo que dificultará el desarrollo eficiente de los APV y de otros trabajos igualmente importantes. Es probable, sin embargo, que la renovación de un APV lleve menos tiempo que el proceso inicial. La renovación puede centrarse en la actualización y adaptación de los elementos de hecho, de los criterios sectoriales y económicos y de los cálculos. Para evitar la doble imposición (o no imposición) será necesario, en el caso de los APV bilaterales, obtener el acuerdo de las autoridades competentes de ambos Estados contratantes para su renovación.

4.151 Puede observarse otro inconveniente potencial cuando una administración tributaria ha acometido un cierto número de APV bilaterales que conciernen solamente a una parte de las empresas asociadas de un grupo multinacional. Puede existir una tendencia a concluir los APV ulteriores sobre bases similares a las de los acuerdos precedentes, sin tener suficientemente en cuenta las condiciones que se dan en otros mercados. Es necesario tener cuidado de no considerar los resultados de los APV anteriores como representativos de todos los mercados.

4.152 Se puede temer igualmente que, por su propia naturaleza, el procedimiento de APV interese a los contribuyentes que siempre han cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias. En ciertos países, la experiencia ha demostrado que, la mayor parte de las veces, los contribuyentes interesados por los APV son las empresas muy grandes sometidas periódicamente a inspección, cuyos métodos de determinación de precios se examinan siempre. Las diferencias en las comprobaciones efectuadas sobre sus precios de transferencia estarían más relacionadas con los plazos que con su alcance. Asimismo, no se ha demostrado que los APV sean de interés, exclusiva o principalmente, para dichos contribuyentes. Ciertamente, parece que los contribuyentes que han experimentado dificultades con las administraciones tributarias en materia de precios de transferencia, y que desean poner fin a las mismas, suelen estar interesados en la solicitud de un APV. Existe el grave riesgo de desviar hacia esos contribuyentes recursos y competencias que sería preferible destinar a la inspección de los contribuyentes menos escrupulosos, donde estos recursos podrían emplearse mejor reduciendo el riesgo de pérdida de recaudación. El equilibrio de los recursos destinados al cumplimiento puede ser particularmente difícil de alcanzar porque un programa de APV suele requerir un personal muy experimentado y a menudo especializado. Las

solicitudes de APV pueden concentrarse en áreas o sectores particulares, por ejemplo, en las operaciones con productos financieros a escala mundial, lo cual puede sobrecargar al personal especializado que las autoridades fiscales ya han asignado a esas áreas. Las administraciones tributarias necesitan tiempo para formar expertos en campos especializados, con el fin de atender solicitudes impredecibles de APV por parte de los contribuyentes en esas áreas.

4.153 Además de los inconvenientes anteriores, también pueden plantearse las dificultades que se describen a continuación en caso de que los procedimientos para la negociación de APV no estuvieran convenientemente gestionados. Las administraciones tributarias que los utilizan deben evitar que surjan estas dificultades a medida que evolucionan en su aplicación práctica.

4.154 Por ejemplo, un APV puede precisar de más información detallada sobre una rama de actividad o sobre un contribuyente, que la necesaria para la inspección de un precio de transferencia. En principio, no debería ocurrir así y la documentación requerida para un APV no tendría por qué ser más onerosa que para una inspección excepto que, en el contexto de un APV, la administración tributaria necesitará disponer de detalles sobre las previsiones y sus fundamentos, que no serían esenciales en el contexto de una inspección de los precios de transferencia, ya que estas se centran en operaciones ya realizadas. De hecho, como se vio anteriormente, debería limitarse la documentación necesaria para los APV, circunscribiéndola a los elementos relacionados con las prácticas empresariales del contribuyente. Es necesario que las administraciones tributarias reconozcan que:

- a) la información sobre competidores y operaciones comparables accesibles al público es limitada;
- b) no todos los contribuyentes disponen de los medios para proceder a un análisis en profundidad del mercado; y
- c) solamente las sociedades matrices pueden estar perfectamente informadas sobre la política de determinación de precios en el grupo.

4.155 Puede ocurrir también que un APV permita a la administración tributaria estudiar las operaciones en cuestión con más profundidad que en el caso de la inspección de los precios de transferencia, en función de los hechos y circunstancias. El contribuyente deberá suministrar información detallada sobre la determinación de sus precios de transferencia y ajustarse a cualquier otra obligación que la administración tributaria le imponga para asegurar el respeto de las condiciones exigidas en el APV. Al mismo tiempo, el contribuyente no está exento de las inspecciones normales y periódicas a

las que la administración tributaria puede proceder sobre otros puntos, a la vez que la conclusión de un APV tampoco determina obligatoriamente que el contribuyente esté exento de la inspección de sus operaciones con precios de transferencia. El contribuyente podrá todavía tener que demostrar que ha cumplido de buena fe con los términos y condiciones del APV, que las declaraciones fundamentales efectuadas durante el proceso siguen siendo válidas, que los datos utilizados para aplicar el método escogido eran correctos, que las hipótesis críticas sobre las que descansa el APV siguen siendo pertinentes y que la metodología se aplica con coherencia. En consecuencia, las administraciones tributarias deberían actuar de manera que los APV no resulten innecesariamente gravosos y no se impongan a los contribuyentes exigencias que vayan más allá de las estrictamente necesarias para la aplicación del APV.

4.156 Pueden plantearse igualmente problemas si, durante sus prácticas inspectoras, las administraciones tributarias hacen un uso abusivo de las informaciones obtenidas en un APV. Si el contribuyente retira su solicitud de APV o si tras considerar los hechos concurrentes esta se rechaza, la información de carácter no fáctico que ha suministrado el contribuyente en el curso de su solicitud, por ejemplo, ofertas de acuerdo, razonamientos, opiniones y juicios, no puede considerarse utilizable a efectos de inspección. Además una petición infructuosa de APV por parte de un contribuyente no debe incitar a la administración tributaria a iniciar una inspección de su situación.

4.157 Las administraciones tributarias deben preservar igualmente la confidencialidad de los secretos mercantiles y de otra información y documentación confidencial que se les haya suministrado durante el procedimiento de APV. En consecuencia, deben aplicarse las normas internas que prohíben la divulgación de información. En caso de un APV bilateral se aplican las reglas de confidencialidad que vinculan a los co-signatarios del convenio, impidiendo así la divulgación de datos confidenciales.

4.158 No todos los contribuyentes pueden acceder al procedimiento de negociación de los APV debido a su coste y dilación en el tiempo que, por lo general, lo harán inaccesible para los pequeños contribuyentes. Esta circunstancia será especialmente acusada cuando deban intervenir expertos independientes. Los APV pueden, en consecuencia, contribuir únicamente a resolver casos de precios de transferencia de gran envergadura. Además, las implicaciones presupuestarias de los APV pueden limitar el número de solicitudes que la administración tributaria puede aceptar. Al valorar los APV, las administraciones tributarias pueden atenuar estos problemas

asegurándose de que la profundidad del análisis se corresponde con la importancia de las operaciones internacionales en cuestión.

F.5 Recomendaciones

F.5.1 De índole general

4.159 Desde la publicación de las Directrices en su versión original de 1995, son numerosos los países de la OCDE que han adquirido experiencia con los APV. Por el momento, los países con alguna experiencia parecen satisfechos con este procedimiento, por lo que cabe esperar que, dándose las circunstancias apropiadas, la experiencia con los APV continúe desarrollándose. El éxito de los procedimientos de negociación de los APV depende varios elementos: la atención prestada para determinar el grado adecuado de especificidad del acuerdo sobre la base de las hipótesis críticas, de la buena gestión del procedimiento y de la existencia de salvaguardias adecuadas que eviten los problemas antes descritos, a lo que hay que añadir la flexibilidad y el espíritu abierto que debe presidir este procedimiento.

4.160 Desde el punto de vista de la forma y del ámbito de aplicación de los APV, siguen existiendo ciertos problemas cuya solución requiere de una mayor experiencia que permita eliminarlos totalmente y llegar al acuerdo entre los países miembros, siendo una de estas complicaciones la de los APV unilaterales. El Comité de Asuntos Fiscales pretende un control exhaustivo sobre la aplicación extensiva de los APV y el fomento de una mayor coherencia en la práctica entre los países que los utilizan.

F.5.2 Ámbito de aplicación de un acuerdo

4.161 En el examen del campo de aplicación de un acuerdo, los contribuyentes y las administraciones tributarias han de prestar una atención particular a la fiabilidad de las predicciones, de manera que se excluyan aquellas no fiables. Es necesario, en general, una gran prudencia cuando el APV va más allá de la determinación de la metodología, su aplicación y la determinación de las hipótesis críticas. Véanse los párrafos 4.123 a 4.128.

F.5.3 Acuerdos unilaterales versus bilaterales (multilaterales)

4.162 En la medida de lo posible, un APV debe concluirse bilateral o multilateralmente entre autoridades competentes, por medio del procedimiento amistoso previsto en el convenio aplicable. En el ámbito de los APV bilaterales, es menos probable que los contribuyentes se sientan

obligados a concluir o a aceptar un acuerdo que no se ajuste al principio de plena competencia con la finalidad de evitar costosas y prolongadas inspecciones y eventuales sanciones. Además, un APV bilateral reduce enormemente los riesgos de no imposición o de doble imposición de los beneficios. Por otra parte, la conclusión de un APV a través del procedimiento amistoso puede constituir la única fórmula disponible para la administración tributaria de un país cuya legislación interna no contemple la posibilidad de concluir directamente acuerdos vinculantes con el contribuyente.

F.5.4 Ecuanimidad en el acceso de los contribuyentes a los APV

4.163 Como se ha visto anteriormente, la propia naturaleza del APV puede limitar "de facto" su disponibilidad al ámbito de los grandes contribuyentes, lo que puede plantear problemas de ecuanimidad y de uniformidad, ya que los contribuyentes que se hallen en situaciones idénticas no deben recibir un tratamiento distinto. Un reparto flexible de los recursos de inspección puede remediar estas dificultades. Quizás sea también necesario que las administraciones tributarias contemplen la posibilidad de adoptar un procedimiento simplificado para los pequeños contribuyentes. Al evaluar los APV, las administraciones tributarias deberían procurar adaptar el nivel de investigación necesaria a la importancia de las operaciones internacionales en cuestión.

F.5.5 Adopción de acuerdos de trabajo entre autoridades competentes relativos a los APV y a la mejora de procedimientos

4.164 La uniformidad en las prácticas relativas a los APV entre los países que los utilizan podría ser beneficiosa tanto para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. En consecuencia, las administraciones tributarias de tales países podrían contemplar la conclusión de acuerdos de trabajo entre autoridades competentes referidos a los APV. Estos acuerdos podrían establecer las directrices generales y los conceptos básicos para alcanzar un acuerdo mutuo cuando el contribuyente haya solicitado un APV sobre precios de transferencia.

4.165 Además, los APV bilaterales con co-signatarios de convenios deben responder a ciertas exigencias. Por ejemplo, sería necesario que cada una de las administraciones tributarias dispusiera simultáneamente de la misma información necesaria y pertinente, y que el método convenido fuera conforme al principio de plena competencia.

G. Arbitraje

4.166 En la medida en que el comercio y la inversión han adquirido progresivamente un carácter internacional, las controversias tributarias que ocasionalmente se derivan de tales actividades se sitúan también, cada vez más, en el plano internacional. Más concretamente, las disputas ya no constituyen simples controversias entre un contribuyente y su administración tributaria, sino que implican diferencias entre las propias administraciones tributarias. En muchas de estas situaciones, el grupo multinacional es meramente una parte interesada y los verdaderos protagonistas son las administraciones implicadas. Aun cuando tradicionalmente los problemas de doble imposición se han resuelto a través de un procedimiento amistoso, su eliminación no está garantizada si las administraciones tributarias, tras sus deliberaciones, no consiguen llegar a un acuerdo, y si no existe un mecanismo, como una cláusula sobre arbitraje similar a la contenida en el apartado 5 del artículo 25, que posibilite su resolución. Sin embargo, cuando un convenio concreto contiene una cláusula similar a la del mencionado apartado 5 del artículo 25, esta ampliación del procedimiento amistoso permite que siga siendo posible resolver el caso, mediante la remisión a arbitraje de una o más cuestiones sobre las que las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo.

4.167 En la actualización de 2008 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, el artículo 25 se complementó con un nuevo apartado 5 que prevé que, en aquellos casos en los que las autoridades competentes no puedan llegar a un acuerdo en el plazo de dos años, las cuestiones pendientes se resolverán mediante arbitraje a instancia de la persona que presentó el caso. Esta ampliación del procedimiento amistoso garantiza que, cuando las autoridades competentes no puedan acordar una o más cuestiones que impiden la resolución del caso, esta seguirá siendo posible mediante su remisión a arbitraje. El arbitraje previsto en el apartado 5 del artículo 25 es parte integrante del procedimiento amistoso y no constituye una vía alternativa de resolución de controversias en materia tributaria entre Estados. Los párrafos 63 a 85 de los Comentarios al artículo 25 constituyen una guía sobre la fase de arbitraje del procedimiento amistoso.

4.168 La existencia de una cláusula sobre arbitraje similar a la contenida en el apartado 5 del artículo 25 en un convenio bilateral debe mejorar la eficacia del procedimiento amistoso en sí, incluso en aquellos casos en los que no es necesario recurrir a él. La mera existencia de esta posibilidad debe fomentar la utilización del procedimiento amistoso, ya que tanto los gobiernos como los contribuyentes sabrán desde el principio que el tiempo y los recursos destinados al procedimiento tienen una gran probabilidad de

generar un resultado satisfactorio. En esa misma línea, las administraciones estarán interesadas en velar por el desarrollo eficiente del procedimiento a fin de evitar procedimientos complementarios ulteriores.

Capítulo V

Documentación

A. Introducción

5.1 Este capítulo contiene unas orientaciones generales que deben seguir las administraciones tributarias en el desarrollo de sus normas y procedimientos sobre la documentación que deben aportar los contribuyentes en el marco de las comprobaciones de los precios de transferencia. Constituye también una guía para ayudar a los contribuyentes a identificar la documentación que resulta más útil para demostrar que sus operaciones vinculadas cumplen con el principio de plena competencia y, por tanto, para resolver cuestiones sobre precios de transferencia y facilitar las inspecciones tributarias.

5.2 Las obligaciones en materia de documentación pueden verse afectadas por las normas reguladoras de la carga de la prueba en la jurisdicción pertinente. En la mayoría de las jurisdicciones la carga de la prueba recae sobre la administración tributaria. Por tanto, no es al contribuyente a quien le corresponde probar la correcta determinación de sus precios de transferencia, a menos que la administración tributaria demuestre, prima facie, que dicha determinación no es coherente con el principio de plena competencia. Las reflexiones sobre documentación contenidas en este capítulo no pretenden crear a los contribuyentes obligaciones que excedan de las impuestas por normas internas. Sin embargo, debe señalarse que, incluso cuando la carga de la prueba corresponde a la administración tributaria, esta puede obligar razonablemente al contribuyente a presentar la documentación sobre sus precios de transferencia, ya que sin la información oportuna la administración tributaria no podría inspeccionar el caso adecuadamente. De hecho, cuando el contribuyente no suministra información adecuada, en algunos países puede producirse la inversión de la carga de la prueba en forma de presunción que admite prueba en contrario en favor del ajuste propuesto por la administración tributaria. Quizás sería más importante que tanto la administración tributaria como el contribuyente hicieran un esfuerzo

de buena fe para demostrar que sus determinaciones de precios de transferencia satisfacen el principio de plena competencia, independientemente de quién soporta la carga de la prueba. Durante los procedimientos de inspección las actuaciones de la administración tributaria no deben resultar afectadas por el hecho de que la carga de la prueba recaiga sobre el contribuyente, cuando así sea. Ni la administración tributaria ni el contribuyente deben utilizar la carga de la prueba como pretexto para sostener afirmaciones infundadas o indemostrables en relación con los precios de transferencia.

B. Criterios sobre normas y procedimientos de documentación

5.3 Los contribuyentes deben procurar determinar sus precios de transferencia, a efectos fiscales, de acuerdo con el principio de plena competencia, apoyándose en la información a la que puedan acceder en los márgenes de lo razonable al proceder a su determinación. Así, el proceso normal sería que el contribuyente considerara si su precio de transferencia es apropiado a efectos fiscales antes de fijarlo como tal. Por ejemplo, sería deseable que el contribuyente hubiera llegado a una conclusión respecto a la disponibilidad o no de datos comparables referidos a operaciones no vinculadas. También cabría esperar que el contribuyente analizase, basándose en la información disponible, si las condiciones utilizadas para determinar los precios de transferencia de años anteriores han cambiado, en el caso de que estos vayan a utilizarse para determinar los precios de transferencia del año en curso.

5.4 Para considerar si la determinación de los precios de transferencia es adecuada a efectos fiscales, el contribuyente debe regirse por los mismos principios de gestión prudente que gobernarían el análisis de una decisión empresarial con un nivel de complejidad e importancia similar. Cabe esperar que la aplicación de estos principios requiera que el contribuyente prepare o utilice documentos escritos que puedan servir para ilustrar las actuaciones llevadas a cabo con el fin de cumplir el principio de plena competencia, incluyendo la información en la que se basó la determinación de los precios de transferencia, los factores considerados y el método seleccionado. Lo razonable es que las administraciones tributarias confíen en que los contribuyentes, al fijar sus precios de transferencia para una actividad empresarial concreta, preparen u obtengan la documentación relativa a la naturaleza de la actividad y a la determinación de los precios de transferencia y que la conserven para su presentación, en caso necesario, en el curso de una inspección tributaria. Este proceder contribuirá a que los contribuyentes presenten correctamente sus declaraciones fiscales. Obsérvese, sin embargo,

que no debe exigirse la presentación de esta documentación en el momento de determinar los precios de transferencia o de presentar la declaración, ni su preparación a efectos de una revisión por parte de la administración tributaria. En el apartado 5.15 se detallan los documentos que sería oportuno requerir junto con la declaración del impuesto.

5.5 En la medida en que el interés último de la administración tributaria queda satisfecho con la presentación oportuna de los documentos necesarios cuando se demanden en el curso de una inspección, la forma de conservación debe dejarse al arbitrio del contribuyente. Por ejemplo, el contribuyente puede elegir almacenar los documentos pertinentes en su formato original o compilarlos en forma de libro, en el idioma que prefiera, antes de tener que proporcionárselos a la administración tributaria. No obstante, este deberá cumplir con las solicitudes de traducción que resulten razonables respecto de la documentación que se pone a disposición de la administración tributaria.

5.6 Al considerar si un precio de transferencia es apropiado a efectos fiscales, puede ser necesario, atendiendo a los principios de una gestión empresarial prudente, que el contribuyente prepare o utilice documentación escrita que no hubiera preparado, o a la que no se hubiera referido, en ausencia de consideraciones fiscales, incluyendo documentos de empresas asociadas extranjeras. Cuando se requiera la presentación de este tipo de documentos, la administración tributaria debe mostrarse cuidadosa y medir la necesidad de disponer de ellos teniendo en cuenta el coste y la carga administrativa que puede suponer para el contribuyente su confección u obtención. Por ejemplo, no debe esperarse del contribuyente que incurra en costes y cargas desproporcionadamente altos para obtener documentos de empresas asociadas extranjeras, o que efectúe una búsqueda exhaustiva de datos comparables de operaciones no vinculadas cuando esté razonablemente convencido, atendiendo a los principios expuestos en estas Directrices, de que no existen datos comparables o de que el coste de localización sería desproporcionadamente elevado en relación con los importes que se cuestionan. Las administraciones tributarias deben tener asimismo en cuenta que pueden recurrir a los artículos sobre intercambio de información incluidos en los convenios para evitar la doble imposición cuando quepa esperar una respuesta oportuna y eficiente a través de este procedimiento.

5.7 Así, aun cuando algunos documentos que pudieran utilizarse o servir de base para la determinación de un precio de transferencia de plena competencia a efectos fiscales sean de naturaleza tal que no se hubieran preparado u obtenido sino con fines tributarios, únicamente cabe esperar que el contribuyente los prepare u obtenga en caso de que sean indispensables para poder valorar razonablemente si los precios de transferencia se ajustan

al principio de plena competencia, y sólo si el contribuyente puede elaborarlos u obtenerlos sin incurrir en costes desproporcionados. No debe esperarse que el contribuyente elabore u obtenga más documentos que los mínimos necesarios para realizar una valoración razonable sobre su cumplimiento del principio de plena competencia.

5.8 Con arreglo a los criterios anteriores, no debe obligarse a los contribuyentes a conservar documentación referida a operaciones realizadas en ejercicios prescritos respecto de los que no es posible el ajuste más allá del período exigido en la legislación interna para la conservación de documentos de naturaleza similar. Además, en condiciones normales, las administraciones tributarias no deben requerir documentos relativos a esos años aun cuando se hubieran conservado. Sin embargo, habrá ocasiones en las que esos documentos puedan ser relevantes para la comprobación de los precios de transferencia de un año posterior no prescrito, por ejemplo, cuando los contribuyentes conserven por propia iniciativa los documentos relativos a sus contratos a largo plazo, o los que sirvan para determinar si se cumplen los criterios de comparabilidad relativos a la aplicación de un método de determinación de precios de transferencia en un ejercicio posterior no prescrito. Las administraciones tributarias deben tener siempre presente la dificultad que entraña la localización de documentos de años anteriores y deberían restringir sus requerimientos a los casos en los que existan razones fundadas para revisarlos en relación con la operación objeto de examen.

5.9 Del mismo modo, las administraciones tributarias deberían restringir sus requerimientos de aquella documentación que estuviese disponible sólo después de realizada la operación, a aquella respecto de la que sea razonable esperar que contenga información relevante, tal como se determina en el Capítulo III, aplicando los principios que rigen la utilización de datos referidos a varios años, o información relativa a los hechos que concurrieron en el momento en que se determinó el precio de transferencia. Al valorar la idoneidad de la información, la administración tributaria debe considerar si el contribuyente pudo disponer de ella en el momento de determinar el precio de transferencia.

5.10 Asimismo, las administraciones tributarias no deben exigir a los contribuyentes que presenten documentación que no obre en su poder, o sobre la que no tengan control, o a la que no puedan acceder, dentro de lo razonable, por otros motivos; por ejemplo, la información que no se pueda obtener legalmente o de la que el contribuyente no pueda realmente disponer por ser confidencial para sus competidores, o que no esté publicada y no sea accesible por solicitud o a través de la consulta de los datos del mercado.

5.11 En muchos casos, la información sobre empresas asociadas extranjeras es crucial para las inspecciones de precios de transferencia. Sin embargo, el contribuyente se puede encontrar con dificultades para reunir esa información que no tendría si aportara sus propios documentos. Cuando el contribuyente es una filial de una empresa extranjera asociada o es sólo un accionista minoritario, puede ser difícil obtener la información como consecuencia de que el contribuyente no tiene control sobre la empresa asociada. En cualquier caso, las normas contables y las obligaciones legales de documentación (incluidos los plazos para su preparación y remisión) difieren de un país a otro. Los documentos requeridos al contribuyente pueden no ser aquellos que los principios de una gestión empresarial prudente aconsejen conservar a la empresa asociada extranjera; y traducir y presentar estos documentos puede suponer un tiempo y un coste importantes. Al definir las obligaciones de documentación exigibles al contribuyente deben sopesarse estas consideraciones.

5.12 Podría no ser necesario ampliar la información requerida a todas las empresas asociadas que intervengan en las operaciones vinculadas objeto de revisión. Por ejemplo, al determinar un precio de transferencia para un distribuidor con un número limitado de funciones, podría ser oportuno tener información sobre esas tareas, sin extender la petición de información a otros miembros del grupo multinacional.

5.13 Las administraciones tributarias deben tener cuidado para asegurarse de que no se divulguen secretos comerciales o científicos u otros datos confidenciales. Por lo tanto, deben actuar con discreción al requerir este tipo de información, procediendo a ello únicamente cuando puedan comprometerse a mantener la confidencialidad de la información frente a terceros, salvo cuando la divulgación resulte necesaria en procedimientos públicos ante tribunales o en resoluciones judiciales. Incluso en dichos procedimientos y resoluciones debe procurarse mantener la confidencialidad en la mayor medida posible.

5.14 Los contribuyentes deben admitir que, sin perjuicio de las limitaciones en materia de requerimiento de documentación, la administración tributaria tendrá que llegar a concretar un precio de transferencia de plena competencia aun cuando la información disponible sea incompleta. Como consecuencia, el contribuyente debe tener en cuenta que la conservación de archivos y la presentación voluntaria de documentos aumentan la credibilidad de su valoración de los precios de transferencia. Así será tanto en los casos muy obvios como en los complejos pero, cuanto más complicado e inusual sea, mayor importancia tendrá la documentación.

5.15 Las administraciones tributarias deben limitar la cantidad de información exigible al presentar la declaración tributaria, momento en el que aun no se ha concretado la comprobación de precios de transferencia respecto de operación alguna. En esta fase, resultaría muy gravoso exigir información detallada sobre todas las operaciones transfronterizas entre empresas asociadas y sobre la totalidad de las empresas participantes en las mismas. Por consiguiente, no sería lógico exigir que el contribuyente aportara, junto con la declaración tributaria, documentos que justifiquen de manera específica la procedencia de los precios de transferencia determinados. Esta exigencia podría obstaculizar el comercio internacional y la inversión exterior. La documentación exigible en la fase de presentación de la declaración tributaria debería limitarse a la aportación de aquella que permita a la administración tributaria determinar, aproximadamente, qué contribuyentes deben ser objeto de una comprobación más exhaustiva.

C. Información útil para determinar los precios de transferencia

5.16 La información relevante para la verificación de los precios de transferencia depende de los hechos y de las circunstancias del caso. Por esta razón, no es posible definir con carácter general la medida y la naturaleza precisas de la información que sería razonable que la administración tributaria requiriese y que el contribuyente presentase con ocasión de la inspección. Sin embargo, hay ciertos rasgos distintivos que son comunes a cualquier comprobación de precios de transferencia que dependen de la información relativa al contribuyente, a las empresas asociadas, a la naturaleza de la operación y a la base para la determinación del precio. En la sección siguiente se expone, en líneas generales, la información que podría ser relevante según las circunstancias particulares de cada caso. Su objeto es exponer qué tipo de información facilitaría la investigación en la generalidad de los casos, pero subrayando el hecho de que la información que se cita no constituye la norma mínima que deba cumplirse. Del mismo modo, tampoco pretende constituir una enumeración exhaustiva de la información que las administraciones tributarias puedan tener derecho a exigir.

5.17 El análisis efectuado bajo la perspectiva del principio de plena competencia requiere, por lo general, de información acerca de las empresas asociadas que participan en la operación vinculada, así como de información relativa a las operaciones en cuestión, a las funciones desempeñadas, la referida a empresas independientes que participan en operaciones o actividades económicas similares, e información relativa a otros factores comentados a lo largo de estas Directrices, teniendo presentes los criterios mencionados en el párrafo 5.4. También podría ser pertinente alguna

información adicional sobre la operación vinculada en cuestión; por ejemplo, su naturaleza y los términos en los que se produce, las condiciones económicas y los bienes objeto de la misma, sobre cómo circulan los productos o servicios que constituyen el objeto de la operación vinculada entre las empresas asociadas, y sobre las modificaciones en las condiciones comerciales o las renegociaciones de los acuerdos en vigor. También podría incluir una descripción de las circunstancias de cualesquiera otras operaciones conocidas entre el contribuyente y un tercero independiente que sean similares a la operación con una empresa asociada extranjera, y cualquier información susceptible de ser útil para saber si empresas independientes que negocian en plena competencia hubieran concluido operaciones estructuradas de forma similar en circunstancias comparables. Otra información útil puede ser la relación de sociedades comparables conocidas que lleven a cabo operaciones similares a las vinculadas.

5.18 En casos concretos sobre precios de transferencia puede ser útil referirse a información relativa a cada empresa asociada que participe en la operación vinculada sometida a revisión, como puede ser:

- a) la descripción sucinta de la actividad;
- b) la estructura organizativa;
- c) la articulación de la propiedad en el seno del grupo multinacional;
- d) el volumen de ventas y los resultados de explotación en los años inmediatamente previos al de la operación;
- e) el nivel de operaciones del contribuyente con empresas extranjeras asociadas: por ejemplo, el importe de las ventas de activos inventariados, las prestaciones de servicios, el arrendamiento de activos materiales, el uso y la transmisión de activos intangibles y los intereses sobre préstamos.

5.19 También puede resultar de utilidad la información relativa a la determinación de precios, incluyendo las estrategias empresariales y otras circunstancias especiales del caso. Esta información podría incluir factores que hayan influido en la determinación de los precios, o en la concreción de las políticas de determinación de precios del contribuyente y de todo el grupo multinacional. Por ejemplo, esas políticas de precios podrían consistir en añadir un margen al coste de fabricación, en deducir del precio de venta fijado para el consumidor final los costes que corresponda cuando las partes asociadas extranjeras ejercen una actividad de venta al por mayor, o en practicar una política integrada de determinación de precios o de reparto de costes basándose en la consideración global del grupo. La información relacionada con los factores que hayan conducido al desarrollo de cualquiera

de estas políticas puede ayudar a la multinacional a convencer a las administraciones tributarias de que sus políticas de precios de transferencia son conformes con las condiciones de las operaciones en el mercado libre. También podría ser útil explicar la selección y aplicación del método de precios de transferencia, así como su coherencia con el principio de plena competencia. Se debe mencionar a este respecto que la información más útil para determinar precios de plena competencia puede variar en función del método utilizado.

5.20 Entre las circunstancias especiales habría que incluir los pormenores de las operaciones de compensación que puedan incidir en la determinación del precio de plena competencia. En tal caso, es útil disponer de documentos que ayuden a describir los hechos relevantes, la conexión cualitativa entre las operaciones y la cuantificación de la compensación. La documentación que corresponda al momento en que se realiza la operación permitirá minimizar el uso de la retrospección. Como se señaló en el Capítulo III, puede darse una operación de compensación, por ejemplo, cuando el vendedor suministra bienes a un precio inferior porque el comprador le presta servicios gratuitamente; cuando se fija un canon superior para compensar una reducción intencionada en los precios de los bienes, o cuando se concluye un acuerdo de cesión recíproca, y exenta de canon, para el uso de propiedad industrial o de conocimientos prácticos –*know-how*–.

5.21 La estrategia de gestión o el tipo de empresa podrían constituir otras circunstancias especiales. Pueden citarse como ejemplos la actividad del contribuyente que persigue la penetración en un mercado, el incremento de la cuota de mercado, la introducción de nuevos productos en el mercado o eludir un aumento en la competencia.

5.22 Las condiciones comerciales generales o del sector que afectan al contribuyente también pueden ser relevantes. La información relevante puede incluir también aquella explicativa del entorno comercial de ese momento y los cambios previstos, la influencia de estas previsiones en el sector en que opera el contribuyente, la dimensión del mercado, las condiciones de competencia, el marco regulador, el progreso tecnológico y el mercado de cambio de divisas.

5.23 La información acerca de las funciones desempeñadas (teniendo en cuenta los activos utilizados y los riesgos asumidos) puede ser útil para el análisis funcional que normalmente se practica para aplicar el principio de plena competencia. Las funciones comprenden la fabricación, el montaje, la gestión de compras y de material, la comercialización, las ventas al por mayor, los controles de existencias, la gestión de garantías, la publicidad y la comercialización, las actividades de transporte y de almacenaje, las

condiciones de los préstamos y los términos de pagos, la formación y la gestión de personal.

5.24 Los posibles riesgos asumidos que se contemplan en el análisis funcional pueden abarcar los riesgos de variación de los costes, de los precios o de las existencias, los riesgos referidos al éxito o al fracaso de actividades de investigación y desarrollo, los riesgos financieros, incluyendo los relativos a las alteraciones en los tipos de cambio y a los tipos de interés, los riesgos derivados de las condiciones de préstamos y pagos, los riesgos propios de la responsabilidad en la fabricación y los riesgos empresariales ligados a la propiedad de los activos y de las instalaciones.

5.25 La información financiera puede ser útil igualmente cuando resulta necesario comparar beneficios y pérdidas entre empresas asociadas con las que el contribuyente mantiene operaciones sometidas a las normas sobre precios de transferencia. Esta información puede incluir la documentación explicativa de los beneficios y las pérdidas en la medida necesaria para valorar si la política de precios de transferencia de un grupo multinacional es adecuada. De la misma manera, podría comprender documentos relativos a los gastos soportados por empresas asociadas extranjeras, como los gastos de promoción de ventas o de publicidad.

5.26 Asimismo, la empresa asociada extranjera podría disponer de información financiera útil, que podría consistir en informes sobre costes de fabricación, de investigación y desarrollo o sobre gastos generales y de administración.

5.27 También puede resultar útil contar con documentos que sirvan para mostrar el proceso de negociación conducente a la determinación o revisión de los precios de las operaciones vinculadas. Cuando los contribuyentes negocian con empresas asociadas la determinación o revisión de un precio, pueden resultar interesantes los documentos referidos a las previsiones sobre beneficios y sobre los gastos administrativos y de ventas en los que incurren las filiales extranjeras, como los gastos de personal, amortización, comercialización, distribución o transporte, y que explican cómo se determinan los precios de transferencia; por ejemplo, deduciendo, para las filiales, los márgenes brutos de los precios de venta estimados para los consumidores finales.

D. Resumen de las recomendaciones sobre documentación

5.28 Los contribuyentes deben esforzarse razonablemente al determinar sus precios de transferencia y comprobar si resultan apropiados a efectos

fiscales de conformidad con el principio de plena competencia. Las administraciones tributarias deben poder obtener la documentación elaborada o utilizada en este proceso con el fin de comprobar el cumplimiento del principio de plena competencia. Sin embargo, las necesidades de documentación deben concretarse aplicando los principios de gestión empresarial prudente que regirían el análisis de cualquier decisión empresarial de un nivel de complejidad e importancia similares. Es más, debe sopesarse la necesidad de documentación frente a los costes y cargas administrativas que conlleva, especialmente cuando este proceso implique la elaboración de documentos que, en otras circunstancias, no se prepararían ni se utilizarían en ausencia de estas consideraciones tributarias. Las obligaciones de documentación no deben implicar costes y cargas desproporcionadas a las circunstancias para los contribuyentes. No obstante, estos deben ser conscientes de que las prácticas adecuadas de registro de operaciones y la presentación voluntaria de documentos facilitan las inspecciones y la resolución de los problemas de precios de transferencia que puedan surgir.

5.29 Las administraciones tributarias y los contribuyentes deben comprometerse a cooperar más estrechamente en materia de documentación, con el objeto de evitar obligaciones excesivas al respecto, permitiendo a la vez contar con información relevante para que el principio de plena competencia pueda aplicarse correctamente. Los contribuyentes deberían facilitar la información necesaria que obrara en su poder y las administraciones tributarias deben reconocer que, en algunos casos, pueden recurrir a sus disposiciones sobre intercambio de información, lo que permite reducir la necesidad de requerir al contribuyente durante una inspección. El Comité de Asuntos Fiscales se propone realizar un estudio más detallado en materia de documentación, a fin de desarrollar unas pautas adicionales que puedan ayudar a los contribuyentes y a las administraciones tributarias en esta área.

Capítulo VI

Consideraciones específicas aplicables a los activos intangibles

A. Introducción

6.1 Este capítulo revisa las consideraciones específicas que se plantean al examinar si las condiciones fijadas o impuestas en las operaciones entre empresas asociadas en las que intervienen activos intangibles se ajustan al principio de plena competencia. Es correcto prestar una atención especial a las operaciones relativas a activos intangibles, puesto que su evaluación con fines tributarios suele resultar difícil. Se examinará la aplicación de los métodos apropiados, basados en el principio de plena competencia, para la determinación de los precios de transferencia en las operaciones en las que intervienen activos intangibles empleados en actividades comerciales, comprendidas las de comercialización. También se estudiarán los problemas específicos que surgen cuando las empresas dedicadas a la comercialización no son las propietarias de los intangibles de comercialización, tales como las marcas o los nombres comerciales. Los acuerdos de reparto de costes adoptados entre empresas asociadas y aplicados a los gastos en investigación y desarrollo que pueden generar activos intangibles se estudian en el Capítulo VIII.

6.2 En el ámbito de este capítulo la expresión "activos intangibles" abarca los derechos de utilización de activos industriales tales como las patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, dibujos o modelos. Asimismo, comprende la propiedad literaria y artística y la propiedad intelectual, como los conocimientos prácticos -know-how- y los secretos mercantiles. Este capítulo se centra en la propiedad industrial; esto es, en los intangibles asociados a actividades comerciales, incluyendo las de comercialización. Estos intangibles son activos que pueden tener un valor considerable, aunque carezcan de valor contable en el balance de la sociedad. También pueden entrañar riesgos importantes (por ejemplo, la responsabilidad contractual o sobre los productos y daños medio-ambientales).

B. Intangibles comerciales

B.1 *Términos generales*

6.3 Los intangibles comerciales incluyen las patentes, los conocimientos prácticos -know-how-, los diseños y los modelos que se utilizan para la producción de un bien o la prestación de un servicio, así como los intangibles que constituyen por sí mismos activos de una empresa transferidos a sus clientes o utilizados en la explotación de la actividad económica (por ejemplo, las aplicaciones informáticas -software-). Los intangibles de comercialización son un tipo especial de intangibles comerciales de naturaleza distinta, como se estudiará más adelante. A efectos de clarificación, los intangibles comerciales distintos de los de comercialización se denominan intangibles mercantiles. A menudo, estos últimos son el resultado de actividades arriesgadas y costosas de investigación y desarrollo (I+D), y quien los ha desarrollado, normalmente, trata de recuperar los gastos incurridos en estas operaciones y de obtener un beneficio por la venta de esos productos o por la ejecución de esos contratos de prestación de servicios o de licencia. Quien realice la labor de desarrollo de los intangibles puede ejercer la actividad de investigación en nombre propio, es decir, con la intención de tener la propiedad jurídica y económica de todo intangible mercantil que se derive de esa actividad de I+D, en representación de uno o varios miembros del grupo, en virtud de un contrato de investigación en el que el beneficiario o los beneficiarios dispongan de la propiedad jurídica y económica del intangible, o en representación de uno o varios miembros del grupo y suya propia en el marco de un acuerdo conforme al que los intervinientes desarrollan una actividad conjunta y tienen la propiedad económica del intangible (véase también el Capítulo VIII sobre acuerdos de reparto de costes). Las licencias recíprocas (licencias cruzadas) son frecuentes y también pueden darse otros acuerdos más complejos.

6.4 Los intangibles de comercialización comprenden las marcas comerciales y los nombres comerciales que ayudan en la explotación comercial de un producto o servicio, las listas de clientes, los canales de distribución y las denominaciones, símbolos o grafismos únicos que tienen un importante valor promocional para el producto en cuestión. Algunos intangibles de comercialización (por ejemplo, las marcas comerciales) pueden estar protegidas por la ley del país que corresponda y no pueden utilizarse si no es con la autorización del propietario en lo que se refiere a los productos o servicios a los que concierne. El valor de los intangibles de comercialización depende de numerosos factores; entre ellos, la reputación y credibilidad del nombre comercial o de la marca, favorecidas por la calidad

de los bienes y servicios prestados en el pasado bajo ese nombre comercial o esa marca, la importancia del control de calidad y del esfuerzo en I+D; la distribución y disponibilidad de los bienes o servicios comercializados; el alcance y el éxito de los gastos de promoción destinados a familiarizar a los clientes potenciales con los bienes o los servicios (en particular, los gastos de publicidad y de comercialización incurridos para desarrollar una red de relaciones de apoyo con los distribuidores, agentes u otros establecimientos auxiliares); el valor del mercado al que esos intangibles de comercialización permiten acceder y la naturaleza de los derechos que les confiere la ley.

6.5 La propiedad intelectual, como los conocimientos prácticos *-know-how-* y los secretos mercantiles, puede tomar la forma de intangible mercantil o de comercialización. Los conocimientos prácticos *-know-how-* y los secretos mercantiles son informaciones o conocimientos de posesión exclusiva, que facilitan o mejoran una actividad comercial pero que no son registrables a efectos de su protección, como lo son las patentes o las marcas comerciales. La expresión “conocimientos prácticos *-know-how-*” es quizás un concepto poco preciso. El apartado 11 de los Comentarios al artículo 12 del Modelo de Convenio tributario de la OCDE la define del siguiente modo: “Normalmente [los “conocimientos prácticos *-know-how-*”] son información [no divulgada] de carácter industrial, comercial o científico, nacida de experiencias previas, que tiene aplicaciones prácticas en la explotación de una empresa, y de cuya comunicación puede derivarse un beneficio económico”. Por tanto, los conocimientos prácticos *-know-how-* pueden incluir fórmulas y procesos secretos u otras informaciones secretas que abarquen la experiencia industrial, comercial o científica no incluida en una patente. Cualquier divulgación de los conocimientos prácticos *-know-how-* o de los secretos mercantiles podría reducir sensiblemente el valor de estos activos. Los conocimientos prácticos *-know-how-* y los secretos mercantiles juegan, a menudo, un papel importante en las actividades comerciales de los grupos multinacionales.

6.6 Debe tenerse cuidado en la determinación de la existencia de un intangible mercantil o de comercialización. Por ejemplo, no todos los gastos de I+D generan intangibles mercantiles valiosos, ni todas las actividades de comercialización resultan necesariamente en la creación de un intangible de comercialización. Puede ser difícil determinar en qué medida un gasto concreto ha permitido obtener un activo empresarial y calcular los efectos económicos de este activo para un ejercicio dado.

6.7 Por ejemplo, las actividades de comercialización pueden comprender un amplio abanico de actividades, tales como los estudios de mercado, el diseño o planificación de productos adecuados para las necesidades del mercado, las estrategias de venta, las relaciones públicas, las

ventas, los servicios y el control de calidad. Algunas de estas actividades pueden no tener consecuencias más allá del ejercicio en el curso del cual se desempeñan, de forma que convendría calificarlas de gastos corrientes del ejercicio y no como gastos capitalizables. Otras actividades pueden tener efectos tanto a corto como a largo plazo. El tratamiento que se dé a estas actividades será probablemente determinante cuando se efectúe el análisis funcional para apreciar la comparabilidad a efectos del análisis de precios de transferencia. En algunos casos, se puede tratar de recuperar los costes de las actividades de comercialización y, con respecto a las actividades mercantiles, los gastos de I+D, mediante un recargo en el precio de los bienes y servicios. En otros casos puede desarrollarse un activo intangible que genere el cobro de un canon específico; aunque también es posible una combinación de ambos métodos.

B.2 Ejemplos: patentes y marcas comerciales

6.8 Las diferencias entre los intangibles mercantiles y los de comercialización pueden detectarse en una comparación entre patentes y marcas comerciales. Las patentes afectan esencialmente a la producción de bienes (que pueden venderse o utilizarse en la prestación de servicios), en tanto que las marcas comerciales se emplean para la promoción de ventas de bienes o servicios. Una patente confiere a su dueño el derecho exclusivo del uso de una determinada invención durante un período limitado. Una marca comercial puede existir de forma indefinida; su protección sólo desaparece en circunstancias particulares (renuncia voluntaria, falta de renovación en plazo, cancelación o anulación por decisión judicial, etc.). Una marca comercial es una denominación, símbolo o grafismo único que su propietario o licenciatario puede utilizar para identificar productos o servicios específicos de un fabricante o mayorista determinado y cuyo corolario es la prohibición de su uso por terceras partes con fines similares, en virtud de la legislación nacional e internacional. Las marcas comerciales pueden conferir a los bienes o servicios a los que se refieren una posición importante en el mercado, con independencia del carácter único o no de esos productos o servicios. Las patentes pueden crear una situación de monopolio para ciertos productos o servicios, mientras que las marcas no pueden hacerlo por sí mismas, puesto que los competidores pueden vender los mismos productos o productos similares siempre que utilicen signos distintivos diferentes.

6.9 Las patentes suelen ser el resultado de trabajos de I+D arriesgados y costosos y quien los desarrolla intentará recuperar parte de los gastos en los que ha incurrido (y obtener un beneficio) por medio de la venta de los productos cubiertos por la patente, a través de acuerdos de licencia con

terceros para el uso de su invención (normalmente un producto o proceso), o a través de la venta pura y simple de la patente. El coste del procedimiento jurídico para la creación de una nueva marca (o para la introducción en un determinado mercado de una marca nueva) no suele ser muy elevado. Sin embargo, dotarla de valor y tratar de mantenerlo (o incrementarlo) suele ser una actividad muy cara. Normalmente será necesario recurrir a campañas publicitarias intensivas y costosas, así como a otras actividades de comercialización, y a gastos para el control de la calidad del producto vendido con esa marca. El valor de la marca y sus variaciones dependerá, en cierta medida, de la eficacia de los esfuerzos de promoción en los mercados en los que se emplea. El valor también dependerá de la reputación del propietario en cuanto a la calidad en la fabricación, de la prestación de servicios y de las medidas adoptadas para mantener esta reputación. En algunos casos, el valor de la marca comercial para el licenciador puede aumentar como consecuencia de los esfuerzos y gastos realizados por el licenciario. Por otro lado, la calidad excepcional de las patentes puede ser un instrumento muy eficaz de comercialización análogo al de una marca y los pagos por el derecho de uso de esas patentes deben verse como si se tratara de pagos efectuados por el derecho de uso de una marca comercial.

6.10 Las marcas comerciales pueden aplicarse sobre productos específicos o sobre una línea de productos. Son quizás más habituales en el mercado de consumidores finales, pero pueden encontrarse en todos los niveles del mercado. Los servicios también pueden prestarse bajo una marca determinada. Por lo general, las marcas comerciales pertenecen a una sola persona, por ejemplo a una sociedad jurídicamente independiente. Un nombre comercial (a menudo, el nombre de una empresa) puede tener la misma fuerza de penetración que una marca comercial y registrarse específicamente al igual que esta. Por ejemplo, los nombres de ciertas empresas multinacionales en el sector farmacéutico o de la electrónica tienen un gran valor en la promoción de ventas y pueden utilizarse para la comercialización de un gran número de bienes y servicios. Los nombres de personajes conocidos, diseñadores, deportistas, actores, personalidades del mundo del espectáculo, etc., pueden asociarse también con nombres comerciales o con marcas y constituyen, a menudo, instrumentos de comercialización particularmente eficaces.

6.11 Las marcas comerciales pueden venderse, cederse vía licencia o transferirse de cualquier otro modo de una persona a otra. En la práctica se acuerdan distintos tipos de contratos de licencia. Un distribuidor puede estar autorizado a utilizar una marca comercial sin acuerdo de licencia para la venta de productos fabricados por el propietario de esa marca comercial, pero la licencia de la marca comercial también se ha convertido en una

práctica habitual, especialmente en el marco del comercio internacional. De este modo, el propietario de una marca comercial puede otorgar una licencia a una empresa que la utiliza para bienes que ella misma produce o que obtiene de otras fuentes (del licenciador, por ejemplo, cuando los bienes o sus componentes se adquieren de forma genérica en el marco de una operación separada sin marca comercial). Los términos y condiciones de los acuerdos de licencia pueden ser extremadamente diversos.

6.12 A veces es difícil distinguir de forma clara entre las rentas procedentes de los intangibles mercantiles y de los de comercialización. Por ejemplo, en los sectores industriales orientados hacia la investigación, la marca y el nombre comercial son componentes esenciales si se pretende garantizar ingresos suficientes destinados a remunerar la investigación anterior y a emprender nuevos proyectos, especialmente debido a que las patentes tienen un límite temporal. Reforzar la confianza en el nombre y hacer reconocible la marca comercial reviste una importancia vital si se quiere que el producto continúe siendo comercialmente viable una vez que la patente haya caducado, o incluso en los casos en que no se desarrolló ninguna patente. Véase la Sección D que describe los acuerdos de plena competencia en relación con intangibles de comercialización.

C. Aplicación del principio de plena competencia

C.1 *Términos generales*

6.13 Las indicaciones generales dadas en los Capítulos I, II y III para la aplicación del principio de plena competencia también son válidas para la determinación de precios de transferencia entre empresas asociadas en el caso de activos intangibles. No obstante, este principio puede parecer particularmente arduo de aplicar en operaciones vinculadas que afecten a activos intangibles, porque tales activos pueden tener un carácter específico que complique la búsqueda de comparables y, en ocasiones, dificulte la determinación del valor en el momento de la operación. En ese mismo sentido, por razones mercantiles plenamente legítimas atendiendo a las relaciones entre ellas, las empresas asociadas pueden estructurar sus operaciones, en ciertos casos, atendiendo a una fórmula que empresas independientes no se plantearían (véanse los párrafos 1.11 y 1.64).

6.14 Para determinar el precio de plena competencia de activos intangibles, deben tenerse en cuenta, a los efectos de la comparabilidad, el punto de vista del transmitente y el del adquirente. Desde el punto de vista del transmitente, la aplicación del principio de plena competencia consistiría

en buscar el precio que una empresa independiente comparable estaría dispuesta a aceptar transferir el activo. Desde el punto de vista del adquirente, una empresa independiente comparable puede estar dispuesta o no a pagar dicho precio en función del valor y de la utilidad que tenga el intangible en cuestión para su actividad económica. El adquirente estará normalmente dispuesto a pagar este precio de licencia si el beneficio que puede esperar de la utilización de los intangibles es satisfactorio a la vista de otras opciones disponibles de modo realista. Puesto que el licenciatario deberá emprender inversiones o incurrir en otros gastos para explotar la licencia, hay que determinar si una empresa independiente estaría dispuesta a pagar el precio de una licencia por el importe considerado, teniendo en cuenta la rentabilidad esperada de las inversiones adicionales y de los otros gastos en los que probablemente deberá incurrir.

6.15 Este análisis es importante si se quiere asegurar que una empresa asociada no tenga por qué pagar por la adquisición o utilización de un activo intangible un importe calculado sobre la máxima utilidad o el máximo valor productivo, cuando dicho activo tiene una utilidad más limitada para la empresa asociada, dadas sus actividades y otros elementos significativos. En ese caso, al determinar la comparabilidad debería considerarse la utilidad del activo. Puede observarse así la importancia que reviste la consideración de todos los hechos y circunstancias en la determinación de la comparabilidad de las operaciones.

C.2 *Identificación de los acuerdos alcanzados para la transmisión de activos intangibles*

6.16 Las modalidades de transmisión de activos intangibles pueden ser diversas: venta pura y simple o, más habitualmente, el pago de un canon en el marco de un acuerdo de licencia para obtener ciertos derechos sobre los activos intangibles en cuestión. Un canon es, en general, un pago periódico fijado de conformidad con la producción, con las ventas o, en algunas ocasiones especiales, con el beneficio de quien utiliza el bien. Cuando el canon se basa en la producción o en las ventas del licenciatario, el porcentaje puede variar en función de su volumen de negocios. También ocurre que las variaciones en los hechos y circunstancias (por ejemplo, nuevos diseños o una intensificación de la publicidad de la marca realizada por su propietario) conducen a la revisión de las condiciones de la remuneración.

6.17 La remuneración por la utilización de un activo intangible puede incluirse en el precio facturado por la venta de los bienes cuando, por ejemplo, una empresa vende a otra productos no terminados, poniendo a disposición de esta última su experiencia para el procesamiento ulterior de esos

productos. La determinación de si puede presuponerse que el precio de transferencia de los bienes incluye una remuneración por licencia que, por consiguiente, implique que el país del adquirente no admita pagos adicionales en concepto de cánones, depende en gran medida de las circunstancias de cada operación, y no parece existir un principio general aplicable, salvo que no procede la doble deducción por la provisión de tecnología. El precio de transferencia puede ser un precio global, es decir, por los bienes y activos intangibles, en cuyo caso, en función de los hechos y circunstancias, el comprador no tendrá necesariamente que efectuar un pago adicional en concepto de cánones por la provisión de experiencia técnica. En los países que apliquen una retención en fuente para los cánones puede ser necesario desagregar este tipo de precios globales para calcular el importe de plena competencia del canon.

6.18 En ciertos casos, el activo intangible formará parte de un contrato global que incluya los derechos sobre las patentes, las marcas comerciales, los secretos mercantiles y los conocimientos prácticos *-know-how-*. Por ejemplo, una empresa puede conceder una licencia para todos los activos de propiedad industrial e intelectual que posee. Deberán considerarse independientemente las partes del conjunto a fin de verificar el carácter de plena competencia de la transmisión (véase el párrafo 3.11). También es importante tener en cuenta el valor de servicios tales como la asistencia técnica y la formación de empleados que puede prestar la empresa que ha desarrollado el intangible en relación con la operación. Asimismo, puede ser necesario contabilizar los beneficios que aporta el licenciatario al licenciador en forma de mejoras de productos o de procesos. Estos servicios deben valorarse aplicando el principio de plena competencia, teniendo en cuenta las disposiciones específicas aplicables a los servicios que se describen en el Capítulo VII. A estos efectos, puede ser necesario distinguir entre los distintos medios de suministro de conocimientos prácticos *-know-how-*. Los párrafos 11 a 11.6 de los Comentarios al artículo 12 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE establecen unos criterios respecto a dichos puntos.

6.19 Un contrato de conocimientos prácticos *-know-how-* y un contrato de servicios pueden ser objeto de un trato distinto en un determinado país, de acuerdo con su legislación fiscal interna o conforme a los convenios que haya suscrito con otros países. El Grupo de Trabajo número 1 sobre doble imposición y cuestiones conexas estudiará esta cuestión con mayor detalle. Por ejemplo, la procedencia o improcedencia de una retención en la fuente sobre los pagos efectuados a no residentes puede depender del modo en que se contemple el contrato. Si el pago se considera como una remuneración por servicios prestados, normalmente no se someterá a imposición en el país de fuente a no ser que la empresa beneficiaria ejerza sus actividades en ese país

por medio de un establecimiento permanente situado en él y que el pago pueda imputarse a ese establecimiento permanente. Por el contrario, en determinados países, los cánones pagados por el uso de activos intangibles se someten a imposición en la fuente.

C.3 *Cálculo de una contraprestación de plena competencia*

6.20 Cuando se aplica el principio de plena competencia a operaciones vinculadas en las que intervienen activos intangibles, habrá que tener en cuenta ciertos factores específicos que afectan a la comparabilidad entre las operaciones vinculadas y las no vinculadas. Entre estos factores se incluyen los beneficios que se espera obtener del activo intangible (que pueden determinarse por medio de un valor actualizado neto). Otros factores son: cualquier limitación en el ámbito geográfico en el que pueden ejercerse los derechos; las restricciones en la exportación de bienes por razón de la transferencia de derechos; el carácter exclusivo o no de los derechos transferidos; las inversiones de capital (para construir nuevas plantas o adquirir maquinaria especial), los gastos de inicio de actividad y los trabajos de desarrollo requeridos por el mercado; la posibilidad de ceder la licencia obtenida, la red de distribución del licenciataria, así como si este último tiene derecho a participar en posteriores desarrollos del activo efectuados por el licenciador.

6.21 Cuando el activo intangible es una patente, el análisis de comparabilidad deberá atender a la naturaleza de esta patente (por ejemplo, patente de producto o de proceso) y al grado y período de protección que establece el derecho de patentes en los países a los que atañe, teniendo en cuenta que pueden desarrollarse rápidamente nuevas patentes basadas en las anteriores, de tal modo que la protección efectiva del activo intangible pueda prolongarse considerablemente. No sólo es importante la duración de la protección legal, sino también el período durante el cual las patentes son susceptibles de conservar su valor económico. Una patente absolutamente nueva y original que representa un “avance muy importante” puede convertir rápidamente en obsoletas a las patentes existentes y justificar un precio superior que el que se establezca para una patente destinada a mejorar un proceso ya cubierto por una patente preexistente o un proceso para el que fácilmente pueden encontrarse sustitutos.

6.22 Otros factores relativos a las patentes son el proceso de producción en el que se usan los activos, así como el valor que aporta este proceso al producto final. Por ejemplo, cuando una invención patentada sólo abarca un elemento de un dispositivo, no sería apropiado calcular el canon correspondiente a la invención tomando como referencia el precio de venta

del producto completo. En ese caso, un canon basado en una fracción del precio de venta debería tener en cuenta el valor relativo de ese componente respecto de los restantes componentes del producto. Por otra parte, en un análisis de las funciones desempeñadas (incluyendo activos empleados y riesgos asumidos) para las operaciones en las que intervienen activos intangibles, los riesgos considerados deberían incluir la responsabilidad ambiental y la derivada del producto, que están adquiriendo una importancia creciente.

6.23 Para determinar un precio de plena competencia en el caso de una venta o de la concesión de una licencia relativa a un activo intangible, cabe utilizar el método del precio libre comparable cuando el mismo propietario haya transmitido o licenciado activos intangibles comparables en condiciones comparables a empresas independientes. Podría servir de pauta la información relativa a la contraprestación exigida en operaciones comparables entre dos empresas independientes del mismo sector, cuando se disponga de ella, y puede que sea adecuado determinar un rango de precios. Asimismo, pueden tenerse en cuenta las ofertas efectuadas a partes independientes o las pujas auténticas de licenciarios que compitan. Si la empresa asociada cede el activo objeto de licencia a terceras partes, también será posible aplicar de alguna forma el método del precio de reventa para analizar los términos de la operación vinculada.

6.24 En el caso de venta de bienes que incorporan activos intangibles, también es posible utilizar el método del precio libre comparable o el del precio de reventa siguiendo los principios del Capítulo II. Cuando intervienen intangibles de comercialización (por ejemplo, una marca comercial), el análisis de comparabilidad debe considerar el valor añadido por la marca comercial, teniendo en cuenta su aceptación por los consumidores, la extensión del ámbito geográfico de aplicación, sus cuotas de mercado, su volumen de ventas y otros factores pertinentes. Cuando intervienen intangibles mercantiles el análisis de comparabilidad debería además prestar atención al valor atribuible a esos intangibles (patente protegida u otros intangibles exclusivos) y la importancia de las actividades de I+D en curso.

6.25 Por ejemplo, puede que unas zapatillas de deporte de marca, objeto de una operación vinculada, sean comparables a unas zapatillas de deporte de una marca distinta objeto de una operación no vinculada, tanto en términos de calidad como por las características de las zapatillas mismas y también en términos de aceptabilidad por el consumidor y por otras características de la marca comercial en este mercado. Cuando esta comparación es inviable, puede ser útil también, si se dispone de evidencias adecuadas, comparar el volumen de ventas, los precios facturados y los beneficios obtenidos por los

productos de marca con los relativos a productos similares sin marca. Por lo tanto, es posible utilizar las ventas de los productos sin marca como operaciones comparables a las ventas de productos con marca, siempre que sean comparables en los restantes aspectos, pero sólo en la medida en que puedan efectuarse los ajustes necesarios que subsanen el valor que añade la marca. Por ejemplo, unas zapatillas de deporte de marca "A" pueden ser comparables en todos los aspectos a unas zapatillas de deporte sin marca (tras ajustes), excepto en lo que se refiere a la marca. En este caso, la prima atribuible a la marca podría determinarse mediante la comparación de una zapatilla sin marca que presente características distintas, objeto de transmisión en una operación no vinculada, con su equivalente de marca, también transmitida en una operación no vinculada. Será entonces posible utilizar esta información para determinar el precio de la zapatilla de marca "A", si bien pueden ser necesarios ciertos ajustes que subsanen el efecto de la diferencia de características en el valor de la marca. No obstante, los ajustes pueden resultar especialmente difíciles cuando un producto de marca domina el mercado de modo tal que el producto genérico se dirige esencialmente a un mercado distinto, especialmente cuando se trata de productos sofisticados.

6.26 Cuando intervienen activos intangibles de gran valor puede ser complicado identificar operaciones comparables entre empresas independientes. Por tanto, será difícil aplicar los métodos tradicionales basados en las operaciones y el método del margen neto operacional, sobre todo cuando las dos partes de la transacción poseen activos intangibles de gran valor o activos únicos, empleados en la operación, que la distinguen de las operaciones de sus competidores potenciales. En estos casos, el método de la distribución del resultado puede ser adecuado, aunque su aplicación puede plantear problemas.

6.27 Para determinar si las condiciones de una operación en la que intervienen activos intangibles se ajustan al principio de plena competencia deben examinarse el importe, la naturaleza y los efectos de los costes incurridos en el desarrollo o conservación del activo intangible, a fin de determinar la comparabilidad o el posible valor relativo de las aportaciones de cada parte, especialmente cuando se opta por el método de la distribución del resultado. Sin embargo, no tiene por qué existir una relación necesaria entre los costes y el valor. En particular, el valor real de mercado del activo intangible no suele ser cuantificable en relación con los costes incurridos en el desarrollo y conservación del activo. Una de las razones es que los activos intangibles, como las patentes y los conocimientos prácticos *-know-how-*, pueden ser el resultado de actividades de I+D prolongadas y costosas. La dotación de los presupuestos de I+D depende de distintos factores, entre ellos la política seguida por los competidores reales o potenciales, la rentabilidad

esperada de la actividad de investigación y la tendencia de los beneficios; o de consideraciones basadas en el volumen de negocios o en la evaluación del rendimiento de las anteriores actividades de I+D como base para determinar los niveles de gasto futuro. Los presupuestos de I+D pueden financiarse con las ventas de los propios productos aunque dichos productos no tengan una relación directa, o ni siquiera indirecta, con el resultado de la actividad de I+D. Otra razón es que los activos intangibles pueden requerir gastos constantes de I+D y controles de calidad de los que pueden beneficiarse una amplia gama de productos.

C.4 *Determinación del precio de plena competencia cuando la valoración es muy incierta en el momento de la operación*¹

6.28 Como se ha indicado al principio de esta Sección, los activos intangibles a veces son muy específicos, de forma que es difícil tanto encontrar comparables como, en ciertos casos, valorar los activos en el momento de la operación vinculada. Cuando la valoración de activos intangibles en el momento de la operación es muy incierta, el problema que se plantea es cómo determinar el precio de plena competencia. La cuestión pueden resolverla tanto los contribuyentes como las administraciones tributarias tomando como referencia la actuación de las empresas independientes en circunstancias comparables a efectos de reflejar en la determinación del precio de la operación la incertidumbre de la valoración.

6.29 En función de los hechos y circunstancias, las empresas independientes pueden actuar de distintas formas para afrontar el problema de la incertidumbre en la valoración al determinar el precio de una operación. Una de las posibilidades consiste en utilizar los beneficios previsibles (teniendo en cuenta todos los factores económicos pertinentes) como medio para determinar el precio inicial de la operación. Para determinar los beneficios previsibles, las empresas independientes tendrían en cuenta en qué medida es predecible y determinable la evolución futura. En algunos casos las empresas independientes juzgarán que las previsiones de beneficios son suficientemente fiables para determinar el precio de la operación desde el inicio en función de esas previsiones, sin reservarse el derecho de efectuar ajustes en el futuro.

6.30 En otros casos, las empresas independientes juzgarán que la determinación del precio basándose exclusivamente en los beneficios

¹ En el Anexo al Capítulo VI se recoge un ejemplo que ilustra la aplicación del principio de plena competencia a activos intangibles de valoración muy incierta.

previsibles no constituye protección suficiente contra los riesgos vinculados a la alta incertidumbre que rodea la valoración de un activo intangible. En esos casos, las empresas independientes podrán optar por contratos de corta duración o incluir en sus contratos cláusulas de revisión de precios, a fin de protegerse contra acontecimientos impredecible. Por ejemplo, el tipo del canon podrá incrementarse a medida que aumenten las ventas del licenciatario.

6.31 También cabe el supuesto de que empresas independientes decidan asumir hasta cierto punto el riesgo de acontecimientos imprevisibles, eso sí, en el entendimiento común de que los imprevistos que modifiquen las hipótesis críticas empleadas en la determinación de los precios conducirán a la renegociación pactada de los acuerdos alcanzados para su determinación. Por ejemplo, una renegociación de este tipo podría ser conforme a las condiciones de plena competencia si el tipo del canon calculado en función de las ventas de un medicamento patentado resultara sumamente excesivo debido al desarrollo inesperado de un tratamiento alternativo de coste más reducido. El canon excesivo puede provocar que el licenciatario deje de tener interés en fabricar el fármaco, lo cual podría justificar una renegociación del contrato (aunque si esto realmente ocurriera dependería de todos los hechos y circunstancias).

6.32 Cuando una administración tributaria evalúa el precio de una operación vinculada en la que interviene un activo intangible, cuya valoración inicial era muy incierta, debe basarse en los acuerdos que hubieran adoptado empresas independientes en circunstancias comparables. Por tanto, si las empresas independientes hubiesen fijado el precio basándose en una cierta previsión, la administración tributaria debería seguir el mismo método para la determinación de los precios. En este caso, la administración tributaria podría, por ejemplo, investigar si las empresas asociadas han realizado adecuadamente o no sus previsiones, teniendo en cuenta el conjunto de los acontecimientos razonablemente previsibles, sin recurrir a la retrospcción.

6.33 La administración tributaria posiblemente encuentre ciertas dificultades, especialmente si el contribuyente no coopera, en la determinación de cuáles eran los beneficios razonablemente previsibles en el momento en que se cerró la operación. Cabe suponer, por ejemplo, que un contribuyente transfiera un intangible a una empresa asociada en una etapa inicial, fije un canon que no refleja el valor posteriormente demostrado de dicho intangible a efectos fiscales o con otros propósitos, y posteriormente alegue que en el momento de la operación no era posible prever el éxito posterior del producto. En ese caso, la administración tributaria, a la vista de los acontecimientos ulteriores, podría informarse sobre el modo en que

hubieran actuado empresas independientes sobre la base de la información razonablemente disponible en el momento de la operación. En particular, habría que plantearse si las empresas asociadas tuvieron o no la intención de hacer previsiones que empresas independientes hubieran juzgado adecuadas, y si las hicieron efectivamente teniendo en cuenta los acontecimientos razonablemente previsibles y el riesgo de acontecimientos imprevisibles; y si las empresas independientes hubieran insistido en fijar algunas protecciones adicionales contra el riesgo vinculado a la incertidumbre de la valoración.

6.34 En el caso de que en circunstancias comparables las empresas independientes hubieran optado por una cláusula de revisión de precios, la administración tributaria debería tener la posibilidad de fijar el precio basándose en una cláusula de ese tipo. Asimismo, en el caso de que las empresas independientes hubieran juzgado imprevisibles acontecimientos ulteriores tan importantes que su acaecimiento hubiera provocado una renegociación futura del precio fijado para la operación, estos acontecimientos deberían también modificar el precio de una operación vinculada comparable entre empresas asociadas.

6.35 Hay que admitir que las administraciones tributarias pueden no ser capaces de llevar a cabo una comprobación de la declaración del contribuyente hasta después de transcurridos unos cuantos ejercicios desde su presentación. En ese caso, la administración tributaria tendrá el derecho de ajustar la contraprestación respecto de todos los ejercicios abiertos hasta el momento de la comprobación, sobre la base de la información que hubieran utilizado empresas independientes en situaciones comparables para la determinación del precio.

D. Actividades de comercialización realizadas por empresas que no son propietarias de una marca comercial o de un nombre comercial

6.36 Pueden plantearse problemas especialmente delicados de precios de transferencia cuando las actividades de comercialización las realizan empresas que no son propietarias de la marca o del nombre comercial que están promocionando (por ejemplo, distribuidores de productos de marca). En ese caso hay que determinar el modo de remunerar adecuadamente a la comercializadora por esas actividades. Se trata de discernir si debe remunerársela en calidad de proveedora de servicios, es decir, por los servicios promocionales realizados, o si en ciertos casos podría obtener una remuneración adicional atribuible a los intangibles de comercialización. Otra

cuestión conexas es cómo identificar los rendimientos atribuibles a los intangibles de comercialización.

6.37 En lo que se refiere a la primera cuestión (si la comercializadora tiene derecho a un rendimiento superior sobre los intangibles de comercialización respecto de los rendimientos normales correspondientes a las actividades de comercialización), habrá que analizar los derechos y obligaciones adquiridos por las partes en virtud del contrato. A menudo, el rendimiento de las actividades de comercialización será suficiente y apropiado. La situación es relativamente clara cuando el distribuidor actúa pura y simplemente como agente y el propietario del intangible de comercialización le reembolsa los gastos de promoción. En ese caso, el distribuidor sólo tendría derecho a una remuneración adecuada a sus actividades de agente y no podría beneficiarse de un porcentaje de los ingresos atribuibles al intangible de comercialización.

6.38 Cuando el distribuidor soporte efectivamente el coste de esas actividades de comercialización (es decir, cuando no haya acuerdo por el cual el propietario deba reembolsar los gastos), el problema que se plantea es saber en qué medida el distribuidor puede beneficiarse de un porcentaje de los beneficios potenciales derivados de esas actividades. En general, en el ámbito de las operaciones de plena competencia, la capacidad de una parte que no es propietaria de un intangible de comercialización para obtener los beneficios futuros de las actividades de comercialización que incrementan el valor de ese intangible dependerá básicamente de la esencia de los derechos de esa parte. Por ejemplo, un distribuidor puede obtener beneficios de sus inversiones en el desarrollo del valor de una marca comercial, respecto del volumen de ventas y de la cuota de mercado, cuando intervenga en virtud de un contrato a largo plazo de distribución exclusiva del producto de marca. En dichos casos, la participación del distribuidor en los beneficios debe determinarse tomando como referencia lo que hubiera obtenido un distribuidor independiente en circunstancias comparables. En ciertos casos, un distribuidor podría incurrir en gastos de comercialización extraordinarios que excedan aquellos en los que hubiera incurrido un distribuidor independiente con derechos similares en beneficio de su propia actividad de distribución. En tal caso, un distribuidor independiente podría obtener del propietario de la marca un rendimiento adicional, quizá mediante la disminución del precio de compra del producto o mediante una reducción en el porcentaje del canon.

6.39 La segunda cuestión es la relativa a la identificación del rendimiento imputable a las actividades de comercialización. Un intangible de comercialización puede generar valor gracias a las campañas de publicidad y demás gastos de promoción, que pueden ser importantes para

preservar el valor de una marca. Sin embargo, puede ser difícil determinar en qué medida contribuyen estos gastos al éxito del producto. Por ejemplo, cuáles son los gastos de publicidad y de comercialización que han contribuido a la producción o a la generación de rentas, y en qué medida. También es posible que una nueva marca comercial, o una marca recientemente introducida en un mercado determinado, carezca de valor o tenga muy poco en este mercado, y que su valor aumente con el tiempo (o disminuya) en función de su presencia en el mismo. Una cuota de mercado dominante puede atribuirse, en cierta medida, a los esfuerzos de comercialización del distribuidor. El valor de una marca y sus variaciones dependerá en algún grado de la eficacia de su promoción en el mercado considerado. Aun resulta más importante el hecho de que, muy a menudo, el aumento de los rendimientos procedentes de la venta de productos de marca se debe tanto a las características específicas del producto o a su alta calidad como al éxito de las campañas de publicidad y demás gastos de promoción. Para valorar el rendimiento imputable a las actividades de comercialización, habrá que prestar atención al comportamiento efectivo de las partes durante varios ejercicios; véanse a este respecto los párrafos 3.75 a 3.79 (datos sobre varios ejercicios).

Capítulo VII

Cuestiones de aplicación específica a los servicios intragrupo

A. Introducción

7.1 Este capítulo analiza los problemas que se plantean en materia de precios de transferencia para determinar si un miembro de un grupo multinacional ha prestado servicios a otros miembros de ese grupo y, en caso afirmativo, al fijar el precio de plena competencia aplicable a esos servicios intragrupo. Este capítulo no trata, excepto de forma incidental, si los servicios se han prestado en aplicación de un acuerdo de reparto de costes, conforme al que los miembros de un grupo multinacional adquieren, producen o suministran conjuntamente, bienes, servicios o activos intangibles, compartiendo los costes de estas actividades entre las distintas partes firmantes del acuerdo y, de ser así, no intentará determinar el precio de plena competencia apropiado. Los acuerdos de reparto de costes son objeto del Capítulo VIII.

7.2 Casi todos los grupos multinacionales deben poner a disposición de sus miembros un amplio abanico de servicios, especialmente administrativos, técnicos, financieros y comerciales. Estos servicios pueden incluir las funciones de gestión, coordinación y control para el conjunto del grupo. La sociedad matriz, un miembro del grupo especialmente designado ("un centro de servicios del grupo") u otro miembro del grupo, pueden asumir inicialmente el coste de la prestación de estos servicios. Una empresa independiente que necesite un servicio puede adquirírselo a un proveedor de servicios especializado o encargarse ella misma de su prestación (es decir, internamente). De modo similar, un miembro de un grupo multinacional que necesite un servicio, puede adquirirlo directa o indirectamente de empresas independientes o de una o varias empresas asociadas del mismo grupo multinacional (es decir, intragrupo), o ejecutar el servicio él mismo. Frecuentemente, los servicios intragrupo incluyen aquellos que pueden prestar externamente empresas independientes (como son los servicios jurídicos o contables), así como los que suelen prestarse internamente (por ejemplo, los servicios prestados por la propia empresa tales como la auditoría central, la asesoría financiera o la formación del personal).

7.3 Los acuerdos intragrupo para la prestación de servicios se encuentran, a veces, vinculados a acuerdos de transmisión de bienes o de activos intangibles (o a la cesión mediante licencia de los mismos). En ciertos casos, como los contratos de conocimientos prácticos *-know-how-* que contienen un elemento de servicio, puede ser difícil determinar el límite preciso entre la transmisión o la cesión vía licencia del activo por una parte y la transferencia de servicios por otra. Las transferencias de tecnología suelen estar asociadas a la prestación de servicios auxiliares. Por consiguiente, puede entonces ser necesario considerar los principios de agregación y segregación de operaciones del Capítulo III en los casos de transmisión mixta de servicios y activos.

7.4 La actividad de servicios intragrupo puede variar considerablemente entre los grupos multinacionales, al igual que la medida en la que dichas actividades proporcionan un beneficio, o un beneficio esperado, para uno o varios miembros del grupo. Cada caso dependerá de sus propios hechos y circunstancias y de los acuerdos alcanzados en el seno del grupo. Por ejemplo, en un grupo descentralizado, la sociedad matriz podrá limitar sus actividades intragrupo al seguimiento de sus inversiones en sus filiales en su calidad de accionista. Por contra, en un grupo centralizado o integrado, el consejo de dirección y la dirección general de la sociedad matriz podrán tomar todas las decisiones importantes relativas a las actividades de las filiales, y la sociedad matriz puede desempeñar todas las funciones de comercialización, de formación de personal y de gestión de tesorería.

B. Principales problemas

7.5 En el análisis para la determinación de los precios de transferencia de los servicios intragrupo se plantean dos problemas. El primero es saber si el servicio se ha prestado realmente. El segundo, si la remuneración de esos servicios a efectos fiscales debería adecuarse al principio de plena competencia. A continuación se estudian ambos.

B.1 Concreción de los servicios intragrupo prestados

7.6 En aplicación del principio de plena competencia, la cuestión de si se ha prestado un servicio intragrupo en el ejercicio de una actividad realizada por uno o más miembros del grupo en beneficio de otro u otros, depende de si la actividad supone un interés económico o comercial para un miembro del grupo que refuerza así su posición comercial. Puede responderse a esta cuestión preguntándose si, en circunstancias comparables, una empresa independiente hubiera estado dispuesta a pagar a otra empresa

independiente la ejecución de esta actividad o si la hubiera ejecutado ella misma internamente. Si una empresa independiente no hubiera estado dispuesta a pagar por la actividad ni a ejecutarla por ella misma, en términos generales no debe considerarse como un servicio intragrupo de conformidad con el principio de plena competencia.

7.7 El análisis precedente depende, obviamente, de los hechos y circunstancias reales, no siendo posible en abstracto definir categóricamente las actividades que constituyen o no una prestación de servicios intragrupo. No obstante, pueden ofrecerse algunas indicaciones que permitan dilucidar cómo debería aplicarse el análisis a ciertas categorías comunes de actividades ejercidas en el seno de los grupos multinacionales.

7.8 Para satisfacer las necesidades identificadas de una o varias empresas que forman parte del grupo, un miembro de ese mismo grupo realiza servicios intragrupo. En este caso, se puede responder directamente a la cuestión de si se ha prestado un servicio. En general, en circunstancias comparables, una empresa independiente hubiera satisfecho la necesidad identificada ejerciendo ella misma la actividad o recurriendo a un tercero. En consecuencia, en este caso normalmente se deducirá que existe un servicio intragrupo. Por ejemplo, se determinará la existencia de un servicio intragrupo cuando una empresa asociada repara los bienes de equipo empleados por otra empresa miembro de un grupo multinacional en el ámbito de sus actividades de fabricación.

7.9 Debe procederse a un análisis más complejo cuando una empresa asociada acomete actividades que afectan a varios miembros del grupo o al conjunto del grupo. En un número reducido de casos, puede realizarse una actividad intragrupo para miembros del grupo, aun cuando estos no tengan necesidad de ella (y por lo tanto no estarían dispuestos a pagar por ella si fueran empresas independientes). Se trataría de un tipo de actividad que un miembro del grupo (normalmente, la sociedad matriz o una sociedad *holding* regional) realiza únicamente debido a sus intereses en uno o varios miembros del grupo, es decir, en su calidad de accionista. Esta clase de actividad no justificaría una retribución con cargo a las sociedades que se benefician de la misma. Cabe referirse a ellas como "actividades de accionista" a fin de diferenciarlas del concepto más amplio de "actividades de tutela" empleado en el Informe de 1979. Las actividades de tutela abarcan un conjunto de actividades ejercidas por un accionista que pueden incluir la prestación de servicios a otros miembros del grupo, por ejemplo, los servicios que prestaría un centro de coordinación. Estas últimas actividades, distintas de las "de accionista", pueden comprender servicios de planificación pormenorizados para operaciones concretas, gestión en caso de emergencia o asesoría técnica

("resolución de problemas") o, en ciertos casos, la asistencia en la gestión de las tareas cotidianas.

7.10 Los ejemplos siguientes (descritos en el Informe de 1984), constituirán actividades de accionista de acuerdo con el criterio expuesto en el párrafo 7.6:

- a) los costes de actividades relacionadas con la estructura jurídica de la sociedad matriz, tales como las juntas generales de accionistas de la sociedad matriz, la emisión de acciones de esta sociedad y los gastos del consejo de vigilancia;
- b) los costes relativos a las obligaciones de la sociedad matriz en materia de registro contable de las operaciones, incluyendo la consolidación de informes;
- c) los costes de obtención de fondos destinados a la adquisición de las participaciones;

Por el contrario, si por ejemplo una sociedad matriz obtiene fondos por cuenta de otro miembro del grupo para la adquisición de una nueva sociedad, normalmente se considera que la sociedad matriz está ofreciendo un servicio al miembro del grupo. El Informe de 1984 también citaba "los costes de actividades de gestión y control ("seguimiento") relacionados con la gestión y la protección de las inversiones representadas por las participaciones". Para determinar si estas actividades entran o no en la definición de actividades del accionista, tal y como se definen en estas Directrices, habría que saber si una empresa independiente, en circunstancias comparables, hubiera estado dispuesta a pagar por ellas o las hubiera realizado por sí misma.

7.11 En general, no deberían considerarse servicios intragrupo las actividades que lleva a cabo un miembro del grupo que se limita a duplicar un servicio que realiza por sí mismo otro miembro del grupo, o que realiza un tercero por cuenta de este otro miembro del grupo. Habría que hacer una excepción en el caso de que los servicios se dupliquen sólo temporalmente, por ejemplo, cuando un grupo multinacional se reorganiza para centralizar sus funciones de dirección. Otra excepción sería cuando la duplicación tiene como finalidad reducir el riesgo de decisiones empresariales desacertadas (por ejemplo, solicitando un segundo consejo jurídico sobre un tema).

7.12 En algunos casos, el servicio intragrupo realizado por un miembro del grupo, como un accionista o un centro de coordinación, sólo afecta a algunos miembros aunque indirectamente genere beneficios a otros miembros del grupo. Se puede citar como ejemplo el análisis de la cuestión de si es necesario reorganizar el grupo, adquirir nuevos miembros o suprimir una división. Estas actividades pueden considerarse servicios intragrupo para

los miembros a los que afecta, por ejemplo, aquellos que realicen la adquisición o que supriman una de sus divisiones, pero también pueden generar ventajas económicas para otros miembros del grupo no implicados en la decisión, aumentando la eficiencia, las economías de escala u otras sinergias. Normalmente no se considera que esos otros miembros del grupo beneficiados de forma indirecta hayan recibido un servicio intragrupo, dado que las actividades que generan los beneficios no son tales que una empresa independiente hubiera estado dispuesta a adquirir.

7.13 Asimismo, no debería considerarse que una empresa asociada se beneficia de un servicio intragrupo cuando obtiene ventajas accesorias que sólo se generan por formar parte de una empresa mayor y no por ejercer una actividad específica. Por ejemplo, no hay prestación de servicios cuando una empresa asociada, por el mero hecho de ser filial, tiene una mejor calificación crediticia que si no lo fuera; pero se considera que existe un servicio intragrupo cuando su mejor calificación crediticia se deba a un aval de otro miembro del grupo o cuando la empresa se beneficie de la reputación del grupo debido a sus campañas de comercialización y de relaciones públicas. A estos efectos, debe distinguirse entre la asociación pasiva y la promoción activa de las características del grupo multinacional que refuerza la capacidad de obtención de beneficios de determinados miembros del grupo. Hay que tener en cuenta los hechos y circunstancias que concurren en cada caso.

7.14 Las otras actividades, que pueden afectar al grupo en su conjunto, son aquellas centralizadas en la sociedad matriz o en un centro de servicios de grupo (como una cabecera regional de la compañía) y puestas a disposición del grupo (o de varios de sus miembros). Las actividades que se centralizan dependen del tipo de negocio y de la estructura organizativa del grupo pero, en general, suelen incluir servicios administrativos tales como planificación, coordinación, control presupuestario, asesoría financiera, contabilidad, auditoría, servicios jurídicos, factoraje, servicios informáticos; servicios financieros tales como la supervisión de los flujos de tesorería y de la solvencia, de los aumentos de capital, de los contratos de préstamo, de la gestión de riesgo de los tipos de interés y del tipo de cambio y refinanciación; asistencia en las áreas de producción, compra, distribución y comercialización; y servicios de gestión de recursos humanos, tales como la selección de personal y la formación. A menudo, los centros de servicio del grupo ejecutan los trabajos de I+D o gestionan y protegen los activos intangibles de una parte o del conjunto del grupo multinacional. En general, las actividades de este tipo se consideran como servicios intragrupo dado que son el tipo de actividades por las que una empresa independiente estaría dispuesta a pagar, o que ejecutaría por sí misma.

7.15 Al considerar si empresas independientes hubieran facturado la prestación de servicios, también sería importante considerar la forma que adoptaría la remuneración en condiciones de plena competencia si la operación hubiera ocurrido entre empresas independientes que operaran en el mercado libre. Por ejemplo, en lo que se refiere a servicios financieros tales como préstamos, operaciones de cambio de moneda y operaciones de cobertura, la remuneración normalmente se incorporaría en el margen, por lo que no cabe esperar que se aplique una tarifa adicional por el servicio prestado.

7.16 Se plantea otro problema en lo que se refiere a los servicios prestados “a demanda”. La cuestión es saber si la disponibilidad de estos servicios constituye un servicio distinto en sí mismo para el que habría que fijar una remuneración de plena competencia (además de la remuneración de los servicios efectivamente prestados). La sociedad matriz o el centro de servicios del grupo puede estar dispuesto a suministrar, por ejemplo, asesoría de tipo financiero, administrativo, técnico, jurídico o fiscal y asistir a todos los miembros del grupo en cualquier momento. En ese caso, el servicio consiste en poner a disposición de las empresas asociadas personal, equipos, etc. Existen servicios intragrupo en la medida en que cabe plantearse razonablemente que una empresa independiente, en circunstancias comparables, incurriría en gastos en concepto de “igual” para asegurar la disponibilidad de los servicios en cuestión cuando surja la necesidad de recurrir a ellos. No es extraño, por ejemplo, que una empresa independiente pague una “cuota” anual a un despacho de abogados que le pueda proporcionar asesoramiento jurídico y le represente en litigios. También puede citarse como ejemplo los contratos de servicios que permiten beneficiarse de forma prioritaria de los servicios de asistencia técnica para una red informática en caso de avería.

7.17 Estos servicios podrán obtenerse a demanda, ser más o menos numerosos y revestir una importancia variable de un año a otro. Es poco probable que una empresa independiente incurra en gastos en concepto de iguala cuando la necesidad potencial de servicios es remota, cuando la ventaja de contar con estos servicios sea desdeñable o cuando puedan obtenerse con inmediatez a través de otra vía sin que sea necesario suscribir contratos de asistencia permanente. En consecuencia, debe tenerse en cuenta el beneficio que aportan a una sociedad del grupo los acuerdos de prestación de servicios a demanda, examinando quizá el número de veces que se ha recurrido a ellos a lo largo de varios años, en lugar de únicamente en el año en que se ha de efectuar un pago, para determinar si se ha prestado un servicio intragrupo.

7.18 El hecho de que se haya efectuado un pago a una empresa asociada en concepto de supuestos servicios puede ser de utilidad para determinar si esos servicios se han prestado o no efectivamente, pero la simple calificación de un pago como "comisión por gastos de gestión" no debe considerarse, a primera vista, como la prueba de que ha habido prestación de servicios. Asimismo, la ausencia de pagos o de contratos no debe llevar automáticamente a la conclusión de que no se ha prestado ningún servicio intragrupo.

B.2 *Determinación de la retribución de plena competencia*

B.2.1 *Términos generales*

7.19 Una vez determinado que se ha realizado un servicio intragrupo se debe precisar, al igual que para otras operaciones intragrupo, si el importe de la remuneración, cuando exista, se ajusta al principio de plena competencia. Esto significa que el precio facturado por los servicios intragrupo debería ser el que habrían fijado y aceptado dos empresas independientes en circunstancias comparables. En consecuencia, estas operaciones no deben someterse a un tratamiento fiscal distinto al de las operaciones comparables entre empresas independientes por el mero hecho de haberse realizado entre empresas asociadas.

B.2.2 *Identificación de los acuerdos efectivos para la remuneración de los servicios intragrupo*

7.20 Para identificar el importe realmente facturado en concepto de servicios, si lo hubiera, la administración tributaria deberá identificar qué acuerdos, si los hubiera, se han concluido realmente entre las dos empresas asociadas para facilitar la facturación por prestación de servicios entre ellas, cuando estos existan. En ciertos casos, es fácil identificar los acuerdos para la remuneración de los servicios intragrupo, por ejemplo, cuando el grupo multinacional recurre al cargo directo, es decir, cuando se cargan directamente determinados servicios a las empresas asociadas. En general, el método de cargo directo es de gran interés práctico para las administraciones tributarias, puesto que permite identificar de forma precisa el servicio realizado y la base de cálculo del pago. En consecuencia, el método de cargo directo permite determinar con mayor facilidad si el importe exigido es coherente o no con el principio de plena competencia.

7.21 Por lo general, los grupos multinacionales pueden adoptar un sistema de cargo directo, especialmente cuando además de los servicios

prestados a empresas asociadas también prestan servicios similares a empresas independientes. Si determinados servicios no sólo se proveen a empresas asociadas sino también a empresas independientes en condiciones comparables y como una parte sustancial del negocio, podría presumirse que el grupo multinacional tiene la posibilidad de justificar el cálculo del cargo facturado sobre una base independiente (por ejemplo, registrando contablemente los trabajos efectuados y los gastos incurridos para la ejecución de los contratos suscritos con terceros). En consecuencia, se fomenta la utilización del cargo directo por parte de las multinacionales en relación con sus operaciones con empresas asociadas. Sin embargo, debe admitirse que este criterio no es siempre el más apropiado si, por ejemplo, los servicios prestados a terceros tiene un carácter ocasional o marginal.

7.22 Es frecuente que el método de cargo directo de los servicios intragrupo resulte tan difícil de aplicar para las multinacionales que estas han optado por desarrollar otros métodos de facturación para los servicios prestados por las sociedades matrices o por los centros de servicios. En estos casos, las prácticas seguidas por los grupos multinacionales para la facturación de los servicios intragrupo suelen consistir en la confección de acuerdos que son: a) fácilmente identificables aunque no se basen en el método de cargo directo; o b) más difíciles de identificar, y que pueden incorporarse en la facturación de otras operaciones y repartirse entre los miembros del grupo siguiendo ciertos criterios o, en algunos casos, no repartirse en modo alguno.

7.23 En esos casos, los grupos multinacionales pueden estimar que, para calcular una remuneración de plena competencia siguiendo los principios expuestos en la Sección B.2.3, no tienen otro remedio que utilizar los métodos de asignación y reparto de costes que, con frecuencia, precisan de estimaciones o valoraciones aproximadas. Estos métodos se califican normalmente como métodos de cargo indirecto y deben autorizarse siempre que se dedique suficiente atención al valor de los servicios prestados a sus destinatarios y a la medida en que se presten servicios comparables entre empresas independientes. Estos métodos de cálculo no son aceptables cuando ciertos servicios específicos, que constituyen la actividad principal de la empresa, se prestan no sólo a empresas asociadas sino también a terceros independientes. Aunque hay que hacer cuanto sea preciso para proceder a un cargo razonable por el servicio prestado, toda facturación debe sustentarse en un beneficio identificable y razonablemente previsible. Cualquier método de cargo indirecto debe responder a las características comerciales de cada caso (por ejemplo, el criterio de reparto deberá ser racional en función de las circunstancias), contener cláusulas de salvaguardia contra cualquier manipulación, ser conforme con los principios básicos contables y ser capaz

de generar cargos o atribuciones de costes proporcionales a los beneficios obtenidos o razonablemente previstos por el destinatario del servicio.

7.24 En ciertos casos, la naturaleza del servicio prestado puede exigir un método de cargo indirecto; por ejemplo, cuando sólo puede cuantificarse de forma aproximada o estimada la proporción del valor de los servicios prestados a las diversas entidades. Este problema puede plantearse, por ejemplo, cuando las actividades de promoción de ventas realizadas a nivel central (con ocasión de exposiciones universales, en prensa internacional o por medio de otras campañas publicitarias centralizadas) pueden afectar a la cantidad de bienes producidos o vendidos por un cierto número de sociedades filiales. Otro caso sería cuando un registro y análisis separado de las actividades de prestación de servicios correspondientes a cada beneficiario, implique una carga administrativa desproporcionada respecto de las propias actividades. En estos casos, la facturación podría determinarse mediante un reparto entre todos los beneficiarios potenciales de los costes que no pueden imputarse directamente, es decir, que no pueden asignarse de forma específica a los destinatarios efectivos de los distintos servicios. Para cumplir con el principio de plena competencia, el método de atribución elegido debe alcanzar un resultado compatible con lo que empresas independientes comparables hubieran estado dispuestas a aceptar. Véase la Sección B.2.3 más adelante.

7.25 La atribución puede basarse en el volumen de negocios, en el personal empleado o en otros criterios. La idoneidad del método de reparto puede depender de la naturaleza y de la utilización del servicio. Por ejemplo, el uso o la prestación de servicios de nómina puede estar más relacionado con el número de empleados que con el volumen de negocios, en tanto que la asignación de costes en concepto de iguala por el mantenimiento prioritario de los ordenadores o por copias de seguridad podría hacerse en proporción a los gastos en equipo informático de los distintos miembros del grupo.

7.26 La remuneración de los servicios prestados a una empresa asociada puede incluirse en el precio de otras operaciones. Por ejemplo, el precio de la cesión de una licencia de una patente o de conocimientos prácticos *-know-how-*, puede incluir un pago en concepto de servicios de asistencia técnica o de servicios centralizados realizados para el licenciataria, o de asesoría de gestión de comercialización de los bienes producidos al amparo de la licencia. En estos casos, la administración tributaria y los contribuyentes tendrán que comprobar que no se facture ningún pago adicional en concepto de servicios prestados y que no haya doble deducción.

7.27 Cuando se aplica un método de cargo indirecto, puede difuminarse la relación entre lo facturado y los servicios prestados, complicando el

cálculo del beneficio obtenido. De hecho, puede significar que la empresa a la que se factura un servicio no haya establecido relación alguna entre lo facturado y el servicio. Aumenta pues, el riesgo de doble imposición, dado que es más difícil determinar una deducción en concepto de costes incurridos por cuenta de los miembros del grupo si la remuneración no puede identificarse de forma directa, o si el destinatario del servicio no puede deducir los pagos efectuados por su incapacidad de demostrar que se han prestado los servicios.

7.28 En lo que se refiere a los acuerdos para el pago de un depósito por los servicios prestados a demanda (a los que se refieren los apartados 7.16 y 7.17), puede ser necesario examinar las condiciones de utilización efectiva de esos servicios dado que dichos acuerdos pueden prever que no se facture el uso efectivo de esos servicios siempre que su nivel de utilización no sobrepase una cuantía predeterminada.

B.2.3 Cálculo de la contraprestación de plena competencia

7.29 Para determinar el precio de plena competencia de los servicios intragrupo, debe considerarse tanto el punto de vista del proveedor del servicio como el del beneficiario. A estos efectos, los factores relevantes comprenden el valor del servicio para el destinatario y el importe que una empresa independiente comparable hubiera estado dispuesta a pagar por ese servicio en circunstancias comparables, así como los costes para el proveedor del servicio.

7.30 Por ejemplo, desde el punto de vista de una empresa independiente que necesita un servicio, los proveedores del mismo en ese mercado pueden estar dispuestos o no, o ser capaces o no, de ofrecer el servicio al precio que la empresa independiente acepta pagar. Si los proveedores del servicio están en condiciones de prestarlo a un precio que se sitúe dentro del rango de precios aceptables para las empresas independientes, podrá cerrarse el acuerdo. Los elementos que considerará el proveedor de los servicios son el precio por debajo del cual no aceptaría ofrecerlo y su coste, aunque estos factores no determinan el resultado en todos los casos.

7.31 El método que deba emplearse para determinar los precios de plena competencia aplicables a los servicios intragrupo debe elegirse de acuerdo con los principios enunciados en los Capítulos I, II y III. A menudo, la aplicación de estos principios llevará a la utilización del método del precio libre comparable o del método del coste incrementado para fijar los precios de los servicios intragrupo. En general, el método del precio libre comparable será el más apropiado cuando exista un servicio comparable

prestado en circunstancias comparables entre empresas independientes en el mercado en el que opera el perceptor del servicio, o cuando una empresa asociada preste servicios a una empresa independiente en circunstancias comparables. Por ejemplo, este podría ser el caso cuando se prestan servicios de contabilidad, auditoría, jurídicos o informáticos, siempre que las operaciones vinculadas y las operaciones independientes sean comparables. El método del coste incrementado sería apropiado en ausencia de un precio libre comparable si las actividades desarrolladas, los activos empleados y los riesgos asumidos son comparables a los de empresas independientes. Como se indica en el Capítulo II, Parte II, al aplicar el método del coste incrementado debe haber coherencia entre las operaciones vinculadas y las no vinculadas para las categorías de costes consideradas. Podría recurrirse a los métodos basados en el resultado de las operaciones cuando resulten los más apropiados para las circunstancias del caso (véanse los párrafos 2.1 a 2.11). En ciertos casos excepcionales, por ejemplo cuando es difícil aplicar el método del precio libre comparable o el método del coste incrementado, podrá aplicarse más de un método (véase el párrafo 2.11) para determinar correctamente el precio de plena competencia.

7.32 Puede ser útil efectuar un análisis funcional de los distintos miembros del grupo para establecer la relación entre sus actividades y resultados y los servicios en cuestión. Asimismo, tal vez sea necesario considerar no sólo el impacto inmediato de un servicio, sino también sus efectos a largo plazo, teniendo presente que algunos costes nunca generarán realmente los beneficios que cupo esperar razonablemente de ellos en el momento en que se contrajeron. Por ejemplo, los gastos ocasionados por la preparación de una operación de comercialización podrían parecer excesivos a primera vista para ser asumidos por un miembro del grupo, a tenor de sus recursos actuales. Para determinar si el importe facturado en ese caso es de plena competencia hay que tener en cuenta los beneficios esperados de la operación y la posibilidad de que el importe y el plazo de la facturación en algunos acuerdos de plena competencia pudieran depender de los resultados de la operación. En estos casos, el contribuyente debería poder demostrar la corrección de los importes facturados a sus asociados.

7.33 Al depender del método empleado para determinar una remuneración de plena competencia por los servicios intragrupo, puede plantearse si es necesario que el precio aplicado permita al proveedor de los servicios obtener un beneficio. En una operación de plena competencia, una empresa independiente normalmente trataría de facturar sus servicios de modo que obtuviera un beneficio en lugar de prestarlos a precio de coste. Para determinar la remuneración de plena competencia habrá que tener en cuenta las alternativas económicas disponibles para el destinatario del

servicio. Sin embargo, hay circunstancias (como por ejemplo las que se presentan en el estudio de las estrategias mercantiles en el Capítulo I) en las que una empresa independiente puede no obtener un beneficio sólo por la prestación del servicio, por ejemplo, cuando el proveedor del servicio tiene unos costes (previsibles o reales) que exceden del valor normal de mercado y a pesar de ello acepta prestar ese servicio para aumentar su rentabilidad, quizás completando así su gama de actividades. En consecuencia, no es siempre necesario que el precio de plena competencia se traduzca en un beneficio para la empresa asociada que presta un servicio intragrupo.

7.34 Por ejemplo, puede que el valor de mercado de los servicios intragrupo no sea superior al de los costes incurridos por su proveedor. Esto podría ocurrir cuando, por ejemplo, el servicio no constituye una actividad normal o recurrente del proveedor, ofreciéndose ocasionalmente a los miembros del grupo multinacional para su comodidad. Para determinar si los servicios intragrupo generan el mismo valor por el dinero invertido que el que podría obtener una empresa independiente, la comparación de las funciones y los beneficios esperados permitiría juzgar la comparabilidad de las operaciones. Un grupo multinacional podrá decidir la prestación de un servicio intragrupo, en lugar de un servicio externo ofrecido por un tercero, por una amplia variedad de razones, tal vez porque se obtienen otros beneficios intragrupo (para los que podría ser adecuada una remuneración de plena competencia). En ese caso no sería apropiado aumentar el precio del servicio por encima del nivel calculado aplicando el método del precio libre comparable simplemente para permitir a la empresa asociada obtener un beneficio. Este resultado sería contrario al principio de plena competencia. Sin embargo, debe garantizarse que se tienen en cuenta adecuadamente todos los beneficios del destinatario.

7.35 Cuando se considera que el método del coste incrementado es el más apropiado para las circunstancias del caso, el análisis requerirá el examen de si los costes incurridos por el proveedor de servicios del grupo precisan de algún ajuste que valide la comparación de las operaciones vinculadas y no vinculadas. Por ejemplo, si la operación vinculada tiene una proporción mayor de gastos generales en relación con los costes directos que la operación por lo demás comparable, no sería apropiado aplicar el incremento sobre los costes obtenido en esta última operación si no se ajustan los costes de la empresa asociada para que la comparación sea válida. En algunos casos, los costes en que hubiera incurrido el destinatario, si hubiese tenido que ejecutar el servicio por cuenta propia, pueden indicar el tipo de acuerdo que él mismo estaría dispuesto a aceptar por la prestación del servicio en condiciones de plena competencia.

7.36 Cuando una empresa asociada interviene únicamente como agente o como intermediario en una prestación de servicios es importante, al aplicar el método del coste incrementado, que el rendimiento o el incremento sobre los costes resulte apropiado para el ejercicio de las funciones del agente y no para la propia prestación de los servicios. En ese caso no sería apropiado fijar un precio de plena competencia incrementando un margen sobre los costes de los servicios sino sobre los costes inherentes a la función de agente o, incluso, según el tipo de datos comparables utilizados, el incremento sobre el coste de los servicios debería ser más reducido que el que correspondería a la prestación de los propios servicios. Por ejemplo, una empresa asociada puede soportar los costes relativos al alquiler de los espacios publicitarios por cuenta de los miembros del grupo, costes que los miembros del grupo habrían soportado directamente si hubieran sido independientes. En ese caso, podrá ser apropiado repercutir esos costes a los destinatarios del grupo sin incremento alguno, reservando el incremento únicamente a los costes incurridos por el intermediario en el ejercicio de sus funciones de agente.

7.37 Si bien, por principio, la administración tributaria y el contribuyente deben esforzarse en establecer el precio de plena competencia correcto, no debe olvidarse que pueden existir razones de orden práctico por las que una administración tributaria pueda estar excepcionalmente dispuesta, en el marco de sus facultades discrecionales, a renunciar al cálculo y a la imposición de un precio de plena competencia para la realización de ciertos servicios, con independencia de que permita a un contribuyente, en las circunstancias adecuadas, proceder a la simple atribución de los costes de prestación de esos servicios. Por ejemplo, un análisis coste-beneficio podría demostrar que la recaudación tributaria adicional que pudiera obtenerse no justifica los costes y las cargas administrativas que ocasionaría la determinación de lo que podría constituir, en ciertos casos, un precio de plena competencia. En esos casos, la facturación de todos los costes pertinentes y no de un precio de plena competencia podría ofrecer un resultado satisfactorio para las empresas multinacionales y para las administraciones tributarias. Sin embargo, es poco probable que las administraciones tributarias hagan esta concesión cuando la prestación de un servicio constituye la actividad principal de la empresa asociada, cuando el elemento de beneficio es relativamente importante o cuando puede aplicarse un método de cargo directo para fijar el precio de plena competencia.

C. Algunos ejemplos de servicios intragrupo

7.38 En esta sección se exponen algunos ejemplos de problemas que se plantean en la determinación de precios de transferencia relacionados con la

prestación de servicios intragrupo. Los casos citados se indican sólo a título ilustrativo. Al tratar los casos particulares será necesario considerar los hechos y circunstancias reales que permitan juzgar la aplicabilidad de los métodos de determinación de precios de transferencia.

7.39 Un primer ejemplo lo constituyen las actividades de gestión de cobro, cuando un grupo multinacional decide centralizarlas por razones económicas. Por ejemplo, podría ser prudente centralizar las actividades de gestión de cobro para limitar los riesgos de fluctuación del tipo de cambio y de deuda, y reducir las cargas administrativas. Un centro de gestión de cobro que asume esta responsabilidad está realizando servicios intragrupo que debería facturar a un precio de plena competencia. La aplicación del método del precio libre comparable puede ser adecuada en ese caso.

7.40 La contratación de especialistas en fabricación es otro ejemplo de una actividad que puede comportar servicios intragrupo. En este caso, el fabricante puede recibir instrucciones muy precisas acerca de lo que debe fabricar, en qué cantidades y con qué calidad. El fabricante soporta un riesgo bajo al garantizársele la venta de toda su producción en la medida en que se ajuste a las normas de calidad. En ese caso, puede considerarse que está realizando un servicio, y que el método del coste incrementado podría ser el apropiado, siempre que se respeten los principios del Capítulo II.

7.41 Los contratos de investigación constituyen un ejemplo de servicios intragrupo que demanda personal altamente cualificado cuyo papel es a menudo crucial para el éxito del grupo. Los acuerdos concretos pueden revestir formas diversas, que van desde el establecimiento de programas detallados concebidos por el empresario principal, a los acuerdos por los que la sociedad encargada de las investigaciones organiza libremente sus trabajos en el marco de directrices definidas en términos generales. En este último caso, que afecta normalmente a la investigación más puntera, las funciones complementarias, consistentes en la identificación de las áreas de investigación que ofrecen las perspectivas comerciales más interesantes y la evaluación de los riesgos de investigaciones fracasadas, pueden jugar un papel determinante en los resultados del grupo en su conjunto. Sin embargo, es frecuente que se proteja de riesgos financieros a la empresa dedicada a la investigación, dado que los acuerdos normalmente contemplan el reembolso de los gastos tanto en caso de éxito como de fracaso. Además, los activos intangibles obtenidos de las actividades de investigación pertenecen, normalmente, al empresario principal y, en consecuencia, la sociedad dedicada a la investigación no asume los riesgos inherentes a la explotación comercial de dicho activo. En ese caso, la aplicación del método del coste incrementado será adecuada siempre que se respeten los principios de Capítulo II.

7.42 Otro ejemplo de servicios intragrupo es la gestión de licencias. A estos efectos habría que distinguir entre la administración y protección de los derechos concernientes a los activos intangibles de la explotación de esos derechos. El control de una licencia podría confiarse a un centro de servicios responsable del seguimiento de los posibles incumplimientos respecto a la licencia y de la ejecución de los derechos de esa licencia.

Capítulo VIII

Acuerdos de reparto de costes

A. Introducción

8.1 En este capítulo se examinan los acuerdos de reparto de costes (ARC) entre dos o más empresas asociadas (y, ocasionalmente, con empresas independientes). Existen numerosos tipos de acuerdos de reparto de costes. Este capítulo no pretende analizar ni describir las consecuencias fiscales de cada uno de los tipos, sino proporcionar una orientación general que permita determinar si las condiciones establecidas por las empresas asociadas en un ARC son coherentes con el principio de plena competencia. Las consecuencias fiscales de un ARC varían en función de que el acuerdo se estructure conforme al principio de plena competencia, definido en los términos de las disposiciones del presente capítulo y de que se documente de manera adecuada. Este capítulo no resuelve todas las cuestiones relevantes sobre la administración de los ARC ni sus consecuencias fiscales. Por ejemplo, será necesario disponer de directrices complementarias sobre la evaluación de las aportaciones a los ARC, especialmente, para determinar cuándo procede basarse en los costes o en los precios de mercado y precisar los efectos de las subvenciones públicas o de los incentivos fiscales (véanse los párrafos 8.15 y 8.17). También podría resultar de utilidad profundizar en la calificación fiscal de las aportaciones, de los pagos compensatorios y de los pagos de entrada y de salida (véanse los párrafos 8.23, 8.25, 8.33 y 8.35). A medida que vaya disponiéndose de más experiencia sobre el funcionamiento efectivo de los ARC se irán desarrollando trabajos complementarios para la actualización y profundización en el contenido de este capítulo.

8.2 En la sección B se revisa el concepto de los ARC y ofrece una definición general. La sección C describe la norma que permite determinar si un ARC cumple con el principio de plena competencia. El análisis incluye orientaciones sobre la forma de medir las aportaciones a un ARC a tal fin, sobre la necesidad o no de efectuar pagos compensatorios (es decir, pagos entre participantes que permitan ajustar la proporción de las aportaciones que les corresponde a cada uno) y sobre qué tratamiento fiscal debería darse a dichas aportaciones y pagos compensatorios. La sección C aborda asimismo

la determinación de los participantes y el tratamiento de las sociedades que tienen un fin específico. La sección D analiza los ajustes que deben realizarse cuando se considere que las condiciones previstas en un ARC no son conformes con el principio de plena competencia, incluidos los ajustes en la cuota de participación en las aportaciones según el acuerdo. La sección E trata lo referente a la adhesión a un ARC o a la retirada del acuerdo durante su vigencia. Por último, la sección F formula una serie de sugerencias sobre la estructura y la documentación de los ARC.

B. Concepto de ARC

B.1 *Términos generales*

8.3 Un ARC es un acuerdo marco que permite a las empresas mercantiles repartirse los costes y los riesgos de desarrollar, producir u obtener activos, servicios o derechos y determinar la naturaleza y el alcance de los intereses de cada uno de los participantes en estos activos, servicios o derechos. Un ARC es más bien un acuerdo contractual que una entidad jurídica distinta o un establecimiento permanente de todos sus participantes. En un ARC, la proporción de los beneficios esperados del acuerdo que recibe un participante está en función de su participación en el total de las aportaciones al acuerdo, teniendo en cuenta que la determinación de los precios de transferencia no constituye una ciencia exacta. Además, cada participante en un ARC tiene derecho a explotar separadamente su participación en el mismo como propietario efectivo de esa parte y no como licenciario y, por consiguiente, está exento de pagar a ninguna de las partes canon o remuneración alguna. Inversamente, cualquier otra parte deberá pagar una remuneración apropiada a un participante (por ejemplo, un canon) por explotar total o parcialmente la propiedad de dicho participante.

8.4 Ciertos beneficios derivados de los ARC se conocen por anticipado, mientras que otros, como por ejemplo los resultados de las actividades de investigación y desarrollo, son inciertos. Ciertos tipos de actividades del ARC producen beneficios a corto plazo, mientras que otros tienen un marco temporal más largo o tal vez no lo consigan. En todo caso, en un ARC siempre existe un beneficio esperado al que cada participante aspira con su aportación, incluyéndose el derecho intrínseco de que el ARC se administre adecuadamente. Los derechos de cada participante sobre los resultados de la actividad llevada a cabo en el marco del ARC deben establecerse desde el inicio, incluso cuando tales derechos estén interrelacionados con los del resto de participantes, por ejemplo, porque la propiedad legal del activo intangible desarrollado se confiera exclusivamente

a uno de los participantes y, no obstante, todos tengan el derecho de explotación.

B.2 Relación con otros capítulos

8.5 Los Capítulos VI y VII proporcionan criterios sobre la forma de determinar una contraprestación de plena competencia en una transmisión intragrupo de activos intangibles y de servicios, respectivamente. Este capítulo pretende proporcionar una orientación adicional en los casos en que los recursos y las competencias se pongan en común y en los que la remuneración recibida sea, total o parcialmente, el resultado que cabe esperarse de los beneficios mutuos. En consecuencia, los Capítulos VI y VII y, de hecho, el resto de los capítulos de estas Directrices serán aplicables en la medida que sean relevantes, por ejemplo, para cuantificar el importe de una aportación a un ARC como parte del proceso de determinación de las aportaciones proporcionales. Se invita a las empresas multinacionales a seguir las orientaciones del presente capítulo, con el fin de asegurar que sus ARC se ajustan al principio de plena competencia.

B.3 Tipos de ARC

8.6 Quizás el tipo de ARC más frecuente sea el de un acuerdo para el desarrollo conjunto de activos intangibles donde cada participante recibe una participación en los derechos sobre el activo que se desarrolla. En ese ARC, a cada participante se le conceden derechos específicos de explotación del activo intangible, por ejemplo, para ciertas zonas geográficas o para ciertas aplicaciones. En general, el participante utiliza el activo intangible para su uso particular más que en el marco de una actividad conjunta con otros participantes. Los derechos específicos obtenidos pueden ser verdaderos derechos de propiedad; por el contrario, puede ocurrir que sólo uno de los participantes sea el propietario legal del activo pero que, económicamente, todos los participantes sean copropietarios. En el caso de que un participante posea un derecho efectivo de propiedad sobre cualquier activo desarrollado en el marco de un ARC y de que las aportaciones sean proporcionales, no procede el pago de un canon o de cualquier otra remuneración por la utilización del activo desarrollado en función del derecho adquirido por el participante.

8.7 Si bien los ARC más frecuentes son los acordados para actividades de investigación y desarrollo de activos intangibles, no se limitan a ese tipo de actividad. Pueden acordarse ARC para la financiación conjunta o para el reparto de los costes y de los riesgos, para el desarrollo o la adquisición de

activos o para la obtención de servicios. A título de ejemplo, las empresas mercantiles pueden aunar recursos para adquirir servicios administrativos centralizados o desarrollar campañas publicitarias comunes en los mercados de los participantes.

C. Aplicación del principio de plena competencia

C.1 *Términos generales*

8.8 Para que las condiciones previstas en un ARC satisfagan el principio de plena competencia, las aportaciones efectuadas por cada participante deben ajustarse a las que una empresa independiente aceptaría en circunstancias comparables, teniendo en cuenta los beneficios que cabe esperar obtener del acuerdo. Lo que diferencia la aportación a un ARC de una transmisión ordinaria intragrupo de bienes o de servicios es que la remuneración buscada por los participantes está constituida, total o parcialmente, por los beneficios esperados por cada uno al poner en común los recursos y las técnicas. Las empresas independientes concluyen acuerdos de reparto de costes y de riesgos cuando existe una necesidad común de la que ambas se pueden beneficiar. Es probable que, por ejemplo, las partes independientes que operan conforme al principio de plena competencia deseen compartir los riesgos (por ejemplo en la investigación en el ámbito de las tecnologías avanzadas) para reducir al mínimo las pérdidas que pudieran resultar de una actividad, o que procedan a un reparto de los costes o a un desarrollo conjunto con el fin de conseguir ahorros, quizá a través de las economías de escala, o de mejorar la eficiencia y la productividad aprovechando los puntos fuertes y las áreas de experiencia de cada una. De manera más general, estos acuerdos se observan cuando un grupo de sociedades que comparten la necesidad de ciertas actividades concretas, decide centralizar o desarrollar conjuntamente estas actividades, de forma que se reduzcan los costes y los riesgos en beneficio de cada participante.

8.9 La expectativa de beneficios mutuos es fundamental para la aceptación, por parte de empresas independientes, de un acuerdo para compartir recursos y habilidades sin que genere una remuneración adicional. Las empresas independientes exigirían que la aportación de cada participante, con respecto del total del acuerdo, sea proporcional a su parte en el total de los beneficios que espera recibir del mismo. Para aplicar el principio de plena competencia a un ARC es, por tanto, necesario constatar que todas las partes del acuerdo esperan obtener beneficios; posteriormente, calcular la aportación relativa (en dinero o en especie) de cada participante en la actividad conjunta; y, finalmente, determinar si es apropiado el

porcentaje de las aportaciones al ARC (eventualmente ajustadas para tener en cuenta cualquier pago compensatorio efectuado entre participantes). Sería preciso tener en cuenta que estos factores pueden tener un cierto grado de incertidumbre. Es posible repartir los costes entre los participantes de un ARC de forma que se genere una sobreestimación de los beneficios imponderables en ciertos países y una subestimación en otros, si se comparan con los resultados de plena competencia. Por esta razón, los contribuyentes deberían estar en condiciones de justificar el fundamento de su petición con respecto al ARC (véase la sección F).

C.2 *Determinación de los participantes*

8.10 Dado que la noción de beneficio mutuo es fundamental en un ARC, no se considerará participante a una parte a menos que pueda esperar un beneficio de la propia actividad del ARC (y no sólo por el ejercicio de toda o parte de esa actividad). A un participante se le debe asignar, por tanto, un beneficio efectivo sobre los bienes o servicios objeto del ARC y dotar de una expectativa legítima de la posibilidad de explotar o utilizar, directa o indirectamente, el derecho que se le ha asignado (por ejemplo a través de acuerdos de licencia o de venta a empresas asociadas o independientes).

8.11 La exigencia de un beneficio esperado no impone la condición de que la actividad tenga un resultado positivo. A título de ejemplo, la investigación y el desarrollo pueden fracasar en su intento de conseguir activos intangibles con valor comercial. No obstante, si a lo largo del período durante el cual se debería obtener un beneficio, la actividad no produce ningún beneficio efectivo, la administración tributaria podrá plantearse si las partes, en el caso de haberse tratado de empresas independientes, habrían continuado con su participación (véanse en el Capítulo I los párrafos dedicados a las estrategias mercantiles, en particular el 1.63, y a las pérdidas, 1.70 a 1.72).

8.12 En ciertos casos, los participantes en un ARC pueden decidir que una sociedad independiente, que no se considera participante en los términos del párrafo 8.10 anterior, ejerza total o parcialmente la actividad objeto del ARC. En el caso de un contrato de investigación o de fabricación, esta sociedad deberá ser retribuida a un precio de plena competencia por los servicios prestados a los participantes del ARC. Este sería el caso incluso si, por ejemplo, la sociedad es una filial de uno o varios de los participantes en el ARC que se ha constituido para beneficiarse de un régimen de responsabilidad limitada cuando la actividad del ARC sea la investigación y el desarrollo de alto riesgo. La retribución de plena competencia de la sociedad se determinaría según los principios generales expuestos en el

Capítulo I, teniendo en cuenta, entre otros factores, las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos, así como las consideraciones especiales que afectan a la remuneración de plena competencia de los servicios descritas en el Capítulo VII, en particular, en los párrafos 7.29 a 7.37.

C.3 *Importe de la aportación de cada participante*

8.13 Para determinar si un ARC se ajusta al principio de plena competencia, es decir, si la participación relativa de cada participante en el total de las aportaciones al ARC es coherente con su cuota proporcional de beneficios esperados, es necesario medir el valor o el importe de las aportaciones de cada uno de los participantes en el ARC.

8.14 En virtud del principio de plena competencia, el valor de la aportación de cada participante debe ser coherente con el que se habría determinado entre empresas independientes en circunstancias comparables. En consecuencia, para determinar el valor de las aportaciones a un ARC, se deben seguir las indicaciones dadas en los Capítulos I a VII de estas Directrices. Por ejemplo, como se señala en el Capítulo I, la aplicación del principio de plena competencia tendría en cuenta, entre otros, los términos contractuales y las circunstancias económicas específicas de un ARC como, por ejemplo, el reparto de riesgos y de costes.

8.15 No puede darse un resultado específico para todas las situaciones; los problemas deben resolverse caso por caso, respetando la aplicación general del principio de plena competencia. Los países tienen experiencia tanto en la utilización de los costes como de los precios de mercado para determinar el valor de las aportaciones a los ARC según el principio de plena competencia. Probablemente no es fácil determinar el valor relativo de la aportación de cada participante, salvo que todas las aportaciones se realicen íntegramente en efectivo como, por ejemplo, cuando la actividad la ejerce un proveedor de servicios externo y todos los participantes financian conjuntamente los costes.

8.16 Es importante que el proceso de evaluación reconozca todas las aportaciones de los participantes en el acuerdo, incluyendo los bienes o servicios que se utilizan tanto para la actividad del ARC como, simultáneamente, para las actividades mercantiles específicas del participante. Puede ser difícil medir las aportaciones que incluyan activos o servicios compartidos por ejemplo, cuando un participante aporta la utilización parcial de bienes de capital como instalaciones y equipos, o ejerce funciones de vigilancia, de oficina o de administración para el ARC y para su

propia actividad. Será necesario determinar la proporción de los activos utilizados o de los servicios relacionados con la actividad del ARC de forma comercialmente justificable respecto de las normas contables aceptadas y de los datos reales, así como efectuar ajustes, cuando sea necesario, para lograr una mayor uniformidad cuando intervengan diferentes jurisdicciones. Una vez determinada esta proporción, la aportación podrá medirse conforme a los principios que aparecen en el resto del capítulo.

8.17 Para evaluar la aportación de un participante, hay que analizar la cuestión del ahorro que pueda resultar de las subvenciones o de los beneficios fiscales (incluidos los créditos a la inversión) concedidos por una Administración. Cuando y hasta qué punto estos ahorros deben de tenerse en cuenta al evaluar la aportación de un participante dependerá de cómo hubieran actuado las empresas independientes en circunstancias comparables.

8.18 Pueden ser necesarios pagos compensatorios para ajustar las aportaciones proporcionales de los participantes. Un pago compensatorio supone el aumento del valor de las aportaciones del pagador y la reducción de la aportación del beneficiario en un importe equivalente al pago efectuado. Los pagos compensatorios deberán respetar las reglas de plena competencia según las cuales la proporción de cada participante en el total de las aportaciones debe ser coherente con su proporción en el total de los beneficios esperados del acuerdo. Respecto del tratamiento fiscal de los pagos compensatorios véase el párrafo 8.25 más adelante.

C.4 *Determinación de la corrección del reparto*

8.19 No existe una regla de aplicación universal para determinar si la proporción relativa de cada participante en el total de aportaciones a la actividad de un ARC se corresponde con su proporción relativa en el total de beneficios esperados del acuerdo. El objetivo es estimar la cuota de beneficios esperados por cada participante y determinar las aportaciones en la misma proporción. La proporción de beneficios esperados puede estimarse tomando como punto de referencia la renta adicional o el ahorro de costes que obtiene cada participante como resultado del acuerdo. Puede ser útil, en ciertos casos, recurrir a otras técnicas para el cálculo de los beneficios esperados (por ejemplo, la utilización del precio cobrado en la venta de activos o de servicios comparables). Otro criterio utilizado frecuentemente en la práctica consiste en determinar la cuota de beneficios esperados atribuida a cada participante utilizando una clave de atribución. Entre las claves de atribución posibles podemos citar las ventas, las unidades utilizadas, producidas o vendidas, el beneficio bruto o el beneficio de explotación, el

número de asalariados, el capital invertido, etc. La validez la clave de atribución depende de la naturaleza de la actividad del ARC y de la relación entre esta y los beneficios esperados.

8.20 En la medida en que los beneficios totales o parciales de la actividad de un ARC se materialicen en el futuro y no en el presente, el reparto de las aportaciones se basará en la cuota de participación en los beneficios prevista para cada participante. La utilización de provisiones puede causar problemas a las administraciones tributarias, tanto en el momento de verificar la corrección de su estimación, como cuando se aparten mucho de los resultados reales. Los problemas pueden agravarse cuando la actividad objeto del ARC concluya varios años antes de que los beneficios esperados se materialicen realmente. Podría ser oportuno, especialmente cuando se espera que los beneficios se materialicen en el futuro, que el ARC prevea un mecanismo, operativo durante toda su vigencia, que permita realizar ajustes en los porcentajes respectivos de las aportaciones con el fin de reflejar los cambios habidos en las circunstancias que puedan generar variaciones en el reparto de los citados beneficios. Cuando los resultados reales se aparten mucho de las provisiones, las administraciones tributarias podrán plantearse si unas empresas independientes, actuando en condiciones comparables, las habrían considerado aceptables, teniendo en cuenta la evolución que hubiera sido razonable prever en ese momento y sin recurrir a la retrosección.

8.21 Para calcular los beneficios relativos que se espera obtener de una actividad de I + D orientada al desarrollo de una nueva línea de productos o de un nuevo proceso, las empresas recurren, en algunas ocasiones, a la previsión de ventas de la nueva línea de productos o a la previsión de ingresos en concepto de cánones por la concesión de licencias relativas al nuevo proceso. Este ejemplo se menciona a título ilustrativo y no significa que se priorice la utilización de los datos relativos a las ventas en ningún caso concreto. Sea cual sea el indicador elegido, cuando los beneficios vayan a materializarse en el futuro, es necesario asegurarse de que todos los datos actuales utilizados constituyen un indicador fiable para la distribución futura de dichos beneficios.

8.22 Con independencia del método de reparto, en ciertos casos habrá que realizar ajustes en el indicador utilizado que subsanen las diferencias en los beneficios previstos que vayan a recibir los participantes, por ejemplo, en relación con el momento en el que vayan a obtenerlos, con el carácter exclusivo de sus derechos, y con los diferentes riesgos vinculados a la obtención de los beneficios, etc. Es posible que la clave de atribución que mejor se adapte a un determinado ARC varíe a lo largo del tiempo. Si un acuerdo se refiere a múltiples actividades, habrá que tener en cuenta este

factor en la elección del método de reparto, de forma que las contribuciones estén convenientemente proporcionadas respecto de los beneficios que espera obtener un participante. Uno de los métodos posibles (que, sin embargo, no es el único) consiste en utilizar más de una clave de atribución. Por ejemplo, si se concluye un ARC entre cinco participantes y uno de ellos no puede beneficiarse de ciertas actividades de investigación llevadas a cabo en el marco del ARC, en ausencia de un método de compensación o de disminución de la aportación, los costes ligados a las actividades citadas podrían repartirse únicamente entre los otros cuatro participantes. En este caso podrían utilizarse dos claves distintas para el reparto de costes. Además, el intercambio de información entre los signatarios de convenios, los procedimientos amistosos y los acuerdos previos sobre precios de transferencia bilaterales o multilaterales, pueden contribuir a determinar el grado de aceptabilidad de la clave de reparto.

C.5 Tratamiento fiscal de las aportaciones y de los pagos compensatorios

8.23 Las aportaciones de un participante a un ARC deben tratarse desde el punto de vista fiscal de acuerdo con las reglas tributarias generales que se aplicarían a dicho participante si estas aportaciones se efectuaran al margen de un ARC para realizar la misma actividad objeto del acuerdo (por ejemplo, para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo, o para obtener un beneficio efectivo en los activos necesarios para el ejercicio de la actividad del ARC). El carácter de la aportación, por ejemplo como gasto en investigación y desarrollo, dependerá de la naturaleza de la actividad que se realice a través del ARC y determinará su tratamiento desde un punto de vista fiscal. Es frecuente que las aportaciones se consideren gastos deducibles en aplicación de estos criterios. Ninguna porción de la aportación de un participante en un ARC constituirá un canon por la utilización de activos intangibles, salvo en la medida en que la aportación tan sólo permita a quien la ha efectuado disponer de un derecho a utilizar los activos intangibles pertenecientes a uno de los participantes (o a un tercero) y quien realiza la aportación no obtenga además un beneficio efectivo en el propio activo intangible.

8.24 Dado que la aportación de un participante en un ARC debe recibir la compensación de su cuota en los beneficios que se espera obtener del acuerdo, y que probablemente estos beneficios no se obtendrán hasta después de transcurrido un cierto plazo de tiempo, por lo general no se considera que el partícipe percibe una renta inmediata en el momento de efectuar la aportación, sino que este percibe un rendimiento procedente de su

aportación, bien en forma de ahorro en los costes (en cuyo caso, es posible que la actividad del ARC no genere directamente renta alguna) o a medida que los resultados de la actividad generen rentas (o pérdidas) para dicho partícipe como, por ejemplo, en el caso de una actividad de investigación y desarrollo. Naturalmente, en ciertos casos, como en el de la prestación de servicios, los beneficios surgidos del acuerdo pueden materializarse en el mismo ejercicio en el que se efectúa la aportación, por lo que se consideran generados en ese ejercicio.

8.25 Los pagos compensatorios deben tratarse como costes adicionales para el pagador y como un reembolso (y, por tanto, una reducción) de costes para el beneficiario. Normalmente los pagos compensatorios no constituyen un canon por la utilización de activos intangibles, excepto en la medida en que dichos pagos únicamente otorguen al pagador el derecho de uso de los activos intangibles pertenecientes a un participante (o a un tercero) cuando el pagador no obtenga un derecho de explotación sobre el propio activo intangible. En ciertos casos, los pagos compensatorios pueden exceder de los gastos o costes fiscalmente deducibles por el beneficiario, según se definan en su sistema fiscal nacional, en cuyo caso el excedente se consideraría como renta imponible.

D. Consecuencias fiscales de la no conformidad de un ARC con el principio de plena competencia.

8.26 Podrá considerarse que un ARC es conforme con el principio de plena competencia cuando la parte proporcional de cada participante en el total de las aportaciones al acuerdo, ajustada en función de posibles pagos compensatorios, sea coherente con la proporción de los beneficios esperados por el participante en el marco del acuerdo. En caso contrario, la retribución recibida por al menos uno de los participantes por su aportación será insuficiente y la retribución recibida por, al menos, otro participante será excesiva, si se compara con lo que habrían recibido en el mismo supuesto empresas independientes. En tal caso, el principio de plena competencia exigiría que se lleve a cabo un ajuste. La naturaleza de este ajuste dependerá de los hechos y circunstancias pero, en la mayoría de los casos, se traducirá en un ajuste de la aportación neta, posiblemente mediante la realización o la imputación de un pago compensatorio. Cuando la realidad comercial de un acuerdo difiera de las condiciones supuestamente acordadas por los participantes, puede ser conveniente ignorar todos o parte de los términos del ARC. Estas situaciones se examinan a continuación.

D.1 Ajuste de las aportaciones

8.27 Cuando el porcentaje correspondiente a un participante en el total de las aportaciones a un ARC, ajustado en función de los pagos compensatorios, no es proporcional a la cuota de beneficios que espera obtener del acuerdo, la administración tributaria tiene derecho a ajustar la aportación del participante (teniendo en cuenta, en todo caso, que las administraciones tributarias deben abstenerse de practicar ajustes menores o marginales; véase el párrafo 2.10). Esta situación puede presentarse cuando no se valora correctamente la aportación de bienes o servicios de un participante, o cuando los beneficios que proporcionalmente corresponden a un participante se han calculado erróneamente; por ejemplo, cuando la clave de atribución escogida, o ajustada en función de variaciones en las circunstancias, no refleja adecuadamente el reparto proporcional de los beneficios esperados (véase el párrafo 8.19). Por lo general, el ajuste se realizará en forma de pago compensatorio por uno o más participantes, efectuado o imputado a otro.

8.28 Si en todos los demás aspectos el ARC resulta aceptable y su aplicación correcta en términos generales, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Sección F, las administraciones tributarias deben abstenerse de realizar ajustes basados en un solo ejercicio fiscal. Es preciso considerar si la parte proporcional correspondiente a cada participante en el total de las aportaciones es coherente con la cuota en los beneficios que espera obtener del acuerdo en el transcurso de su vigencia (véanse los párrafos 3.75 a 3.79).

D.2 Decisión de ignorar todo o parte de un ARC

8.29 En ciertos casos, de los hechos y circunstancias puede deducirse que la realidad de un acuerdo difiere de los términos supuestamente convenidos por los participantes, por ejemplo, cuando uno o varios de ellos no pueden esperar razonablemente obtener beneficios de la actividad del ARC. Aunque, en principio, la escasa participación en los beneficios no constituye un obstáculo para la participación, en el supuesto de que un participante que ejecute toda la actividad se beneficie únicamente de una pequeña cuota en los beneficios esperados, cabe plantearse si su adhesión al acuerdo tiene realmente por objeto participar en los beneficios, o si se ha simulado una participación para obtener ventajas fiscales. En estos casos, la administración tributaria puede determinar que las consecuencias fiscales sean las que hubieran resultado en el caso de que el acuerdo se hubiera celebrado entre empresas independientes, conforme a las pautas contenidas en los párrafos 1.64 a 1.69.

8.30 Una administración tributaria puede también decidir ignorar todos o una parte de los términos convenidos en un ARC si, a lo largo de un determinado período, se comprueba una diferencia sustancial entre la aportación proporcional de un participante (teniendo en cuenta los pagos compensatorios) y su cuota en los beneficios esperados, y si la realidad comercial impone que el participante que aporta una parte desproporcionadamente alta debe percibir un beneficio efectivo mayor en la actividad objeto del acuerdo. En este caso, el participante podría tener derecho a recibir un pago compensatorio de plena competencia de los demás participantes que se están beneficiando del uso de ese beneficio efectivo. Si las circunstancias indican que se trata de un intento de abuso de las reglas de los ARC, la administración tributaria podrá ignorar el ARC en su totalidad.

E. ARC: adhesión, retirada o rescisión

8.31 Una entidad que se adhiera a un ARC ya en vigor podría obtener una participación en los resultados de la actividad anterior del ARC, por ejemplo de los activos intangibles desarrollados en el marco del acuerdo, de los trabajos en curso y de los conocimientos adquiridos en actividades previas. En tal caso, los antiguos participantes transfieren de manera efectiva una parte de sus derechos respectivos en los resultados de la actividad anterior del ARC. De acuerdo con el principio de plena competencia, toda transmisión de derechos preexistentes de los participantes a un nuevo partícipe debe compensarse en función del valor de plena competencia del derecho transmitido. Este pago compensatorio se denomina “pago de entrada”. La terminología utilizada varía según los países y sucede, por tanto, que cada aportación (o pago compensatorio) realizada como contraprestación por la transmisión de activos o de derechos ya existentes se califica como pago de entrada sea o no efectuado por un nuevo partícipe en el ARC. Sin embargo, en el marco de este capítulo, el término “pago de entrada” se limita a los pagos efectuados por los nuevos participantes en un ARC ya existente para la obtención de una participación en los resultados de las actividades anteriores del ARC. Las restantes aportaciones, incluyendo los pagos compensatorios, se tratan por separado en este capítulo.

8.32 El importe de un pago de entrada debe calcularse sobre la base del valor de plena competencia de los derechos que el nuevo participante obtenga, teniendo en cuenta su cuota de participación en los beneficios totales que se espera obtener del ARC. Es posible que los resultados de las actividades anteriores del ARC carezcan de valor y, en consecuencia, no exista pago de entrada. También puede haber casos en los que el nuevo partícipe aporte al ARC activos intangibles por los que tenga derecho a

percibir pagos compensatorios librados por los restantes participantes para retribuir esta aportación. En estos casos, los pagos compensatorios y el pago de entrada podrían contrarrestarse pero, a efectos fiscales, es necesario contabilizar el importe total de los pagos efectuados de forma separada.

8.33 A efectos fiscales, los pagos de entrada tienen el mismo tratamiento que el resultante de la aplicación de las disposiciones generales del derecho tributario a los participantes (incluidos los convenios para evitar la doble imposición) en caso de que los pagos se realizaran al margen de un ARC, por la adquisición de un derecho, por ejemplo una participación en los activos intangibles ya desarrollados por el ARC, en los trabajos en curso y en los conocimientos adquiridos durante las actividades del ARC en el pasado. Ningún elemento integrante de un pago de entrada a un ARC constituiría un canon por la utilización de activos intangibles, salvo en la medida en que este pago otorgue al pagador únicamente el derecho de uso de los activos intangibles pertenecientes a un participante (o a un tercero) y en la medida en que el pagador no obtenga también un beneficio efectivo sobre el propio activo intangible.

8.34 Podrían aparecer problemas similares a los relativos a los pagos de entrada cuando un participante abandona un ARC. En particular, un partícipe que deja un ARC puede ceder su parte de derechos en los resultados de las actividades ya desarrolladas en el marco del acuerdo (incluidos los trabajos en curso) a los demás partícipes. Si existe una transmisión efectiva de derechos de propiedad en el momento de la retirada de un participante, esta transmisión debe compensarse mediante un pago de plena competencia. Esta compensación se denomina “pago de salida”.

8.35 En ciertos casos, los resultados de las actividades anteriores del ARC pueden no tener ningún valor, por lo que no habrá pago de salida. Además, para determinar el importe del pago de salida según el principio de plena competencia hay que tener en cuenta el punto de vista de los restantes partícipes. Por ejemplo, en ciertos casos, la retirada de un partícipe conduce a una reducción identificable y cuantificable del valor de las actividades ulteriores del ARC. Por otra parte, cuando el valor de la cuota de los participantes que permanecen en el ARC sobre los beneficios de las actividades pasadas de dicho ARC no ha aumentado como consecuencia de la retirada, no procede que este partícipe efectúe un pago de salida. A efectos fiscales, los pagos de salida tienen el mismo tratamiento que el resultante de la aplicación de las disposiciones generales del derecho tributario a los participantes (incluidos los convenios para evitar la doble imposición), en caso de que los pagos se realizaran al margen de un ARC, como contraprestación por la enajenación de los derechos preexistentes (por ejemplo, una participación en los activos intangibles ya desarrollados en el

ARC, en los trabajos en curso y en los conocimientos adquiridos durante las actividades del ARC en el pasado.) Ningún elemento integrante de un pago de salida de un ARC constituiría un canon por la utilización de activos intangibles, salvo en la medida en que este pago otorgue al pagador únicamente el derecho de uso de los activos intangibles pertenecientes al partícipe saliente, y en la medida en que el pagador no obtenga también un beneficio efectivo sobre el propio activo intangible.

8.36 En ciertos casos, la ausencia de pagos de entrada o de salida no plantea problemas. Por ejemplo, la previsión de estos pagos no es necesaria cuando el acuerdo afecta exclusivamente a la prestación de servicios que los participantes adquieren conjuntamente y pagan a medida que se utilizan y que no generan activos o derechos.

8.37 Cuando un participante se adhiere a un ARC o se retira de él, puede ser necesario ajustar las proporciones relativas de las aportaciones (tomando como referencia la modificación de las cuotas en los beneficios esperados) en función del número incrementado o reducido de partícipes que permanezcan tras la adhesión o la retirada.

8.38 Pueden darse casos en los que, incluso si el ARC no prevé nada en relación con las consecuencias de una adhesión o de una retirada, los participantes efectúen pagos de entrada o de salida y ajusten las proporciones relativas de las aportaciones (reflejando la modificación de las cuotas en los beneficios esperados) cuando se produzcan tales movimientos entre los integrantes del acuerdo. La ausencia de disposiciones específicas a este respecto no impide llegar a la conclusión de la existencia del ARC en relación con actividades ya realizadas, siempre que las intenciones y el comportamiento de las partes intervinientes se ajusten a las directrices contenidas en el presente capítulo. Sin embargo, lo idóneo sería que estos acuerdos se modificaran para abordar expresamente cualquier variación futura en su composición.

8.39 Cuando concluye un ARC, el principio de plena competencia exige que cada participante reciba un beneficio efectivo sobre los resultados de la actividad del ARC, proporcional a su participación en las aportaciones durante toda la duración del acuerdo (ajustada en función de los pagos compensatorios efectivamente realizados, incluyendo aquellos efectuados con motivo de su conclusión). También es posible que uno o varios participantes compensen a otro con un importe de plena competencia a cambio de la renuncia a su derecho en los resultados de la actividad del ARC.

F. Recomendaciones para la estructuración y la documentación de los ARC

8.40 Los ARC debe estructurarse de forma que se ajusten al principio de plena competencia. Para que así sea, el ARC debe cumplir las siguientes condiciones:

- a) los participantes serán exclusivamente empresas que puedan beneficiarse mutuamente con la propia actividad del ARC, directa o indirectamente (y no sólo por el ejercicio de toda o parte de esa actividad). Véase el párrafo 8.10;
- b) el acuerdo debe especificar la naturaleza y la importancia del beneficio efectivo de cada participante sobre los resultados de las actividades del ARC;
- c) no se realizará ningún pago distinto a las aportaciones al ARC, los pagos compensatorios y los pagos de entrada que correspondan para la adquisición del beneficio efectivo sobre los activos, servicios o derechos obtenidos a través del ARC;
- d) el reparto proporcional de las aportaciones debe determinarse adecuadamente, utilizando un método de atribución que refleje la cuota de participación en los beneficios que se espera obtener del acuerdo;
- e) el acuerdo permitirá pagos compensatorios o la modificación a futuro del reparto de aportaciones, una vez transcurrido un plazo razonable, de forma que estas reflejen las variaciones en la cuota de participación en los beneficios esperados de los partícipes; y
- f) pueden efectuarse ajustes, cuando corresponda (comprendidos los posibles pagos de entrada o de salida) por razón de la adhesión o la retirada de un partícipe y de la rescisión del ARC.

8.41 Como se indicó en el Capítulo V sobre Documentación, la aplicación de los principios de prudencia en la administración de empresas debería llevar a los participantes en un ARC a preparar o a recopilar información sobre la naturaleza de la actividad del ARC, los términos del acuerdo y su adhesión al principio de plena competencia. Esto implica que cada partícipe debe tener pleno acceso a los detalles de las actividades que vayan a realizarse en el marco del acuerdo, a las previsiones sobre las que se basarán las aportaciones y se determinarán los beneficios esperados, así como a los gastos presupuestados y reales en relación con la actividad del ARC. Toda esta información podría ser pertinente y útil para las administraciones tributarias en el contexto de los ARC y los contribuyentes

deben poder suministrarla cuando se les solicite. La información relativa a un determinado ARC dependerá de los hechos y de las circunstancias. Conviene subrayar que la información que se cita a continuación no constituye ni un criterio de cumplimiento mínimo ni una enumeración exhaustiva de la información que una administración tributaria puede tener derecho a solicitar.

8.42 La siguiente información relativa a las condiciones iniciales de un ARC es útil e importante:

- a) una lista de participantes;
- b) una lista de cualesquiera otras empresas asociadas que se verán involucradas en la actividad del ARC, o que explotarán o usarán los resultados de esta actividad;
- c) el ámbito de las actividades y proyectos específicos cubiertos por el ARC;
- d) la duración del acuerdo;
- e) los criterios para cuantificar las cuotas de participación en los beneficios esperados correspondientes a cada participante y las previsiones utilizadas para determinar sus importes;
- f) la forma y el valor de las aportaciones iniciales de cada participante, así como una descripción detallada del modo de cuantificar el valor de las aportaciones iniciales y en curso, y de aplicar los principios contables de forma homogénea a todos los participantes para la determinación de los gastos y del valor de las aportaciones;
- g) la atribución apriorística de las responsabilidades y las obligaciones asociadas a la actividad del ARC entre los participantes y otras empresas;
- h) los procedimientos para la adhesión o la retirada de un participante en el ARC, y sus consecuencias, así como los procedimientos y consecuencias en caso de rescisión del ARC; y
- i) las disposiciones que prevean pagos compensatorios o que permitan ajustar los términos del acuerdo para reflejar una modificación de las circunstancias económicas.

8.43 Durante la vigencia del acuerdo, podría ser útil contar con la siguiente información:

- a) cualquier modificación del acuerdo (por ejemplo: en sus condiciones, participes, o en su actividad) y las consecuencias de tal modificación;

- b) una comparación entre las previsiones utilizadas para determinar los beneficios esperados de la actividad del ARC y los resultados reales (no obstante, debe tenerse en cuenta el párrafo 3.74); y
- c) los gastos anuales incurridos para el desarrollo de la actividad del ARC, la forma y el valor de las aportaciones que realiza cada participante durante la vigencia del ARC, así como una descripción detallada del modo de cuantificar el valor de las aportaciones y de cómo se aplican los principios contables uniformemente a todos los partícipes al determinar los gastos y el valor de las aportaciones.

Capítulo IX

Reestructuración de empresas y precios de transferencia

Introducción

A. Ámbito

A.1 *Reestructuraciones empresariales comprendidas en el ámbito de este capítulo*

9.1 No existe una definición jurídica o universalmente aceptada del concepto de reestructuración empresarial. En el contexto de este capítulo, esta expresión se define como la redistribución transnacional de funciones, activos o riesgos que llevan a cabo las empresas multinacionales. Las reestructuraciones de empresas pueden implicar la transferencia internacional de activos intangibles valiosos, aunque no tiene por qué ocurrir siempre así. Puede implicar también la finalización o la renegociación sustancial de acuerdos preexistentes. Las reestructuraciones empresariales comprendidas en el ámbito de este capítulo consisten principalmente en la redistribución interna de funciones, activos y riesgos en el seno de una multinacional, aunque las relaciones de la multinacional con terceros (por ejemplo, proveedores, subcontratistas, clientes) también pueden ser una razón para la reestructuración o quedar afectadas por ella.

9.2 Desde mediados de la década de los 90 las reestructuraciones de empresas más frecuentes han consistido en la centralización de los activos intangibles y de los riesgos, junto con el beneficio potencial que conllevan. Típicamente, han consistido en:

- la transformación de los distribuidores “plenos”^{*} en distribuidores de riesgo limitado o comisionistas que ejercen sus funciones para una

^{*} (N. de la T.) En el original “*full-fledged*”. Con el término “pleno” quiere reflejarse su condición de distribuidor que desarrolla amplias funciones y asume riesgos que exceden de las funciones desarrolladas y de los riesgos asumidos por los distribuidores denominados “de riesgo limitado” (*limited risk*) o “de bajo riesgo” (*low risk*). Por su nivel de “autonomía” se diferencian asimismo de los

empresa extranjera asociada que puede intervenir como empresario principal,

- la transformación de los fabricantes “plenos” en fabricantes por contrato o fabricantes “a precio fijo” para una empresa extranjera asociada que puede intervenir como empresario principal,
- la transferencia de los derechos sobre bienes intangibles a una entidad central dentro del grupo (las denominadas “*IP company*”^{*}).

9.3 Existen también otras reestructuraciones de empresas que conllevan la transferencia de más activos intangibles o riesgos a entidades operativas (por ejemplo, a fabricantes o distribuidores). Las reestructuraciones de empresas pueden consistir también en la racionalización, especialización o generalización de actividades (emplazamientos industriales o procesos de fabricación, actividades de investigación y desarrollo, ventas, servicios) que pueden incluir también la reducción de las operaciones o su cese. El principio de plena competencia y las orientaciones proporcionadas en este capítulo se aplican en igual forma a las diversas clases de operaciones de reestructuración de empresas comprendidas en el ámbito de la definición del párrafo 9.1, con independencia de que conduzcan a un modelo centralizador o descentralizador.

9.4 Los representantes del mundo empresarial que participaron en el proceso de consulta efectuado por la OCDE entre 2005 y 2009 explicaron que, entre las razones para proceder a una reestructuración de empresas, están el deseo de aprovechar al máximo las sinergias generadas y las economías de escala, la optimización de la gestión de las líneas de actividad y la mejora de la eficiencia en la cadena de suministro aprovechando las ventajas de las tecnologías basadas en Internet que han facilitado la aparición de organizaciones globales. Señalaron asimismo que las reestructuraciones de empresas pueden ser necesarias para mantener la rentabilidad o limitar las pérdidas en periodos de descenso en la actividad económica, por ejemplo, en el caso de exceso de capacidad.

distribuidores que operan “por contrato” (*contract distributor*), y de los distribuidores denominados más adelante “menoscabados” (del original “*stripped*”). Esta misma distinción se aplica también en el caso de los fabricantes, entre los que se establece además la diferenciación entre fabricantes “plenos” y los “*toll-manufacturers*”, es decir, los fabricantes “a precio fijo”.

* (N. de la T.) Denominación procedente de su nomenclatura en inglés. IP es el acrónimo de los términos “intangible *property*”, en adelante “Entidad IP”.

A.2 *Cuestiones comprendidas en el ámbito de este capítulo*

9.5 Este capítulo examina los aspectos de la reestructuración de empresas relacionados con los precios de transferencia, es decir, la aplicación del artículo 9 (Empresas asociadas) del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y de estas Directrices a las reestructuraciones empresariales.

9.6 Las reestructuraciones empresariales van acompañadas normalmente de la redistribución de los beneficios entre los miembros de un grupo multinacional, bien inmediatamente tras la reestructuración o a lo largo de unos cuantos años. Uno de los principales objetivos de este capítulo, en relación con el artículo 9, consiste en el análisis de la medida en la que tales redistribuciones de beneficios son coherentes con el principio de plena competencia y, en términos más generales, cómo se aplica el principio de plena competencia a las reestructuraciones empresariales. La aplicación de modelos empresariales integrados y la creación de organizaciones globales, cuando están basadas en razones comerciales legítimas, ponen de relieve la dificultad de seguir el razonamiento teórico de la plena competencia que considera a las empresas integrantes de un grupo multinacional como partes independientes. Esta dificultad conceptual para la aplicación práctica del principio de plena competencia se recoge de hecho en estas Directrices (véanse los párrafos 1.10 y 1.11). A pesar de esta dificultad, estas Directrices son el reflejo del fuerte apoyo que otorgan los países integrantes de la OCDE al principio de plena competencia y de los esfuerzos realizados para describir su concepción y perfeccionar su aplicación práctica (véanse los párrafos 1.14 y 1.15). Al analizar los problemas que se plantean en el contexto de la reestructuración empresarial, la OCDE ha tenido presente esta dificultad conceptual con la intención de elaborar planteamientos realistas y razonablemente pragmáticos.

9.7 Este capítulo aborda únicamente las operaciones entre empresas asociadas en el contexto del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y no la distribución de beneficios en el marco de una única empresa sobre la base del artículo 7 de dicho Modelo, que sí es objeto de estudio en el informe del Grupo de Trabajo nº 6 *sobre la Atribución de beneficios a los establecimientos permanentes*¹. Las pautas contenidas en el

¹ Véase el *Informe sobre la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes*, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 24 de junio de 2008 y por el Consejo para su publicación el 17 de julio de 2008, así como la versión depurada de 2010 del *Informe sobre la Atribución de beneficios a los establecimientos permanentes*, aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 y por el Consejo para su publicación el 22 de julio de 2010.

artículo 9 evolucionaron independientemente del criterio autorizado por la OCDE, desarrollado para su aplicación al artículo 7.

9.8 Las normas nacionales antiabuso y las normas en materia de transparencia fiscal internacional (“*CFC Legislation*”) no están comprendidas en el ámbito de este capítulo. El tratamiento fiscal interno de un pago efectuado en condiciones de plena competencia, incluyendo las normas relativas a la posibilidad de deducir dicho pago y la forma de aplicación de las disposiciones nacionales para la imposición de las ganancias de capital a un pago de capital de plena competencia, tampoco son objeto de estudio en este capítulo. Del mismo modo, tampoco se estudian en este capítulo el IVA y los impuestos indirectos, aun cuando plantean problemas importantes en el contexto de la reestructuración de empresas.

B. Aplicación del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y de estas Directrices a las reestructuraciones de empresas: marco teórico

9.9 Este capítulo parte de la premisa de que el principio de plena competencia y estas Directrices no se aplican ni deben aplicarse de forma distinta a las reestructuraciones o a las operaciones post-reestructuración que a las operaciones inicialmente estructuradas de una forma concreta. La cuestión clave respecto del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y del principio de plena competencia es si en una reestructuración empresarial existen condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes. Este es el marco teórico en el que deben interpretarse todas las pautas que establece este capítulo, que está integrado por cuatro partes que deben leerse conjuntamente.

Parte I: Consideraciones específicas en materia de riesgos

A. Introducción

9.10 Los riegos revisten una importancia fundamental en el contexto de las reestructuraciones empresariales. El análisis de la atribución de riesgos entre empresas asociadas es una parte esencial del análisis funcional. Por lo general, en el mercado libre, la aceptación de un riesgo mayor se compensará con un aumento en los beneficios que se espera obtener, aun cuando el rendimiento real aumentará o no dependiendo del grado en que se materialice efectivamente el riesgo (véase el párrafo 1.45). Las reestructuraciones empresariales suelen provocar que las operaciones locales se transformen en actividades de bajo riesgo (por ejemplo, distribuidores de bajo riesgo, o fabricantes por contrato) a los que se asigna un rendimiento relativamente bajo (pero, por lo general, estable) sobre la base de que es otra la parte que soporta el riesgo empresarial, a la que se le atribuye el resultado residual. Por tanto, es muy importante que las administraciones tributarias evalúen la redistribución de los riesgos importantes de la empresa que se reestructura y las consecuencias de esa redistribución en la aplicación del principio de plena competencia a la propia reestructuración y a las operaciones que la suceden. Esta parte del capítulo trata la atribución de riesgos entre empresas asociadas en el contexto del artículo 9 y, en particular, la interpretación y aplicación de los párrafos 1.47 a 1.53. La intención es la de ofrecer unas pautas generales en relación con los riesgos que resulten útiles para otras cuestiones planteadas en este capítulo, incluido el análisis que se lleva a cabo en la Parte II sobre la compensación de plena competencia por razón de la propia reestructuración, el análisis efectuado en la Parte III sobre la remuneración de las operaciones vinculadas posteriores a la reestructuración, y el análisis de la Parte IV sobre la admisión o no de las operaciones presentadas por el contribuyente.

B. Términos contractuales

9.11 A diferencia del criterio autorizado elaborado para su aplicación en el marco del artículo 7, el análisis de los riesgos que entraña una situación comprendida en el ámbito del artículo 9 comienza con el examen de los términos contractuales acordados entre las partes, ya que esos suelen definir

cómo se distribuyen los riesgos entre ellas. Estos términos son el punto de partida para determinar qué parte de una operación soporta el riesgo que esta conlleva. Por tanto, el que las empresas asociadas documenten por escrito sus decisiones sobre la atribución o transferencia de riesgos importantes antes de proceder a realizar la operación en relación con la que se transferirán o soportarán dichos riesgos constituye una buena práctica, así como que documenten la valoración de las consecuencias que entraña la redistribución de riesgos importantes respecto del beneficio potencial. Como se señaló en el párrafo 1.52, los términos en los que se realiza una operación suelen estar definidos en contratos escritos, en la correspondencia o en las comunicaciones entre las partes. Cuando no existan cláusulas o condiciones escritas, habrá que deducirlas de la conducta de las partes y de los principios económicos que rigen normalmente las relaciones entre empresas independientes.

9.12 Sin embargo, como se señaló en los párrafos 1.47 a 1.53, las administraciones tributarias pueden poner en duda si una pretendida atribución de riesgos entre empresas asociadas, basada en cláusulas contractuales, resulta o no coherente con la sustancia económica de la operación. Por tanto, al examinar la atribución de riesgos entre empresas asociadas y las consecuencias de esta atribución respecto de los precios de transferencia, es importante revisar no sólo los términos contractuales, sino también los siguientes aspectos:

- si la conducta entre las empresas asociadas se ajusta a la atribución de riesgos recogida en el contrato (véase el apartado B.1 a continuación),
- si la atribución de los riesgos en la operación vinculada es de plena competencia (véase el apartado B.2, más adelante), y
- cuáles son las consecuencias de la atribución de riesgos (véase el apartado B.3, más adelante).

B.1 Determinación de si la forma en la que se conducen las empresas asociadas responde a la atribución de riesgos determinada mediante contrato

9.13 En las operaciones entre empresas independientes, la divergencia de intereses entre las partes garantiza su empeño en el respeto mutuo del contrato y en que las cláusulas contractuales únicamente se ignoren o modifiquen posteriormente si es en beneficio de ambas partes. Esa misma divergencia de intereses puede no existir en el caso de empresas asociadas, por lo que es importante verificar si la conducta de las partes se ajusta a los términos del contrato o si, por el contrario, su forma de conducirse indica que

no se han seguido los términos contractuales o que estos son una mera simulación. En tales casos, es necesario profundizar en el análisis para determinar los términos auténticos de la operación.

9.14 Suele considerarse la conducta de las partes como la evidencia más clara de la auténtica atribución de los riesgos. El párrafo 1.48 ofrece un ejemplo sobre un fabricante que vende bienes a un distribuidor asociado en otro país, en el que se sostiene que el distribuidor asume todos los riesgos derivados del tipo de cambio cuando, sin embargo, el precio de transferencia parece de hecho ajustado de forma que el distribuidor está protegido de las oscilaciones del tipo de cambio. En ese caso, las administraciones tributarias podrían cuestionar la pretendida atribución del riesgo derivado del tipo de cambio.

9.15 Otro ejemplo pertinente al caso de las reestructuraciones empresariales es aquel en el que una empresa asociada extranjera asume por contrato todos los riesgos de inventario. Cuando se analiza esta atribución de riesgos puede ser oportuno considerar, por ejemplo, donde se contabilizan las pérdidas de inventario (es decir, si el contribuyente nacional deduce las pérdidas) y buscar confirmación sobre si la conducta de las partes coincide con la atribución de riesgos prevista en el contrato.

9.16 Un tercer ejemplo puede tratar sobre la determinación de qué parte soporta el riesgo de crédito en un acuerdo de distribución. En los acuerdos de distribución "plena", el distribuidor que contabiliza los ingresos procedentes de las ventas suele soportar el riesgo de impago (con independencia de los mecanismos de atenuación o de transferencia del riesgo que pueda aplicar). Normalmente, este riesgo quedará reflejado en el balance a final de año. Sin embargo, la amplitud del riesgo asumido por el distribuidor en condiciones de plena competencia puede ser distinta si este recibe una indemnización por un tercero (por ejemplo, un proveedor) por las deudas incobrables, o si el precio de compra se determina sobre la base del precio de reventa o de una comisión proporcional a la renta cobrada (no a la facturada). El análisis de las condiciones reales de las operaciones entre las partes, comprendida la fijación del precio de la operación y el grado, cuando sea pertinente, en que le afecta el riesgo de crédito, puede constituir una prueba de si es un hecho cierto el que el proveedor, o el distribuidor (o ambos) soporte(n) el riesgo de impagos.

B.2 *Determinación de si la atribución de los riesgos en una operación vinculada es conforme con el principio de plena competencia*

9.17 Los párrafos 1.47 a 1.51 contienen las pautas aplicables al análisis de riesgos en el contexto del análisis funcional.

B.2.1 *El papel que desempeñan los comparables*

9.18 Cuando los datos muestren una atribución de riesgos similar en operaciones no vinculadas comparables, la atribución de riesgos entre empresas asociadas se considerará de plena competencia. A tal fin, pueden encontrarse datos comparables en una operación entre una de las partes de la operación vinculada y una parte independiente (“comparable interno”) o en una operación entre dos empresas independientes, ninguna de las cuales interviene en la operación vinculada (“comparable externo”). Por lo general, la búsqueda de comparables para valorar la coherencia de la atribución de riesgos con el principio de plena competencia no se desvinculará del análisis de comparabilidad general de las operaciones a las que está asociado el riesgo. Los datos comparables servirán para verificar el cumplimiento del principio de plena competencia en las operaciones vinculadas, comprendida la atribución de los riesgos significativos que comporte la operación.

B.2.2 *Casos en los que no pueden encontrarse comparables*

9.19 Reviste más dificultad y es mucho más controvertida aquella situación en la que no pueden encontrarse comparables que demuestren la coherencia de la atribución del riesgo en una operación vinculada con el principio de plena competencia. El mero hecho de que no pueda encontrarse entre empresas independientes un acuerdo suscrito entre empresas asociadas no determina su alejamiento del principio de plena competencia. Sin embargo, cuando no pueden encontrarse comparables que refrenden una atribución contractual de riesgos entre empresas asociadas, es preciso determinar si esa atribución de riesgos es la que hubieran acordado partes independientes en circunstancias similares.

9.20 Esta determinación es, en sí misma, subjetiva, por lo que resulta deseable contar con ciertas pautas de evaluación que limiten en lo posible la incertidumbre y los riesgos de doble imposición que pueda generar. Un factor importante, aunque no determinante, que puede ayudar en tal determinación es el examen de la parte o partes que tienen mayor control sobre el riesgo, como se analiza en los párrafos 9.22 a 9.28 más adelante. En el contexto de las operaciones efectuadas en condiciones de plena competencia, otro factor que puede influir en la voluntad de una parte

independiente de asumir un riesgo es su capacidad financiera para proceder a ello, como se verá en los párrafos 9.29 a 9.32. No es posible proponer un criterio prescriptivo que elimine la incertidumbre en todas las situaciones, más allá de identificar estos dos importantes factores. Por tanto, determinar si la atribución del riesgo en una operación vinculada no es la que hubieran acordado partes independientes, es un proceso al que debe aplicarse gran cautela, considerando los hechos y circunstancias de cada caso.

9.21 La referencia a las nociones de “control sobre el riesgo” y de “capacidad financiera para asumir el riesgo” no pretende determinar un criterio al amparo del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario, en virtud del cual la atribución de los riesgos deba hacerse sistemáticamente en función del capital o de las funciones humanas. El marco analítico del artículo 9 difiere del criterio autorizado de la OCDE desarrollado en relación con el artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario.

B.2.2.1 Atribución del riesgo y control

Importancia de la noción de “control”

9.22 La cuestión de la relación entre la atribución del riesgo y el control como factor relacionado con la sustancia económica se aborda en el párrafo 1.49. Lo allí expuesto se basa en la experiencia. En ausencia de comparables que evidencien la coherencia de la atribución del riesgo en el marco de una operación vinculada con el principio de plena competencia, analizar qué parte que tiene mayor capacidad de control del riesgo puede ser un factor importante para llegar a determinar si esa misma atribución hubiera sido la acordada entre partes independientes en circunstancias comparables. Siendo así, si los riesgos se atribuyen a la parte de la operación vinculada que relativamente tiene menos control sobre ellos, la administración tributaria puede oponerse a considerar que esa atribución de riesgos es de plena competencia.

Significado del término “control” en este contexto

9.23 En el contexto del párrafo 1.49, el término “control” debe entenderse como la capacidad para tomar decisiones relativas a la asunción de riesgos (la decisión de arriesgar capital) y aquellas relativas a cuándo y cómo gestionar el riesgo, a nivel interno o utilizando un proveedor externo. Esto exigiría que la sociedad contara con personas –empleados o administradores– que estuvieran facultados para llevar a cabo estas funciones de control, y que las realizaran efectivamente. Así, cuando una parte soporta un riesgo, el hecho de que contrate con otra parte la gestión y supervisión cotidianas no es suficiente para transferir el riesgo a esa otra parte.

9.24 Si bien no es necesario desarrollar las funciones cotidianas de gestión y supervisión para controlar un riesgo (ya que es posible externalizar estas funciones), sí es necesario poder valorar el resultado de esa gestión y supervisión cotidianas que realiza el proveedor del servicio (el nivel de control necesario y el tipo de evaluación de resultados dependerá de la naturaleza del riesgo). Los ejemplos que siguen ilustran este criterio.

9.25 Supongamos que un inversor contrata a un gestor de fondos para invertir fondos por su cuenta. Dependiendo del acuerdo al que lleguen el inversor y el gestor de fondos, este último podrá estar facultado para adoptar todas las decisiones cotidianas relativas a la inversión en nombre del inversor, si bien es el propio inversor quien asume el riesgo de pérdida de valor de la inversión. En este caso, el inversor controla sus riesgos a través de tres decisiones fundamentales: la decisión de contratar a ese gestor de fondos concreto (o de poner fin al contrato), la decisión sobre la amplitud de las facultades que confiere al gestor de fondos, junto con los objetivos que le fija, y la decisión sobre la cuantía de la inversión que confía a este gestor de fondos. Asimismo, el gestor de fondos tendrá que rendir cuentas regularmente al inversor en la medida en que este quiera evaluar los resultados de la actividad. En este ejemplo, el gestor de fondos presta un servicio y gestiona su riesgo operativo según su propio interés (por ejemplo, para proteger su credibilidad). El riesgo operativo del gestor de fondos, comprendida la posibilidad de pérdida de un cliente, es distinto del riesgo de inversión de su cliente. Con esto se ilustra el hecho de que un inversor que confiere a un tercero la capacidad de tomar las decisiones cotidianas sobre la inversión no le está transfiriendo necesariamente el riesgo de inversión.

9.26 Otro ejemplo: supongamos que un empresario principal contrata a un investigador por contrato para que realice una investigación en su nombre. Supongamos que el acuerdo al que llegan ambas partes es que el empresario principal soporta el riesgo de fracaso en la investigación y que, en caso de éxito, será el propietario del resultado; por su parte, al investigador por contrato se le asigna una remuneración garantizada con independencia del éxito o el fracaso de la investigación, y no se le confiere derecho de propiedad alguno sobre los resultados. Aun cuando la investigación cotidiana estará a cargo de personal científico del investigador por contrato, el empresario principal tendrá que adoptar una serie de decisiones importantes y necesarias para controlar el riesgo como pueden ser: la decisión de contratar a ese investigador concreto (o de poner fin al contrato), la decisión sobre el tipo de investigación que debe llevarse a cabo, junto con la determinación de objetivos, y la decisión sobre la dotación presupuestaria para la remuneración del investigador por contrato. Asimismo, el investigador por contrato tendrá que rendir cuentas de su actividad

regularmente al empresario principal, por ejemplo, según se vayan cumpliendo objetivos. El empresario principal deberá poder evaluar los resultados de las actividades de investigación. El riesgo operativo del investigador contratado, a saber, el riesgo de perder un cliente o de sufrir una sanción en caso de negligencia, es distinto del riesgo de fracaso que soporta el empresario principal.

9.27 Un tercer ejemplo podría consistir en lo siguiente: supongamos ahora que un empresario principal contrata a un fabricante para que fabrique productos en su nombre sirviéndose de la tecnología que posee el primero. Supongamos que el acuerdo al que llegan las partes es que el empresario principal garantiza al fabricante por contrato que le adquirirá el 100 por cien de los productos que fabrique siguiendo sus especificaciones técnicas y diseños, y aplicando un plan de fabricación en el que se determina el volumen de producción y los plazos de entrega. Por su parte, al fabricante por contrato se le asigna una contraprestación garantizada, con independencia de que el empresario principal pueda colocar los productos en el mercado y, de ser así, del precio al que los venda. Si bien será el personal del fabricante por contrato quien realice la actividad cotidiana de fabricación, el empresario principal tendrá que adoptar una serie de decisiones importantes para poder controlar los riesgos de mercado y de existencias, por ejemplo: la decisión de contratar a ese fabricante en concreto (o de poner fin al contrato), la decisión sobre el tipo de producto que debe fabricar, junto con las especificaciones técnicas, y la decisión sobre las unidades que debe fabricar el fabricante por contrato y los plazos de entrega. El empresario principal debe poder evaluar el resultado de las actividades de fabricación y llevar a cabo los controles de calidad del proceso fabril y del producto fabricado. El riesgo operativo del fabricante por contrato, a saber, el riesgo de perder un cliente o de sufrir una sanción en caso de negligencia o de incumplimiento de los estándares de calidad u otros fijados por el empresario principal, es distinto de los riesgos de mercado y de existencias que soporta el empresario principal.

9.28 No debe olvidarse el hecho de que existen otros riesgos sobre los que ninguna de las partes tiene un control efectivo, como ya se señaló en el párrafo 1.49. Son riesgos que exceden el área de influencia de las partes (por ejemplo, la coyuntura económica, el estado de los mercados monetarios y de la bolsa, la situación política, las tendencias y características sociales, la competencia y la disponibilidad de materia prima y de mano de obra), aun cuando las partes pueden adoptar decisiones por lo que respecta a su exposición a estos riesgos y sobre la posibilidad de mitigarlos y cómo. Por lo que respecta a estos riesgos que las partes no pueden controlar, el control no

sería un factor coadyuvante en la determinación de si su atribución entre las partes es o no de plena competencia.

B.2.2.2 Capacidad financiera para asumir el riesgo

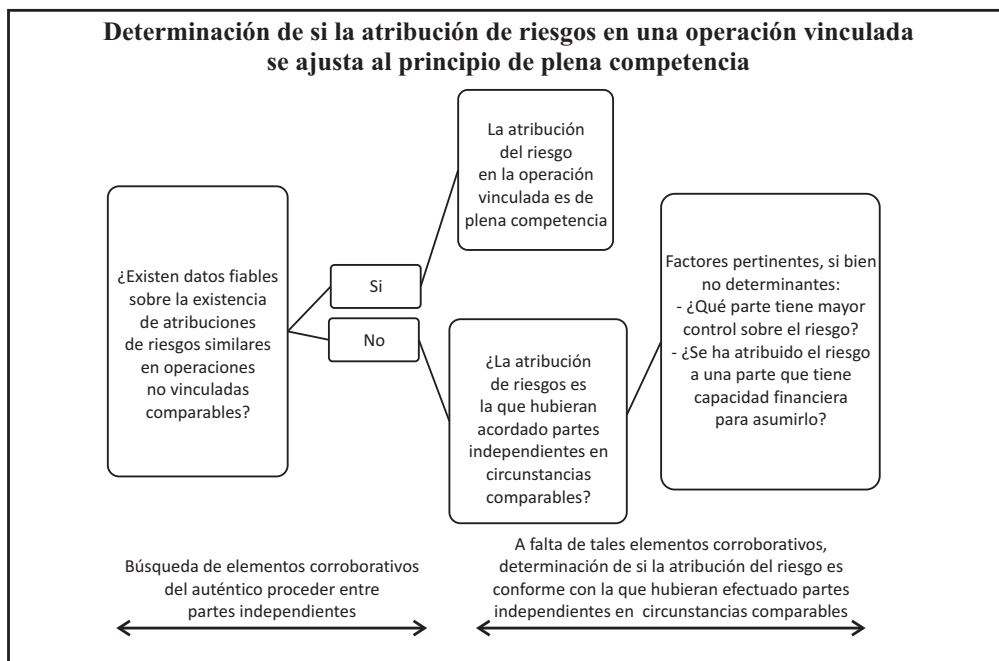
9.29 Otro factor importante, aunque no determinante, que puede ayudar en la determinación de si la atribución de un riesgo en el marco de una operación vinculada es la que hubieran efectuado partes independientes en circunstancias comparables, es si la parte que soporta el riesgo tiene, en el momento en que este se le atribuye, capacidad financiera para asumirlo.

9.30 Cuando el riesgo se atribuye por contrato a una parte (en adelante “el adquirente del riesgo”) que no tiene capacidad financiera para asumirlo en el momento de celebrar el contrato, por ejemplo porque se prevé que no tendrá capacidad para soportar las consecuencias de la materialización del riesgo y porque tampoco establece un mecanismo para su cobertura, se plantea la duda de si la atribución del riesgo a esta parte es una atribución de plena competencia. Efectivamente, en esta situación, el riesgo puede ser efectivamente soportado por su transmitente, la sociedad matriz, los acreedores u otra parte, dependiendo de los hechos y circunstancias de cada caso, con independencia de las cláusulas contractuales que supuestamente asignan el riesgo al adquirente.

9.31 Esta circunstancia puede ilustrarse como sigue: supongamos que la Sociedad A asume la responsabilidad del producto frente a sus clientes y que celebra un contrato con la Sociedad B conforme al que esta última reembolsará a A toda reclamación que A pueda sufrir sobre la base de esta responsabilidad. Existe una cesión contractual del riesgo de A a B. Supongamos ahora que, en el momento de celebrar el contrato, la Sociedad B no tiene capacidad financiera para asumir el riesgo, es decir, se prevé que B no podrá reembolsar a A en caso de reclamación y que tampoco ha establecido un mecanismo de cobertura del riesgo en caso de que este se materialice. Dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, esta circunstancia puede provocar que A soporte efectivamente el coste de la materialización del riesgo de responsabilidad sobre el producto, en cuyo caso la transferencia de riesgo de A a B no será efectiva. Por el contrario, puede ocurrir que la sociedad matriz de B u otra parte, cubra la reclamación que A tiene frente a B, en cuyo caso la transferencia del riesgo que ha hecho A será efectiva (aun cuando no sea B quien hace frente a la reclamación).

9.32 La capacidad financiera de asunción del riesgo no coincide necesariamente con la capacidad financiera para soportar todas las consecuencias de la materialización del riesgo, dado que dependerá de la

capacidad de la parte que soporta el riesgo para autoprotegerse de las consecuencias de su materialización. Es más, un nivel elevado de capitalización no implica por sí mismo que la parte fuertemente capitalizada soporte el riesgo.



B.2.2.3 Ejemplo

9.33 El proceso general de determinación de si la atribución de riesgos en una operación vinculada se ajusta o no al principio de plena competencia puede ilustrarse como sigue:

B.2.3 Diferencia entre practicar un ajuste de comparabilidad y el rechazo de la atribución de los riesgos efectuada en el marco de una operación vinculada²

9.34 La diferencia entre practicar un ajuste de comparabilidad y no aceptar la atribución de riesgos en una operación vinculada puede ilustrarse con el siguiente ejemplo, que sigue las líneas de lo expuesto en el párrafo 1.69. Supongamos que un fabricante en el país A tiene distribuidores asociados en el país B. Supongamos asimismo que la administración tributaria del país A está inspeccionando las operaciones vinculadas del fabricante y, en concreto, la atribución del riesgo de exceso de inventario entre el fabricante y sus distribuidores asociados en el país B. Se parte de la hipótesis de que en este caso concreto, el riesgo de exceso de inventario es importante y merece un análisis minucioso de los precios de transferencia. Como punto de partida, la administración tributaria examinará los términos contractuales acordados entre las partes, si estos tienen trascendencia económica (lo que se determinará en función de la conducta de las partes), y si son de plena competencia. Supongamos que en este caso no hay duda de que el proceder de las partes es coherente con los términos contractuales, es decir, que el fabricante realmente soporta el riesgo de exceso de inventario en sus operaciones vinculadas con distribuidores asociados.

9.35 Para determinar si la atribución contractual de los riesgos es conforme con el principio de plena competencia, la administración tributaria examinará si pueden extraerse datos de las operaciones no vinculadas comparables que corroboren la atribución de los riesgos en el marco de las operaciones vinculadas del fabricante. Si existen tales pruebas, ya procedan de comparables internos o externos, no habrá razones para oponerse a la atribución de riesgos efectuada por el contribuyente en sus operaciones vinculadas.

9.36 Supongamos ahora que no existen pruebas, ni de comparables externos ni internos, que apoyen la atribución de riesgos efectuada en las operaciones vinculadas del fabricante. Como se señaló en el párrafo 1.69, el hecho de que las empresas independientes no atribuyan sus riesgos del mismo modo que el contribuyente en sus operaciones vinculadas no es suficiente en sí mismo para no aceptar la atribución de riesgos efectuada en el marco de la operación vinculada, pero sí puede constituir una razón para examinar más detenidamente la lógica económica del acuerdo de distribución vinculado. En ese caso sería necesario determinar si la atribución

² Esta sección vincula las pautas recogidas en el párrafo 1.49 con las de los párrafos 1.64 a 1.69.

contractual de los riesgos en la operación vinculada se habría efectuado en condiciones de plena competencia. Un factor coadyuvante en tal determinación es el análisis de qué parte o partes tienen mayor control sobre el riesgo de exceso de inventario (véanse los párrafos 1.49 y 9.22 a 9.28 más arriba). Como se señala en el párrafo 9.20, en las operaciones efectuadas en condiciones de plena competencia, otro factor que puede influir en la atribución del riesgo a una parte independiente es su capacidad financiera para asumir dicho riesgo en el momento de su atribución.

9.37 Podría ocurrir que, a pesar de la falta de operaciones no vinculadas comparables que corroboraran la atribución de riesgos efectuada en la operación vinculada del contribuyente, esta atribución de riesgos tuviera un trasfondo económico y fuera razonable desde el punto de vista comercial, por ejemplo debido al hecho de que el fabricante tiene un mayor control relativo sobre el riesgo de exceso de inventario, dado que es él quien toma las decisiones sobre la cantidad de producto adquirido por los distribuidores. En tal caso, se respetaría la atribución de riesgos y podría ser necesario realizar un ajuste de comparabilidad que eliminara los efectos de cualquier diferencia significativa que pudiera existir entre las operaciones vinculadas y no vinculadas objeto de comparación.

9.38 Supongamos ahora que la administración tributaria observa que los acuerdos suscritos por el contribuyente en relación con sus operaciones vinculadas, y en concreto la atribución del riesgo de exceso de inventario al fabricante, difieren de lo que hubieran acordado empresas independientes cuyo proceder se ajustara a la lógica comercial y que, en circunstancias comparables y en condiciones de plena competencia, un fabricante no aceptara asumir un riesgo sustancial de exceso de inventario, por ejemplo, acordando adquirir nuevamente a los distribuidores las existencias no vendidas al precio inicial. En tal caso, la administración tributaria debería buscar una solución razonable mediante el ajuste de precios. No obstante, en las circunstancias excepcionales en las que no se puede llegar a una solución razonable a través del ajuste de los precios de transferencia, la administración tributaria podrá redistribuir las consecuencias de la atribución de los riesgos a los distribuidores asociados siguiendo las directrices marcadas en los párrafos 1.47 a 1.50 (por ejemplo, no admitiendo la obligación del fabricante de recomprar las existencias no vendidas al precio inicial) si la atribución de ese riesgo es uno de los factores de comparabilidad que afectan a la operación vinculada objeto de examen.

B.3 ¿Cuáles son las consecuencias de la atribución de riesgos?

B.3.1 Consecuencias de una atribución de riesgos admitida a efectos fiscales

9.39 En general, las consecuencias que entraña la atribución de un riesgo asociado a una operación vinculada para una parte, cuando se considere que esa atribución es de plena competencia, son que dicha parte deberá:

- a) soportar los costes, si los hubiera, de gestión (interna o a través de proveedores de servicios asociados o independientes) o de atenuación del riesgo (por ejemplo los costes de cobertura o las primas de seguros);
- b) soportar los costes que pueda entrañar la materialización del riesgo. Esto incluye, cuando corresponda, los efectos previstos de dicha materialización sobre la valoración del activo (de inventario, por ejemplo) o la dotación de provisiones, según las normas contables y fiscales aplicables en el país, y
- c) por lo general, recibir una compensación mediante un incremento en el rendimiento esperado (véase el párrafo 1.45).

9.40 La reasignación de los riesgos entre empresas asociadas puede tener efectos tanto positivos como negativos para el transmitente y el adquirente: por un lado, las pérdidas y responsabilidades potenciales pueden atribuirse al adquirente como resultado de la cesión; por otro lado, es el adquirente y no el transmitente quien obtendrá los beneficios esperados vinculados al riesgo transferido.

9.41 Es importante evaluar si el riesgo es significativo desde el punto de vista económico, es decir, si entraña un beneficio potencial significativo y, por tanto, si la reasignación de ese riesgo puede explicar una reasignación significativa de beneficio potencial. La importancia de un riesgo dependerá de su volumen y de la probabilidad y previsibilidad de su materialización, así como de la posibilidad de mitigarlo. Si el análisis del riesgo determina que no es significativo desde el punto de vista económico, su asunción o reasignación no explicará, por lo general, una cuantía sustancial de beneficios o una reducción significativa del beneficio potencial. En condiciones de plena competencia no es de esperar que una parte transfiera un riesgo que no se considera significativo desde el punto de vista económico a cambio de una reducción sustancial de su beneficio potencial.

9.42 Por ejemplo, cuando un distribuidor con capacidad de compra y venta pasa a ser un comisionista, transfiere la propiedad de sus existencias a

un empresario principal extranjero y, en la medida en que esta operación entraña una transferencia del riesgo de inventario, la administración tributaria estará interesada en conocer si el riesgo de inventario que se transfiere es significativo desde el punto de vista económico, para lo que podrá inquirir sobre:

- el nivel de inversión en inventario,
- el histórico de obsolescencia de las existencias,
- el coste de su seguro, y
- el histórico de pérdidas durante el transporte (en caso de no estar aseguradas).

9.43 Los registros contables pueden proporcionar información valiosa sobre la probabilidad y la magnitud de ciertos riesgos (por ejemplo, los riesgos de impagos o de inventario), pero también hay riesgos con importancia económica que no se reflejan como tal en los estados financieros (por ejemplo, los riesgos de mercado).

B.3.2 ¿Puede generar un entorno de bajo riesgo la utilización de un método concreto de determinación de precios de transferencia?

9.44 La cuestión de la relación entre la elección de un método de determinación de precios de transferencia concreto y el nivel de riesgo que sigue asumiendo la entidad remunerada sobre la base de ese método, reviste gran importancia en el contexto de la reestructuración empresarial. Suele ser habitual sostener que dado que un acuerdo se remunera utilizando un método que garantiza cierto nivel de beneficio bruto o neto a una de las partes, como el método del coste incrementado o el del margen neto operacional, esa parte opera en un entorno de bajo riesgo. En este sentido debe distinguirse entre, por una parte, la determinación contractual del precio y de otras condiciones financieras de la operación y, por otro lado, el método de determinación de precios de transferencia al que se recurre a fin de verificar si el precio, el margen o los beneficios de una operación son conformes con las condiciones de plena competencia.

9.45 Por lo que respecta a las primeras, las condiciones contractuales en virtud de las cuales se remunera a una de las partes no pueden ignorarse a la hora de evaluar el riesgo soportado por esa parte. En efecto, el acuerdo de precios de transferencia puede afectar directamente a la atribución de ciertos riesgos entre las partes y, en algunos casos, puede generar un entorno de bajo riesgo. Por ejemplo, un fabricante puede estar protegido del riesgo de

fluctuación del precio de las materias primas como consecuencia de estar remunerado sobre la base del coste incrementado, que tiene en cuenta sus costes efectivos. Por otro lado, pueden existir ciertos riesgos cuya atribución no resulte del acuerdo de precios de transferencia. Por ejemplo, remunerar una actividad de fabricación sobre la base del coste incrementado no tiene que incidir necesariamente *per se* sobre la atribución del riesgo de finalización del contrato de fabricación entre las partes.

9.46 En relación con el método de determinación de precios de transferencia utilizado para comprobar los precios, márgenes o beneficios de la operación, debe optarse por el más apropiado para las circunstancias del caso (véase el párrafo 2.2). En concreto, el método debe ser coherente con la atribución de riesgos entre las partes (siempre que dicha atribución de riesgos sea de plena competencia), dado que tal atribución es una parte importante del análisis funcional de la operación. Por tanto, debe ser el mayor o menor nivel de riesgo de la actividad el que deba dictar la selección del método de precios de transferencia más apropiado, y no al contrario. Véase la Parte III de este capítulo, donde se analiza la remuneración de plena competencia para las operaciones posteriores a la reestructuración.

C. Cuestiones de cumplimiento

9.47 Una buena práctica que pueden seguir los contribuyentes es la de establecer un proceso que les permita determinar, controlar y revisar sus precios de transferencia, teniendo en cuenta el volumen de las operaciones, su complejidad, el nivel de riesgo que entrañan y el hecho de que se desarrollen en un entorno estable o variable (véanse los párrafos 3.80 a 3.83). Evaluar si las atribuciones de riesgo efectuadas por un contribuyente son coherentes con el principio de plena competencia puede ser un proceso costoso y generador de dificultades. Lo razonable es esperar que la amplitud y exhaustividad del análisis dependa:

- de la importancia del riesgo y, en particular, de si conlleva un beneficio potencial importante, y
- de si han ocurrido cambios importantes en la atribución del riesgo, por ejemplo, tras una modificación importante del perfil de riesgo como resultado de una reestructuración.

Parte II: compensación de plena competencia por la propia reestructuración

A. Introducción

9.48 Una reestructuración de empresas puede conllevar transferencias transfronterizas de algunos elementos de valor, por ejemplo, activos intangibles valiosos, aunque no siempre es así. Puede ocurrir también, u opcionalmente, que implique la finalización de acuerdos vigentes o su renegociación sustancial, por ejemplo de los contratos de fabricación, de distribución, de licencia, de prestación de servicios, etc. Las consecuencias que entraña la transferencia de un elemento valioso en los precios de transferencia se abordan en la Sección D de esta parte, y en la Sección E se abordan las consecuencias en materia de precios de transferencia que implican la finalización o la renegociación sustancial de los acuerdos vigentes.

9.49 Conforme a los términos del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, cuando en una transferencia de funciones, activos o riesgos, o en el caso de la finalización o la renegociación de la relación contractual entre dos empresas asociadas ubicadas en dos países distintos, se acepten o impongan condiciones que difieran de las que serían acordadas o impuestas entre empresas independientes, los beneficios que hubiera obtenido una de las empresas de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se hayan realizado a causa de las mismas, pueden incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

B. Comprender la propia reestructuración

9.50 Para poder determinar si las condiciones acordadas o impuestas en una operación de reestructuración empresarial son de plena competencia se recurrirá al análisis de comparabilidad y, en concreto, al examen de las funciones ejercidas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes, así como de los términos contractuales, las circunstancias económicas y las estrategias empresariales.

9.51 Cuando se identifiquen operaciones no vinculadas potencialmente comparables a las operaciones de reestructuración, el análisis de

comparabilidad se orientará también hacia la valoración de la fiabilidad de la comparación y, cuando sea posible y necesario, hacia la determinación de los ajustes de comparabilidad razonablemente precisos que permitan eliminar los efectos importantes de las diferencias que se observen entre las situaciones objeto de comparación.

9.52 Puede ocurrir que no se encuentren operaciones no vinculadas que puedan compararse a una operación de reestructuración entre empresas asociadas. Esto no significa que la reestructuración en sí misma no se haya desarrollado en condiciones de plena competencia, pero sí sigue siendo necesario determinar si satisface ese principio.³ En estos casos, para determinar si cabría esperar que partes independientes acordaran las mismas condiciones en circunstancias comparables, puede resultar útil revisar:

- Las operaciones de reestructuración y las funciones, activos y riesgos previos y posteriores a la reestructuración (véase la Sección B.1);
- Las razones empresariales para la reestructuración y los beneficios que se espera obtener de ella, incluido el papel de las sinergias (véase la Sección B.2);
- Las opciones disponibles de modo realista para las partes (véase la Sección B.3).

B.1 Identificación de las operaciones de reestructuración: funciones, activos y riesgos previos y posteriores a la reestructuración

9.53 Las reestructuraciones pueden adoptar formas diversas y pueden implicar sólo a dos o a más miembros de un grupo multinacional. Por ejemplo, un simple acuerdo previo a la reestructuración puede atañer a un fabricante “pleno”^{*} que produzca bienes y los venda a un distribuidor asociado, igualmente “pleno”, para su venta en el mercado. La reestructuración podría llevar a la modificación de este acuerdo entre las dos partes, convirtiendo al distribuidor en un distribuidor de riesgo limitado o comisionista, siendo el fabricante quien asuma el riesgo que anteriormente asumía el distribuidor (véase el análisis de los riesgos en la Parte I de este capítulo). Normalmente las reestructuraciones son más complejas, las funciones, los activos o los riesgos que incumben a una de las partes, o a ambas, antes de la reestructuración, se transfieren a un tercero o terceros miembros del grupo.

³ Véase el párrafo 1.11

^{*} (N. de la T). Véase nota de traducción al párrafo 9.2

9.54 A fin de determinar la compensación de plena competencia que deben percibir las entidades reestructuradas en el seno de un grupo multinacional, así como qué miembro del grupo debe soportar esa compensación, es importante identificar la operación u operaciones que ocurren entre la entidad reestructurada y otro u otros miembros del grupo. Este análisis normalmente precisará de la identificación de las funciones, activos y riesgos previos y posteriores a la reestructuración. Puede ser importante analizar los derechos y obligaciones de la entidad reestructurada en virtud del acuerdo previo a la reestructuración (incluyendo, cuando corresponda, los derechos y obligaciones vigentes por contrato o en aplicación del derecho mercantil) y la forma y el grado en que tales derechos y obligaciones varían como resultado de la reestructuración.

9.55 Obviamente, toda evaluación de derechos y obligaciones de la entidad reestructurada debe basarse necesariamente en que esos derechos y obligaciones reflejan los principios económicos que rigen las relaciones entre empresas independientes (véanse los párrafos 1.52 y 1.53). Por ejemplo, una entidad reestructurada puede operar, desde el punto de vista jurídico, en el marco de un contrato a corto plazo o de libre rescisión en el momento de la reestructuración. Sin embargo, el modo de proceder de la entidad en los años o décadas previos a la reestructuración puede ser indicativo de un acuerdo a largo plazo, y tener por tanto más derechos que los previstos en el acuerdo contractual.

9.56 En ausencia de pruebas sobre los derechos y obligaciones que existirían en una situación comparable, puede ser necesario determinar qué derechos y obligaciones se hubieran previsto en caso de que las partes operaran entre sí en condiciones de plena competencia. Al proceder a esa evaluación debe tenerse especial cuidado en no recurrir a la retrospección (véase el párrafo 3.74).

B.2 *Comprensión de las razones empresariales para la reestructuración y de los beneficios que se espera obtener de ella, incluido el papel de las sinergias*

9.57 La representación empresarial que participó en el proceso de consulta efectuado por la OCDE, explicó que entre las empresas multinacionales, con independencia de sus productos o sectores de actividad, crecía la necesidad de reorganizar sus estructuras con el fin de centralizar el control y la gestión de las funciones de fabricación, investigación y distribución. Los factores que identificaron como importantes motivaciones para la reestructuración empresarial fueron: la

presión que ejerce la competencia en una economía globalizada, el ahorro que suponen las economías de escala, la necesidad de especialización y la de aumentar la eficiencia y reducir costes. Cuando un contribuyente plantea que la perspectiva de generar sinergias constituye una razón empresarial importante para proceder a la reestructuración, el contribuyente, como buena práctica, debe documentar, en el momento en el que se decide efectuar la reestructuración o que se efectúa de hecho, cuáles son esas sinergias y en qué se basa para preverlas. Es probable que este tipo de documentación se prepare a nivel de grupo con fines distintos de los fiscales, como apoyo en la toma de decisiones sobre la reestructuración. A los efectos del artículo 9 sería una buena práctica que el contribuyente documentara cómo esas sinergias anticipadas influyen a nivel de la entidad en la aplicación del principio de plena competencia. A este respecto, si bien las sinergias anticipadas pueden ser necesarias para entender una reestructuración empresarial, es preciso evitar el uso de la retrospección en los análisis a posteriori (véase el párrafo 3.74).

9.58 El hecho de que una reestructuración empresarial pueda estar motivada por la perspectiva de sinergias no significa necesariamente que los beneficios del grupo multinacional se vayan a incrementar tras la reestructuración. Puede ocurrir que la mejora en las sinergias permita al grupo multinacional obtener beneficios adicionales en comparación con la situación a la que hubiera llegado en el futuro en caso de no reestructurarse, pero no tiene que tener necesariamente más beneficios de los que obtuviera antes de la reestructuración, por ejemplo, si la reestructuración es necesaria para mantener la competitividad y no para incrementarla. Del mismo modo, no siempre se materializan las sinergias, puede haber casos en los que la puesta en marcha de un modelo operativo mundial concebido para generar mayores sinergias en el grupo conlleve costes adicionales y una reducción en la eficiencia.

B.3 Otras opciones disponibles de modo realista

9.59 La aplicación del principio de plena competencia se basa en la idea de que para evaluar los términos de una operación potencial, las sociedades independientes compararán esta operación a otras alternativas disponibles de modo realista y únicamente concluirán la operación si no encuentran una solución claramente más ventajosa. Dicho de otro modo, las empresas independientes únicamente realizarán la operación si no existe otra opción más favorable. El examen de las demás opciones disponibles de modo

realista puede ser oportuno al efectuar el análisis de comparabilidad, a fin de comprender las posiciones respectivas de las partes.

9.60 Por tanto, al aplicar el principio de plena competencia, las administraciones tributarias evalúan cada operación tal como la ha estructurado el contribuyente, a menos que se ignoren conforme a las directrices contenidas en el párrafo 1.65. Sin embargo, hay que considerar otras estructuras alternativas disponibles de modo realista para la sociedad a la hora de evaluar si los términos de la operación vinculada (especialmente la determinación de precios) resultarían aceptables para un contribuyente no vinculado que operara en condiciones comparables y que tuviera que elegir entre esas mismas alternativas. No se ignorará una operación aun cuando hubiera podido optarse por una estructura más rentable si la sustancia económica de la estructura presentada por el contribuyente no difiere de esta en la forma y no resulta irracional, desde el punto de vista comercial, en el sentido de que prácticamente impida a la administración tributaria determinar un precio de transferencia apropiado. No obstante, la remuneración de la operación vinculada puede ajustarse tomando como referencia los beneficios que hubieran podido obtenerse con la otra estructura, dado que las empresas independientes únicamente llevan a cabo una operación si no encuentran alternativas que les resulten claramente más atractivas.

9.61 En condiciones de plena competencia hay situaciones en las que una entidad hubiera podido optar por más de una opción disponible de modo realista que resultara claramente más atractiva que aceptar las condiciones de la reestructuración (teniendo en cuenta las condiciones pertinentes que concurran en el caso, incluidas las comerciales y de mercado que vayan a plantearse, el beneficio potencial de las distintas opciones y las posibles compensaciones o indemnizaciones que resulten de la reestructuración) entre ellas, la de no efectuar la reestructuración. En estos casos, una parte independiente podría no haber aceptado las condiciones de la reestructuración.

9.62 En condiciones de plena competencia pueden darse también situaciones en las que una entidad reestructurada no tenga opciones disponibles de modo realista claramente más atractivas que la de aceptar las condiciones de la reestructuración, por ejemplo, aceptar la finalización de un contrato, con o sin indemnización, como se analiza en la Sección E más adelante. En los contratos a largo plazo, esta situación puede resultar de la aplicación de una cláusula de salida que permita a una parte rescindir el contrato antes de la fecha de término por una causa válida. En los contratos que permiten la rescisión a ambas partes, la parte que finalmente opta por ella puede hacerlo porque haya determinado, conforme a los términos de la cláusula de rescisión, que le resulta más favorable dejar de utilizar una

función, o ejercerla internamente, contratar a un proveedor más barato o más eficiente (como prestatario), o buscar oportunidades más lucrativas (como proveedor). En el caso de que la entidad reestructurada transfiera a otra parte derechos u otros activos, o una actividad en desarrollo, podrá percibir una compensación por dicha transferencia como se analiza en la Sección D más adelante.

9.63 El principio de plena competencia requiere la evaluación de las condiciones acordadas o impuestas entre empresas asociadas, en el nivel de cada una de ellas. El hecho de que la redistribución transfronteriza de las funciones, activos o riesgos pueda basarse en sólidas razones comerciales a nivel del grupo multinacional, por ejemplo, con la intención de crear sinergias dentro del grupo, no responde a la pregunta de si la operación se ajusta al criterio de plena competencia desde el punto de vista de cada una de las entidades reestructuradas.

9.64 La referencia a la noción de opciones disponibles de modo realista para las empresas no pretende imponer a los contribuyentes el deber de documentar todas las opciones hipotéticas a las que realmente puedan recurrir. Como se señaló en el párrafo 3.81, cuando se lleva a cabo un análisis de comparabilidad, no es necesario hacer una búsqueda exhaustiva de todas las fuentes de información posibles. En lugar de ello, la intención de esta noción es la de subrayar el hecho de que si realmente existe una opción claramente más atractiva, esta debe considerarse en el análisis de las condiciones de la reestructuración.

C. Redistribución del beneficio potencial como consecuencia de la reestructuración empresarial.

C.1 *Beneficio potencial*

9.65 Una empresa independiente no tiene que percibir necesariamente una compensación cuando una modificación en su modelo empresarial reduzca su beneficio potencial o los beneficios futuros esperados. El principio de plena competencia no exige una compensación por la mera reducción de los beneficios futuros que espera recibir una empresa. Al aplicar el principio de plena competencia a las reestructuraciones empresariales, la cuestión que se plantea es si tal reestructuración implica la transferencia de un elemento de valor (derechos u otros activos) o la finalización o renegociación sustancial de acuerdos preexistentes, y si esa transferencia, terminación o renegociación sustancial se hubieran remunerado o indemnizado entre partes independientes en circunstancias

comparables. Ambas situaciones se describen en las Secciones D y E más adelante.

9.66 En estas Directrices el “beneficio potencial” significa “los beneficios futuros esperados”. En algunos casos puede englobar las pérdidas. La noción de “beneficio potencial” se usa frecuentemente a los efectos de valoración, en la determinación de una compensación de plena competencia por la transferencia de un intangible o de la actividad (negocio en funcionamiento), o en la determinación de una indemnización de plena competencia por la finalización o renegociación sustancial de acuerdos preexistentes, toda vez que se determine que partes independientes, en situaciones comparables, hubieran procedido a dicha compensación o indemnización.

9.67 En el contexto de las reestructuraciones empresariales, el beneficio potencial no debe interpretarse únicamente como las pérdidas/beneficios que se hubieran generado si se hubiera continuado indefinidamente con la organización previa. Por un lado, si una entidad no cuenta con derechos ni activos claramente identificables en el momento de la reestructuración, entonces no tiene un beneficio potencial que justifique una compensación. Por otro lado, si una entidad tiene cuantiosos activos o derechos en el momento de la reestructuración, puede tener un beneficio potencial muy importante, por lo que debe percibir una remuneración apropiada que justifique la pérdida de ese beneficio potencial.

9.68 Para poder determinar si en condiciones de plena competencia la reestructuración en sí misma podría generar algún tipo de compensación, es esencial comprender la reestructuración, incluidos los cambios que han ocurrido, cómo afectan al análisis funcional de las partes, cuáles han sido las razones empresariales subyacentes y los beneficios que se espera obtener de la reestructuración, así como qué opciones disponibles de modo realista tienen las partes a su disposición, como se analiza en la Sección B.

C.2 *Redistribución de los riesgos y del beneficio potencial*

9.69 Las reestructuraciones empresariales suelen implicar cambios en los perfiles de riesgo respectivos de las empresas asociadas. Las redistribuciones de riesgos pueden resultar de la transferencia de un elemento de valor, como se verá en la Sección D más adelante, o de la finalización o renegociación sustancial de acuerdos preexistentes, como se verá en la Sección E. La Parte I del presente capítulo contiene el análisis de las cuestiones de precios de transferencia que entrañan los riesgos.

9.70 Pongamos por ejemplo la conversión de un fabricante “pleno” en un fabricante por contrato. En ese caso, si bien una remuneración consistente en el coste incrementado podría constituir una remuneración de plena competencia por las funciones que asume tras la reestructuración, otra cuestión que se plantea es si debe existir una indemnización de plena competencia por la variación en los acuerdos preexistentes cuyo resultado es la renuncia al beneficio potencial más incierto por parte del fabricante, teniendo en cuenta sus derechos y otros activos.

9.71 Otro ejemplo podría consistir en un distribuidor que ejerce una actividad asumiendo plenamente el riesgo en el marco de un contrato de larga duración para un tipo de operación dada. Supongamos que, en virtud de los derechos que le confiere el contrato de larga duración respecto de estas operaciones, tiene la opción disponible de modo realista de aceptar o rechazar el convertirse en un distribuidor de bajo riesgo ejerciendo la actividad para una sociedad asociada extranjera, y que la remuneración de plena competencia para esa actividad de distribución de bajo riesgo se estima en un beneficio estable de +2% anual, mientras que el resto del beneficio potencial asociado al riesgo se atribuye a la empresa asociada extranjera. Supongamos, a los efectos de este ejemplo, que esa reestructuración se implementa exclusivamente a través de la renegociación de los acuerdos contractuales preexistentes, sin que ocurra transferencia de activo alguna. Desde el punto de vista del distribuidor, se plantea la cuestión de si el nuevo acuerdo (teniendo en cuenta tanto la remuneración que percibirá por las operaciones que realice tras la reestructuración, como una posible compensación o indemnización por la propia reestructuración) le colocan en una situación tan ventajosa, o incluso más que las otras opciones viables – aunque más arriesgadas – por las que puede optar. Si no fuera este el caso, habría que concluir que la remuneración de las operaciones posteriores a la reestructuración se ha calculado erróneamente, o que sería necesaria una compensación complementaria para remunerar correctamente al distribuidor por la reestructuración. Desde el punto de vista de la empresa extranjera asociada, se plantea la cuestión de si estaría dispuesta en condiciones de plena competencia a aceptar el riesgo, y de ser así hasta qué punto, cuando de hecho el distribuidor continúa ejerciendo la misma actividad, pero en una condición distinta.

9.72 En condiciones de plena competencia es muy probable que la respuesta dependa de los derechos y otros activos de las partes, del beneficio potencial del distribuidor y de su empresa asociada en relación con ambos modelos empresariales (el de la distribución “plena” y el de distribuidor de bajo riesgo), así como de la duración prevista del nuevo acuerdo. La

situación desde el punto de vista del distribuidor puede ilustrarse mediante el ejemplo siguiente.

Nota: Este ejemplo tiene un mero valor ilustrativo. No pretende extraer conclusiones sobre la elección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado, sobre la agregación de operaciones o sobre el importe de la remuneración de plena competencia para las actividades de distribución. En este ejemplo se asume que el cambio en la atribución del riesgo del distribuidor proviene de la renegociación del contrato de distribución preexistente, que implica una nueva distribución de riesgos entre las partes. Este ejemplo pretende ilustrar la perspectiva del distribuidor, sin considerar la de la empresa extranjera asociada (empresario principal), si bien en el análisis de precios de transferencia deben tenerse en cuenta ambos puntos de vista.

Beneficios del distribuidor previos a la reestructuración: datos históricos de los últimos cinco años	Expectativas de beneficio futuro para el distribuidor para los tres años siguientes	Beneficios obtenidos por el distribuidor tras la reestructuración
(actividad desarrollada con asunción de riesgo plena)	(si hubiera seguido asumiendo plenamente el riesgo, suponiendo que realmente hubiera tenido la opción de poder hacerlo)	(actividad de bajo riesgo)
(margen neto de beneficio / ventas)	(margen neto de beneficio / ventas)	(margen neto de beneficio / ventas)

Caso n° 1:

Año 1: (-2%)	[-2% a +6%]	Beneficio garantizado
Año 2: +4%		estable de
Año 3: +2%	con alto nivel de incertidumbre	+2% anual
Año 4: 0	dentro de ese rango	
Año 5: +6%		

Caso n° 2:

Año 1: +5%	[+5% a +10%]	Beneficio garantizado
Año 2: +10%		estable de
Año 3: +5%	con alto nivel de incertidumbre	+2% anual
Año 4: +5%	dentro de ese rango	
Año 5: +10%		

Caso nº 3:		
Año 1: +5%	[0% a +4%]	Beneficio garantizado estable de +2% anual
Año 2: +7%	con alto nivel de incertidumbre dentro de ese rango	
Año 3: +10%		
Año 4: +8%	(por ej. provocado por nueva presión competitiva)	
Año 5: +6%		

9.73 En el caso nº 1, el distribuidor renuncia a un beneficio potencial que comporta un grado de incertidumbre elevado por un beneficio relativamente bajo, pero estable. El que una parte independiente estuviera dispuesta a proceder de ese modo dependería del rendimiento que esperara obtener en cada una de esas situaciones, de su nivel de tolerancia al riesgo, de la viabilidad de las alternativas y de la posible compensación que pudiera obtener por la propia reestructuración. En el caso nº 2, es poco probable que partes independientes que estuvieran en la situación del distribuidor acordaran la redistribución de los riesgos y del beneficio potencial sin una compensación adicional si tienen la opción de proceder de otro modo. El caso nº 3 ilustra el hecho de que el análisis debe tener en cuenta el beneficio potencial futuro y que, cuando se producen variaciones importantes en el entorno económico o comercial, los datos históricos no constituyen una base de análisis suficiente.

D. Transferencia de un elemento de valor (por ejemplo un activo o una actividad en desarrollo)

9.74 Las Secciones D.1 a D.3 a continuación abordan el análisis de ciertas transferencias que pueden encontrarse habitualmente en las reestructuraciones empresariales: transferencias de activos tangibles, de activos intangibles y de actividades (negocio en funcionamiento).

D.1 Activos tangibles

9.75 Las reestructuraciones empresariales pueden implicar la transferencia de activos tangibles (por ejemplo, equipos) por parte de una entidad reestructurada a una empresa asociada extranjera. Si bien normalmente se considera que las transferencias de activos tangibles no

plantean dificultades especiales en cuanto a la determinación de los precios de transferencia, es frecuente que se planteen problemas relacionados con la valoración de las existencias que transfiere en el momento de la reestructuración un fabricante o distribuidor reestructurado a una empresa asociada extranjera (por ejemplo un empresario principal), cuando esta última adquiere la propiedad de las existencias desde el momento de la aplicación del nuevo modelo empresarial y de la nueva organización de la cadena de suministro.

Ejemplo

Nota: El ejemplo que sigue únicamente pretende ilustrar la cuestión de la valoración de las transferencias de existencias. No pretende extraer conclusión alguna sobre si las autoridades fiscales deben admitir o no una reestructuración concreta, ni si es coherente o no con el principio de plena competencia; tampoco pretende sugerir que un determinado método de determinación de precios de transferencia pueda aplicarse en todos los casos a las operaciones de reestructuración.

9.76 Supongamos que un contribuyente, miembro de un grupo multinacional, ha ejercido una actividad de fabricante y distribuidor “pleno”. Conforme al modelo empresarial previo a la reestructuración, el contribuyente adquiriría materias primas, fabricaba productos terminados utilizando bienes tangibles e intangibles que le pertenecían o que poseía en alquiler o sobre los que tenía licencia de uso, ejercía las funciones de comercialización y distribución, y vendía los productos terminados a terceras partes clientes. Con estas actividades, el contribuyente soportaba una serie de riesgos tales como el riesgo de inventario, el riesgo de impago y el riesgo de mercado.

9.77 Supongamos que se procede a reestructurar el acuerdo y que el contribuyente opera ahora en la condición de fabricante a precio fijo y distribuidor “menoscabado”^{*}. Como parte de la reestructuración, se crea una empresa asociada extranjera que adquiere diversos intangibles mercantiles y de comercialización a varias de las entidades asociadas, incluyendo al contribuyente. Tras la reestructuración, la empresa asociada extranjera adquirirá las materias primas y las dejará en depósito en las instalaciones del contribuyente para que este proceda a la fabricación a cambio de una remuneración fija. Los productos finales pertenecen a la empresa asociada y el contribuyente los adquiere para proceder inmediatamente a su venta a

^{*} (N. de la T.) Véase nota de traducción al párrafo 9.2

terceros clientes (es decir, el contribuyente únicamente adquiere aquellos productos terminados respecto de los que ya ha pactado la venta con el cliente). Conforme a este nuevo modelo empresarial, la empresa asociada extranjera soporta el riesgo de inventario que anteriormente soportaba el contribuyente.

9.78 Supongamos que, a fin de poder migrar del acuerdo preexistente a las condiciones que van a regir la relación una vez reestructurada, las materias primas y los productos terminados que figuran en el balance del contribuyente en el momento de la reestructuración se transfieren a la empresa asociada extranjera. Se plantea la cuestión de cómo determinar el precio de transferencia de plena competencia para esas existencias en el momento de la conversión de los modelos operativos. Esta cuestión suele plantearse siempre que existe una transición de un modelo a otro. El principio de plena competencia se aplica a las transferencias de inventario entre empresas situadas en jurisdicciones tributarias distintas. La selección del método de determinación de precios de transferencia apropiado depende del análisis de comparabilidad (incluido el análisis funcional) de las partes. Es posible que el análisis funcional deba abarcar un periodo de transición durante el que se lleva a cabo la transferencia. Por ejemplo, en el supuesto anterior:

- Podría determinarse el precio de plena competencia correspondiente a las materias primas y a los productos terminados tomando como referencia los precios comparables en el mercado libre, en la medida en que dichos precios satisfagan los factores de comparabilidad, es decir, que las condiciones de la operación no vinculada sean comparables a las de la transferencia que se efectúa en el contexto de la reestructuración.
- Otra posibilidad podría consistir en determinar el precio de transferencia para los productos terminados como el precio de reventa a los clientes menos la contraprestación de plena competencia por las funciones de comercialización y distribución que aun quedan por efectuarse.
- Otra posibilidad podría consistir en partir de los costes de fabricación y añadir un margen de plena competencia para remunerar al fabricante por las funciones que ha desarrollado, los activos que ha utilizado y los riesgos que ha asumido respecto de los productos considerados. No obstante, en ciertos casos el valor de mercado de las existencias es demasiado bajo como para que pueda añadirse un elemento de beneficio sobre los costes en condiciones de plena competencia.

9.79 La selección del método de determinación de precios de transferencia apropiado depende, en parte, de qué parte de la operación es menos compleja y puede evaluarse con mayor certidumbre (las funciones

desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por el fabricante, o las funciones de comercialización y venta que aun deban desempeñarse teniendo en cuenta los activos que vayan a usarse y los riesgos que vayan a asumirse en tal desempeño). Véanse los párrafos 3.18 y 3.19, referidos a la selección de la parte objeto de análisis.

D.2 *Activos intangibles*

9.80 Las transferencias de activos intangibles plantean cuestiones difíciles tanto respecto de la identificación de los activos transferidos como en relación a su valoración. La identificación puede resultar difícil, ya que no todos los activos intangibles valiosos se registran y protegen legalmente, y no todos se anotan contablemente. Estos activos intangibles valiosos pueden potencialmente consistir en derechos de uso de activos industriales tales como patentes, marcas o nombres comerciales, diseños o modelos, así como derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas (comprendidas las aplicaciones informáticas) y las propiedades de carácter intelectual, como los conocimientos prácticos *–know-how–* y los secretos comerciales. Pueden comprender también listas de clientes, canales de distribución, denominaciones, símbolos o dibujos únicos. En el análisis de la reestructuración de empresas resulta esencial identificar los activos intangibles valiosos que se transfieren (cuando sea el caso), determinar si partes independientes hubieran remunerado esta transferencia, así como el valor de plena competencia que les corresponde.

9.81 La determinación de un precio de plena competencia para la transferencia de derechos intangibles sobre la propiedad debe realizarse tanto desde la perspectiva del transmitente como de la del adquirente (véase el párrafo 6.14). Son varios los factores que inciden sobre esta determinación, entre otros, el importe de los beneficios esperados procedentes de la explotación del bien intangible, su duración y su nivel de riesgo, la naturaleza del derecho de propiedad y las restricciones a las que esté sujeto (referidas al modo de utilización o explotación, de índole geográfica o temporal), el grado y período restante de protección jurídica de la que se beneficia el bien (cuando corresponda), así como la existencia de alguna cláusula de exclusividad que pudiera estar vinculada al bien. La valoración de los intangibles puede resultar compleja e incierta. Las indicaciones generales relativas a los intangibles y a los acuerdos de reparto de costes contenidas en los Capítulos VI y VII pueden aplicarse en el contexto de las reestructuraciones empresariales.

D.2.1 Transferencia de activos intangibles efectuada por una entidad local a una entidad central (empresa asociada extranjera)

9.82 Las reestructuraciones empresariales entrañan a veces la transferencia de activos intangibles que anteriormente poseían y gestionaban una o más entidades locales a una central situada en otra jurisdicción tributaria (por ejemplo, una empresa asociada extranjera que interviene como empresario principal o como “entidad IP”^{*}. Los activos intangibles transferidos pueden ser o no valiosos para el transmitente o para el grupo multinacional en conjunto. En algunos casos, el transmitente continúa utilizando los intangibles transferidos, pero lo hace en otra condición legal (por ejemplo, como licenciatario autorizado por el adquirente, o en virtud de un contrato que incorpora derechos limitados sobre el activo intangible, como puede ser un contrato de fabricación que permite la utilización de las patentes transferidas; o un acuerdo de distribución “menoscabado” que permite utilizar una marca comercial que se ha transferido). En otros casos, el transmitente deja de usar el activo transferido.

9.83 Los grupos multinacionales pueden tener sólidas razones empresariales para centralizar la propiedad y la gestión de los activos intangibles. En el contexto de las reestructuraciones empresariales, sería buen ejemplo de ello la transferencia de los intangibles vinculados a la especialización de los emplazamientos de fabricación de un grupo multinacional. Antes de la reestructuración, es factible que cada entidad fabricante posea y gestione una serie de patentes, como ocurriría si las plantas de fabricación se hubieran adquirido tiempo atrás a terceras partes, junto con sus bienes intangibles. En el contexto de un modelo empresarial global, cada instalación fabril puede estar especializada por tipo de proceso de producción o por áreas geográficas, más que por patentes. Como consecuencia de la reestructuración, el grupo multinacional podrá transferir todas las patentes que poseen y gestionan las entidades locales a una entidad central que, por su parte, otorgará derechos contractuales (a través de licencias o acuerdos de fabricación) a todas las plantas del grupo para la fabricación de los productos que corresponda según sus nuevas áreas de competencia, utilizando patentes que antes poseían ellas mismas u otras entidades del grupo.

9.84 El principio de plena competencia requiere la evaluación de las condiciones acordadas o impuestas entre empresas asociadas, en el nivel de cada una de ellas. El hecho de que la centralización de los derechos de

* (N. de la T.) Véase nota de traducción al párrafo 9.2.

propiedad intangibles pueda estar motivada por sólidas razones comerciales al nivel del grupo multinacional no aclara si la transferencia es conforme con el principio de plena competencia desde el punto de vista tanto del transmitente como del adquirente.

9.85 Del mismo modo, en el caso de que una entidad local transfiera sus derechos de propiedad intangibles a una empresa asociada extranjera y continúe utilizando los activos transferidos, pero lo haga con otra capacidad legal (por ejemplo, como licenciatario) las condiciones de la transferencia deberán analizarse desde el punto de vista tanto del transmitente como del adquirente; especialmente analizando el precio al que empresas independientes comparables hubieran estado dispuestas a transmitir y adquirir la propiedad. Véase el párrafo 9.81. La determinación de la contraprestación de plena competencia para la ulterior propiedad, uso y explotación del activo transferido deben tener en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por las partes en relación con el intangible transferido. Esta consideración reviste especial importancia en el caso de las reestructuraciones empresariales, ya que varios países han expresado su preocupación por el hecho de que no suela facilitárseles la información relevante relativa a las funciones, activos y riesgos de las empresas asociadas extranjeras.

9.86 Cuando la reestructuración empresarial conlleve la transferencia de un activo intangible seguida por un nuevo acuerdo en virtud del que el transmitente continuará usando el activo transferido, debe examinarse la globalidad del acuerdo comercial suscrito entre las partes a fin de valorar si las operaciones son conformes con el principio de plena competencia. Si una parte independiente transfiriera un activo que tiene intención de seguir explotando, será prudente que negocie las condiciones de tal utilización futura (por ejemplo, en el marco de un contrato de licencia) conjuntamente con las condiciones de la transferencia. En efecto, por lo general suele existir una relación entre la determinación de la compensación de plena competencia por la transferencia, la determinación de una contraprestación de plena competencia para las operaciones que suceden a la reestructuración en relación con el intangible transferido, tales como los pagos por futuras licencias a los que esté obligado el transmitente para poder seguir utilizando el activo, y el rendimiento futuro esperado por el transmitente derivado de la utilización futura del activo. Por ejemplo, un acuerdo por razón del cual se transfiere una patente por el precio de 100 en el año N, al tiempo que se concluye un acuerdo para la continuación de la utilización de la patente por el transmitente, a cambio de un canon de 100 anuales durante un período de 10 años, difícilmente será compatible con el principio de plena competencia.

D.2.2 Transferencia de activos intangibles en el momento en el que aun no se ha determinado su valor

9.87 En el marco de las reestructuraciones empresariales pueden plantearse dificultades cuando se transfiere un bien intangible sin que aun se haya determinado su valor (por ejemplo, antes del inicio de su explotación), especialmente cuando exista un desfase importante entre el beneficio futuro esperado que se tuvo en cuenta en la valoración efectuada en el momento de la venta y los beneficios realmente obtenidos por el adquirente de la explotación de dicho intangible. Cuando la valoración de los bienes intangibles en el momento de efectuar la operación es muy incierta, se plantea la cuestión de cómo determinar el precio de plena competencia. Tanto los contribuyentes como las administraciones tributarias deben resolver esta cuestión tomando como referencia lo que hubieran hecho empresas independientes en circunstancias comparables para tener en cuenta la incertidumbre de la valoración en el momento de determinar el precio de la operación. Véanse los párrafos 6.28 a 6.35 y los ejemplos contenidos en el Anexo al Capítulo VI: “Ejemplos ilustrativos de la aplicación de las Directrices sobre precios de transferencia a activos intangibles de valoración muy incierta”.

9.88 Siguiendo estas orientaciones, el aspecto clave es determinar si la valoración de partida fue lo suficientemente incierta como para que partes que operaran en condiciones de plena competencia hubieran requerido un mecanismo de ajuste de precios; o si el cambio de valor constituye un hecho tan fundamental que hubiera conducido a la renegociación de la operación. Cuando sea así el caso, la administración tributaria tendrá justificación para determinar el precio de plena competencia correspondiente a la transferencia del intangible sobre la base de la cláusula de ajuste o de la renegociación que se hubiera considerado en el caso de una operación comparable no vinculada efectuada en condiciones de plena competencia. Siendo otras las circunstancias, cuando no haya razón para considerar que la valoración inicial fue lo suficientemente incierta como para que las partes hubieran requerido una cláusula de ajuste de precios o para proceder a la renegociación de los términos del acuerdo, no hay razón para que las administraciones tributarias practiquen dicho ajuste, ya que constituiría un uso injustificado de la retrospección. La mera existencia de incertidumbre en el momento de la operación no justifica un ajuste a posteriori sin analizar lo que hubieran hecho o acordado entre si terceras partes.

D.2.3 Activos intangibles locales

9.89 Cuando una operación “plena” ejercida por una entidad local se convierte en una operación “de riesgo limitado, intangibles limitados y baja remuneración”, se plantea la cuestión de si esta conversión implica la transferencia por parte de la entidad local reestructurada a una empresa asociada extranjera de activos intangibles valiosos tales como listados de clientes, y si la entidad local conserva activos intangibles locales.

9.90 En concreto, en el caso de la conversión de un distribuidor “pleno” en distribuidor de riesgo limitado o comisionista, puede ser importante examinar si el distribuidor ha desarrollado intangibles de comercialización a nivel local durante los años previos a su reestructuración y, de ser así, cuál es la naturaleza y el valor de esos intangibles, y si se han transferido a una empresa asociada. Cuando existan tales activos locales y se hayan transferido a la empresa asociada extranjera, debe aplicarse el principio de plena competencia para determinar si es preciso remunerar esta transferencia, y de ser así cómo, basándose en lo que hubieran acordado partes independientes en circunstancias similares. Por otro lado, cuando existan dichos intangibles locales, pero permanezcan en posesión de la entidad reestructurada, deberán tenerse en cuenta al efectuar el análisis funcional de las actividades que se desarrollen tras la reestructuración, por lo que podrán influir en la selección y aplicación del método de precios de transferencia más apropiado para las operaciones vinculadas post-reestructuración, o remunerarse por separado, por ejemplo a través del pago de cánones efectuado por la empresa asociada extranjera que los explota a partir de la reestructuración a la empresa reestructurada, durante el ciclo de vida de los intangibles.⁴

D.2.4 Derechos contractuales

9.91 Los derechos contractuales pueden ser intangibles valiosos. Cuando estos derechos contractuales se transfieren (o se ceden) entre empresas asociadas deben remunerarse en condiciones de plena competencia, teniendo en cuenta el valor de los derechos transferidos desde la perspectiva de ambas partes, transmitente y adquirente.

9.92 Las administraciones tributarias han mostrado preocupación respecto de aquellos casos en los que han observado la práctica según la cual una entidad finaliza voluntariamente un contrato que le proporciona beneficios a fin de permitir a una empresa asociada extranjera concluir un

⁴

Véase la Parte III de este capítulo, en la que se analiza la remuneración de los acuerdos que siguen a la reestructuración.

contrato similar y obtener así el beneficio potencial a él vinculado. Por ejemplo, supongamos que la sociedad A tiene valiosos contratos a largo plazo con clientes independientes que le reportan un nivel de beneficios importante. Supongamos que en un determinado momento, A pone fin voluntariamente al contrato con sus clientes en circunstancias tales que estos últimos se ven legal o comercialmente obligados a celebrar un contrato similar con la sociedad B, una entidad extranjera que pertenece al mismo grupo multinacional que A. Como consecuencia de ello, los derechos contractuales y el beneficio potencial que anteriormente poseía A, pasa ahora a manos de B. Si, las circunstancias fueran tales que B únicamente pudiera celebrar esos contratos con los clientes una vez que A renunciara a sus propios derechos contractuales en beneficio de B, y que A sólo pusiera fin a sus contratos con sus clientes con el conocimiento de que estos iban a quedar legal o comercialmente obligados a celebrar contratos similares con B, estaríamos ante una operación tripartita que podría interpretarse como una transferencia de derechos contractuales de valor desde A a B, que hubiera podido remunerarse en condiciones de plena competencia, dependiendo del valor de los derechos cedidos por A desde la perspectiva tanto de A como de B.

D.3 Transferencia de una actividad (negocio en funcionamiento)

D.3.1 Valoración de una transferencia de actividad

9.93 Las reestructuraciones empresariales implican a veces la transferencia de negocios activos, es decir, unidades de negocio integradas económicamente y operativas. La transferencia de un negocio en funcionamiento en este contexto significa la transferencia de activos, conjuntamente con la capacidad de llevar a cabo ciertas funciones y de soportar ciertos riesgos. Estas funciones, activos y riesgos pueden incluir, entre otras cosas: bienes tangibles e intangibles, pasivo vinculado a la tenencia de ciertos activos y al desarrollo de ciertas funciones, tales como I+D y fabricación; la capacidad de desarrollar las actividades que el transmitente desarrollaba antes de la transferencia; así como los recursos, las capacidades y los derechos. La valoración de la transferencia de un negocio en funcionamiento debe tener en cuenta todos los elementos de valor que serían remunerados entre partes independientes en circunstancias comparables. Por ejemplo, en el caso de una reestructuración que implicara la transferencia de una unidad de negocio que abarcara, entre otras cosas, infraestructuras de investigación en la que trabajara personal experimentado en ese campo, la valoración de tal transferencia de actividad debe reflejar,

entre otros, el valor de esa infraestructura y el valor (cuando corresponda) de la plantilla de trabajadores que se hubiera acordado en condiciones de plena competencia.

9.94 La determinación de la compensación de plena competencia por la transferencia de un negocio en funcionamiento no equivale necesariamente a la suma de las valoraciones separadas de cada elemento independiente que integra el conjunto de la transferencia. En concreto, si la transferencia de un negocio en funcionamiento comprende múltiples transferencias realizadas en el mismo momento, de activos, riesgos o funciones relacionados entre sí, puede ser necesario proceder a la valoración agregada de tales transferencias para poder obtener una valoración fiable del precio de plena competencia de ese negocio en funcionamiento. Los métodos de valoración utilizados en las operaciones de adquisición entre partes independientes pueden resultar útiles para valorar la transferencia de un negocio en funcionamiento entre empresas asociadas.

9.95 Puede servir como ejemplo el caso en el que una actividad de fabricación anteriormente desarrollada por F1, una entidad del grupo multinacional, se reasigna a otra entidad F2 (por ejemplo, por economías de localización). Supongamos que F1 transfiere a F2 su maquinaria y equipamiento, existencias, patentes, procesos de fabricación y conocimientos técnicos *–know-how–*, así como los contratos clave con proveedores y clientes. Supongamos que varios empleados de F1 pasan a F2 a fin de ayudar a esta última en el inicio de la actividad de fabricación reasignada. Supongamos que dicha transferencia se consideraría la de un negocio en funcionamiento si ocurriera entre partes independientes. Para poder determinar la eventual contraprestación de plena competencia aplicable a dicha operación entre empresas asociadas, debería compararse con la transferencia de un negocio en funcionamiento entre partes independientes, en lugar de tratarla como una transferencia de activos aislados.

D.3.2 Actividades deficitarias

9.96 No en todos los casos en los que la entidad reestructurada pierde funciones, activos o riesgos ocurre una pérdida real de beneficios futuros esperados. En algunas reestructuraciones las circunstancias pueden ser tales que en lugar de perder “la oportunidad de obtener beneficios”, la entidad reestructurada tenga la posibilidad de librarse de la “ocasión para incurrir en pérdidas”. Una entidad puede aceptar la reestructuración y la pérdida de funciones, activos o riesgos como opción preferible a la de simplemente tener que cesar la actividad. Si la entidad reestructurada prevé pérdidas futuras en caso de no proceder a la reestructuración (por ejemplo, porque

explote una planta de fabricación no rentable debido a la creciente competencia de las importaciones de bajo coste) entonces, de hecho, puede que no haya una pérdida de la posibilidad de obtener beneficios como consecuencia de proceder a la reestructuración en lugar de continuar con el negocio existente. En tales circunstancias, la reestructuración puede ser beneficiosa para la entidad reestructurada al reducir o eliminar las pérdidas futuras en caso de que estas superaran los costes que implica la reestructuración.

9.97 La cuestión que se plantea es si el adquirente debe recibir una contraprestación por parte del transmitente por el hecho de hacerse cargo de una actividad deficitaria. La respuesta depende de si una parte independiente, en circunstancias comparables, hubiera pagado por librarse de la actividad deficitaria, o si por el contrario hubiera considerado otras posibilidades como la de cesar la actividad. Dependerá también de si una tercera parte se hubiera mostrado interesada en adquirir la actividad deficitaria (quizá por las sinergias que generara junto con sus otras actividades) y de ser así en qué condiciones, por ejemplo, acordando una compensación. Pueden darse casos en los que una parte independiente quisiera pagar, por ejemplo si los costes financieros y los riesgos sociales del cierre de la actividad fueran tales que el transmitente considerara más ventajoso pagar al adquirente, quien por su parte trataría de reconvertir la actividad y asumiría la responsabilidad de un posible expediente de regulación de empleo.

9.98 Sin embargo, la situación puede ser distinta cuando la actividad deficitaria genere otros beneficios, como por ejemplo sinergias con otras actividades que desarrolle el mismo contribuyente. Pueden encontrarse también casos en los que una actividad deficitaria se mantenga por el hecho de que reporte algún beneficio al conjunto del grupo. En tal caso, la cuestión que puede plantearse es si en condiciones de plena competencia la entidad que mantiene la actividad deficitaria debería percibir una contraprestación por parte de quienes puedan beneficiarse de su mantenimiento.

D.4 Externalización

9.99 En los casos de externalización, puede ocurrir que una parte decida voluntariamente acometer una reestructuración y soportar los costes a ella asociados a cambio de anticipar ahorros. Por ejemplo, supongamos que un contribuyente que fabrica y vende productos en una jurisdicción con costes muy elevados, decide externalizar la actividad de fabricación a una empresa asociada ubicada en una jurisdicción cuyos costes son inferiores. Tras la reestructuración, el contribuyente comprará a su empresa asociada los productos fabricados y continuará con su actividad de venta a terceros

clientes. La reestructuración puede conllevar costes para el contribuyente, mientras que al mismo tiempo puede permitirle ahorrar en los costes de futuros aprovisionamientos, en comparación con sus propios costes de fabricación. Las partes independientes llevan a efecto este tipo de acuerdos de externalización y no exigen al adquirente una compensación explícita si el ahorro de costes que prevé el transmitente supera sus costes de reestructuración.⁵

E. Indemnización de la entidad reestructurada por la terminación o renegociación sustancial de los acuerdos existentes

9.100 Cuando se finaliza o renegocia sustancialmente una relación contractual en el contexto de una reestructuración empresarial, la entidad reestructurada puede sufrir algún perjuicio como por ejemplo los costes que implique la reestructuración (depreciación de activos, finalización de contratos laborales), costes de reconversión (generados por la adaptación del modelo existente a otras necesidades de los clientes) o pérdidas en el beneficio potencial. En las reestructuraciones empresariales, los acuerdos existentes suelen renegociarse de forma tal que se modifican los perfiles de riesgo de las partes, con las consecuencias que esto entraña respecto de la distribución entre ellas del beneficio potencial. Por ejemplo, cuando un contrato de distribución "plena" se convierte en un contrato de distribución de bajo riesgo, o en un contrato de comisión; o cuando un contrato de fabricación "plena" se convierte en un contrato para la fabricación a precio fijo. En estos casos se plantea la cuestión de si partes independientes, en circunstancias similares, hubieran acordado el pago de una indemnización a la parte reestructurada (y de ser así, cómo calcular tal indemnización).

9.101 La renegociación de los acuerdos existentes se acompaña en algunas ocasiones de una transferencia de derechos u otros activos. Por ejemplo, la finalización de un contrato de distribución se acompaña en ocasiones de la transferencia de intangibles. En esos casos, deben leerse conjuntamente las orientaciones contenidas en las Secciones D y E de esta parte.

9.102 A los efectos de este capítulo, indemnización significa un tipo de compensación que puede pagarse a la entidad reestructurada por el

⁵

Otro aspecto que se analiza en los párrafos 9.148 a 9.153 es si el ahorro derivado del emplazamiento de la actividad debe distribuirse entre las partes en condiciones de plena competencia, y de ser así, cómo.

detrimento sufrido, bien en forma de pago inmediato, como porcentaje de los costes incurridos en la reestructuración, o como reducción (o aumento) del precio de adquisición (de venta) para las operaciones posteriores a la reestructuración, o de alguna otra forma.

9.103 No debe presumirse que todas las rescisiones de contratos o renegociaciones sustanciales deben generar un derecho de indemnización en condiciones de plena competencia. Para determinar si en condiciones de plena competencia existiría tal indemnización es importante analizar el contexto en el que ocurre la reestructuración, especialmente en relación con los derechos y otros activos de las partes, así como las opciones por las que realmente puedan optar las partes, cuando sea el caso. A estos efectos, las cuatro condiciones siguientes pueden ser importantes:

- Si el contrato rescindido, no renovado o sustancialmente renegociado se formaliza por escrito y prevé una cláusula de indemnización (véase la Sección E.1 a continuación);
- Si los términos del acuerdo y la existencia o no de una cláusula de indemnización u otro tipo de garantía (así como los términos de dicha cláusula, cuando exista) son de plena competencia (véase la Sección E.2 más adelante);
- Si el derecho mercantil o la jurisprudencia amparan el derecho a recibir la indemnización (véase la Sección E.3 más adelante); y
- Si en condiciones de plena competencia, la otra parte hubiera estado dispuesta a indemnizar a aquella que sufre la finalización del contrato o su renegociación (véase la Sección E.4 más adelante).

E.1 ¿Se ha formalizado por escrito el contrato finalizado, no renovado o sustancialmente renegociado? ¿Se ha previsto una cláusula de indemnización?

9.104 Cuando el contrato rescindido, no renovado o renegociado se formaliza por escrito⁶, el punto de partida del análisis debe ser la comprobación de si se han respetado las condiciones establecidas para la finalización, no renovación o renegociación (por ejemplo, en relación con los

⁶ Como se señaló en el párrafo 1.52, los términos de una operación pueden encontrarse en la correspondencia o en las comunicaciones entre las partes y no sólo en los contratos escritos. Cuando no existan contratos escritos, las relaciones contractuales de las partes se deducirán de su conducta y de los principios económicos que normalmente rigen las relaciones entre partes independientes.

plazos para la notificación) y si en dicho contrato se especifica alguna cláusula que prevea la indemnización u otro tipo de garantía en caso de terminación, no renovación o renegociación. Como se señaló en el párrafo 1.53, en las relaciones comerciales entre empresas independientes los distintos intereses de cada parte aseguran que estas intenten hacer respetar los términos del contrato, que sólo se ignorarán o modificarán si resulta de interés para ambas partes.

9.105 Sin embargo, el análisis de los términos del contrato entre las empresas asociadas puede no ser suficiente desde la perspectiva de la determinación de precios de transferencia por el mero hecho de que, como se explica más adelante, el que un determinado contrato rescindido, no renovado o renegociado no contenga cláusulas que prevean la indemnización u otra garantía no implica necesariamente que se respete el principio de plena competencia.

E.2. *¿Son de plena competencia los términos del acuerdo y la existencia o no de una cláusula de indemnización u otro tipo de garantía (así como los términos de dicha cláusula, cuando exista)?*

9.106 Entre partes independientes se dan casos de contratos rescindidos, no renovados o sustancialmente renegociados que no implican indemnización. Sin embargo, dado que esa misma divergencia de intereses que existe entre partes independientes puede no darse en el caso de empresas asociadas, la cuestión que se plantea es si los términos de un contrato concluido entre empresas asociadas es de plena competencia, es decir, si partes independientes, en circunstancias comparables hubieran celebrado un contrato con esas características (por ejemplo un contrato sin cláusula de indemnización o garantía de ningún tipo en caso de finalización, no renovación o renegociación). Cuando los datos comparables muestren la existencia de cláusulas de indemnización similares (o su ausencia) en circunstancias comparables, la cláusula de indemnización (o su ausencia) en una operación vinculada se considerará como de plena competencia. En los casos en los que sin embargo no existan datos comparables, la determinación de si las partes independientes hubieran acordado tal cláusula de indemnización (o su ausencia) tendrá en cuenta los derechos y otros activos de las partes en el momento de celebrar el acuerdo y en el de su finalización

o renegociación, pudiendo examinarse también las opciones disponibles de modo realista para las partes⁷.

9.107 Al examinar si las condiciones de un contrato son de plena competencia, puede ser necesario comprobar tanto la remuneración de las operaciones objeto del contrato como las condiciones financieras de su finalización, ya que ambas pueden estar interrelacionadas. En efecto, los términos pactados en la cláusula de rescisión (o su ausencia) pueden ser un elemento significativo en el análisis funcional de las operaciones y específicamente del análisis del riesgo de las partes, por lo que puede ser necesario tenerlos en cuenta al determinar una remuneración de plena competencia para las operaciones. Del mismo modo, la remuneración de las operaciones afectará a la determinación de si las condiciones de la finalización del contrato son de plena competencia.

9.108 En algunos casos puede ocurrir que, en circunstancias comparables, una parte independiente no disponga de modo realista de ninguna opción que resulte claramente más atractiva que la de aceptar las condiciones de la finalización del contrato o su renegociación sustancial. En otros puede ocurrir que, al analizar el fondo del acuerdo y el proceder de las empresas asociadas, se deduzca la existencia de un contrato de larga duración implícita por el que la parte a la que se le rescinde el contrato hubiera tenido derecho a algún tipo de indemnización en el caso de finalización anticipada.

9.109 Una circunstancia que merece especial atención, dado que en caso de haberse pactado entre partes independientes hubiera podido influir en los términos del contrato, es aquella en la que un contrato ahora finalizado impuso a una de las partes la obligación de realizar una importante inversión para la que razonablemente solo cabría esperar una remuneración de plena competencia si el contrato se hubiera mantenido por un largo período de tiempo. Esto genera un riesgo financiero para la parte que realiza la inversión en el caso de que el contrato se rescinda antes de la expiración de este plazo. El grado de riesgo varía en función de que la inversión sea muy especializada o susceptible de utilización por otros clientes (probablemente tras ciertas adaptaciones). Cuando el riesgo es sustancial, lo que hubiera ocurrido entre partes independientes que operan en circunstancias comparables es que habrían tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de negociar el contrato.

⁷

Véanse los párrafos 9.59 a 9.64, donde se analizan las opciones disponibles de modo realista.

9.110 Un ejemplo de la situación anterior podría ser aquella en la que un contrato de fabricación entre empresas asociadas exige al fabricante la inversión en una nueva unidad de fabricación. Supongamos que, en el momento de la finalización del contrato, el fabricante puede tener la perspectiva realista de obtener un rendimiento de plena competencia por la inversión en la nueva unidad de fabricación, siempre que el contrato de fabricación dure al menos cinco años, y que las condiciones de la actividad sean la de la fabricación de un mínimo de X unidades anuales, calculando la contraprestación por dicha producción sobre una base determinada (por ejemplo la de Y unidades monetarias por año). Supongamos que al cabo de tres años la empresa asociada rescinde el contrato aplicando las cláusulas en él contenidas, por razón de una reestructuración de la actividad de fabricación a nivel del grupo. Supongamos que la unidad de fabricación está altamente especializada y que tras la finalización el fabricante no tiene más opción que la de dar de baja los activos. La cuestión que se plantea es si, en circunstancias comparables, un fabricante independiente no hubiera intentado en primer lugar atenuar el riesgo financiero vinculado a la finalización del contrato antes del plazo de cinco años necesario para obtener un rendimiento de plena competencia por su inversión.

9.111 En un caso de estas características serán aplicables las pautas generales señaladas en la Parte I de este capítulo relativas al modo de determinar si una atribución de riesgos es conforme con el principio de plena competencia. En caso de poder hallar operaciones no vinculadas comparables que muestren una distribución similar del riesgo en una operación en el mercado libre (teniendo en cuenta especialmente las condiciones de la inversión, la remuneración de la actividad de producción y las condiciones de la finalización), entonces la atribución del riesgo entre empresas asociadas se considerará de plena competencia.

9.112 En caso de no poder hallar tal comparable, habrá que determinar si partes independientes hubieran procedido a una atribución de riesgos semejante, lo que dependerá de los hechos y circunstancias de la operación y, en concreto, de los derechos y otros activos de las partes.

- En condiciones de plena competencia, la parte que realiza la inversión puede no estar dispuesta a asumir sin garantías un riesgo que controla la otra parte, como el de finalización (véanse los párrafos 1.49 y 9.17 a 9.33). Las posibilidades para tener en cuenta ese riesgo en la negociación del contrato son diversas, por ejemplo, puede pactarse una cláusula de indemnización en caso de finalización anticipada, o permitir la opción de que la parte que realiza la inversión la transfiera a un precio determinado a la otra parte en caso de que tal inversión dejara de ser útil para la

primera por razón de la finalización anticipada del contrato por la segunda.

- Otro planteamiento posible sería el de considerar el riesgo vinculado a la finalización del contrato en la determinación de la contraprestación que deba percibirse por las actividades objeto del mismo (por ejemplo, utilizando este riesgo como factor comprendido en la determinación de la contraprestación por las actividades de fabricación y utilizando comparables de terceros que soporten riesgos comparables). En tal caso, la parte que realiza la inversión acepta conscientemente el riesgo y recibe una contraprestación por ello, luego no parece necesaria una indemnización aparte por la finalización del contrato.
- Finalmente, en algunos casos, el riesgo puede compartirse entre ambas partes, por ejemplo, la parte que rescinde el contrato puede soportar un porcentaje de los costes en los que incurra la otra parte por razón de dicha finalización.

9.113 Se plantea una cuestión similar cuando una parte ha incurrido en gastos de desarrollo que generan pérdidas o bajos rendimientos en las primeras fases, y un rendimiento por encima de lo normal en los períodos posteriores a la finalización del contrato.

9.114 En caso de que las condiciones pactadas o impuestas entre empresas asociadas respecto de la finalización, no renovación o renegociación sustancial de los contratos vigentes difiera de las condiciones que se hubieran acordado entre empresas independientes, los beneficios que habría obtenido una empresa de no existir dichas condiciones, y que de hecho no se han obtenido a causa de las mismas, pueden incluirse en los beneficios de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.

E.3. ¿Amparan el derecho mercantil o la jurisprudencia el derecho a recibir la indemnización?

9.115 A la hora de valorar si las condiciones de la finalización o no renovación de un contrato vigente son de plena competencia, los posibles recursos que pueda ofrecer la legislación mercantil vigente pueden resultar esclarecedores. La legislación vigente o la jurisprudencia en materia mercantil pueden aportar información valiosa sobre los derechos de indemnización y los términos y condiciones que cabe esperar encontrar en el caso de la finalización de ciertos tipos de contratos, por ejemplo, los de distribución. En aplicación de esa normativa puede ocurrir que la parte a la que se le ha rescindido el contrato tenga derecho a reclamar ante los

tribunales una indemnización con independencia de que esté previsto o no en el contrato. Sin embargo, cuando las partes pertenecen al mismo grupo multinacional, es muy poco probable que la parte a la que se le rescinda el contrato entable pleito alguno contra su asociada en busca de esa indemnización, por lo que las condiciones de la finalización pueden ser distintas de las que se hubieran pactado entre empresas independientes en circunstancias similares.

E.4 En condiciones de plena competencia ¿hubiera estado una de las partes dispuesta a indemnizar a la que sufre la finalización del contrato o su renegociación?

9.116 El análisis de precios de transferencia de las condiciones de la finalización o de la renegociación sustancial de un contrato debe tener en cuenta la perspectiva tanto del transmitente como del adquirente. Desde el punto de vista de este último, es tan importante valorar el importe de la posible indemnización de plena competencia, si la hubiera, como determinar qué parte debe hacerse cargo de ella. No es posible ofrecer una única respuesta válida en todos los casos, por lo que esta se basará en el análisis de los hechos y circunstancias del caso y, en concreto, en los derechos y otros activos de las partes, en el motivo económico conducente a la rescisión, en la determinación de qué parte o partes pueden beneficiarse de ella y en las opciones de las que realmente disponen las partes. Todo esto puede ilustrarse como sigue.

9.117 Supongamos la existencia de un contrato de fabricación entre dos empresas asociadas, la entidad A y la entidad B, que A rescinde (B es la fabricante). Supongamos que A decide recurrir a otra entidad fabricante asociada, la entidad C, para que continúe con el trabajo de fabricación que anteriormente desarrollaba B. Como se señaló en el párrafo 9.103, no cabe presuponer que todas las rescisiones o renegociaciones sustanciales de contratos generen un derecho de indemnización de plena competencia. Supongamos que siguiendo lo expuesto en las Secciones E.1 a E.3 anteriores se determina que, partiendo de las circunstancias de este caso, pero entre partes independientes, B estaría en situación de reclamar una indemnización por razón de los perjuicios causados a consecuencia de la finalización del contrato. Se plantea la cuestión de si es A (la parte que rescinde el contrato) quien debe proceder a indemnizar a B, si es C (es decir, la parte que asume la actividad de fabricación que antes ejercía B) quien debe hacerlo, o si la responsable de la indemnización es la sociedad matriz M u otra parte.

9.118 Como se señaló en la Sección E.1, el punto de partida del análisis sería la revisión de los términos contractuales entre A y B. En algunos casos, los términos contractuales que atañen a C, M u otra parte también podrían resultar pertinentes. La respuesta depende de si estas entidades, en condiciones de plena competencia, hubieran estado dispuestas a pagar tal indemnización por la rescisión.

9.119 Pueden darse circunstancias en las que A deseara hacerse cargo de los costes de la indemnización en condiciones de plena competencia, por ejemplo si esperara que la finalización de su contrato con B y su nuevo contrato de fabricación con C le permitiera ahorrar costes, y el valor actual de los ahorros de costes excediera del importe de la indemnización.

9.120 Pueden darse casos en los que C pudiera estar dispuesta a pagar ese importe como un pago inicial que le permitiera obtener un contrato de fabricación con A, por ejemplo, si el valor actual de los beneficios que espera obtener de su nuevo contrato de fabricación justificara tal inversión. En estos casos, C podría proceder al pago de distintas formas, por ejemplo C podría pagar a B, o C podría pagar a A, o C podría hacer un pago a A supliendo la obligación de indemnización de esta para con B.

9.121 Pueden darse casos en los que, en condiciones de plena competencia, A y C estuvieran dispuestas a compartir los costes de indemnización.

9.122 También pueden darse casos en los que ni A ni C desearan soportar los costes de indemnización en condiciones de plena competencia, porque ninguna de ellas esperara obtener beneficios suficientes con el cambio. Puede darse el caso de que dicha rescisión sea parte de una reestructuración a nivel de todo el grupo, decidida por la sociedad matriz M, a fin de generar sinergias en el grupo, y que fuera M quien soportara la indemnización de plena competencia de B (a menos que, por ejemplo, B, a pesar de la finalización o renegociación de su contrato, obtuviera beneficios de esa sinergia generada en el grupo que compensara los perjuicios de esa finalización o renegociación).

Parte III: Remuneración de las operaciones vinculadas ulteriores a la reestructuración

A. Reestructuraciones frente a “estructuración” empresarial

A.1 *Regla general: aplicación uniforme del principio de plena competencia*

9.123 El principio de plena competencia y estas Directrices no se aplican ni pueden aplicarse de forma distinta a las operaciones que siguen a la reestructuración que a las operaciones estructuradas como tales desde el inicio. De no hacerlo así, se estaría distorsionando la competencia entre aquellas entidades que reestructuran sus actividades y las que entran en escena por primera vez y aplican el mismo modelo empresarial sin haber tenido que reestructurar su actividad.

9.124 Las situaciones comparables deben tratarse de idéntico modo. La selección y aplicación del método apropiado de determinación de precios de transferencia se realizará mediante el análisis de comparabilidad, incluyendo el análisis funcional de las partes y la revisión de los acuerdos contractuales. Deben aplicarse el mismo criterio de comparabilidad y las mismas pautas de selección y ejecución práctica del método de determinación de precios de transferencia con independencia de si un acuerdo en concreto nace o no de la reestructuración de una estructura preexistente.

9.125 Sin embargo, las reestructuraciones implican cambios, y el principio de plena competencia debe aplicarse no sólo a las operaciones posteriores a la reestructuración, sino también a las operaciones que constituyen la reestructuración en sí misma y que consisten en la redistribución de funciones, activos o riesgos. La aplicación del principio de plena competencia a estas operaciones adicionales se analiza en la Parte II de este capítulo.

9.126 Además, como se explica más adelante, el análisis de comparabilidad de un acuerdo que resulta de la reestructuración de una empresa puede revelar ciertas diferencias de hecho si se compara con un acuerdo estructurado como tal desde el principio. Estas diferencias factuales no afectan al principio de plena competencia o al modo en que deben interpretarse y aplicarse estas Directrices, pero sí pueden afectar al análisis de

comparabilidad y, por tanto, a su resultado. Véase la Sección D, donde se comparan las situaciones previas y posteriores a la reestructuración.

A.2 Posibles diferencias factuales entre las situaciones que resultan de una reestructuración y las que se estructuran como tal desde el principio

9.127 Cuando un contrato entre empresas asociadas sustituye a un acuerdo preexistente (reestructuración), podrán observarse diferencias factuales en la situación inicial de la entidad reestructurada si se compara con la situación de una entidad de nueva creación. Estas diferencias pueden derivarse, por ejemplo, del hecho de que el contrato ulterior a la reestructuración se negocia entre partes que ya han tenido previamente relaciones contractuales y comerciales. Estas diferencias, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso y, en concreto, de los derechos y obligaciones que entrañan esos contratos anteriores para las partes, pueden determinar las opciones disponibles de modo realista para las partes en la negociación de los términos de un nuevo contrato y, por tanto, en las condiciones de los contratos de reestructuración o los que se concluyan tras ella⁸. Por ejemplo, supongamos que una parte ha demostrado en el pasado ser capaz de asumir correctamente la función de distribuidor “pleno”, llevando a cabo toda una serie de funciones de comercialización y venta, empleando para ello y desarrollando intangibles de comercialización valiosos, y asumiendo una serie de riesgos concomitantes a su actividad, tales como el riesgo de inventario, el riesgo de impago y los riesgos de mercado. Supongamos que su contrato de distribución se renegocia, convirtiéndolo en un contrato de distribución “de riesgo limitado”, en virtud del que realizará actividades de comercialización limitadas bajo la supervisión de una empresa asociada extranjera, empleando unos intangibles de comercialización limitados y soportando riesgos limitados en sus relaciones con la empresa asociada extranjera y con sus clientes. El distribuidor reestructurado podrá negociar un contrato sin período de prueba u otra condición desfavorable similar, mientras que estas condiciones sí se aplicarían a un nuevo distribuidor.

9.128 Cuando existe una relación económica que ya vincula a las partes antes de la reestructuración, y lo sigue haciendo después, también podrá haber una cierta relación entre, por un lado, las condiciones vigentes antes de

⁸ Véanse los párrafos 9.59 a 9.64 donde se analizan las opciones disponibles de modo realista en el contexto de la determinación de una compensación de plena competencia por razón de la propia reestructuración.

la reestructuración o durante la propia reestructuración y, por otro, las condiciones pactadas en los contratos posteriores a la reestructuración, como se analiza en la Sección C más adelante.

9.129 Algunas diferencias entre la situación inicial de una entidad reestructurada frente a la situación de una entidad de nueva creación pueden estar relacionadas con la posición bien establecida de la primera. Por ejemplo, si se compara la situación de un distribuidor “pleno” bien establecido que se convierte en un “distribuidor de riesgo limitado” con la de un nuevo “distribuidor de riesgo limitado” en un mercado en el que el grupo no tenía presencia comercial anteriormente, es muy probable que la entidad de nueva creación tenga que llevar a cabo acciones que le permitan introducirse en el mercado que no serían necesarias en el caso de la entidad reestructurada. Esta circunstancia debería reflejarse en el análisis de comparabilidad y afectaría a la determinación de la contraprestación de plena competencia que correspondería en ambas situaciones.

9.130 Cuando se compara la situación en la que un distribuidor “pleno” y bien establecido se convierte en un “distribuidor de riesgo limitado” con la de un “distribuidor de riesgo limitado” que ha estado operando en un mercado dado durante el mismo tiempo, pueden observarse diferencias debidas al hecho de que el distribuidor “pleno” puede haber desarrollado funciones, soportado gastos (por ejemplo de comercialización) y asumido algunos riesgos que contribuyeran al desarrollo de ciertos intangibles antes de su conversión, que el “distribuidor de riesgo limitado” bien establecido no habrá tenido que desarrollar, soportar o asumir. Se plantea entonces la cuestión de si, en condiciones de plena competencia, tales funciones, activos y riesgos adicionales deben afectar únicamente a la contraprestación que recibe el distribuidor antes de su conversión, si deben tenerse en cuenta para determinar la contraprestación de las operaciones que se realizan durante la conversión (y de ser así, cómo), si deben afectar a la contraprestación del “distribuidor de riesgo limitado” reestructurado (y de ser así, cómo), o una combinación de las tres posibilidades. Por ejemplo, si se constata que las actividades anteriores a la reestructuración llevaron al distribuidor “pleno” a poseer algunos intangibles, mientras que el distribuidor “de riesgo limitado” no los posee, el principio de plena competencia puede exigir o bien que estos intangibles se remuneren tras la reestructuración, en el caso de que el distribuidor “pleno” los haya transferido a una empresa asociada extranjera, o que se tengan en cuenta al determinar la contraprestación de plena

competencia de las actividades posteriores a la reestructuración en caso de que no se transfieran.⁹

9.131 Cuando la reestructuración entrañe la transferencia a una empresa asociada extranjera de los riesgos que anteriormente asumía el contribuyente, puede ser importante examinar si la transferencia de los riesgos concierne únicamente a los riesgos futuros que surgirán con motivo de las actividades ejercidas tras la reestructuración o también a los riesgos que existen en el momento de la reestructuración como resultado de las actividades previas a la conversión, es decir, se plantea un problema de punto de corte. Por ejemplo, supongamos que un distribuidor ha estado asumiendo un riesgo de impago que va a dejar de soportar tras su conversión en “distribuidor de riesgo limitado”, y que este se compara con un “distribuidor de riesgo limitado” bien establecido que nunca ha soportado el riesgo de impagos. A la hora de comparar ambas situaciones es importante examinar si el “distribuidor de riesgo limitado” que resulta de la conversión sigue soportando los riesgos de impago que hayan surgido antes de la reestructuración, en el momento en que operaba como distribuidor “pleno”, o si se han transferido esos riesgos, incluidos aquellos preexistentes a la conversión.

9.132 Estas mismas observaciones e interrogantes se plantean para otros tipos de reestructuraciones, comprendidas otras reestructuraciones de actividades de ventas, así como actividades de fabricación, investigación y desarrollo o actividades relacionadas con la prestación de servicios.

B. Aplicación a situaciones de reestructuraciones de empresa: selección y aplicación de un método de determinación de precios de transferencia a las operaciones vinculadas posteriores a una reestructuración

9.133 La selección y aplicación de un método de determinación de precios de transferencia a las operaciones vinculadas realizadas tras la reestructuración debe resultar del análisis de comparabilidad de la operación. Resulta esencial entender cuáles son las funciones, los activos y los riesgos implicados en esas operaciones posteriores a la reestructuración y qué parte las ejecuta, los posee o los soporta. Esto requiere disponer de información sobre dichas funciones, activos y riesgos respecto de las dos partes que

⁹ Véanse los párrafos 9.80 a 9.92 en relación con la aplicación del principio de plena competencia a la transferencia de intangibles.

intervienen en la operación, por ejemplo, la entidad reestructurada y la empresa asociada extranjera con la que opera. El análisis debe trascender la mera denominación otorgada a la entidad reestructurada, ya que en ocasiones puede observarse cómo una entidad a la que se etiqueta como “comisionista” o “distribuidor limitado” posee sus propios intangibles locales valiosos y continúa asumiendo importantes riesgos de mercado; al igual que se observa en ocasiones que una entidad calificada como “fabricante por contrato” realiza importantes actividades de desarrollo o posee y utiliza intangibles únicos. En las situaciones que suceden a la reestructuración debe prestarse especial atención a la identificación de los activos intangibles valiosos y a los riesgos importantes que continúa soportando la entidad reestructurada (incluyendo, cuando corresponda, los intangibles propios no protegidos), y si tal atribución de riesgos e intangibles satisface el principio de plena competencia. Las cuestiones referidas a riesgos e intangibles se analizan en las Partes I y II de este capítulo. Véanse en concreto los párrafos 9.44 a 9.46 en los que se revisa la relación entre la selección de un método de determinación de precios de transferencia y el perfil de riesgo de la parte.

9.134 Los acuerdos que suceden a la reestructuración pueden plantear ciertos retos respecto de la identificación de comparables potenciales en aquellos casos en los que la reestructuración conlleve un modelo empresarial que difícilmente pueda encontrarse entre empresas independientes.

9.135 Pueden darse casos en los que existan comparables (comprendidos los comparables internos), aunque haya que practicar algunos ajustes de comparabilidad. Un ejemplo de la posible aplicación del método del precio libre comparable podría ser el de la adquisición de una empresa que anteriormente operaba de forma independiente con el grupo multinacional, a la que sucede una reestructuración de las operaciones ahora vinculadas. A reserva de un examen de los cinco factores de comparabilidad y del posible efecto que pudieran causar las operaciones vinculadas y no vinculadas realizadas en distintos momentos, podría darse el caso de que las condiciones en las que se desarrollan las operaciones no vinculadas previas a la adquisición proporcionaran un precio libre comparable que pudiera aplicarse a las operaciones vinculadas posteriores a la adquisición. Incluso una vez reestructuradas las condiciones de las operaciones aun podría ser posible, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso, proceder a los ajustes necesarios por la transferencia de funciones, activos o riesgos que haya habido durante la reestructuración. Por ejemplo, podrá realizarse un ajuste de comparabilidad si la parte que asume el riesgo de impago no sigue siendo la misma.

9.136 Otro ejemplo de aplicación plausible del método del precio libre comparable sería el caso de partes independientes que realizaran actividades

de fabricación, venta o prestaciones de servicios comparables a las actividades realizadas por la sociedad vinculada reestructurada. Dado el creciente avance de la externalización de actividades, en algunos casos es posible encontrar operaciones de externalización independiente que pueden servir de base para la utilización del método del precio libre comparable a fin de determinar la contraprestación de libre competencia de las operaciones vinculadas. Naturalmente, esta comparación está condicionada a que las operaciones de externalización satisfagan los criterios necesarios para poder considerarlas como operaciones no vinculadas, y que la revisión de los cinco factores de comparabilidad provea de suficiente certeza de que no hay diferencias importantes entre las condiciones de la operación de externalización no vinculada y las condiciones en las que se desarrolla la actividad vinculada de externalización posterior a la reestructuración o, en todo caso, de que pueden hacerse los ajustes necesarios (y que se hacen de hecho) para eliminar tales diferencias.

9.137 Cuando se proponga un comparable, es importante asegurarse de que se analiza esa comparabilidad a fin de identificar las posibles diferencias sustanciales, en caso de haberlas, entre las operaciones vinculadas y no vinculadas y, cuando sea posible y necesario, asegurarse de que se procede a su ajuste. En concreto, los análisis de comparabilidad pueden revelar que la entidad reestructurada continua desarrollando importantes funciones que añaden valor a la operación, o que la entidad “menoscabado” tras la reestructuración sigue teniendo intangibles locales o riesgos significativos que no se encuentren en los comparables propuestos. Véase la Sección A sobre las posibles diferencias entre actividades reestructuradas y actividades de nueva creación.

9.138 La identificación de comparables potenciales debe tender a encontrar los datos comparables más fiables para las circunstancias del caso, teniendo en cuenta que la información disponible puede ser limitada y entrañar una pesada carga de cumplimiento (véanse los párrafos 3.2 y 3.80). Hay que admitir que los datos no siempre serán perfectos. También hay casos en los que no pueden encontrarse comparables. Esto no significa necesariamente que la operación vinculada no sea de plena competencia. En tales casos puede ser necesario determinar si las condiciones de la operación vinculada hubieran sido las mismas si las partes hubieran operado en condiciones de plena competencia. No obstante las dificultades que pueden surgir en el proceso de búsqueda de comparables, es necesario encontrar una solución razonable para todos los casos de determinación de precios de transferencia. Siguiendo las pautas señaladas en el párrafo 2.2, incluso en aquellos casos en los que los datos comparables son escasos e incompletos, la selección del método de determinación de precios de transferencia más

apropiado a las circunstancias debe ser coherente con la naturaleza de la operación vinculada, determinada para cada caso mediante un análisis funcional.

C. Relación entre la compensación por la reestructuración y la remuneración de las operaciones que siguen a la reestructuración

9.139 En algunos casos puede existir una estrecha relación entre la compensación por la reestructuración y la remuneración correspondiente en condiciones de plena competencia a la explotación de la actividad tras la reestructuración. Esto puede ocurrir cuando un contribuyente traspase actividades a una empresa asociada con la que posteriormente deba mantener relaciones comerciales como parte de esas actividades. En el párrafo 9.99 puede encontrarse un ejemplo de esa naturaleza en relación con la externalización.¹⁰

9.140 Otro ejemplo podría ser el de un contribuyente que, ejerciendo una actividad de fabricación y distribución, se reestructura cediendo su actividad de distribución a una empresa asociada extranjera, a la que en el futuro venderá los bienes que fabrica. La empresa asociada extranjera esperará poder obtener una remuneración de plena competencia por la inversión que representa la adquisición y explotación del negocio. En esta situación, el contribuyente puede acordar con la empresa extranjera asociada la renuncia total o parcial a la compensación inicial que pudiera corresponderle en condiciones de plena competencia, obteniendo en lugar de ello un beneficio financiero comparable a largo plazo por la venta de los productos a la empresa asociada extranjera a precios superiores a los que se hubieran acordado en caso de haberse pagado la compensación inicial. Y al contrario, las partes pueden acordar un pago compensatorio inicial por la reestructuración que se compense parcialmente con la aplicación en el futuro de precios de transferencia más bajos por los productos fabricados que los que se hubieran determinado en otras circunstancias. Véase la Parte II de este capítulo en la que se examinan aquellas situaciones en las que procedería el pago de una compensación de plena competencia por la reestructuración en sí misma.

9.141 Dicho de otro modo, en esta situación en la que el contribuyente tendrá una relación comercial continuada como proveedor de la empresa asociada extranjera, que desarrolla una actividad de la que anteriormente se

¹⁰

Véanse también los párrafos 9.82 a 9.86

encargaba el contribuyente, este y la empresa asociada extranjera tienen la oportunidad de obtener beneficios económicos y comerciales a través de esa relación (por ejemplo, el precio de venta de los bienes) que pueden explicar, por ejemplo, por qué se ha renunciado al pago inicial de un capital en concepto de compensación por el traspaso de la actividad, o por qué el precio de transferencia que se aplicará en el futuro a los productos puede diferir del que se hubiera acordado en caso de no existir la reestructuración. Sin embargo, en la práctica puede ser difícil estructurar y controlar un acuerdo de esa naturaleza. Si bien los contribuyentes son libres para elegir el modo de obtener pagos compensatorios, en forma de pago inicial o aplazados en el tiempo, las administraciones tributarias, al revisar tales acuerdos, desearán conocer cómo influyen sobre la compensación correspondiente a la actividad posterior a la reestructuración decisiones tales como, por ejemplo, la renuncia a una compensación por la propia reestructuración. Concretamente, y en ese caso, la administración tributaria deseará examinar la totalidad de los acuerdos, y proceder a evaluar por separado la compensación de plena competencia correspondiente a las operaciones previas y posteriores a la reestructuración.

D. Comparación de las situaciones que preceden y siguen a la reestructuración

9.142 Una cuestión importante que hay que plantearse es el papel de las posibles comparaciones que puedan efectuarse entre los beneficios realmente obtenidos por una parte en una operación vinculada antes y después de la reestructuración. En concreto, cabe preguntarse si es apropiado determinar los beneficios de una entidad reestructurada, posteriores a la reestructuración, tomando como referencia los beneficios anteriores a la reestructuración, ajustados de forma que reflejen la transferencia de ciertas funciones, activos o riesgos, o la renuncia a los mismos.¹¹

9.143 Un problema importante que se plantea con estas comparaciones “previas y posteriores” es que la comparación de los beneficios derivados de las operaciones vinculadas posteriores a la reestructuración con los beneficios obtenidos en operaciones vinculadas anteriores a la reestructuración no satisfacen los requisitos impuestos por el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, que obliga a la comparación con operaciones no vinculadas. Las comparaciones efectuadas entre las

¹¹

Esta cuestión es diferente de la que se planteaba en el caso de los beneficios potenciales que se analizan en la Parte II de este capítulo.

operaciones vinculadas del contribuyente y otras operaciones vinculadas son irrelevantes a los efectos de la aplicación del principio de plena competencia, por lo que las administraciones tributarias no deben recurrir a ellas como base para un ajuste de precios de transferencia, ni tampoco los contribuyentes en busca de argumentos que respalden su política de determinación de precios de transferencia.

9.144 Otro problema que se plantea con estas comparaciones “previas y posteriores” concierne a la dificultad que posiblemente entraña la valoración del conjunto de funciones, activos y riesgos que pierde la entidad reestructurada, teniendo en cuenta que no siempre se da esa transferencia de funciones, activos y riesgos a otra parte.

9.145 Una vez dicho esto, en las reestructuraciones empresariales las comparaciones “previas y posteriores” pueden desempeñar un papel importante a la hora de comprender la reestructuración en sí misma, pudiendo formar parte de un análisis de comparabilidad “previa y posterior” (incluido el análisis funcional) que permita comprender cuáles son los cambios que originan la modificación en la atribución de beneficios y pérdidas entre las partes. En efecto, la información sobre los acuerdos que existían antes de la reestructuración y sobre las condiciones de la propia reestructuración puede ser esencial para entender el contexto en el que se aplican los acuerdos que siguen a la reestructuración, así como para valorar su conformidad con el principio de plena competencia. También puede arrojar luz sobre las opciones disponibles de modo realista para la entidad reestructurada.¹²

9.146 Un análisis de comparabilidad (incluyendo el análisis funcional) de la actividad antes y después de la reestructuración puede revelar por qué unas funciones, activos y riesgos se transfieren, mientras que la entidad “menoscabada” conserva otros en virtud de contratos celebrados con la empresa asociada extranjera. Un cuidadoso análisis de los papeles que desempeñan la empresa asociada extranjera y la entidad “menoscabada” determinará cuál es el método más apropiado para fijar los precios de transferencia en función de las circunstancias del caso, por ejemplo, si es

¹²

Véanse los párrafos 9.59 a 9.64 en los que se analizan las opciones disponibles de modo realista; véanse también los párrafos 9.127 a 9.132, en los que se estudian las posibles diferencias factuales entre las situaciones que resultan de una reestructuración y las situaciones estructuradas como tal desde el inicio, y cómo pueden afectar esas diferencias a las opciones por las que realmente pueden optar las partes al negociar los términos de un nuevo acuerdo y, por tanto, a las condiciones de la reestructuración o de los acuerdos posteriores a la misma.

apropiado o no atribuir todo el resultado residual a la empresa extranjera en vista de los riesgos y activos reales de la entidad “menoscabada” y los que corresponden a la empresa asociada.

9.147 También habrá casos en los que las comparaciones “previas y posteriores” puedan llevarse a cabo porque las operaciones anteriores a la reestructuración no fueran operaciones vinculadas, por ejemplo, cuando la reestructuración sigue a una adquisición y puedan practicarse con fiabilidad ajustes que subsanen las diferencias entre las operaciones no vinculadas previas a la reestructuración y las operaciones vinculadas que la suceden. Véase el ejemplo propuesto en el párrafo 9.135. Para determinar si esas operaciones no vinculadas pueden ofrecer comparables fiables debemos referirnos a las pautas del párrafo 3.2.

E. Economías de localización

9.148 Los grupos multinacionales pueden obtener economías de localización reubicando algunas de sus actividades en emplazamientos en los que los costes (laborales, inmobiliarios, etc.) son menores que en los que se ubicaron inicialmente, teniendo en cuenta los costes que puede entrañar el cambio de emplazamiento (los costes de cierre de una actividad en curso, posible incremento en los costes de infraestructura en el nuevo emplazamiento, posible incremento en los costes de transporte si el nuevo centro operativo está ubicado más lejos del mercado, costes de formación de los empleados locales, etc.). Las indicaciones contenidas en los párrafos 1.59 a 1.63 son aplicables cuando la razón que se plantea para la reestructuración es una estrategia empresarial orientada a la obtención de economías de localización.

9.149 Cuando tras la reestructuración de la actividad se obtienen notables economías de localización, se plantea la cuestión de si este ahorro debe repartirse entre las partes y, de ser así, cómo. La respuesta dependerá, obviamente, de lo que hubieran acordado partes independientes en circunstancias similares, que normalmente hubieran dependido de las funciones, activos y riesgos de cada una de ellas y de sus respectivas capacidades de negociación.

9.150 Tomemos como ejemplo el de una empresa que diseña, fabrica y vende ropa de marca. Supongamos que el proceso de fabricación es simple y que la marca es muy conocida y constituye un intangible muy valioso. Supongamos que la empresa está establecida en el país A, donde los costes laborales son altos, por lo que decide terminar con su actividad fabril en este país y reasignar esas funciones a una sociedad afiliada en el país B, donde los

costes laborales son sustancialmente inferiores. La empresa del país A conserva los derechos sobre la marca y continúa con el diseño de la ropa. Tras la reestructuración, la ropa se fabricará en la empresa filial del país B en virtud de un contrato de fabricación. El contrato no entraña el uso de ningún intangible importante que se ceda a la afiliada, o que esta posea, ni la asunción de ningún riesgo importante por parte de la sociedad afiliada del país B. Una vez fabricada la ropa en el país B, esta se vende a la empresa del país A, que a su vez la venderá a terceras partes que son sus clientes. Supongamos que esta reestructuración hace posible que el grupo formado por la empresa en el país A y su afiliada en el país B obtengan notables economías de localización. Se plantea entonces la cuestión de si las economías de localización deben atribuirse a la empresa del país A, o a su afiliada en el país B, o a ambas (y, de ser así, en qué proporción).

9.151 En este ejemplo, dada la gran competencia a la que está sometida la actividad deslocalizada, es muy probable que la empresa del país A pueda optar tanto por su afiliada en el país B como por un tercer fabricante. Por tanto, sería posible encontrar datos comparables para determinar las condiciones en las que un tercero estaría dispuesto a fabricar la ropa para la empresa en condiciones de plena competencia. En esa situación, a un fabricante por contrato que operara en condiciones de plena competencia, se le asignaría una parte mínima, en caso de asignársele alguna, de las economías de localización obtenidas. En caso de obrar de otro modo, se estaría colocando al fabricante asociado en una posición distinta de la de un fabricante independiente, lo que sería contrario al principio de plena competencia.

9.152 Pongamos ahora otro ejemplo en el que una empresa del país X presta unos servicios de ingeniería altamente especializados a clientes independientes. La empresa es muy afamada por su alto nivel de calidad. Factura a sus clientes independientes en función de una tarifa fija por hora similar a la aplicada por sus competidores por la prestación de servicios similares en el mismo mercado. Supongamos que los sueldos de los ingenieros especializados en el país X son altos. La empresa abre después una subsidiaria en el país Y para la que contrata ingenieros igualmente cualificados con sueldos significativamente inferiores, y subcontrata una gran parte de sus trabajos de ingeniería a su filial en el país Y, obteniendo así importantes economías de localización para el grupo que forman la empresa y su filial. Los clientes siguen tratando directamente con la empresa del país X y no tienen por qué tener conocimiento de la subcontratación. Durante algún tiempo, la afamada empresa del país X continúa aplicando la tarifa inicial por sus servicios, a pesar de haber reducido significativamente los costes que implican sus ingenieros. Sin embargo, una vez transcurrido un

cierto tiempo, se ve forzada, por razones de competitividad, a reducir sus tarifas y a repercutir parte de sus economías de localización a sus clientes. En este caso también se plantea la pregunta de a qué parte o partes del grupo multinacional deben atribuirse, en condiciones de plena competencia, las economías de localización: a la filial en el país Y, a la empresa del país X, o a ambas (y, de ser así, en qué proporción).

9.153 En este ejemplo, puede ocurrir que exista una alta demanda de los servicios de ingeniería en cuestión y que la filial en el país Y sea la única que pueda prestarlos con el nivel de calidad exigido, de forma que la empresa en el país X no tenga muchas más opciones que la de recurrir a esta proveedora de servicios. Puede ocurrir que la filial en el país Y haya desarrollado un intangible valioso consistente en sus conocimientos técnicos *–know-how–*. En ese caso sería necesario considerar este intangible en la determinación de la contraprestación de plena competencia correspondiente a los servicios subcontratados. En las circunstancias adecuadas (por ejemplo, en el caso de contribuciones únicas importantes tales como intangibles utilizados por ambas empresas, la del país X y su filial en el país Y), cabe considerar la utilización de un método de la distribución del resultado.

F. Ejemplo: implantación de una función centralizada de compras

9.154 Esta sección ilustra la aplicación del principio de plena competencia en el caso de la ejecución de una función centralizada de compras. Se destaca la importancia clave de los análisis de comparabilidad y, en concreto, del análisis funcional para llegar a comprender el papel que desempeña cada una de las partes en la generación de sinergias, la reducción de costes y otros efectos de la integración. La enumeración que sigue no pretende abarcar todas las situaciones posibles, sino sólo las más frecuentes. La elección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado dependerá de los hechos y circunstancias del caso. En concreto, la determinación de a qué parte o partes deben atribuirse la reducción de costes o las ineficiencias generadas por la centralización de la función de compras dependerá de las circunstancias de cada caso.

9.155 Supongamos que un grupo multinacional crea una central de compras encargada de la negociación con terceros proveedores para la adquisición de materias primas utilizadas por todas las plantas del grupo en el proceso de fabricación. Dependiendo de los respectivos análisis funcionales de las plantas de fabricación, de la entidad encargada de las compras centralizadas y de los términos contractuales que hayan acordado,

se pueden considerar distintos patrones de remuneración y distintos métodos de determinación de precios de transferencia.

9.156 En primer lugar, habrá casos en los que deba aplicarse el método del precio libre comparable. Supongamos que la entidad de compras centralizadas adquiere las materias primas a terceros proveedores y se las vende a las plantas de fabricación. Podrá aplicarse el método del precio libre comparable cuando las materias primas se negocian en un mercado de productos primarios (véase el párrafo 2.18). Puede ocurrir que el precio pagado por las fábricas antes de la interposición de la entidad central de compras, o el precio pagado por partes independientes por materias primas comparables, pueda utilizarse, sujeto a la revisión de los hechos y circunstancias y de los efectos que provoque la realización de las operaciones vinculadas e independientes en momentos distintos, como precio libre comparable que permita determinar el precio al que las fábricas adquirirían las materias primas a la entidad central de compras. Sin embargo, en caso de no ajustarse, la utilización de este precio libre comparable puede conducir a la atribución de todas las reducciones de costes a la central de compras. Como se señaló en el párrafo 9.154, es necesario proceder caso por caso para determinar si esta atribución sería conforme con el principio de plena competencia. En caso de que se concluyera que, en las circunstancias concretas del caso, una parte del ahorro en los costes debe imputarse a las fábricas, se plantea la cuestión de si debe y puede ajustarse el precio libre comparable.

9.157 Cuando no puede utilizarse el precio libre comparable, por ejemplo, porque el precio de las materias primas fluctúe, y el precio pagado por las fábricas antes de la interposición de la entidad central de compras no sirva como referencia, puede considerarse la posibilidad de recurrir al método del coste incrementado. Por ejemplo, la entidad central de compras puede adquirir las materias primas a terceros proveedores y revenderlas a las fábricas al precio de coste incrementado en un margen, es decir, el nuevo precio de adquisición de las materias primas por la entidad central de compras más un margen de plena competencia. En tal caso, el margen atribuido a la central de compras debe ser comparable al obtenido en operaciones no vinculadas comparables.

9.158 En algunos casos, la entidad central de compras interviene como agente tanto para los proveedores o para los compradores (o para ambos) y se remunera mediante una comisión pagada bien por los proveedores, o por los compradores (o por ambos). Esta situación puede darse cuando la central de compras negocia con proveedores independientes, pero no adquiere la titularidad de las existencias, es decir, las fábricas siguen adquiriendo las materias primas directamente de los proveedores, pero con una reducción en

el precio, obtenida gracias a la intervención de la entidad central de compras y a la participación del grupo de fábricas en el acuerdo. La comisión puede ser proporcional a las compras (sobre todo cuando la paga el proveedor) o a los descuentos obtenidos (cuando las pagadoras sean las fábricas). Debe ser comparable a la comisión que se hubiera pagado entre partes independientes por el desempeño de una función de agente comparable en circunstancias similares.

9.159 Puede ocurrir que lo que a primera vista pueda considerarse como un margen sobre los costes o una comisión de plena competencia desde el punto de vista de la entidad central de compras, conduzca en realidad a una determinación de precios de adquisición para las empresas fabricantes superiores a los que podrían obtener por sí mismas. Si el incremento de costes generado resulta significativo para los fabricantes (por ejemplo, si afecta recurrente y sustancialmente a la cartera de productos que se canalizan a través de la entidad central de compras) se plantea la cuestión de si entre fabricantes independientes se hubiera acordado pagar esos precios más altos y cuál sería la lógica económica subyacente a esa decisión, o si en condiciones de plena competencia la entidad central de compras debería soportar toda o parte de la ineficiencia a través de la reducción en sus precios de venta a los fabricantes. La respuesta dependerá de los hechos y circunstancias del caso. El análisis debe apoyarse básicamente en la determinación de los beneficios que las partes (las plantas de fabricación y la entidad central de compras) hubieran esperado obtener, en buena lógica, de la centralización de las adquisiciones, y de las opciones disponibles de modo realista de que dispongan, incluyendo, cuando proceda, la opción de no participar en la adquisición centralizada en caso de que los beneficios que puedan preverse de esta centralización sean menos atractivos que los de otras opciones. Cuando sea razonable que las partes pudieran esperar obtener un beneficio, es fundamental analizar las razones de la aparente ineficiencia de la central de compras, los términos contractuales conforme a los que esta ópera y el análisis funcional tanto de las fábricas como de la entidad central de compras, en concreto, de sus respectivas funciones y responsabilidades en la toma de decisiones que han conducido a la ineficiencia. Este análisis debe hacer posible determinar a qué parte o partes atribuir los costes de la ineficiencia y en qué medida. Cuando este análisis apunte que las ineficiencias deben atribuirse a la entidad central de compras, tal atribución puede llevarse a cabo fijando el precio de la operación de venta a las plantas de fabricación sobre la base del método del precio libre comparable, es decir, basándose en los precios que las fábricas hubieran podido obtener en el mercado libre respecto de adquisiciones comparables efectuadas en condiciones igualmente comparables. No debe asumirse sin embargo que toda ineficiencia deba atribuirse por defecto a la función de la centralización

de compras, o que el efecto positivo generado por la sinergia deba compartirse siempre entre los miembros del grupo.

9.160 Finalmente, pueden darse casos en los que el ahorro en los costes (o su incremento) generado por la centralización de la función de adquisición se comparta entre la entidad central de compras y las plantas de fabricación a través de un mecanismo de distribución de resultados.

Parte IV: Aceptación de las operaciones realmente efectuadas

A. Introducción

9.161 Todo análisis de precios de transferencia debe partir de la correcta identificación y calificación de las operaciones vinculadas objeto de revisión. Los párrafos 1.64 a 1.69 tratan sobre la importancia de las operaciones reales efectuadas por las empresas asociadas y analizan las circunstancias excepcionales en las que puede ser legítimo y apropiado que una autoridad fiscal no admita, a los efectos de la determinación de los precios de transferencia, la operación que le presenta el contribuyente.

9.162 Los párrafos 1.64 a 1.69 se circunscriben al rechazo de las operaciones a los efectos de practicar los ajustes de precios de transferencia a los que se refiere el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE (es decir, los ajustes efectuados conforme al principio de plena competencia). Estos párrafos no ofrecen pauta alguna respecto de la capacidad de un país para calificar las operaciones en aplicación de otras disposiciones de su derecho interno. En los Comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE puede leerse un análisis sobre la relación entre las normas anti-abuso contenidas en el derecho interno y los convenios (véanse en concreto los párrafos 9.5, 22 y 22.1 de los Comentarios).

9.163 Las multinacionales son libres de organizar sus operaciones comerciales como estimen oportuno. Las administraciones tributarias no tienen derecho a dictar a una multinacional el modo en que debe diseñar su estructura o dónde ubicar sus operaciones. No se puede forzar a los grupos multinacionales a tener o a mantener un cierto nivel de presencia en un país. Son libres para actuar según sus propios intereses económicos y comerciales y, a este respecto, es posible que las consideraciones fiscales puedan ser un factor que tengan en cuenta. Sin embargo, las administraciones tributarias tienen derecho a determinar las consecuencias tributarias de la estructura por la que opta la multinacional, con sujeción a lo dispuesto en sus convenios fiscales y, en particular, en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Esto significa que las administraciones tributarias pueden realizar ajustes en los precios de transferencia, cuando sea preciso, de acuerdo con el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, u otro tipo de ajustes que permita su normativa interna (por ejemplo, en virtud

de normas antiabuso generales o específicas), en la medida en que esos ajustes sean compatibles con las obligaciones contraídas en virtud de sus convenios.

B. Operaciones realmente efectuadas. El papel que desempeñan los términos contractuales. Relación entre los párrafos 1.64 a 1.69 y otras partes de estas Directrices

9.164 En el contexto del artículo 9, todo análisis para verificar la conformidad de las operaciones vinculadas con el principio de plena competencia debe iniciarse por las operaciones realmente efectuadas por las empresas asociadas, y las cláusulas contractuales desempeñan un papel fundamental (véase el párrafo 1.64). Sin embargo, como se admite en los párrafos 1.47 a 1.51 y 1.64 a 1.69, la revisión de los términos contractuales no es suficiente.

9.165 Según lo dispuesto en el artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, las administraciones tributarias pueden ajustar los beneficios de los contribuyentes cuando las condiciones en las que se realiza una operación vinculada difieran de las que se hubieran acordado entre empresas independientes. En la práctica, los ajustes en los precios de transferencia consisten en el ajuste de los beneficios de una empresa que siguen a los ajustes practicados en los precios u otras condiciones de una operación vinculada (por ejemplo, las condiciones de pago o la atribución de los riesgos). Esto no significa que todos los ajustes de precios de transferencia, tanto aquellos que se circunscriben al ajuste del precio o también (o exclusivamente) al ajuste de otras condiciones de una operación vinculada, como los que resultan de la evaluación separada de las operaciones que se presentan en forma conjunta de acuerdo con lo señalado en los párrafos 3.11 y 6.18, deben contemplarse como equivalentes a la inadmisión de una operación vinculada en virtud de los párrafos 1.64 a 1.69. En efecto, tales ajustes pueden resultar del análisis de comparabilidad, véase en concreto el párrafo 1.33. Los párrafos 1.48 a 1.54 proporcionan pautas sobre la posibilidad de que una administración tributaria cuestione los términos contractuales cuando no sean coherentes con la sustancia económica de la operación, o cuando no se ajusten a la conducta de las partes.

9.166 En la Parte I de este capítulo puede leerse cómo determinar si la atribución de riesgos en una operación entre empresas asociadas es de plena competencia. Como se señaló en el párrafo 9.11, el análisis de los riesgos en el contexto del artículo 9 se inicia con la revisión de las cláusulas

contractuales acordadas entre las partes, ya que son estas las que, por lo general, definen cómo deben distribuirse los riesgos entre ellas. Sin embargo, como se señaló en los párrafos 1.48 a 1.54, una supuesta atribución de riesgos entre empresas asociadas se respetará únicamente en la medida en que sea coherente con la sustancia económica de la operación. Por tanto, al examinar la atribución de riesgos entre las empresas asociadas y las consecuencias que implica en los precios de transferencia, es importante revisar no sólo las cláusulas contractuales, sino también si las empresas asociadas se ajustan a la atribución contractual de los riesgos y si las cláusulas contractuales proponen una atribución de riesgos de plena competencia. Al evaluar la conformidad con el principio de plena competencia, surgen dos factores que desempeñan un papel muy importante: la existencia o no de datos que muestren una distribución similar de riesgos en operaciones no vinculadas comparables y, en ausencia de estos datos, si la atribución de riesgos tiene sentido desde el punto de vista comercial (y en concreto si el riesgo se atribuye a la parte que tiene un mayor control sobre él). Los párrafos 9.34 a 9.38 explican la diferencia entre realizar un ajuste de comparabilidad y no aceptar la atribución del riesgo que se ha efectuado en la operación vinculada; también examinan la relación entre las orientaciones contenidas en el párrafo 1.49 y las de los párrafos 1.64 a 1.69.

9.167 En la Parte II de este capítulo se sigue un razonamiento similar respecto de los derechos de indemnización por la finalización o renegociación sustancial de un contrato preexistente. El párrafo 9.103 señala que, además de examinar si el contrato que se rescinde, que no se renueva o que se renegocia sustancialmente, está formalizado por escrito y contiene una cláusula que prevé la indemnización, también puede resultar importante valorar si los términos del contrato y la posible existencia o no de una cláusula de indemnización u otro tipo de garantía (así como sus propios términos en caso de que esta exista) son de plena competencia.

C. Aplicación de los párrafos 1.64 a 1.69 de estas Directrices a las reestructuraciones de empresas

C.1 *El rechazo de una operación se limita a casos excepcionales*

9.168 Los párrafos 1.64 a 1.69 limitan explícitamente la no aceptación de la operación o el acuerdo real a casos muy excepcionales. Esto indica que el rechazo no es la norma, sino la excepción al principio general de que las revisiones que realice la administración tributaria de una operación vinculada

deben basarse, de ordinario, en la operación realmente efectuada por las empresas asociadas, tal como estas la hayan estructurado.¹³ El término “excepcional” en este contexto, significa “raro” o “inhabitual”, y hace referencia al hecho de que, en la mayoría de los casos, se espera satisfacer el principio de plena competencia que exige el artículo 9 calculando un precio de plena competencia para el acuerdo tal como realmente se ha desarrollado y estructurado..

9.169 Conforme a los párrafos 1.64 a 1.69, las administraciones tributarias pueden, en casos excepcionales, rechazar la calificación o estructura otorgada por las partes a la operación o al acuerdo cuando, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias del caso, concluyan que:

- La sustancia económica de la operación o del acuerdo difiere de su forma (Sección C.2); o
- Unas empresas independientes, en circunstancias comparables, no habrían calificado o estructurado la operación o el acuerdo como lo han hecho las empresas asociadas, y no es posible determinar fehacientemente un precio de plena competencia para esta operación o acuerdo (Secciones C.3 y C.4).

Ambas situaciones son ejemplos en los que la calificación o la estructuración de la operación o del acuerdo por las partes se consideran como el resultado de condiciones que no hubieran existido entre empresas independientes (véase el párrafo 1.66).

C.2 *Determinación de la sustancia económica de una operación o de un acuerdo*

9.170 La sustancia económica de una operación o de un acuerdo se determina analizando todos los hechos y circunstancias del caso, tales como el contexto económico y comercial de dicho acuerdo u operación, su objeto y los efectos que provoca desde el punto de vista práctico y del negocio, así como el proceder de las partes, incluyendo las funciones que desempeñan, los activos que utilizan y los riesgos que asumen.

¹³

Como se señaló en el párrafo 1.53, es importante analizar si el proceder de las partes se ajusta a los términos del contrato o si este indica que no se han seguido, o que son simulados. En tales casos es necesario realizar un análisis más minucioso para determinar las verdaderas condiciones de la operación, y el ajuste de precios puede no ser la solución.

C.3 *¿Hubieran llegado al mismo acuerdo partes independientes?*

9.171 La segunda circunstancia que se plantea en el párrafo 1.65 se refiere explícitamente a aquellas situaciones en las que los acuerdos adoptados por las empresas asociadas “difieren de los que habrían suscrito empresas independientes que actuaran de modo racional desde un punto de vista comercial...” Conforme al párrafo 9.163, las administraciones tributarias deben evitar intervenir en las decisiones empresariales de un contribuyente en cuanto a la forma de estructurar su actividad. Por tanto, la determinación de que una operación vinculada no responde a la lógica comercial debe realizarse con sumo cuidado, y sólo en condiciones excepcionales se llegará a la no admisión de los acuerdos suscritos entre empresas asociadas.

9.172 Cuando datos fiables muestren que existen operaciones no vinculadas comparables, no cabe argumentar que dichas operaciones entre empresas asociadas carecen de lógica comercial. La existencia de datos comparables que corroboren la determinación del precio de transferencia acordado por las empresas asociadas demuestra su lógica comercial para empresas independientes en circunstancias comparables. Por otro lado, no obstante, el mero hecho de que un acuerdo entre empresas asociadas no pueda encontrarse entre empresas independientes no significa por sí mismo que no sea de plena competencia o que carezca de lógica comercial (véase el párrafo 1.11).

9.173 Las reestructuraciones empresariales suelen llevar a los grupos multinacionales a aplicar modelos empresariales globales que difícilmente se encuentran entre empresas independientes, si es que se dan alguna vez, ya que aprovechan el hecho de ser grupos multinacionales y las posibilidades que les ofrece su modelo integrado de trabajo. Por ejemplo, los grupos multinacionales pueden disponer de cadenas de suministro mundiales o de funciones centralizadas que no se dan entre empresas independientes. En esto radica la dificultad de valorar si tales modelos empresariales son del tipo que hubieran adoptado empresas independientes que se comportaran con lógica comercial. La falta de comparables no significa en absoluto que la aplicación de estos modelos globales deba considerarse automáticamente fuera de la lógica comercial.

9.174 Lo que se intenta discernir es si el resultado (el acuerdo adoptado) es conforme con el que obtendrían empresas independientes que actuaran con la lógica comercial habitual; no se trata de un test de comportamiento en el sentido de exigir a las empresas asociadas que procedan como lo harían empresas independientes a la hora de negociar y acordar los términos de sus acuerdos. Por tanto, el hecho de que las empresas asociadas lleven a cabo

una auténtica negociación, o simplemente actúen en favor de los intereses del conjunto de la multinacional a la hora de acordar una reestructuración, no determina si empresas independientes, siguiendo la lógica comercial, hubieran concluido tal acuerdo o si se ha llegado a un precio de plena competencia.

9.175 La aplicación del principio de plena competencia se basa en la noción de que empresas independientes no emprenderían una operación si contarán con una alternativa claramente más atractiva. Véanse los párrafos 9.59 a 9.64. Como se analiza en estos párrafos, para determinar el precio de plena competencia de un acuerdo puede ser importante considerar las opciones disponibles de modo realista. También puede ser importante saber si los acuerdos adoptados por las empresas asociadas difieren de los que hubieran sido adoptados por empresas independientes que actuaran de acuerdo con la lógica comercial. Pueden darse casos excepcionales en los que no pueda determinarse fehacientemente un precio de plena competencia para el acuerdo adoptado y se concluya que empresas independientes, actuando según la lógica comercial, no hubieran adoptado tal acuerdo en circunstancias comparables (véase la Sección C.4).

9.176 Una empresa independiente no hubiera iniciado una operación de reestructuración si considera que realmente dispone de una opción claramente más atractiva, incluida la posibilidad de no acometer la reestructuración. Al evaluar si una parte dispone realmente, en condiciones de plena competencia, de opciones más atractivas que la reestructuración, debe prestarse atención a todas las condiciones que esta reestructuración entraña, a los derechos y otros activos de las partes, a la compensación o indemnización que pudiera percibir con ese motivo y a la remuneración correspondiente a los acuerdos posteriores a la reestructuración (como se analiza en las Partes II y III de este capítulo), así como a las circunstancias comerciales que se derivan de la participación en un grupo multinacional (véase el párrafo 1.11).

9.177 Al valorar la racionalidad comercial de una reestructuración, puede plantearse la cuestión de si debe considerarse una operación aisladamente o en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las restantes operaciones que tengan relación económica con esta. Por lo general, lo conveniente será observar la racionalidad comercial del conjunto de la reestructuración. Por ejemplo, al examinar la venta de un intangible comprendido en una reestructuración de mayor calado que implica cambios en los acuerdos relativos al desarrollo y al uso de ese intangible, no deberá examinarse la racionalidad comercial de la venta del activo aisladamente de los cambios que implica. Por otro lado, cuando una reestructuración implique cambios en más de un elemento o aspecto de una actividad, que no estén relacionados

desde el punto de vista económico, podrá ser necesario determinar la racionalidad comercial de los cambios de forma individual. Por ejemplo, una reestructuración puede implicar la centralización de la función de compras del grupo, así como de la propiedad de intangibles de valor no relacionados con la función de compras. En tal caso, la racionalidad comercial de la centralización de la función de compras deberá evaluarse independientemente de la de la centralización de la propiedad de los intangibles.

9.178 Pueden existir razones comerciales al nivel del grupo para una reestructuración. Sin embargo, merece la pena destacar el hecho de que el principio de plena competencia obliga a la consideración de los miembros de un grupo multinacional como entidades independientes, en lugar de como partes indivisibles de una sola entidad unificada (véase el párrafo 1.6). Por tanto, desde la perspectiva de los precios de transferencia, no es suficiente con que el acuerdo de reestructuración tenga sentido para el conjunto del grupo: el acuerdo debe ser de plena competencia a nivel de cada contribuyente particular, teniendo en cuenta sus derechos y otros activos, los beneficios que espera obtener del acuerdo (a saber, la contraprestación correspondiente a los acuerdos que sucedan a la reestructuración más todo pago compensatorio que pueda derivarse de la propia reestructuración), así como otras opciones disponibles de modo realista.

9.179 Cuando una reestructuración es racional desde el punto de vista comercial para el conjunto del grupo multinacional, cabe esperar que se determine un precio de transferencia apropiado (es decir, una compensación por los acuerdos posteriores a la reestructuración más una compensación por la reestructuración en sí) de forma que la operación resulte conforme con el principio de plena competencia para cada miembro del grupo que participa en ella. Véase la Parte II del este capítulo, Sección B.

C.4 *Constatación de si para una operación o acuerdo hay una solución basada en los precios de transferencia*

- 9.180 En la segunda circunstancia analizada en el párrafo 1.65, el segundo criterio acumulativo es que la “estructura real impide en la práctica que la administración tributaria determine el precio de transferencia apropiado.” Si se puede llegar a determinar un precio de plena competencia (es decir, un precio que tenga en cuenta el análisis de comparabilidad, incluido el análisis funcional, de ambas partes del acuerdo u operación) en las circunstancias del caso, con independencia de que no pueda encontrarse ese acuerdo u operación entre partes

independientes y de que la administración tributaria pueda albergar dudas sobre la lógica comercial que sigue el contribuyente al iniciar dicho acuerdo u operación, este no se ignorará en virtud del segundo criterio descrito en el párrafo 1.65. Siendo otras las circunstancias, la administración tributaria puede decidir si el rechazo del acuerdo u operación está justificado en virtud de ese segundo criterio del párrafo 1.65.

C.5 *Importancia de la motivación fiscal*

9.181 En virtud del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, el hecho de que un acuerdo de reestructuración empresarial esté motivado por la posibilidad de obtener ventajas fiscales no implica por sí mismo que no pueda tratarse de un acuerdo de plena competencia.¹⁴ La mera presencia de una motivación o de un objetivo fiscal no justifica el rechazo de la calificación o estructuración otorgada por las partes al acuerdo por aplicación de los párrafos 1.64 a 1.69.

9.182 En el marco del artículo 9 y siempre que se transfieran realmente las funciones, los activos y los riesgos, puede resultar racional desde el punto de vista comercial que un grupo multinacional se reestructure con la intención de obtener ahorros gastos fiscales. Sin embargo, esta consideración no es pertinente para determinar si el principio de plena competencia se respeta a nivel de la entidad para un contribuyente afectado por la reestructuración (véase el párrafo 9.178).

C.6 *Consecuencias del rechazo por aplicación de los párrafos 1.64 a 1.69*

9.183 En la primera de las circunstancias descritas en el párrafo 1.65, cuando la sustancia económica de la operación difiere de su forma, las administraciones tributarias pueden ignorar la calificación otorgada por las partes a la operación y recalificarla conforme a su verdadera sustancia económica.

9.184 Respecto de la segunda circunstancia, el párrafo 1.65 incluye un ejemplo de no admisión de una venta y señala que, si bien es oportuno respetar la operación como una transmisión de propiedad comercial, lo adecuado sería, no obstante, que la administración tributaria ajustara los términos del conjunto de la operación (y no simplemente en relación al

¹⁴

Como se señaló en el párrafo 9.8, las normas internas antiabuso no están comprendidas en el ámbito de este capítulo.

precio) a aquellos que hubiera sido razonable encontrar en el caso de que la transmisión de la propiedad se hubiera efectuado entre empresas independientes. En tal caso, la administración tributaria debería ajustar las condiciones del acuerdo de forma racional desde el punto de vista comercial.

9.185 En ambas circunstancias, el artículo 9 permitiría un ajuste de las condiciones a fin de reflejar aquellas que se hubieran acordado en caso de que la operación se hubiera estructurado de acuerdo con la realidad económica y comercial de partes que operan en condiciones de plena competencia (véase el párrafo 1.66). Al proceder de este modo, la administración tributaria que aplique el principio de plena competencia tendrá que determinar cuál es la realidad que subyace al acuerdo contractual (véase el párrafo 1.67).

9.186 El párrafo 1.68 ofrece alguna orientación en el caso de que una administración tributaria pueda considerar útil referirse a operaciones entre empresas independientes estructuradas de otro modo para determinar si la estructura de una operación vinculada satisface el principio de plena competencia. El hecho de que se puedan considerar o no los datos que arroje una alternativa concreta dependerá de los hechos y de las circunstancias de cada caso, incluyendo el número y la precisión de los ajustes necesarios para salvar las diferencias entre la operación vinculada y su alternativa, así como de la fiabilidad de cualquier otro dato disponible.

9.187 Estas orientaciones indican que la administración tributaria deberá intentar sustituir la operación no aceptada por una calificación o estructura alternativa que refleje al máximo posible los hechos del caso, es decir, aquella que sea coherente con los cambios funcionales ocurridos en la actividad económica del contribuyente, resultantes de la reestructuración, que refleje al máximo la sustancia económica de las operaciones, así como los resultados que se hubieran obtenido si estas se hubieran estructurado de acuerdo con la realidad económica en la que operarían partes independientes. Por ejemplo, cuando entre los aspectos de un acuerdo de reestructuración se contemple el cierre de una fábrica, la recalificación de la reestructuración no puede ignorar la realidad de que la fábrica deja de funcionar. Del mismo modo, cuando uno de los aspectos de la reestructuración consista en la reubicación de importantes funciones empresariales, la recalificación de la reestructuración no puede ignorar la reubicación efectiva de esas funciones. Otro ejemplo: cuando un acuerdo de reestructuración implique la transferencia de propiedad entre dos partes, el rechazo del acuerdo de reestructuración tendría que reflejar que la transferencia ha tenido lugar entre las dos partes, aunque pueda resultar útil cambiar la calificación de la transmisión por otra distinta que se ajuste al máximo posible a los hechos (por ejemplo, una supuesta transmisión de todos los derechos sobre la

propiedad podría recalificarse como un mero arrendamiento o cesión de la propiedad, o viceversa).

D. Ejemplos

D.1 *Ejemplo (A): conversión de un distribuidor “pleno” en un distribuidor “sin riesgo”*

9.188 La sociedad Z es un distribuidor bien conocido de productos de lujo. Posee un valioso nombre comercial y puntos de venta minorista y contratos con proveedores a largo plazo igualmente valiosos. Un grupo multinacional adquiere esta sociedad. La multinacional opera con un modelo empresarial mundial en virtud del que todos los nombres comerciales y otros intangibles de valor son propiedad de la sociedad V en el país V. La sociedad W en el país W posee todos los contratos con los proveedores y es responsable de la gestión de estos contratos para todo el grupo. Los puntos de venta minorista son propiedad de una sociedad inmobiliaria en el país X. Inmediatamente después de la adquisición, el grupo decide reestructurar la sociedad Z transfiriendo su nombre comercial a la sociedad V, sus contratos de valor con los proveedores a la sociedad W y sus puntos de venta minorista a la sociedad X, todo ello a cambio de un pago único. Como consecuencia de la transferencia, la sociedad Z interviene ahora como comisionista para la sociedad W. Su beneficio potencial tras la reestructuración es sustancialmente inferior que el anterior a ella. Los representantes del grupo multinacional explican que la razón mercantil para proceder a la reestructuración es la de alinear el modelo operativo de la sociedad Z con el del resto del grupo multinacional, y que esta perspectiva constituyó uno de los factores decisivos para la adquisición. Los directivos de la sociedad Z no tienen más alternativa que aceptar la reestructuración, ya que la adquisición es efectiva. Según ellos, el precio fijado para la transmisión de su nombre comercial, de sus contratos y de sus puntos de venta es de plena competencia, y la remuneración para sus actividades posteriores a la reestructuración se ajustará igualmente a la que corresponda en plena competencia.

9.189 Suponiendo que en este caso el proceder de las partes sea coherente con la reestructuración, no habrá discordancia entre la sustancia económica del acuerdo y la calificación y la estructura que le confieren las partes. En este caso se espera que la determinación del precio de plena competencia por la propia reestructuración y por las actividades que la suceden arroje un resultado de plena competencia para cada una de las partes, en cuyo caso se aceptará la operación de reestructuración.

D.2 Ejemplo (B): transferencia de intangibles de valor una sociedad instrumental

9.190 Una multinacional fabrica y distribuye productos cuyo valor no viene determinado por las características técnicas del producto en sí, sino por el nombre y grado de exposición de la marca. La multinacional quiere diferenciarse de sus competidores mediante el desarrollo de marcas de gran valor, aplicando una estrategia de comercialización costosa y cuidadosamente desarrollada. Las marcas son propiedad de la sociedad A en el país A. La concepción, gestión y ejecución de la estrategia mundial de comercialización constituye la clave de generación de valor del grupo multinacional, de lo que se encargan 125 empleados en la sede de la sociedad A. El valor de las marcas se traduce en un precio elevado de los productos ofrecidos a los consumidores. La sede de la sociedad A ofrece igualmente servicios centrales para las filiales del grupo (gestión de recursos humanos, servicios jurídicos y accesoria fiscal, por ejemplo). Las sociedades filiales fabrican los productos en virtud de contratos de fabricación con la sociedad A. La distribución también está a cargo de filiales que adquieren el producto a la sociedad A. Los beneficios que obtiene la sociedad A tras la atribución de una contraprestación de plena competencia a las fabricantes y distribuidoras por contrato se considera como constitutiva de la remuneración por los intangibles, las actividades de comercialización y los servicios centralizados que presta la sociedad A.

9.191 Supongamos que se lleva a cabo una reestructuración. La sociedad A transfiere las marcas a una filial de nueva creación, la sociedad Z en el país Z, a cambio de un pago único. Tras la reestructuración, la sociedad A obtiene una remuneración basada en el coste incremento por los servicios que presta a la sociedad Z y al resto del grupo. La remuneración de las fabricantes y distribuidoras por contrato afiliadas sigue siendo la misma. El resultado residual tras la retribución de fabricantes y distribuidores por contrato y en concepto de servicios prestados por la sede Sociedad A, se paga a la sociedad Z. Del análisis de comparabilidad pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- No hay datos fiables relativos a operaciones comparables no vinculadas en las que la propiedad de marcas comerciales y los riesgos que implican se atribuyan entre empresas independientes del mismo modo que en el caso de las operaciones vinculadas entre la sociedad A y la sociedad Z;
- La sociedad Z está gestionada por una sociedad fiduciaria local. Carece de personal (asalariados o administradores) capacitado para ejercer y que ejerza efectivamente funciones de control en relación con los riesgos

asociados al desarrollo estratégico de las marcas. Tampoco tiene capacidad económica para asumir los riesgos.

- Altos directivos de la sede de la sociedad A viajan una vez al año al país Z para validar formalmente las decisiones estratégicas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Estas decisiones se preparan en la sede de la sociedad A en el país A antes de que se celebren las reuniones en el país Z. La multinacional considera que estas actividades son prestaciones de servicios que efectúa la sede de la sociedad A para Z. Estas actividades de toma de decisiones estratégicas se remuneran según el método del coste incrementado, del mismo modo que la prestación de servicios centralizados (gestión de recursos humanos, servicios jurídicos y asesoría fiscal, por ejemplo).
- La concepción, gestión y ejecución de la estrategia mundial de comercialización sigue siendo competencia de los mismos empleados de la sede de la sociedad A y continúan remunerándose conforme al método del coste incrementado. No hay previsto en el contrato un incentivo para la sociedad A que la incite a maximizar el valor de las marcas comerciales o la cuota de mercado, ya que su remuneración se basa en el coste incrementado.

9.192 Al considerar todos los hechos y circunstancias se llega a la conclusión de que la sustancia económica del acuerdo difiere de su forma. En concreto, los hechos indican que la sociedad Z no tiene capacidad real para asumir el riesgo que se la atribuye en virtud del acuerdo tal como las partes lo han calificado y estructurado. Además, no hay datos que sustenten las razones comerciales del acuerdo. En un caso de esta naturaleza, el párrafo 1.65 permite a las administraciones tributarias rechazar la estructura adoptada por las partes.¹⁵

D.3 Ejemplo (C): aceptación de la transferencia de un intangible

9.193 El escenario es el mismo que en el ejemplo (B), salvo por el hecho de que parte de la sede de la sociedad A se reasigna efectivamente al país Z: se despiden a 30 de los 125 empleados de la sede, otros 30 se transfieren a la nueva sociedad Z en el país Z, y la sociedad Z contrata directamente a 15 nuevos empleados en el país Z para llevar a cabo las funciones que

¹⁵

Esta observación no obsta la posible aplicación de las normas generales antiabuso ni el planteamiento de la cuestión de la sede de dirección efectiva de la sociedad Z.

desempeñaban los trabajadores despedidos. Los empleados de la sociedad Z tienen la capacidad y la competencia necesarias para llevar a cabo el desarrollo estratégico de la marca y para aplicar tal estrategia a nivel mundial. Asimismo, en este ejemplo se entiende que la sociedad Z tiene capacidad financiera para asumir los riesgos asociados al desarrollo estratégico de las marcas. La sociedad Z, que es ahora la propietaria legal de las marcas, ejerce las actividades de concepción, gestión y ejecución de una estrategia de comercialización mundial. Los empleados de la sociedad Z tienen capacidad para ejercer las funciones de control, y lo llevan a cabo efectivamente, en relación con los riesgos asociados al desarrollo estratégico de las marcas. Los servicios prestados por el resto de la sede de la sociedad A son servicios centrales (gestión de recursos humanos, servicios jurídicos y asesoría fiscal, por ejemplo) así como funciones de apoyo a la comercialización, ejercidas bajo el control del personal de la sociedad Z. La razón principal para que el grupo efectúe esta reestructuración es obtener el beneficio de un régimen de tributación en el país Z más favorable que el del país A.

9.194 Los cambios de escenario respecto del ejemplo (B) nos llevan a concluir que la sustancia económica del acuerdo no difiere de su forma, y que empresas independientes en circunstancias comparables que actuaran siguiendo la lógica comercial hubieran calificado o estructurado el acuerdo como lo han hecho las empresas asociadas. Teniendo esto en cuenta, las administraciones tributarias buscarán conseguir un resultado de plena competencia tanto para la propia reestructuración como para las actividades de las partes tras la misma sobre la base de la aceptación de los acuerdos realmente adoptados.¹⁶

¹⁶

Con esto no quiere hacerse referencia a la posible aplicación de las normas nacionales antiabuso.

Listado de Anexos

- Anexo a las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia: Líneas rectoras de los procedimientos de seguimiento de la aplicación de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y la implicación del mundo empresarial.
- Anexo I al Capítulo II: Sensibilidad de los indicadores de beneficios brutos y netos.
- Anexo II al Capítulo II: Ejemplo ilustrativo de la aplicación del método de la distribución del resultado residual.
- Anexo III al Capítulo II: Ejemplo de las distintas medidas del resultado cuando se aplica un método de la distribución del resultado.
- Anexo al Capítulo III: Ejemplo de ajuste del capital circulante.
- Anexo al Capítulo IV: Líneas rectoras de los acuerdos previos de valoración en el marco de los procedimientos amistosos (“APV PA”).
- Anexo al Capítulo VI: Ejemplos ilustrativos de la aplicación de las Directrices sobre precios de transferencia a activos intangibles de valoración muy incierta.

Anexo a las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia

Líneas rectoras de los procedimientos de seguimiento de la aplicación de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y la implicación del mundo empresarial

A. Antecedentes

1. En julio de 1995, el Consejo de la OCDE aprobó para su publicación las *“Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y a administraciones tributarias”* (“las Directrices”) presentadas por el Comité de Asuntos Fiscales (“el Comité”). Paralelamente, el Consejo de la OCDE aprobó la recomendación del Comité para la revisión y actualización periódica de las Directrices, según se considerara conveniente sobre la base de la experiencia que fueran adquiriendo los países miembros y el mundo empresarial al aplicar los principios y métodos definidos en las Directrices. Con tal fin y al objeto de facilitar las aclaraciones y mejoras que se están llevando a cabo, el Consejo de la OCDE dio instrucciones al Comité para que iniciara un período de seguimiento de la experiencia internacional en materia de precios de transferencia. Se considera que el desempeño de esta función de seguimiento forma parte integral del acuerdo alcanzado en julio de 1995 y es indispensable que su aplicación sea un éxito para que las Directrices puedan aplicarse de forma consistente. La recomendación del Consejo “instruye al Comité de Asuntos Fiscales para que realice un seguimiento de la aplicación del informe de 1995, en colaboración con las autoridades fiscales de los países miembros y con la participación del mundo empresarial y recomienda al Consejo, si fuese necesario, la modificación y actualización de este informe a la luz de los resultados de esta revisión”.

2. En resumen, el objetivo principal de este seguimiento es examinar en qué medida la legislación, la reglamentación y las prácticas administrativas de los países miembros se ajustan a las Directrices, así como enumerar los campos donde estas últimas podrían necesitar modificaciones y adiciones. Esta actividad no debe consistir únicamente en la enumeración de

los aspectos que plantean problemas, sino también en la identificación de las formas de aplicar las Directrices adoptadas por uno o varios países miembros que merecerían ampliarse a otros países. Este seguimiento no tiene como objeto pronunciarse sobre casos particulares.

3. El procedimiento debe ser permanente y abarcar todos los aspectos cubiertos por las Directrices con un énfasis especial en la utilización de los métodos basados en el resultado de las operaciones. Esta nota aspira a presentar algunos métodos para instrumentar esa supervisión, acatando así las instrucciones dictadas por el Consejo de la OCDE. Los procedimientos de supervisión se aplicarán progresivamente, pudiendo ser necesario revisarlos más adelante, una vez que se hayan puesto en práctica.

4. En línea con la Recomendación del Consejo, el mundo empresarial también deberá desempeñar un cierto papel en el proceso de seguimiento, como se describe en la sección C.

B. Procedimiento

5. El proceso de seguimiento se instrumentará mediante cuatro proyectos relacionados entre sí: 1. Evaluaciones paritarias de las prácticas en los países miembros; 2. Identificación y análisis de problemas paradigmáticos complejos; 3. Revisión de los cambios en los textos legales, reglamentos y prácticas administrativas; y 4. Elaboración de ejemplos. A continuación, se examina cada uno de los puntos.

B.1 Evaluaciones paritarias (*peer review*)

6. El Grupo de Trabajo n ° 6 sobre la tributación de las empresas multinacionales (“el Grupo de Trabajo”) ha emprendido en estos últimos años evaluaciones paritarias de las prácticas seguidas por los países miembros en materia de precios de transferencia. Estas evaluaciones tienen como meta obtener información detallada sobre la legislación, las prácticas y la experiencia de los países miembros en materia de precios de transferencia. Los delegados del Grupo de Trabajo deciden conjuntamente qué país deberá ser objeto de evaluación y cuáles serán los países que la llevarán a cabo. Las evaluaciones siguen las directrices aprobadas por el Comité.

7. Estas directrices aplicables a las evaluaciones paritarias prevén la entrega al Grupo de Trabajo de un informe de cada país que se haya sometido a dicha revisión. El informe abarca los fundamentos jurídicos aplicables en materia de precios de transferencia, las normas para su aplicación, los criterios que se utilizan normalmente para abordar un

problema complejo de precios de transferencia, las medidas administrativas previstas para el tratamiento de las cuestiones de precios de transferencia, los principios de la jurisprudencia y la experiencia en materia de obtención de datos y de documentación relativos a los contribuyentes. Este informe debe describir también los procedimientos administrativos utilizados para evitar y resolver los litigios en el campo de los precios de transferencia (por ejemplo: los procedimientos amistosos, APV y regímenes de protección).

8. Las evaluaciones paritarias seguirán llevándose a cabo, pero en tres niveles diferentes:

1. El primer nivel sería un “*examen temático*” que consistiría en estudiar el criterio adoptado por todos los países miembros respecto a una cuestión concreta de importancia para la generalidad. Idealmente, este examen debe vincularse a otros aspectos del proceso de seguimiento. Por ejemplo, el mejor medio de resolver los problemas que pudieran plantearse tras un examen de esta naturaleza sería el de analizar la cuestión con detenimiento, desarrollando una casuística paradigmática de casos difíciles (véase la Sección B.2 de este anexo) o elaborar ejemplos prácticos para su inserción en las Directrices (véase la Sección B.4 de este anexo).
2. El segundo nivel sería un “*examen limitado*” porque estaría referido exclusivamente al criterio aplicado en uno o varios países en relación con un asunto concreto y de ámbito relativamente limitado. El examen lo efectuarían dos analistas para cada país y el nivel de las aportaciones necesarias dependería de la naturaleza de la cuestión objeto de estudio.
3. El tercer nivel sería un “*examen completo*” de un país en particular que se realizaría sobre la base de los principios de las evaluaciones paritarias mencionados en el párrafo 7 anterior. Por tanto, el examen completo abordaría directamente la interpretación y aplicación de las Directrices en ese país miembro en concreto.

Criterios de selección

9. Con el fin de mejorar la eficacia del proceso de evaluación paritaria*, es importante que esta se efectúe de forma selectiva y que se concentre en los campos donde la aplicación de las Directrices presenta más dificultades. La decisión final de acometer uno de estos tres tipos de exámenes la tomará el Grupo de Trabajo en sesión plenaria, teniendo en cuenta tanto el interés general de cualquier revisión para el trabajo de este

* (N. de la T.) En inglés “peer review”.

Grupo sobre el seguimiento de la aplicación de las Directrices, y si los recursos disponibles son suficientes para asumir la revisión propuesta. Es importante que cualquier revisión, una vez iniciada, se lleve a cabo con un alto nivel de calidad, de forma que permita extraer conclusiones significativas.

B.2 Identificación y análisis de paradigmas de casos difíciles

10. Uno de los aspectos esenciales del proceso de seguimiento consistirá en identificar y después analizar los hechos y áreas problemáticas que puedan ilustrarse mediante ejemplos prácticos y que constituyan un obstáculo para poder aplicar internacional y homogéneamente los métodos de determinación de precios de transferencia recogidos en las Directrices. Asimismo, el proceso de seguimiento abarcará aquellas áreas en las que las Directrices no ofrecen indicación alguna a las administraciones tributarias ni a los contribuyentes, u ofrecen unas pautas insuficientes. Todos los países miembros participarán activamente en este proceso y asumirán la dotación de un presupuesto que garantice su éxito. El mundo empresarial también participará en la supervisión (véase la sección C de este anexo).

11. El primer punto consiste en seleccionar los procedimientos que vayan a utilizarse y determinar a quién corresponde la selección del paradigma de casos difíciles, centrándose en aquellas cuestiones y situaciones respecto de las que las Directrices no ofrezcan pautas adecuadas, o estas sean insuficientes, o respecto de las que los países miembros puedan tener una interpretación diversa, circunstancias que obstaculizarían la homogeneidad de su aplicación internacional. Los países miembros pueden identificar aquellas áreas en las que, en su opinión, las Directrices no abordan un problema concreto, o no lo hacen adecuadamente.

12. En el marco de las reuniones periódicas de inspectores organizadas por el Comité de Asuntos Fiscales, el Grupo de Trabajo convocará reuniones bienales para examinar los problemas tipo y reunir elementos para una eventual actualización de las Directrices. La OCDE sólo estudiará los casos paradigmáticos desde la perspectiva del seguimiento de la aplicación de las Directrices.

13. Durante las reuniones del Grupo de Trabajo nº 6, los países podrían asumir la responsabilidad de conducir el análisis de los paradigmas de casos difíciles y de las áreas problemáticas que puedan ilustrarse mediante ejemplos prácticos.

14. Entre los resultados que el Grupo de Trabajo espera obtener de la identificación y el análisis de los paradigmas de casos difíciles puede

incluirse la plasmación en ejemplos de la aplicación de las Directrices a casos (elegidos para análisis) a los que puedan aplicarse los principios ya contenidos en ellas. Asimismo, podría incluirse la identificación de las áreas o aspectos en los que cabría modificar las Directrices con el fin de hacer de ellas una pauta más clara, o en las que convendría añadir nuevos elementos.

B.3 *Actualizaciones de la legislación y de la práctica*

15. De acuerdo con la misión que le ha sido encomendada por el Consejo, el Secretariado solicitará a los países miembros los informes sobre la evolución de su legislación, reglamentos y prácticas administrativas en materia de precios de transferencia.

B.4 *Elaboración de ejemplos*

16. Los procedimientos de seguimiento descritos anteriormente seguirán el desarrollo de ejemplos teóricos complementarios que se añadirán a las Directrices. Estos ejemplos no tienen como objetivo abordar nuevos problemas ni desarrollar nuevos principios, sino facilitar la interpretación de los ya abordados en las Directrices. Con el fin de garantizar su interés práctico y evitar que sean demasiado normativos, los ejemplos serán breves y se basarán en hechos probados y relativamente simples, de forma que su ámbito sea lo suficientemente amplio para que las indicaciones que ofrezcan no tengan una aplicación estricta y limitada. Los ejemplos se dividirán en dos grandes categorías. La primera ilustrará la aplicación de los métodos y criterios descritos en las Directrices. La segunda se diseñará de forma que sirva de ayuda en la selección de uno o varios métodos de determinación de precios de transferencia. Aunque hipotéticos, estos ejemplos se inspirarán en la experiencia práctica adquirida por las administraciones tributarias y por los contribuyentes en la aplicación del principio de plena competencia previsto en las Directrices, contribuyendo así a la identificación de las buenas prácticas.

C. Participación del mundo empresarial.

17. No está previsto que la OCDE intervenga en la resolución de litigios relativos a los precios de transferencia entre un contribuyente y su administración tributaria. La supervisión no aspira a erigirse en una forma de arbitraje, por lo que los contribuyentes no podrán someter casos particulares al Grupo de Trabajo para que éste los resuelva. De todas formas, como lo prevén las Directrices y las recomendaciones del Consejo, se promoverá que

el mundo empresarial identifique los problemas (en la medida de lo posible ilustrándolos con ejemplos prácticos pero hipotéticos) que generan dificultades en la homogeneidad de la aplicación internacional de las Directrices.

18. Se invitará al Comité Consultivo Económico e Industrial (BIAC) a que someta a la consideración del Grupo de Trabajo las dificultades concretas surgidas en el seguimiento de la aplicación de las Directrices, con el fin de que examine la idoneidad de las pautas que estas ofrecen en relación con esas áreas concretas, respetando siempre la confidencialidad de las informaciones.

19. Al asistir a la OCDE en el seguimiento de la aplicación de las Directrices, se promoverá que el mundo empresarial tenga especialmente en cuenta las orientaciones formuladas en el párrafo 17 de este anexo. Deberá por tanto centrarse en los temas que originan dificultades teóricas o prácticas y no en casos concretos y no resueltos referidos a la determinación de precios de transferencia. No obstante, puede ser útil ilustrar una determinada cuestión haciendo referencia a un ejemplo hipotético. Al elaborar este tipo de ejemplos, que pueden inspirarse en las características de casos reales, es preciso asegurarse de que conservan su naturaleza hipotética y que no se asemejan a ningún caso real, así como de que las características descritas se limitan a los aspectos problemáticos con el fin de evitar la impresión de que se trata de establecer un precedente general para la resolución de un problema específico.

C.1 Evaluaciones paritarias

20. Se considera que uno de los puntos fuertes de las evaluaciones paritarias consiste en el hecho de que se llevan a cabo exclusivamente entre iguales, en este caso entre países miembros, en el marco de un proceso positivo y constructivo que permite la generalización de las prácticas más positivas y la mejora de las menos satisfactorias. No obstante, las directrices generales dirigidas al mundo empresarial les animan a identificar las cuestiones problemáticas que pudieran ser objeto de análisis ulterior y el Grupo de Trabajo podrá tener en cuenta esta contribución a la hora de realizar una selección definitiva de las cuestiones que deban abordarse en el marco de una evaluación paritaria.

21. Está también previsto que una vez que el Grupo de Trabajo haya seleccionado la cuestión o el país que deba estudiarse con detenimiento se notificará al BIAC, de forma que este pueda aportar sus observaciones. Si se trata de una cuestión inicialmente identificada por el BIAC y, en particular,

en el contexto de los exámenes temáticos, se le mantendrá informado de los debates del Grupo de Trabajo y, si fuera necesario, se le invitará a que efectúe las aclaraciones necesarias. Por el momento no se contempla la ampliación del papel del BIAC en el proceso de evaluación paritaria más allá de lo descrito.

C.2 *Identificación y análisis de paradigmas de casos difíciles y elaboración de ejemplos*

22. Los paradigmas de casos difíciles aspiran a ofrecer ejemplos de cuestiones o situaciones en las que las orientaciones marcadas por las Directrices son inexistentes o inadecuadas. Los ejemplos prácticos se incluirán en las Directrices una vez concluidos a fin de ilustrar determinados principios. La comunidad empresarial puede desempeñar un papel muy claro en el desarrollo de estos paradigmas o ejemplos aportando su experiencia práctica. Durante su elaboración, el Grupo de Trabajo solicitará comentarios a intervalos regulares tanto sobre los paradigmas de casos difíciles como sobre los ejemplos prácticos. El propio BIAC puede elaborar paradigmas o ejemplos, siempre que se respeten las salvaguardas formuladas en el párrafo 17 de este anexo, de modo que no se utilice el proceso para resolver un problema concreto de precios de transferencia.

C.3 *Actualización de la legislación y de la práctica.*

23. El objetivo de este elemento del proceso de supervisión es mantener informados a los países miembros sobre la evolución habida en los restantes países. Por lo general, a nivel nacional existen mecanismos bien asentados que permiten al mundo empresarial contribuir a la actualización de la legislación, de los reglamentos y de las prácticas administrativas de los países miembros. A nivel de la OCDE, el BIAC tendrá la posibilidad de llamar la atención del Grupo de Trabajo sobre las modificaciones introducidas en la legislación o en las prácticas de los países miembros y no miembros que considere contrarias a las Directrices o susceptibles de crear problemas prácticos a la hora de su aplicación, naturalmente sin hacer referencia explícita a casos individuales.

24. La contribución del BIAC se analizará en el marco de las reuniones mixtas regulares que este mantenga con el Grupo de Trabajo.

Anexo I al Capítulo II

Sensibilidad de los indicadores de beneficios brutos y netos

Véase el Capítulo II, parte III, sección B de estas Directrices, en donde se ofrecen pautas generales sobre la aplicación del método del margen neto operacional.

Las hipótesis relativas a los acuerdos de plena competencia que se utilizan en los siguientes ejemplos tienen un carácter meramente ilustrativo, por lo que no debe considerarse que obliguen a la realización de ajustes ni a la imposición de acuerdos de plena competencia en situaciones concretas que atañen a sectores de actividad en particular. Si bien estos ejemplos pretenden ilustrar los principios enunciados en los diversos apartados de las Directrices a los que se refieren, estos principios deben aplicarse en cada caso de acuerdo con los hechos y circunstancias concretos de cada uno de ellos.

Del mismo modo, los comentarios recogidos a continuación se refieren a la aplicación de un método del margen neto operacional en aquellos casos en los que teniendo en cuenta los hechos y circunstancias concretos, y en particular el análisis de comparabilidad (comprendido el análisis funcional) de la operación, y tras la revisión de la información disponible sobre operaciones comparables no vinculadas, se resuelva que este método es el más apropiado para el caso.

1. Se admite que el método del margen neto operacional puede ser menos sensible a ciertas diferencias en las características de los productos que los métodos del precio libre comparable o del precio de reventa. En la práctica, al aplicar el método del margen neto operacional se presta más atención a la comparabilidad funcional que a las características de los productos. Sin embargo, el método del margen neto operacional puede ser menos sensible a ciertas diferencias en las funciones que quedarían reflejadas en los gastos de explotación, como se ilustra a continuación.

Ejemplo 1:**Efecto provocado por una variación en el grado y complejidad de la función de comercialización ejercida por un distribuidor**

El ejemplo que se muestra a continuación es meramente ilustrativo. No pretende constituir indicación o pauta alguna sobre la selección del método de determinación de precios de transferencia o de los comparables, ni sobre la eficiencia de los distribuidores o sobre los niveles de retribución de plena competencia, sino meramente ilustrar el efecto que provoca una variación en el grado y complejidad de la función de comercialización que ejerce un distribuidor y sus comparables.

	Caso 1 El distribuidor realiza una función de comercialización limitada	Caso 2 El distribuidor realiza una función de comercialización más amplia
Venta de productos (A los efectos del ejemplo, asumimos que ambos venden el mismo volumen del mismo producto, en el mismo mercado y al mismo precio)	1.000	1.000
Precio de adquisición al fabricante, teniendo en cuenta la importancia de la función de comercialización según el análisis funcional.	600	480 (*)
Margen bruto	400 (40%)	520 (52%)
Gastos de comercialización	50	150
Otros gastos (generales)	300	300
Margen de beneficio neto	50 (5%)	70 (7%)

(*) En este caso, suponemos que la diferencia de 120 en el precio de la operación se corresponde con la diferencia en el grado y complejidad de la función de comercialización que lleva a cabo el distribuidor (gasto adicional de 100 más la remuneración de la función del distribuidor).

2. En el ejemplo 1, si un contribuyente opera con un fabricante asociado en las condiciones del caso 2, mientras que terceros “comparables”

operan como en las del caso 1, y suponiendo que no hay constancia de la diferencia en el grado y complejidad de la función de comercialización por carecer, por ejemplo, de información suficientemente detallada sobre los terceros “comparables”, entonces el riesgo de error al aplicar un método basado en el margen bruto puede ser de 120 ($12\% \times 1.000$), mientras que ascendería a 20 ($2\% \times 1.000$) si se aplicara un método basado en el margen neto. Esto ilustra el hecho de que, dependiendo de las circunstancias del caso y, en concreto, del efecto que provocan las diferencias funcionales en la estructura de costes y en las rentas de los “comparables”, los márgenes de beneficio neto pueden ser menos sensibles a las diferencias en el grado y complejidad de las funciones que los márgenes brutos.

Ejemplo 2:**Efecto provocado por una variación en el nivel de riesgo asumido por un distribuidor**

El ejemplo que se muestra a continuación es meramente ilustrativo. No pretende constituir indicación o pauta alguna sobre la selección del método de determinación de precios de transferencia o de los comparables, ni sobre la eficiencia de los distribuidores o sobre los niveles de retribución de plena competencia, sino meramente ilustrar el efecto que provoca una variación en el nivel de riesgo asumido por un distribuidor y sus comparables.

	Caso 1 El distribuidor no asume el riesgo de obsolescencia de los productos porque se beneficia de una cláusula de recompra mediante la que se prevé la devolución al fabricante de los productos no vendidos	Caso 2 El distribuidor asume el riesgo de obsolescencia de los productos. No hay prevista una cláusula de recompra en su relación contractual con el fabricante.
Venta de productos (A los efectos del ejemplo, asumimos que ambos venden el mismo volumen del mismo producto, en el mismo mercado y al mismo precio)	1.000	1.000
Precio de adquisición al fabricante, teniendo en cuenta el riesgo de obsolescencia según el análisis funcional.	700	640 (*)
Margen bruto	300 (30%)	360 (36%)
Pérdidas por existencias obsoletas	0	50
Otros gastos (generales)	250	250
Margen de beneficio neto	50 (5%)	60 (6%)

(*) En este caso, suponemos que la diferencia de 60 en el precio de la operación se corresponde con la diferencia en la atribución del

riesgo de obsolescencia entre el fabricante y el distribuidor (pérdida adicional estimada en 50 más la contraprestación correspondiente al riesgo del distribuidor), es decir, este es el precio de la cláusula contractual de recompra.

3. En el ejemplo 2, si se efectúa una operación vinculada en las condiciones del caso 1, mientras que terceros “comparables” operan en las del caso 2, y suponiendo que no haya constancia de la diferencia en el nivel de riesgo por carecer de información suficientemente detallada sobre los terceros “comparables”, entonces el riesgo de error al aplicar un método basado en el margen bruto puede ser de 60 ($6\% \times 1.000$), en lugar de 10 ($1\% \times 1.000$) que se obtendría si se aplicara un método basado en el margen neto. Esto ilustra el hecho de que, dependiendo de las circunstancias del caso y, en concreto, del efecto que provocan las diferencias en el nivel de riesgo sobre la estructura de costes y en las rentas de los “comparables”, los márgenes de beneficio neto pueden ser menos sensibles que los márgenes brutos a las diferencias en el nivel de riesgo (suponiendo que la atribución contractual de los riesgos sea de plena competencia).

4. Por tanto, las empresas que ejercen funciones diferentes pueden tener una amplia variedad de márgenes de beneficio bruto, mientras que obtienen niveles de beneficio neto bastante similares. Por ejemplo, los comentaristas del entorno empresarial indican que el método del margen neto operacional sería menos sensible a las diferencias experimentadas en el volumen, grado y complejidad de las funciones y de los gastos de explotación. Por otro lado, el método del margen neto operacional puede ser más sensible que el método del coste incrementado o que el método del precio de reventa por lo que respecta a las diferencias en la utilización de la capacidad, ya que las diferencias en los niveles de absorción de los costes fijos indirectos (por ejemplo, costes fijos de fabricación o de distribución) pueden afectar al beneficio neto pero no al margen bruto o al margen bruto incrementado sobre los costes si no se traducen en diferencias en el precio, como se ilustra a continuación.

Ejemplo 3:***Efecto provocado por una variación en la utilización de la capacidad del fabricante***

El ejemplo que se muestra a continuación es meramente ilustrativo. No pretende constituir indicación o pauta alguna sobre la selección del método de determinación de precios de transferencia o de los comparables, ni sobre los niveles de retribución de plena competencia, sino meramente ilustrar el efecto que provoca una variación en la utilización de la capacidad de un fabricante y sus comparables.

En unidades monetarias (u.m.)	Caso 1 El fabricante opera a pleno rendimiento: 1.000 unidades al año	Caso 2 El fabricante opera por debajo de su capacidad, es decir, fabrica únicamente el 80 por ciento de lo que podría fabricar a pleno rendimiento: 800 unidades al año
Venta de productos (a los efectos del ejemplo, asumimos que ambos fabricantes tienen la misma capacidad total, ambos fabrican y venden el mismo producto en los mismos mercados y al mismo precio de 1 u.m. por producto fabricado) (*)	1.000	800
Coste de los productos vendidos: coste directo más la parte proporcional de los costes indirectos de fabricación (a los efectos del ejemplo, asumimos que ambos fabricantes tienen los mismos costes variables sobre los productos vendidos por unidad fabricada, es decir, 0.75 u.m. por producto fabricado, y costes fijos de personal de 50).	Variables: 750 Fijos: 50 Total: 800	Variables: 600 Fijos: 50 Total: 650
Margen bruto incrementado sobre el coste de los bienes vendidos	200 (25%)	150 (23%)

Costes indirectos (a los efectos del ejemplo asumimos que ambos fabricantes soportan los mismos costes indirectos)	150	150
Margen de beneficio neto	50 (5%)	Punto de equilibrio

(*) Con esto se asume que la utilización de la capacidad del fabricante no afecta al precio de plena competencia de los productos fabricados.

5. En el ejemplo 3, si se realiza una operación vinculada en las condiciones del caso 1, mientras que terceros “comparables” operan según las del caso 2, y suponiendo que no haya constancia de la diferencia en la utilización de la capacidad por carecer de información suficientemente detallada sobre los terceros “comparables”, entonces el riesgo de error al aplicar un método basado en el margen bruto puede ser de 16 ($2\% \times 800$), en lugar de 50 ($5\% \times 1.000$) que se obtendría si se aplicara un método basado en el margen neto. Esto ilustra el hecho de que los indicadores de beneficio neto pueden ser más sensibles que el margen bruto incrementado sobre el costes o que los márgenes brutos respecto de las diferencias en la utilización de la capacidad, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso y, en concreto, del porcentaje de costes fijos y variables, y de si es el contribuyente o el “comparable” el que opera por debajo de su capacidad.

Anexo II al Capítulo II

Ejemplo ilustrativo de la aplicación del método de la distribución del resultado residual

Véase el Capítulo II, parte III, sección C de estas Directrices, donde se ofrece una orientación general respecto de la aplicación del método de la distribución del resultado.

Los ajustes e hipótesis relativos a los acuerdos de plena competencia que se utilizan en los ejemplos siguientes tienen un carácter meramente ilustrativo, por lo que no debe considerarse que obliguen a la realización de ajustes ni a la imposición de acuerdos de plena competencia en situaciones concretas o sectores de actividad en particular. Si bien estos ejemplos pretenden ilustrar los principios enunciados en las secciones de las Directrices a las que se refieren, esos principios deben aplicarse en cada caso de acuerdo con los hechos y circunstancias concretos de cada uno de ellos.

1. El éxito de un producto electrónico está relacionado con el innovador diseño tecnológico de sus procesos electrónicos y de su componente principal. La sociedad asociada A fabrica y diseña este componente y se lo transfiere a la sociedad asociada B, que diseña y fabrica el resto del producto que finalmente distribuye la sociedad asociada C. Se dispone de información que permite verificar, gracias al método del precio de reventa, que las funciones de distribución y los riesgos asumidos por la sociedad C se remuneran de forma apropiada con el precio de transferencia del producto final de B a C.

2. El método más apropiado para valorar el precio del componente transferido de A a B sería el del precio libre comparable si se pudiera encontrar un comparable lo suficientemente parecido (véase el párrafo 2.14 de las Directrices). No obstante, como el componente transferido de A a B refleja el innovador avance tecnológico del que se beneficia la sociedad A en este mercado, en este ejemplo resulta imposible (después de haber realizado el análisis funcional y de comparabilidad apropiados) encontrar un precio libre comparable fiable que permita calcular el precio correcto que A podría exigir en plena competencia por su producto. Sin embargo, al calcular el rendimiento de los costes de fabricación de A podría obtenerse una estimación del elemento de beneficio que remuneraría la función de

fabricación que lleva a cabo A, ignorando el elemento de beneficio atribuible al intangible utilizado. Se podrían efectuar cálculos similares relativos a los costes de fabricación de la sociedad B a fin de proceder a una estimación del beneficio que B obtiene de sus funciones manufactureras, ignorándose el elemento de beneficio atribuible a su intangible. Dado que conocemos el precio de venta que B cobra a C y que se acepta como un precio de plena competencia, puede determinarse el resultado residual conjunto obtenido por A y B gracias a la explotación de sus intangibles respectivos. Véanse los párrafos 2.108 y 2.121 de estas Directrices. En esta fase queda sin determinar el porcentaje de resultado residual atribuible a cada empresa.

3. El resultado residual puede atribuirse sobre la base de un análisis de los hechos y circunstancias que mostrara cómo se habría atribuido el beneficio adicional en condiciones de plena competencia (véase el párrafo 2.121 de las Directrices). La actividad de investigación y desarrollo de cada una de las sociedades está dirigida al diseño tecnológico de las mismas categorías de producto, estableciéndose en el marco de este ejemplo que los importes de los gastos de investigación y desarrollo constituyen una medida fiable del valor relativo de las aportaciones efectuadas por las sociedades (véase el párrafo 2.120 de las Directrices). Ello significa que la contribución de cada sociedad a la innovación tecnológica del producto puede medirse de forma cierta mediante sus gastos relativos en investigación y desarrollo, de forma que si los gastos de investigación y desarrollo de A son de 15 y los de B de 10, el porcentaje residual puede fraccionarse en 3/5 para A y 2/5 para B.

4. Algunas cifras pueden ayudar a comprender mejor el ejemplo.

a) Pérdidas y ganancias de A y B

	A	B
Ventas	50	100
Menos:		
Compras	(10)	(50)
Costes de fabricación	<u>(15)</u>	<u>(20)</u>
Beneficio bruto	25	(20)
Menos:		
I+D	15	10
Gastos de explotación	10 <u>(25)</u>	10 <u>(20)</u>
Beneficio neto	0	10

b) Determinación del beneficio normalmente obtenido por las actividades de fabricación que desarrollan A y B y cálculo del resultado residual total

5. En este ejemplo, y en ambas jurisdicciones, los fabricantes independientes comparables que no disponen de activos intangibles innovadores obtienen un rendimiento sobre sus costes de fabricación (excluyendo compras) de un 10% (ratio de beneficio neto a costes directos e indirectos de fabricación)¹. Véase el párrafo 2.121 de las Directrices. Los costes de fabricación de A son de 15 y, en consecuencia, al calcular el rendimiento respecto a los costes, se atribuiría a A un beneficio por la actividad de fabricación de 1.5. Los costes equivalentes de B son de 20 y, por tanto, al calcular el rendimiento sobre los costes se atribuiría a B un beneficio de 2 por la actividad de fabricación. El resultado residual es, por consiguiente, de 6.5 y se obtiene deduciendo del beneficio neto combinado de 10, el beneficio combinado sobre la actividad de fabricación de 3.5.

c) Atribución del resultado residual

6. La atribución inicial del beneficio (1.5 para A y 2.0 para B) retribuye las funciones de fabricación que ejercen A y B, pero no engloba el valor de sus actividades respectivas de investigación y desarrollo que han propiciado un producto avanzado en términos tecnológicos. Por consiguiente, este resultado residual puede dividirse entre A y B, basándose para ello en su porcentaje en los costes totales de I+D ya que, a los efectos de este ejemplo,² puede presuponerse que los gastos relativos de I+D de las sociedades son un reflejo exacto de sus contribuciones relativas al valor de la innovación tecnológica del producto. Los gastos de I+D de A son 15 y los de B, 10, por lo que suman unos gastos combinados de I+D iguales a 25. El resultado residual es 6.5 del que puede imputarse 15/25 a A y 10/25 a B, lo

¹ Este rendimiento del 10% no se corresponde técnicamente con la aplicación de un margen incrementado sobre el coste en sentido estricto, ya que se trata de un beneficio neto y no de un beneficio bruto. Pero este rendimiento del 10% tampoco corresponde a un margen del método del margen neto del conjunto de operaciones en sentido estricto, ya que la base de los costes no incluye los gastos de explotación. El rendimiento neto sobre los costes de fabricación se utiliza como una primera fase cómoda y práctica del método de la distribución del resultado, porque simplifica la determinación del beneficio neto residual atribuible a los activos intangibles.

² Véase, no obstante, el párrafo 6.27 de las Directrices.

que genera un porcentaje de 3,9 y 2,6 respectivamente, como se muestra a continuación:

Porcentaje de A $6,5 \times 15/25 = 3,9$

Porcentaje de B $6,5 \times 10/25 = 2,6$

d) Nuevo cálculo de los beneficios

7. Los beneficios netos de A, por lo tanto, pasarían a ser $1,5 + 3,9 = 5,4$

Los beneficios netos de B pasarían a ser $2,0 + 2,6 = 4,6$

Las pérdidas y ganancias revisadas a efectos fiscales serían las siguientes:

	A	B
Ventas	55,4	100
Menos:		
Compras	(10)	(55,4)
Costes de fabricación	(15)	(20)
Beneficio bruto	30,4	(24,6)
Menos:		
I+D	15	10
Gastos de explotación	10 (25)	10 (20)
Beneficio neto	5,4	4,6

Nota

8. El ejemplo tiene como objeto ilustrar de forma sencilla los mecanismos de la distribución del resultado residual y no debe interpretarse como constitutivo de una orientación general sobre la forma en que se ha de aplicar el principio de plena competencia en la identificación de operaciones comparables y la determinación de una distribución adecuada. Es importante que los principios que este ejemplo trata de ilustrar se apliquen en cada caso teniendo en cuenta los hechos y circunstancias específicas. En particular, es preceptivo observar que la atribución del reparto residual puede necesitar en la práctica de una gran precisión para identificar y cuantificar la base apropiada para dicha distribución. Cuando se utilizan los gastos de investigación y desarrollo, puede ser necesario tener en cuenta, por ejemplo, las diferencias en los tipos de actividades de investigación y desarrollo realizadas, puesto que diferentes tipos de actividades de investigación y desarrollo pueden corresponder a diferentes niveles de riesgo y, en

consecuencia, a diferentes niveles en el rendimiento esperado en condiciones de plena competencia. Por otra parte, los niveles relativos de gastos corrientes de investigación y desarrollo pueden no reflejar tampoco adecuadamente la contribución a la obtención de los beneficios corrientes, que son atribuibles a activos intangibles desarrollados o adquiridos en el pasado.

Anexo III al Capítulo II

Ejemplo de las medidas del resultado cuando se aplica un método de la distribución del resultado

Véase el Capítulo II, parte III, sección C de estas Directrices, donde se ofrece una orientación general respecto de la aplicación del método de la distribución del resultado.

Las hipótesis relativas a los acuerdos de plena competencia que se utilizan en los ejemplos siguientes tienen un carácter meramente ilustrativo, por lo que no debe considerarse que obliguen a la realización de ajustes ni a la imposición de acuerdos de plena competencia en casos reales que atañen a sectores de actividad concretos. Si bien estos ejemplos pretenden ilustrar los principios enunciados en las secciones de las Directrices a las que se refieren, esos principios deben aplicarse en cada caso de acuerdo con los hechos y circunstancias concretos de cada uno de ellos.

Del mismo modo, los comentarios recogidos a continuación se refieren a la aplicación del método de la distribución del resultado en aquellos casos en los que teniendo en cuenta los hechos y circunstancias concretos, y en particular el análisis de comparabilidad (comprendido el análisis funcional) de la operación, y tras la revisión de la información disponible sobre operaciones comparables no vinculadas, se resuelva que este método es el más apropiado para el caso.

1. A continuación se muestran algunos ejemplos sobre el efecto resultante de la elección de una forma de medir los resultados para calcular los resultados conjuntos que vayan a repartirse cuando se aplica el método de distribución del resultado de la operación.

2. Supongamos que A y B son dos empresas asociadas situadas en dos jurisdicciones tributarias distintas. Ambas fabrican los mismos artículos e incurren en gastos que generan un activo intangible del que pueden beneficiarse conjuntamente. A los efectos de este ejemplo, se asume que la naturaleza de este activo concreto es tal que el valor de las contribuciones atribuidas a A y B en el año en cuestión son proporcionales a los gastos relativos de A y B en ese activo para ese año (conviene tener en cuenta que esta hipótesis no siempre será cierta en la práctica. Esto es así porque pueden darse casos en los que los valores relativos de las contribuciones al activo atribuibles a cada una de las partes se basen en los gastos acumulados en

años precedentes y en el año en curso.) Supongamos que A y B venden sus productos exclusivamente a terceras partes. Supongamos que se establece que el método más apropiado es el de a distribución del resultado residual; que las actividades de fabricación de A y de B son simples, y no operaciones únicas, a las que debe atribuirse un rendimiento inicial del 10% del coste de los bienes vendidos, y que el resultado residual debe repartirse en proporción a sus contribuciones respectivas al activo intangible. Las cifras que se muestran a continuación tienen únicamente valor ilustrativo:

	A	B	A+B combinadas
Ventas	100	300	400
Coste de los bienes vendidos	60	170	230
Beneficio bruto	40	130	170
Gastos generales	3	6	9
Otros gastos de explotación	2	4	6
Gasto en activos intangibles	30	40	70
Beneficio de explotación	5	80	85

3. Paso uno: determinación del rendimiento inicial correspondiente a las operaciones no únicas de fabricación (coste de los bienes vendidos + 10% en este ejemplo)

A	$60 + (60 * 10\%) = 66$	Rendimiento inicial por las operaciones de fabricación de A = 6
B	$170 + (170 * 10\%) = 187$	Rendimiento inicial por las operaciones de fabricación de B = 17
		Beneficio total atribuido en función de los rendimientos iniciales $(6 + 17) = 23$

4. Paso 2: determinación del resultado residual que va a distribuirse

a) En caso de que se determine como beneficio de explotación:

Beneficio de explotación combinado	85
Beneficio ya atribuido (rendimientos iniciales por las actividades de fabricación)	23
Resultado residual a cuya distribución se procede en proporción al gasto en activos intangibles efectuado por A y B	62

Resultado residual atribuido a A:	$62 * 30/70$	26,57
Resultado residual atribuido a B:	$62 * 40/70$	35,43
Total de beneficios atribuidos a A:	6 (rendimiento inicial) + 26,57 (residual)	32,57
Total de beneficios atribuidos a B:	17 (rendimiento inicial) + 35,43 (residual)	52,43
Total		85

b) En caso de que se determine como beneficio de explotación antes de gastos generales (suponiendo que se determine que los gastos generales de A y B no están vinculados a la operación examinada y que deben excluirse de la determinación de los resultados conjuntos objeto de distribución):

	A	B	A+B combinadas
Ventas	100	300	400
Coste de los bienes vendidos	60	170	230
Beneficio bruto	40	130	170
Otros gastos de explotación	2	4	6
Gasto en activos intangibles	30	40	70
Beneficios de explotación antes de costes generales	8	86	94
Gastos generales	3	6	9
Beneficio de explotación	5	80	85

Beneficio de explotación combinado antes de gastos generales	94
Beneficio ya atribuido (rendimientos iniciales por las actividades de fabricación)	23
Resultado residual antes de gastos generales a cuya distribución se procede en proporción al gasto en activos intangibles efectuado por A y B	71

Resultado residual atribuido a A:	$71 * 30/70$	30,43
Resultado residual atribuido a B:	$71 * 40/70$	40,57

Total de beneficios atribuidos a A:	6 (rendimiento inicial) + 30,43 (residual) - 3 (gastos generales)	33,43
Total de beneficios atribuidos a B:	17 (rendimiento inicial) + 35,43 (residual) - 6 (gastos generales)	51,57
Total		85

5. Como se muestra en el ejemplo anterior, al excluir ciertos elementos específicos de la determinación de los resultados conjuntos objeto de distribución, cada parte es responsable de sus propios gastos correspondientes. En consecuencia, la decisión de si excluir o no algunos elementos específicos debe ser coherente con el análisis de comparabilidad (incluido el análisis funcional) de la operación.

6. Otro ejemplo: en algunos casos puede ser apropiado prescindir de un cierto tipo de gastos en la medida en que la clave de atribución utilizada en el análisis de distribución del resultado residual se apoye en esos gastos. Por ejemplo, en aquellos casos en los que se establece que el factor de distribución del resultado más apropiado es el gasto relativo en que se incurre por la contribución al desarrollo de un activo intangible, los resultados residuales pueden basarse en los beneficios de explotación obtenidos antes de incurrir en ese gasto. Tras determinar la distribución del resultado residual, cada empresa asociada resta entonces sus propios gastos. Esto puede ilustrarse como sigue. Supongamos que los hechos son los mismos que en el ejemplo del párrafo 2 anterior y que los gastos generales no se excluyen de la determinación del resultado residual que va a distribuirse.

7. Paso uno: determinación del rendimiento básico por las actividades de fabricación (Coste de los bienes vendidos + 10% en este ejemplo)

El mismo método que en el párrafo 3.

8. Paso dos: determinación del resultado residual objeto de distribución

a) En caso de que se determine como el beneficio de explotación tras haber incurrido en el gasto asociado al activo intangible:

El mismo método que en el párrafo 4, caso a)

b) En caso de que se determine como beneficio de explotación previo al gasto relacionado con el activo intangible:

	A	B	A+B combinadas
Ventas	100	300	400
Coste de los bienes vendidos	60	170	230
Beneficio bruto	40	130	170
Gastos generales	3	6	9
Gasto en activos intangibles	30	40	70
Otros gastos de explotación	2	4	6
Beneficio de explotación gastos en activos intangibles	35	120	155
Gasto en activos intangibles	30	40	70
Beneficio de explotación	5	80	85

Beneficio de explotación combinado antes de gastos por razón del activo intangible	155
Beneficio ya atribuido (rendimientos iniciales por las actividades de fabricación)	23
Resultado residual antes de gastos incurridos por razón de activo intangible a cuya distribución se procede en proporción al gasto en activos intangibles efectuado por A y B	132

Resultado residual atribuido a A:	$132 * 30/70$	56,57
Resultado residual atribuido a B:	$132 * 40/70$	75,43

Total de beneficios atribuidos a A:	6 (rendimiento inicial) + 56,57 (residual) - 30 (gastos en activos intangibles)	32,57
Total de beneficios atribuidos a B:	17 (rendimiento inicial) + 75,43 (residual) - 40 (gastos en activos intangibles)	52,43
Total		85

Es decir, a A y B se les atribuye el mismo beneficio que en el caso en el que los beneficios objeto de distribución se determinaban como beneficio de explotación tras gastos vinculados al intangible, véase el caso a) más arriba.

9. Este ejemplo ilustra el hecho de que, cuando la clave de atribución utilizada en el reparto del resultado residual reside en una categoría de gastos incurridos durante el período comprendido, no existen diferencias entre la determinación del resultado residual objeto de distribución antes de que se haya incurrido en dichos gastos, procediendo después a su deducción por cada parte, y la determinación del resultado residual objeto de distribución tras haber incurrido en los mismos. No obstante, el resultado sí puede variar en caso de que el factor de reparto se base en el gasto acumulado durante el año precedente y el corriente (véase el párrafo 2 anterior).

Anexo al Capítulo III

Ejemplo de ajuste del capital circulante

Véase el Capítulo III, sección A.6 de estas Directrices, donde se ofrece una orientación general respecto de los ajustes en la comparabilidad.

Las hipótesis relativas a los acuerdos de plena competencia que se utilizan en los ejemplos siguientes tienen un carácter meramente ilustrativo, por lo que no debe considerarse que obliguen a la realización de ajustes ni a la imposición de acuerdos de plena competencia en casos reales o a sectores de actividad concretos. Si bien estos ejemplos pretenden ilustrar los principios enunciados en las secciones de las Directrices a las que se refieren, esos principios deben aplicarse en cada caso de acuerdo con los hechos y circunstancias concretos de cada uno de ellos.

Este ejemplo tiene carácter meramente ilustrativo y constituye un método, pero no necesariamente el único, para el cálculo del ajuste.

Del mismo modo, los comentarios recogidos a continuación se refieren a la aplicación de un método del margen neto operacional en aquellos casos en los que teniendo en cuenta los hechos y circunstancias concretos, y en particular el análisis de comparabilidad (comprendido el análisis funcional) de la operación, y tras la revisión de la información disponible sobre operaciones comparables no vinculadas, se resuelva que este método es el más apropiado para el caso.

Introducción

1. Este simple ejemplo muestra cómo proceder a un ajuste que permita subsanar las diferencias en los niveles de capital circulante entre la parte objeto de análisis (*TestCo*) y una sociedad comparable (*CompCo*). Véanse los párrafos 3.47 a 3.54 de estas Directrices, en los que se ofrecen unas pautas generales sobre los ajustes de comparabilidad. Los ajustes del capital circulante pueden resultar oportunos cuando se aplica el método del margen neto operacional y, en la práctica, suelen efectuarse cuando se aplica este método, aunque también pueden practicarse en los métodos del coste incrementado o del precio de reventa. Estos ajustes de capital circulante deben considerarse únicamente cuando su aplicación mejore los comparables

y siempre que puedan hacerse ajustes razonablemente precisos. Su aplicación no debe ser automática, como tampoco debe ser automática su aceptación por parte de las administraciones tributarias.

¿Por qué proceder a un ajuste del capital circulante?

2. En un entorno de competencia, el dinero tiene un valor temporal. Si, por ejemplo, una empresa fija una demora en el cobro de sus cuentas de 60 días, el precio de los bienes debe ser igual al precio en caso de pago inmediato más 60 días de intereses sobre ese precio. Al soportar un número elevado de cuentas pendientes de cobro, la empresa permite a sus clientes disponer de un plazo de pago relativamente largo. En ese caso, podrá necesitar pedir préstamos para financiar las condiciones de pago o sufrir una reducción en la cuantía de sus excedentes de tesorería del que, en otras circunstancias, hubiera dispuesto para invertir. En un entorno competitivo, el precio tiene que incluir por tanto un elemento que permita repercutir estas condiciones de pago y compensar el efecto que provoca la demora.

3. Lo contrario es aplicable en caso de mantener altos niveles de cuentas pendientes de pago. Si una empresa se beneficia de unas condiciones de pago que le permiten una demora en el pago a sus proveedores relativamente prolongada, podrá necesitar menos dinero pedido en préstamo para financiar sus adquisiciones o beneficiarse de un incremento en su excedente de tesorería que le permitirá invertir. En un entorno competitivo, el coste de los bienes vendidos tiene que incluir un elemento que refleje estas condiciones de pago y compensar el efecto que provoca la demora.

4. Una empresa que tenga un elevado nivel de existencias necesitará igualmente solicitar préstamos para financiar las adquisiciones o reducir el excedente de tesorería del que dispone para inversión. Téngase en cuenta que el tipo de interés puede verse afectado por la estructura de financiación (por ejemplo, cuando la adquisición de existencias se financia en parte mediante fondos propios) o por el riesgo que impliquen ciertos tipos de existencias.

5. Proceder a un ajuste del capital circulante es un intento de corregir las diferencias de valor del dinero en el tiempo entre la parte objeto de análisis y los posibles comparables, partiendo de la hipótesis de que esta diferencia debe reflejarse en los resultados. El razonamiento subyacente es el siguiente:

- Una sociedad necesitará financiación para cubrir el periodo de tiempo que media entre el momento en el que invierte dinero (es decir, paga al

proveedor) y el tiempo en que recupera el fruto de su inversión (es decir, cobra a sus clientes).

- Este lapso de tiempo se calcula como: el plazo necesario para vender las existencias a los clientes + (más) el plazo necesario para cobrar a los clientes – (menos) el tiempo acordado para el pago a proveedores.

6. Proceso de cálculo de los ajustes de capital circulante:

- a) Identificación de las diferencias en los niveles de capital circulante. En general, las cuentas por cobrar, las existencias y las cuentas por pagar son los tres aspectos considerados. El método del margen neto operacional se aplica en relación a una base de cálculo apropiada, por ejemplo los costes, ventas o activos (véase el párrafo 2.58 de las Directrices). Si la base adecuada son las ventas, por ejemplo, entonces las diferencias en los niveles de capital circulante deben valorarse en relación con las ventas.
- b) Cálculo del valor de las diferencias en los niveles de capital circulante entre la parte objeto de análisis y el comparable, utilizando una base adecuada y reflejando el valor temporal del dinero, recurriendo para ello a un tipo de interés apropiado.
- c) Ajuste del resultado a fin de subsanar las diferencias en los niveles de capital circulante. En el ejemplo siguiente se ajustan los resultados del comparable de forma que reflejen el nivel de capital circulante de la parte objeto de análisis. Los cálculos alternativos permiten ajustar los resultados de la parte objeto de análisis de forma que reflejen los niveles de capital circulante de la parte comparable o el ajuste de los resultados de ambas partes a fin de reflejar un capital circulante “cero”.

Ejemplo práctico de cálculo de ajustes en el capital circulante:

7. El cálculo que sigue es hipotético. Su única intención es la de demostrar cómo puede calcularse un ajuste de capital circulante.

TestCo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas	\$179,5m	\$182,5m	\$187m	195m	\$198m
Resultados antes de intereses e impuestos (EBIT)	\$1,5m	\$1,83m	\$2,43m	\$2,54m	\$1,78m
EBIT / Ventas (%)	0,8%	1%	1,3%	1,3%	0,9%
Capital circulante (al final del ejercicio)¹					
Cuentas por cobrar (CpC)	\$30m	\$32m	\$33m	\$35m	\$37m
Existencias (E)	\$36m	\$36m	\$38m	\$40m	\$45m
Cuentas por pagar (CpP)	\$20m	\$21m	\$26m	\$23m	\$24m
CpC + E – CpP	\$46m	\$47m	\$45m	\$52m	\$58m
CpC + E – CpP / Ventas	25,6%	25,8%	24,1%	26,7%	29,3%

CompCo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	\$120,4m	\$121,2m	\$121,8m	\$126,3m	\$130,2m
Resultados antes de intereses e impuestos (EBIT)	\$1,59m	\$3,59m	\$3,15m	\$4,18m	\$6,44m
EBIT / Ventas (%)	1,32%	2,96%	2,59%	3,31%	4,95%
Capital circulante (al final del ejercicio)¹					
Cuentas por cobrar (CpC)	\$17m	\$18m	\$20m	\$22m	\$23m
Existencias (E)	\$18m	\$20m	\$26m	\$24m	\$25m
Cuentas por pagar (CpP)	\$11m	\$13m	\$11m	\$15m	\$16m
CpC + E – CpP	\$24m	\$25m	\$35m	\$31m	\$32m
CpC + E – CpP / Ventas	19,9%	20,6%	28,7%	24,5%	24,6%

¹ Véanse los comentarios al párrafo 8

Ajuste de capital circulante	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
CpC + E – CpP / Ventas (de TestCo)	25,6%	25,8%	24,1%	26,7%	29,3%
CpC + E – CpP / Ventas (de CompCo)	19,9%	20,6%	28,7%	24,5%	24,6%
Diferencia (D)	5,7%	5,1%	-4,7%	2,1%	4,7%
Tipo de interés (i)	4,8%	5,4%	5,0%	5,5%	4,5%
Ajuste (D*i))	0,27%	0,28%	-0,23%	0,12%	0,21%
EBIT / Ventas de CompCo (%)	1,32%	2,96%	2,59%	3,31%	4,95%
Capital circulante ajustado EBIT / Ventas de CompCo	1,59%	3,24%	2,35%	3,43%	5,16%

8. Algunas observaciones:

- Una cuestión que se plantea al efectuar ajustes en el capital circulante es en qué momento concreto se comparan las cuentas por cobrar, las existencias y las cuentas pendientes de pago entre la parte objeto de análisis y sus comparables. En el ejemplo anterior se comparan los niveles o importes correspondientes al último día del ejercicio financiero. Sin embargo, la elección de este momento puede no resultar adecuada en caso de que el capital circulante en ese momento no sea representativo del capital circulante de ese ejercicio. En estos casos pueden utilizarse medias cuando estas permitan reflejar mejor el nivel de capital circulante del ejercicio.
- La selección del tipo o tipos de interés que vayan a utilizarse reviste una importancia decisiva a la hora de realizar ajustes en el capital circulante. Este tipo o tipos deben determinarse, en términos generales, por referencia al tipo o tipos de interés aplicables a una empresa comercial que opere en el mismo mercado que la parte objeto de análisis. En la mayoría de los casos lo apropiado será utilizar los tipos de interés de los préstamos comerciales. En los casos en los que el capital circulante de la parte objeto de análisis sea negativo (es decir, las cuentas por pagar > cuentas por cobrar + existencias), lo correcto será utilizar otro tipo. El tipo de interés utilizado en los ejemplos anteriores corresponde al tipo al que *TestCo* puede obtener fondos en su mercado local. En este ejemplo se asume asimismo que el mismo tipo de interés es apropiado respecto de las cuentas por pagar, por cobrar y de las existencias, lo que puede ser

o no cierto en la práctica. Cuando se observe que lo correcto es aplicar distintos tipos de interés a cada clase concreta de activos o pasivos, los cálculos pueden resultar considerablemente más complejos que los mostrados anteriormente.

- El objeto que se pretende con los ajustes del capital circulante es mejorar la fiabilidad de los comparables. Es preciso plantearse la licitud de los ajustes en el capital circulante cuando los resultados de ciertos comparables puedan ajustarse de forma fiable mientras que los de otros no.

Anexo al Capítulo IV:

líneas rectoras de los Acuerdos Previos de Valoración de Precios de Transferencia en el marco de los procedimientos amistosos (APV PA)

A. Contexto

A.1 Introducción

1. Los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia (APV) son objeto de un análisis exhaustivo en las *Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias*, concretamente en el Capítulo IV Sección F. En el párrafo 4.164 se analizan los acuerdos de trabajo entre autoridades competentes:

La uniformidad en las prácticas relativas a los APV entre los países que los utilizan podría ser beneficiosa tanto para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. En consecuencia, las administraciones tributarias de tales países podrían contemplar la conclusión de acuerdos de trabajo entre autoridades competentes referidos a los APV. Estos acuerdos podrían establecer las directrices generales y los conceptos básicos para alcanzar un acuerdo mutuo cuando el contribuyente haya solicitado un APV sobre precios de transferencia.

Debe señalarse que la utilización del término "acuerdo" en la cita anterior no tiene como objeto conceder a estos acuerdos procedimentales una categoría superior a la prevista en el artículo sobre Procedimiento Amistoso del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Además, el Comité de Asuntos Fiscales declaró en el párrafo 4.160 de las Directrices sobre precios de transferencia que pretende "un control exhaustivo sobre la aplicación extensiva de los APV y el fomento de una mayor coherencia en la práctica entre los países que los utilizan".

2. Este Anexo sigue las anteriores recomendaciones. El objetivo es mejorar la coherencia en la aplicación de los APV, orientando a las administraciones tributarias sobre la forma de gestionar los procedimientos amistosos que incluyan un APV. Aunque el Anexo se centre en el papel de las administraciones tributarias, también se analiza cómo el contribuyente puede contribuir mejor al proceso. Estas pautas están destinadas a su uso por parte de aquellos países -ya sean miembros o no de la OCDE- que deseen recurrir a los APV.

A.2 *Definición de un APV*

3. Desde hace cierto tiempo, en muchas jurisdicciones, existen procedimientos (por ejemplo, sistemas de resolución de consultas*) que permiten al contribuyente tener un cierto grado de certidumbre relativo al modo en que la ley se aplicará en un conjunto dado de circunstancias. Las consecuencias jurídicas de la acción propuesta quedan determinadas con carácter previo, basándose en hipótesis relativas a los hechos concretos del caso. La validez de esta resolución depende de que las hipótesis después coincidan con los hechos, una vez efectuada la operación real. La expresión “Acuerdos previos de valoración” se refiere a un acuerdo procedimental entre un contribuyente o unos contribuyentes y una administración tributaria cuyo objeto es resolver con antelación las controversias en materia de precios de transferencia. El APV difiere del procedimiento tradicional de evacuación de consultas en que es necesario proceder a un análisis detallado y, siempre que sea apropiado, a una verificación de la hipótesis sobre las que se basa la determinación de las consecuencias jurídicas de la operación, antes de poder emitir dicha resolución. Además, el APV permite un seguimiento continuo para saber si las hipótesis continúan siendo válidas en todo el período de vigencia de dicho acuerdo.

4. La primera frase del párrafo 4.123 de las Directrices sobre precios de transferencia define el APV como un “acuerdo que determina, con carácter previo a la ejecución de la operación vinculada, una serie de criterios oportunos (relativos, por ejemplo, al método de cálculo, los elementos de

* (N. de la T.) El término utilizado en la versión en inglés es “rulings”, del que debe entenderse que engloba todos los actos susceptibles de negociación entre el administrado y la administración con carácter previo al hecho imponible, así como la interpretación judicial o administrativa de ciertas disposiciones del Derecho, comprendidas la evacuación de consultas, y la emisión de cualquier otra resolución tras la realización del hecho imponible, que constituya doctrina (ruling system).

comparación, los ajustes pertinentes y las hipótesis críticas que redefinen su evolución) para la determinación de los precios de transferencia aplicados a estas operaciones, a lo largo de un cierto período". Asimismo, se establece en el párrafo 4.131 que "El concepto de APV puede resultar también útil en la resolución de las cuestiones que plantea el artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE sobre problemas de atribución, establecimientos permanentes y sucursales".

5. En las Directrices sobre Precios de Transferencia (véase el párrafo 4.129) los acuerdos concluidos únicamente entre uno o varios contribuyentes y una administración tributaria se denominan "APV unilaterales". Las Directrices sobre Precios de Transferencia promueven los APV bilaterales y recomiendan en el párrafo 4.162 que "en la medida de lo posible, un APV debería concluirse bilateral o multilateralmente entre autoridades competentes, por medio del procedimiento amistoso previsto en el convenio aplicable". Un APV bilateral se basa en un único acuerdo amistoso entre las autoridades competentes de dos administraciones tributarias en virtud del convenio correspondiente. "APV multilateral" es la expresión utilizada para describir una situación en la que existen varios acuerdos amistosos bilaterales.

6. Aunque en general los APV están referidos a operaciones transfronterizas en las que intervienen varios contribuyentes y entidades con personalidad jurídica, es decir, entre miembros de un grupo multinacional, también es posible que el APV se aplique sólo a un contribuyente y a una entidad con personalidad jurídica. Por ejemplo, considérese el caso de una empresa situada en un país A que efectúa operaciones a través de sus sucursales de los países B, C y D. Para estar totalmente seguros de que no se produzca doble imposición, será necesario que los países A, B, C y D se pongan de acuerdo sobre la cuantía de los beneficios que se ha de asignar a cada país en razón de esa actividad comercial en virtud del Artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. Para tener esta certidumbre, habría que negociar una serie de acuerdos amistosos bilaterales distintos, pero compatibles entre sí, entre A y B, A y C y A y D. La existencia de múltiples acuerdos amistosos bilaterales suscita varias cuestiones específicas, que se analizan más adelante en la Sección B, párrafos 21 a 27 de este Anexo.

7. Es importante distinguir entre los diversos tipos de APV y, en consecuencia, los APV bilaterales o multilaterales que constituyen el tema principal de este Anexo, a los que en lo sucesivo nos referiremos como "APV PA". Los APV que no implican la negociación de un acuerdo amistoso se denominan "APV unilaterales". Se utiliza la expresión genérica "APV" cuando la característica objeto de análisis se aplica a ambos tipos de

APV. Se ha de observar que en una amplia mayoría de casos se llegará a un APV bilateral en el marco de un procedimiento amistoso en virtud de un convenio de doble imposición. No obstante, en algunos casos, cuando se ha intentado llegar a un APV bilateral y el Convenio no constituía un marco apropiado o no resultaba aplicable, las autoridades competentes de determinados países han podido, a pesar de ello, lograr un acuerdo gracias al poder ejecutivo conferido a las más altas instancias de las administraciones tributarias. Debe interpretarse que la expresión APV PA, a reserva de las adaptaciones necesarias, incluye este tipo de acuerdos excepcionales.

8. El principal objetivo de este Anexo es orientar a las administraciones tributarias para que puedan resolver controversias gracias al procedimiento amistoso, contribuyendo así a eliminar el riesgo de una doble imposición potencial y ofreciendo al contribuyente un grado razonable de certidumbre respecto al tratamiento fiscal aplicable. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que existen otros mecanismos que permiten conseguir los mismos objetivos y que no se estudian en este Anexo.

A.3 *Objetivos del procedimiento de APV*

9. Varios países han tenido la experiencia de la resolución de controversias en materia de precios de transferencia mediante técnicas tradicionales de inspección o comprobación. Dicha experiencia ha resultado muy difícil y también costosa para los contribuyentes y las administraciones tributarias, tanto en términos de tiempo como de recursos. Estas técnicas llevan inevitablemente a examinar los precios de transferencia (y las condiciones en las que estos se fijan) cierto tiempo después de su determinación, por lo que pueden surgir verdaderas dificultades para obtener la información suficiente que permita evaluar adecuadamente si los precios utilizados eran conformes al principio de plena competencia en el momento en que se fijaron. Estas dificultades han contribuido en parte a desarrollar el proceso de APV como una forma alternativa de resolución de las cuestiones planteadas en algunos casos de precios de transferencia, a fin de evitar parcialmente los problemas anteriormente descritos. Los objetivos de un APV son: posibilitar unas negociaciones bien fundamentadas, prácticas y cooperativas; resolver temas de precios de transferencia de forma rápida y prospectiva; utilizar los recursos del contribuyente y de la administración tributaria más eficientemente, y permitir al contribuyente prever el régimen que le será aplicable.

10. Para que el proceso llegue a buen fin, no debe gestionarse en forma de confrontación sino de modo práctico y eficiente, y requiere de la cooperación de todas las partes intervinientes. Su objetivo es el de

complementar, y no sustituir, los mecanismos administrativos y judiciales tradicionales, así como los previstos en los convenios, para resolver los problemas de precios de transferencia. Recurrir a un APV puede ser lo más apropiado cuando la metodología de aplicación del principio de plena competencia plantea problemas significativos respecto a su fiabilidad y precisión, o cuando las circunstancias específicas que rodean las cuestiones de precios de transferencia estudiadas son excepcionalmente complejas.

11. Unos de los objetivos clave del proceso APV PA es la eliminación de la doble imposición potencial. Los APV unilaterales son fuente de gran preocupación en este sentido, lo cual explica por qué "la mayor parte de los países prefiere los APV bilaterales o multilaterales" (párrafo 4.130 de las Directrices). Sin embargo, es necesaria alguna clase de confirmación o de acuerdo entre el contribuyente y la administración tributaria con el fin de aplicar el APV PA en cada una de las jurisdicciones implicadas. La forma exacta de tal confirmación o acuerdo depende de los procedimientos nacionales de cada jurisdicción (analizados con más detalle en los párrafos 65-66 de este anexo). Tal confirmación o acuerdo también ofrece un mecanismo que garantiza que el contribuyente cumple con las cláusulas y requisitos del APV PA al que se refiere dicha confirmación o acuerdo.

12. Además, con objeto de alcanzar los fines descritos en esta Sección, el proceso APV PA debe conducirse de forma neutral. En particular, el proceso debe ser imparcial en relación con la residencia del contribuyente, la jurisdicción en la que se inició la solicitud de APV PA, la situación del contribuyente respecto a las inspecciones o comprobaciones efectuadas y la selección de los contribuyentes en general que deben someterse a una auditoría o inspección. También deben tenerse en cuenta las orientaciones expuestas en el párrafo 4.156 de las Directrices respecto al posible mal uso de la información obtenida en el curso de un procedimiento de APV por parte de las administraciones tributarias en su actividad inspectora. Las orientaciones recogidas en este anexo pretenden contribuir a alcanzar los objetivos descritos en esta Sección.

B. Posibilidad de acceso a un APV PA

B.1 Cuestiones relativas a los convenios

13. La primera cuestión que se plantea es si es posible llevar a cabo un APV. Para juzgar la posibilidad de acceso de un contribuyente a un APV unilateral se aplicarán los requisitos nacionales específicos de la administración tributaria pertinente. Los APV PA se rigen por el

procedimiento amistoso del convenio de doble imposición aplicable (artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE) y el recurso a este procedimiento es discrecional por parte de las administraciones tributarias a las que afecte.

14. En algunos casos el contribuyente solicitará sólo un APV unilateral. Cuando esto ocurra deben investigarse las razones por las que el contribuyente no solicita un APV PA. De acuerdo con las orientaciones dadas en el párrafo 4.162 de las Directrices “en la medida de lo posible un APV debe concluirse bilateral o multilateralmente”, las autoridades fiscales deben animar al contribuyente a que solicite un APV PA si las circunstancias lo requieren. Algunos países pueden negarse a iniciar conversaciones unilaterales con el contribuyente, incluso si este último insiste en que se siga ese procedimiento, cuando consideren que debería participar otra administración tributaria.

15. La negociación de un APV PA requiere del consentimiento de las autoridades competentes. En algunos casos, el contribuyente puede tomar la iniciativa presentando simultáneamente su solicitud ante las autoridades competentes afectadas; en otros, puede presentar su solicitud en una jurisdicción en virtud del correspondiente procedimiento nacional, y pedir a esta que contacte con la otra u otras jurisdicciones afectadas para ver si es posible el APV PA. En consecuencia, en cuanto sea posible desde el punto de vista administrativo, la autoridad competente de esa jurisdicción debe proceder a notificar al co-signatario o co-signatarios de los convenios a los que corresponda para saber si desean participar. La otra administración tributaria debe responder a la invitación tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta la necesidad de disponer del tiempo suficiente para evaluar si su participación es posible o factible.

16. Sin embargo, el artículo 25 no obliga a las autoridades competentes a participar en un APV PA instado por el contribuyente. La voluntad de participar en este procedimiento dependerá de la política específica del país en cuestión y de su interpretación del artículo relativo al procedimiento amistoso que contengan sus convenios bilaterales. Algunas autoridades competentes sólo admitirán iniciar un tal acuerdo en los casos en que sea necesario “resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación del convenio”. El deseo del contribuyente de contar con certeza en cuanto al tratamiento que se le aplique no es suficiente en sí mismo para satisfacer los requisitos expuestos. Otras autoridades competentes aplican un umbral menos restrictivo para participar en un APV PA, ya que consideran que debe fomentarse el uso de este procedimiento. Además, el contribuyente debe cumplir con ciertos requisitos para beneficiarse de un determinado convenio (por ejemplo, poder ser

considerado residente de uno de los Estados contratantes) y debe satisfacer los demás criterios contenidos en el artículo relativo al procedimiento amistoso.

B.2 Otros factores

17. El hecho de que un contribuyente pueda ser objeto de inspección o comprobación no debería impedirle solicitar un APV PA concerniente a operaciones futuras. La inspección o comprobación y el procedimiento amistoso son procesos distintos que pueden resolverse de forma independiente. Las administraciones tributarias, por lo general, no interrumpen las actividades de inspección o comprobación durante la tramitación de un APV PA, a menos que todas las partes convengan en la procedencia de la interrupción debido al hecho de que el posible acuerdo alcanzado en el marco del APV PA puede facilitar la conclusión de la inspección o comprobación. No obstante, el tratamiento de las operaciones objeto de inspección o comprobación puede estar imbuido de la metodología que se acuerde aplicar en el futuro en virtud del APV PA, siempre que los hechos y circunstancias que rodean la operación sometida a inspección o comprobación sean comparables a los de las operaciones futuras. Esta cuestión se analiza más adelante, en el párrafo 69.

18. La posibilidad de concluir un APV PA se fundamenta en una total cooperación del contribuyente. Tanto el contribuyente como todas las empresas asociadas, deben: a) cooperar plenamente con las administraciones tributarias en la evaluación de su propuesta; y b) facilitar previa solicitud, toda la información necesaria para esta evaluación, por ejemplo, los detalles de sus operaciones a las que se apliquen los precios de transferencia, sus acuerdos comerciales, sus previsiones y planes de negocio, así como sus resultados financieros. Es deseable lograr este compromiso del contribuyente antes de iniciar el APV PA.

19. En ciertos casos, la libertad de que disponen ambas autoridades competentes, o una de ellas, para llegar a un APV PA puede estar limitada, por ejemplo, por una decisión jurídicamente vinculante relativa a las cuestiones que pueden ser objeto de propuestas de APV. En tales circunstancias, dado que el APV PA es, por definición, un proceso consensuado, compete a las autoridades competentes afectadas (a reserva de las legislaciones y políticas nacionales de cada una de las jurisdicciones) decidir si iniciar o no las conversaciones conducentes a un APV PA. Por ejemplo, una autoridad competente puede negarse a iniciar unas conversaciones si decide que tal limitación de la posición de la otra autoridad competente reduce de forma inaceptable la posibilidad de un acuerdo

amistoso. No obstante, es posible que en muchos casos las conversaciones referentes a un APV PA puedan considerarse deseables aun cuando el margen de maniobra de una o de ambas autoridades competentes esté limitado. Esta cuestión deben determinarla caso por caso las autoridades competentes.

20. Al decidir sobre la pertinencia de un APV PA, uno de los puntos esenciales que se ha de analizar es saber en qué medida es ventajoso acordar un método que evite anticipadamente el riesgo de doble imposición. Esto requiere un juicio de valor y obliga a equilibrar el uso eficiente de los recursos limitados tanto financieros como humanos, con el deseo de reducir la posibilidad de una doble imposición. Las administraciones tributarias podrían considerar relevante contestar a las siguientes preguntas:

- a) ¿Respetan la metodología y las demás cláusulas y condiciones de la propuesta las orientaciones dadas por las Directrices? De no ser así, será deseable conseguir que el contribuyente revise la propuesta con el fin de aumentar las posibilidades de alcanzar un acuerdo amistoso. Como establece el párrafo 17 de la Introducción de las Directrices “Estas Directrices también pretenden, en primer lugar, regir la resolución de los casos de precios de transferencia planteados en el marco de procedimientos amistosos”.
- b) ¿Existen “algunas dificultades o dudas en relación con la interpretación o aplicación del Convenio” que aumenten significativamente el riesgo de doble imposición y justifiquen la utilización de recursos para solucionar los problemas antes de que se efectúen las operaciones propuestas?
- c) ¿Serían de naturaleza continua las operaciones cubiertas por la propuesta? ¿Queda excluida alguna parte importe de un proyecto de duración limitada?
- d) ¿Se analizan seriamente las operaciones en cuestión o tienen un carácter puramente hipotético? Este procedimiento no debería servir para conocer el eventual punto de vista de la administración tributaria como principio general. En numerosos países, existen otros métodos bien arraigados para alcanzar este propósito.
- e) ¿Se están inspeccionando los precios de transferencia de ejercicios anteriores en los que el modelo fáctico era sustancialmente similar? Si así fuera, la inspección podría concluirse más rápidamente participando en un APV PA, cuyos términos podrían aplicarse para informar o resolver la inspección y cualquier procedimiento amistoso no resuelto en los años anteriores.

B.3 APV PA *multilateral*

21. El deseo de certidumbre se traduce en la tendencia creciente de los contribuyentes a intentar llegar a APV PA multilaterales que abarquen sus operaciones a nivel mundial. El contribuyente dirige a cada una de las jurisdicciones a las que concierne una propuesta global y sugiere la conveniencia de que las negociaciones se lleven a cabo sobre una base multilateral en la que intervengan todas las jurisdicciones afectadas y no como una serie de negociaciones independientes con cada autoridad tributaria. Debe tenerse en cuenta que no existe un método multilateral para aplicar el acuerdo al que pueda llegarse, excepto concluyendo una serie de APV PA bilaterales independientes. El éxito en la negociación de una serie de APV PA bilaterales concluidos de este modo aportaría mayor certidumbre y supondría menores costes para el grupo multinacional que si los APV PA se negociaran bilateral e independientemente los unos de los otros.

22. Aunque como se ha dicho anteriormente, concertar APV PA multilaterales puede ofrecer ventajas potenciales, es necesario considerar varias cuestiones. En primer lugar, es poco probable que se aplique una única metodología para determinar los precios de transferencia cuando concurren una amplia gama de hechos y circunstancias, de operaciones y de países susceptibles de estar sujetos al APV PA multilateral, a menos que esta pueda adaptarse adecuadamente con el fin de reflejar los hechos y circunstancias concretos de cada país. Por lo tanto, las jurisdicciones participantes deberán garantizar que la metodología, incluso una vez adaptada, constituye una aplicación adecuada del principio de plena competencia en función de las condiciones que concurren en su país.

23. En segundo lugar, también se plantean problemas porque, en el marco de un APV PA multilateral, son varias las autoridades competentes afectadas por un procedimiento concebido en principio para ser bilateral. Uno de los problemas suscitados es saber en qué medida podría ser necesario un intercambio de información entre las jurisdicciones afectadas. Esto podría resultar problemático en los casos en que no existieran flujos de información u operaciones comunes entre dos o más socios de un convenio, generando así dudas sobre la relevancia de la información a los efectos del APV PA bilateral objeto de estudio. Sin embargo, en los casos en los que partes distintas de la multinacional realicen operaciones similares, o en los que el campo considerado se refiera al comercio efectuado sobre una base consolidada, puede ser necesario tener información sobre los flujos entre las demás partes con el fin de poder comprender y evaluar aquellos que constituyen el objeto del APV PA bilateral concreto. Otro problema estriba

en que puede ser difícil juzgar si tal información es realmente relevante antes de conseguirla.

24. Además, incluso si dicha información es relevante para el APV PA bilateral en cuestión aún pueden darse problemas de confidencialidad que impidan el intercambio de la información, ya sea en virtud de los términos del artículo o artículos sobre intercambio de información del convenio aplicable, o en virtud de la normativa interna de una de las administraciones tributarias participantes. Dada la amplia gama de circunstancias posibles que pueden darse en los APV PA multilaterales, no puede ofrecerse una solución general para todos ellos. Por el contrario, deben abordarse específicamente en cada uno de los APV PA bilaterales.

25. En los casos en que se estime oportuno disponer de información sobre los flujos entre otras partes, es probable que puedan solventarse algunos de los problemas de intercambio de información que puedan plantearse pidiendo al contribuyente que asuma la responsabilidad de aportar la información a todas las administraciones tributarias implicadas (aunque se necesiten procedimientos para verificar que se ofrece la misma información a todas ellas) en vez de sobre la base de lo dispuesto en los convenios en relación con estos intercambios. Finalmente, pueden darse casos en los que los artículos relativos al procedimiento amistoso de los convenios pertinentes no constituyan una base adecuada para el análisis y el debate multilateral, aun cuando el artículo referente al procedimiento amistoso del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE está pensado para contribuir a eliminar la doble imposición en una amplia gama de circunstancias y, por ello, cuando proceda su aplicación, puede tener carácter autoritativo en la mayoría de los casos.

26. En resumen, como se analizó en la Sección A, el deseo de certidumbre del contribuyente no es suficiente por sí mismo para obligar a una administración tributaria a concertar un APV PA cuando dicho acuerdo pudiera resultar inapropiado. La invitación a participar en un APV PA multilateral debe pues evaluarse de acuerdo con los criterios usuales para determinar si puede aplicarse un APV PA bilateral, debiendo evaluar también de forma independiente cada propuesta de APV bilateral. Posteriormente se decidirá si la mejor forma de llevar a cabo el APV PA que la administración haya decidido acometer es participando en las negociaciones multilaterales. Este análisis debe realizarse caso por caso.

27. El desarrollo de APV PA multilaterales se halla en una fase relativamente temprana excepto tal vez en el ámbito de las operaciones con productos financieros en el mercado mundial. De hecho, cuando estas se realizan de forma plenamente integrada (es decir, las operaciones y la gestión

del riesgo de una cartera de productos financieros se lleva a cabo desde una serie de emplazamientos distintos, habitualmente al menos tres), los APV multilaterales se han convertido en la norma general en detrimento de los bilaterales.¹ Está previsto llevar a cabo un estrecho seguimiento de la evolución ulterior en el ámbito de los APV PA multilaterales.

C. Solicitudes de APV PA

C.1 Introducción

28. Aunque un APV PA, por su propia naturaleza, implica el acuerdo entre administraciones tributarias, para que el proceso llegue a buen fin es necesario que el contribuyente o contribuyentes participen activamente. En esta Sección se examinan las primeras etapas de este proceso, a saber, la solicitud de inicio de un APV PA que normalmente instan los contribuyentes. (N.B. Algunas administraciones tributarias consideran que son ellos quienes deben tener la iniciativa y animan de forma activa a los contribuyentes para que formulen solicitudes en los casos pertinentes, por ejemplo después de una inspección o un análisis de valoración de riesgos). Una vez que se ha decidido la idoneidad del inicio del APV PA es inevitable que recaiga sobre los contribuyentes la responsabilidad inicial de aportar suficiente información a las administraciones participantes para que estas puedan llevar a cabo las negociaciones del procedimiento amistoso. En consecuencia, el contribuyente debe presentar una propuesta detallada para su análisis por parte de la administración tributaria correspondiente y estar preparado para aportar más información si esta fuese requerida por la administración tributaria.

C.2 Deliberaciones preliminares

29. Un rasgo característico de muchos procedimientos nacionales para la obtención de un APV unilateral es la posibilidad de tener una o varias reuniones preliminares antes de que se formule la petición formal. Estas reuniones ofrecen al contribuyente la posibilidad de discutir con la administración tributaria la pertinencia de un APV, la clase e importancia de la información que puede requerirse y el alcance de los análisis necesarios

¹ Para más detalles consúltese el Documento de la OCDE (1998): *The Taxation of Global Trading of Financial Instruments* (La Fiscalidad de las operaciones en el mercado mundial de productos financieros), OCDE, París.

para llevarlo a buen fin (por ejemplo: la magnitud de los análisis funcionales de las empresas filiales; la identificación, selección y ajuste de las operaciones comparables; y la necesidad de proceder a análisis de mercado sectoriales y geográficos, y su alcance). El proceso también ofrece al contribuyente la posibilidad de discutir cualquier problema relativo a la comunicación y la confidencialidad de la información, la duración del APV, o similares. La experiencia ha demostrado que, en general, la posibilidad de proceder a estas discusiones preliminares agiliza el procedimiento de solicitud formal ulterior para el inicio de los APV PA.

30. En el marco de un APV PA, también puede ser útil que las autoridades competentes tengan capacidad para mantener conversaciones previas con el contribuyente. Además de los puntos mencionados anteriormente, en su transcurso cabría analizar si las circunstancias son favorables para un APV PA, por ejemplo, si existen bastantes “dificultades o dudas en cuanto a la interpretación o aplicación del convenio”.

31. La reunión preliminar puede jugar un papel importante en la clarificación de las expectativas y objetivos del contribuyente y de la administración tributaria. También ofrece la oportunidad de explicar el proceso, la política de la administración tributaria respecto a los APV PA, y de aportar detalles sobre los procedimientos necesarios en el marco de la legislación interna para dar vigencia al acuerdo alcanzado. Al mismo tiempo, la administración tributaria podría ofrecer alguna indicación sobre el contenido de la propuesta, así como de los plazos previstos para la evaluación o la firma del acuerdo amistoso. Las administraciones tributarias deberían publicar orientaciones de orden general sobre el procedimiento seguido por los APV PA de acuerdo con las recomendaciones dictadas para otras clases de acuerdos amistosos en los párrafos 4.60 y 4.61 de las Directrices.

32. La reunión preliminar puede plantearse de forma anónima o identificando a los participantes según los usos y costumbres nacionales. Sin embargo, si la reunión se produce en condiciones de anonimato, se exigirá la aportación de información suficiente sobre las operaciones para que la discusión resulte de interés. El carácter de la reunión se acordará entre las partes, pudiendo ser desde una charla informal a una presentación en toda regla. En general, al propio contribuyente le interesa presentar un memorándum en el que se esbocen las cuestiones objeto de análisis. Puede ser necesaria más de una reunión preliminar para alcanzar el objetivo de celebrar una discusión informal sobre la conveniencia potencial de solicitar un APV PA, su ámbito, la adecuación de una metodología o la clase e importancia de la información que ha de facilitar el contribuyente.

33. Además de las discusiones informales con el contribuyente, un intercambio de puntos de vista previo entre autoridades competentes sobre la idoneidad del APV PA puede resultar también útil. Con ello puede evitarse un trabajo innecesario, si es poco probable que una de las autoridades competentes participe. Estas conversaciones pueden ser de naturaleza informal y no requieren necesariamente una reunión formal presencial. Asimismo, pueden existir ocasiones para tales intercambios de puntos de vista en el transcurso de las reuniones y negociaciones periódicas entre autoridades competentes.

C.3 *Propuestas de APV PA*

C.3.1 Introducción

34. Si el contribuyente desea solicitar el inicio de un APV PA, deberá someter una propuesta detallada a la administración tributaria competente conforme a las reglas de procedimiento vigentes en su jurisdicción: por ejemplo, el contribuyente puede estar obligado a presentar la solicitud ante un órgano determinado de su administración tributaria. En el caso de un APV PA, el objeto de la propuesta del contribuyente es proporcionar a las autoridades competentes toda la información necesaria para evaluar la solicitud e iniciar las discusiones relativas al procedimiento amistoso. Los países disponen de métodos diversos para asegurarse de que las autoridades competentes obtengan la información necesaria. Uno de ellos es que el contribuyente pueda plantear directamente su propuesta a la autoridad competente. Otra forma de lograr dicho objetivo es que el contribuyente entregue una copia de la solicitud de inicio presentada en su país ante las otras jurisdicciones intervinientes. Lo ideal sería que la forma y el contenido exactos de la propuesta se hubieran fijado en una reunión preliminar.

C.3.2 Actividades habitualmente comprendidas en un APV PA

35. El ámbito de aplicación del APV PA dependerá de los deseos de las jurisdicciones participantes y del contribuyente. Puede aplicarse para resolver los problemas que surjan en relación con los artículos 7 y 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE y determinar la cuantía de los beneficios generados en las jurisdicciones fiscales intervinientes.

36. El APV PA puede abarcar todas las cuestiones relativas a los precios de transferencia de un contribuyente (o de los miembros de un grupo multinacional) o puede tener un ámbito más restringido, aplicándose por ejemplo a una operación determinada, a un cierto grupo de operaciones, a

líneas de productos o sólo a algunos miembros del grupo multinacional. Si bien algunos países reconocen la necesidad de que el proceso sea flexible, están preocupados por la pertinencia de ciertos APV. Puede ser difícil evaluar por separado algunas cuestiones, por ejemplo cuando las operaciones cubiertas por la propuesta están estrechamente vinculadas con operaciones no cubiertas por ella, o cuando es necesario analizar las cuestiones de precios de transferencia en un contexto más amplio, debido a la existencia de compensaciones intencionadas (véanse los párrafos 3.13 a 3.17 de las Directrices).

37. Un APV PA puede abarcar también cuestiones distintas a la metodología de determinación de precios de transferencia, siempre que su relación con las cuestiones subyacentes de precios de transferencia sea lo suficientemente clara como para que valga la pena resolverlas con antelación y que estén en consonancia con los términos del artículo relativo al procedimiento amistoso del convenio aplicable. Esto lo deberán decidir las partes afectadas en cada caso específico.

C.3.3 Contenido de una propuesta de APV PA.

38. El contenido de la propuesta y la importancia de la información y documentación que debe adjuntarse dependerán de los hechos y circunstancias de cada caso y de los requisitos exigidos por cada una de las administraciones tributarias que en él participen. Parece pues poco factible enumerar o definir exactamente lo que debería aportarse. No obstante, el principio rector debe ser el de aportar la información y documentación necesarias para explicar los hechos relevantes de la metodología propuesta y para demostrar su aplicación de acuerdo con los artículos pertinentes del convenio en cuestión. La propuesta, pues, debe ser coherente con cualquier indicación general ofrecida en los comentarios a los artículos correspondientes del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, así como con las orientaciones sobre la aplicación del principio de plena competencia del artículo 9 que ofrecen las Directrices en los casos que entrañan precios de transferencia entre empresas asociadas.

39. Por lo que respecta a la información y documentos que deben incluirse deben tenerse en cuenta las directrices expuestas en los Capítulos IV (párrafos 4.154 a 4.157) y V de las Directrices sobre Precios de Transferencia. Sin embargo, debido a la naturaleza prospectiva del acuerdo buscado, es posible que la clase de información que ha de aportarse no sea la misma que la necesaria en los procedimientos amistosos, que sólo se refieren a operaciones ya realizadas. La información que se cita a continuación a

modo de guía puede ser de importancia general para los APV PA, aunque debe insistirse en que esta lista no es exhaustiva ni normativa:

- a) las operaciones, productos, actividades económicas o acuerdos a los que se refiera la propuesta (incluyendo, en su caso, una explicación sucinta de los motivos por los que no se ha incluido la totalidad de las operaciones, productos, actividades económicas o acuerdos del contribuyente o contribuyentes que han realizado la solicitud);
- b) las empresas y establecimientos permanentes que intervienen en estas operaciones o acuerdos;
- c) el otro país o los demás países a los que se ha solicitado su participación;
- d) la información relativa a la estructura organizativa a nivel mundial, los datos históricos, los estados financieros, los productos, las funciones y activos (tangibles e intangibles) de las empresas asociadas participantes;
- e) una descripción de la metodología de determinación de precios de transferencia propuesta, así como información detallada y los análisis que sustenten su aplicación, por ejemplo, la identificación de precios o márgenes comparables y el rango de resultados esperados, etc.;
- f) las hipótesis en las que se basa la propuesta y una discusión de las consecuencias de los cambios en dichas hipótesis o de otros acontecimientos, tales como resultados imprevistos que puedan afectar a la validez de la propuesta;
- g) los períodos contables o los años fiscales que han de considerarse;
- h) una descripción general de las condiciones del mercado (por ejemplo, las tendencias del sector y el entorno de competencia);
- i) un análisis de otros aspectos fiscales colaterales que plantee la metodología propuesta;
- j) el análisis de la legislación nacional aplicable y la demostración del cumplimiento con esta y con las disposiciones de los convenios fiscales y directrices de la OCDE que tengan relación con la propuesta; y
- k) cualquier otra información que pudiera afectar a la metodología actual o propuesta para la determinación de los precios de transferencia, así como los datos subyacentes de toda parte interviniente en la solicitud.

El resto de esta Sección analiza con más detalle algunos de los puntos más importantes de la lista anterior.

C.3.4 Información sobre precios comparables

40. El contribuyente debe incluir un análisis sobre la disponibilidad y utilización de información sobre precios comparables. Esto incluye una descripción de cómo se ha procedido a la búsqueda de comparables (comprendidos los criterios de búsqueda), qué datos referidos a operaciones no vinculadas se han obtenido y sobre su aceptación o rechazo como comparables. Asimismo, debe presentar las operaciones comparables y los ajustes efectuados para salvar las diferencias importantes, en el caso de que existan, entre las operaciones vinculadas y no vinculadas. En los casos en que no puedan identificarse operaciones comparables, el contribuyente debe demostrar, basándose en los mercados y en los datos financieros pertinentes (incluyendo los datos internos del contribuyente) por qué la metodología escogida refleja fielmente el principio de plena competencia.

C.3.5 Metodología

41. La solicitud de inicio del APV PA debe contener una descripción completa de la metodología seleccionada. En los casos en que intervengan empresas asociadas, esta metodología debe respetar las indicaciones contenidas en las Directrices sobre precios de transferencia respecto de la aplicación del principio de plena competencia del artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. El párrafo 2.10 de las Directrices dicta lo siguiente: “debe permitirse la aplicación de cualquier método siempre que resulte correcto a juicio de todos los miembros del grupo multinacional que intervienen en la operación u operaciones a las que vaya a aplicarse esa metodología, así como a las administraciones tributarias correspondientes a esos miembros del grupo multinacional.” Esta directriz sobre el uso de los métodos de determinación de los precios de transferencia es particularmente relevante en el contexto de un APV PA por la oportunidad de alcanzar un acuerdo previo sobre el método que se ha de usar. La aplicación de la metodología debería apoyarse en datos que puedan obtenerse y actualizarse durante la vigencia del APV PA sin que su obtención suponga una carga demasiado pesada para el contribuyente, y cuya revisión y comprobación eficaz esté garantizada para las administraciones tributarias.

42. El contribuyente debe, en la medida de lo posible, aportar un análisis de los efectos de la aplicación de la metodología o metodologías seleccionadas durante el periodo de vigencia del acuerdo que se solicita. Este análisis debe basarse necesariamente en la previsión de resultados, por lo que es necesario conocer detalles sobre las hipótesis en las que tales previsiones se basan. También puede ser útil ilustrar el efecto de la aplicación de la metodología o metodologías del APV a los períodos inmediatamente

anteriores al de su vigencia. La utilidad de este análisis, incluso a modo ilustrativo, dependerá de la comparabilidad de los hechos y circunstancias que rodean las operaciones en cuestión con la de las operaciones futuras consideradas en la propuesta.

C.3.6 Hipótesis críticas

43. Al iniciar un APV PA relativo a la determinación de precios de plena competencia de operaciones que aún no se han llevado a cabo, es necesario teorizar sobre las condiciones operativas y económicas que las afectarán cuando se efectúen. El contribuyente debe describir en la propuesta las hipótesis sobre las que se basa para afirmar que el método considerado permite fijar los precios de las operaciones futuras de acuerdo con el principio de plena competencia. Además, el contribuyente debe explicar la posibilidad de adaptación de la metodología seleccionada a cualquier modificación de las hipótesis. Las hipótesis se califican de “críticas” si las condiciones reales en el momento en que se llevan a cabo las operaciones pueden divergir de las supuestas hasta el punto de menguar la capacidad de la metodología para reflejar de forma fiable la determinación de precios de plena competencia. Podría ofrecerse como ejemplo una variación fundamental del mercado causada por una nueva tecnología, nueva normativa o una pérdida generalizada de aceptación por los consumidores. En tal caso, la divergencia puede implicar la revisión o cancelación del acuerdo.

44. Para aumentar la fiabilidad de la metodología de un APV PA, los contribuyentes y las administraciones tributarias deben intentar definir las hipótesis críticas basándolas, cuando sea posible, en datos observables, fiables e independientes. Tales hipótesis no se limitan a los aspectos controlados por el contribuyente. Todo conjunto de hipótesis críticas tiene que adaptarse a las circunstancias particulares del contribuyente, al contexto comercial específico, a la metodología y al tipo de operaciones cubiertas. No deben establecerse de forma tan restrictiva como para poner en peligro la seguridad que garantiza el acuerdo; por el contrario, deben englobar un rango de variaciones en las condiciones subyacentes lo suficientemente amplio como para que las partes que intervienen en el acuerdo se sientan cómodas. En general, y únicamente a modo de ejemplo, cabría enumerar las siguientes hipótesis críticas:

- a) hipótesis relativas a la legislación tributaria nacional y a las disposiciones de los convenios;

- b) hipótesis relativas a aranceles, derechos de aduanas, restricciones a la importación y regulaciones gubernamentales;
- c) hipótesis sobre las condiciones económicas, la cuota de mercado, las condiciones de mercado, el precio de venta final y el volumen de venta;
- d) hipótesis sobre la naturaleza de las funciones efectuadas y de los riesgos incurridos por las empresas que participan en las operaciones;
- e) hipótesis sobre los tipos de cambio, los tipos de interés, la calificación crediticia y la estructura de capital;
- f) hipótesis referentes a la administración o a la contabilidad financieras y a la clasificación de los ingresos y gastos;
- g) hipótesis relativas a las empresas que operarán en cada jurisdicción y sobre la forma en que lo harán.

45. También puede ser útil fijar unos parámetros que permitan determinar con antelación el nivel aceptable de divergencia para ciertas hipótesis con el fin de dotarlas de la flexibilidad necesaria. Dichos parámetros deben fijarse individualmente para cada uno de los APV PA y formar parte de las negociaciones entre autoridades competentes. Sólo si la divergencia respecto de las previsiones excediera del parámetro determinado, la hipótesis pasaría a ser “crítica”, y habría que considerar llevar a cabo alguna actuación. Estas actuaciones dependerán también de la naturaleza de la hipótesis y del nivel de divergencia.

46. Si se sabe que la fiabilidad del método de determinación de precios propuesto es sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio, lo razonable sería diseñar una metodología capaz de aceptar un cierto nivel de fluctuación, previendo tal vez un ajuste de los precios que permita soslayar las fluctuaciones. También podría acordarse con anticipación que las variaciones en cualquier sentido de hasta un X % no necesitarán de actuación alguna; que las variaciones comprendidas entre X % e Y % propiciarán una revisión prospectiva de la metodología para asegurarse de que sigue siendo apropiada; mientras que una variación superior a Y % significaría que se incumple una hipótesis crítica y que es necesario renegociar el APV PA. Estos parámetros deberán fijarse para cada APV PA concreto y deben ser objeto de negociación entre las autoridades competentes.

C.3.7 Resultados imprevistos

47. Puede plantearse un problema cuando los resultados de la aplicación de los métodos de determinación de precios de transferencia

convenidos en el APV PA no satisfacen las expectativas de una de las partes, pudiendo dicha parte cuestionarse si las hipótesis críticas, y la metodología que sustentan, son aun válidas. La resolución de dichos problemas puede necesitar tiempo y esfuerzos considerables, lo que obstaculiza la consecución de uno de los objetivos del procedimiento. Una posible solución es dotar a la propuesta de flexibilidad suficiente para afrontar los eventuales cambios de hechos y circunstancias, de forma que la probabilidad de obtener resultados imprevistos sea menor, reduciendo así la probabilidad de renegociación del APV PA basado en la propuesta. Naturalmente, la propuesta debe ser siempre conforme con el principio de plena competencia.

48. Un modo de alcanzar el objetivo citado es diseñar una metodología que tenga en cuenta de forma apropiada los cambios en los hechos y circunstancias, por ejemplo, puede integrarse desde el principio en la metodología de determinación de los precios cierta desviación entre el volumen de venta previsto y el real, incluyendo cláusulas de ajuste de los precios futuros o permitiendo una variación de estos en función del volumen. El nivel de desviación tolerado debe fijarse tomando como referencia al que hubieran aceptado partes independientes.

49. Otro método posible para alcanzar el objetivo de aumentar la certidumbre es convenir un rango aceptable de resultados susceptibles de obtenerse aplicando el método del APV PA. Con el fin de que se cumpla el principio de plena competencia, el rango debe acordarse con antelación por todas las partes afectadas, lo que evita el uso de la retrosección, y basarse en lo que las partes independientes habrían convenido en circunstancias similares (consúltense los párrafos 3.55 a 3.66 para analizar el concepto de “rango”). Por ejemplo, la cuantía de un elemento, como un canon, se aceptaría mientras permanezca en los límites del rango acordado, expresado como porcentaje de los beneficios.

50. Si los resultados obtenidos están fuera del rango convenido, las medidas que vayan a tomarse dependerán de lo negociado en la propuesta conforme a la voluntad de las partes. Algunas partes tal vez no deseen correr el riesgo de que los resultados sean significativamente distintos de los previstos. En consecuencia, utilizarán el concepto de rango simplemente como un medio para valorar el incumplimiento de una hipótesis crítica, como se ha descrito en el párrafo 46. Otras partes pueden dar más importancia a la certidumbre sobre el tratamiento que al hecho de evitar resultados inesperados, por lo que pueden acordar que el APV PA incluya un mecanismo de ajuste de los resultados, de modo que entren en el rango previamente convenido.

C.3.8 Duración del APV PA

51. Por su propia naturaleza, los APV se aplican a operaciones futuras, por lo que una de las cuestiones que deben acordarse es su duración. Existen dos tipos de objetivos contradictorios que afectan a la negociación de la vigencia adecuada. Por una parte, es deseable contar con un período lo suficientemente amplio como para garantizar un nivel razonable de certidumbre respecto al tratamiento que se otorgará como resultado del acuerdo. De no ser así, tal vez no valga la pena hacer el esfuerzo inicial de resolver anticipadamente los problemas que puedan surgir en la determinación de los precios de transferencia, en vez de abordarlos en el momento en que surjan, mediante los procedimientos comunes de inspección o de comprobación de declaraciones. Por otra parte, en un período de tiempo prolongado, la previsión de las condiciones futuras en la que se basa la negociación del procedimiento amistoso es menos precisa, lo que arroja dudas sobre la fiabilidad de la propuesta de inicio de un APV PA. El correcto equilibrio entre estos dos objetivos dependerá de varios factores, tales como el sector industrial, las operaciones implicadas y el entorno económico. Las autoridades competentes deben negociar, por tanto, la duración caso por caso. La experiencia hasta la fecha ha demostrado que un APV PA puede durar, como media, entre tres y cinco años.

D) Conclusión del APV PA

D.1 Introducción

52. El éxito de un APV PA como alternativa a las técnicas tradicionales de inspección o comprobación depende en gran medida del compromiso de todos los participantes. La capacidad de las autoridades competentes para alcanzar un acuerdo de forma rápida dependerá tanto de sus actuaciones como -lo que es muy importante- de la voluntad del contribuyente a la hora de aportar toda la información necesaria a la mayor brevedad. La utilidad del proceso, tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales, disminuirá significativamente si el acuerdo se alcanza muy poco antes de que expire el plazo del período de vigencia propuesto en la solicitud presentada por el contribuyente. Esta demora puede dificultar aun más evitar el uso de la retrosección al evaluar la propuesta, dado que se conocerán los resultados de la aplicación de la metodología para la mayor parte del período de vigencia propuesto para el APV PA. Es comprensible, dada la fase actual relativamente incipiente en la evolución de los APV PA, que no siempre se ha cumplido el objetivo de una pronta resolución. Naturalmente, y hasta cierto punto, es inevitable cierto retraso en

el proceso; los APV PA suelen concernir a grandes contribuyentes y entrañar situaciones complejas y difíciles problemas económicos y legales, cuya comprensión y análisis requieren tiempo y recursos.

53. En la medida de lo posible, se anima a las autoridades fiscales a que dediquen a este proceso los recursos y el personal cualificado necesario para garantizar que los casos se resuelven con prontitud y eficiencia. Algunas autoridades fiscales pueden desear aumentar esta eficiencia fijando unos objetivos no obligatorios sobre los plazos necesarios para completar el proceso y publicando el plazo medio de resolución. Algunos co-signatarios de convenios pueden también acordar objetivos no vinculantes para la conclusión de sus negociaciones bilaterales. Debido a la complejidad y dificultad de la casuística, la posible necesidad de llevar a cabo traducciones, y la relativa novedad de los acuerdos, no parece deseable fijar objetivos más específicos o vinculantes por lo que respecta a la conclusión de los APV PA en esta fase. No obstante, sí será apropiado establecer objetivos más específicos en materia de plazos de conclusión, cuando se cuente con una mayor experiencia en este tipo de procedimientos.

54. Una vez que las administraciones tributarias hayan recibido la propuesta de un contribuyente, estas deben acordar la coordinación de la revisión, evaluación y negociación del APV PA. El proceso del APV PA puede dividirse en dos fases fundamentales: a) la obtención, el análisis y la evaluación de los datos y b) las deliberaciones entre autoridades competentes; a continuación se examinan ambas con más detalle.

D.2 Obtención, análisis y evaluación de datos

D.2.1 Términos generales

55. Al revisar la propuesta de APV PA, las administraciones tributarias pueden dar los pasos que consideren necesarios para aplicar el procedimiento amistoso teniendo en cuenta de las circunstancias del caso. Entre ellos, aunque no sean los únicos: la petición de la información complementaria que se considere pertinente para revisar y evaluar la propuesta del contribuyente, la realización de trabajo de campo (por ejemplo, visitas a las instalaciones del contribuyente, entrevistas con el personal, análisis de las operaciones financieras o de gestión, etc.) y la captación de los expertos necesarios. Las administraciones tributarias pueden también recurrir a la información obtenida de otras fuentes, incluyendo información y datos sobre contribuyentes comparables.

56. Para las autoridades competentes que participan en el procedimiento de APV PA, el objetivo en esta fase del procedimiento es contar con toda la información, datos y análisis pertinentes para la negociación. Cuando una administración tributaria obtiene una información adicional del contribuyente que tenga relevancia a efectos del APV PA, por ejemplo, en una reunión con los empleados del contribuyente, tanto este como la administración tributaria han de garantizar que la información llega a la otra u otras administraciones tributarias que participan en el proceso. Las autoridades competentes deben preparar, entre ellas y conjuntamente con los contribuyentes, un mecanismo apropiado que certifique la integridad y el detalle de los documentos y de la información facilitados por el contribuyente, debiendo respetarse las exigencias de las autoridades competentes que participan en el proceso. Por ejemplo, muchas jurisdicciones requieren que no sólo se aporte a todas las autoridades competentes participantes la misma información de los hechos, sino que, en la medida de lo posible, se haga simultáneamente.

57. Con frecuencia, la naturaleza prospectiva de los APV PA implica que el contribuyente tiene que proporcionar información comercial relativa a sus previsiones, que probablemente es aún más sensible a las consecuencias de su divulgación que la referida a hechos pasados. En consecuencia, con el fin de garantizar la confianza que depositan los contribuyentes en el APV PA, las administraciones tributarias deben asegurarse de que la información aportada por el contribuyente en el transcurso del procedimiento está sujeta a las mismas salvaguardias de secreto, confidencialidad y privacidad que las que confiere la legislación nacional a cualquier otra información del contribuyente. Además, cuando se intercambia información entre autoridades competentes en virtud de los términos del convenio tributario, dicha información puede revelarse únicamente de acuerdo con las disposiciones específicas de este, y todo intercambio debe atenerse al artículo o artículos relativos al intercambio de información del convenio aplicable.

58. En general, las autoridades competentes deberán revisar y evaluar la propuesta del contribuyente de forma independiente y simultánea, asistidas en esta tarea, cuando sea necesario, por especialistas en precios de transferencia, en el sector, u otros especialistas de su administración tributaria. No obstante, habrá casos en los que lo más efectivo sea recopilar conjuntamente parte de la información, lo que puede llevarse a efecto mediante diversos mecanismos: desde reuniones ocasionales para la recopilación de datos o la visita presencial, hasta la preparación de un informe conjunto por el personal encargado de trabajar en el caso.

D.2.2 Papel del contribuyente en el procedimiento de obtención, análisis y evaluación de la información

59. Con el fin de acelerar el proceso, los contribuyentes deben asumir la responsabilidad de garantizar que las autoridades competentes, antes del inicio de las negociaciones, tengan conocimiento de los mismos hechos, dispongan de la información que necesitan y comprendan plenamente el caso. Esto puede conseguirse si el contribuyente transmite sistemática y simultáneamente a una administración tributaria la información solicitada por la otra; si una de las administraciones tributarias prepara y transmite a la otra notas sobre las reuniones convocadas para recabar datos y, cuando sea factible logística y económicamente, facilitando reuniones informativas conjuntas. El contribuyente debe facilitar las traducciones necesarias y garantizar que no existen retrasos indebidos en la contestación a las peticiones complementarias de información relevante. El contribuyente debe tener así mismo la posibilidad de ponerse en contacto con su administración tributaria durante la revisión y evaluación de su propuesta, siempre que sea apropiado y conveniente para ambas partes, y deberá informársele de los avances en la tramitación de su expediente.

D.3 Desarrollo de la discusión entre las autoridades competentes

D.3.1 Coordinación entre autoridades competentes

60. Muchos países desean participar íntegramente en el proceso tan pronto como éste se inicia y trabajar en estrecho contacto con las otras autoridades competentes. Otros países prefieren limitar su compromiso al análisis y comentario de las propuestas de APV PA, cuando estén próximas a concluirse. No obstante, se recomienda la participación de todas las administraciones tributarias que intervienen en el proceso desde las primeras etapas, con sujeción a las restricciones existentes en los recursos disponibles, ya que con ello se optimiza el proceso y se evitan retrasos injustificados en la conclusión del acuerdo amistoso.

61. Las autoridades competentes deben negociar el acuerdo amistoso en los plazos previstos. Esto exige destinar los recursos suficientes y el personal cualificado para este cometido. Es deseable que las autoridades competentes discutan y coordinen un plan de acción apropiado respecto a temas tales como: la designación de funcionarios delegados, el intercambio de información, la coordinación del análisis y evaluación de la propuesta, la fijación de un calendario provisional de las consultas posteriores, y la

negociación y conclusión de un acuerdo apropiado. Los medios y recursos necesarios deben adaptarse a las necesidades de cada caso.

62. La experiencia ha demostrado que las discusiones frecuentes entre las autoridades competentes, desde las primeras etapas y a medida que surgen los problemas, pueden ser útiles y evitar sorpresas desagradables durante el proceso. Dada la naturaleza de los APV PA, existirán temas importantes que no pueden resolverse simplemente con un intercambio de documentos de posición y, en consecuencia, tal vez se requieran intercambios más formales, tales como reuniones presenciales entre las diferentes autoridades competentes. Las llamadas telefónicas y vídeo conferencias pueden resultar de utilidad.

D.3.2 El papel del contribuyente en las discusiones entre las autoridades competentes.

63. El papel del contribuyente en esta fase del proceso es necesariamente más limitado que en el de obtención de información, dado que la conclusión del APV PA es un proceso entre administraciones. Las autoridades competentes pueden acordar que el contribuyente haga una presentación de las cuestiones fácticas y legales antes de que se inicien las propias discusiones, durante las cuales no deberá estar presente. También puede ser útil que el contribuyente esté disponible, cuando se le requiera, para contestar cualesquiera preguntas sobre hechos que puedan surgir durante las discusiones. El contribuyente debería abstenerse de presentar información fáctica adicional o de invocar nuevos argumentos en esta reunión ya que las autoridades fiscales necesitarían tiempo para su análisis, lo que implicaría un retraso en la consecución del acuerdo final. La información debe proporcionarse antes de iniciar las conversaciones.

D.3.3 Desistimiento de un APV PA

64. El contribuyente o la administración tributaria pueden desistir del APV PA en cualquier momento. No obstante, se debe desincentivar la retirada del proceso, sobre todo en las últimas etapas y sin un motivo justificado, por el desperdicio inevitable de recursos que conlleva dicha acción. En caso de desistimiento de una solicitud de APV PA, ni el contribuyente ni las administraciones tributarias tendrán obligaciones mutuas, y cualquier compromiso o acuerdo anterior alcanzado entre las partes quedará vacío de contenido y sin efecto, a menos que exista una disposición en contrario en la normativa interna (por ejemplo, el pago de tasas por el solicitante del APV puede no ser reembolsable). Si una

administración tributaria propone desistir del procedimiento, se informará al contribuyente de las causas de tal acción, otorgándole la oportunidad de presentar nuevos argumentos.

D.3.4 Documentos utilizados en el procedimiento amistoso

65. Las autoridades competentes participantes deben preparar un proyecto de acuerdo amistoso cuando hayan acordado la metodología y otras cláusulas y condiciones. Puede ocurrir que, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades competentes, el acuerdo amistoso propuesto no elimine completamente la doble imposición. El contribuyente tendrá entonces la oportunidad de decir si tal proyecto de APV PA es aceptable antes de su conclusión. No es posible imponer el acuerdo sin el consentimiento del contribuyente.

66. El APV PA se materializará en un documento escrito y las autoridades competentes implicadas decidirán su contenido, presentación, etc. Para que el acuerdo amistoso quede claramente registrado y pueda aplicarse eficazmente es necesario que contenga, como mínimo, la siguiente información, o que indique dónde puede encontrarse dicha información en la solicitud de inicio del APV PA:

- a) nombre y domicilio de las empresas a las que concierne el acuerdo;
- b) las operaciones, los acuerdos o planes, ejercicios fiscales o períodos contables cubiertos;
- c) una descripción de la metodología acordada y otros temas afines como los comparables acordados o el rango de resultados previstos;
- d) la selección de los criterios relevantes que constituyen la base de aplicación y cálculo de la metodología (por ejemplo, las ventas, el coste de las ventas, el beneficio bruto, etc.);
- e) las hipótesis críticas sobre las que se basa la metodología y cuyo incumplimiento haría necesaria la renegociación del acuerdo;
- f) cualesquiera procedimientos convenidos para hacer frente a cambios en las circunstancias fácticas que no sean lo suficientemente importantes como para requerir la renegociación del acuerdo;
- g) si fuera necesario, el tratamiento fiscal convenido para las cuestiones accesorias;
- h) las cláusulas y condiciones que debe cumplir el contribuyente para garantizar la validez del acuerdo amistoso, así como los procedimientos

- para garantizar que el contribuyente cumple dichas cláusulas y condiciones;
- i) los detalles sobre las obligaciones de los contribuyentes respecto a las administraciones tributarias como resultado de la aplicación en su jurisdicción del APV PA (por ejemplo, los informes anuales, la contabilidad, la notificación de los cambios habidos en las hipótesis críticas, etc.); y
 - j) la confirmación de que, con el fin de garantizar la confianza de los contribuyentes y de las autoridades competentes en el proceso del APV PA, en el que se intercambia información con toda libertad, se impedirá la divulgación de la información suministrada por los contribuyentes (incluida su identidad), en la medida que sea posible conforme a la legislación interna de las respectivas jurisdicciones. La información intercambiada entre las autoridades competentes intervinientes quedará protegida por el convenio bilateral aplicable y por la legislación interna pertinente.

D.4 Aplicación del APV PA

D.4.1 Aplicación del APV PA y confirmación del acuerdo al contribuyente

67. Una vez que el APV PA se ha acordado definitivamente, es necesario que las autoridades fiscales que participan en él lo apliquen en su propia jurisdicción. Las administraciones tributarias deben suscribir alguna forma de confirmación o de acuerdo con sus contribuyentes respectivos, conforme al procedimiento amistoso en el que han intervenido las autoridades competentes participantes. Esta confirmación o acuerdo conferirá al contribuyente la seguridad de que no se procederá al ajuste de las operaciones de precios de transferencia cubiertas por el APV PA, siempre que el contribuyente cumpla las cláusulas y condiciones del acuerdo amistoso, tal como queden reflejadas en la confirmación o en el acuerdo pactado a nivel nacional, y que no haya hecho declaraciones falsas o susceptibles de inducir a error durante el procedimiento, comprendidas las declaraciones incluidas en los informes anuales de cumplimiento. Las cláusulas y condiciones incluyen ciertas hipótesis que, en el caso de no cumplirse, podrían requerir el reajuste o la reconsideración del acuerdo.

68. El modo en que se llega a esta confirmación o a este acuerdo variará en función del país y la forma exacta dependerá de la legislación y prácticas internas. En algunos países, la confirmación o el acuerdo adoptarán

la forma de un APV de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa interna. Para aplicar el acuerdo amistoso de forma efectiva, la confirmación dada o el acuerdo firmado deben ser conformes con el APV PA y ofrecer como mínimo al contribuyente las mismas ventajas que las negociadas en el acuerdo mutuo. Además, cuando no haya sido posible suprimir totalmente la doble imposición, una de las jurisdicciones participantes puede reducir unilateralmente, en el marco de su procedimiento interno de confirmación, la doble imposición subsistente. Asimismo, esta confirmación o acuerdo pueden abarcar otros temas además de los contenidos en el APV PA, por ejemplo, el tratamiento fiscal de otras cuestiones colaterales, las obligaciones adicionales en materia de registro contable o las obligaciones de documentación y de presentación de informes. Es necesario prestar atención al hecho de que ninguna de las cláusulas adicionales de la confirmación o del acuerdo suscrito en el ámbito nacional entre en conflicto con las disposiciones del APV PA.

D.4.2 Posible aplicación retroactiva “roll-back”

69. Ni las administraciones tributarias ni el contribuyente están en modo alguno obligados a aplicar la metodología acordada en el APV PA a los ejercicios fiscales anteriores al primer año de vigencia del acuerdo (aplicación conocida como aplicación retroactiva o “roll-back”). Naturalmente, esta aplicación sería imposible si las circunstancias de ese momento fueron distintas. No obstante, la metodología que se ha de aplicar a los años venideros en el marco del APV PA puede ser útil para determinar el tratamiento de las operaciones comparables en los años anteriores. En algunos casos, los precios de transferencia de los períodos anteriores al de vigencia del APV pueden estar siendo objeto de inspección por una administración tributaria, por lo que tanto esta como el contribuyente tal vez deseen aprovechar la oportunidad de utilizar la metodología acordada para la resolución de esa inspección o, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación interna, la citada administración tributaria puede decidir proceder al ajuste incluso sin que medie solicitud ni acuerdo por parte del contribuyente. Si el contribuyente quiere tener la seguridad de conseguir la eliminación de la doble imposición, se necesitará el consentimiento de la otra administración o administraciones tributarias afectadas para aplicar retroactivamente la metodología. La aplicación retrospectiva dependerá también de la legislación nacional y del convenio en cuestión, por ejemplo, en relación con los plazos previstos.

E. Seguimiento de los APV PA

70. Es esencial que las administraciones tributarias estén en situación de confirmar que el contribuyente está respetando las cláusulas y condiciones en las que se basa el acuerdo amistoso durante toda su vigencia. Como el acuerdo amistoso lo pactan las administraciones tributarias sin que el contribuyente sea parte, estas deben basarse en la confirmación o en el procedimiento de acuerdo descrito anteriormente con el fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Si este último incumple las cláusulas y condiciones del APV PA se interrumpe la obligación de su aplicación. Esta Sección se centra, por tanto, en los aspectos de los procedimientos internos necesarios para la aplicación satisfactoria del APV PA, y en las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todas sus cláusulas y condiciones.

E.1 *Registro y archivo de la documentación.*

71. El contribuyente y las administraciones tributarias deben convenir la documentación (incluyendo las traducciones que puedan ser necesarias) que el contribuyente debe tener y conservar con el fin de verificar su grado de cumplimiento del APV PA. Se deben seguir las orientaciones dadas en los Capítulos IV y V de las Directrices con el fin de evitar las obligaciones de documentación constituyan una carga demasiado pesada. También pueden incluirse disposiciones relativas al período durante el cual deben conservarse los documentos y los plazos durante los que su presentación es exigible.

E.2 *Mecanismos de supervisión*

E.2.1 *Informes anuales*

72. Para cada ejercicio fiscal o período contable cubierto por un APV PA, se puede exigir al contribuyente que presente, además de su declaración tributaria, un informe anual que describa sus operaciones efectivas del ejercicio y demuestre el cumplimiento de las cláusulas y condiciones del APV PA, incluyendo la información necesaria para decidir si se han cumplido las hipótesis críticas u otras garantías. El contribuyente debe poner esta información a disposición de la administración tributaria con la que ha suscrito el acuerdo en las condiciones previstas por la legislación o el procedimiento interno aplicable.

E.2.2 Inspección

73. Un APV PA se aplica sólo a las partes especificadas en el acuerdo y únicamente a operaciones concretas. La existencia de tal acuerdo no impedirá a las administraciones tributarias participantes realizar una actividad inspectora en el futuro, aunque toda inspección de las operaciones cubiertas por un APV PA deberá limitarse a la determinación del grado de cumplimiento del contribuyente con las cláusulas y condiciones y a la comprobación de si siguen existiendo las circunstancias e hipótesis necesarias para la aplicación fiable de la metodología escogida. Las administraciones tributarias afectadas pueden exigir que el contribuyente demuestre:

- a) que ha cumplido con las cláusulas y condiciones del APV PA;
- b) que los argumentos que figuran en la propuesta, en los informes anuales y en cualquier documentación en apoyo de la solicitud siguen siendo válidos y que cualesquiera cambios importantes en los hechos o circunstancias se han incluido en los informes anuales;
- c) que la metodología se ha aplicado con precisión y coherencia conforme a las cláusulas y condiciones del APV PA; y
- d) que siguen siendo válidas las hipótesis críticas subyacentes a la metodología de determinación de precios de transferencia.

E.3 Consecuencias del incumplimiento o de los cambios en las circunstancias

74. En general, las consecuencias del incumplimiento de las cláusulas y condiciones de un APV PA, o de la imposibilidad de materializar una hipótesis crítica, se abordarán mediante: a) las cláusulas del APV PA; b) los acuerdos posteriores entre las autoridades competentes referidas al tratamiento de dicho incumplimiento o no materialización; y c) toda legislación nacional o reglas de procedimiento aplicables. Es decir, el APV PA puede, por sí mismo, indicar explícitamente los procedimientos que deben seguirse en caso de incumplimiento de las obligaciones, o las consecuencias derivadas del mismo. En estas situaciones las autoridades competentes pueden, según su criterio, entablar conversaciones sobre las medidas que deban adoptarse en cada caso. Finalmente las disposiciones legislativas o las reglas de procedimiento para la aplicación en cada jurisdicción pueden tener consecuencias o imponer obligaciones para el contribuyente y la administración tributaria afectada. Los párrafos siguientes sugieren directrices similares a los procedimientos que se han adoptado en

ciertas jurisdicciones y que, en general, han resultado prácticos. No obstante, debe subrayarse que algunas administraciones tributarias desearán tal vez adoptar procedimientos y criterios distintos.

75. A pesar de que las administraciones tributarias establezcan que no se ha respetado un requisito del APV PA, pueden convenir seguir aplicándolo en virtud de sus cláusulas y condiciones, por ejemplo, cuando el incumplimiento no tiene consecuencias graves. Si no están de acuerdo en continuar aplicando el APV PA, cada administración tributaria tiene tres opciones. La naturaleza de las medidas que pueden adoptarse dependerá probablemente de la gravedad del incumplimiento.

76. La acción más drástica es la revocación, cuyo efecto es que el contribuyente sea tratado como si no se hubiese acordado nunca el APV PA. Una medida menos grave es la cancelación, que implica que el contribuyente sea tratado como si el APV PA hubiera sido efectivo y vigente pero sólo hasta la fecha de cancelación y no durante todo el período de vigencia propuesto. En caso de cancelación o revocación del APV PA la administración tributaria y los contribuyentes intervinientes conservarán todos los derechos que les otorguen la legislación de sus jurisdicciones y las disposiciones del convenio aplicable, como si el APV PA no hubiera existido durante los ejercicios fiscales o períodos contables para los que es efectiva la cancelación o la revocación. Finalmente, el APV PA puede ser objeto de revisión, lo que significa que el contribuyente continuará beneficiándose de él durante el período propuesto aunque las condiciones aplicables antes y después de la fecha de revisión sean diferentes. Se ofrecen más detalles a continuación.

E.3.1 Revocación de un APV PA

77. Una administración tributaria puede revocar un APV PA (unilateralmente o de mutuo acuerdo) si queda probado:

- a) que existió falsedad, error u omisión imputables a la negligencia, falta de diligencia debida o incumplimiento deliberado de un contribuyente al elaborar y presentar la solicitud del APV PA, los informes anuales u otros documentos justificativos, o al aportar cualquier clase de información al efecto; o
- b) que el contribuyente o contribuyentes participantes incumplieron materialmente algún término o condición fundamental del APV PA.

78. Cuando se revoca un APV PA, la revocación es retroactiva a partir del primer día del primer ejercicio fiscal o del primer período contable

respecto del que el APV PA surtiera efectos, y dejará de estar vigente y de surtir efectos respecto de la otra administración tributaria y del contribuyente o contribuyentes afectados. Debido a la importancia de los efectos de esta acción, la administración tributaria que propone la revocación del APV PA sólo debe llevarla a cabo después de una evaluación cuidadosa y completa de las circunstancias concurrentes, y debe informar y consultar oportunamente al contribuyente o contribuyentes afectados y a la otra administración tributaria.

E.3.2. Cancelación de un APV PA

79. Una administración tributaria puede cancelar un APV PA (ya sea unilateralmente o de mutuo acuerdo) si queda probado que se ha dado una de las situaciones siguientes:

- a) que ha habido un falseamiento de los hechos, un error u omisión no imputables a la negligencia, falta de diligencia debida o incumplimiento deliberado de un contribuyente al elaborar y presentar la solicitud del APV PA, los informes anuales u otros documentos justificativos, o al aportar cualquier clase de información al efecto; o
- b) que el contribuyente o contribuyentes participantes han incumplido materialmente cualquier término o condición del APV PA; o
- c) que se han incumplido una o más de las hipótesis críticas; o
- d) que ha habido un cambio en la legislación tributaria -comprendidos los cambios en los convenios- muy relevante para el APV PA; y que no ha sido posible revisar el acuerdo (véanse los párrafos 80 a 82 siguientes) de forma que se subsane el cambio de circunstancias.

80. En caso de cancelación de un APV PA, la fecha de cancelación vendrá determinada por la naturaleza del acontecimiento que la propició. Puede ser una fecha concreta, por ejemplo cuando el acontecimiento que causó la cancelación fue un cambio importante en la legislación tributaria (aunque el APV PA puede prever un período de transición entre la fecha de la modificación de la legislación y la fecha de cancelación). En otros casos, la cancelación tendrá efecto para un ejercicio fiscal o un período contable determinado, por ejemplo cuando se produce una modificación importante en una de las hipótesis críticas que no pueda adscribirse a una fecha específica en dicho ejercicio fiscal o período contable. El APV PA dejará de tener vigencia para el contribuyente o contribuyentes afectados y para la otra administración tributaria desde la fecha de cancelación.

81. La administración tributaria puede renunciar a la cancelación si el contribuyente puede probar motivos razonables que satisfagan a la administración tributaria, y si se muestra de acuerdo en realizar el ajuste propuesto por dicha administración para corregir la falsedad, el error, la omisión o el incumplimiento, o para subsanar los cambios ocurridos en las hipótesis críticas, en la legislación tributaria o en las disposiciones del convenio aplicables al APV PA. Tal acción puede llevar a la revisión del APV PA (véase más adelante).

82. La administración tributaria que propone la cancelación debe informar y consultar oportunamente al contribuyente o contribuyentes y a la otra administración o administraciones afectadas. Esta consulta debe incluir una explicación de los motivos por los que se propone la cancelación del APV PA. Debe concederse al contribuyente la oportunidad de dar una respuesta antes de que se tome una decisión definitiva.

E.3.3 Revisión de un APV PA

83. La validez de la metodología de determinación de precios de transferencia depende de que las hipótesis críticas sigan siendo válidas durante la vigencia del APV PA. El APV PA y toda confirmación u acuerdo de ámbito interno debe exigir, por tanto, que el contribuyente notifique cualquier cambio a las administraciones tributarias afectadas. Si, tras la evaluación realizada por las administraciones tributarias, se determina que se ha producido un cambio importante en las condiciones de una hipótesis crítica, puede procederse a la revisión del APV PA a fin de reflejarlo. Como ya se ha visto anteriormente, el APV PA puede también contener hipótesis que, sin ser cruciales para la validez del acuerdo, merecen su análisis por las partes afectadas. Uno de los resultados de tal análisis puede ser también una revisión del APV PA. Sin embargo, en muchos casos, las cláusulas y condiciones del APV PA pueden ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los efectos provocados por esos cambios sin que sea necesaria su revisión.

84. El contribuyente deberá notificar el cambio a las administraciones tributarias lo antes posible una vez que éste se haya producido, o desde que el propio contribuyente haya tenido conocimiento de él y, en cualquier caso, siempre antes de la presentación, si fuese preceptivo, del informe anual relativo a dicho ejercicio o período contable. La comunicación inmediata es deseable con el fin de que las partes afectadas dispongan de más tiempo para intentar llegar a un acuerdo sobre la revisión del APV PA, reduciendo así el riesgo de cancelación.

85. El APV PA revisado debe indicar tanto la fecha a partir de la cual la revisión surtirá efectos, como la fecha a partir de la cual el APV PA inicial dejará de ser aplicable. Si se puede identificar la fecha de la modificación con precisión, entonces la revisión tendrá efecto a partir de esa fecha; si ello no es posible, la revisión del APV PA surtirá efectos a partir del primer día del período contable posterior a aquel en el que tuvo lugar el cambio. Si las administraciones tributarias y el contribuyente no pueden ponerse de acuerdo sobre la necesidad de revisar el APV PA o sobre el modo de revisarlo, el APV PA se anulará y dejará de surtir efectos tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias que han participado en él. La determinación de la fecha efectiva de la cancelación del APV PA se rige por los mismos principios que se aplican para determinar la fecha de revisión.

E.4 Renovación del APV PA

86. La solicitud de revisión de un APV PA se presentará en los plazos previstos por las administraciones tributarias intervinientes, teniendo en cuenta la necesidad de disponer de tiempo suficiente para que el contribuyente o contribuyentes y las administraciones tributarias revisen y valoren la solicitud de renovación y alcancen un acuerdo. Puede ser útil abordar el proceso de renovación mucho antes de que expire el APV PA vigente.

87. En términos generales, el formato, procedimiento y evaluación de la solicitud de renovación serán similares a los de la solicitud inicial. No obstante, el nivel de detalle necesario puede reducirse con el consenso de las administraciones tributarias implicadas, en particular, si no se han producido variaciones importantes en los hechos y circunstancias del caso. La renovación de un APV PA no es automática y depende del consentimiento de todas las partes intervinientes y de que el contribuyente demuestre, entre otras cosas, el cumplimiento de las cláusulas y condiciones del APV PA vigente. Naturalmente, la metodología, los términos y condiciones del APV PA renovado pueden diferir de los del APV PA anterior.

Anexo al Capítulo VI

Ejemplos ilustrativos de la aplicación de las directrices sobre precios de transferencia a activos intangibles de valoración muy incierta

Los tres ejemplos que se recogen a continuación ilustran la aplicación de los principios relativos a la determinación de precios de transferencia cuando en el momento de la operación la valoración de los bienes intangibles transferidos es muy incierta. Véanse los párrafos 6.28 a 6.35.

Los ajustes y las hipótesis sobre acuerdos de plena competencia a los que se ha recurrido en estos ejemplos tienen un carácter meramente ilustrativo, por lo que no debe considerarse que obliguen a la realización de ajustes ni a la imposición de acuerdos de plena competencia en casos reales o a sectores de actividad concretos. Si bien estos ejemplos pretenden ilustrar los principios enunciados en las secciones de las Directrices a las que se refieren, esos principios deben aplicarse en cada caso de acuerdo con los hechos y circunstancias concretos de cada uno de ellos.

Ejemplo 1

1. Los derechos de fabricación y distribución de un medicamento son objeto de licencia entre empresas asociadas en virtud de un acuerdo que determina un porcentaje de cánones durante su vigencia, acordada en tres años. Estos términos se ajustan a las prácticas seguidas en el sector y a los acuerdos concluidos en condiciones de plena competencia tomando como referencia productos comparables. El porcentaje acordado se acepta como equivalente al que se hubiera acordado en una operación no vinculada, basándose en los beneficios que razonablemente pueden esperar obtener las dos partes en el momento de concluir el acuerdo.

2. En el transcurso del tercer año de vigencia del acuerdo se descubre que el medicamento, en combinación con otro fármaco, tiene propiedades aplicables a otra categoría terapéutica, y este descubrimiento lleva a un aumento considerable de las ventas y beneficios del licenciatario. Si el acuerdo se hubiese negociado en este tercer año en condiciones de plena competencia y disponiendo de esta información, es indudable que se habría

convenido un porcentaje superior en concepto de cánones con objeto de reflejar el aumento del valor del intangible.

3. Existen pruebas (puestas a disposición de la administración tributaria) que demuestran que las nuevas propiedades del medicamento no se habían previsto en el momento en que se concluyó el acuerdo, y que el porcentaje de cánones fijado en el año 1 se ajustaba a los beneficios que las dos partes podían esperar obtener en ese momento. La ausencia de una cláusula de ajuste de los precios o de cualquier otra protección contra el riesgo de incertidumbre de la valoración es también coherente con las condiciones en las que se efectúan las operaciones no vinculadas comparables. Y, basándose en un análisis del comportamiento de empresas independientes en circunstancias similares, no existe motivo alguno para creer que la evolución en el año 3 iba a ser tan importante que, en condiciones de plena competencia, hubiera conducido a una renegociación del precio de la operación.

4. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias no hay motivo para ajustar el porcentaje de cánones en el año 3. Tal ajuste estaría en contra de los principios formulados en el Capítulo VI porque constituiría un uso indebido de la retrospección. Véase el párrafo 6.29 de las Directrices. No hay razón para considerar que la valoración inicial fuese tan incierta como para que partes que operan en condiciones de plena competencia hubieran exigido una cláusula de ajuste de precios, o que el cambio en el valor iba a constituir un cambio tan importante que hubiera conducido a una renegociación de la operación. Véanse los párrafos 6.30-6.31.

Ejemplo 2

5. Se repiten los mismos hechos que en el ejemplo anterior. Supongamos que al final del período de tres años, las partes renegocian el acuerdo. En esta fase, sabemos que los derechos sobre el fármaco tienen un valor considerablemente más elevado de lo que parecía al principio. Sin embargo, el acontecimiento inesperado del año anterior es aun reciente y no es posible predecir con certidumbre si las ventas van a seguir aumentando, si se van a descubrir otros efectos beneficiosos y qué evolución del mercado podrá afectar a las ventas a medida que los competidores puedan beneficiarse del hallazgo. Todas estas consideraciones hacen de la revaluación de los derechos intangibles un proceso muy incierto. Sin embargo, las empresas asociadas concluyen un nuevo acuerdo de licencia de 10 años de duración, que aumenta significativamente el tipo fijo de canon, basándose en expectativas especulativas de estabilidad y crecimiento de la demanda.

6. No es habitual en el sector formalizar acuerdos a largo plazo con porcentajes fijos de cánones cuando el intangible en cuestión tiene potencialmente un valor elevado que no puede determinarse sobre la base de la experiencia. Tampoco existen pruebas de que, dada la incertidumbre de la valoración, empresas independientes hubieran considerado las estimaciones planteadas por las empresas asociadas como justificativas de la conclusión de un acuerdo en el que se fijara el porcentaje de los cánones. Supongamos que existen pruebas de que empresas independientes hubieran insistido en protegerse mediante cláusulas de ajuste de los precios futuros, tomando como base revisiones efectuadas anualmente.

7. Supongamos que en el año 4 las ventas se incrementan y que el porcentaje de cánones fijado en el acuerdo de diez años se considera apropiado desde el punto de vista del principio de plena competencia. Sin embargo, a principios del año 5, una empresa de la competencia presenta al mercado un fármaco más beneficioso que el primero en la categoría terapéutica en la que el medicamento que nos ocupaba anteriormente, en combinación con otro, resultó inesperadamente beneficioso, y las ventas de este empiezan a decrecer rápidamente. El porcentaje de cánones fijado al inicio de la vigencia del acuerdo de diez años no puede considerarse como de plena competencia más allá del quinto año, por lo que estaría justificado que la Administración Tributaria realizara un ajuste de precios de transferencia a partir del principio del año 6. Este ajuste es apropiado debido a las pruebas, mencionadas en el párrafo anterior, que apoyan el que, en circunstancias comparables, empresas independientes habrían previsto en el acuerdo un ajuste de precios basado en una revisión anual. Véase el párrafo 6.34 de las Directrices.

Ejemplo 3

8. Supongamos que la sociedad X concede una licencia en la que otorga el derecho de producir y distribuir un microchip a la sociedad Y, filial recientemente creada, durante un período de cinco años. El porcentaje de cánones se fija en el 2 por ciento. Este porcentaje se basa en una previsión de los beneficios que pueden derivarse de la explotación del intangible, que muestra unas ventas esperadas del producto de entre 50 y 100 millones por año durante un periodo de cinco.

9. Queda demostrado por los contratos entre empresas independientes relativos a intangibles comparables en circunstancias comparables, que la estimación no es lo suficientemente fiable como para justificar un porcentaje fijo de canon y, por tanto, lo normal hubiera sido acordar una cláusula de ajuste de precios que permitiera subsanar las diferencias entre los beneficios

reales y los estimados. Un acuerdo realizado entre la Sociedad X y un fabricante independiente en relación con un intangible comparable, en circunstancias comparables, prevé los siguientes ajustes en el porcentaje:

Ventas	Porcentaje
Hasta 100 millones	2,00%
Siguientes 50 millones	2,25%
Siguientes 50 millones	2,50%
Más de 200 millones	2,75%

10. Los hechos son que, aunque las ventas efectuadas por Y en el primer año ascendieron a 50 millones, en los años posteriores las ventas fueron tres veces superiores a las cifras previstas. En ese caso, y de acuerdo con lo enunciado en esta sección, la administración tributaria estaría justificada para determinar el porcentaje de cánones sobre la base de la cláusula de ajuste prevista en una operación no vinculada comparable, como la concluida entre la sociedad X y el fabricante independiente. Véanse los párrafos 6.30, 6.32 y 6.33 de las Directrices.

Apéndice

Recomendación del Consejo sobre la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas [C(95)126/FINAL]

Modificada el 11 de abril de 1996 [C(96)46/FINAL], el 24 de julio de 1997 [C(97)144/FINAL], el 28 de octubre de 1999 [C(99)138], el 16 de julio de 2009 [C(2009)88] y el 22 de julio de 2010 [C(2010)99]

El CONSEJO,

Visto el Artículo 5(b) del convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 14 de diciembre de 1960;

Vista la Declaración de 21 de junio de 1976 adoptada por los Gobiernos de los países miembros de la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, y las Directrices que se adjuntan a la misma [C(76)99(Final)];

Visto el Informe sobre las Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias, denominado en adelante "el Informe de 1995" [DAFFE/CFA(95)19 y la Fe de erratas I], aprobado el 27 de junio de 1995 por el Comité de Asuntos Fiscales, y complementado por el Informe sobre activos intangibles y servicios aprobado el 23 de enero de 1996 por el Comité de Asuntos Fiscales [DAFFE/CFA(96)2], e incorporado en los Capítulos VI y VII, y por el Informe sobre los acuerdos de reparto de costes aprobado el 25 de junio de 1997 por el Comité de Asuntos Fiscales [DAFFE/CFA(97)27] incorporado en el Capítulo VIII; por el Informe sobre las líneas rectoras de los procedimientos de seguimiento de la aplicación de las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y la implicación del mundo empresarial [DAFFE/CFA/WD(97)11/REV1], aprobado el 24 de junio de 1997 por el Comité de Asuntos Fiscales e incorporado en los Anexos, por el Informe sobre las líneas rectoras de los acuerdos previos de valoración de precios de transferencia en el marco de los procedimientos amistosos

aprobado el 30 de junio de 1999 por el Comité de Asuntos Fiscales [DAFFE/CFA(99)31] e incorporado en los Anexos, por el Informe sobre reestructuración de empresas y precios de transferencia, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 [CTPA/CFA/(2010)46] e incorporado en el Capítulo IX; revisado en virtud del Informe sobre comparabilidad y métodos de determinación de beneficios, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 [CTPA/CFA/(2010)55], que sustituyó a los Capítulos I a III; modificado mediante actualización del Capítulo IV, aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales el 6 de junio de 2008 [CTPA/CFA(2008)30/REV1]; por una actualización del Prefacio y el Prólogo aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2009 [CTPA/CFA(2009)51/REV1], y por la actualización del Prefacio, el Prólogo, el Glosario, los Capítulos IV a VIII y los Anexos, aprobada por el Comité de Asuntos Fiscales el 22 de junio de 2010 [CTPA/CFA(2010)47];

Vista la necesidad fundamental de cooperación entre administraciones tributarias para suprimir los obstáculos que representa la doble imposición para la libre circulación de bienes, servicios y capitales entre los países miembros;

Considerando que las operaciones entre empresas asociadas pueden desarrollarse en condiciones diferentes de aquellas en las que operan empresas independientes;

Considerando, sin embargo, que los precios utilizados en esas operaciones entre empresas asociadas (denominados habitualmente “precios de transferencia”) deben corresponderse, a efectos fiscales, con los precios que se hubieran facturado entre empresas independientes (generalmente designados como “precios de plena competencia”) como se establece en el Artículo 9 (apartado 1) del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE sobre la renta y el patrimonio;

Considerando que los problemas planteados por los precios de transferencia en las operaciones internacionales tienen una importancia especial por el considerable volumen de estas operaciones;

Considerando la necesidad de llegar a una mayor coherencia en los criterios aplicados por las administraciones tributarias, por una parte, y por las empresas asociadas, por la otra, para determinar los ingresos y gastos de una sociedad perteneciente a un grupo multinacional, que deben tenerse en cuenta dentro de una jurisdicción.

I. RECOMIENDA a los Gobiernos de los países miembros:

I.1 que sus administraciones tributarias sigan, cuando revisen y, en su caso, ajusten los precios de transferencia entre empresas asociadas a efectos

de determinar la renta imponible, las directrices aplicables que figuran en el Informe de 1995, con sus correspondientes modificaciones (considerando la integridad del Informe y la interacción de los diferentes capítulos) para llegar a la determinación de un precio de plena competencia para las operaciones entre empresas asociadas;

I.2. que sus administraciones tributarias estimulen a los contribuyentes a seguir las directrices aplicables que figuran en el Informe de 1995, con sus correspondientes modificaciones y que, a tal fin, den en su país una amplia publicidad al Informe modificado de 1995 y lo traduzcan, cuando sea necesario, a su(s) lengua(s) nacional(es);

I.3 que desarrollen una mayor cooperación entre sus administraciones tributarias, sobre una base bilateral o multilateral, en asuntos relacionados con los precios de transferencia.

II. INVITA a los Gobiernos de los países miembros:

II.1 a notificar al Comité de Asuntos Fiscales cualquier modificación en el texto de las leyes o reglamentos aplicables en la determinación de los precios de transferencia o la introducción de nuevas leyes o reglamentos.

III. ORDENA al Comité de Asuntos Fiscales:

III.1 que continúe con sus trabajos sobre las cuestiones relativas a los precios de transferencia y que publique las adiciones a las directrices a las que se refiere el Informe modificado de 1995;

III.2 que haga un seguimiento de la aplicación del Informe modificado de 1995, en cooperación con las autoridades fiscales de los países miembros y con participación del mundo empresarial y que recomiende al Consejo modificar y actualizar, cuando sea necesario, el Informe de 1995 modificado, a la vista de su revisión;

III.3 que informe periódicamente al Consejo de los resultados de su trabajo en estas materias y que le eleve cualquier propuesta pertinente que mejore la cooperación internacional;

III.4 que lleve a cabo un dialogo con los países no miembros, conforme con la política de la Organización, con la finalidad de ayudarlos a familiarizarse con el Informe modificado de 1995 y, si ha lugar, estimularlos a adherirse al Informe modificado de 1995.

IV. DECIDE derogar la Recomendación sobre la determinación de los precios de transferencia entre empresas asociadas aprobada el 29 de mayo de 1979 [C(79)83(Final)].

DIRECTRICES DE LA OCDE APLICABLES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA A EMPRESAS MULTINACIONALES Y ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS.

Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias ofrecen pautas para la aplicación del “principio de plena competencia” que constituye el consenso internacional sobre los precios de transferencia, es decir, sobre la valoración, a efectos fiscales, de las operaciones internacionales entre empresas asociadas. En una economía globalizada en la que las empresas multinacionales desempeñan un papel preponderante, los precios de transferencia ocupan un lugar destacado en la agenda tanto de las administraciones tributarias como de los contribuyentes. Los gobiernos necesitan asegurarse de que las rentas imponibles de las multinacionales no se desvían artificialmente fuera de sus jurisdicciones y de que la base imponible que declaran las multinacionales en sus respectivos países refleja la actividad económica efectuada en cada uno de ellos. Para los contribuyentes, es esencial limitar el riesgo de doble imposición económica que pueda tener su origen en una controversia entre dos países respecto de la determinación de la contraprestación de plena competencia correspondiente a sus operaciones internacionales con empresas asociadas.

Las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia recibieron la aprobación del Consejo en su versión original en 1995. En 2009 se llevó a cabo una pequeña actualización tendente básicamente a reflejar la adopción de un nuevo apartado 5 en el artículo 25 en la actualización del Modelo de Convenio Tributario de 2008 que trata sobre el arbitraje, así como los cambios efectuados en los Comentarios a dicho artículo 25 referidos a los procedimientos amistosos para la resolución de controversias fiscales de ámbito internacional. En la edición de 2010 se ha procedido a una importante revisión de los Capítulos I a III, en los que se ofrecen nuevas pautas para la selección del método de determinación de precios de transferencia más apropiado en función de la casuística, sobre la aplicación práctica de los métodos basados en el resultado de las operaciones (el método del margen neto operacional y el método de distribución del resultado) y el funcionamiento de los análisis de comparabilidad. Se ha añadido, además, un nuevo Capítulo IX que trata aquellos aspectos de las reestructuraciones empresariales que están relacionados con cuestiones de precios de transferencia. A lo largo de todas las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia se han efectuado cambios tendentes a dotarlas de coherencia.

www.oecd.org



ISBN: 978-84-8008-336-2



**Precio: 89 euros
(I.V.A. incluido)**